

ANAYASA HUKUKU I. DÖNEM

Yürürlükteki Hukuk: Belli bir dönemde belli bir toplumu düzenleyen hukuk kuralları. Yürürlükteki hukuk 2 yerden kaynaklanır. 1.Yazılı hukuk kurallarıdır ve buna mevzu hukuk, pozitif hukuk da denir. 2. Yazılı olmayan hukuk kuralları: örneğin 19. yy.'dan öncesine kadar yürürlükteki hukukun büyük bir bölümü yazılı olmayan geleneksel hukuktur. Bugünkü bildiğimiz biçimde anayasa diye yazılı bir hukuk metninin ortaya çıkması 18.yy dadır. İlki 1653 de İngiltere de hükümet aracı adı altında ortaya çıktı. İngiliz iç savaşından sonra, çok kısa (2 yıl) bir uygulaması oldu. Bugünkü anlamda anayasalar Amerika da 13 koloninin İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesiyle tek tek yazılı anayasa yaptılar, arkasından 1781 de ABD anayasası yazılmıştır.

1789 Fransız Devrimi İYHB 2 şeyden söz eder: bir anayasanın bugünkü anlamda yazılı bir anayasa olabilmesi için erkler, güçler ayrılığı (siyasal iktidarı sınırlaması) ve insan haklarını düzenlemesini tanıması gerekir. Anayasanın anlamı: Anayasanın ayırt edici özelliği, o hukuk düzeni içinde yer alan diğer hukuk kurallarının üzerinde yer almasıdır. Bir hukuk düzeninde farklı düzeylerde farklı derecede birden fazla hukuk kuralı vardır. O hukuk düzeninde hiçbir hukuk normunun anayasaya aykırı olmamasıdır.

Hukuki Pozitivizm: temel insan haklarına değer verip vermemesi, erkler ayrılığının olup olmaması önemli değildir. En önemlisi anayasanın bütün normların üzerinde yer alması ve her bir normunda anayasaya uygun olmasıdır. Buna anayasalı devlet denir.

Siyasal anlamı: Anayasanın işlevi ve amacıyla ilgilidir. Anayasa hangi amaca hizmet ediyor. Hangi işlevi yerine getiriyor. 1789 Bildirgesindeki işlev olan erkler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler olduğu zaman buna anayasa denir.

Anayasal devlet: Hukuk devletinde üstün olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan ve siyasal iktidarı çeşitli araçlarla sınırlayan devlettir. Bağımsız yargının olmadığı, siyasal iktidarın sınırlandırılmasından söz edilemez. Erklerin çeşitli araçlarla birbirini denetlemesi, bir erkin bir başka erk üzerinde aşırı güçlenmesinin engellenmesi yani denetleme ve dengelem sisteminin sağlanmasıdır. Böyle bir sistemi anayasasında öngördüyse o zaman bu anayasal devlet anlamına gelir.

Anayasa Hukuku: Siyasal iktidarı (1) kullanan devlet organlarının (2) (yasama, yürütme, yargı) kuruluşunu, işleyişini, görev ve yetkilerini ve bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri (3), siyasal iktidar karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini (4) düzenleyen disipline anayasa hukuk denir. Bu 4 unsur anayasa hukukunun konusunu oluşturur.

Anayasa hukukunun konusu: Yasama yürütme yargı organlarının kuruluşu işleyişi görev ve yetkileri, bu organlar arasında karşılıklı ilişki ve siyasal kurumlar, siyasal olaylar ve toplumun örgütlenmesi ve temel hak ve özgürlükler yer alır. Anayasa hukukunun konusuyla, anayasa metni birbiriyle özdeş değildir. Anayasa hukuk anayasa metnini inceliyor. Anayasa metnin de yer alan her düzenleme anayasa hukuku konusuyla ilgili olmayabilir. İlgili değilse anayasa hukukunun alanın dışında kalıyor. Örnek 1874 İsviçre anayasasında kasaplık hayvanların bayıltılmadan kesilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme var. 1999 da benzer düzenleme var. Anayasa konusunun içinde yer alan, ama anayasa metninin de düzenlenmeyen alanlar da vardır. Böyle bir durumda, anayasa hukuku, anayasanın dışında o alanı düzenlemiş diğer hukuk kaynaklarından da yararlanır. Diğer hukuk kaynakları da anayasa hukukunun konusu içinde yer alır. Bizim anayasamızda siyasi partilerle ilgili düzenleme mevcuttur. Ancak buna ilişkin ayrıntılar siyasal partiler kanununda yer alır.

Anayasa Hukukunun Yöntemleri: Hukuki Yöntem: 1.Yürürlükteki anayasa kurallarını inceler, açıklar ve bunları olaylarla karşılaştırır. 2. Olguları uygunluk açısından açıklamaya çalışır. 3. Bir hukuk kuralını olguya ve olaya uygular bu nedenle Tümden gelimcidir. 4. Kuraldan olaya gider ve kural olaya uygulanır. 5. Olması gerekeni inceler.

Siyaset Bilimi Yöntemi: 1. Siyasal iktidar ve devleti inceler, asli olan kamudur. 2. Tümevarımcıdır, yani olayları tek tek inceler. 3. Özel olgulardan bütüne varıp genel sonuçlar çıkarır. 4. Olguları illiyet açısından açıklamaya çalışır. 5. Olanı inceler.

Üretim: Bir toplumda, üretimin dışında kalan ancak üretimin yapılması ve sürdürülmesi için gerekli olan işlerin tümüne siyaset denir. Siyasal iktidarlar, toplumun farklı kesimlerine ait olan farklı çıkarların eşgüdümünde tutabilmek için baskı ve onay unsurunu aynı anda bünyesinde bulundurur.

Otorite: Hakimiyet ve emretme gücüdür. Kişinin yeterli olduğuna herkesi inandırması, kişi o alanda yeterli olduğuna ilişkin olarak başkalarında bir inancın, düşüncenin oluşması. Bu varsa orada otorite kurulmuş demektir.

İktidar: Başkalarının davranışlarını etkileyebilme ve kontrol edebilme yeteneğine verilen isimdir. Her otorite bir iktidar değildir ama her iktidar aynı zamanda bir otoritedir. İki tür otoriteden söz edilebilir. Meşru otorite: İlgili topluluk tarafından onaylanır, meşru görülür, hatta bu otorite toplumun genel olarak inançlarıyla uygundur ve hukuk düzeni tarafından tanınmış ve kurala bağlanmıştır. Örneğin anne babanın ergin olmayan çocuk üzerindeki otoritesi. Böyle otorite aynı zamanda iktidardır. Meşru olmayan otorite: Topluluk tarafından onaylanmayan, uyulması zorunlu kılınmayan hukuk tarafından düzenlenmemiş olan otoriteye verilen isimdir. Bilgiliilerin bilgisizler üzerindeki otoritesi. Bu tip otoriteler iktidar değildir. Bu otoriteye uymak zorunda değildir. Ne toplum ne de hukuk düzeni kişiyi bu otoriteye zorunlu kılmaz. Bu tip otoriteler iktidar ilişkisi içinde değillerdir.

Siyasal İktidar: diğer iktidar biçimlerinden ayıran özelliklerinden biri iktidarın bütün toplum üzerinde kullanılmasıdır. 2. Özellik belli bir coğrafi bölgenin ülkenin üzerinde kullanılan iktidardır. Diğer bir unsuru, baskı ve zor tekeline sahip olmalıdır. Yani kamu gücüne sahip olmalıdır. Bir diğer özelliği, yönetilenlerin siyasal iktidarın karşısında olanların o iktidara ilişkin rızası yani onayının olmasıdır.

Meşruluk: topluluk arasında iktidarın doğru ve haklı olduğuna dair bir inancın bulunmasına denir. Zor kullanma yetkisi bir yere kadardır. Toplumun belli bir kesiminin onayına dayanmak zorundadır. Seçimle gelirse meşruiyetin kaynağı demokratik olur. Siyasal iktidar çok yüksek bir meşruiyet iktidara gelebilir, zamanla meşruiyet düşebilir. Meşruluk ne kadar yüksekse bu siyasal iktidarın barış içerisinde yaşama olasılığı kadar yüksektir. Topluluğun büyük bölümü o iktidarın doğru ve haklı olduğuna inanmaktadır. Meşruluk ne kadar düşükse o siyasal iktidarın kullandığı zora baskıya dayanır. Baskıyla ne kadar tutabiliyorsa varlığını da o kadar devam ettirir. Bir toplumda ne kadar çok ayaklanma varsa o toplumda siyasal iktidarın meşruluğu düşüktür. Meşruluk o siyasal iktidarın barışçıl biçimde sürdürülebilmesi bakımından gereklidir. Siyasal iktidarı sınıflamada siyaset bilimi yöntemi kullanılır.

Max Weber in iktidar- otorite tipolojisi:

1. Geleneksel otorite: İktidar meşruluğunu yerleşik geleneklerden ve bu geleneklerin kutsallığına ilişkin inançtan alır. Bu otoritede yönetilenlerin yasaya değil kişiye boyun eğlerler. Otorite sahibin yetkilerinin sınırı belirsizdir, muğlaktır. Demokratik değildir. Örnek monarşik otorite, feodal otorite.

2. Hukuki Otorite: Yönetici emir verme gücünü akılcı ve toplumun bütün üyelerine uygulanan herkes için bağlayıcı olan kurallardan alır. İktidara itaat etme, iktidarın hukuka uygun olarak kullanıldığı inancından kaynaklanır. Yönetilenler, kişiye değil o kişinin işgal ettiği makama itaat ederler. Yöneticilerin yetkilerinin sınırları bellidir, muğlak değildir. Demokratik yönetimlerde yöneticilerin otoriteleri hukuki otorite niteliğindedir.

3. Karizmatik otorite: Liderde kutsallık kahramanlık ya da örnek alınacak bir kişilik görüldüğü için onun yarattığı düzene uyulur. Karizmatik olduğuna inanılan kişide bu özelliklerin olup olmaması önemli değildir. Önemli olan toplumun bir bölümünde o kişide yukarıdaki özelliklerden birinin veya birkaçının olduğuna inanılmasıdır. Bu kişilerin yaşamlarıyla sınırlıdır. Kalıcı değildir. Meşruluğunu karizmasından alıyor, hukuktan almaz ve orada bulunduğu süreyle sınırlıdır. Ölene kadar veya o makamda kalıncaya kadardır.

David Easton'ın meşruluğun kaynağına ilişkin tipolojisi:

1.İdeolojik Kaynak: Yönetilenler, rejimin temelinde yatan değerleri araçları ilkeleri benimser ve onun doğruluğuna ve gerekliliğine inanır. Kişi yok hukuk da yok. Sadece rejimin ideolojisi var. Bu ideolojinin dayandığı değerler araçlar ve ilkeler var. Bunların doğruluğuna gerçekliğine inanılır ve siyasal iktidar da meşruluğunu bu ideolojiden alıyor. SSCB.

2. Yapısal Kaynak: Siyasal yapı ve onun işleyişini düzenleyen normların yönetilenler tarafından geçerli kabul edilmesi hukuk düzeninin meşruluğu. Weber in hukuki otoritesine benziyor. Siyasal iktidar, devletin anayasasına ve diğer pozitif hukuk kurallarına uygun olarak yönetiyorsa o siyasal iktidar meşruluk kaynağı yapısal kaynaktır.

3. Liderin Kişisel Niteliklerine Dayanan Kaynak: Weber in karizmatik otoritesi değildir. Easton'a göre toplumsal desteği kazanmada bir lider etkili ve başarılı ise o zaman meşruluk kaynağı liderin kişisel niteliğine dayalıdır. Burada liderin kutsal özel veya olağandışı bir özelliğe sahip olması beklenmiyor. Beklenen liderin kendi toplumsal desteğini edinmek konusunda etkili ve başarılı olmasıdır. Bunu sağlıyorsa o zaman

meşruluğun kaynağı o kişisel niteliğidir. Siyasal iktidarın en üstünde bulunan devlet başkanları için değil alt kademelerinde bulunan liderler de kaliteliyse aynı zamanda yetenekliyse onların yöneteceği yönetimde toplumun rejime bağlılığını arttırıyor. Weber in karizmatik otoritesinden daha kapsayıcıdır. Weber in tipolojisine sokamadığımız her türlü siyasal iktidar biçimlerini bu liderin kişisel niteliklerine dayalı kaynağa sokuyoruz.

Siyasal Sistem: Her devlet o topluma dayanmak zorunda ve o toplumdan kaynaklanmak zorunda. Yani devletin biçimi, araçları, ideolojisi görevlileri o toplumdan kaynaklanır. İşte devletin, toplumla kurduğu bu sıkı ilişkiler ağına siyasal sistem denir.

Siyasal Düzen: Toplumun tümünün siyasete etkisi açısından ele alınması anlamına gelir. Toplumun bir bütün olarak siyasete etki etmesinin ele alınmasına denir.

Devlet: Belli bir insan topluluğunun belli bir toprak üzerinde egemen olmasıyla oluşan hukuki kişiliğe sahip sürekli bir örgüte verilen isim. Devletin unsurları: bir toprak parçası, insan topluluğu, kendine ait hukuki bir kişiliğinin olması, egemenlik, sürekli bir örgütlenme. Toprak parçası: Ülke olarak adlandırılır. Her devletin bir ülkesi olmalıdır. Devletin bir kara sınırının olmasıdır. Bu sınırlar burjuvazinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıktı. Burjuvazinin, ticaret yapacağı alanı genişletme ihtiyacından sınır kavramı açığa çıktı. 2. Dışarıda kendisiyle aynı ürünü üretenle rekabet etmeme isteği, gümrük vergilerinin konulma isteği. 3. O dönemde devletin nitelikli işgücünün yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı. Bunun için coğrafi sınırların olması gerekiyordu. Kara parçası bir devletin olmazsa olmaz şartı: sürekli olarak su üzerinde bulunmasıdır. 3 Boyutludur: yerin altı, hava sahası, yerin üstü. Hava sahası: Her ülkenin hava sahası olmak zorunda değildir. Uluslararası hukukta belli bir kural yoktur. Bazı ülkeler, kendilerine göre hava sahası mesafesi belirlemişlerdir. Kıta sahanlığı veya kara suları: Devletin kara sınırının bitip suyun başladığı noktadan denize doğru belli bir mil içindeki bölgeye devletin kara suyu denir. Bu günümüzdeki uluslararası hukuka göre 12 mildir. İki devletin birbirine çok yakın olduğu noktada bu 6 mile iner. Kara sularında devlet kararı ile aynı hukuki değere sahiptir. Kara suları da 3 boyutludur. Denizin altı, denizin üstü, hava sahanlığı da o devletin ülke sınırlarında yer alır. Kara sularından sonra 200 mile kadar, başka devletlerle ortak kullanılabilen ekonomik münhasır bölge vardır. O bölgedeki devletin yurttaşları, balıkçılık faaliyetlerinde, başka ekonomik faaliyetlerde de bulunabilir. Ondan sonra açık deniz olup kimseye ait değildir. Devletin, üzerinde egemenliğini kullanabileceği insan topluluğunun olması gereklidir. İnsan topluluğunun ulusa dayanmasının 2 farklı anlayışı olabilir. 1.Nesnel Ulus 2. Öznel Ulus anlayışı

Nesnel ulus anlayışı: Alman ulus anlayışı olarak tanımlanır. Alman birliğinin yaratılması bakımından bir katkı sağlıyor. Devletin üzerinde egemenlik kurduğu insan topluluğunu ulus olarak tanımlayabilmek için kan bağı, etnik köken, dil ya da din gibi nesnel ölçütler kullanılır. Bu anlayışın özellikleri 1. Saldırgan bir vatanseverlik var (şovenizm). 2. İrredentizm'e dayanır. Egemenliği altında yaşayan ulusun bazı üyelerinin başka devletlerin egemenliği altında yaşamaları durumunda, bu millet anlayışına sahip devletin, o toprakları kendi toprağına katması veya katmak istemesi siyasetidir. Bu 2 unsur, nesnel ulus anlayışının 2 siyasal ayağıdır. Nesnel ulus anlayışına sahip devlet, bu özellikleri taşımayan kendi egemenliği altında yaşamayan topluluklardan da kurtulmayı amaçlar. Kırım, sürgün, soykırım bu anlayışa sahip devletin uyguladığı politikalarıdır. Amaç türdeş bir ulus yaratmaktır. Hitler, germen ırkından gelen, Almanca konuşan ve Hristiyan olan etnik köken din ve dil birliğine dayalı bir ulus örneğidir.

Öznel (Sübjektif) ulus anlayışı: Mimarisi Fransız Ernest Rena'dır. Bir topluluğu, ulus olarak adlandırabilmek için, o ulusu oluşturan bireyler, bir arada yaşama isteğine sahip olmalıdır. Bunun temelinde geçmişin manevi mirası anılara bağlılık, ortak tehlike ve tehditlerle karşılaşmak bunlarla birlikte mücadele etmek gelecek için birlikte tutum belirlenmesi gibi unsurlar yer alır. Ulusun bir ruh bir de manevi ilkesi vardır. Ruhi ilke geçmişe ilişkin manevi ilke günümüze ilişkindir. Geçmişe ilişkin demek, topluluğun üyelerinin geçmişte yaşama, her türlü iyi ve kötü şeyleri birlikte kabullenmesi. Bugüne ilişkin manevi ilke ise topluluk üyelerinin birlikte yaşama isteğine karşılık geliyor, geleceğe ilişkin birlikte hayal kurmaktır. Ortak geçmiş, hatıra, amaç, ideal, gelecek, ülkü birliği

Şovenizm: Saldırgan vatanseverlik ve bir ulusun kendini başka uluslardan üstün ayrıcalıklı görme anlayışına denir.

İrredentizm: Kendi etnik grubunun yaşadığı başka bir devletin egemenliğindeki toprakları kendi topraklarına katma siyasetidir. Etnik grup: Üyeleri bir kökeni paylaşan, tarihi kültürel ve bölgesel bağlara sahip siyasal bir talebi olmayan insan topluluğuna denir. Kendi kendini yönetme talebinin olmaması gereklidir. **Ulus:** ortak bir

kültürü paylaşan sınırları tartışma yaratmayacak biçimde belirlenmiş bir toprağa bağlı ortak bir gelecek projesiyle kendini yönetme bilincine sahip insan topluluğudur. Milliyet: Ulusun özelliklerine sahip olan ama devleti bulunmayan vatandaşlık bağı bulunmayan soy bağına dayalı olan topluluklara verilen isimdir.

Ulus Devlet: Sınırları belirlenmiş, bir toprak parçası üzerinde yasal güç kullanma tekeline sahip belli bir ulusa dayanan devlete verilen isim. En önemli özelliği, bir türdeşlik yaratmasıdır. Dil bakımından türdeşlik olup resmi dilde. Yasalar bakımından, o devletin sınırları içerisinde herkese uygulanabilen aynı yasaların geçerli olmasıdır. Yine türdeşliğin bir sonucu ulus devlette, yargılama tekelidir. Yine ölçüde türdeşlik, yani o devlet sınırları içinde her türlü konuda herkesin aynı kurallara bağlı tutulması anlamına gelir. Eşitlik denildiğinde, yasa yapma sürecinde herkesin temsilcileri aracılığı ile bulunması anlaşılır. Kardeşlik boyutu, gelecekte bir arada yaşama isteği amacı anlamına gelir. Siyasal bütünlük.

Milliyet: Ulusun özelliklerine sahip. Devleti yok. Vatandaşlık bağı değil, soy bağı önemli

Meşru ulus devlet: Belli bir ulusa dayanmış devlet, ulusu olan devlet. Gayrimeşru ulus devlet: belli bir ulusa dayanmayan ulusun devletin oluşumundan sonra yaratıldığı devlet anlamına gelir.

Ulussuz devletler: devletin kuruluş süresinde belli bir ulusa dayanmaması, devletin kurulduktan sonradan ulusun yaratılması, Afrika devletleri.

Devletçi ya da çoğunlukçu ulusçulukta: Devletin içinde tek bir ulus var ya da diğer azınlık uluslar bu çoğunluk olan ulus tarafından asimile edilmiş demektir.

Azınlıkçı ya da çevreci ulusçulukta: Devletin kurulma aşamasında birden fazla ulusun olması gibi, Belçika örneği. Devletsiz uluslara örnek: Katalanlar, İskoçlar, Galler

Devleti, diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi onun kendine özgü bir hukuki kişiliğe sahip olmasıdır. Hukuki kişilik: gerçek kişilik ve kamu tüzel kişiliği. Hukuki kişiliğe sahip olan hem hakka sahip olur hem de yükümlülüğe hem de davalarda taraf olur. Hukuki kişilik, siyasal iktidarın kişiselleşmesini önlemeyi amaçlayan bir araçtır. Devlete hukuki kişilik verilince o iktidarın devlet gücünü kullananların o iktidarı kişiselleştirmesini önliyoruz. Bunun sonucunda, devlet adına işlem yapan yöneticiler o işlerin sonucunu kendi hesaplarına yazmazlar. Devletin hesabına yazarlar. Devlet adına borçlanan bir yönetici var ise bu borç devletin hanesine yazılır. Devlet ile devlet iktidarını kullanan erk ile yönetici arasında bir ayrılık oluşturulur. Böylelikle iktidarın kişiselleşmesi önlenmiş olur. Devlet kurumsallaşmış bir siyasal iktidardır. Devlet denilince idare anlaşılır 1. Merkezi yönetim (CB, Bakanlıklar) 2. Yerel yönetim (Belediyeler, köyler, il özel idareler). Devletin varlığının sürekli olması: devlet adına yapılan işlemlerin o işlemleri yapan kamu görevlisi görevden ayrılmış olsa bile, yürürlükte kalmaya devam etmesidir. İdari işleri yapan kamu görevlileri o görevden ayrılrsa bile o yapılan işlem yürürlükte kalmaya devam eder.

John Boden: 1. Egemen güç hukuki bir güçtür. Yani devletin kökeni güç ve şiddete dayanır. Devleti, korsanlarda ayrılan özellik, devletin her zaman doğruluğu, adaleti içermesidir.

2. Egemenlik asli bir güçtür. Egemenlik, başka bir güçten ya da otoriteden kaynaklanmaz.

3. Egemenlik, Boden e göre mutlak bir iktidardır. Yasa yapma yetkisi yalnızca egemene ait bir yetkidir. Egemenin, kendisinden önce yapılmış olan ya da kendisinin yaptığı bir yasayla kendisini bağlı saymamasıdır. Buna uymak zorunda değildir.

4. Egemen, egemenliğini kullanırken kendisinden daha yüksek bir iktidara bağlı değil.

5. Egemenlik sürekli bir iktidardır. Gelip geçici değildir. Egemenlik, sürekli bir unsurdur. Egemenlik, herhangi bir güçten kaynaklanmaması, herhangi bir kişiden yasadan kaynaklanmaması anlamına geliyor. Boden'e göre egemenliğin bazı sınırları vardır. Bu sınırlar, doğa ve ilahi yasalardır, bunlara uymak zorundadır. Çünkü egemenlik, doğruluk ve adalete dayanır. Boden'in bu kuramının anayasalarımızdaki sonucu: siyasal iktidarın kişiselleşmesini önlemesidir.

Hobbes: 1.Egemenlikten vazgeçilmez. Egemen de egemenlikten vazgeçemez. 2. Egemen güç mutlaklıktır. Yani kendi üzerinde bir güç tanımıyor. 3. Aynı zamanda egemenlik devredilmez ve bölünmez bir nitelik taşıyor. 4. Egemenlik kuramı, mutlakiyetçi monarşi anlayışına dayalıdır. Bu ikisinin ortak yönü: egemenliği, mutlak egemenlik anlayışı olarak görürler.

Egemenlik:

1. İç Egemenlik: Ülke sınırları içinde egemenliğin hukuk düzenini belirleyen üstün irade, kuralları koyma yetkisi, kuralları uygulama yetkisi, uygulanan kurallar sonucunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözme yetkisi. Her üç yetki de kullanılırken bir egemenlik yetkisi kullanılmış olur. Yasama, yürütme yargı yetkileri demek ki egemenliğin kullanıldığı yetkilere. Bu yetkiler egemenliğin içeriğine işaret eder. Egemenliğin üstün, sınırsız, bölünmez parçalanmaz sürekli olması gibi bazı niteliklerini açıklar. Bu egemenliğin niteliklerini açıklayan yönüdür.

2. Dış Egemenlik: Devletin egemen eşitliği, **1)** devletin diğer devletlerle eşit statüde olması, eşit ilişki içinde olması **2)** Başka devletlerin iç işlerine karışmaması, bir devletin başka bir devletin iç egemenliğine mutlak bir şekilde karışmaması anlamına gelir.

İstisnalar: II. Dünya savaşından sonra insan hakları devletlerin iç egemenlik olmasından çıktı. Dış egemenlik, her devletin mutlak bir biçimde her devletin başka bir devletin iç işlerine karışmaması anlamına gelmiyor. İstisna, insani müdahaledir. Bir devletin kendi ülke sınırları içinde yaşayan kişilerin yaşam hakkını ağır ve sistematik bir şekilde ihlal ediyorsa diğer devletler bu ihlali ortadan kaldırmak amacıyla o devlete müdahale edebilirler. Örnek: Bosna, 1999 Kosova, Ruanda Bu sadece askeri bakımdan müdahale anlamına gelmiyor. Bu insani müdahale yetkisi, devletin yargılama tekeline de istisna getiriyor. 1998 Tarihli Roma Sözleşmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin koyduğu soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlemiş devletlerin, bu devletlerde bu suça karışmış kişileri yargılama yetkisine sahip. 1982 Anayasasının 38.maddesi Uluslararası Ceza Mah. atf yapıyor ama uygulanabilme kabiliyeti yok. Dış egemenlik anlayışındaki, o mutlak üstün egemenlik anlayışının dış egemenlik bakımından insani müdahaleyle sınırlı olduğunu görüyoruz. İnsan hakları kuruluşları, AIHM, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan insan hakları komiteleri, IMF, Dünya Bankası gibi uluslar üstü kuruluşlar var. Mutlak bağımsızlık bir devlet günümüzde yoktur. Klasik egemenlik anlayışı, dış egemenlik bakımından günümüzde geçerli değildir. Devletin egemen eşitliği ilkesi Filistin devleti bakımından geçerli ama iç egemenliği iç egemenliği yok. Görüntüde bağımsız, herkes tanıyor ama bağımsızlığı yok. Uluslararası hukukta Filistin gibi devletlere, sahte devlet denir. De facto devletler, başka devletler tarafından tanınmayan ama iç egemenliği tam olan devlettir. KKTC. Dış devletlerle eşit ilişki söz konusu değil ama iç egemenliği var. Güney Osetya, Abhazya

İç egemenlik denilince 2 şey anlaşılır: **1.** Egemenliğin niteliği, bu egemenlik tek mi, sürekli mi, bölünebilir mi niteliklerini belirtiyor. **2.** Egemenliğin yetkileri, sınırı, egemenliğin kullanılabileceği 3 temel yetki var. Egemenliğin kullanılabileceği yasama, yürütme ve yargılama yetkileri. Egemenliğin kaynağı 2 tanedir. Egemenlik kime aittir buna cevap verir. **1.** Teokratik Egemenlik kuramında, egemenlik tanrıya aittir, kaynağı ilahidir. **2.** Demokratik egemenlik kuramında, egemenlik halka aittir. Kaynağı dünyevidir.

1.Teokratik Egemenlik Kuramları: Her ikisinde de egemenliğin kaynağı tanrıdır.

A) Doğaüstü ilahi hukuk öğretisi: Tanrı, yeryüzünde onun adına egemenliği kimin kullanacağına kendisi karar veriyor, bizzat seçiyor. Bizzat Tanrı tarafından, onun egemenliğini sürekli olarak yeryüzünde kullanması için seçilmiş kişi kraldır. Kralın, yönettiği kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Yöneticiye boyun eğme, onun yönetimine rıza gösterme, aynı zamanda dini bir buyruktur. Bu nedenle krallar “Tanrı Kral” olarak tanımlanırlar.

B) Providansiyel hukuk öğretisi: Egemenliğin kaynağı tanrıdır. Egemenliği, kullanacak kişileri bizzat kendisi doğrudan seçmez. Yeryüzünde oluşan insani ve doğa olayları tanrının eliyle gerçekleşir. Bu olayların sonucunda seçilmiş olan kişi, tanrının egemenliğini kullanacak kişidir. D’Aquin St. Thomas bu öğretinin sahibidir. Yeryüzündeki egemenliğin tümü tanrıya aittir ve bu egemenlik, halk aracılığı ile verilir. halk aracılığı ile verilir. Yani seçimlerle iktidara gelmesi mümkündür. Doğaüstü hukuk öğretisine göre daha dünyevidir.

Ulus egemenliği anlayışı: **1. Soyut bir varlıktır.** Belli bir dönemde belli bir devletin ülkesi içinde yaşayanlar, daha önce yaşamış olanlar ve gelecekte yaşayanları da kapsar.

2. Seçmenlik ödevdir. Soyut bir varlık olduğu için, ulus egemenliğini kendisi doğrudan kullanamaz Bu sebeple temsilciye ihtiyaçları vardır.

3. Seçmenlik görevi ulusun iradesini açıklaya en yetkili olana verilir. Temsili demokrasiye dayanır. Bu temsilcileri seçmek veya temsilci olmak bir hak değil bir ödevdir. Ödev olmanın sonucunda 2 sonuç oluşur:

Seimlerde oy kullanmak zorunludur. Hak olsaydı, oy kullanmak isteęe baęlı olurdu. Dięer sonucu, bu önemli görevi sıradan kiřiler deęil, bu iři yapabilme kabiliyetinde olan kiřiler yapacak hem semen hem de seilme anlamında. Ulus egemenliğinde baştan itibaren herkesin oy kullanması esasına dayalı genel oy ilkesini yatsır, sınırlı oy ilkesini kabul eder.

4. Temsili demokrasi: Temsilci seildi mi artık bütün ulusu temsil eder. Temsilci kendisini seenleri deęil bütün ulusu temsil eder.

5. Bunun pratik sonucu kendisini seenlerin, temsilciye belli bir konuda emir ya da talimat vermesi mümkün deęildir. Ulusun temsilcisidir. Emredici vekaleti yasaklar. Semen kendisini temsil etmek üzere setięi temsilciyi görevden alamamasıdır. Bu yetki varsa bunu yapacaęı oylama ile temsilciyi görevden alır.

6. Egemenlik güçler ayrılığı yoluyla bölünebilir. Yasama, yürütme, yargı erklerinin ayrı ellere verilmesi ulus egemenliği anlayışıyla baędařır. Fransız İYHB ve 1761 Fransız anayasasının ulusal egemenliğe ve ulusal egemenliğin niteliğine ilişkin düzenlemeleri bunlardır. Egemenlik ulusa aittir. Egemenlik tek ve bölünemez, devredilemez ve zaman aşımına uğramaz. Ulus egemenliği temsilciler yoluyla kullanır. Temsilciler bütün ulusu temsil eder. Ulusal egemenlik Fransız halkına aittir. 1789 Bildirgesi: egemenlik bölünmez, devredilmez, ve zaman aşımına uğramaz, ulusa aittir. Halkın hiçbir zümresi hiçbir birey açıka millettten kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz.

Halk Egemenliği: J.J. Rousseau, Toplum sözleşmesi adlı eserinde halk egemenliği anlayışını ortaya koymuřtur. **1.** Halkı oluřturan her bir birey egemenliğin bir parasına eřit miktarda sahiptir. Herkes egemenliğe eřit sahipse halkın egemenliği kullanması mümkündür. Bunun için ulusal egemenlikteki gibi bir aracıya bir temsilciye ihtiyaı yoktur.

2. Halkın tümü egemenliğin bir parasına sahip olduęuna göre artık seimlerde oy kullanmak bir görev deęil bir haktır. Dilerse bu hakkı kullanır dilemezse kullanmaz.

3. Ulus egemenliği anlayışından farklı olarak halk egemenliğinde genel oy ilkesi geçerlidir.

4. Halkın iradesi temsil edilemez.

5. Halk egemenliği emredici vekalet anlayışına dayanır. Yani halk adına bu egemenliği kullanacak olan halkın hizmetlisi olan görevlilere onu seen semen istedięi gibi emir verebilir. Bu yasaya evet veya hayır de gibi. Temsilci bu talimata uymak zorundadır. Eęer uymazsa semenler bu temsilciyi yapacakları bir halk oylaması ile görevden alabilirler. Buna emredici vekalet anlayışı denir.

6. Egemenlik bölünemez, halk egemenliği anlayışı, yasa yapma yetkisini genel iradenin dıřında bařka bir irade paylaşmaz, sadece genel irade yasa yapma yetkisini kullanabilir. Yasa yapma yetisinin birden fazla ele verilmemesidir. Yasa yapma yetkisi sadece parlamentoda olmalıdır. Son ařamada yapacaęı kanunların halk tarafında onaylanması řartı vardır. Yani parlamento, millet adına yasa yapma yetiř konusunda mutlak yetiye sahip deęildir. Kabul edilen bütün yasalar halk oylaması ile halkın oyuna sunulması gerekir. Halk egemenliği anlayışı, halk oylaması halk vetosu gibi doęrudan ya da yarı doęrudan demokrasi araçlarıyla uyumludur. Ulus egemenliği bu anlayışı dıřlar. Çünkü temsil esasına dayanır. Halkın egemenliği, belli bir parasına herkesin sahip olduęunu varsayılır.

İki anlayışın kaynařtığı nokta: Özellikle temsili demokrasi ile birlikte halk oylaması halk giriřimi halk vetosu gibi yarı doęrudan demokrasi yöntemlerinde benimsenmesi esasına dayanmasıdır. Artık bugün sınırlı oy ilkesi kabul edildięi bir demokratik devlet yok. Genel oy ilkesi ve semenin ve seilmenin bir hak olduęu bugünkü demokrasi anlayışının temelini oluřturur. Bu nedenle 2 egemenlik anlayışı iç içe girmiřtir diyebiliriz.

Bu iki řahsiyetin egemenlik anlayışları, günümüz demokrasilerine ve günümüz devlet yapısına uymuyor.

1. Günümüz devletleri oklu tüzel kiřilięe sahip, devlet tüzel kiřilięinin yanında ok sayıda kamu tüzel kiřilikleri de var Klasik devlet egemenlik anlayışı oklu tüzel kiřilikle baędařmaz.

2. Günümüz uluslararası devletler hukukunda, dıř egemenlik bakımında devletlerin eřitlik ilkesi vardır. Oysa ki klasik egemenlik anlayışı, kendisi üzerinde kendisine eřit herhangi bir güç tanımıyor. Günümüzde başta insan hakları olmak üzere ama pek ok konuda devletler ya da ulusal üstü kurumlar uluslararası sözleşmeler yapıyorlar. Devletler, bu sözleşmelerin tarafı ve bu tarafı olduęu sözleşme hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Uluslararası hukuk bu durumda devletleri baęlıyor. İnsan hakları, devletlerin bir iç meselesi olmaktan ıktı. Ulusal üstü bir meseledir artık. Bu da mutlak hesap vermez kendi iç işlerine hiçbir řekilde karışılmaz devlet klasik egemenlik anlayışının yerinin kalmadıęını bize gösteren bir konudur. IMF, Dünya

Bankası gibi pek çok ulusal üstü kurumda, devletler ekonomik olarak karşılıklı bir bağımlılık içerisindeyler. Hiçbir devlet günümüzde Hobbes ya da Bodin'in tanımı çerçevesinde mutlak bir egemenlik sahibi değildir.

Çoğunlukçu Demokrasi: Seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi parti ya da partilerin ülkeyi yönetme hakkı olduğu, azınlık kesimin de kendi hak ve özgürlüklerini koruma ve bu hak ve özgürlükleri çoğunlukçu parti ya da partilerin yapmış olduğu yasalara uygun olup olmadığına ilişkin yargısal denetim hakkının olduğu demokrasi anlayışıdır.

Maddi anlamda anayasa: O hukuki işlemin konusuna bakarak tanımlamak demektir. Anayasanın içeriği, anayasal normların konusu göz önünde bulundurularak tanımlanan maddi anlamda anayasa; devlet organlarının kuruluşu işleyişi görev ve yetkileri, temel hak ve özgürlük konuları hangi hukuki işlemle düzenlenirse düzenlensin maddi anlamda anayasa anlamına gelir. Parlamentonun iç işleyişini iç tüzük düzenler ve bu maddi anlamda anayasadır. Seçim kanunları da parlamentonun kuruluşuna ilişkin hükümleri düzenlediği için maddi anlamda anayasadır. İster kanun, iç tüzük, yönetmelik olsun bu konular da yapılan düzenlemelerin bütünü maddi anlamda anayasadır. Maddi anayasa yazılı da olabilir geleneksel bir anayasa hükmü de olabilir.

Şekli anlamda anayasa: Şekli açıdan ise, Anayasanın yapılışı, ortaya çıkış usulleri ve yapan organ göz önünde bulundurulur. O hukuki işlemi kim hangi organ yapmış, hangi usule dayalı olarak yapmış, hangi biçimde yapıldığının göz önünde bulundurularak tanımlanmasıdır. Anayasa hukukuna giren konularının anayasa adı altında bir metnin yapılmasıdır. Şekli anlamda anayasa, her zaman yazılı olan anayasadır. Maddi ve şekli anayasalar kural olarak bir arada bulunurlar. Şekli anayasa hükümleri maddi anayasa konularını içerir. Devletin, hükümetin şekli, devlet organları, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir düzenleme yasayla yapıldı ise ve bu düzenleme anayasa adı altında bir metinde düzenlenmediyse bu düzenleme şekli anlamda değil maddi anlamda anayasanın içindedir. Şekli anayasanın içinde Anayasa Hukuku konusu olmayan yani maddi anlamda anayasa olarak nitelendirilemeyecek düzenlemeler de olabilir. Maddi anlamda anayasa ile şekli anayasa her zaman birbiriyle örtüşmeyebilir. 1999 İsviçre Anayasasındaki kasaplık hayvanların bayıltılmadan kesilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme. Maddi anlamda anayasa hükmü şekli anayasa hükmü olabilir. Fransa da, seçim sistemi şekli anayasanın içinde yer almaz ama maddi anayasanın içindedir. Türkiye de seçimle ilgili düzenlemeler maddi anlamda anayasa hükmü içindedir. Bu konular anayasada yer almadığından şekli anlamda anayasa değildir.

Katı, sert, bükülmez anayasa: Olağan yasalardan daha zor ve farklı usullerle yapılan ve değiştirilen şekli anayasaya verilen isimdir. Katı anayasa aynı zamanda şekli anayasadır. Şekli anayasa yazılı olmak zorundadır. Günümüzdeki anayasaların büyük çoğunluğu katıdır. İlk katı anayasa 1787 ABD anayasasıdır. ABD, İsviçre, Danimarka, Rusya, Arjantin örnektir. Olağan yasalar basit çoğunlukla kabul edilir.

1. Anayasayı kabul için aranan çoğunluk farklı olabilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğu nitelikli çoğunluktur. Bir anayasa değişikliği için bu çoğunluk aranıyorsa, bir anayasa değişikliği için üye tam sayısının en az 3/5 ini arayan anayasa bu anayasaya göre daha az katı bir anayasadır. Anayasanın kabulündeki nitelikli çoğunluk o anayasanın katılık derecesini belirliyor. 1921 anayasası dışındaki 1876 Kanuni Esasiye de dahil anayasalarımız katı anayasadır. Her anayasanın katılığı ve sertliği bir değildir.

2. Bir anayasada değişmez maddeler var ise değişmez madde içermeyen anayasaya göre o anayasa daha katı bir anayasadır. Anayasanın değiştirilmez madde içermesi o anayasanın katılığını artırır.

3. Anayasaya onay koşulu getirilmesi: kabul aşamasının yanı sıra onunla birlikte onay aşamasının getirilmesi o anayasanın katılığını artırır. 1921-1924 Anayasaları onay aşamasını öngörmemiştir. Bun a karşılık 1982 anayasasında 3/5 ile kabul eder. Halk oylamasına sunulmak zorunda olduğundan, geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan anayasa yürürlüğe girer. 1982 Anayasası CB ve halk oylaması aracılığı ile bir de onay aşamasını öngörmüştür. 1982 Anayasası bu bakımdan 1961-1924 anayasalarına göre daha katıdır. Aranan kabul çoğunluğu bakımından 3/5 ile yetindiği için daha az katı bir anayasadır. Dünyadaki en katı anayasa ABD dedir.

4. Bir anayasanın daha katı bir anayasa olduğunu gösteren diğer bir durum ise, sadece bu iş için kurucu meclis tarafından yapılıyor olmasıdır. Böyle kurucu meclis tarafından yapılacağına dair özel bir hüküm varsa bu da anayasanın katılığını artırır. Parlamentonu değil kurucu meclisin seçilerek o meclise bu yetkinin verilmesi işin katılığını artırır. Örnek İspanya anayasası.

Esnek anayasa: Olağan yasalarla aynı usullere bağlı kalınarak değiştirilen anayasaya verilen isimdir. Aynı usuller aynı esaslar aynı kabul çoğunluğu olağan bir yasa basit bir çoğunlukla kabul ediliyorsa anayasa değişiklikleri de basit çoğunlukla kabul ediliyor demektir. Katı anayasada saydığımız 4 hususun hiçbiri yumuşak anayasada aranmıyor demektir. Bizim anayasalarımız içinde tek esnek anayasamız 1921 anayasasıdır. 1848 İtalya anayasası, Yeni Zelanda anayasası.

Yazılı anayasa: Maddi anlamda yer alan hususların yazılı belgede yer aldığı anayasalara yazılı anayasa denir. 18. Yy sonlarından bu yana olan bütün anayasalar yazılı anayasadır. Yazılı anayasalar tek bir metin yerine birden çok metinden oluşabilir. Örnek: Bir devletin birden fazla yazılı anayasası olabilir. İsrail anayasası 11 temel yasa İsveç anayasası 4 yasanın toplamından oluşmaktadır. Tarihteki ilk yazılı anayasa 1653-1657 yılları arasında İngiltere de yürürlükte kalmış olan “Hükümet Aracı” metnidir. Yazılı anayasa gücünü, onu yapan organdan alır, kurucu meclis parlamento.

Geleneksel anayasa: anayasa konularının yazılı bir metinde toplanmadığı anayasadır. Geleneksel anayasa ise zaman içinde toplumda sürekli olarak yinelenen davranışlar sonucunda bu davranış biçimine uyulmasının zorunlu olduğu kanısının yerleşmesiyle ortaya çıkar. **Örf ve adet normunun 3 temel unsuru vardır.**

Maddi unsuru: uzunca bir süre bir davranışın yinelenmesidir. **Manevi unsuru:** toplumda o davranışa uyulmasının zorunlu olduğuna ilişkin bir kanının yerleşmiş olmasıdır. **Hukukilik unsuru:** anlaşmazlık çıktığı zaman başta yargı olmak üzere hem yargı hem de yürütme organının o normu uygulamak zorunda olması, norma uyulmasını yaptırma bağlanmasıdır. 18.yy a kadar hukuk kuralları geleneksel hukuk kurallarıydı. Birleşik krallık geleneksel anayasa normlarını bünyesinde yürürlükteydi. 1707’den beri Kral ya da kraliçe parlamentonun kabul ettiği yasayı veto etme yetkisini kullanmıyor. İngiltere de hem yazılı hem de geleneksel anayasa uygulanmaktadır. Aynı konuyu yazılı anayasa kuralı ve teamüli anayasa kuralı düzenliyorsa yazılı anayasa kuralı uygulanır. O zaman teamüli anayasa ne işe yarar? 1. Anayasada o konuya ilişkin bir düzenleme yoksa ama bir geleneksel bir anayasa kuralı varsa o zaman anayasanın düzenlemediği konuyu ya da alanı geleneksel anayasa kuralı tamamlar. 2. Anayasanın yorumlanmasında ve uygulanmasında yardımcılık işlevi görür. 3. Aynı konuyu her iki anayasa da düzenliyor ise teamüli anayasa daha önce düzenlenmiş olsa bile geleneksel anayasa kuralı yazılı anayasa kuralını değiştiremez.

Ferman anayasa: Monarkın tek yanlı iradesiyle yapılan anayasaya denir. 1848 İtalya-1876 Osmanlı AY.

Misak anayasası: Monarkla birlikte onun iradesinin karşısında ona kendini kabul ettirebilen ve monarkın iradesine eklenen bir meclis ya da organın ortak iradesiyle yapılan anayasaya denir. 1850 Fransız ve Prusya

Çerçeve anayasa: anayasa konularını ana hatlarıyla düzenleyen, ayrıntılı biçimde düzenlemeyen, anayasa hükümlerinin uygulanmasında yasama ve yargı organlarına geniş takdir alanı bırakan anayasaya verilen isimdir. Çerçeve anayasa kısalık uzunluk ile ilgili olmayıp içerik ile ilgilidir. 1921 Anayasası 23+1 madde, 1924 Anayasası 105 madde.

Olumlu yönü: Kaziistik anayasanın olumsuz yönüdür. Çerçeve anayasa ele aldığı konuyu genel hatlarıyla ele aldığı ve detaylı inceleme yapmadığı için siyasal, toplumsal, teknolojik gelişmelere ayak uydurması daha kolay olur. Anayasada ne kadar genel bir düzenleme yapılırsa yasama veya yargı organı o alanda ortaya çıkacak yeni gelişmeler izlenebilir, bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulmadan o alan düzenlenebilir. Anayasanın yeni gelişmelere adaptasyonu sağlanabilir. 18.yy da ortaya çıkan ABD anayasası kısa ve çerçeve bir anayasadır. 7 maddeden oluşur, sonradan 27 madde ek düzenlenmiştir. Bu anayasa çerçeve bir anayasa olduğundan o zamandan günümüze kadar ki olaylara ayak uydurmayı başarmış olan yaşayan en eski anayasa olarak bilinmektedir.

Olumsuz yönü: Kaziistik anayasanın olumlu yönüne denk gelir. Hem yasama hem de yargı organına çok geniş alanda takdir yetkisi sağlar ve kötüye kullanılmasına uygun bir ortam yaratır. Çerçeve anayasalar, siyasal iktidarı sınırlamada yeterli değildir. Temel hak ve özgürlükleri tanımlar fakat güvenceye almaz. 1924 anayasasının 76.maddesi konut dokunulmazlığını düzenlemektedir. Anayasa bu usul ve hallerin sınırını belirlemez ve takdir yetkisini yasama organına bırakır. Yasama organını sınırlamak 1924 anayasasına göre yeterli olmamıştır. O yıllarda AYM de olmadığı için TBMM’nin yaptığı yasaları anayasaya uygun olup olmadığı konusunda yargı organını da denetlemede bulunmamıştır. Çerçeve anayasaya sahip ülkelerde yargı organı diğer organlara göre daha aktif olmaya başladı. Bu bakımdan yargısal aktivizm çerçeve anayasada vardır.

Yargısal aktivizm: Yargı organının, mahkemelerin anayasal yetkilerini yorum yoluyla genişletmesidir. Bu anlayış güçlü bir yargı organını ve güçlü mahkemeleri beraberinde getirir. Bu yetki, hak ve özgürlükler için kullanılıyorsa olumlu tam tersi ise o zaman olumsuz sonuç yaratır.

Kazuistik anayasa: Konuları en ince ayrıntısına kadar ele alıp düzenlemesidir. 1961 anayasası 157 madde, 1982 anayasası 177 madde olup daha kazuistik anayasadır. 18.yy dan 1. Dünya Savaşına kadar yazılan anayasalar genel olarak çerçeve anayasaydı. İlk yazılı anayasalar ortaya çıktığı zaman bu anayasaların tümünün çerçeve anayasa olduğu görürüz. Kazuistik anayasa tercihi, 2. Dünya savaşından sonra açığa çıkan bir tercihtir. 2.Dünya savaşından önce yapılan çerçeve anayasaya örnek ABD ve Avustralya anayasalarıdır. Kazuistik anayasacılığa geçilmesindeki en önemli etkenlerden biri yasama organının çerçeve anayasadaki üstünlüğünü kendi çıkarları için kullandığı, hak ve özgürlükleri sınırlandırdığı ya da hak ve özgürlükleri kaldırmak amacıyla kullanmasıdır. Bir anayasanın ne kadar ayrıntılı olarak düzenlenirse o alanda siyasal iktidarın ve yargı organlarının takdir marjı daraltılmış olur. Anayasanın ayrıntılı olmasının nedeni: siyasal iktidarın gerçek anlamda sınırlanmasını sağlamaktır. Siyasal iktidarın yetkilerini kötüye kullanmasını önlemektir.

Olumlu yönü: Kazuistik anayasa ele aldığı konuyu detaylı olarak ele aldığı için yasama organını sınırlar. Bu sayede siyasal iktidarın temel hak ve özgürlükleri kısıtlaması konusundaki alanını daraltır ve siyasal iktidarın takdir yetkilerini sınırlar. Hak ve özgürlükler güvenceye alınmış olur. Yargı organının hak ve özgürlüklere müdahale etmesini engeller. Meclisin yaptığı yasaların anayasaya uygun olup olmadığını AYM tarafından detaylı bir şekilde tanımlanması yasama organının yetkilerini sınırlar. Böylece hak ve özgürlüklerin yasa yoluyla nasıl ve hangi sınırlar çerçevesinde olacağı açık ve ayrıntılı olarak belirlenir.

Olumsuz yönü: Toplum, siyaset, teknoloji sürekli olarak değişiyor. Ayrıntılı düzenleme olursa yeni gelişmelere esnetilmesi o kadar güç olur. “Herkes yazılı basın özgürlüğüne sahiptir.” Teknolojik gelişmeye birlikte internet özgürlüğü bunun dışında kalmış ve yargı organının takdirine bırakılmıştır. Her konuyu ayrıntılı olarak ele aldığından temel hak ve özgürlükleri fazla sınırlama riskini içerir.

Siyasal anayasa kavramı: Bütün anayasalar siyasal anayasadır. Çünkü devlet organını kuruyor ve bu şekilde bir bütün içinde siyasal iktidar ilişkilerini düzenliyor anayasa.

Sosyal anayasa: Ekonomik ve sosyal hakları düzenlemiş olan anayasaya denir. Eğer bir anayasada ekonomik ve sosyal haklar yoksa o anayasaya sosyal anayasa denilmez. 1787 Tarihli ABD anayasasına bakınca sosyal haklara ilişkin bir düzenleme yoktur.

Mali anayasa: İktisadi ve mali dengenin sağlanmasına ilişkin ilkelere yer veren anayasadır. Amaç, devletin bütçe dengesinin sağlanmasını amaçlamayan hükümlerin bulunmasını sağlamaktır. Örnek: 2008 yılından bu 2 devlet büyük bir mali kriz içine girmişti. Krizin çıkış sebebi sınırsız borçlanma yüzünden ortaya çıkmıştı. İspanya 2011-İtalya 2012 anayasaları ile kamu borçlarını kamu gelirlerinin ancak belli bir % sini aşmayacağına ilişkin bir anayasal düzenleme getirdi. Bunlar bölgesel devlet olup bölgelerin de borçlanma yetkileri vardı. Anayasa ile o yetiyi sınırlayarak devletin mali dengesini korumak istediler.

İktisadi anayasa: Ekonomik örgütlenmesini, üretim kaynaklarını ve ilişkilerini düzenleyen anayasaya verilen isimdir. Bundan, maddi anlamda iktisadi anayasayı anlıyoruz. Yalnızca anayasa metninde buna ilişkin düzenleme değil ekonominin örgütlenmesi, üretim kaynaklarına ilişkin yani borçlar kanunu, ticaret kanununa ilişkin düzenlemeleri anlıyoruz. Anayasa metninde, şekli anayasa metninde de iktisadi anayasa ile ilgili düzenlemeler oluyor. Örneğin 1982 Anayasasını 161-163. maddeleri. 1924 Anayasası iktisadi bir anayasa hükmü içermiyordu. Buna karşılık 82 anayasası gibi 61 anayasası karma bir ekonomik modeli benimsemiş. 82 Anayasası daha sulandırılmış olup tam karma ekonomi modeli değildir. Ama karma ekonomi modeli benimserse anayasaya aykırı olmayacak biçimde birtakım düzenlemeler getirdi. Örnek: 1982 anayasasında ayrıntılı biçimde yapılan bütçe örneği.

Çevresel anayasa: Çevreye ve doğaya ilişkin düzenlemeler içeren, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını da içinde barındıran anayasaya denir. İklim değişikliği, insanın yarattığı tahribat, bunun gelecek kuşaklara etkisiyle anayasa nasıl baş edeceğin cevabını verir. Çevresel anayasada doğa da bir hak öznesidir. Alma anayasası gelecek kuşakların haklarını korudu. Latin Amerika da Kolombiya- Ekvator anayasaları buna örnektir.

Anayasanın program hükümleri: Anayasalar zaman zaman geleceğe ilişkin ekonomik ve toplumsal birtakım hedefler öngörür. Eğer bir anayasa, geleceğe ilişkin ekonomik, toplumsal hedefler öngörüyor ise o zaman biz

o anayasanın program hükümlere sahip bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin: 1787 ABD’de, 1924 TC. Anayasası program hükümleri içeren anayasalar değillerdi. Buna karşılık 1961 (53.madde)-82 Anayasaları program hükümleri içeren anayasalardı. Bunlar sosyal hakların tanındığı anayasalarda bulunur. Yine Sosyalist Yugoslavya-SSCB, Küba anayasalarının program hükümlerine yer verdiğini not edelim. 2.Dünya Savaşından sonra yazılan anayasaların çoğu program hükümleri içerir. 82 Anayasasında 65.madde, ekonomik ve sosyal haklar başlığı altında devlete birçok ödevler yüklemiştir. Devlete birtakım ödevler getiriyor. Bunun sınırı ise mali kaynakların yeterliliğini sınır olarak kabul etmiştir.

Türk Anayasalarının Özellikleri:

1921 Anayasası: 24 maddeden oluşan, kısa, çerçeve ve yumuşak anayasadır. Tek yumuşak anayasamızdır

1924 Anayasası: 105 maddeden oluşan uzun, çerçeve ve sert bir anayasadır. Çerçeve anayasa olması nedeniyle yasama organını yeteri kadar sınırlayamamıştır. Bu nedenle hem sınırsız yasama hakim olmuş hem de çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiştir.

1961 Anayasası: 157 maddeden oluşan uzun, kazuistik ve sert bir anayasadır. 2.Dünya savaşından sonra hakim olan kazuistik anayasa anlayışı bizde de benimsenmiş ve 91 anayasamız ilk kazuistik anayasa olmuştur. Ayrıca 1961 Anayasasının çerçeve anayasa olmasıyla birlikte ortaya çıkan demokrasiyle ilgili olumsuz deneyimlerin tekrar yaşanmaması için 61 anayasası ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu anayasa ile temel hak ve özgürlükler güvence altına almış ve siyasal iktidarı çeşitli mekanizmalarla sınırlandırılmıştır.

1982 Anayasası: 177 maddeden oluşan daha uzun, kazuistik ve daha sert bir anayasadır. Ancak kazuistik niteliğinin arkasında yatan neden temel hak ve özgürlükleri sınırlamak ve siyasal iktidarın yetkilerini genişletmek isteğidir. 1982 Anayasası sorunları uzlaşmaktan çok kanunla çözmeye çalışır. 82 Anayasasını yapanlar, siyasi kargaşanın nedenini 61 anayasasının özgürlükçü anayasası olarak görüyorlardı. Bu olumsuzlukları engellemek için yeni düzenlemeler koyunca anayasa daha kazuistik hale geldi. 82 Anayasasının daha kazuistik olmasının bir başka nedeni: benimsediği genel yaklaşımdır. 82 anayasasını yapanlar, devlet otoritesini güçlendirmeyi istediler ve bunun yolu olarak temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında yaptılar. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir sınırlama geldi. Düzenlenen her bir madde 61’den daha ayrıntılı olduğunu görüyoruz. 1924-1961-1982 De din ve vicdan özgürlüğü: 61 anayasası özgürlüğü daha geniş tanımlıyordu. Din ve vicdan özgürlüğünü tanıyor. 24 anayasasındaki maddeyle özdeştir. Din ve vicdan özgürlüğünün kötüye kullanılmasını düzenleyen fıkra. 1961 anayasası hakkın kullanımını kolaylaştırmak ve hakkı daha geniş bir şekilde tanımak bakımından 24 anayasasından daha kazuistik bir düzenleme getirmiştir din ve vicdan özgürlüğüne. 1982 anayasası 24.madde, 5 fıkradan oluşan detaylı bir düzenleme yapmıştır. Beta sayfa 39 da 84.madde ile ilgili bir örnek vardır.

Anayasanın İşlevi: 2 temel işlevi vardır.

1.Hukuksak İşlevi: Siyasal iktidarın örgütlenmesine ilişkin düzenlemeler getiriyor ve bunun içinde bir düzen oluşturuyorlar. Böylece siyasal iktidarın organlarının yetkilerini, görevlerini işlemleri, bunların sınırlarını, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir metin olarak önceden liberal demokratik olan veya olmayan hukuksal bir ara çerçeveye oturtuluyor. Bütün devletlerin yazılı katı bir anayasası vardır. Bütün anayasaların içeriği liberal ve demokratik bir içerik taşıyor. Buna rağmen anayasalar hukuksal işlev görüyorlar. Devlet organlarının kuruluşu işlevi yetkilerini görüyorlar.

2. Anayasanın Siyasal İşlevi: 2 işlevi vardır.

1. Kuruculuk işlevi: “*Asli kurucu iktidar*”, Anayasayı yapan ve değiştiren iktidara verilen isimdir. **a.** Yeni bir devlet kurulduysa o zaman yeni bir anayasa yapılır. Bütün kurulan yeni devletlerin bir anayasası vardır. Anayasa, yeni bir devleti kurma işlevi görür. 2.Dünya Savaşından sonra sömürge olmaktan çıkıp bağımsızlıklarını kazanan Afrika devletleri, ilk defa devlet olduklarından dolayı bir anayasa yaptılar. İşte bu devleti kuran, anayasayı yapan iktidara “*Asli Kurucu İktidar*” denir.

b. Rejimin değişmesi ve bu rejim değişikliğinden sonra yeni bir anayasa yapılması da Kurucu iktidarın işidir. Aynı zamanda bir devlet vardır ama çeşitli nedenlerle ortadan kalkmıştır ve yeniden kurulmuştur. Örneğin, 2.Dünya Savaşından sonra Almaya, 2 Almanya olarak yeniden kuruldu ve her ikisi de yeni bir anayasa yaptılar.

c. Devletler anayasalarını yenileyebilirler. Bu anayasa, devletin hukuk düzeninin yeniden kurulması işlevini görüyor. Bunun için anayasanın içeriğine bakmaya gerek yok.

2. Bütünleştirme ya da birleştirme işlevi: Siyasal birliğin ve bütünlüğün sağlanması işlevini görebiliyor. Her anayasa aynı ölçüde bütünleştirme işlevini görmez. Bazı anayasalar daha çok bazıları ise daha az görebilir. A) Temel hak ve özgürlükleri, bir değerler ve kültür sistemi olarak öngörürse anayasanın bu yaklaşımı siyasal bütünleştirme işlevini görür. B) Anayasa bir başlangıç hükmüne dayanıyorsa, bu bölümde belirtilen kurallar, hedefler o siyasal bütünleşmeyi sağlayıcı bir rol üstlenebilir. Başlangıç bölümleri, o anayasanın hangi koşullarda yapıldığını, hangi ilkeleri ve değerleri benimsediğinin gösteren bölüm olduğundan toplum içinde bütünleştirme işlevini görür. C) Anayasadaki devletin ülke unsuru, ülkenin bayrağı, devletin biçimi, resmi diline ilişkin hükümler var ise o anayasanın bütünleştirme işlevini yerine getiren düzenlemeler arasında yer alır. Anayasanın, toplumun genelinde ne ölçüde benimsendiğine bağlı olarak o anayasanın bütünleştirme işlevini görüp görmediği daha iyi anlaşılabilir. Anayasalar, toplumsal uzlaşıya dayanıyorsa o zaman anayasanın bütünleştirme işlevi daha güçlüdür. Eğer toplumsal uzlaşıya dayanmıyorsa, o anayasanın bütünleştirme işlevi ya hiç yoktur ya da azdır. Bosna Hersek anayasası uzlaşıya dayalı değildi.

3. Siyasal iktidarın temel hak ve özgürlükler aracılığı ile sınırlandırılması: Bu durumda anayasanın içeriğine bakacağız. Bir anayasa, ne kadar liberal ve özgürlükçü bir içeriğe sahipse bu işlevi o kadar çoktur. Bir anayasa liberal ve demokratik değilse o zaman o anayasa siyasal iktidarı temel hak ve özgürlükler aracılığı ile sınırlandırma işlevini o denli görmez. Bu işlev ne kadar az ise bu işlevi o kadar az yerine getirir veya hiç getirmez. 1961 Anayasası bu işlevi 82'nin ilk biçiminden çok daha geniş olarak görüyordu.

4.Yönlendiricilik işlevi: Bir anayasa sosyal ve ekonomik haklara ilişkin düzenlemeler ve geleceğe ilişkin program hedefleri bulunduruyorsa o anayasanın yönlendiricilik işlevini yerine getiriyordur. 1787 ABD ve 1924 Anayasalarında ya hiç yok ya da çok sınırlı yönlendiricilik işlevi var. 1924 Anayasasında “eğitim herkese parasızdır” ifadesi sosyal bir haktır ama başka bir düzenleme de yoktur. 2. Dünya Savaşından sonra yapılan anayasalar belli ölçüde yönlendiricilik işlevine sahiptir.

5. Siyasal İktidarı Sağlama İşlevi: Katı ve yazılı bir anayasa ile siyasal istikrar bir ölçüde sağlanır. Onu değiştirmek yasalardan daha zor olunca engel çıkıyor ve bu da bir ölçüde siyasal iktidarı sağlayabilir. Anayasamız yazılı ve katı idi ama bu siyasal istikrarın sağlanmasına yeterli olmadı. 1970-80 yılları arasında siyasal istikrar yoktu. Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda da yazılı ve katı bir anayasa yok ama orada siyasal istikrar vardır. Anayasanın tek başına yerine getirebileceği bir işlevi kısmi olarak sağladığını iddia edebiliriz.

6. Siyasal İktidarın Meşruluğunu Sağlama İşlevi: Eğer siyasal iktidar, anayasaya uygun davranırsa, anayasaya aykırı davranmazsa o zaman bu siyasal iktidara bir meşruluk kazandırır. Siyasal iktidarın anayasaya aykırı davranmaması bu anayasanın işlevlerinden birini oluşturur. Bu meşruluk mutlak bir meşruluk değil bu bir meşruluk karinesi olabilir. Ya da siyasal iktidarın meşruluğunu sağlayan unsurlardan biri olabilir. Aynı zamanda anayasanın içeriğine bakılmalıdır. O anayasa liberal ve özgürlükçü bir anayasa mı değil mi buna bakıyoruz. Günümüz toplumsal siyasal düzenlerinde, anayasaya uygun davranmak meşruluğun kriterlerinden biridir. Anayasanın içeriği de anayasanın bu işlevi görmesi bakımından önem taşır.

Anayasanın İdeolojik yönü: İdeoloji, belli bir sınıfa ya da gruba özgü inançlar sisteminin düşünce üretiminin genel sürecine verilen isimdir. Olaylar üzerine kurulu, insanların düşünce ve davranışlarını etkileyen çeşitli kaynaklardan beslenen inanç sistemidir. Haliyle ideoloji, doğru ya da bilimsel bilgiyle çelişebilecek yanlış bilgiler içerebilir. Milliyetçilik de, Nazizm'im de bir ideolojidir.

Sonuç: Bir anayasanın ideolojisini nereden anlarız? 1982 Anayasasının 35.md.si mülkiyet hakkını düzenliyor. Bir anayasada, mülkiyet hakkının bulunması iktisadi liberalizmi benimsediği anlamına gelir. Bir hakkın bulunması veya bulunmaması o anayasanın belli bir ideolojiye yatkın olduğunu bize gösterir. İdeolojik dayanakları bakımından liberalizm md.35 kanun önünde eşitlik bir mülkiyet hakkı. Bir anayasada mülkiyet hakkının bulunması veya bulunmaması hakkı ideolojik bir tercihtir. Ekonomik bakımdan liberal bir anayasa. Ama hak ve özgürlükler bakımından liberal ve demokratik yönü sınırlı bir anayasa. Her anayasa da bir hak ve özgürlüğün bulunup bulunmaması bile o anayasada yasa koyucunun benimsediği ideolojiyi gösterir.

Hükümet sistemleri, aynı yönetim düzeyi içinde yetkilerin paylaşılmasıdır. Merkezi bir hükümet içinde yasama, yürütme, yargı yetkilerinin paylaşılmasına ilişkin bir konudur. Hükümet sistemini belirleyen yasama ve yürütme arasındaki ilişkidir. Demokratik tüm rejimlerde yargı zaten diğerlerinden bağımsızdır.

Anayasacılık Hareketleri:

Çağdaş devletin yani ulus devletin ortaya çıkmasıyla başlayan olgudur. Bu hareketi başlatan sınıf burjuva sınıfidır. Siyasal iktidarın sınırlandırılması amaçlanmış olup bunun amacı: kişilerin hak ve hürriyetlerinin,

özgürlüklerinin güvence altına alınmasıdır. Sınıf farkı gözetmeksizin herkesin anayasa ya da o hukuki düzende tanınmış hakların güvence altına alınması anlaşılıyor. Ulus devletin, Kıta Avrupası'nda bir siyasal yönetim biçimi olarak yerleşmesi 1648 Vestfalya antlaşmasına rastlar. Ulus devletlerin sınırları belirlenmiştir. Ulus devletin oluşu anayasacılık hareketinin temelini oluşturur. 15.yy'da İspanya ilk ulus devlettir. Hangi araçlarla sınırlandırıyor: 1. Erklar, güçler ayrılığı 2. Bağımsız yargı 3. Yazılı bir anayasa yoluyla. Devlet iktidarını sınırlamak yoluyla birey özgürlüklerini güvenceye almak, keyfi yönetim yerine kurallara bağlı, hukuki ve kurumsal düzeneklerle sınırlandırılmış bir devlet yapısı anlamına gelir.

Çağdaş Anayasacılık: Burjuvazinin 2.evredeki talepleridir, çağdaş anayasalar. Burjuvazinin mutlak monarşilere karşı siyasal özgürlüğü gerçekleştirme ve güvenceye alma amacıyla ortaya çıkmıştı. Siyasal özgürlük yönetime katılmayı amaçlar.

John LOCKE'a göre Güçler Ayrılığı: 1. Kural koyma: yasama organı mutlaka yürütme organından bağımsız olmalıdır. Yasama bir kurula bırakılabilir ama yürütmeyle birlikte bir kişinin elinde olamaz.

2. Yürütme gücü: Yasama organından bağımsız olmalıdır ve yasalara bağlı olması gereklidir.

3. Federatif güç: Devletle, devletin dışındaki kişiler arasında ilişkileri düzenleyen güç. Savaş, barış, ittifak kurma gibi konular federatif güce aittir. Locke, güçler ayrılığı ilkesi yasama organının üstünlüğüne dayanır. Anayasal bir monarşiyi savunur. Kralın parlamentonun çıkardığı yasalara bağlı olduğunu söyler.

MONTESQUIEU'ya göre güçler ayrılığı: bu ilkeyi ilk kez ortaya koyandır. Kanunların Ruhu adlı kitabında ayrıntılı olarak anlatıyor. Bizdeki demokrasi anlayışı, 1789 devriminden öykünmüş ve Fransız Devriminden etkilenmiştir. İnsanlar gücü kötüye kullanırlar. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Gücü, güçle sınırlamakla engellenmesini savunuyor. Bu 3 gücün farklı ellere verilmesi. Gücün tek elde toplanması, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını ortadan kaldırır. Bunun için bu 3 güç birbirinden ayrılmalıdır. Ona göre yargıç, kendi benliğinden bir yorum katamaz. Kanun ne derse onu yapar. 1789 Devrimi ve sonrasında, ulusun yalnızca parlamento tarafından temsil edildiği anlayışına dayalıdır. Sonuç: ilk defa yasama, yürütme, yargı erklerinin farklı ellere verilmesidir. Anayasal monarşiyi savunuyor. Yasama yetkisi parlamentoda, yürütme yetkisi kralda, yargı da yargıçlarda olmalıdır. Fakat bu hak ve özgürlüklerin korunması için yeterli değildir. Aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin korunması için gücün güçle korunması gereklidir. Her bir erkin, birbirine karşı kullanabileceği yetkiler yoluyla hiçbir erkin iktidarın yetkisini kötüye kullanmasının önüne geçilir. Bugün de bunlar geçerlidir. Anayasayı, bir toplum sözleşmesi olarak görülmesini ortaya koymuştur.

Anayasacılığın üçüncü evresi sanayi devrimi ve proleteryanın doğuşu: 18.yy'ın sonlarında sanayi devrimiyle yeni bir sınıf olan işçi sınıfının doğdu. Sanayileşme, seri üretimi beraberinde getiriyor. Ustalık değersizleşiyor, çalışmayı sıradanlaştırıyor. Bu dönemde İşçi sınıfının en önemli talebi, örgütlenme özgürlüğü idi. İşçiler bir araya gelip örgütleniyorlar. Talep edilen ilk özgürlük örgütlenme özgürlüğüydü. 18.yy'dan itibaren ücretlerin yükseltilmesi için örgütlenme anlayışı parlamentolar tarafından yasaklanıyor. 1831 Lyon ayaklanması: işçiler ayaklanıp, çalışma hakkını talep ediyorlar. İşçi sınıfından parlamentoya temsilci gönderme isteği oluşuyor. Bunun sonucunda 1917 yılında Sosyalist Anayasacılık ortaya çıktı. Ana özellikleri: güçler ayrılığına değil, güçler birliğine dayanır. Doğal haklara karşıdır. Pozitif hukuka dayalı haklar silsilesini benimser. Burjuvanın talep ettiği hak ve özgürlükleri benimsemez. İşçi sınıfının doğuşuyla birlikte talep edilen: çalışma, konut, sağlık, asgari ücret hakkı çok daha gelişmiştir. Mülkiyet, dolaşım, ifade, basın özgürlüğü gibi haklar geridedir.

Chartist hareketi: İşçi sınıfının, seçme ve seçilme talep haklarını gösteriyor. Dünyadaki ilk ulusal işçi hareketidir. İngiltere'de 1 milyondan fazla kişi parlamentoya verilmek üzere bir dilekçe hazırlamış olup bu dilekçede; 1. Oy hakkı herkese verilmeli 2. Seçilmek için mülk sahibi olmak koşulu kaldırılmalı 3. Seçim çevreleri eşitlensin. 4. Seçimlerde gizli oy ilkesi kabul edilsin. 5. Milletvekillerine aylık bağlansın. 6. Parlamento seçimleri her yıl yapılsın. Bu taleplerden ilk 5 talep kabul edilmiştir.

Paris Komünü (1871): 1870 Yılında Almanya- Fransa savaşında Almanya kazandı. Napolyon esir düşünce Paris'teki işçiler ayaklandı. Bütün kilisenin mallarına el konuldu. Ordu ile halk arasında bir özdeşlik yarattılar. Yasama ve yürütmenin komün adı verilen kurulun elinde olduğunu belirttiler. Kamu görevlilerine de ortalama işçi ücreti verilmesi öngörüldü. Komün üyeleri için emredici vekalet görevi getirildi. İlk sosyalist örgütlenmenin yaşandığı bir deneyimdir.

1918 Spartakis Ayaklanması: Almanya'da çıkmış olup işçi sınıfının son ayaklanmasıdır. Bundan sonra işçi sınıfı, yönetime katılma ve sosyal haklar elde etme amacına büyük ölçüde ulaşmıştır.

Magna Carta (1215): Tarihteki ilk anayasal belgedir. Bunun anlamı büyük özgürlük fermanıdır. Bu belge soyluların geleneksel olarak sahip olduğu hakları yazılı olarak krala bir kez daha imzalatılmasıdır. Suçsuz ceza olmaz, Suç ve ceza orantılı olmalı, Ülkeye giriş-çıkış serbestisi, Feodal beylerin mülkiyet ve miras hakları güvenceye alınmıştır. Bunların uygulanmasını denetlemek için soylulardan 25 kişilik kurul oluşturulması, Beta 57

Charles I: Haklar Dilekçesi: 1628 Yılında parlamentonun hazırladığı bu dilekçeyi kral onaylıyor. Bu dilekçe, Magna Carta'dan sonra önemli kabul edilen en önemli 2. Anayasal belgedir. Önemi maddeleri; Parlamentonun izni olmadan vergi salınmayacak, Keyfi tutuklamak yasaklanacak, Yeni bir iktidar anlayışı ile iktidara gelen krala Magna Carta'daki belgeler hatırlatıldı. Bu maddelerde pek çok güvence yinelenmiştir. 13 Yıl hiç ara vermeden çalıştığı için bu parlamentoya uzun parlamento denir.

Yönetim Aracı: 1654 yılında, tarihteki ilk yazılı anayasadır.

Habeas Corpus Act (Bedenine sahipsin): Kişinin kanuna aykırı olarak tutuklandığı savıyla, tutukluluğunun kaldırılması talebiyle kendisinin ya da bir başkasının mahkemeye başvurusu: Tutuklunun bu amaçla en kısa sürede yargıç karşısına çıkarılması ve yargıcın tutukluluğun yasaya aykırı olup olmadığına karar vermesidir. Bugünkü ceza kanunun en temel ilkelerinden birisidir. Keyfi tutuklamaya karşı en önemli güvencedir. En eski, en temel anayasal belgedir.

Bill of Rights (Haklar Yasası): 1. Magna Carta'dan beri var olan güvenceleri yenilemiştir.

2. Parlamento kendisini güvenceye alıyor. Parlamento üyeleri, keyfi tutuklanmasın, yasama faaliyetlerinden keyfi olarak alıkonulmasın

3. Yasaların kral dahil herkesi bağlaması bakımından önemlidir. Parlamentonun kraldan mutlak üstün olduğunu ve sınırlı bir monarşi olduğunu, kralın sınırlandırıldığının gösterir. Alınan Kararlar: Parlamento sık toplanacak, Parlamento seçimleri serbest yapılacak, Parlamentoda ifade özgürlüğü olacak, Yasalar kral dahi herkesi bağlayacak, Fermanlar yasalara aykırı olmayacak, Parlamentodan habersiz vergi ve asker toplanamayacak.

Marry Flower Sözleşmesi: 1620'de İngiltere'deki dini baskılardan kurtulmak için ABD'ye yerleşiyor. Dirlik ve düzen için bir araya gelmekten söz ediyor. Adil, eşit yasalara dayalı bir sözleşme yapılmış. ABD'deki anayasanın temelidir.

1776 Virjinya Anayasası: Günümüzdeki anlamıyla temel hak ve özgürlüklerin bulunduğu, yasama ve yürütme organlarının kuruluşunun, işleyişinin görev ve yetkilerini aynı zamanda yargının yer aldığı ilk anayasadır. Bütün hak ve özgürlüklerin yer aldığı Locke'un ortaya attığı kurama dayalı ilk haklar bildirgesidir. Bu anayasa da mülkiyet hakkı da tanınmıştır.

1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesi: temel özelliği: Virjinya anayasasındaki temel anlayışın tekrarıdır. John Locke'un düşüncesi, temel anlayış olmuştur. Direnme hakkı vardır. Halkın, doğal haklarının olduğu ve bunları yerine getirmeyen hükümetlerin halk tarafından değiştirilebileceği.

Direktuar yönetimi: Yürütme, 5 direktuar adı verilen kişiler arasında paylaştırılıyor. Bunun amacı, 1789 öncesindeki döneme dönmek. Yani yürütmeyi mutlak monarşideki gibi tek kişinin eline vermemek. Parlamento 2 kanatlı hale gelmiştir. Tek meclisli parlamentonun aşırılığını önlemek için 2.meclis kuruluyor.

Orleans'cı parlamentarizm: Temel özelliği, klasik parlamenter sistemde hükümet parlamentoya karşı sorumluydu. Bu sistemde ise, hem krala hem de parlamentoya karşı sorumlu. Hükümet yalnızca yasama organına karşı değil, aynı zamanda devlet başkanına karşı da sorumlu. Orlean hanedanının tahta olduğu dönemde ortaya çıkan bir yönetim olduğu için bu ismi almıştır.

Anayasacılık hareketlerinin ortak özellikleri:

1. Burjuva sınıfının istekleri doğrultusunda dolayısıyla onların önderliğinde ortaya çıkmıştır.

2. İktisaden gelişmiş bu üç ülkede, demokrasinin ortaya çıktığını ve geliştiğini görüyoruz. İktisadi gelişmişlik ile demokrasi arasında bir ilişki vardır. Bugün bakacak olursak iktisadi olarak gelişmemiş Hindistan'da demokrasi vardır. Çin iktisadi olarak gelişmiş ama demokrasinin temel ölçüleri bakımından geridir. Rusya, gelişmiş ülke olmasına rağmen demokrasi ile arasında mesafe vardır. Yani günümüzde bu ilişkinin birebir paralel bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz.

3. Bu üç ülkeden çıkan sonuç, Demokrasi bakımından bazı değerlerin olması zorunludur. Bunların olmadığı yerden demokrasi çıkmaz.

Bunlar; **a) Ussallık:** hukuk ve siyasal düzenin akla dayalı olması. Bunun siyasal alandaki karşılığı laikliktir. Bunun olmadığı yerde demokrasi olmaz.

b) Hoşgörünün olması ve şiddetin dışlanması: siyasal ve toplumsal alanın hoşgörüyü dayanması, farklı düşüncelerin, inançların bir arada yaşaması ve şiddetin dışlanması. Bunun siyasal alandaki iz düşümü çoğulculuktur.

c) Hukukilik: Hukuk devletin varlığının olması, demokrasinin olabilmesi için kuralların olması ve bu kuralların işlemesi gerekir. Demokrasinin kurallarına uyulması. Bunun siyasal iz düşümü hukukiliktir. Bütün kurallara bütün tarafların uyması gerekir.

Sened-i İttifak: Tanzimat dönemindeki gelişmelere yön veren bir gelişmedir. Osmanlı'daki ilk anayasal belge olup, yenilikçi bir gelişme, batılılaşma hareketidir. Padişahın mutlak otoritesi karşısında ayanların kendi durumlarını ve fiilen var olan güçlerini güvenceye almak amacı görülür. Ayanlara bir çeşit direnme hakkı tanır. Ayanlar, merkezi iktidarın keyfi işlemlerine karşı koyabilecek diğer ayanlar bir karşı koyma sırasında haksızlığa uğrayanlara yardım edecek. Bu belge ile zayıflayan devlet otoritesi tekrar güçlenmeye başlamıştır. Kişi güvenliği, suç ve cezaların yasallığı ilkesi kazanımdır. Bu belgede padişahın yetkilerini denetleyecek bir kurum yok.

Islahat Fermanı: Tanzimat Fermanı'nda tanınan, ancak uygulamada tam olarak yer bulmayan güvenceleri bir kez daha tekrarlıyor. Berat/direktif, yenileşme programı niteliğinde. İbadet ve din özgürlüğü tanınıyor. (Kimse din ve mezhebi dolayısıyla aşağılanamaz. Kimse din değiştirmeye zorlanamaz. İslamdan çıkma idamla cezalandırılmayacak.) İşkence yasaklanıyor. Vergide eşitlik ilkesi

1876 Kanun-i Esasiye: Osmanlının İlk anayasasıdır. 2 Yıl yaşayabiliyor. Teokratik ve monarşik bir yapı vardır. Anayasanın üstünlüğü (md.113 bunu güvencesiz kılıyor "hükümetin emniyeti ihlal ettikleri saptanan kişileri sürgüne gönderebilme yetkisi"), Egemenliğin kaynağı belirtilmiyor. Padişah yürütme organının kendisi, Parlatmentonun kanun koyma yetkisi, padişah lehine sınırlandırılıyor. Heyet-i Vükela, Yasama (Meclis-i Umumi- Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan). Hak ve özgürlüklere dair haklar veriyor kanunda yazılı ama bunları denetleme anlayışı yok: Kanun önünde eşitlik, kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı, Din ve ibadet özgürlüğü, basın özgürlüğü, girişim özgürlüğü, işkence yasağı, dilekçe, eğitim, mülkiyet hakkı, hak arama özgürlüğü, kanuni yargıç ilkesi tanınmıştır.

II. Meşrutiyet ve 1909 Değişiklikleri: Jön Türk hareketi, monarşik ve teokratik yapı sürüyor. Hükümdarın yetkilerinin sınırlandırılması ve parlatmentonun yetkilerinin arttırılması öngörülüyor. Padişahın, Meclis-i Umumi ve Heyet-i Vükela üzerindeki yetkileri sınırlanıyor. 113.madde kaldırılıyor. Sansür yasağı getiriliyor. Haberleşme özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlükleri tanınıyor.

1921 Teşkilatı Esasiye: Çerçeve ve yumuşak anayasa. 3.md. "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur." 1.md. "Ulusal egemenlik", meclisin üstünlüğü, güçler birliği ve meclis hükümeti sistemi, Yerinden yönetim (Vilayetler ve nahiyeler tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip), iki anayasalı dönem (Teşkilat-ı Esasiye ve Kanun-i Esasiye)

1961 Anayasası: TBMM'ni frenlemeyi amaçlayan yeni organlar vardır. 1. İki meclisli sistem: Millet Meclisi ve Senato. 2. Anayasa Mahkemesi. İdare içindeki bazı kurum ve kuruluşlara tanınan idari özerklik verilmiştir: Üniversiteler, TRT

1982 Anayasası: Kaziistik ve katı bir anayasa. Otorite-özgürlük dengesinde otoriteye öncelik verilmiştir. Yürütmenin, yürütme içinde de CB'nın güçlendirilmiştir. Bakanlar kurulu içinde Başbakan güçlendirilmiştir. Daha az katılımcı demokrasi anlayışı, TBMM'de siyasal partilerin grup kurmaları için gerekli asgari milletvekili sayısında artış. MGK, YÖK, HSYK. Bir geçiş dönemi öngörür. Tıkanıklıkları giderici çözüm yolları anayasaya konulmuştur; Tek meclisli sisteme dönüş, toplantı yeter sayısı düşürülmüştür, CB'na TBMM seçimlerini yenileme yetkisi tanındı. TBMM'nin CB'nı toplam 4 oylamada seçememesi durumunda TBMM seçimlerinin yenilenmesi, TBMM başkanının üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilmesi şartının değiştirilmesi.

1961 ve 1982 Anayasalarının Yapılışları Bakımından Karşılaştırılması:

1961 Anayasası: Askeri müdahale sonucu yapılmıştır. Askeri kanat (Milli Birlik Komitesi), sivil kanat (Temsilciler meclisi), Kurucu meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır. Daha temsildir. Halkoylaması sonrası süreç belirli, Sivil kanadın BK'nın kurulmasına ve düşürülmesine ilişkin yetkisi yok.

1982 Anayasası: Askeri müdahale sonrası yapılmıştır. Askeri kanat (Milli Güvenlik Konseyi), sivil kanat (Danışma Meclisi), Kurucu meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır. Daha az temsil niteliği. Hiçbir siyasi parti anayasa hazırlama sürecine katılmamıştır. Sivil kanadın BK'nın kurulmasına ve düşürülmesine ilişkin yetkisi yok. Halkoylaması sonrası süreç belirsiz. Siyasi partilerin kamuoyu oluşumunda rolü yok. Anayasanın kabulü CB seçimiyle birleştirildi.

Devlet Biçimi: Dikey güçler ayrılığıdır. Merkezi yönetim ile merkezi yönetim altındaki diğer yönetim birimleri arasındaki yetki bölüşümüdür. Her devlette bir merkezi devlet vardır. Tine o merkezin altında bölge, il, ilçe, köy gibi yönetim birimleri vardır. Devlet Başkanının belirlenme biçimine göre 2'ye ayrılır: Monarşi: Devlet Başkanının soy esasına göre belirlendiği yönetim biçimi ve Cumhuriyet. Bu bize o devletin biçimini de gösteriyor. Kuşkusuz devlet başkanının seçilme biçimi aynı zamanda o devletin biçimini belirliyor aynı zamanda hükümet biçimini de belirliyor. Mutlak Monarşi ve Parlamenter Monarşi olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Mutlak Monarşi: Yasama yürütme hatta yargı yetkileri bu şekilde belirlenen devlet başkanına aittir. Parlamenter Monarşi: Devlet Başkanı soy esasına göre belirlenir ama yasama yetkisi halkın oylarıyla seçilmiş parlamentoda yürütme yetkisi de bu parlamentonun içinden çıkan ve ona karşı sorumlu olan hükümettedir. Dar anlamda Cumhuriyet, devlet başkanının soy esasına göre belirlenmediği devlet biçimine verilen isim. Doğrudan ya da dolaylı biçimde halk tarafından seçilen cumhuriyet biçimine karşılık geliyor. Geniş anlamda ise, dar anlamda ki bu unsurlarla birlikte demokratik düzenin temel unsurlarını da içine alan devlet biçimine verilen isim. Devlet başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından seçildiği ve düzeninde demokrasinin temel ilkelerine uygun olduğu devlet biçimine verilen isim. İkincisi seçimin nasıl yapıldığı, kimin devlet başkanı seçildiği ile ilgili değil aynı zamanda devlet yönetiminin nasıl bir yönetim olduğu ile ilgilidir. 1923'den itibaren bizde de cumhuriyetin geniş anlamda kullanılmıştır. Örnek 1960-61 ve 81-82 yılındaki darbe dönemleridir. O dönemde kendilerini CB olarak değil devlet başkanı olarak adlandırmışlardır. 1924 Anayasasının 1.md "*TC Devleti Cumhuriyettir*" ibaresi vardır. 61-82 Anayasaları da bu ifadeyi kullanmıştır. 1961 Anayasasının 1.md gerekçesinde "devlet biçiminin bir zümre ye şahsa dayanmadığını, kaynağın ulus olduğunu gösteriyor ve demokratik bir cumhuriyet olduğunu belirtiyor ki bu geniş anlamda bir cumhuriyet ilkesidir. 1982 Anayasasının gerekçesinde, dar anlamda bir cumhuriyet olarak gerekçelendirilmiş. Anayasanın 2 ve 3.maddeleri de değiştirilmez olarak kabul edilmiş 61'den farkı vardır. 2.Maddenin kenar başlığı, cumhuriyetin nitelikleri olup bu madde ile cumhuriyetin geniş anlamda kullanıldığı sonucuna varabiliriz.

Devlet biçimi denilince dikey güçler ayrılığı anlaşılır. Yatay güçler ayrılığı: aynı yönetim düzeyi içinde yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirinden ayrılmasıdır. Dikey güçler ayrılığı farklı yönetim düzeyleri yani merkezi yönetim ile merkezi yönetim arasındaki yetki ve görev paylaşımı veren unsurdur. Dikey güçler ayrılığında devlet biçimi vardır. Üniter devlet (tek yapılı), Federal devlet, Bölgeli devlet, Konfederal devlet Tek yapılı devlet de 2'ye ayrılır: klasik üniter devlet (Türkiye, İsrail, Yunanistan) ve özerk üniter devlet olarak Birleşik Krallık ve Fransa en önemli örnektir. Federal Devletler: ABD, Kanada, Rusya, Almanya, Hindistan. Konfederal devlette, dış egemenlik bakımından devletler bağımsızlıklarını korumaya devam ediyorlar. Hem iç hem de dış egemenlikleri bakımından bağımsızlıklarını sürdürüyorlar.

Üniter devlet: Merkezi yasama organının üstünlüğüne ve egemenliğine dayanan, tek merkezi hükümet altında örgütlenmiş devlet biçimine üniter devlet denir. Bu merkezi yasama organının üstünlüğüne hem yargı organının merkezi olması, tekliğine dayalı bir devlet biçimidir. En önemli özelliği devletin tekliği ve bölünmezliği ilkesine dayanmasıdır ve 3 unsuru vardır; egemenliğin, ulusun ve ülkenin tekliği ve bölünmezlikleri anlaşılır. Bu 3 unsur bir aradadır.

Egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesi: Egemenliğin tekliği ve bölünmezliğini ilk defa Jean Bodin tanımlamıştır. Egemenlik yetkileri: yasama, yürütme ve yargı yetkisidir. Egemenliğin bölünmezliği de bu yetkilerin tek elde toplanmasıdır. Egemenliğin kullanımı, demokratik devletlerde egemenliği halk kullanır ve halk adına parlamento kullanır. Tek ve bölünmez ise egemenlik, o zaman bu yetkiye sahip olan organ taktır. Bir tane yasama organı olabilir başka bir parlamento olamaz. Bir devletin sınırları içinde tek bir parlamento olur ve o parlamentonun yapmış olduğu yasalar ve kurallar herkesi bağlar. Bunun istisnası olamaz.

Egemenliğin tekliği ve bölünmezliğinin üniter devlet biçimi tarafında karşılığı budur. Egemenliği, millet adına bir de yargı kullanır. O zaman yargı yetkisi de tek ve bölünmez olmalıdır. Ani yargı yetkisinin de tek ve merkezi olmalıdır. Yasama ve yargı yetkisinin tekliğini anlıyoruz. Parlamento 2 kanatlı olabilir. İki kanatlı olması egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesini zedelemeyiz. Çünkü aynı ulusu temsil ediyorlar. İkisi bir araya gelerek aynı yasayı çıkarıyor ve bu yasa bütün ulusa uygulanıyor. Önemli olan 2 kanadın da aynı ulusu temsil etmesidir.

Ulusun tekliği ve bölünmezliği: Her devlet ulus devlettir. Kaynağını ulustan alır. Tek bir ulusun olması, devletin tek bir ulusa dayanmasıdır. Bir devlet birden fazla ulusun egemenliğine dayalı olamaz. Bu ulusu oluşturan farklı etnik kökenler, farklı dini, kültürel unsurlar olabilir. Bu önemli değildir. Birden fazla olması birden fazla ulus olduğu anlamına gelmez. Bunların tümü aynı yasama organına bağlıdır. Aynı yasama organının çıkardığı kanunlara bağlıdır ve bu kanunlar herkese uygulanır. Federalizmde yer yönünden federal birimlerin oluşturulması (yersel federalizm) veya cemaat, topluluk esasına dayalı olan korporatizm, ulusun tekliği ve bölünmezliği ilkesi ile bağdaşmaz. Üniter devlette, tek bir yasa yapılır ve o yasa herkese uygulanır. Farklı unsur, organlara yasama, yürütme görevi tanımak klasik üniter devlette mümkün değildir. Federal devlette birden fazla ulus o devleti oluşturabilir. Örnek: Belçika volan ve Flaman uluslarından oluşuyor. Belçika federal bir devlettir. Bütün federal devletler çok uluslu yapıya sahip olmak zorunda değildir. Federalizm, çok uluslu olmayı dışlamaz ama şart da koşmaz. Üniter devlette, çok ulusluluk dışlanır.

Ülkenin tekliği ve bölünmezliği: Bir ulus devlet içinde aynı yasaya aynı anayasaya bağlı tek bir ülke söz konusudur. Bir ülke il, bölge, ilçe, belediye gibi alt birimlere ayrılabilir. Bu tür bölünmeler idari nitelikte yani daha iyi hizmet sunabilmek, yönetebilmek amacıyla yapılan bölünmelerdir. Bunlar yasama ve yargı yetkisine sahip mi? Yasama ve yargı yetkisine sahip değilse sadece idarenin işleyişini, hizmetlerin yapılışını kolaylaştırma amacı taşıyorsa o zaman bunların ayrılmasının ya da çeşitli birimler oluşturulması üniter devlet ilkesiyle bağdaşmaz bir yönü yoktur. Ülkenin tekliği ve bölünmezliği ilkesi aynı zamanda ülkenin belli bir bölgesinin başka devlete katılmasını ya da bağımsızlık elde etmesini engelleyen bir ilkedir. Devletin bir bölümünün devletten ayrılması, kopması, devletin başka bir devlete katılması mümkün değildir. Ülke topraklarının tümünün veya bir bölümünün devletten kopması bakımından üniter devlete özgü bir özellik değildir. Ülkenin bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan bir ilkedir. Bu bakımdan ülkenin tekliği ve bölünmezliği sadece üniter devlete özgü değildir. Anayasa da açıkça yazmadığı sürece federal devlet, federal devlet, bölgesel devlet ulus devlet içinde yer alan devlet biçimlerinin hepsi bakımından geçerlidir. Federal, bölgesel devletlerde de buna izin verilmez. Anayasasında self determinasyon denen, halkın kendi geleceğini belirlemesi hakkını tanıır. Böyle bir imkan olmadığı sürece hiçbir ulus-devlet bu yetkiyi tanımaz. 1861-65 arasında ABD de iç savaş bu sebeple çıktı. Yugoslavya ve SSCB kendi ülkesini oluşturan toplulukların kendi geleceklerini belirleme yetkisini tanıdı ama Yugoslavya uygulamadı.

Üniter devletin diğer özellikleri: Merkezden yönetim ilkesi, Yerinden yönetim ilkesi, Yönetimin bütünlüğü ilkesi (Hiyerarşi ve idari vesayet)

Merkezden Yönetim İlkesi: Bütün kamu hizmetlerinin merkezde toplanması ve tek elden yürütülmesi anlamına geliyor. Ülke ne kadar büyürse kamu hizmetlerinin yapılması o kadar güçleşir. Devlet, il, ilçe, bölge gibi farklı yönetsel idari bölümlere ayrılır. Burada önemli olan bu bölünmeler içinde merkezi yönetimin kendi teşkilatının olmasıdır. Buna taşra örgütlenmesi denir. Merkezde yer alan örgütlenmenin, merkezin dışında yer alan bölgelerde de oluşturulmasına taşra örgütlenmesi denir. Merkez, kamu hizmetlerini kendisine bağlı ve bağımlı olan bu taşra örgütlenmeleri yoluyla bütün ülkede gerçekleştirilir. Örneğin merkezde MEB vardır. İl ve ilçe ME müdürlükleri vardır. Bunlar vasıtasıyla eğitim hizmeti sağlanır. Merkez ile taşra örgütlenmeleri arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. Taşra örgütlenmesinin kendisine ait bir kaynağı yoktur. Bütün kaynak merkezden gelir. 2. Hangi kamu hizmetinin ne şekilde görüleceği de yine merkezin kararıdır. Sadece taşra örgütlenmesi, merkezin aldığı kararı ilgili bölgede uygulayan birimdir. Tüm işlerin, merkezin denetimi, hiyerarşisi altında taşra örgütlenmeleri aracılığı ile yapılmasıdır. Taşra örgütlenmesi kendisine kaynak da yaratamaz. Merkezin gönderdiği mali kaynağı, merkez nasıl istiyorsa o şekilde kullanmak zorundadır. Özerklik denilen olgu, bu taşra örgütlenmelerinde yoktur. Taşra örgütlenmesi içinde merkezin atadığı yöneticiler bulunur. Bunlar merkezin hiyerarşisine bağlıdır. Bunun birtakım sakıncaları vardır. 1. Bir bölgede ihtiyaçların karşılanması çok büyük bir bürokrasi ortaya çıkartıyor. 2. Taşra yöneticilerini merkezden atar. Yöneticinin, yerel sorunları hakkında çok az bilgisi olur. O yerel birimin ihtiyaçlarının karşılanmasında her şeyin merkezden idare edilmesi yöneticilerin merkezden atanmasının bu gereksinimlerin ortaya çıkarılması ve

karşlanması bakımından sorun yarattığını görüyoruz. 3. Günümüz demokrasi anlayışı, yetkilerin tek elde merkezde toplandığı bir yönetim anlayışını dışlıyor. Günümüz demokrasi anlayışı olabildiği kadar ihtiyaçların yerel gereksinimlerin halka en yakın olan ve halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir yönetim birimi tarafından karşılanması ilkesine dayanır. 1789 Fransız devriminden sonra kıta Avrupa'sında oluşan biçimde merkezi yönetimin taşradaki temsilcileri valilerdi. Osmanlı 19.yy dan itibaren idari teşkilatlanmayı Fransa'dan örnek alarak geliştirdi. Her ilin başında bir vali vardır. Vali o ilde merkezin en üst temsilcisidir. Merkezin belirlediği işleri yapmak ve merkeze karşı sorumlu olmak durumundadır.

Üniter devlet 2'ye ayrılıyor; Klasik ve özerk üniter devlet. Bir devlet biçiminin nasıl olduğuna bakarken öncelikle devletin unsurlarını göz önünde bulunduruyoruz. Yani egemenlik, ülke ve ulus unsurlarını. Klasik üniter devlet: devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü anlayışına dayalı bir devlet biçimi olup, ulusun, ülkenin ve egemenliğin tekliği ve bölünmezliği anlayışına dayanır. Aynı zamanda merkezden yönetim hizmetleri, bütün kamu hizmetlerinin tek elden yürütülmesi ilkesi uygulamada yerelin ihtiyaçlarının merkezden belirlenememesi ve bugünün demokrasi anlayışıyla 2 önemli araçla merkezden yönetim ilkesi yumuşatılır. 1.Yetki devri 2. Yetki genişliği

Yetki genişliği: Anayasa ve yasayla memura tanınan ve memurun merkezin denetimi altında kullandığı sürekli nitelikteki yetkiye verilen addır. Merkez bazı yetkilerini taşradaki memuruna aktarıyor. Bu yetkiler, anayasa ve yasayla tanımlandığı için sürekli. Bu yetki ancak anayasa ya da yasa değişikliği ile geri alınabilir.

Yetki devri: sınırlı ve belirli konularda adı belirtilen memura geçici olarak yetkinin aktarılmasıdır.

Yerinden Yönetim ilkesi: 1. Siyasal yerinden yönetim 2. Yönetimsel (idari) yönden yönetim.

Siyasal yerinden yönetim: Belli bir birimin, yalnızca yönetsel olarak değil ama yasa yapma, kural koyma hatta o kuraldan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme bakımından da özerkliğe sahip olmasıdır. Bu bakımdan siyasal yerinden yönetim ilkesi bölgesel devletin ve federal devletin bir özelliğidir. Üniter devlet yapısı ile bağdaşmaz.

Ama buna karşılık yönetsel (idari) yerinden yönetim ilkesi ile tek yapılı devlet ilkesinin bağdaştığını söyleyebiliriz. Demokratik devlet ilkesi her şeyin merkezden yapılması ilkesini engelleyen bir yapıdır. Bir üniter devlet, demokratik ise yerinden yönetim ilkesinin bulunmasının güçlü olması gerekir. Yerinden yönetim ilkesi denince, merkezin altında bulunan bölgeye de yasama ya da yargı yetkisi vermez. O her zaman üniter devlette merkezdedir. Sadece idareye ilişkin birtakım yetkiler verir. YY ilkesinin temel özelliği; merkezin dışında kalan yerel yönetimlerin, organlarının o yöre halkı tarafından seçilmesi, dolayısıyla demokrasiye dayanması ve bu organlarında o yöre halkına tarafından seçilmesi dolayısıyla demokrasiye dayanması ve bu organlarında o yöre halkına ilişkin olarak yönetsel, idari birtakım yetkilerle donatılmış olmasıdır.

Yerinden yönetim 2 şekilde olabilir.

1. Yer yönünden yerinden yönetim (belediyeler, iller) Belli bir coğrafi bölgede kurulmuş olan yönetim birimin sahip olduğu yetkidir. Bizde 24 Anayasası döneminden beri 61-82 Anayasalarında da belediye, iller, köyler vardır.

2. Hizmet yönünden yerinden yönetim yani belli bir hizmetin bir özerkliğe sahip kuruluş tarafından yerine getirilmesidir. Bağımsız otoriteler buna örnektir.

Hizmet yönünden yerinden yönetim birimlerinin ortak özelliği; 1. Bunların hepsinin kendi tüzel kişiliğinin vardır. Kendi mal varlıkları vardır. 2. Bunlar kendilerine kaynak yaratırlar. Vergi, harç alırlar.

3. Merkezden bu yerinden yönetim birimlerine aktarılan bir kaynak var ise bu kaynağı merkezin herhangi bir denetimi olmaksızın kendi kendilerine kullanırlar. Yani YY birimlerinin idari özerkliği vardır (Siyasal değildir). 4. Bunların kendi bütçeleri vardır. 5. Kendi organları ve yöneticileri vardır. 6. Karar alma ve personel bakımından merkezden özerktirler. Merkez ve taşra örgütlenmesi arasındaki hiyerarşik ilişki merkezle yerinden yönetim birimleri arasında söz konusu değildir. Onlar arasındaki hiyerarşik ilişki idari vesayet ilkesine dayanır. Merkezle taşra örgütlenmesi arasında hiyerarşik, merkezle, özerkliğe sahip olan YY birimleri arasında idari vesayet ilişkisi bulunur.

Üniter devlet sistemi, merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasında işbirliğini, bütünlüğünü sağlamak amacıyla yönetimin bütünlüğü ilkesini kabul eder. Amaç: devlet yönetiminin belli bir uyum içerisinde çalışmasını 2 yolla sağlar.

Hiyerarşi: Hiyerarşi aynı yönetim düzeyi içinde olur. Merkez ile taşra örgütlenmesi arasındaki ilişkidir. Bunun sonucunda üstte bulunan memur altta bulunan memura emir ve talimat verir. Altta bulunan memurun yaptığı işleri onaylar, değiştirir, kaldırır, iptal eder. Üstteki memur, alttakının disiplin amiridir. Altta bulunan memurun yaptığı

işlemi erteleyebilir, değiştirebilir. Aynı tüzel kişilik çatısı altında üstteki birimin alttaki birimle olan ilişkisidir. Üstteki birimin alttaki birimi denetlemesidir. Alttaki birim üstekine bağlıdır.

İdari vesayet: Birbiri ile hiyerarşik yapı içinde bulunmayan 2 yapı arasındaki bir konumdur. Merkezi idarenin yerinden yönetim birimleri üzerinde sahip olduğu denetim yetkisidir. İdari vesayet yetkisi her zaman veya merkezin dilediği zaman kullanabileceği bir yetki değildir. İdari vesayet, merkezin hukukilik ve yerindelik bakımından, yerinden yönetim kuruluşunun yapmış olduğu işlemin denetlenmesidir. Günümüzde, demokratik üniter devletlerde idari vesayet yetkisinin yalnızca hukukilik yetkisiyle sınırlı bir yetki olarak kullanıldığını görürüz. Demokratik düzenlerde yargı organına bırakılmış bir yetkidir. Merkezi yönetimin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisidir. İstisnai yetkidir.

Özerk Üniter Devlet: Birleşik Krallık ve Fransa artık klasik üniter devlet özelliğini göstermiyor. Birleşik Krallık 4 bölgeden oluşuyor; Galler, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda. Birleşik Krallığı oluşturan farklı ulusal unsurların taleplerini karşılayabilmek için B.K parlamentosu 1997 yılında 3 ayrı yasa çıkardı. Belli konularda düzenleme yapması için bölge meclisleri kuruluyor ve yetki merkezin bölgelere yasa yoluyla tek taraflı olarak verdiği yetkilerle ortaya çıkan yeni bir devlet biçimidir. Ülkenin en büyük parçasını oluşturan İngiltere'nin hiçbir yetkisi yoktur. Özerklik verilen toprağın yüzdesi çok düşüktür. Ülkenin büyük bölümü merkezden yönetim ve klasik üniter devlet ilkesine göre yönetiliyor. Merkezi parlamento tarafından bir kanunla bu yetkiler veriliyor. Tek taraflı olarak verilen yetkiler yine tek taraflı olarak geri alınabilir. 2. Olarak İskoçya dışında yargılama yetkisi halen merkezi devletin elindedir. Üniter bir devlet olarak kabul edilir. Özerk bölgeler: Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya'dır. Londra parlamentosu, İngiltere'yi yönetir. Yetki devri yoluyla yetkilendirilen yerinden yönetim birimlerine dayalı devlet üniter kabul edilir. Bu yetkiler her zaman merkez tarafından tek taraflı olarak geri alınabilir. Yasama niteliğinde yetkilere sahip bu bölgeler klasik üniter devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Bunun için Özerk Üniter devlet adını almıştır. Buna karşılık, federal ve bölgesel devletten farklı olarak bu yasama niteliğindeki yetkiler merkez tarafından tek taraflı olarak aktarılmış olup anayasa ile güvence altına alınmamıştır. Bu sebeple yasa yoluyla verilen yetkiler geri de alınabilir. Her bir kanun merkeze, sadece merkezin kullanabileceği yetkiler veriyor. Örneğin sosyal güvenlik, uluslararası ilişkiler, göç, sığınma, ticaret, mali, anayasa gibi konular merkezi devlete aittir. Merkezin yetkilerinin, federal ve klasik, bölgesel devlet biçimine göre çok geniş olduğunu görürüz. Bu yetkilerin özelliği; bunların ülkeyi tek bir ekonomik ve toplumsal yapı içinde tutmayı amaçlayan yetkiler olmasıdır. Diğer 3 bölge parlamentosunun sağlık, eğitim, çevre, yerel yönetim, ulaşım, planlama, kültür ve sadece İskoçya için güvenlik ve adalet yetkileri vardır. Yalnızca İskoçya da vergi koyma yetkisi vardır.

Her bölgenin kendi meclisi vardır ve ilgili bölgenin kendi halkı tarafından seçilir. İçinden bir hükümet çıkarıyor ve bir Başbakanı vardır. Bu yetkiler o şekilde kullanılıyor. Merkezi hükümet bölgelere bıraktığı konularda herhangi bir düzenleme yapmıyor. Yaparsa hiçbir şey olmaz. Bölgelerin yetkileri arasında farkların olmasının nedeni: tarihsel nedenleri vardır. Farklı nedenlerle BK lığa katılmışlardır. Birbirlerinden farklı talepleri vardır. İskoçya daha geniş yetkiler istiyor mesela. Tarihsel, hukuki olarak da bu 4 bölge ulus olarak tanımlanıyor. Ama bu devlet biçimini üniter olmaktan çıkartmıyor.

Bölgelerin, kendilerine ait özerk bir bütçeleri vardır. Kendileri kaynak yaratabilirler, vergi toplarlar. Bu yarattıkları kaynakları da diledikleri gibi harcamaları en temel özellikleridir (İskoçya). Merkez bu bölgelere belli bir kaynak aktarıyor. Bu bölgelerde nasıl kullanacağına karışmıyor ama kaynak merkezden geliyor. Bu sebeple BK üniter bir devlet olarak tanımlanıyor.

Fransa: 2003-2004 ve 2008 yılında yapılan reformlarla Fransa Klasik üniter devletten, özerk üniter devlete döndü. Bunun nedeni: daha etkin kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde görülmesini sağlamaktır. Bugün bölgeler en önemli yerinden yönetim birimidir. Bugün bölge, il, özel statülü yerinden yönetim birimleri ve belediyeler var. Bunlar siyasal nitelikte değil idari nitelikteki yetkililerdir. Her yerinden yönetim biriminin kendi meclisi vardır. Fransa'daki özerk üniter devletin en önemli özelliklerinden biri, bu yetkilerin farklı yerinden yönetim birimleri arasında iç içe geçmiş olmasıdır. Bu sebeple yerinden yönetim birimleri sıkı bir ilişki ve işbirliği içindedirler. Korsika meclisinin yetkileri diğer yerinden yönetim birimlerinin yetkilerinden daha geniştir. Korsika meclis, sadece yasaya aykırı olmamak kaydıyla düzenleyici işlem yapma yetkisi vardır. Bölgelerin oluşturulmasının arkasında yatan sebep, kimlik siyaseti değildir. Amaç kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesinin sağlanmasıdır.

Subsidiarite ilkesi (Yetkide yakınlık) Bir kamu hizmetinin olabildiği kadar halka en yakın yerinden yönetim birimi tarafından görülmesidir. Bu birim tarafından hiç veya yeterince yerine getirilmeyen hizmetlerin bir üst

birim tarafından üstlenilmesidir. Bir yerel yönetim birimi halka ne kadar yakınsa o yörenin gereksinimlerini o kadar iyi bilir ve en yakın olan en iyi hizmeti verir. AB tarafından da en önemli ilkesidir. Bu ilke, yönetimin temel ilkesi olarak Fransa'nın anayasasına girmiştir. 2008 yılındaki Anayasa değişikliği ile farklı diller, Fransa'nın ulusal kültürünün bir parçası sayılmıştır.

Desantralize (Merkezsizleşme): Merkezin yetkilerinin yerel yönetim birimlerine aktarılmasının esas olduğunun benimsenmesi.

Fransa da tamamen kamu hizmetlerinin daha iyi daha etkili olarak yürütülmesi amacı ön plandayken, BK da daha siyasal nitelikteki amaç ön plandadır. Fransa'nın en önemli özelliği, bu yerinden yönetim birimleri arasında bir hiyerarşi yoktur.

Federal Devlet: Birbirinden farklı, bağımsız unsurların bir araya gelerek ortak bir ulus devlet çatısı altında birleşmesidir. Dış egemenlik bakımından federal devletle, üniter devlet arasında hiçbir fark yoktur. İç egemenlik bakımından fark önemlidir. Federal yani merkezi devlet, İç egemenliğin kullanılması bakımından üniter devletten ayrılır. Farklı unsurların kendi iradeleri ile bir araya gelip ortak bir ulus devlet çatısı altında yaşamalarını sürdürmeleri, bazı yetkilerini kullanmaya devam ederler. Özerklik ilkesi federal devletin ayrılmaz parçasıdır. Federe birimler kendi varlıklarını, kimliklerini federal devletten ayrı olarak devam ettirirler. Federal devletin en önemli özelliği, yönetimin iki uçlu olmasıdır. 2 Ayrı yönetim yapısına dayalı bir devlettir. 1. Bütün ülkeye ilişkin yetkileri kullanan federal yönetim ve 2. Federal devleti oluşturan eyaletler yani federe devletler. Bu 2 yönetim düzeyi arasında hiyerarşi yoktur. Merkezi yönetim, federe yönetimlere emir veremez, verdiği kararları iptal edemez, kaldıramaz. Bu nedenle “farklılık içinde birlik” olarak adlandırılır. Farklılık en az 2 tane olan federe birimlerin bir araya gelmesi ve aynı zamanda da bunların toplamından oluşan bir federal devlet yapısının olmasından kaynaklanmaktadır.

Yapıcı Federalizm: Kamu hizmetlerinin görülmesinde sivil toplumu işin içine katmayan, federal ve federe devletler arasındaki ilişkileri, federal devletin yetki alanını geniş tutan bir yönetim biçimine denir.

Federalizm: Yapıcı federalizmin tam tersidir. Hizmetlerin görülmesinde ve yetkilerin paylaşılmasında federe devletlere öncelik tanıyan federal devlete, icrai federalizm denir. Olabildiği kadar küçük ve sınırlı bir merkezi devlet, kamu hizmetlerinin ve yetkilerinin geniş bir şekilde eyaletlerde federe devletlerin elinde olmasıdır.

Nominal Federalizm: Adı olan kendisi olmayan federalizm. Yani, federe devletlerin yetkilerini yönetsel yetkilerle sınırlı olduğu federal devlet biçimine denir. Federe devletlerin idari, yönetsel yetkilerinin ötesinde siyasal birtakım yetkilere de sahip olması. Oysa nominal federalizm, yalnızca idari sınırlı biçimde federe devletlere yetki verdiği için adı federe devlet olmasına rağmen ya hiç olmayan ya da sınırlı olan bir devlet biçimidir. Arjantin, Brezilya ve Venezuela.

Tek yapıli devletin unsurları; Devletin tekliği ve bölünmezliği vardır. Devletin 3 unsuru: egemenlik, ülke ve ulus. Bunların tekliği ve bölünmezliği.

Federal devletin temel özellikleri: 1.Siyasal iktidarın bölünmesi ilkesi, devleti oluşturan 3 unsurun bölünebileceği oluyor. Federal devlet düzeni, tek yapıli devletteki egemenlik anlayışının tam tersidir. Üniter devlet tek ve bölünmezdi. Egemenlik, parlamento ve merkezden örgütlenen yargı aracılığı ile kullanılır. Federal devlette egemenlik de, ulus da bölünebilir. Federal devlet belli ölçüde yetkilerle donatılmış federe devletlerden oluştuğu için federe devletlerin her birinin kendi alanlarında kullanabilecekleri egemenlikleri vardır. Egemenlik anlayışı çokludur. Yani çoklu yasa çoklu yargı anlamına gelir. Yasa yapma yetkisiyle donatılmış merkezi bir parlamento vardır. Aynı zamanda federal devleti oluşturan federe devletlerin kendi parlamentoları, hükümetleri ve yargı düzeninin olması gerekir. Bu parlamentolar, federe devletin yetisi neyse o alanda yasa yapma yetkisine sahiptir. Her iki yönetim düzeyinin kendisine ait yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Her iki düzeyde de bu yetkilerin kullanılması yoluyla egemenlik paylaşılıyor. Yargı yetkisi de bölünmüştür. Federe devlet içinde örgütlü bir yargı düzeni vardır. Konulan kurallarla ilgili uyuşmazlıkları çözer. Ayrıca her federe devletin içinde örgütlenmiş ayrı ayrı yargı düzeni vardır. Egemenliğin çokluğundan söz edilir. Federe devletler, kendilerine ait egemenliklerini,

1. Kurucu iktidar işlevi görürken kullanılır. 2. Bütün ülkeyi ilgilendiren yasaların yapılmasında kullanılır. Federal devletlerin merkezi parlamentoları 2 kanatlıdır. Biri tüm halkı temsil eder ikincisi ise federal devletleri oluşturan federe devletleri temsil eder. Merkezi devlet egemenliğini bütün ülke sınırları ve o ülkede yaşayan bütün insanlar üzerinde kullanıyor. Federe devlet ise kendi yetki alanları içine giren insan topluluğu ve coğrafi bölge sınırları itibariye kullanıyor.

Federe devletler, ikinci meclisler yoluyla ya anayasanın yapılmasında, değiştirilmesinde ya da tüm ülkeyi ilgilendiren yasaların yapılmasında sürece katılırlar. Federal parlamentonun iki kanatlı olması şart. Çünkü egemenlik çokludur. Her federe devletin kendine ait bir egemenlik alanı vardır.

2. Ulus unsuru: Üniter devlette farklı etnik kökenler ve inançlar bir ulusu oluşturan bireyler arasında farklı olabilir. Ama bu birden fazla ulus olduğu anlamına gelmez. Federal devlette, tek bir ulusta olabilir birden fazla ulustan da oluşabilir. Çoklu ulusa da dayanabilir. Üniter devlet bunu dışlar. Almanya, ABD tek bir ulusa dayalıdır. Kanada, Fransızca ve İngilizce konuşanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Belçika da aynı. Federal devlet, birden fazla ulustan oluşuyorsa birden fazla resmi dili vardır. G.Afrika da resmi dil 11, Hindistan da 18 resmi dil vardır.

3. Ülke bütünlüğü: Üniter devlette, yönetsel nitelikte bölünme olabilir, il, ilçe gibi. Bunların hiçbirinin siyasal nitelikte yetkileri yoktur. Yani yasa koyma ve yargılama yetkisi gibi. Federe devlette kendi sınırları içerisinde kendi siyasal yetkilerini kullanırlar. Varsa yargı yetkilerini de kullanırlar. Çok ülkelilik, federe devlet biçiminin temel özelliğidir. Hem federal devletin ülkesi hem de federe devletin kendi ülkesi vardır.

4. Merkeziyetçi olmama ilkesi: Federal devlet, eyaletlerden ve federal devletten oluşur. 1 Federal devletin olması için en az 2 federe devletin olması gerekir ve bir de merkezi devlet olmalıdır. Hem merkezi devlet hem de federe devletlerin merkezinin toplamı bu merkezlerin toplamını oluşturur. ABD de 50 eyalet var ve merkezi devletle birlikte 51 iktidar merkezinden oluşur. Federal devletin çok merkezli olma ilkesi en temel özelliğidir. Merkeziyetçilik klasik üniter devletin bir ilkesiydi. Bir siyasal sistemde yetkilerle donatılmış birden fazla merkezin olması merkeziyetçi olmamaktır. Federal devlette yetkilerin merkeziliği değil, genelliği söz konusudur. Yetki genişliği ilkesi federal devlet ilkesiyle bağdaşmaz. Çünkü federe devletlerin zaten kendilerine ait yetkileri vardır ve bu yetkileri kullanırlar. Bir yönetimden diğer yönetime yetki devri olabilir. Ancak yetki genişliği olmaz.

5. Anayasanın üstünlüğü ilkesi: Bütün federal devletler yazılı ve katı bir anayasaya dayalıdır. Federalizm yazılı bir anlaşmadır ve bu anayasa da federalizm anayasasıdır. Bu sebeple anayasası olmayan bir federe devlet olmaz. Üniter devlette, anayasa yazılı da olabilir veya olmayabilir. Katı da olabilir veya olmayabilir. Federal bir anayasa, kişi hak ve özgürlükleri, devlet organlarının kuruluşu ve işleyişi gibi konuların yanı sıra federal devletle, federe devletler arasındaki ilişkiyi, görev ve yetki bölüşümünü de düzenleyen anayasalardır. Katı ve yazılı bir anayasa, federal devletin olmazsa olmaz unsurudur. Bu anlaşmayı sağlayan anayasa olduğuna göre bunun federal devlette 2 izdüşümü vardır; 1. Anayasanın yapılmasına ve değiştirilmesine federe devletlerin katılması 2. Bütün ulusu ilgilendiren yasaların yapılmasına ve değiştirilmesine yine federe devletlerin katılması 3. Mutlaka anayasanın yazılı ve katı olması. 2 Yönetim düzeyi arasındaki ilişkiyi yetki bölüşümünü güvence altına alıyor olması nedeniyle katı anayasa şarttır. Yetki düzenleme ve uyumsuzluklarına ilişkin hiçbir düzenlemesi olmayan federal devlet anayasası olmaz. Böyle bir anayasa yoksa o devlet federal devlet olmaz. Çünkü güvencesi yok. Bir başka özelliği

Anayasal yetki bölüşümü: Bütün federal devletlerin anayasalarında buna ilişkin birden çok düzenleme bulunur. Federe devletle federal devletler arasındaki yetki bölüşümü gerçek anlamda bir federal devletten söz edebiliyorsak her iki yönetim düzeyine de ait olan münhasır yetki konularının olması gerekir. Federal devlette, merkezi devlet dış egemenlik bakımından tek bir devlet olmasını sağlayacak ve tek elden kullanılması zorunlu yetkileri elinde bulundurmalıdır. Uluslararası ilişkiler, para birimi, merkez bankası gibi tek elden yürütülmesi gereken ve dış egemenlik bakımından da tek bir devlet niteliği taşıması bakımından merkezi devlete ait olması gerekir. Tek elden yürütülmesi zorunlu olmayan konular federe devlete bırakılmıştır. Sağlık, eğitim, polisiye gibi yetkiler federe devletlere bırakılır. Bazılarında federe bazılarında federal devletin yetki sınırları çok geniştir. Günümüz çağdaş federal devletlerde merkezi devletin federe devletler aleyhine yetki alanını genişlettiğini görüyoruz.

Federe devletler arasındaki yetki paylaşımı anayasa da yer alması kuraldır ve çeşitli biçimlerde olabilir. Yetki bölüşümünün anayasa da olmasında 2 yaklaşım söz konusudur.

1. Avrupa tipi federalizm: merkezi devletin yetkilerini tek tek sayıp, sayılmayan bütün yetkilerin eyaletlere bırakılması. Bu federe devletleri güçlendiren bir yetki bölüşüm biçimidir. İleride ortaya çıkabilecek yeni konulara ilişkin düzenleme yetkisi federe devletlere bırakıldığı için. Örnek; ABD, İsviçre, Brezilya, Bosna Hersek, Pakistan ve Rusya'dır.

2. Amerikan tipi federalizm: Eyaletlerin yetkilerini tek tek sayılıp, sayılmayan yetkilerin kendiliğinden merkezi devlete bırakıldığı durum. Bu durumda merkezi devlet güçlendirilmiş olur. Çünkü ileride ortaya

çıkabilecek yeni konular merkezi otoritenin yetki alanına sokulmuş olur. Örnek; Hindistan, Kanada, Nijerya, Avusturya, Malezya anayasaları örnek verilebilir. Hem federe devletler hem de merkezi devlet birlikte düzenleme yaparak ortak yetkiler listesine dayalı bir federal devlet yapısı vardır. Bu durumda federe devletler o alanda federal devlet yapmadı ise düzenleme yapabilir. Eğer o alanda federal devletin bir yasal düzenlemesi var ise o yasaya aykırı olarak federe devlet düzenleme yapamaz. Federal devlette, normlar hiyerarşisi bakımından özel bir kural vardır.

Federalizm de federe devletlerin yetkilerinin ne kadar az ya da ne kadar çok olduğu önemli değildir. Önemli olan federe devletlere bırakılan münhasır yetki alanı içinde federe devletin federal devletle işbirliği yapma zorunda olmamasıdır.

Avrupa ve Amerikan tipi Federalizm ayrımı:

1. Federal yasalar, federe devlet yasalarının üzerindedir. Avrupa tipinde merkezi yönetimin yetkileri oldukça geniş. Çok sayıda konuda düzenleme yapabiliyor. Ama merkezin yaptığını uygulama ve burada çıkan uyuşmazlıkları çözme görevi federe devlete bırakılmıştır. İsviçre’de cezaya ilişkin kanun düzenlemesi yapma yetkisi federal parlamentoya aittir. Bu ceza kanununun uygulanması yetkisi kanton yönetimine aittir. Ceza kanununun uygulanması ve kanundan çıkacak uyuşmazlıkları çözme yetkisi yine kanton mahkemelerine aittir. Uluslararası antlaşmaların yapılması ulusal güvenliğin sağlanması ulusal para birimi gibi dış egemenlik bakımından federal devlette olması gereken konularda düzenleme yetkisi federal devlette bunu uygulama ve uyuşmazlıkları çözme yetkisi ise federe devlette olur. Bu Avrupa tipi federalizmdir. Avrupa tipi federalizm de konular ya da ilgili konulara ilişkin yasal düzenleme yetkisi genel olarak federal yönetim alanına bırakılmıştır. Ama federal parlamentonun çıkardığı kanunların uygulanması ve bundan çıkan uyuşmazlıkların karara bağlanması yetkileri ise federe devlet organına bırakılmıştır.

Amerikan tipi federalizm: konunun bir bütün olarak ya federal devlette ya da federe devletlerde olmasını anlıyoruz. Bir bütün olarak bir konunun ya da bir alana ilişkin düzenleme yapma onu uygulama ondan çıkan uyuşmazlıkları çözme yetkisi bir yönetim alanına bırakılmıştır. ABD ve Latin Amerika da görülen federal devletlerin bu yetki paylaşımını yaptığını görüyoruz.

2. Avrupa tipi federalizm kantonların, prensliklerin kendi istekleriyle bir araya gelip bir federal devlet kurmalarıyla oluşmuştur. Federal devlet bu devletlerden çok daha sonra kuruldu.

3. Amerikan tipi federalizm de konu bakımından yetkiler 2 yönetim düzeyi arasında kesin bir biçimde birbirinden ayrılmıştır. Eğitim Federe devletlere ait bir konu olup eğitime ilişkin bütün düzenlemelerin yapılması uygulanması ve bundan çıkacak uyuşmazlıkları çözme yetkisi federe devlet düzeyindeki yasama yürütme ve yargı organları aracılığı ile yapılır. Buna ilişkin federal devlet organlarının herhangi bir yetki ya da müdahalesi yoktur.

Bu yetki bölüşümü meselesinde iki konu vardır. **Anayasal yetki bölüşümü**, Avrupa tipi, Amerikan tipi olması o devlet biçiminin federal olarak tanımlanması bakımından belirleyici değildir. Belirleyici olan 1. Federal devletin, mutlaka tek bir ulus devlet, dış egemenlik bakımından tek bir ulus devlet biçiminde olmasını sağlayacak münhasır yetkilere sahip olmasıdır. Bu münhasır yetkiler; para biriminin belirlenmesi, gümrük konusu, uluslararası antlaşmaların yapılması, ulusal güvenlik, dış güvenlik konuları eğer federal devlete bırakılmamışsa federe devletlerin bu alanlarda yetkisi varsa o zaman biz o devlete federal devlet diyemeyiz. Federal bir devlet olarak tanımlama için: mutlaka yukarıdaki konuların federal devlete bırakılmış münhasır konular olması gerekir.

İkinci olarak federe devletlerin yetki alanının geniş ya da dar olması o devleti federal devlet olarak tanımlamamız bakımından birinci önemde değildir. Bir devleti federal devlet olarak tanımlayabilmek için ne kadar az bir yetki alanı tanımlanmış olursa olsun o yetki federe devletlere tanınan yetkileri federe devletlerin federal devletlerin müdahalesinden uzak biçimde kullanılabilmesi gerekir. Yani federe devletlere de ait münhasır yetki alanının bulunması gerekir. Federe devletlerin mali kaynağa ve bu mali kaynağın da anayasa ile güvence altına alınması zorunludur.

İkisinde ortak noktalar:

1. Federe devlete verilen yetkiler anayasa ile güvence altına alınır.
2. Merkezi devlet Federe devlete haber vermeden tek taraflı olarak federe devletin haklarını alamaz. Tek taraflı hak da bırakamaz.
3. Federal yasa yapılırken federe devletler de olur

4. Mutlaka 2 yönetim düzeyinin de gelir kaynağı olmalı yoksa federal devlet diyemeyiz.
 5. Federe devletin, geliri de bütçeyi de kendi istediği gibi harcama ve kullanma hakkı vardır.
 6. Federal anayasa hem federe devleti hem de federal devleti bağlayan üst hukuk normudur. Bütün hukuk normları federal anayasaya uygun olmak zorundadır.
 7. Federe devletler kendi parlamentolarında yasa yaparlar. Bu yasa federe devlet sınırları içindedir ve uygulanır.
 8. Her federe devletin kendi anayasa mahkemesi vardır. Anayasa mahkemeleri, federe devletin anayasasının federal anayasaya aykırı olup olmadığını denetler. Normlar hiyerarşisinde, federe devlet anayasaları en alttadır. Federe devlet anayasası ile federal anayasa arasındaki çatışmayı federal anayasa mahkemesi çözer.
- Yetki paylaşımı yönünden konu paylaşımı** şöyledir; Bir devleti tek bir ulus görüntüsüne sokan ve tek elden yürütülmesi gereken konular merkezi devlete aittir. Örneğin ulusal savuma, merkez bankası, ortak para birimi, gümrüklerin denetimi ve uluslararası antlaşmalar, bunlar merkezi devlette olmalıdır. Bunun dışında sağlık, eğitim, asayişin sağlanması, altyapı gibi tel elden yürütülmesi zorunluluğu olmayan alanlar federe devletlere bırakılır. Günümüzde uygulama, karar alma ve finanse etme bakımından bu 2 düzey birbiriyle yakın ilişki içindedirler. Ancak federe devlete bırakılan münhasır yetki alanı içinde kalmış bir konuya ilişkin olarak federe devletin, merkezi devletle işbirliği yapma zorunda olmamasıdır.

Federe devletlerde yetki bölüşümü:

- 1.**Simetrik federalizm:** Bütün federe devletlerin aynı yetkilere sahip olduğu federal devlete denir.
- 2.**Asimetrik federalizm:** Federe devletlerin yetkilerinin aynı olmamasıdır. Yani diğer federe devletlere göre anayasayla daha geniş veya daha az yetkiyle donatıldığı federal sistem. Örneğin Hindistan, Rusya, Kanada. Dil ve kültürel bakımdan bir kısmı farklılık taşıyorsa bu federe devletlere daha geniş ya da özel kültürel haklar tanınabiliyor.

Federal devlet ya da merkezi devlet: Bütün ülke içinde yetkili. İkincisi ise bu federe devletler, anayasanın kendilerine tanıdığı yetkileri yine anayasada belirtilen ilke sınırları içinde kullanırlar. Federe devletlerin yetki alanları ya coğrafi sınırlar içerisinde veya topluluk esasına göre belirlenebilir. Federal devletlerin çok büyük bölümü Belçika dışında hep coğrafi bölge esasına bağlı olarak belirlenmiştir. Topluluk esasına göre federe devletlerin yetki sınırlarının bölünmesi ise belli bir etnik grup belli bir inanç grubu ya da belli bir kültürel grup bakımından yetkili olması anlamına gelir. Coğrafi bölgeye göre değil belli bir kişi topluluğunun üzerinde kendini gösterir. Federe devletlerin yetki sınırlarının topluluk esasına göre belirleme **korparatif federalizm** olarak adlandırılır. Federalizmin dinsel, kültürel, etnik bir unsura dayalı kurulmuş olmasıdır. Belli bir dinsel, kültürel, etnik unsura sahip olan vatandaşlar ülkenin neresinde olursa olsun federe devletin özelliklerine dahildirler. Nüfus unsuru göz önüne alınarak toplumsal faaliyetler 2 yönetim alanına bölünürler. Federal yönetim etkisi tüm vatandaşlar üzerindeyken, federe yönetimin etkisi nerede yaşadıklarına bakılmaksızın sadece belli bir toplumsal grup üzerindedir. İlk örnek başlangıcı Avusturya- Macaristan olarak gösterilir. Bu imparatorluk çok ulusluydu ve buna çare olarak korparatif federalizmi benimsedi. İkinci örnek Osmanlı'daki "Millet" sistemidir. Bu sistemde padişah inanç esasına dayalı olarak belli konularda düzenleme yapma, o cemaati yönetme ve belli alanda çıkan uyuşmazlıkları cemaat içindeki kendi mahkemeleri yoluyla çözme yetkisini cemaatlere tanıyordu. Mezhep esasına dayanıyordu. Millet cemaatlerinin temel yetkileri: her cemaat kendi üyeleri tarafından seçilen bir meclis ve o meclis içinden çıkan yöneticiler tarafından yönetiliyordu. Bu cemaat meclislerinin kişi hukuku, miras, borçlar, ticaret konularını düzenleme ve bu konulardan kaynaklanan uyuşmazlıkları da cemaat mahkemelerinde çözme yetkileri vardı. Osmanlı millet sistemi bir korparatif federalizm örneği değildi. Çünkü Osmanlı, bir federal devlet değildi. Ama o federalizmin ilk nüvesi denilebilecek temel özellikleri göstermesi bakımından önemli bir örnektir. Tıpkı Avusturya-Macaristan örneğinde olduğu gibi.

Çağdaş anlamda ülkenin neresinde yaşadığına bakılmaksızın topluluk esasına dayalı bir federal sistem Estonya'da vardır. Alman ve Yahudi topluluklarının kendi içlerinde seçtikleri meclisleri vardı. Bu meclisler tarafından yönetiliyorlardı. Bu meclislerin yetkileri kültürel konularla sınırlıydı.

1960 Kıbrıs Anayasası: 2 federe devlet olarak kuruldu. Rum ve Türkler adanın her tarafında dağınık yaşadıkları için korparatif federal bir devlet olarak kuruldu.

Her federe devletin bir meclisi vardır. Bu meclislerin; 4 konuda kural koyma yetkisi; Kültür, eğitim, dini konular spor kuruluşları. Her federe devletin yetki alanı içindedir. Yine bu federe devletlerin bu konularla ilgili uyuşmazlıkları çözen kendi mahkemeleri de vardır. 1960 Kıbrıs anayasası tamamen özel topluluk esasına

dayalı bir federal devlet biçimi öngörür. Ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın bu federe devletin üyesi o federe devletin parlamento seçimlerinde oy kullanabilir. Günümüzde korparatif federalizmi benimseyen örnek yoktur. Ama buna en yakın örnek 1993 tarihli Belçika anayasası olup federe devletler hem coğrafi bölge hem de topluluk esasına göre belirlendi. Belçika da anayasa, bölge esasına göre kurulan bölgelerin yetkileriyle topluluk esasına göre kurulan bölgelerin yetkilerini birbirinden ayırmıştır. Bütün federe devletler aynı yetkilere sahip değildir. Belçika da 6 federe devletin her biri kendi yasama meclisi ve kendi içinden çıkardığı bir yürütme organı bulunuyor. Bunun istisnası Flamanca konuşanlar topluluğudur.

Coğrafi bölge esasına göre kurulmuş federe devletler ile topluluk esasına göre kurulmuş olan federe devletlerin yetki bakımından özellikleri: 1. Topluluk esasına göre kurulmuş federe devletler eğitim, anadil, din, kültürel konularda yetkili, bu alanlarla sınırlı yetkilere sahip federe devletlerdir. Coğrafi bölge esasına göre kurulmuş federe devletlerin ise daha geniş bir biçimde ekonomi ile ilgili maliye, sanayi, altyapı, gibi konularda yetkileri bulunuyor. Bu iki sistemin yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Bu toplulukların kendi meclisleri yürütme organları birbirinden ayrılmıştır. Eğer bir coğrafi sınır gözetilerek bir federe devletler oluşturuldu ise biz buna coğrafi bölge esasına dayalı federalizm diyoruz. Eğer federe devletler o federal devlet ülkesinin neresinde yaşadığı önem taşımaksızın belli bir nüfusu gözeterek oluşturulmuşsa biz buna topluluk esasına dayalı federalizm diyoruz.

Federalizmin kurumsal yapısı: Federal devlette yasama organı mutlaka 2 kanatlıdır. Bu meclisten biri mutlaka federe devletleri temsil etmek durumundadır. Federal parlamento yasaların yapımında veya anayasanın değiştirilmesinde ya federal parlamentonun her iki kanadı da aynı ya da birbirine çok yakın yetkilere sahiptir. Federal devlete özgü bir hükümet sistemi yoktur. Herhangi bir hükümet sistemi federal devlet biçimi ile bir arada yürüyebilir. ABD ve Latin Amerika'daki federal devletlerin başkanlık sistemi ile yönetiliyorlar. Buna karşılık Almanya, Hindistan, Avustralya gibi devletler parlamenter sistem ile yönetiliyorlar. Rusya, Avusturya yarı başkanlık sistemi ile yönetiliyorlar. Yürütme erki bakımından bütün ülkeyi ulusu temsil eden parlamentonun eyaletleri temsil eden meclise göre üstünlüğü vardır. Ancak özellikle federe devletleri ilgilendiren konularda birinci meclisin federe devlet meclisinde genellikle federal devlet düzenindeki yasama ve yürütme kompozisyonu nasılsa ona benzer yasama ve yürütme kompozisyonu vardır. Her federe devlet kendi vatandaşının oylarıyla bir parlamento seçer ve yürütme organıyla yetkilerini kullanır. Hem federal devlet hem de her bir federe devlet düzeyinde ayrı ayrı yargı organı, mahkemeleri vardır. Her federe devletin kendi haklının onayına sunduğu kendi parlamentolarında kabul ettikleri anayasaları vardır. Federe devleti yasaları, federe devletin anayasalarına aykırı olamaz. Bunu o federe devletin en üst mahkemesi denetler. Federe devlet ile merkezi devlet arasındaki uyuşmazlıklara en üstteki merkezi yargı organı bakıyor. Yani anayasa mahkemesi. ABD de her federe devlet 2 meclisli bir parlamentodan oluşur. Başkanlık sistemi gibi her federe devlet vali adı verilen doğrudan halkın seçtiği bir yönetici tarafından yönetilir. Almanya ve Avustralya da federe devletler tek meclisli bir parlamentodan oluşur. Bu parlamentonun içinden çıkan on karşı sorumlu olan bir hükümet tarafından yönetilirler. Federe devletlerde klasik parlamenter sistemi benzer bir yönetim yapısının olduğunu görürüz. Almanya da eyaletlerde de parlamenter sistem vardır. Federe devletin anayasası federal yasalara, federal devletin anayasalarına aykırı olamaz. Bu aykırılığı denetleme yetkisi federal devletin en üst mahkemesine aittir.

En önemli özellik: federal devletle, federe devletler arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Yetki devri, yetki genişliği gibi araçlar federal devlet biçimine uzaktır. Federal devlet, federe devletleri denetleme yetkisine sahip değildir. Federe devletlerin, federal anayasaya uygun olup olmadığını denetleme yetkisi bir tek yargı organına ait bir yetkidir. Ne bir idari vesayete dayalı ne de hiyerarşik bir ilişki söz konusu değildir.

Federe devletlere bakacak olursak kural olarak görülen merkezdeki hükümet sistemi ne ise federe devletler de onu benimsiyorlar. Federal devletlerde, üniter devlette görülen yerel yönetimler bulunur, belediyeler, iller gibi. Bunların özerkliği vardır. Federe devlete bağlı özerk yerel yönetimler bulunur.

Federalizm neden seçiliyor: 1. Geniş topraklara sahip olan merkezden kontrol edilmesi güç olan ülkeler benimsemiştir. Brezilya, Kanada, Rusya, Hindistan, ABD.

2. Bağımsız devletler çeşitli nedenlerle gevşek bağlarla konfederasyon biçiminde bağlanmış olan bağımsız devletlerin ulusa birlik ve merkezi otoritenin içinde yer almak istemeleri durumunda birtakım yetkileri kendilerinde tutabilmelerini sağlayan federe devlet biçimini tercih ediyor. Örnek İsviçre. Çünkü ulus devlet çatısı altında olmanın avantajlarından yararlanmak istiyorlar. Zaten bağımsız devlet oldukları için bir üniter devlet içinde bütün yetkilerini de merkeze bırakmak istemiyorlar. Böylece federal modeli tercih ediyorlar.

3. Federal devletler, aynı zamanda etnik dinsel unsurları aynı çatı altında tutmanın en uygun aracı olabilir. Bir ülke etnik, kültürel, inançsal olarak türdeş olmayan bir yapı gösteriyorsa bunları bir arada tutmanın aracı federe devlettir. Hindistan ve Belçika. 4. Aşırı otoriter deneyim yaşayan ülkelerin bu deneyime tepki olarak federalizmi benimsiyorlar. Uzun yıllar bu tip rejimler altında yaşayan devletler bu rejimlerin tekrar yaşanmasını engellemek için federalizmi benimsemişlerdir. 1811 Venezuela 1824 Meksika, 1891 Brezilya, 1853 Arjantin anayasaları buna örnektir.

Bölgeli Devlet: Devlet tek ve bölünmez, ülke bölgelere ayrılabilir, Anayasanın üstünlüğü temel özellikleridir. İtalya, bölgeli devlette, federal devletle benzer biçimde bütün ülkenin bölgelere ayrıldığını görürüz. Bir anayasa etrafında birleşen anayasanın yetkilerini belirttiği ve güvence altına aldığı bir devlet biçimidir. Bazı özellikleri bakımından federal devlete bazı özellikleri bakımından üniter devlete benzeyen bir devlet biçimidir. Genel olarak, siyasal yetkilerle donatılmış bölgelerden oluşan bunların kurumsal ve yetkilere ilişkin ayırıcı niteliklerinin anayasada yer aldığı devlet biçimine verilen isim olarak tanımlayabiliriz. Federal devletten farklı olarak bölgeli devlette, devletin tekliği ve bölünmezliği ilkesinin ve buna ilişkin bir formülün anayasalarda yer aldığına tanık oluyoruz. İtalyan anayasası, cumhuriyetin tekliği ve bölünmezliğini açık belirlemiştir. Sonuç: bölgeli devletler, üniter devlete benzer biçimde devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne benzeyen anayasal hükümlere yer veren bir devlet biçimidir. İspanya ve İtalya devletlerinde, bölgeli devlet biçimi ağır otoriter olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Her ikisinde de bir daha bu olumsuzlukları yaşamamak için değişikliğe gitmişlerdir.

Tıpkı üniter devletlerde olduğu gibi **devletin tekliği ve bölünmezliği vardır**. Egemenliğin bölünmezliği: yasama yürütme, yargı tek elde toplanmıştır, başka kimseyle paylaşılmamaktadır. Bu iki devletin anayasasına bakınca bizdeki 3.maddeye benzer düzenlemeleri görüyoruz. İtalyan anayasasında; Cumhuriyetin tekliği, İspanya anayasasında; İspanya ulusu ve ortak vatanın bölünmez bütünlüğü ve tüm İspanyolların birliği ilkesine anayasanın 3.maddesinde yer veriliyor. Fakat bazı bölgelere de siyasal özerklik verilmiştir. Yargı bölgeli devlette de taktır (Üniter devlete benzemektedir). Yasama yetkisi bakımından çokludur. Her bölgenin parlamentosu vardır. Bu parlamento anayasada bölgelere tanınan yetkileri kullanmaktadır. O alanlarda yasa yapma yetkisine sahip olup bu bakımdan federal devlete benzemektedir. Federal devlette olduğu gibi bölgeler anayasa yapımına ve bütün ülkeyi ilgilendiren yasaların kabulüne aynı ölçüde katılamıyorlar. Burada merkezi devletin ağırlıklı bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. 2 Kanatlı parlamentoları vardır. Ama bölgeleri temsil etmesi gereken 2.meclis tam anlamıyla bölgeleri temsil etmiyor (2.meclis senatodur). İtalya'da senatoda eski CB'ları, CB'nın atadığı 5 senatör üyeler vardır. Bu tamamen bölgelerin temsil edilmesini engellemektedir. Benzer durum İspanya senatosunda da vardır. Kongre ulusu temsil etmekle birlikte senatonun bir bölümü özerk toplulukların temsilcilerinden oluşuyor. Doğrudan halk tarafından seçilen temsilciler de vardır. Senato bölgeleri veya özerk toplulukları temsil eden saf bir topluluk olmaktan çıkıyor. İtalya'da 2 kanat aynı yetkilerle donatılmış. Başbakan 2 kanattan da güvenoyu almak zorundadır. İspanya'da 1.meclisin aşırılıklarını frenlemek amacıyla ikinci meclis vardır. Hem yasa hem de anayasa yapılmasında 1.meclis söz sahibidir. 2.meclisin yetkileri hemen hemen yoktur. Ülke bütünüyle bölgelere ayrılmış ve bu bölgelerin belli konularda kural koyma yetkisi bulunuyor. Bu bölgeler belli konularda oluşturdukları meclislerle kural koyma yetkisine sahiptir.

Ulusun tekliği ve bölünmezliği bakımından; bölgeli devletin üniter devlete benzediğini söyleyebiliriz. İtalya'da birden fazla ulustan söz edilemez. Etnik ve inanç bakımından bir türdeşlik söz konusudur. İspanya bakımından bunu söylemek mümkün. Farklı etnik kökenlere sahip uluslar olmasına rağmen bir tek ulustan söz eder anayasa. Buna rağmen ülke içindeki milliyetleri tanıdığını ve onların haklarını güvence altına aldığını belirtiyor. Çok ulusluluk yoktur. Tek bir İtalyan ulusu vardır. Ama ulus altında başka etnik gruplar, milletler vardır. Her iki anayasa, ülke içinde yer alan farklı dilleri ve kültürleri güvence altına almıştır. 2. Özelliği, bölgelere ayrılması ve bu bölgelere çeşitli yetkiler tanınması 3.olarak merkezîyetçi olmama ilkesi diyebiliriz. Tıpkı federal devlet gibi merkezîyetçi değildir. Her bir bölgenin statü adı verilen bir anayasası vardır. O bölgenin organlarını, kuruluşunu, görev ve yetkilerini bölge halkının hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bölgeye verilen isimdir, statü. Bu statüler merkezi devletin anayasasına ve yasalarına aykırı olamaz. Merkezi parlamentonun da onayına bağlıdır. Federal devletten farklı olarak bir denetim vardır. Bütün bölgelerin anayasayla kendilerine verilmiş ve güvence altına alınmış yetkileri vardır. Yine bütün bölgelerin anayasayla güvence altına alınmış organları, bölge parlamentoları vardır. Bu parlamentonun içinden çıkan hükümetleri vardır. Yani yetkiler merkezde tek elde toplanmış yetkiler değildir.

Çok ölkelilik var. Bölgelere yönetsel nitelikte yetkiler tanınır. Siyasal nitelikte yetkiler tanınmıştır. Yani bazı bölgelerin bazı alanlarda yasa yapma yetkilerine sahip olması.

Üniter devlet de merkezi devlet yerinden yönetim birimlerini idari vesayet ile denetliyordu. Federal devlette ise son derece istisnai olarak merkezi devlet federe devletlere müdahale eder ya da yargıya başvurur. Bölgesi devlette ise merkezi devletin idari vesayet benzeri yetkileri vardır.

Bütün bölgesi devletler yazılı ve katı bir anayasaya sahiptir. Bölgelerin yetkilerini ve bölgelerle merkezi devlet arasındaki ilişkileri güvence altına alan düzenlemeler anayasada vardır. Bölgelerin kendi mahkemeleri kendi yargı organları bulunmaz. Yargılama yetkisi merkeze ait bir yetkidir. Bu da bölgesi devleti, üniter devlete yaklaştırır.

Yetki bölüşümü: Federal devlette olduğu gibi anayasada belirtilmiştir. Hem merkezin hem de bölgelerin yetkileri tek tek sayılmıştır. Hem birlikte kullanabilecekleri ortak yetki alanları da sınırlanmıştır. Tıpkı federal devlette olduğu gibi bölgelerin ortak yetki alanında düzenleme yapabilmesi için mutlaka o alanda merkezi devletin herhangi bir düzenleme yapmamış olması gereklidir. Bölgenin yasası, merkezin yasasıyla çelişiyorsa merkezin yasası geçerlidir. Bölgelerin yasaları, merkezi devletin yasalarının anayasalarının altında yer alır, ona uymak durumundadır.

Anayasanın üstünlüğü ilkesi: Bölgesi devletin anayasası hem merkezi ve bölgelerin yetkilerini tek tek sayıyor hem de bunların ortak yapabileceklerini sayıyor. Her bölgede statü adı verilen anayasalar var. Her bölgenin çıkaracağı yasalar hem merkezi devlet anayasasına hem de statülere aykırı olamaz. Federal devlette, federe devletler kendi anayasalarını yapabilirler. Bu anayasayı yaparken federal parlamentonun etkisi yoktur. Federal anayasaya aykırıysa biri gider AYM'e başvuru. Yani yaptırımı hukukidir. Bölgesi devlette ise statülerin yapılma ve değiştirilmesi parlamentonun onayına bağlıdır.

Yetki paylaşımı bakımından: merkezin yetkileri ile bölgelerin yetkileri tıpkı federe devlette olduğu gibidir. Tek elden yürütülmesi gereken yetkiler merkeze bırakılmıştır. Diğer konularda bölgeler yetkili kılınmıştır. Yetki paylaşımına ilişkin uyuşmazlık çıkarsa bunu AYM çözer. Bölgesi devlette, yargı organı merkeze ait olduğu için tek bir AYM vardır. Federe devletlerin de birer AYM'leri vardır. Federal devletle, federe devletler arasındaki yetki uyuşmazlıklarını federal AYM ya da yargı düzenine göre federal yüksek mah. çözmekle yükümlüdür. Yerel yönetimler bölgesi devlette de bulunur. Yerel yönetimler, merkezin idari vesayeti altındadır. Federal devlette, eyaletlerin ya da federe devletlerin denetimi altında ama bölgesi devlette, merkezi devletin yönetimi altında bulunuyor ama bunların idari özerkliğinin bulunduğunu görüyoruz. Her bölge aynı yetkilerle donatılmamıştır. Yetkiler asimetrik olarak dağıtılmış ve her bölgenin farklı yetkileri vardır

Bölgesi devlette, bölge halkı tarafından seçilen parlamentoları vardır. Merkezi hükümet sistemine benzer hükümet sistemini benimsiyorlar. İtalya ve İspanya'da bölge yönetimlerinde klasik parlamenter sistem vardır. Bölge halkı bölge meclisini seçiyor. Bölge meclisi kendi içinden bir başbakanı ve bakanları seçiyorlar. Bu kurul bölgeyi yönetmekle görevlidir. İlgili meclise karşı siyaseten sorumludur.

Sonuç: Bölgelerin 2.mecliste kısmi olarak temsil edilmesi federal devlette gördüğümüz gibi 3.meclisin yalnızca ve bütünüyle bölgeler tarafından temsil edilmemesi. 2.olarak egemenliğin bölünebilir olması, üniter devlete yaklaştığını, federal devletten daha geride kaldığını söyleyebiliriz.

Konfederasyon: Ulus devlet değil ulus devletler birliğidir. Konfederasyonu oluşturan devletler hem iç hem de dış egemenliklerini sürdürürler. Belli bir somut konuda işbirliği yapmak için bir araya gelen egemen devletlerin oluşturdukları bir ulus devlet biçimidir. Kendi varlıklarını, egemenliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Savuma, ekonomi gibi bir amaç için bir araya geliyorlar. Üye devletler diledikleri konfederasyondan çıkabilirler. Konfederasyonlar, uluslararası bir anlaşma ile kurulurlar. Bu konfederasyonun bir meclisi vardır. Üye devletlerin eşit temsiline dayalı bir meclisi vardır ve oy birliği ile karar alınır. Meclisin kararları üye devletler tarafından onaylanmak zorundadır. Konfederasyonun yargı ve yürütme yetkisi yoktur. Günümüzde BDT, SSCB'nin içinde yer alan eski devletlerin bir kısmı ekonomik ve savunma amacıyla bir araya gelmişlerdir ve BDT'nu oluşturmuşlardır. Ulus devlet anlayışındaki hiçbir devlet kendiliğinden bir bölgenin devletten ayrılmasına izin vermez. 1815-1866 Alman prenslikleri arasında kurulan konfederasyon ve 2003-2006 arasında Sırbistan-Karadağ

Avrupa Birliği: A tipik bir devlet biçimidir. Avrupa birliği, konfederal devletle, federal devletin bazı özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ulus devlete benzer biçimde uluslararası bir tüzel kişiliğe sahiptir. Ankara da büyükelçiliği vardır. Avrupa Birliğini oluşturan devletler iç ve dış egemenliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu bakımdan konfederal devlete benziyorlar. AB kurumlarının kabul etmiş olduğu

düzenlemeler ve aldıkları kararlar AB vatandaşlarına doğrudan uygulanır. *Doğrudan uygulama yetkisi*: Bir üye devlet içindeki ulusal yargı organı kendi ulusal kanunu ile AB düzenlemesi arasında bir çatışma görür ise araya başka hiçbir hukuki işlem girmesine gerek kalmadan AB düzenlemesini uygulamakla yükümlüdür. AB hukuk, kendi hukukunun üzerinde yer alır. AB içinde bazı kararların alınmasında oy birliği şartı bulunmasına rağmen bazı kararlarda bu şart aranmaz. Üyelikten çıkarılması, oy birliği ile karar alınır. Bazı konularda 2/3 gibi nitelikli çoğunluk aranır. AB, bir anayasaya dayanmıyor. 1957 Roma ve 1972 Maastricht anlaşmasına ve 2007 Lizbon anlaşmasına dayanır. Konfederal devlette olduğu gibi bu metinler hukuki anlamda anayasa olmayıp uluslararası anlaşmalardır. AB'nin bir yargı organı vardır. AT Adalet Divanı olup AB'nin en üst yargı organıdır. Bunun almış olduğu kararlar AB'ni bağlıyor. Ortak yargı olması bu birliği Federal devlete yaklaştırıyor. AB'nin bir anayasası yoktur. Ulusal savunma ve dış politika da ortak bir siyasetleri yoktur. Ortak kurumları da yoktur. Bu yönüyle konfederal devlete benziyor. Konfederal devlete yakın biçimde federe devletlerin eşit temsil esasına dayalı 2.bir meclisi yoktur AB'nin. Avrupa Parlamentosu vardır. Bu parlamento devletlerin halkını temsil ediyor. Bu parlamentonun yetkileri de çok sınırlıdır. Devletleri temsil eden 2. Bir parlamento yoktur. Bu özelliği ile federal devletten ayrılır. AB üye bir devletin yargı, iç hukuk ile topluluk hukuku arasında çatışma olunca topluluk hukukunu uygulamak zorundadır. Bunu federal devletlerde görürüz. Bu 1. topluluk hukukunun üstünlüğü ve 2. AB kurumlarının düzenleme yapma yetkisine sahip. AB'nin normları üye devletler tarafından doğrudan uygulanıyor aynı zamanda AB ile ulusal hukuk arasında bir çatışma olursa AB normu uygulanmak zorundadır. Topluluğun yasama organı, AB Bakanlar Konseyi olup üye devletlerde uygulanacak yönetmelik ve yönergeleri kabul eden organdır. Dolayısıyla yasama organı niteliğini taşır. Bu konseyde kararlar nitelikli çoğunlukla alınıyor. Federal devlete yaklaştıran bir başka özelliği de ortak bir yargı organının olmasıdır. AB Adalet Mahkemesi birlik için içtihat atıyor ve son derece etkili üye devletlerin uygulamalarını AB hukukuna uygunluğunu denetliyor. AB, kendine özgü özellik gösteriyor.

1876 Kanuni Esasi: Osmanlı devletin biçimine ilişkin herhangi bir özel düzenleme içermiyordu. Yetkiler merkezde toplanmıştı. Üniter bir devlet biçimi vardı.

1921 Teşkilatı Esasiye: Temel özelliği ademi merkeziyetçi olması olup buna dayalı bir anayasadır. Yerinden yönetim ilkesi anayasada genel bir ilkedir. Çerçeve bir anayasa olmasından dolayı 24 maddeden oluşuyor. 14 Maddesi yerinden yönetime ilişkin. Devlet 3 tane yönetim birimine ayrılıyor; iller, ilçeler, bucak. İller en önemli yerinden yönetim birimleriydi. İl meclisleri vardı. Yöre halkının yaptığı seçim ile kuruluyordu. Yetkileri bize federal, özerk üniter devlet ve bölgesel devletteki özellikleri gösteriyor. Klasik üniter devlet değil esaslı yetkiler yoktur. Federal devlete de benzemiyor. Yargı yetkisi yoktu. Kural koyma yetkisi tanınmış. Vilayetlerin yetkileri, eğitim, sağlık, tarım, ziraat, vakıf, gibi konular vilayet meclisleri tarafından kullanılır. Bu yetkiler hiç uygulanmamıştır.

1924 Anayasası: Klasik üniter devlet biçimine sahiptir. O zamanki idari yapıda bunu göstermektedir. Yerel yönetimlerin kısaca belediyelerin ve köylerin merkezin katı bir denetimine bağlıydı. Özerkliğin ya hiç olmadığı ya da çok sınırlı olduğu bir devlet biçimidir. Çerçeve bir anayasaydı. Ayrıntılı düzenlemeler içermiyordu. Yerel yönetimin düzenlenmesini pek çok konuda olduğu gibi yasa koyucuya bırakmıştır. Yerel yönetimin kanunla düzenleneceğini söylemiştir.

1961 Anayasası: Daha özgürlükçü bir anayasa ve bunun devlet biçimine yansımaları ilk defa yerel yönetimler 1961 anayasasında düzenleniyor. Merkezi yönetim ilkesi geliyor, yönetimin bütünlüğü ilkesi 61 anayasasında yer alıyor ve ilk defa yerel yönetimlerin özerkliği 61 anayasasında güvence altına alınıyor. Bu anayasa üniter devlet yapısını benimsiyor. Kendi dönemine uygun olarak yerel yönetim birimlerine idari özerklik tanıyarak üniter devlet biçimini daha demokratik hale getirmiştir. İller, belediyeler, köyler tüzel kişiliğe ve idari özerkliğe sahip oluyor. İdari vesayeti tanımakla birlikte Anayasa ile birlikte bunu sınırlandırıyor. Merkez tüzel kişiliğinin içinde yer alan bazı kurum ve kuruluşlar doğrudan anayasa tarafından düzenleniyor ve bunlara ayrı bir tüzel kişilik tanınıyor ve aynı zamanda hizmet yönünden idari bir özerklik veriliyor. AYM kuruluyor.

1982 Anayasası: Devlet biçimine ilişkin düzenlemeler itibariye 61 anayasasına benziyor. Bazı bakımlardan 61 anayasasında olmayan düzenlemeler getirilmiştir. Devlet biçimine ilişkin düzenleme deyince 3.md 1.fıkra "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" Devletin toprağının bir bölümünün başka bir ülkeye katılmaması, o devletten ayrılmaması, başka bir devlet kuramaması sadece üniter devlete ait bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bir devletin anayasasında açık bir şekilde, kendi egemenliği altındaki unsurlara kendi geleceğini belirleme hakkı tanımadıkça bütün devletler bakımından, devletin ülkesiyle bölünmez

bütünlüğü ilkesi geçerlidir. Amerika'daki iç savaş bu sebeple çıktı ve federal devlet bunu kabul etmedi. Anayasa bunu tanımadığı ve merkezi devlette bunu kabul etmedikçe bu söz konusu olamaz. Bu üniter devlete özgü bir özellik değildir. Anayasa açıkça kendi geleceğini tayin hakkı tanımıyorsa böyle bir olanak yoktur. Bütün devlet biçimleri içinde ülkenin bölünmez bütünlüğü ilkesi geçerlidir. Siyasal yerinden yönetim ilkesini dışlar. İller gibi bölünmeler olsa da aynı merkeze bağlı olmak esastır. Bu bölünmeler sadece idari niteliktedir.

Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü: Devletin egemenliği altında yaşayanlar farklı inanca, etnik kökene sahip olabilirler. Tüm farklılıklara rağmen onları koruyarak bir ulus çatısı altında var olurlar. Tek bir ulus vardır. Birden fazla bir ulusa dayalı bir devlet düzeni bulunmuyor anlamına gelir. Devletin ulusuyla bölünmez bütünlüğü ilkesi, üniter devlet, bölgesel devlette görülen bir özelliktir. Tüm vatandaşların aynı ülke sınırları içerisinde aynı yasalara bağlı olması ve devletin bir ulustan oluşmasıdır. Hukuken birden fazla ulusa sahip olmasını bu ilke engeller. Bunun sonucu, devletin resmi dili de genellikle bir tane olur. O ulus içinde farklı etnik kökenler, inançlar ve kültürel özellikleri olan gruplar olabilir. Bu ilke o topluluklara kültürel haklar tanınmasına engel olmaz. Örn: Kürtçe tv yayınları

Anayasaların soyut düzenlemelerini kararlarıyla, içtihatlarıyla somutlaştıran AYM'dir. Anayasayı yorumlama yetkisi vardır ve bu tekeldir.

3. Unsuru. Devletin unsurlarından biri insan topluluğudur. Çağdaş devletler insan topluluğunu ulusa ya da halka dayandırıyor. Bütün devletler ulusa dayanır, ulusal devlettir. İmparatorluklar ulusa dayanmaz, ulus devlet değildir. İnsan topluluğu unsur, ulus denilen bir kurgusal unsur yerine yöneticinin buyruğuna dayanır. Bölgesi, federal, üniter devletler ulusal devletlerdir. İnsan topluluğu unsur ulusa dayanıyorsa egemenlik onlardan kaynaklanıyorsa o devletler ulusal devletlerdir. AYM, azınlık haklarını ulus bütünlüğüne ilkesine aykırı görüyor, üniter devletlerin olduğu devletlerin anayasalarında etnik, kültürel, inanç gibi azınlıklara bazı ayrıksı haklar tanınabilmektedir. Tanınan bazı azınlık haklarına anadilde eğitim, kendi inancında ibadet gibi haklara yer veriyorlar. Bunlar ayrıcalık yaratmayı değil çeşitli nedenlerle toplumda ayrımcılığa uğrayan kesimleri ayrımcılığa uğramamaları konusunda bir güvence veriyor. AYM, sonuç itibariye anayasanın 3.md.'sini katı biçimde uyguluyor. Mahkeme bu kararlarında azınlıklar yaratarak ulus bütünlüğünü bozmayı amaçlamayı anayasaya aykırı buluyor.

123. md. Yerinden yönetim ve merkezi yönetim ilkeleri, üniter devlete ait bir özelliktir. Üniter devlette yönetimin bütünlüğü ilkesini, hiyerarşi ve idari vesayet hukuk ilkeleri sağlıyor.

Hiyerarşi: Aynı yönetim çatısı altında merkezle taşra örgütlenmesi arasında idarenin bütünlüğünü hiyerarşi ilkesi sağlıyor.

İdari vesayet: Devlet tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişiliğe sahip olan ve devletin merkezi yönetimin hiyerarşisi altında bulunmayan yönetim birimlerine karşı merkezi yönetimin yaptığı hukukilik ve yerindelik denetimine verilen isimdir. 126/1. Md. yerinden yönetimleri düzenliyor. Siyasal yerinden yönetim dışlanıyor. 126. md bu ilişkinin 2.fıkra da yetki genişliği esasına dayandığını söylemektedir. Klasik üniter devlet ilkesindeki gibi. Son fıkra da ise kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birçok ili kapsayacak bölgelerin kurulabileceğini belirtiyor.

Madde 127: 1. Kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim vardır. 2. Bu yerel yönetim kanuna dayalı olarak oluşturuluyor. 3. Yönetim organı, yöre halkı tarafından yapılan seçimle belirleniyor. 4. Merkezi yönetimin hiyerarşisine bağlı değil bu yerel yönetimler. 127/1 yerel yönetim birimlerini sınırlı bir şekilde saymıştır. Bunların dışında başka yerinden yönetim birimlerinin kurulamayacağını belirtmiştir. Eğer bu 3 yerel yönetim biriminde birini kaldırmak veya yeni yerel yönetim birimleri kurmak istiyorsa bu madde de değişiklik yapılmalıdır. 127/2 yerel yönetimlerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceğini belirtiyor.

Yerinden yönetim ilkesi: Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi bakımından icrai kararlar almak yetkisinin merkez teşkilatına dahil olmayan idarelere verilmesidir. Yerinden yönetimler 5 yılda bir yapılacak seçimler ile belirleniyor.

127/4 Demokratik bir üniter devlette yerinden yönetim ilkesi esas merkezin yerinden yönetim birimlerine müdahalesi istisna kabul edileceğini düzenliyor 4. Fıkra.

127/5 İdari vesayet yetkisi Anayasa ile güvenceye kavuşmuştur. 123. Madde çerçevesinde idarenin bütünlüğünü sağlama amacı gütmeye gerekiyor. Toplumun kamu yararı ya da yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla merkezi yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır. Üniter devlette, idari vesayet yetkisi istisnai bir yetkidir. Aynı yönetim düzeyi ve aşağısında hiyerarşi yetkisi, genel bir yetkidir. 6758 kanun ile

yapılan düzenleme ile mali özerkliği ortadan kaldırıyor. Bu kanun Anayasanın 2 ve 127. Maddeleri ile bağdaşmaz. 1961'den farklı olarak 82 anayasası idari vesayeti açıkça tanıyor. 61 Anayasası açık olarak tanımamıştı. Dolayısıyla idari vesayet yetkisinin geniş bırakılmıştır. Ancak 82 anayasasının bu yetkiyi daha ayrıntılı biçimde tanıyarak kanun koyucunun takdir yetkisini bu anlamda daralttığını söyleyebiliriz.

1982 Anayasası saf üniter devlet anlayışını kabul etmiştir. İdari bakımdan yetkilendirilmiş yerel yönetimlerde merkezin müdahale etme olanaklarını da geniş biçimde düzenlemiştir. Saf katı üniter devlet anlayışı günümüz demokrasi anlayışı ile uyuşmuyor. Halkın katılımına dayalı olarak hizmetlerin görülmesine dayalı bir anlayış var hem de hizmetlerin olabildiği kadar hızlı bir şekilde görülmesini merkeziyetçi yapı engelliyor.

Avrupa Yerel özerklik şartı 1988'de imzalanıyor. Türkiye de bazı çekincelerle 92 yılında bu şartın bir tarafı oldu. Yerel yönetimlere ilişkin ilkeler sıralanmış. Yerel yönetimlerin o yöre halkı tarafından seçilen yönetim organları tarafından yönetilmesini belirtir. Yerel yönetim organları özerk olacak ve yöre halkı tarafından seçilecek. Biz buna örgütsel özerklik diyebiliriz. Olabildiğince hizmetlerin halka en yakın yerinden yönetim birimi tarafından görülmesi esas alınmalıdır diyor. Yerel yönetimleri kendilerine uygun örgütsel yapıyı oluşturmaları, kendi personelinin çalıştırabilmesi bakımından özerk olması gerektiğini savunuyor. Merkezi yönetim bu alanda müdahale etmemelidir diyor. 2. Mali bakımdan özerk olacaklar, kendilerine ait gelir kaynaklarının olması gerekir. Merkeze aşırı bağımlı yerel yönetimler yaratılmasını engellemektir. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin üzerinde yetkilerini kötüye kullanabilir. Buna **yetki gaspı** denir. Merkezin, bu gasp veya başka yollarla yerel yönetimlerin özerkliğini çiğnemesi durumunda bu aykırılığı bağımsız mahkemelerin vereceği kararlarla güvence altına alınması gerekir. Merkezin, yerel yönetimler üzerinde kullanacağı idari vesayet yetkisini yalnızca hukukilik denetimiyle sınırlı olması, yerindelik denetimine dayalı idari vesayetin uygulanmaması gerektiğini belirtiyor.

Hukukilik denetimi: Yerel yönetimin almış olduğu bir kararın, yasaya uygun olup olmadığının denetlenmesidir. Bunun yargı kararıyla sonuçlanması gerekir. Merkezin bu yasaya uygun değil demesi yetmez. 2005-2010 yılları arasında yerel yönetimler reformu yapıldı. Bu reformun amacı, yerel yönetim birimlerinin özerkliğini genişletmektir. Bununla; 1. Merkezden taşraya ve yerel yönetimlere yetki devri yapıldı. 2. Özelleştirme yoluyla merkezde olan bazı yetkilerin özel kuruluşlara aktarılması sağlandı.

2005 yılında Belediyeler, il özel idaresi yasaları değiştirildi. Bu değişikliklerdeki "yerel yönetim birimlerinin yetkilerinin genel yetki esasına dayandırılması" oldu. Şu şekilde yapıldı 1. Belli yetkilerin listelenmesi gerisinin yerel yönetime bırakılması 2. Belli yetkilerin listelenip geriye kalanların merkeze bırakılması. Geriye bırakılan yetkiler hangi yönetim birimine bırakılıyorsa o genel yetki kuralı idi. Ülkemizde kanun, merkezin yetkilerini genel yetki kuralı esasına bağlamıştır. Bir başka deyişle, yerel yönetimlerin yetkilerini kanun tek tek saymış gerisini merkeze bırakmıştır. 2005 yılındaki kanunla bunun tersi yapılmıştır. 2005 reformuyla birlikte idari vesayet, hukukilik ile sınırlandırılmaya çalışılmış olup yerindelik kaldırılmıştır. Bu reform Avrupa yerel yönetim şartına da uygundur. Bu kanun AYM ne gitti ve yerel yönetimleri güçlendiren tüm uygulamaları anayasaya aykırı buldu. Bu bize AYM'nin üniter devlet anlayışını katı olarak yorumladığını göstermektedir.

Yasama, yürütme ve yargı işlerinin hangisinin yargıya karşılık geldiğini bulabilmek için 2 farklı ölçüt vardır.

1.Maddi ölçüt: Devletin yaptığı işleri, kural işlem, subjektif işlem ve yargı işlemi olarak üçe ayırıyordu. **Kural işlem:** Genel, soyut, kişilik dışı, sürekli, nesnel nitelikte olan işlere denir. Bu niteliğe yani işlemin içeriğine bakıyoruz. Bu içerikte olan bir hukuki işlem, hangi organ tarafından hangi usullere bağlı olarak yapılırsa yapılırsın, kural işlem kabul edilir.

Subjektif işlem: İdari işlem subjektif işlemdir. Subjektif hukuki durum oluşturan ya da objektif bir hukuki durumun şartlarını belirleyen işleme verilen isimdir.

Yargı işlemi: iddia, tespit ve yaptırım aşamalarından oluşan işleme verilen isimdir. Devletin, yasama, yürütme, yargı işlemi, işlerin niteliğine göre belirleniyor kural işlem, subjektif işlem ve yargı işlemi. Bu üç unsur yer alıyorsa biz o işleme yargı işlemi diyoruz. Eleştiri; maddi ölçüt göz önünde bulundurduğumuz zaman, kural işlem niteliği taşıyan ancak yasama organının dışında idarenin de yaptığı işlemler ortaya çıkıyor. Örneğin: idarenin bütün düzenleyici işlemleri maddi bakımdan yasama işleminden ayırmamız mümkün değil. Tüzük, yönetmelik, kararname ve diğer düzenleyici işlemler bunlar nitelik itibarıyla birer kural işlem niteliğindedir. Bu durumda fonksiyonları birbirinden ayırmamız mümkün değildir. Yasama organının bazı işlemleri, md.87 TBMM'nin yetki ve görevleri (beta 115) para basılması kural işlem niteliği taşımaz, bir subjektif işlemdir ama yasama organının biridir. TBMM'ne verilmiş ölüm cezasını onaylama yetkisi vardır. Maddi bakımdan kural işlem

olmayıp bir subjektif işlemdir. Yine yasama organına verilen meclis soruşturma yetkisi, iddia, tespit, yaptırım gibi aşamalardan oluşuyor ve bunu yasama organı yapıyor. Bu kural işlem olmayıp yargı işlemine benzer bir işlemdir. Maddi ölçüt, devletin fonksiyonlarını birbirinden ayırmak bakımından yeterli bir ölçüt değildir.

Organik ölçüt: Hukuki işlemin niteliğine bakmadan, o hukuki işlemi yapan organa ve o hukuki işlem yapılma usulüne göre hukuki işlemin belirlenmesinin adlandırılmasıdır. Niteliği, içeriği ne olursa olsun yasama organı tarafından yapılan yasama işlemi, yürütme organı tarafından yapılan işlem yürütme işlemi ve yargı organı tarafından yapılan işlem yargı işlemi niteliği taşıyor. İdari işlem bakımından esas ölçüt yasallık ilkesidir. İdari işlemlerin tümü bir yasaya dayanmak zorundadır. Ancak yasanın verdiği yetkiye dayanarak bir idari işlem yapılabilir. Yasama işlemi bakımından bu kural geçerli değildir. Parlamento yasama işlemini, herhangi bir hukuki norma dayanarak yapmak yükümlülüğü altında değildir. Eğer o hukuki düzende yazılı ve katı bir anayasa var ise yasama organının yapacağı işlem, anayasaya aykırı olamaz. Ama anayasanın herhangi bir hükmüne dayanmak zorunda değildir yasama işlemi. Buna karşılık yürütme işlemi, mutlaka bir yasaya dayanmak zorunda, işlem yapma yetkisini bir yasadan almak zorunda ve dayandığı yasaya da aykırı olmamak zorunda. Yürütme işleminin, yasaya dayanması, yasaya aykırı olmaması normlar hiyerarşisinde yürütmenin işlemlerinin yasaların altında olması anlamını taşıyor. İdarenin yasallık ilkesine dayanması, yasama ile yürütme işlemini birbirinden ayıran temel özellik bu. İdarenin görevi, yasaların uygulanmasıyla görevli olan fonksiyondur. İdarenin, yasaların uygulanması görevini yerine getirmek amacıyla, istediği ayrıntıda, istediği biçimde düzenleme yapma yetkisi vardır. Yeter ki bu yetkiyi yasadan alsın, bu işlem yasaya aykırı olmasın yeter ki bu işlem yasanın uygulanması mahiyetinde olsun. Organik ölçüt kısaca; idarenin görev alanını, konuyla değil kanunları uygulamak ve yürütmekle bu nitelikte tanımlayan bir fonksiyondur. Yasanın üstünlüğüne ve idarenin kanuna bağlı oluşuna dayanması yasama ile idare arasındaki farktır.

Güçler Ayrılığı İlkesi: 1924 Anayasası güçler ayrılığı ilkesi: Dikey güçler ayrılığını anlıyoruz. Devlet biçimine karşılık geliyordu. Yatay olan yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki yetki paylaşımı. 1924 anayasasını, güçler birliği görevler ayrılığı olarak tanımlayabiliriz. Yargı yetkisi, bağımsız mahkemeler tarafından kullanılıyordu. Buna karşılık, yasama ve yürütme yetkisi TBMM'nindi ve onun yetkisi altındaydı. 1924 ün 5.maddesinde, yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ne verildiği için güçler birliği vardır. Fonksiyonlar ayrılığı şuradan kaynaklanıyor: yasayı TBMM yapıyor. Meclisin seçtiği CB'nin simgesel yetkileri vardır. 24 Anayasası döneminde, Başbakan, Bakanlar Kurulu vardı. Yürütme yetkisi, CB, Başbakan ve BK da. Yürütme yetkisi TBMM de ama bunu 3 unsur aracılığı ile kullanıyor. Yürütme yetkisini TBMM doğrudan kullanmıyor.

1961 Anayasası: Yumuşak güçler ayrılığı. Yasama TBMM de (o zamanki anayasanın 5. Maddesi), yürütme yetkisi CB, BK tarafından kanunlar çerçevesinde yerine getirilir. 1. Yasama bir yetki ve yürütme bir görev olarak tanımlanmış. Yapılan işlemler yasalara uygun olmak zorunda. İdare yasaları uygulamakla görevli. Yasaya dayanma, yasadan kaynaklanma ve yasaya aykırı olmamaya dayanıyor. İdari işlem, kanuna dayanmak zorunda, türevsel işlemdir bu. 1961 anayasasında, yürütme bir görev olarak tanımlanmıştır.

1982 Anayasası: 7.madde 1924 anayasasından beri var olan yetki. 8.madde BK ibaresi kalktı. 1961 7.madde ile arasındaki fark: yetki ve görev diyor. Başka CB ve Başbakan diyor, 1982 anayasaya uygundur ilavesi var. Bir önceki kanuna uygun yazılıdır. Yürütme neden yetki olmuş? Yürütmenin bazı işlemleri, yasallık ilkesi denen bir takım işlemlerinin olması lazım. Kanuna dayanması onun bir görev olmasını, anayasaya dayanması ise, bir yetki olması, doğrudan anayasadan aldığı yetkileri kullanması anlamına geliyor. 1982 anayasasına göre, yürütme yetkisinin anayasal dayanağı, CB kararname yoluyla bu alanı bir yasaya dayanmadan bu alanı düzenleyebilir diyor (md. 107).1982 anayasası, sıkıyönetim ve OHAL, KHK getirdi. Bu KHK'nin önemi, bir kanunu değiştiren, kanunla yapılması gereken alanı kanun gücünde bir işlem gücü ve bunun yürütme organı BK çıkarıyor. KHK'leri yürütme erkinin yetkisi niteliğinde değildir, TBMM'nin çıkaracağı bir yetki kanununa dayanmalıdır. OHAL ise, yetki kanununa ihtiyaç duyulmadan CB'nin başkanlığında toplanan BK'nun çıkaracağı kanun gücündeki kararnamelerdir. 121-122.maddelerde düzenlenen OHAL ve KHK'leri anayasanın 8. Md. Yürütmenin bir yetki olarak nitelemesinin anayasal dayanağını oluşturuyor. Sonuç: Anayasa 121-122-107-108 yürütmenin yetki olarak nitelemesinin anayasal dayanağını oluşturuyor.

Yasama Fonksiyonu: TBMM'nin yasa ya da parlamento kararı olarak yapmış olduğu işlemleri anlıyoruz. Yasalar 1 maddi bakımdan 2 şekli bakımdan yasa olarak tanımladık. 1982'ye göre 7.md yasama yetkisi TBMM'nindir. 87.md TBMM'nin görev ve yetkileri. TBMM'nin yasa yapma usulünü izleyerek yaptığı bütün hukuki işlemler, şekli anlamda yasa olarak kabul ediliyor. Para basılmasına karar vermek, maddi anlamda yasa

değil. TBMM bu yetkisini yasa biçiminde kullanıyor. Genel ve özel af kararını TBMM bir yasa biçiminde kullanıyor. Bu işlem subjektif bir işlem yani belli kişileri belli bir hukuki statüden çıkarıp başka bir hukuki statüye koyan işlem dolayısıyla subjektif bir işlem olup şekli olarak yasa biçiminde yapılıyor. 2004 Yılında kaldırılana kadar mahkemelerin verdiği ölüm cezalarını bir yasa biçiminde onaylıyordu. Bu işlem maddi bakımdan kural işlem değil, subjektif işlem niteliğini taşıyordu.

Sonuç: TBMM, şekli bakımdan yasa yapma yetkisine sahip ve bu yasa olarak kabul ediliyor. Eğer bir hukuki işlem, maddi ya da şekli anlamda yasa olarak tanımlanıyorsa AYM'nin anayasaya uygunluk denetimine bağlı olacaktır. Eğer yalnızca şekli olarak tanımlanıyorsa o zaman maddi bakımdan yasa niteliğini taşıyan hukuki işlemler anayasaya uygunluk denetimi dışında kalır veya TBMM'nin yasa adı altında kabul etmediği diğer işlemlerde maddi bakımdan yasa niteliği taşısa bile anayasaya uygunluk denetimi dışında kalacaktır. Bu, hukuk devletinin gerçekleşmemesi sonucunu doğurur. Hukuk devleti: devlet organlarının yapmış olduğu işlemlerin bağımsız yargı denetimine bağlı olduğu bir devlettir. Eğer bazı devlet organlarının yaptığı işlemler yargı denetiminin dışında tutuluyorsa o zaman orada hukuk devleti ilkesi ya yoktur ya da ciddi ölçüde zedelenmiş demektir. AYM, kurulduğu 1961 yılından beri uyguladığı içtihadı göre: bir normun adı kanun olmasa bile maddi anlamda kanun niteliği taşıyorsa ben o normu anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutarım diyor. Eğer bir norm, maddi anlamda kanun niteliği taşıyorsa adı ne olursa olsun hangi organ yaparsa yapsın, ben o normu anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutarım. Bunun önemi: TBMM'nin yapacağı bazı işlemler, anayasaya uygunluk denetiminden kaçırarak için yasa biçiminde yapması gerekirken, parlamento kararı biçiminde yapmasını engellemek. Sonuç: AYM, hem şekli anlamda hem de maddi anlamda yasayı göz önünde bulunduruyor. Bir normun anayasaya uygunluk denetimi içinde yer alıp almadığını saptar. Yasama yetkisinin 3 özelliği vardır: 1. Genelliği ilkesi 2. Yasama yetkisinin asliliği ilkesi 3. Devredilmezliği ilkesi.

Genelliği ilkesi: Parlatentonun herhangi bir konuda, dilediği ayrıntıda yasa yapabilmesi demektir. Yasama yetkisinde parlamento belli bir norma dayanmak zorunda değildir. Konu bakımından, anayasaya aykırı olamamak kaydıyla, anayasanın emir ve yasaklarını gözetmek şartıyla parlamento dilediği konuyu dilediği ayrıntıda yasa biçiminde düzenleme yetkisine sahiptir. Bu yetkinin birtakım sınırları vardır. 1. Uygulayıcı bireysel işlem niteliğinde işlem yapamaz. Bir kişiyi kaymakam olarak atayamaz. Görevden alma niteliğinde işlem yapamaz. Bunlar subjektif işlemlerdir. Bireysel işlemlerdir. 2. Yine yasama organı, kanunla bir kişiye yükümlülük veremez, yükümlülükten çıkaramaz. Bunlar subjektif işlemdir. 3. Maddi bakımdan, yargı yetkisi niteliği taşıyan bir kanuni düzenleme yapamaz. 1982 Anayasasının genelliğe ilişkin istisnaları: CB Genel Sekreterliğinin alanı, artık yasama organının düzenlemesine kapanmış, bu alanda düzenleme yapma yetkisi CB'na tanınmıştır. Aynı şeyi OHAL ve sıkıyönetim kararnameleri bakımından söyleyemeyiz. Yürütme organına bu nitelikte yasa yapma yetkisi Anayasa 12122. Md. tanıyor. Ama bu alanlarda kanunla düzenleme yapma yetkisini yasaklamıyor. Kanunla düzenleme yapabilir. 2017 anayasa değişikliğinden sonra, 107.md kalktı. CB Kararnamesi diye yeni bir idari işlem türü yarattı. Hangi konularda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Anayasanın çeşitli maddelerinde "kanunla düzenlenir" şeklinde düzenleme vardır. Anayasa 13.md, 123.md., 47.md. "kanunla düzenlenir" denilen alanlar olup başka bir hukuki düzenleme ile düzenlemek mümkün değildir. 104/9 "CB kararnamesi ile düzenlenir" 106/11, 108/son, 118/6 belirtilen konularda yasama yetkisinin genelliği ilkesine anayasayla istisna getirilmiştir. 104/17 "CB kararnamesini düzenleyen fıkra" yürütmeye tanınmış bir işlem türüdür. 104/17 kanunla kararnameler arasında çatışma olunca kanun hükümleri uygulanır. CB Kararnamesi her konuda düzenleme yapmaz. Anayasanın, kanunla öngördüğü konularda düzenleme yapamaz. İki hukuki işleme açık olan bir alanda kanunla düzenleme yapıldıysa ve çatışıyorsa kanun hükmü uygulanır ve CB kararnamesi hükümsüz kalır (104/17). 1. Anayasa koyucu, açık bir şekilde CB kararnamesi ile her alanın düzenlenemeyeceğini öngörür. 2. Anayasa metni belli alanları kanunla düzenlenemeyeceği öngören açık bir yasa hükmü getirmiş mi şu konularda ancak CB kararnamesi ile düzenlenir gibi bir ifade olmadığı sürece, münhasıran kararname ile düzenlenir sonucuna varamayız. Açıkça, kanunla düzenlenemeyeceğine ilişkin bir yasa yok.

Yasama ilkesinin genelliği ilkesi, anayasanın md.7 TBMM'nin görev ve yetkileri md.87 ,1924 anayasasından beri tanınan genelliğine ilişkin aynen devam. Yasanın düzenlediği alanda CB kararnamesi çıkarılamıyor. Ancak TBMM yasanın düzenlediği alandaki yasayı yürürlükten kaldırır o zaman CB kararnamesi ile o alanı düzenlenebilir.

CB kararnamesi, yasama yetkisinin genelliği ilkesine bir istisna getirmiştir. Yasama yetkisinin genelliği aynı şekilde kalmaya devam etmektedir, bu çerçeveler doğrultusunda.

Yasama yetkisinin ilkeliliği: Yasama organının, yasa adı altında yaptığı işlemlerin başta anayasa olmak üzere başka herhangi bir hukuki işleme dayanma zorunluluğunun olmamasıdır. Bu yasama işlemi ile yürütme işlemi arasındaki temel farktır. Yürütme işlemleri bir yasaya dayanma ve o yasaya aykırı olmamak zorundadır. Ama yasa yapma bakımından parlamentonun, herhangi bir kurala dayanması zorunluluğu yoktur. Yaptığı işlemlerin, anayasanın emir ve yasaklarına uygun olması şart, buna karşılık anayasaya dayanması şart değildir. Katı ve yazılı bir anayasaya sahip olmayan hukuk düzenleri de vardır. Bu da yasama yetkisinin ilkeliliği ilkesinin bütün parlamentolarda geçerli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir kurala dayanmak zorunda değil ama yazılı ve katı bir anayasası olan hukuk düzenleri bakımından parlamentonun yaptığı yasaların, o ülkenin anayasalarına aykırı olmaması yani anayasanın öngördüğü emir ve yasaklara uygun olması gerekiyor. TBMM'nin çıkardığı yasaların da anayasaya dayanma zorunluluğu yok, anayasaya aykırı olmama zorunluluğu vardır. Yazılı bir anayasamız olmasa bile yasama yetkisinin ilkeliliği devam edecek.

Yasama yetkisinin devredilmezliği: 1982 md.7, hem 1924 hem de 61 anayasasında bulunan bir ilke bizim anayasal kimliğimizin bir parçasıdır. Yasa gücünde kurak koyma yetkisi parlamento, Türkiye özelinde TBMM'ne aittir. Bu yetki, yasa gücünde ve değerinde kural koyma yetkisinin TBMM ait olan bu yetkinin başka bir organa devredilmemesi anlamına geliyor. Anayasa ile tanınmış bir yetkinin bir görevin anayasanın açıkça verdiği bir izin olmadıkça başka bir kuruma başka bir organa devredilmemesi demektir. Bu kendine özgü bir kuraldır. Yani md.7 de bu açık bir şekilde yazıyor olmasaydı bile biz bu sonuca varırdık. Hiçbir organ anayasa ya da bir yasada kendine ait olan bir yetkinin devredilebileceğini belirtmedikçe kendisine verilmiş olan bu yetkiyi başka bir organa devredemeyecek demektir. 1924 anayasasından beri anayasa koyucular tarafından önemli görüldüğü için açık bir şekilde bütün anayasalara yazılmıştır. 1971-2017 Yılları arasında buna anayasa ile getirilmiş bir istisna vardır. O da KHKY olup, 1971 de anayasa değişiklikleri ile gelmiştir. Hem 1971 hem de 1982 anayasasında açık ve ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. KHK çıkarma yetkisi Bakanlar kuruluna verilmiş özel bir yetkidir. AYM'nin, birçok kararında belirttiği gibi, bizzat anayasa, yasama ilkesinin devredilmezliği ilkesine getirilmiş bir istisnayı. AYM, KHK'leri böyle yorumladığı için AYM pek çok içtihadında anayasanın çok maddesinde yer alan "kanunla düzenlenir" ifadesinin yer aldığı bütün konuları kanunla ve aynı zamanda KHK ile düzenlenebileceği sonucuna varmıştır. 2017'den itibaren anayasada "kanunla düzenlenir" denilen bir konu ancak kanunla düzenlenebilir. KHK yerine konulan CBK ile düzenlenemez. Artık "kanunla düzenlenir" diye yer alan bütün konular, yalnızca kanunla düzenlenebiliyor, CBK ile düzenlenir biçiminde yer alan konular CBK veya kanunla düzenlenebiliyor ise artık yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnasının 1982 anayasasında bulunmadığı sonucuna varıyoruz. Eskiden KHK'lerde istisna vardı bugün istisna kalmamıştır.

Yasama işlemleri: Yasama organı tarafından bir hukuki sonuç doğuran, doğurması amaçlanan işleme yasama işlemi denir. 1. Genel olarak TBMM'nin yasa adı altında yaptığı işlemleri 2. TBMM'nin parlamento kararı adı altında yaptığı işlemleri anlıyoruz. Her 2 işlem TBMM genel kurulunda yapılır. Genel kurulda aldığı kararla bir işlem yasa veya parlamento kararı biçiminde kabul edilir. Bu durumda, TBMM'nin genel kurulu dışında almış olduğu kararlar, yasama işlemi niteliği taşımaz. Sonuç doğuran işlemler, genel kurulda alınan kararlardır. TBMM, bu iki işlem türünün dışında başka işlemlerde yapar. Örneğin TBMM'nin tüzel kişiliği vardır ve idari işlemler yapılır. 2 Nedenle yasama işlemi değildir. 1. İşlemin kendisi hem maddi bakımdan hem de şekli bakımdan yasama işlemi olmaya uygun bir işlem değildir. 2. Genel kurulda alınmış bir karar değildir. TBMM Başkanlığı, maddi ve şekli bakımdan yasa dışında başka işlemlerde yapabiliyor örneğin düzenleyici işlem de yapabiliyor. Örneğin yönetmelikler idari işlem türüdür. Sonuç: Yasa ve parlamento kararı adı altında genel kurulda TBMM'nin yapmış olduğu işlemler yasama işlemidir.

Yasa: Anayasa ve TBMM iç tüzüğünde yasa adı altında kabul edilecek işlemlerin yapılış usul ve esaslarına bağlı olarak yapılan hukuki işlemi anlıyoruz. Genel yasa yapım sürecine aykırılık oluşturan, genel yasa yapım sürecinden ayrılan özel nitelikte yasalar vardır. Bunlar; Bütçe yasaları, kesin hesap yasaları, uluslararası antlaşmaların uygun bulunması hakkındaki yasalar ve anayasa değişikliği yasaları.

Parlamento kararları 2'ye ayrılır. İç tüzük: TBMM'nin kendi iç işleyişini düzenleyen kurallar bütünü. Parlamentodaki iktidar ve muhalefet ilişkilerini düzenlediği için önemlidir iç tüzük ve sessiz anayasa olarak adlandırılır. İç tüzük dışında kalan parlamento kararları da diğer parlamento kararları olarak adlandırılır. Diğer parlamento kararları; seçim, RTÜK, AYM üye seçimleri, yurt dışına silahlı kuvvetleri gönderme veya yabancı silahlı kuvvetleri yurt içinde konuşlandırılmasına izin vermek gibi.

Yasa yapma işlemi: Yasa adı altında TBMM'nin kabul etmiş olduğu işleme yasa diyoruz. Bir teklifin, verildiği anda TBMM de genel kurulda kabul edildiği ana kadar geçen süreçtir yasalaşma süreci. TBMM de kabul edilen bir metin artık yasa olmuştur. Her yasanın, TBMM tarafından kabul ediliş tarihi bir de numarası vardır. O tarihten itibaren o yasa kabul edilmiş demektir. Sonraki aşamalar yasanın kabul edilmesiyle ilgili değil ama yürürlüğü ile ilgili aşamalardır.

1. Aşama teklif aşaması: her konuda yasa teklifi sunma yetkisi TBMM'nin üyelerine tanınmıştır. 2017 Anayasa değişikliğine kadar yasalar ya milletvekili kaynaklı olurdu buna yasa teklifi denirdi. Ya da bakanlar kurulu kararıyla olurdu, buna da yasa tasarısı denirdi. 2017 Anayasa değişikliği ile yasalar yalnızca milletvekili kaynaklıdır. Herhangi bir milletvekili, tek başına yasa teklifi sunma yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi milletvekili tek başına kullanabileceği gibi, başka milletvekilleriyle birlikte de kullanabilir. Bir yasa teklifi 1.yazılı olmalıdır. 2. Teklif sahip ya da sahiplerinin imzasını taşımalıdır. 3. Gerekçeli olmalıdır. Gerekçe yasanın hem bütünü hem de her bir maddesi için ayrı ayrı yer almalıdır. Bu yasaya neden ihtiyaç var, bu yasayla nasıl bir sonuç elde edilecek. Bunun yazılı bir biçimde açıklanmasının belirtilmesi gerekiyor. Eğer bir teklif bütün olarak ve aynı zamanda her bir madde bakımından gerekçeli değil ise o zaman meclis başkanlığı, bunu uygulamada iade ediyor ve bu eksikliklerin tamamlanmasını talep ediyor. Teklif meclis başkanlığına veriliyor. Meclis Başkanlığı eksiklikler yok ise komisyona havale ediyor. Teklifler ve konu bakımından sınır yoktur. Yasama yetkisinin genelliği ilkesiyle her konuda yasa teklif etme yetkisine milletvekilleri sahiptir. Ancak iç tüzükte bir istisna getirilmiştir. O da yaralayıcı nitelikte ifadeler taşıyan tekliflerin meclis başkanlığı tarafından teklif sahiplerine iade edilmesi öngörülüyor. İç tüzükte bulunmamasına rağmen meclis başkanlığının anayasaya aykırı gördüğü teklifleri de teklif sahiplerine iade ettiklerini görüyoruz. Herşey uygunsa meclis başkanlığı bu teklifi ilgili komisyona gönderiyor. TBMM ve genel olarak bütün parlamentolar komisyonlar biçiminde çalışır. TBMM'ndeki komisyonlar, bakanlıklarla eş biçimde gider. Dışişleri, ME, Milli Savunma Komisyonu gibi. Bakanlıklar dışında da bir takım komisyonlar vardır. Örneğin Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa Komisyonu gibi. Teklifin içeriği hangi komisyonun uzmanlık alanına giriyor ise meclis başkanlığı teklifi komisyona havale eder. 2 şey önemlidir: birincisi esas diğeri tali komisyon. Esas komisyon, raporu genel kurul görüşmelerinde esas alınacak komisyona verilen addır. Tali Komisyon ise, raporu esas komisyona gönderilecek ve esas komisyon tarafından göz önünde bulundurulacak komisyona verilen addır. Meclis başkanlığı her teklifi bir esas komisyona yollamak zorundadır. Hangi komisyonun uzmanlık alanında ise. Tali komisyonun esas komisyon bakımından bağlayıcılığı yoktur ama esas komisyona yol gösterici bir nitelik taşıyabilir. Meclis Başkanlığı, dilerse sadece esas komisyona gönderir, tali komisyona göndermez. Yasalaşmanın mutfağı komisyonlardır. Bunlar uzmanlık komisyonlarıdır. Yasa, büyük ölçüde komisyonda somutlaştırılıyor. Komisyonlar, genel kurulun bir izdüşümüdür. Çünkü komisyonlar, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin güçleri oranındaki temsilcilerinden oluşuyor. Bu sebeple uygulamada komisyondan çıkan rapor o teklifin kabulü ya da reddi yönündeki rapor genel kurulda aynen kabul ediliyor. Komisyon aşamasında, konuya ilişkin uzmanlar var ise o uzmanlar hem sivil toplumun konuya ilişkin olan kesimleri komisyonda dinleniyor. Amaç, teknik bakımdan mükemmel bir yasa ortaya çıkarabilmektir. Eğer birden fazla komisyon aşamasında teklife ilişkin değişiklik önerisi var ise komisyon birbirine benzer olan teklifleri birleştirebiliyor. Komisyonun bu aşamada teklifleri değiştirebildiğini, değişiklik önerileriyle yeni maddeler eklediğini görüyoruz. Esas komisyon, genel kuruldaki görüşmeye kaynaklık edecek bir rapor hazırlar. Bu rapor, söz konusu teklifin kabulüne veya reddine ilişkin olabilir. Bu raporda, komisyon aşamasında değişiklik önerileri de dahil her şey yer alıyor. Komisyon, söz konusu raporu meclis başkanlığına veriyor. Meclis Başkanlığı, bu raporu bastırıp hemen milletvekillerine dağıtıyor. Bundan sonra milletvekilleri, söz konusu yasa teklifine ilişkin değişiklik önerileri verebilir. Bir milletvekili, aynı teklife ilişkin en fazla 7 değişiklik önergesi verebilir. Bu rapor dağıtıldıktan sonra en erken 48 saat sonra genel kurulda görüşülmesi için genel kurulun gündemine alınıyor. Biz bu 48 saate, serinleme süresi diyoruz. Bu milletvekilleri için hazırlık aşamasıdır. Ancak genel kurulda, komisyonun talebi üzerine genel kurulda yapılacak oylamayla 1 teklifin görüşülmesine 48 saat beklemeden başlanabilir. Yine o gündemdeki konuların üstüne koyarak en önce görüşülmesine başlanabilir. Bunun için genel kurulda basit çoğunlukla karar alınması gerekir. Bunun adı öncelikli görüşmedir. Öncelikle genel kurulda komisyonun raporu okunuyor. Arkasından söz konusu teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Buna siyasi parti grupları, komisyon temsilcileri ve aynı zamanda milletvekilleri söz alıp katılabiliyor. Herkesin söz hakkı iç tüzükte belirlenmiştir. Bu görüşmelerden sonra teklifin tümünden maddelerin tümüne geçmek için oylama yapılıyor. Eğer bu oylamada maddelere geçiş kabul edildiyse teklif genel kurulda görüşülmeye devam ediliyor. Reddedildiyse yasalaşma süreci orada bitiyor. Bu oylama, genel

kurulda yapılan diğer oylamalarda olduğu gibi anayasanın 96.md hükmüne bağlıdır. Buna göre TBMM toplantı yeter sayısı üye tam sayısının 1/3 ü yani 200 kişinin genel kurulda bulunması gerekiyor. Karar yeter sayısı ise basit çoğunluk yani toplantıya kayılanların salt çoğunluğu. 96.md bir alt sınır koymuştur. Üye tam sayısının ¼ ünden 1 fazlasından az olamaz yani 151 kişi ediyor. Bu toplantının karar yeter sayısıdır. Anayasada aykırı bir hüküm yok ise karar yeter sayısı üye tam sayısının ¼ ün 1 fazlası olmak zorundadır. Eğer teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildiyse o zaman maddelerin her biri için ayrı ayrı görüşme açılıyor. Bu aşamada değişiklik önergesi vermek mümkün olup bunu 5 milletvekili bir araya gelerek yapabilir. Sonra her bir madde ayrı ayrı oylamaya sunulur. Her maddenin görüşülmesi bitip oylandıktan sonra metnin bütünü için son defa oylama yapılıyor. Bu oylamada da 96.md gereğince kabul edilirse, meclis başkanı teklifi genel kurulda oy sonuçlarını açıklayarak teklifin kabul edildiğini duyuruyor. Artık teklif yasa haline gelmiş oluyor. Sonra CB'nına yollanıyor. CB, 15 gün içinde söz konusu kanunu resmi gazetede yayınlatabilir veya gerekçesiyle birlikte yazılı olarak TBMM'ne yeniden görüşülmesi için geri yollayabilir. CB'nın veto yetkisi 2 biçimde olabilir. Ya yasanın tümünü yeniden görüşülmek üzere yollayabilir ya da yasanın bir bölümünün yeniden görüşülmesini talep edebilir. Buna kısmi veto denir. Yasanın belli maddelerinin belli hükümlerinin görüşülmesini istemesi, her iki durumda da kanunun tümünü TBMM'ne yollamak zorundadır. Kanun, kural olarak bir bütün olduğu için o yüzden bazı maddelerine de itiraz ediyor olsa da bunu TBMM'ne yollamak zorundadır. Eğer kısmi bir veto söz konusu ise yalnızca CB'nın yeniden görüşülmesini istediği maddeleri görüşüp oylayabilir veya isterse yasanın tümünü görüşüp oylayabilir. Geri gönderilen yasada süreç yeniden başlamaktadır, TBMM yasayı bir bütün olarak kabul eder veya etmez. Geri gönderilen bir yasayı TBMM kısmen veya tamamen görüşmek zorunda değildir. Eğer görüşmezse o zaman o yasanın yürürlüğe girmesi mümkün olmaz. Ortadan kalkmış olur. TBMM, değiştirerek kanunu kabul ettiyse, o zaman değiştirdiği maddeleri CB yeniden meclise geri göndermesi mümkün. Ancak CB'nın geri gönderdiği kanun aynen kabul edildiyse artık CB buna direnme hakkı yoktur. Kendisine gelmesinden itibaren 15 gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır. Aynen kabul edilmesi için TBMM de üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekiyor. Artık basit çoğunluk yerine 301 oy gerekiyor. 61 ve 82 Anayasalarında 2017'e kadar CB'nın geri gönderdiği kanunların basit çoğunlukla kabul edilebileceğini belirtiyordu. Şimdi ise nitelikli bir çoğunluk getirilmiştir. Buna güçleştirici veto denir. CB'nın geri gönderme yetkisi çerçevesinde parlamento aynen CB geri gönderdiği kanunu nitelikli bir çoğunlukla kabul etmek zorunda ise bunun adı güçleştirici vetodur. Mutlak veto ise, devlet başkanının reddettiği kanunun yasalaşma imkanının olmamasıdır. CB, bir kanunu gerekçesiyle birlikte TBMM'ne göndermesi gerekmektedir. Bu 2 biçimde olabilir; 1. Hukuki bir gerekçe olabilir. 2. Takdiri yani yerindelik denetimi olabilir.

Temel yasa yöntemi: 1991 İç tüzük değişikliği ile birlikte girdi. Temel kanun, bir toplumun belli bir alanını, ceza, idari, usul kanunu, borçlar kanunu yani toplumsal ilişkilerin önemli bölümünü düzenleyen bir kanunda çok geniş değişiklikler yapılıyor ise ya da böyle bir kanun yeniden yazılıyor ise yasalaşma sürecini kısaltmak amacıyla oluşturulmuş kanun yapım yöntemidir. Bir temel kanun olarak görüşülen kanunda, her bir kanun maddesi tek tek görüşülüp oylanmıyor. 30 Maddeyi aşmayacak şekilde kanunlar tek bir kanun maddesiymiş gibi görüşülüp oylanıyor. Bu da kabul ve görüşme sürecini hızlandırıyor. Ancak temel kanun düzenlemesinde TBMM çoğunluğu tarafından hep kötüye kullanılıyor. 8-10 maddelik kanunların bile temel kanun biçiminde görüşüldüğüne tanık oluyoruz. Amaç, parlamentoda muhalefetin yasa yapım sürecine katılımını baltalamaktır. Demokratik yasa yapım tekniği ile bağdaşmayıp, anayasaya aykırılık oluşturuyor.

Torba kanun: ne iç tüzükte ne de anayasada var. Birbiriyle ilgisiz olan maddeler hızlı bir şekilde yasalaşarak yürürlüğe giriyor. Bunun olumsuz yönü: 1. Torba kanun biçiminde, maddelerin kanun yapılması geleneksel komisyon sürecini tamamen etkisiz hale getiriyor. Birden fazla esas komisyon olmaz. Birbiriyle ilgisiz maddelerden oluşan teklifi hangi komisyona göndereceğiz. Son yıllarda tali komisyonun, torba kanundaki maddeler için rapor hazırladığını görmedik. Bir başka olumsuz yönü, bu komisyon süreci ortadan kalkınca yasama hatalarını getiriyor. 2. Demokratik yasama süreci hem muhalefetin hem sivil toplum kuruluşlarının hem konunun uzmanlarının yasama faaliyetlerine etkili katılımını gerektirir. 3. Her kanunun 1. bütününe ilişkin olarak 2. her bir maddesine ilişkin olarak gerekçe yazılır. Bu hem uygulayıcılar hem de mahkemeler bakımından önemlidir. Torba kanunun gerekçesi karmaşık, ne dediği belli değil veya hiç gerekçe yazılmamıştır. Torba kanunun getirdiği bir başka durum; birden fazla alanı aynı anda düzenlediği için kanunlar teknik konuları ilgilendirdiği için çeşitli kurum ve kuruluşları ilgilendirir. Bu kurumların iletişimi zayıf olup bu da kanunun sakat olmaması gereken düzenlemeler içermesine neden oluyor. Bir başka sorunlu yönü, demokratik bir kanunlaşma süreci kanunun başkanlık divanına gelmesinden, genel kurulda kabul edilmesine

kadar saydam bir sürecin olması gerekiyor. Yasama sürecinin topluma açık olması gerekiyor. Torba kanun süreci demokratik olmayan bir yasama sürecinin kılıfı haline geldi. Yasanın hızlı olması değil meşru olması önemlidir. 1. Temel kanunun kötüye kullanılması 2. Torba kanun uygulamasının çok sık kullanılması 1 yasama yılı içerisinde kabul edilen kanunların yaklaşık %40'ı torba kanundur. Bu yöntem, muhalefeti devre dışı bırakmayı amaçlıyor. Sonuç: Bizde yasalaşma süreci demokratik değil. Temel demokratik yasama sürecine ilişkin ilkeleri içermiyor. Bunun en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor.

CB'nın geri gönderme yetkisi, 2017 anayasa değişikliklerinden sonra güçleştirici veto yetkisine dönüştü. 1961 ve 82 anayasalarında 2017 yılına kadar CB'nın geri gönderme yetkisi geciktirici bir veto yetkisiydi. Geciktirici veto yetkisi, devlet başkanlarının bir yasayı parlamentoya yeniden geri görüşülmesi için gönderdiği parlamentonun bu yasayı basit çoğunlukla aynen kabul edebilmesi anlamına geliyor. Mutlak veto yetkisi, devlet başkanlarının parlamentonun kabul ettiği bir kanunu veto etmesi ve bu vetoyu parlamentonun herhangi bir şekilde aşmasının olmaması yani o vetoyla kanunlaşma sürecinin bitmesidir. Resmi gazetede yayınlanma koşulu kanunun varlık koşulu değildir. Kanun zaten genel kurulda kabul edildiği anda o genel kurulu yöneten başkanın bunu duyurduğu anda, kanun haline gelmiş oluyor. Yayınlanma, o kanunun 3. Kişiler bakımından etki ve sonuç doğurabilmesi anlamına geliyor. Eğer bir kanun yürürlük maddesi içermiyorsa o zaman 10 sayılı CB Kararnamesine göre söz konusu kanun resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bu kanun yürürlüğe girmiş olur, eğer yürürlük maddesi içermiyor ise. Anayasa uygunluk denetimi için iptal davası açabilmek için yasanın resmi gazetede yayınlanması gerekir. Anayasada öngörülen özel nitelikli yasalar var. 1. Bütçe yasası: 1215 Magna Carta dan itibaren Anayasacılık hareketlerinin geliştiği bütün ülkelerde yürütme organının vergi koyma ve elde ettiği vergileri harcaması bakımından ulusun temsilcilerinden onay alması zorunluluğu vardır. Buna günümüzde parlamentonun bütçe hakkı deniyor. Yüzlerce yıldır var olan anayasacılığın da gelişmesinin temelini oluşturan bu hakkın bütün parlamentolarda sıkı sıkıya kurulan bir hak olduğunu görüyoruz. 1961 Anayasası, bütçenin nasıl yapılacağını iç tüzüğe bırakmadan ayrıntılı biçimde anayasada düzenlemiştir. Aynı yöntem 1982 anayasasında da yer almıştır. 2017 Değişiklikleri ile bütçe kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

Bütçe kanunu: Bir mali yıl içinde devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin gelir elde etmesi ve bu gelirleri harcaması iznini veren kanundur. Bütçe kanunu, diğer kanunlardan farklı olarak özel nitelikli yasalar içinde yer alıyor. Milletvekilleri, bütçe kanun teklifi veremez. CB tarafından verilecektir. 2017'den önce bu yetki bakanlar kuruluna aitti. Bizim mali sistemimizde, mali yılbaşı 1 Ocak'tır, 31 Aralık'ta sona erer. Bütçe kanunları 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir ve giderlerini açıklayan ve buna izin veren kanundur. CB, yeni mali yılın başlamasından en geç 75 gün önce meclise verir (md.161). Bütçe kanunu, esas komisyonu olan plan ve bütçe komisyonunda görüşülür. Bu komisyonda görüşmelerin mali yıl bitmeden en geç 55 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Amaç yeni mali yıl başlamadan bütçe kanununun kabul edilmesidir. Bütçe kanunu kabul edilmez ise, hiçbir devlet kurumu harcama yapamaz, gelir elde edemez, vergi toplayamaz. Bu nedenle yeni mali yıldan önce bu bütçe yasasının çıkması gerekir. 2017 Anayasa değişikliği daha önce hiçbir anayasada bulunmayan bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemede demokratik bir devlette bulunmayacak bir düzenleme olup hiçbir hükümet sistemiyle bağdaşmıyor. Md. 161/4 bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konamaması halinde geçici bütçe kanunu çıkarılır. Bununda çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar 1 önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirilerek artırılarak uygulanır. 1215 Magna Carta'dan beri insanlığın elde etmek istediği çabanın 4.fıkra ile ortadan kaldırılmasıdır. Bütçe kanunları, bütün demokratik rejimlerde parlamentonun yürütme organına karşı kullanabildikleri en eski silahtır. Bu silah, bu maddeyle parlamentonun elinden alınmaktadır. Artık CB, belli bir konuda parlamento ile uzlaşmasını gerektirecek hiçbir zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeni bütçe kanununun yapılmamasının hiçbir hukuki sonucu artık bulunmuyor. Özellikle başkanlık sistemlerinde, yürütmenin tek kişinin elinde toplanmasına karşı parlamento bu tek kişiye karşı bir denge oluşturmasının bir aracıdır, bu bütçe kanunu yetkisi. 2017 Anayasa değişikliği ile TBMM'nin artık böyle bir yetkisi yoktur. Genel kurul aşamasında anayasa, bütçenin görüşülmesi süresini bu kanunla kısaltmıştır. Milletvekilleri, komisyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ayrı ayrı konuşmuyor. Sadece değişiklik önermeleri konuşuluyor ve oya sunuluyor. Yürütme organının, bütçeyi yapacağı kararname ile delmesini engellemek, kendi siyasal çıkarlarına uygun olacak şekilde kamu çıkarına aykırı olacak şekilde bütçenin değiştirilmesini engellemek. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hüküm dışında hiçbir hüküm konulamaz. 1982 Anayasası torba yasaya ilişkin getirdiği bir yasaaktır bu. Bütçe ile ilgili hüküm demek mali nitelikte bir hüküm değildir. Bütçenin uygulanmasıyla ilgili uygulamayı kolaylaştırıcı ve kanun konusu olabilecek nitelikte hükümlerin konmamasını anlıyoruz. Buna rağmen bu

kanunun içine bütçeyle ilgili olmayan birçok hükmün olduğu bütçe örnekleri vardır. Bu kanun, AYM'nin denetimi altındadır. AYM, bu hükme aykırı davranılıp davranılmadığını önüne gelen başvurularda inceliyor.

Kesin Hesap Kanunu: 161. md. son 3 fıkrası, kesin hesap kanununa ilişkin düzenlemedir. Bir mali yıl içinde devletin ce diğer kamu tüzel kişilerinin bütçe kanunu çerçevesinde gelir elde edip etmediklerinin ve harcama yapıp yapmadıklarını denetleyen kanuna verilen isimdir. 1961 Anayasasından beri bizim anayasalarımızda bulunan bir düzenlemedir. Bu kanun, TBMM yetki alanı içinde yer alıyor. Bu düzenlemeyi CB Kararnamesi ile yapmak mümkün değil. Kesin hesap kanun teklifleri de CB tarafından verilir. İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç 6 ay sonra TBMM Başkanlığına sunulur. Kesin Hesap Kanunu öncelikle ilgili bütçe kanunu yürürlüğü sona erdikten sonra ilgili bütçe kanununun anayasa uygun olarak ve kanuna uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını tespit eden bir kanundur. CB tarafından en geç 6 ay sonra TBMM'ne sunuluyor. TBMM, bu denetimi sayıştay aracılığı ile yapıyor. Sayıştay, genel uygunluk bildirimi hazırlıyor. Her bir kamu kurum ve kuruluşu için kendileri için öngörülen gelir ve giderlere uygun davranıp davranmadıklarına ilişkin bir uygunluk bildirimi. Sayıştay, kanun teklifinin meclise verilmesinden itibaren en az 75 gün içinde TBMM'ne sunuyor. Kesin Hesap Kanun teklifi ve genel uygunluk bildirimi TBMM verildikten sonra tıpkı bütçe kanun teklifi gibi görüşülüyor. Yani esas komisyon plan ve bütçe komisyonu, oradan genel kurula gidiyor. Fakat burada görevli olan bütçe kanunu ile birlikte kesin hesap kanunun görüşülüp karara bağlanması eleştirilir. Çünkü bütçe kanunu ile kesin hesap kanunu 2 ayrı şeyi ifade ediyor. Yürütme organı, bütçe kanununa aykırı davranmış olabilir. Anayasaya aykırı olarak gelir ve gider temin etmiş olabilir. TBMM'nin bunu onaylayıp onaylamaması, gelecek mali yılda yürürlüğe girecek bütçe kanununu onaylayıp onaylamamakla aynı anlama gelmiyor. Bu sürecin birbirinden ayrılması gerekiyor. Bunun özel bir yasa olmasının nedeni: teklifin bütçedeki gibi CB'na ait olması aynı zamanda yöntem, usul, görüşülme ve kabul usulünün genel kanunlardan farklılık taşıması, Sayıştay'ın genel uygunluk bildiriminin ve görüşmede yerinin olması nedeniyle.

Uluslararası Antlaşmaların Uygun Bulunması Hakkındaki Kanunlar: 1982 Anayasası'nda yer almaktadır. Uluslararası antlaşmaları yürütme organı yapıyor. Bunların yapılması, imzalanmasının yetkisi yürütme organına aittir. Bu hükümet sisteminden bağımsız, bütün hükümet sistemlerine verilmiş bir yetkidir. 2017 Anayasa değişikliğinden sonra da uluslararası antlaşmaları imzalama yetkisi 1.CB'na 2. Dışişleri Bakanına 3. CB'nın vereceği bir yetki belgesine dayanarak herhangi bir bürokrata aittir. Yürütme organı bir UAA imzaladıktan sonra bu antlaşmayı iç hukukta etki ve sonuç doğurabilmesi için aynı zamanda uluslararası hukukta da Türkiye'yi bağlayabilmesi için Türkiye de bunun iç hukukta onaylanması gerekiyor. UA onaylama yetkisi de yürütme organındadır. Günümüzde bu yetki CB'na verilmiştir. Daha önce Bakanlar Kurulunda olan bir yetkiydi. Ancak 1961 Anayasasından bu yana bazı uluslararası antlaşmaların onaylanabilmesi için TBMM'nin bu onaya bir kanunla izin vermesi gerekir. Biz buna UA uygun bulunması kanunu diyoruz. Bu kanun ile TBMM, bir UAA uygun bulmasına ve onaylamasına izin veriyor. Bunu kanun yoluyla yapıyor. Bütün Uluslararası antlaşmalar bakımından TBMM'nin uygun bulmasına gerek bulunmamaktadır. Anayasa 90md/5 fıkra: uluslararası antlaşmaların yapılması, uluslararası hukuk bakımından TC ne sorumluluk getiriyor. Haliyle böyle antlaşmaların AYM önüne gitmesi, AYM'nin bunu anayasaya aykırı bulup iptal etmesi uluslararası sorumluluk bakımından devleti zor durumda bırakacak endişesidir. 2004 Yılında 5.fıkraya şu cümle eklendi "usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin UAA ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda UAA hükümleri esas alınır" diyor. Normlar hiyerarşisinde bu nitelikteki antlaşmalar kanunların üzerinde gözüktüyor. Aynı temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir UAA hükmü varsa bir de kanun hükmü varsa ikisi arasında bir çatışma varsa o zaman UAA hükmü esas alınır. Burada hak odaklı yorumladığımızda çatışma halinde hangi norm hakkı daha geniş koruyor ise o normun uygulanması gerekir.

Parlamento kararları (PK): TBMM'nin yasa adı altında yapmadığı genel kurulda kabul ettiği bütün işlemlere PK denir. Bu yalnızca genel kurulda alınan kararlara verilen isimdir. Örneğin: danışma kurulunda, meclis başkanlık divanında, meclis başkanlığında, komisyonlarda alınan kararlar parlamento kararı değildir. Bir kararın PK olabilmesi için mutlaka genel kurulda karar alınması gerekir. Söz konusu kararın yasa niteliğinde ya da yasa dışında olması gerekir. 1. Meclisin iç örgütlenişi ya da çalışmalarına ilişkin kararlar: Meclis iç tüzüğü, bu meclisin iç örgütlenmesine ve çalışmasına ilişkin bir hukuki belge ve teknik olarak meclis kararı biçiminde yapılan bir belgedir. Bunun dışında yine meclisin iç örgütlenmesi ve çalışmasına ilişkin karar örnekleri: başkanlık divanı seçimi, meclisin tatile girmesi, meclis seçimlerinin yenilenmesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, üyeliğin düşürülmesine dönük örnekler.2. Yürütme organıyla olağan ilişkileri

düzenleyen parlamento kararları var. Meclis soruşturmasının açılması CB, CB yardımcıları ve bakanlara karşı. Bunun sonucunda bu kişilerin yüce divana sevk edilmesi kararları PK'dır ve yürütme organı ile parlamento arasındaki ilişkileri düzenleyen kararlardır. Ayrıca yargı organı ile ilgili kararlarda var. Bu kararlar TBMM'nin seçme yetkilerine ilişkin kararlardır; HSYK üye seçiyor, AYM 3 üye seçiyor. Bu seçme işlemlerinde meclis bir parlamento kararı biçiminde yapıyor. Savaş ilanı: 1982 anayasasına göre savaş ilanı ancak TBMM'nin alacağı bir karar ile olabilir. TSK'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerinin Türkiye de bulundurulmasına izin verilmesi, RTÜK'e üye seçilmesi, Kamu Başdenetçisi'nin seçilmesi, CB'nca ilan edilen olağanüstü halin onaylanması, OHAL süresinin uzatılması, kısaltılması ya da kaldırılması kararları da PK biçiminde yapılıyor. Bu kararlar 3 istisna dışında yargı denetiminin dışındadır: Meclis içtüzüğü, yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları ve milletvekillerinin üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlar. Bu kararların, AYM tarafından denetlendiğini görüyoruz (148-151 md) Bunun dışında kalan kararlar herhangi bir yargı denetimine bağlı değildir. Meclis kararları, 3 kişilere etki ve sonuç doğuracak nitelikte kurallar koyan kararlar değildir. Siyasal nitelikte kararlar olduğu için hükümet tasarrufu olarak kabul ediliyor. Savaş ilanı tamamen siyasi bir karardır. Bu ilanın anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutulması söz konusu değildir. Buradaki sorun PK olarak yapılması gereken bir işlemi PK olarak yapıp yapılamayacağıdır. Kanunla ilgili düzenlemenin kanunla yapılması 3.kişilere etki ve sonuç doğurması anlamına geliyor. Aynı zamanda maddi bakımdan yasa denilince, genel, soyut, sürekli, kişilik dışı ileriye dönük nitelikte kural koyan bir normdan bahsediyoruz. Haliyle bir düzenleme bu niteliği taşıyorsa ama meclis bunu kanun yerine karar biçiminde yaptıysa burada bir anayasaya aykırılık söz konusu olacak. Karar biçiminde yaptığı için ama 3.kişilere yönelik etki ve sonuç doğuracak bir nitelik taşıdığı için düzenleme anayasaya uygunluk denetimi dışında tutulacak. Haliyle meclis çoğunluğu anayasaya uygunluk denetimi dışında tutmak istediği bir düzenlemeyi çok rahat bir şekilde karar biçiminde yapacak ve AYM'nin denetiminden kurtulacak. 2. olarak teknik bakımdan sorun. Maddi anlamda kanun niteliğinde olan bir düzenleme yapılırken yürütme organından bu düzenlemenin tekrerrütmesinde bir rolü vardır. Yani yasama organınca kabul edilen bir kanunun tamamlanabilmesi için araya yürütme organının işlevinin de girmesi gerekiyor. Eğer bu işlem karar biçiminde yapılırsa yürütme organının devre dışı bırakılması anlamına geliyor. Bunu hukuktaki anlamı, yetki ve usul saptaması demektir. Aslında TBMM'nin yetkisi olmayan bir normu düzenlemesi anlamına gelir. Yine usul saptırması çünkü kanun yöntemine bağlı kalınarak yapılması gereken bu düzenleme bu esaslar gözetilmeden yapılıyor burada bir anayasaya aykırılık durumu oluşuyor. Tersinden düşünersek, karar bakımından yapılması gereken bir düzenleme kanun biçiminde yapılıyorsa bu sefer yürütme organının bu işin içine dahil edilmesi anlamına gelir. TBMM kendi yetkisini yapmaması gerekirken yürütme organıyla paylaşır. Burada yine bir usul ve yetki saptırmasından söz edebiliriz. AYM, parlamento kararıyla yapılması gereken bir düzenlemeyi kanunla yapılmasını anayasaya aykırı bulmuyor. Örnek: 1991 yılında erken seçim kararı alınmasına ilişkin TBMM kararı, erken seçim kararını bir parlamento kararı biçiminde değil bir yasa biçiminde kabul etti. AYM, bunu anayasaya aykırı bulmadı. Buna karşı AYM, kanunla yapılması gereken bir düzenlemeyi PK ile yapılmasını AYM, anayasaya aykırı buldu. 1960 yıllarda 2015 yılına kadar eylemli içtüzük değişikliği adı verilen bir içtihat geliştirdi. TBMM, karar adı altında bir hukuki işlem yaptıysa ben aynı zamanda o normun içeriğine de bakarım. Gerçekte bir parlamento kararı mı değil mi. Eğer o bir parlamento kararı değil ise o zaman ben o normu anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutar ve iptal ederim demiştir.

İç tüzük: İç tüzükler, hukuki bakımdan bir parlamento kararıdır. Ama düzenledikleri alanın, siyaset bakımından, parlamentonun çalışması bakımından önemi nedeniyle iç tüzüklere 61 ve 82 anayasasında ayrı bir önem verilmiş. Bütün parlamentolar kendi iç işleyişini ve çalışmasını düzenleyen kurallar bütünü olan iç tüzüğü kendileri yaptıkları için bunlar parlamento kararıdır. Kanun biçiminde çıkmaz o zaman yürütme organı da işin içine girer. Bu tamamen parlamentonun kendi çalışması ve iç işleyişi ile ilgili bir konudur. İki meclisli parlamentonun 3 iç tüzüğü olur. Her iki meclis ayrı ayrı kendi iç tüzüklerini yapar. Bir de 2 meclis bir araya gelir bütün parlamentonun yapmış olduğu ortak işlemlerle ilgili olarak ortak bir iç tüzük yapar. 61 ve 82 Anayasaları iç tüzüklerin anayasaya uygunluk denetimine bağlanmıştır. Çünkü iktidar ve muhalefet dengesini öngören hukuki bir metin olduğu için Anayasanın 95.maddesi iç tüzüğe ilişkin bir düzenleme getirmiştir. 2.fıkra ile parlamentodaki siyasal çoğunluğu muhalefeti meclis çalışmalarının dışına itmesini engelliyor. 1. İç tüzük teklifleri milletvekillerinden geliyor. 2. Yasa yapımındaki usul ve esasları uyguluyor. Esas komisyon anayasa komisyonu raporunu hazırlıyor. Genel kurulda görüşülüyor. Kabul edilirse iç tüzük değişikliği ortaya çıkıyor. Bütün kararlarda olduğu gibi iç tüzük değişikliklerinin resmi gazetede yayınlanması için CB onayı gerekiyor. TBMM Başkanı, iç tüzük değişikliklerini resmi gazetede yayınlıyor. Bütün meclis kararları resmi

gazetede yayınlanmaz. İç tüzük hükmü niteliği taşıyan bir konunun mutlaka iç tüzük biçiminde düzenlenmesi gerekiyor. İç tüzükte yer alması gereken bir konu sıradan meclis kararı biçiminde yapıldı ise o zaman bunun anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutulması mümkün değil. Anayasa koyucu bunu anayasa denetimine bağlı tutmuş. AYM, TBMM'nin bunu kötüye kullanmasını engellemek için. 1. AYM göre bir kararın iç tüzük hükmü olup olmadığına karar verirken o kararın çözdüğü konu, alınmasındaki amaç, çözdüğü işin niteliği mahkeme göz önünde bulundurulur. Sıradan bir parlamento kararı ise anayasaya uygunluk denetiminin dışında iç tüzük hükmü niteliğinde ise o zaman bunu eylemli iç tüzük değişikliği olarak görüyor ve anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutuyor. 2. İç tüzükte bir kural olabilir. TBMM'nin yaptığı işlemle bu iç tüzükteki kurala aykırı hareket etmiş olabilir. Bu da eylemli olarak mevcut iç tüzük hükmünün değiştirilmesi anlamına gelir, AYM göre.

Yürütme Organının Temel Fonksiyonu: Yasama organının, anayasal düzlemde işlem yapabilmesi için ayrı bir yasayla bir kez daha yetkilendirilmesine ihtiyaç yoktur. Yasama yetkisinin genelliği, asliliği ve devredilmezliğinden bunu anlıyoruz. Yürütme organı ister 2017 öncesi ister 2017 sonrası için asli ve düzenleme alanına sahip olmakla birlikte bu istisnai bir yetkidir. Yürütme hem bir yetki hem de bir görevdir. Yürütme organının hangi işlemi olursa olsun kural olarak sadece anayasaya aykırı olmamakla yetinemeyeceği aynı zamanda hangi alanda işlem yapabileceğinin daha önceden kanunla belirlenmiş olması gerektiğini anlıyoruz. Bunların birtakım istisnaları mevcuttur. 2017 Anayasa değişikliğinden sonra 1. Olağan hallerde çıkarılan CB kararnameleri 2. Olağanüstü hallerde çıkarılan CBK'leri. Bunları istisna olarak almamızın temel nedeni; belli maddelerde örneğin "Bakanlıklar, CBK ile kurulur" ya da CB Genel Sekreterliği gibi bir takım alanların kararname ile sadece düzenlenebileceğini söylüyor. 2017 öncesinde; 1. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir KHK söz konusuydu. Bunun şundaki CBK'lerdeki içeriğinden farkı yok ama düzenleme yapabileceği işlemler olarak farklıdır. KHK uygulaması 2017 sonrasında CBK sinin çıkarıldığını görüyoruz. Md. 117 de çerçevesi tasarlanmış durumdadır. 2. Olağanüstü Hal KHK ve sıkıyönetim halinde çıkarılan KHK'lerin 2017 sonrasında farklı bir statüye bağlanmış olmasıdır. Artık sıkıyönetim diye bir kavramımız yoktur. 2017 Sonrasında OHAL CBK'sinin çıkarılabildiğini, CB'nda böyle bir yetkiyle donatıldığını görüyoruz. 3. Artık tüzük olarak düzenlememiz yok. Geçmişten gelen tüzükler yürürlükten kaldırılmadığı sürece uygulanmaya devam edecekler. 4. Yönetmelikler hakkında Anayasa 104 de görülen değişiklikler yönetmeliğin kapsamı açısından yürütmenin düzenleyici işlemi olarak 2017 yılından sonra gördüğümüz değişikliklerden biri.

Olağan hallerde çıkarılan CB Kararnameleri: Yalnızca yürütmeye ilişkin konularda çıkarılabilir. Bir diğer özelliği, belli konularda çıkarılamaz oluşudur. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri gibi ve siyasi haklar ve ödevler olarak sınırlanmıştır. Bu konular hakkında KHK ile düzenlemenin yapılamayacağı 82 Anayasasında da bulunmaktaydı. Bu CBK'lerinde de sürdürülmektedir. Sosyal ve ekonomik konulara ilişkin kararname ile düzenleme yapılabilir. Sadece kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK'nin çıkarılamayacağı. Sadece kanunla kurulabileceği söyleniyorsa o zaman bu alanda diğer yetkilerden güç alarak aynı alanın CBK ile düzenlenemeyeceğini söyleyebiliriz. CBK ile kanunların çatışması durumunda; kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Normlar hiyerarşisinde kanun öncelikliyse, o zaman CBK, kanunla eşit olmayıp kanunun altında yer aldığını söyleyebiliriz. Anayasa koyucu isteseydi Olağan Hal CB Kararnamelerinin de kanunla eşdeğer olduğunu kaleme alırdı. Olağan Hal Kararnamelerinin Anayasa denetimine tabii olması, OHAL Kararnameleri, Anayasanın denetiminin dışında. TBMM'nin onayına sunulmaz diyor CBK'lerinin. OHAL de çıkarılan CBK'lerinin aslında meclis denetimine sunulması, Olağan Hal Kararnamelerinin meclisin onayına sunulmaz.

OHAL'in İlkeleri: 1. OHAL, bir yasallık şartına bağlanmıştır. Bir yasaya dayanarak onun keyfi bir uygulama olmaktan çıkarır. 2. Keyfiliği önlemek için belirli nedenleri olmak zorundadır. 3. AİHM'nin aradığı İlan ve bildirim şartı. 4. Belli bir süreyle sınırlı olması. 2017 öncesinde sıkıyönetim kavramı varken 2017 sonrasında bu kaldırılmıştır. Her OHAL ilan nedenleri aynı düzeyde önlemleri hak etmez.

2017 anayasa değişikliği ile OHAL'in hangi nedenlerle ilan edileceği belirlenmiştir. Bunların dışına çıkılamaz. OHAL ile OHAL Kararnamesi birbirinden farklı 2 idari işlem. OHAL kararnamesi düzenleyici bir işlem olup diğeri idari bir karardır. 1. 2017Sonrasında OHAL için tek yetkili organ CB'liğidir. Onun tarafından ilan ediliyor olup yetki kullanımı da ona aittir. 2. Belli süre veya bölge şartı vardır. Yurdun tamamı veya bir bölgesinde de ilan edilebilir. Süresi 6 ayı geçemez. 3. Dört Ayı geçmemek üzere uzatılma ihtimali var. OHAL ilanının savaş halinde bu süre aranmaz. 4. OHAL ilanı resmi gazetede yayınlanıyor ve aynı gün TBMM'nin onayına sunuluyor. Meclis OHAL süresini kısaltabilir veya uzatabilir, OHAL ilanını ortadan kaldırabilir.

OHAL ilanında, vatandaşa getirilecek olan kısıtlamalar da Anayasa 15.md ye uygun hareket edilmek zorunda. OHAL'in kaç kez uzatılabileceği konusunda bir cevap yoktur. Bu sınırsız süre olağanüstü halle ülkeyi yönetebilme imkanı CB'nına veriliyor. OHAL Kararnamelerinde, CB'nın her konuda kararname çıkarabiliyor gözüküyor.

OHAL Kararnameleri: 1. AYM'nin denetiminin dışındadır. OHAL Kararnameleri kanun hükmündedir. 2. OHAL Kararnameleri aynı gün meclisin denetimine sunuluyor. Resmi gazetede yayınlanıyorlar. Meclis 3 ay içinde bunu görüşüyor.

Yasama Organının Kuruluşu: Yasama meclisi bir parlamentodan oluşur. Yasama organları bazı ülkelerde tek, bazı ülkelerde çift meclisten oluşuyor. Federal devletlerde çift parlamento vardır. Bölge devletlerde ise bölge vatandaşlarının temsil edildiğini görüyoruz. Üniter yapıli devletlerde de çift yapıli parlamentolara rastlayabiliyoruz. Daha çok milletvekili tarafından görüşülmesi daha sağlıklı karar alınması amaçlanmıştır.

Yasama organının seçiminde değişmez sabit sayı demek, ülke nüfusu kaç olursa olsun milletvekili sayısının aynı rakam olmasıdır. Nüfus esaslı sayıda ise, nüfus arttıkça milletvekilliğinin sayısının artması demektir. Bizde değişmez sabit sayılı yöntem kullanılmaktadır. Seçimlerin yenilenmesi Anayasada hükme bağlanmıştır. Beta 88 de 4 ayrı sebeple yenilenebilir. Ülkemizde Dont sistemi uygulanmaktadır. %10 Ülke barajlı nisbi bir temsil sisteminden bahsediyoruz. Azınlık oylarını da temsil edilebildiği seçim sistemidir. Md. 67 temsilde adalet, yönetimde istikrar aynı anda sağlanması hayli güç. Temsilde adalet için tüm azınlık oylarının yönetimde temsil edilmesi gerekir. Yönetimde istikrar sağlanabilmesi için çoğunluğun sağlanabilmesi ve o düzeyde istikrarın devam ettirebilmesini sağlayacak bir sistem olmalı.

YSK, seçim çevrelerinin bölünmesinden sorumlu. Seçimlerin ertelenmesi, ara seçim Betadan takip. Milletvekillerin hukuki statüleri Beta 94. Oy verme işlemi saat 17:00 da bittiğinde milletvekili, vekilliği kazanmış olur. Milletvekilliğine başlama şartı ant içme şartıdır. Ant içme göreve başlama şartıdır. Milletvekilliği sıfatını kazandığı an, yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu anlamında haklara sahip oluyor. Milletvekilliği ölüm ile sona erebilir. Seçim dönemi sona ermesiyle o dönem için milletvekilliği sona erer. CB Yardımcısı, Bakan olarak atanırsa milletvekilliği o zaman anayasaya göre milletvekilliği sona erer. Diğer seçenekler üyeliğin düşmesi başlığı altındaki seçeneklerdir. Devamsızlık, kısıtlılık gibi kararlar, istifa, milletvekilliğine engel bir suçtan kesin hüküm giyme (beta 95) istifa kararı TBMM kararlarıyla sonuç doğuruyor. Milletvekilinin, vekillikten istifa etmesi yeterli değil. Meclisin toplanıp istifayı kabul etmesi gerekiyor. Bunun sebebi 1. Parlamentonun sürekliliğidir. 2. Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi değil tüm ülkeyi temsil ederler. Bu temsili vekalettir. Emredici vekalet değildir. Kesin hüküm giyme veya kısıtlama kararları, mahkeme kararları genel kurula bildirilince milletvekilliği otomatik olarak düşüyor. Milletvekili, vekillikle bağdaşmayan işlerini sürdürmeyi ısrar ediyorsa o zaman da genel kurul kararı alınır. Ama daha öncesinde bu işin araştırılması için bir komisyon kurulmalıdır. Bu yetkili komisyonun bu yönde bir kararı gerekiyor. Genel kurulda gizli oyla karar alınıyor. Devamsızlık (beta 96). CB Yardımcısı ve Bakan olarak atananların milletvekilliği kendiliğinden düşer.

Yasama Uyumsuzluğu (md. 82): Milletvekilleri anayasal bir görev sürdürürken bunun için yasama uyumsuzluğu ayrıca düzenlenmiştir. Bu sebepten milletvekilliği düşüyor.

Yasama Bağışıklığı (Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı): Milletvekilleri temsil yetkisini kullanıyorlar. Bunu gerçekleştirirken de keyfi soruşturmalardan muaf tutulmaları temsili demokrasinin doğal sonucudur. O temsil mekanizmasının gereği gibi keyfi müdahalelerden ayrı olarak gerçekleştirilebilmesi için 1689'dan beri gelen haklar ödevidir.

Yasama Sorumsuzluğu: Anayasanın 83/1 de görülen meclis çalışmalarında milletvekillerinin oylarından, sözlerinden, ileri sürdüğü düşüncelerinden milletvekillerinin hiçbir şekilde herhangi bir soruşturmaya uğramadan vekilliğine devam edebilmesi ve bu soruşturmalarla karşılaşmaması amacıyla tasarlanmıştır. Bu, milletvekiline hem cezai hem de hukuki bir koruma sağlar. Dokunulmazlıktan farklı olarak sürekliedir. Yani milletvekili seçildiği andan itibaren milletvekilliği süresi boyunca ve milletvekili değilse devamındaki hayatı boyunca da devam etmektedir. Dokunulmazlık, milletvekilliği süresince sınırlıdır. Hiçbir şekilde sorumsuzluk, vekil kendisi istese dahi bu vazgeçilmez bağışıklık olduğu için meclis kararıyla kaldırılamıyor ve bu sorumsuzluktan vazgeçilemiyor. Anayasa 83/1 Başkanlık Divanı teklif ederse meclis milletvekiline sadece burada söyleyebilirsin diyebilir, dışarıda bunu kullanmasına sınır getirebilir. Hakaret ve sövme suçları, bunların her zaman iç tüzüğe göre disiplin suçudur. Yasama sorumsuzluğunun ana amacı, mecliste çalışma ortamının daha güvenli olmasının sağlanmasıdır.

Yasama Dokunulmazlığının, bir takım keyfi soruşturma ve keyfi cezai kovuşturmalardan bağımsız meclis çalışmalarının sürdürülebilmesidir. Burada ceza soruşturmasına karşı bir koruma vardır. Hukuki anlamda davalara taraf olunabilir. Yasama sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık kaldırılabilir bir muafiyettir. Meclis kararıyla yasama dokunulmazlığı kaldırılabilir. Bu AYM'nin denetimine tabidir. Yasama sorumsuzluğu gibi sürekli değildir. Milletvekili seçilmezse, bu dokunulmazlığı sona erer. Bir daha milletvekili seçilirse, her seferinde dokunulmazlık kazanır. Aynı zamanda kendisi istese de vazgeçilemez bir muafiyettir.

Dokunulmazlığın Kaldırılması: Meclis kararıyla mümkündür. 2016 yılında anayasaya geçici bir madde eklenerek o dönem meclise gönderilmiş fezlekeler hakkında md.83 yasama dokunulmazlığı uygulanmaz ibaresi getirildi. O zaman Anayasanın açık hükmüne aykırı bir hüküm getirilmiş olunuyor. Anayasa değişiklikleri sadece şekli açısından denetime tabii olup içeriğine bakılmıyor. Dolayısıyla yargı denetiminden muaftır. Sadece belli gerekçelerle ve parlamento kararıyla kaldırılabilir yasama dokunulmazlığı. Anayasada belirtilen 2 istisnası vardır. 1. Md 14 de geçen ifadelerden bir yargılama var ise 2. Ağır cezai gerektiren bir suçüstü hali varsa dokunulmazlık kaldırılabilir. Milletvekilliğinin düşmesi ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları, AYM'nin denetimine tabii 2 ayrı parlamento kararıdır. Bu karar 7 gün içinde AYM'nin önüne gitmek zorundadır. Sadece o konuyla ilgili milletvekili değil herhangi bir milletvekili de bu gerekçeyle AYM'ne başvurabilir. AYM, bunu 15 gün içinde görüşüp bitirmesi gerekiyor. Siyasi parti grupları 20 kişiden oluşur. Başkanlık divanı, iç tüzükte ve Anayasa 95/4 de yer alıyor. İç tüzük, meclisin kendi çalışma şekillerini, koşullarını belirler. Meclis çalışırken iç tüzük kurallarına aykırı hareket etmemek zorundadır. İç tüzük parlamento kararıdır. Başkanlık divanı kurulmadan meclis kuruldu sayamayız. Meclisin, işlevine başlayabilmesi için bir başkanın seçilmesi ve o meclis başkanlık divanında görev alacak siyasi partilerin oyları oranında temsil edecek kişilerin seçilmesi gerekiyor.

Başkanlık Divanı: TBMM'nin çalışmasına ve işlemesine ilişkin olarak kuralları koyan bu işleyişi düzenleyen divan. TBMM seçimler sonrası 2 yıl kalıcı olacak Başkanlık Divanını seçiyor. Önce bir geçici başkanlık divanı oluşturuluyor. Buraya başkanlık eden, seçilen 600 milletvekilinin en yaşlısı başkanlık divanına başkanlık ediyor. 6 Tane en genç milletvekilleri de katip üye oluyor. Bir Başkan vekili de seçiliyor. Bu başkan vekili meclisin en yaşlı 2. Üye milletvekilidir. Bu geçici başkanlık divanının görevi, meclisin çalışabilmesi, TBMM üyelerinin görevlerine başlayabilmeleri için yemin etmeleri gerekiyor. Yeni seçilen milletvekillerinin genel kurulda yemin işini yerine getirmekle görevli. Ayrıca kalıcı esas başkanlık divanının seçilme işini de yapmak. Anayasa md. 94'deki başkanlık divanı seçilir. O andan itibaren geçici başkanlık divanının görevi sona erer. Bu divanda TBMM başkanı, başkanvekili (4 kişi), katip üyeler ve idare amirlerinden oluşuyor. Bunun için iç tüzüğe bakmak gerekiyor. Bunların sayısı, danışma kurulunun teklifi üzerine TBMM genel kurulunda değiştirilebilir. İç tüzük değişikliği yoluyla TBMM bu sayıları azaltabilir veya artırabilir. Bunun amacı, siyasi parti gruplarının meclis çalışmalarına güçleri oranında katılması ilkesini getirdi. Bütün meclis çalışmalarında 1. Anayasa siyasal parti gruplarını esas alıyor. 2. Meclis bütün faaliyetlerinde bu grupların güçleri oranında katılmasını öngörüyor. Muhalefet partilerinin, meclis çalışmalarında kendilerini ifade edebilmeleri seçmenlerinin dileklerini belirtebilmeleri aynı zamanda da yürütme erkini denetleyebilmelerini sağlayabilmek. 94. Madde de başkanın seçimi: başkan tarafsız olmalı. Hem 61 hem de 82 anayasaları TBMM Başkanının tarafsızlığını benimsemiş anayasalardır. Geçici başkanlık divanına başkan adaylarının sunulmasında yalnızca milletvekillerine bu yetki verilmiş. Siyasi parti grupları, bir milletvekilini meclis başkanlığına aday gösteremez. Amaç şekli olarak TBMM Başkanının tarafsızlığını sağlamak. Yine bu tarafsızlığı sağlamak amacıyla meclis başkanının ve başkan vekillerinin oy kullanamaması ve üyesi bulunduğu siyasal partinin meclis içindeki ve dışındaki çalışmalarına katılmaması ilkeleri benimseniyor. Amaç hem meclis başkanının hem de onun bulunmadığı durumlarda genel kurulu yönetmekle görevli başkan vekillerinin biçimsel tarafsızlığını sağlamak.

Meclis başkanının seçimi: Seçimler yapıp TBMM'nin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde geçici başkanlık divanına meclis başkanlığı için adaylar sunuluyor. Bu adaylar içinden genel kurulda başkanlık için seçim yapılıyor. İlk 2 turda TBMM üye tam sayısının en az 2/3'sini bir aday elde etmiş ise o aday meclis başkanı seçilmiş oluyor. İlk 2 turda hiçbir aday bu nitelikli çoğunluğu elde edememişse 3.oylama yapılır. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yeterli oluyor. Hiçbir aday, TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oyu elde edememişse 4. ve son oylama yapılıyor. Bu oylamaya bir önceki oylamada en çok oy almış olan 2 aday katılıyor. Bu adaylar arasında kim en çok oyu aldıysa o meclis başkanı seçilir. 1982 anayasası, TBMM Başkanlık seçimini en çok 4 oylamada sonuçlandırıyor. Buna rasyonelleştirilmiş

parlamenterizm denir. Bu parlamentonun işleyişini kolaylaştırmıştır. Başkan dışında, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinin sayısı, danışma kurulunun önerisi üzerine genel kurulda yapılacak oylamayla belirleniyor. Bu üyelikler, mecliste grubu bulunan siyasi partiler arasından güçleri oranında paylaştırılıyor. Başkanın görevi iç tüzükte yazılıdır: 1. TBMM'nin temsil yetkisi 2. TBMM genel kurulunu yönetme yetkisi ve görevi 3. Bu genel kurulda yapılan görüşmelerin, konuşmaların, oylamaların tutanağa bağlanması ve tutanak dergisinde yayınlanmasını gözetme görevi. Başkan Vekilinin görevi ise, meclis başkanının yönetmediği genel kurul görüşmelerini yönetme yetkisi ve yine yönettiği genel kuruldaki görüşmeleri tutanağa bağlanması ve tutanak dergisinin yayınlanması yetki ve görevine sahip. Katip üyeler ise, genel kurulda yapılan oylamaların gözetimiyle denetimiyle sorumlu. Oylamaların yapılması, sayılması yine toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı olup olmadığına ilişkin oylamaları gözetmesi bu oylamadaki sonucu sayarak genel kurula ilan etmesi gibi görev ve yetkileri var. İdare amirinin görev ve yetkileri ise, TBMM'nin mali konularıyla ilgili. Elde ettiği geliri yine meclis çalışmalarında ve meclis kampüsü içinde nasıl harcandığı, bunun denetimi, gözetimi idare amirlerinin yetki ve görev alanı içinde. Başkanlık Divanı seçimleri bir yasama dönemi içinde 2 kere yapılır. Seçimler yapıldıktan sonra seçilen başkanlık divanı 2 yıl görevde kalır. 2 Yılın sonunda, başkanlık divanı seçimleri yenilenir. Bu seçimler sonucunda oluşturulan başkanlık divanı o yasama döneminin sonuna kadar görevde kalır. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa yeni seçimler yapıp yeni başkanlık divanı oluşturulana kadar görevde kalırlar. Anayasanın 95.maddesi siyasal parti gruplarını düzenliyor. TBMM bütün çalışmalarında siyasal parti gruplarını esas alarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. En az 20 kişiden oluşur bir siyasal parti grubu. Bu sayıdan az ise siyasal parti grubu oluşturamıyor. Bu o siyasal parti grubunun TBMM çalışmalarına katılması bakımından dezavantajlı bir durum. Bazı komisyonlar dışında bütün komisyonlar siyasal parti gruplarının temsilcilerinden oluşuyor. Grubu bulunmayan milletvekillerinin bu komisyona üye olması mümkün değil. 1961 anayasasında grup kurulması için gerekli sayı 10 milletvekili idi. 82 de bu sayı artınca muhalefetteki siyasal partilerin TBMM çalışmalarına katılımını güçleştiren bir sayı.

İç tüzüğün 19.maddesine göre bir de danışma kurulu vardır. Bu kurul, meclis başkanından ya da meclis başkanının belirleyeceği bir başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Siyasal parti grubu başkanları ya da başkan vekillerinden biri veya başkanların kendi grupları içinden belirleyeceği bir milletvekilinden oluşur. Danışma kurulunun kompozisyonu parti gruplarının güçleri oranında temsil edilmesi esasına bir istisnadır. Bütün siyasal parti grupları eşit biçimde tek üye ile temsil ediliyor. Danışma kurulu kararları oy birliği ile alınır. Meclisin çalışması ve işleyişine ilişkin konularda genel kurula görüş bildirmek, yol göstermek gibi görevleri vardır. Her siyasal parti grubu eşit bir biçimde temsil edildiğine göre danışma kurulundan oy birliği ile çıkacak bir karar, genel kurulda bütün siyasal partilerin o yönde oy kullanmasını sağlayacaktır. Bu da genel kurul çalışmalarını hızlandıracaktır. 1990-2002 arasında bu kurulun etkili bir şekilde çalıştığını görüyoruz.

Komisyonlar: Bütün yasa yapım ve TBMM'nin görüştüğü diğer işler bakımından işin mutfağıdır. Yasa tekliflerinin gözden geçirilmesi ve genel kurula enine boyuna görüşülmüş biçimde getirilmesi görevi komisyonlarındır. Siyasal partiler, güçleri oranında üye verirler. Kural olarak danışma kurulunun teklifi üzerine genel kurul her bir komisyonun kaç üyeden oluşacağını belirtir. Bunun 2 istisnası vardır 1 Plan ve bütçe komisyonunun üye sayısı anayasa ile belirlenmiştir. 2. Kamu iktisadi teşebbüsleri komisyonu ve insan hakları inceleme komisyonu üye sayısı da o komisyonu kuran kanun tarafından belirlenmiştir. İç tüzük ve genel kurul kararı ile bu komisyonların üye sayısında değişiklik yapmak mümkün değildir. Fakat bunların dışındaki komisyonlarda değişiklik her zaman yapılabilir. Komisyonlar, sürekli, geçici, karma biçiminde oluyor. Sürekli komisyon yasa tekliflerini görüşen, ellerindeki iş bitse bile dağılmadan sürekli nitelikte olan komisyona verilen ad. Bugün iç tüzüğe göre 16 komisyon var. Bu komisyonlar genel olarak bakanlıklarla eş güdümlüdür. Bu komisyonlar esas ya da tali komisyon biçiminde çalışan sürekli komisyonlardır. İç tüzükte yapılacak bir değişiklikle bu komisyonların sayısı artırılabilir ya da azaltılabilir. İstisna, anayasa ya da kanunla kurulmuş bir komisyon olmaması. Bu komisyonlarda değişiklik yapılabilmesi, bunların kaldırılabilmesi için kanunda veya plan ve bütçe komisyonu bakımından anayasada değişiklik yapılması gerekir. Bunun dışındakiler bakımından TBMM de genel kurul kararıyla iç tüzükte yapılacak bir değişiklikle yeni komisyonlar eklenebilir var olan komisyonlar da kaldırılabilir. Geçici komisyon, belli bir işe özgülenmiş komisyondur. O işi araştırmak amacıyla kurulmuş ve bu amacını gerçekleştirdikten sonra kendiliğinden ortadan kalkan komisyondur. Örneğin araştırma komisyonları, genel kurulda alınan bir kararla kurulan komisyonlar. Kuruldukları konuya ilişkin olarak araştırmayı yapar, raporu yazar genel kurula sunarlar ve ondan sonra bu komisyonların görevi biter ve kendiliğinden ortadan kalkarlar. Bunun adı geçici komisyondur. Karma

komisyon ise, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, yasama sorumsuzluğu, üyeliğin düşmesi ne ilişkin konularda genel kurula bir rapor hazırlayan komisyonlar. Adalet ve anayasa komisyonu üyelerinin toplamından oluşur. Komisyonlar da, başkanlık divanı gibi bir yasama dönemi boyunca 2 kere seçilirler. İlk seçilenler komisyonda 2 yıl görev yaparlar. Ondan sonra seçilen komisyonlar 3 yıl ya da yeni seçimler yapılincaya kadar görevlerinde kalırlar.

Yasama dönemi: 2 genel seçim arasında geçen döneme verilen isim. Bu arada ara seçim yapılabilir. Ara seçim yasama döneminin tamamlanmasında göz önünde bulundurulmaz. Genel seçimler göz önünde bulundurulur.

Yasama yılı: TBMM her yılın kendiliğinden (çağrısız olarak) 1 Ekim de toplantıya başlar. Parlatentonun çağrısız olarak kendiliğinden toplanması usulünü ilk defa 1908 anayasa değışiklikleri ile girdi. 1 Ekim-30 Eylül arasındaki döneme yasama yılı deniliyor.

Birleşim, belli günde açılan toplantısına verilen isim. Kuşkusuz genel kurul isterse çalışma saatlerini uzatabilir ya da kısaltabilir. Ama iç tüzüğe göre bu 3 gün çalıştığı ve birleşimin açıldığı günlerdir.

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarının her birine verilen ad. Bir birleşim içinde bir oturum olabileceği gibi birden fazla oturumda yapılabilir. Meclis başkanı, oturuma ara verilmesi veya ara verilmemesi kararını verecek kişidir. Genel seçim sonuçlarını, resmi olarak açıklama yetkisi YSK'nundur. Resmi genel seçim sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 gün içinde TBMM'nin toplanması gerekiyor. Bu toplantı olağan bir toplantıdır.

Tatil, TBMM'nin çalışmalarına belli bir süre ara vermesidir, ertelemesidir. Anayasaya göre bu süre 1 yasama yılı içinde en çok 3 ay olabilir. 1 Temmuz tarihinde TBMM, iç tüzük hükmünce tatile girer, 1 Ekim' e kadar.

Ara verme, tatilin dışında TBMM'nin 15 günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir. Ara verme, meclisin tatil tarihlerinin dışında kalan bir zaman aralığında genel kurulun en çok 15 gün olmak üzere çalışmalarını durdurması anlamına geliyor.

Olağan toplantı: TBMM'nin Salı-Çarşamba-Perşembe günleri ve ara verme tatilde olmadığı dönemlerde yaptığı toplantıya denir.

Olağanüstü toplantı: Belli bir konuya ilişkin olarak TBMM ara vermiş veya tatilde ise bu süre içerisinde ara vermeyi veya tatilini kesip genel kurulunu toplantıya çağırması anlamına geliyor. 2 Kaynak tarafından çağrılıyor; CB ve Meclis Başkanı. Meclis Başkanı bakımından 2 durum söz konusudur. 1. Meclis başkanı kendisi çağırabilir. 2. TBMM üye tam sayısının en az 1/5'inin yazılı ve gerekçeli önergesi üzerine yine Meclis başkanı, TBMM'ni olağan üstü toplantıya çağırabilir. Bu durumda meclis başkanının bir takdir yetkisi yoktur. Bu talep ortaya çıktıktan itibaren 48 saat geçmedikçe yapılamaz ve 7 günden sonraya da bırakılamaz. Bu hangi konu ise, bu konu görüşülmesi bitmeden genel kurul dağılamaz. Eğer böyle bir konu gerekçesiyle genel kurulda görüşüldüyse meclis ara vermişse kaldığı yerden ara vermeye devam eder, tatilde ise tatile kaldığı yerden devam eder. Aksi yönde karar almadıysa. TBMM de kararlar, aksine bir anayasa veya içtüzük hükmü yok ise basit çoğunlukla alınır. Bu kararlar da basit çoğunluk gerektiren kararlar arasındadır. Anayasa 96.md. toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının en az 1/3'ü 200 milletvekili olup, karar yeter sayısı da anayasada aksine bir düzenleme yok ise katılanların salt çoğunluğu yani basit çoğunluk olup buna bir alt sınır getirilmiştir. Hiçbir şekilde karar yeter sayısı üye tam sayısının 1/4'ünün 1 fazlasından az olamaz diyor. Kural, genel kurul toplandığı zaman toplantı yeter sayısının var olduğu kabul edilir. Toplantıyı yöneten başkan, 200 milletvekilinin hazır bulunmadığını düşünüyorsa o zaman yoklama yapar. Herhangi bir milletvekili de toplantının başladığı anda hem de toplantı devam ettiği sürece yoklama yapılmasını talep edebilir. Eğer yapılan oylama ile 200 milletvekilinin hazır bulunmadığı yapılan oylama ile tespit edilirse o zaman toplantı sona erer. Toplantı yeter sayısı, genel kurulda görüşmelerin başlaması için yeterli olan sayı. Karar yeter sayısı ise genel kurulun belli bir konuda karar alabilmesi için gerekli asgari sayıdır. İttüzüğün 139.md.'si TBMM'nin oylama usullerini belirtiyor. 3 Tür oylama vardır: 1. İşaretle 2. Açık 3. Gizli oylama biçiminde.

İşaretle oylama: Milletvekillerinin kabul red ya da çekimser biçiminde el kaldırmasıyla yapılan oylamadır. Yapılan sayım sonucuna göre o yönde karar alınmış kabul ediliyor.

Açık oylama ise: elektronik oylama mekanizmasıyla yapılan oylama her milletvekilinin ne tür oy verdiği bellidir. Bu sebepten adı açık oylamadır. Bir diğer yöntem, her milletvekilinin tek tek başkanlık divanı tarafından adının okunmasından sonra kabul, red ya da çekimser sözcüklerinden birinin söylenmesi biçiminde olur. 3. Açık oylama biçimi, milletvekillerinin eline 3 pul verilir, bu pullar beyaz, yeşil ve kırmızı renktedir.

Her pulun üzerinde milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevresi yer alır. Beyaz pul kabul, kırmızı red, yeşil ise çekimser anlamına gelir ve milletvekili görüşüne göre bu pullardan birini kurulan sandıklara atar.

İşaretle oylama: genel kurul salonunda kabul oyu verenlerle red oyu verenlerin fiziki olarak 2'ye ayrılması ve bunların tek tek sayılması biçiminde yapılabilir. Meclisin yaptığı uygulama el kaldırma biçiminde olur. **Gizli oylama** ise, milletvekillerinin her birine üzerinde hiçbir işaret olmayan 3 pul verilmesi ve sandıkların genel kurulda kurulması ve bu sandıklara milletvekillerinin bu 3 puldan birini atmak yoluyla oy kullanmasıdır. Kimin ne oy kullandığı belli değildir. Kural işaretle oylamadır. Anayasada açık bir şekilde, belli bir kanunun gizli veya açık oylamayla yapılması öngörülüyor ise artık o oylamanın başka türlü yapılması mümkün değildir. Buna karşılık işaretle oylama genel kurulda alınacak bir kararla açık oylamaya ya da gizli oylamaya dönüştürülebilir. Bunun için anayasa ya da içtüzükte aksine bir hüküm olmaması gerekir. Mutlaka işaretle oylama yapılır diyorsa içtüzük, o zaman bunun değiştirilmesi mümkün değildir.

Meclisin görev ve yetkileri: Para basmak, kanun yapmak, üye tam sayısının 3/5 ile af ilan etmek, uluslararası antlaşmayı onaylamak, savaş ilanına karar vermek gibi anayasada yer alan diğer görev ve yetkileri de yapıyor TBMM. Diğerleri ise; 1. Yürütme organını denetlemek, 2. OHAL ilan kararı ve OHAL Kararnamelerini onaylamak. Yürütme organını denetlemek TBMM'ne verilen en önemli yetkilerden biridir. Bütün parlamentoların 2 önemli yetkisi vardır. Biri kural koymak, yasa yapmak diğeri ise yürütme organını denetlemek. Bu yetkiler ne kadar daraltılmış ise parlamento ile yürütme organı arasındaki denge parlamento Aleyhine o kadar bozulmuştur. 82 Anayasasında yürütmenin denetlenmesi bakımından sahip olduğu düzenlemeler 98.md. de yer alıyor. Yürütme organını denetleme araçları, yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturmasıdır. 1982 anayasasının ilk biçimine göre ve 1961 anayasası döneminde milletvekilleri yürütme organına yani Bakanlar Kuruluna ya da ilgili bakana kendi görev alanlarıyla ilgili olarak, belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla sözlü ya da yazılı soru sorabiliyordu. 2017 anayasa değişikliği sözlü soruyu kaldırdı. Yalnızca yazılı soru yöntemini koydu. 1. Soru sorma yetkisi her bir milletvekiline tanınmış bir yetkidir. 2. Soru, yürütme organında yürütme yetkisini kullananlara yöneltiliyor. Parlamenter bir sistemde Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Bakanlar. Yarı başkanlık sisteminde Başbakan, BK ve Bakanlar, Başkanlık sisteminde Başkan ve Bakanlar. Bunların olması gerekiyor Çünkü bu yürütmeyi denetleme aracı. Yürütme sistemine göre yürütme yetkilerini kullananları göstermekle birlikte bu yetkiyi kim kullanıyorsa onlara yönelik olur. İster sözlü, ister yazılı olsun bütün sorular milletvekilleri tarafından yazılı ve gerekçeli olarak meclis başkanlığına verilir. Sorunun muhatabı, parlamentoda genel kurulda sözlü olarak bu soruyu yanıtlar veya parlamento başkanlığına o yanıtını iletir. Başkanlık da gelen cevabı soruyu soran milletvekiline verir. Hükümeti denetlemek bakımından erkili olan sözlü sorudur. Sözlü soru olduğunda ilgili bakan meclis kürsüsüne geliyor ve bu soruyu yanıtlıyor. Bu soruyu yanıtladıktan sonra soruyu soran milletvekili o yanıtı ek bir cevap isteyebiliyor. Ya da o yanıtı yönelik olarak ek bir soru sorabiliyor. Yürütme organı temsilcisiyle yasama organının temsilcisi arasında bir diyalog ortaya çıkıyor. Bu kuşkusuz ki o bakan ya da Başbakan'ın belli bir konuda tatmin edici bir cevap vermesi bakımından son derece etkili bir yöntem. Bütün demokratik parlamentolarda son derece etkili bir şekilde kullanılıyor. Yazılı soruda ise bu diyalog yoktur. Sorunun yazılı olarak yanıtlanıp ya da yanıtlanmaması durumunda herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Günümüzde yazılı sorunun yürütme organını denetlemek amacıyla hiçbir işlevi yoktur. Üstelik 2017 anayasa değişiklikleriyle sözlü soru yöntemi de kaldırıldığı için artık adı olup kendi olmayan bir denetleme yöntemidir. Bütün milletvekillerinin CB Yardımcılarına ve bakanlara soru sorma yetkileri vardır. Bu başkanlık sisteminde görülmeyecek vahim bir durumdur. Yürütmenin başı, tek yetkilisi CB, meclis yürütmenin başı ve yetkilisine soru soramıyor. Sorular CB Yardımcıları ile atanmışlara, hiçbir sorumluluğu olmayanlara. 2. Olarak yazılı sorular, sorunun muhatabına ilişkin kişisel, özel yaşama ilişkin konular ya da sorular içeremez. O konunun muhatabıyla doğrudan onun görev alanındaki bir konu olması gerekir. Yazılı soru gerekçeli olur ve meclis başkanlığına verilir. İchtüzüğe göre muhatabın yazılı soruyu 15 gün içinde cevaplaması gerekir. İchtüzük ya da anayasa bu soruların cevaplanmamasına ilişkin bir yaptırım getirmemiştir. Cevaplanan soruların da uygulamada nitelikli cevaplar olmadığını görüyoruz. Uygulamada bu yazılı soru kurumunun yürütme organını denetlemek bakımından hiçbir etkisi yoktur.

Yasam Organının Yürütmeyi Denetleme Araçları: 1. Yazılı soru önergesi 2. Genel görüşme 3. Meclis araştırması 4. Meclis soruşturması. Bunlar anayasanın 98. Md. de yer alıyor. Ancak bunların nasıl işlediği içtüzükte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

2. Genel görüşme: İç tüzüğün 101 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. Genel görüşme, toplum ya da devlet faaliyetlerine ilişkin bir durumu meclis genel kurulunda görüşülmesine verilen isimdir. **1.** Siyasi parti grupları **2.** En az 20 milletvekili genel görüşme açılması yönünde TBMM Başkanlığına önerge verme yetkisine sahiptir. Bütün önergeler gibi genel görüşme önergesi de gerekçeli olmalıdır. Bu gerekçede 500 sözcüğü geçmemelidir. Bu önergenin kabul edilip edilmeyeceğine genel kurul karar veriyor. Genel kurulda işaretle oylama yapılıyor. Basit çoğunluk aranır. Eğer genel görüşmenin açılması yönünde karar alınırsa o zaman alınan karardan 48 saat geçmedikçe ve 7 günü aşmamak şartıyla genel kurulda bu ilgili genel görüşme açılıyor. Genel görüşme önergesi verenlerin ve siyasi parti gruplarının bu konuda görüşlerini bildirmesi söz konusu. Bunun sonucunda herhangi bir oylama yoktur. Haliyle bu yürütme organı açısından siyasal ya da cezai bir sorumluluğa yol açan bir denetim mekanizması değildir. Bu yüzden de etkisi sınırlıdır. Genel görüşme, herhangi bir oylama ile sonuçlanmadığı için bunun yürütme organı bakımından siyasal ya da cezai bir sonucu yoktur. Ancak genel kurul görüşmeleri kamuya açık olduğu için TV ya da diğer sosyal medya aracılığı ile yayınlandığı için bu tür görüşmelerin kamuoyu oluşturmak bakımından bir anlamı olabilir.

3. Meclis araştırması: İçtüzüğün 104. Ve devamındaki maddelerde düzenleniyor. Meclisin, herhangi bir konuda kuracağı bir komisyon aracılığı ile inceleme yapması ve bilgi edinmesi yoludur. Konu bakımından herhangi bir sınırlama yoktur. Bir istisnası vardır. Ticari sırlar ile devlet sırları meclis araştırmasına konu olamaz. Ticari sır kavramı çok geniş olarak tanımlandığı için pek çok şeyi bu kavram içine alabiliriz. Ve meclisin denetiminin ve incelemesinin dışında tutabilirsiniz. Bu kanun ve bunun yorumlanması demokratik devlet ilkesini zedeleyen bir görüntü sergiliyor. Hem devlet sırrının hem de ticari sırrın açık bir şekilde sınırlarının ve tanımının açık bir şekilde kanunla yapılması gerekir. Soyut bir şekilde tanımlarla, yasama organının denetleme organını denetlemesini zorlaştırır. Meclis araştırması için önerge verilmesi gerekir. Genel görüşmeyle ilgili aynı yani siyasal parti grupları ya da en az 20 milletvekili belli bir konuda meclis araştırmasına ilişkin TBMM başkanlığına verebilir. Bu önerge yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Böyle bir meclis araştırması yapılıp yapılamayacağı ve bu araştırma çerçevesinde komisyon kurulup kurulmayacağına genel kurulda karar verilir. Bu durumda kurulacak komisyon geçici nitelikteki komisyondur. Bu komisyona, siyasal partiler güçleri oranında üye verirler. Bu kurum çok sayıda kurum ve kuruluştan bilgi talep edebilir. Bu kuruluşlarda bu bilgiyi araştırma komisyonu ile paylaşmak zorundadır. Hazırlanan rapor meclis başkanlığına sunulur. Bu rapor milletvekillerine dağıtıldıktan sonra genel kurulda görüşülür. Komisyon adına hem komisyon başkanı hem siyasal parti grubunun temsilcileri hem de milletvekilleri genel kurulda görüşlerini bildirirler. Bu raporun, görüşülmesinin oylamaya konu olması söz konusu değildir. Yürütme organı açısından, ne siyasal ne de cezai bir karşılığı vardır. Bu tür komisyonlar konuya ilişkin yasal boşlukları açığa çıkarmak ya da yasalardaki yanlış düzenlemeleri ortaya koymak gibi önemli bir işlev yerine getirebilir. Bu komisyon raporlarının genel kurulda tartışılmasında kamuoyu oluşturma, kamuoyunun dikkatini belli bir konuya çekmek bakımından önemli bir işlev görebilir.

4. Meclis Soruşturması: CB, CB yardımcısı ve Bakanların görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı yüce divana sevk edilip edilmemesine ilişkin bir denetim yoludur. En önemli sonuç doğuran denetim yoludur. Yürütme organı CB ve yürütme organının diğer unsurları görünürken ayrıntısı bulunacak.

Yürütme Organı: Tekçi (Monist) Yürütme: yürütme erkinin tek bir kişinin veya organın elinde olduğu yürütme biçimine verilen isim. Günümüzde hükümet sistemleri bakımından başkanlık sistemi tekçi yürütme anlayışını benimseyen bir yürütme biçimidir. Çünkü yürütmeye ilişkin bütün yetkiler tek bir kişinin elinde toplandığı için.

Düalist (İkici) Yürütme: Yürütme erkini 2 makam 2 organ arasında paylaşıldığı yürütmeye verilen isim. Parlamenter sistem de yarı başkanlık sisteminde de yürütme 2 başlıdır. Bir taraftan devlet başkanı vardır. Diğer taraftan başbakan ve bakanlardan oluşan bakanlar kurulu vardır. Bu 2 baş arasındaki yetki bölüşümü hükümet sisteminin parlamenter mi yoksa yarı başkanlık mı olduğunu bize gösterir. Eğer devlet başkanının hatırı sayılır nitelikte icrai bazı yetkileri varsa o hükümet sistemi yarı başkanlık sistemidir. Yarı başkanlık ya da parlamenter sistem olması önemli değildir. Her iki hükümet sisteminde yürütme erki tek kişiden tek organdan oluşmaz. 2 organ (1 kişi veya 1 organ) yürütme erkini birlikte kullanır. O nedenle ikici yürütme denir. Birde ortaklaşa yürütme dediğimiz bir yürütme biçimi vardır. Biri 1795-1799 arasında Direktuvar dönemidir. Orada yürütme erki, direktuvar adı verilen 5 kişi arasında paylaşılıyordu. 1799'da Fransa'da uygulanan Konsüllük rejiminin ortaklaşa yürütmeye verebileceğimiz bir diğer örnek. Yürütme erki, konsül adı verilen 3 kişi arasında paylaşılıyordu ve bu 3 kişi dönüşümlü olarak yürütme erkini kullanıyordu. Napolyon darbe yapınca

kısa sürdü. Günümüzde en yakın örnek İsviçre örneğidir. İsviçre’de CB, devlet başkanı, başbakanlık makamı yoktur. Federal konsey başkanı var ve bu başkanın görev süresi 1 yıl ve 7 kişilik federal konsey içinde, bu konseyin 7 üyesi birer yıl süreyle bu görevi yerine getiriyor.

1982 Anayasasında yürütme organı: yürütme ya da hükümet dediğimiz zaman bunu bir dar anlamda bir de geniş anlamda anlıyoruz. Dar anlamda yürütme: yürütme erkini elinde bulunduran ve en üst düzeydeki seçilmiş siyasal kişi ya da organlara verilen isimdir. Örneğin parlamenter sistemde dar anlamda yürütme, CB ya da devlet başkanı ve bakanlar kurulundan oluşur. Keza yarı başkanlık sisteminde de dar anlamda yürütme aynı şeyi ifade eder. Başkanlık sisteminde ise dar anlamda yürütme devlet başkanıdır. Geniş anlamda yürütme ise bu dar anlamdaki yürütmenin içine giren kişi ve organların yanı sıra günlük idari işleri gören dar anlamda hükümetin aldığı kararları yürüten idareyi de içerir. İdare dediğimiz hükümetin çizdiği direktifler çerçevesinde alınan kararları somutlaştıran ve günlük ihtiyaçları yerine getiren aygıtı verilen isimdir. 1982 Anayasasında dar anlamda da yürütmeyi CB oluşturuyor (AY. 8.md). Geniş anlamda yürütme hem CB’ndan hem de idareden oluşan bir bütüne verilen addır.

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği: AY. Md. 76

Üyeliğin Düşmesi: AY md. 84 İstifa: TBMM genel kurulu kararıyla, Kesin hüküm giyme veya kısıtlama: kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle, Kısıtlılık: Kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle, MV ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar: yetkili komisyonun durumu tespit eden raporu+ GK kararı, Devamsızlık (Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmama): Durumun meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, GK kararıyla (üye tam sayısının salt çoğunluğu), CB, CB yardımcısı ya da bakan olarak atanması: kendiliğinden

CB seçilme yeterliği: TC vatandaşı olmak, 40 yaşını doldurmak, yüksek öğrenim yapmış olacak, milletvekilliği seçilme niteliğine sahip olacak. Bu özellikler 1961’den beri var olan seçilme koşulları. 1982 Anayasasının CB’nin yüksek öğrenim yapmış olması, milletvekilliği seçilme yeterliliğinden farklı olması, 40 yaşını doldurma şartlarının bir nedeni var. 1. Hükümet sistemi klasik parlamenter sistemde buna uygun olarak CB’nin yetkileri sınırlıydı yani simgeseldi. Yürütmenin asıl sorumlusu bakanlar kuruluydu. CB, parlamento içerisinde BK ile parlamento arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda tarafsız bir kişi rolünü, hakemlik rolünü üstleniyordu. Bu şartlar başbakan ve bakanlar için aranmıyordu. 82 anayasası milletvekilliği için ilkökul mezunu olmayı yeterli buluyordu. 2017 öncesine kadar başbakan ve bakanların ne 40 yaşında olması ne yükseköğrenim mezunu olması şartı vardı. Bu aradaki farkın nedeni, tarafsız kişinin hem olgun hem de biraz daha eğitimli olması ihtiyacıdır. CB dönemi 5 yıl olup, bir kişi 2 defa en çok seçilebiliyor. Bunun istisnası 106/2 fıkrasında ve 116/3 yürütme erkinin doğrudan halk tarafından seçildiği hükümet sistemlerinde devlet başkanının seçiminin istisnasız belli bir süreyle belli bir dönemle sınırlandırılması kuralıdır. Bu kural bozulduğunda demokrasi ya hiç olmaz ya da ciddi sorunlarla karşılaşılır. Bu 2 tane istisna getirilmesinin hiçbir anlamı yok. Mahkumiyeti ertelenen CB aday olamaz. Ama paraya çevrilirse o cezanın son biçimidir., o zaman aday olabilir. Siyasal parti grupları, son genel seçimlerde geçerli oyların tek başına ya da toplam olarak en az %5 ini almış olan siyasal partiler ve en az 100 bin seçmenin dilekçesiyle CB’liğine aday gösterilebiliyor. Bu yöntem ilk defa 2018 CB seçimlerinde uygulandı.

CB seçimi: 5 yıl için seçilir. Bir kişi en çok iki kez seçilir. İstisna: -CB makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde CB seçimi yapılır. Genel seçime 1 yıldan fazla kalmışsa seçilen CB, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan CB açısından bu süre dönemden sayılmaz (An. Md. 106/2) – CB’nin 2. Döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, CB bir defa daha aday olabilir. (An. Md.116/3)

CB seçimleri: 1. 5 yıllık sürenin bitmesiyle birlikte, CB seçimini TBMM seçimiyle birlikte yapılması. CB’nin görev süresinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. 2. TBMM’nin CB seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi. Bu durumda TBMM seçimleriyle CB seçimleri bir arada yapılıyor. TBMM böyle bir kararı ancak üye tam sayısının ancak 3/5 oy çoğunluğuyla alabiliyor. Böyle bir durumda bu karar 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanır, kararın verildiği günden sonra gelen 60 günü izleyen ilk Pazar gününde seçimler yapılır. 3. CB’nin seçimleri yenilemesi, seçimlerin yenilenmesi yetkisi için herhangi bir gerekçe sunulmasına gerek yoktur. İki durumda da (CB ve TBMM seçimleri yenilediğinde) CB ve TBMM seçimleri birlikte yapılmak zorundadır. Burada orantısız bir yetki vardır. CB tek başına seçimleri yenileyebiliyor iken TBMM’nin üye tam sayısının 3/5 ile bu yetkiyi kullanabiliyor. Bu çok büyük bir oran olup meclisin bu

yetkisini kullanması çok zordur. CB'nın seçimleri yenilemesi durumunda CB'nın seçimleri yenilediğine ilişkin kararını 48 saat içinde resmi gazetede yayınlattır. CB'nın seçimleri yenileme kararı alabilmesi için hakkında bir soruşturma (meclis soruşturma) açılmamış olması gerekir. TBMM tarafından CB hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş ise CB bu yetkisini kullanamıyor. Seçimlerin yapılmasının bir başka koşulu CB makamının boşalmasıdır. Yani CB istifa etmesi, görevini sürekli olarak yerine getiremeyecek bir hastalığa sahip olması ve ölüm ya da CB'nın meclis soruşturması, yüce divan yargılaması sonucunda milletvekilliği seçilmeye engel bir suçtan dolayı mahkum olması. Bu durumda CB'nın görev süresi sona eriyor. CB makamı boşaldıysa ce seçimlere de 1 yıldan fazla bir süre kaldıysa seçim CB makamının boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son Pazar günü yapılır. Eğer CB makamı boşalmışsa ve olağan seçimlere 1 yıldan az bir süre kalmışsa seçimler makamın boşaldığı günden sonra gelen 60.günü izleyen ilk Pazar günü yapılır. Bunların hepsini kurala bağlayan 2018 yılında çıkan 6271 sayılı kanundur.

CB seçilme usulü ve seçimin denetimi: 2014 Yılından buyana doğrudan halk tarafından seçiliyor. CB seçimi 2017 değişikliklerinden itibaren anayasanın 101/5-6. Fıkralarında seçimler tek dereceli ve 2 turlu seçim yöntemiyle yapıldığını görüyoruz. Tek dereceli seçim: araya 2.seçmen adı verilen başka bir grup seçmeni koymadan seçmenin doğrudan adaya oy verdiği seçim sistemine verilen addır. İki dereceli seçim ise, 2.seçmen adı verilen bir grup seçmeni seçmesi ve 2. Seçmeninde adaylar arasında 1 kişiyi CB olarak belirlemesi. 2 Turlu demek; yani ilk oylamada herhangi bir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu alır ise o aday seçilmiş olur. Hiçbir aday bu koşulu sayılamaz ise belli bir süre sonra 2.bir oylama yapılır. Bu oylama, ilk oylamada belli sayıda oy almış adaylar katılır. Bu adaylar arasında en çok oy almış olan aday da seçilmiş olur. Genellikle yarı başkanlık sistemlerinde (Fransa) görülür. Tek turlu seçim Latin Amerika'daki başkanlık sistemlerinde ve ABD'nde uygulanıyor. Bizde 1951 yılına kadar 2 dereceli bir seçim yöntemi vardı. Dünyadaki pek çok demokratik devletlerin bu seçim sistemini benimsediğini görüyoruz.

Sonuç: Bizde de anayasanın 101/5-6. Fıkralarına göre CB seçimi tek dereceli ve 2 turlu yapılıyor. 101/5 Geçerli oyların salt çoğunluğunu 1. oylamada alan aday CB seçilmiş olur. Hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa bu oylamayı izleyen 2. pazar günü 2. bir oylama yapılıyor. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan 2 aday katılır. 2.oylamada geçerli oyların çoğunluğunu almış aday CB geçilir. 101/6'ya göre 2.oylamaya hak kazanmış adaylardan biri herhangi bir nedenle 2.oylamaya katılamıyorsa, ölmüşse, vazgeçmişse, milletvekilliği seçilme yeterliliğinin olmadığı ortaya çıkmışsa o zaman ilk oylamada en çok oyu alan ilk 2 adayın arasından gelen 2.tur oylamaya katılır. Eğer hiçbir aday yoksa ilk turda 2 adaylı bir yarış söz konusu olur. İlk turla 2.tur arasında adaylardan biri yarışmaktan vazgeçti ise bu durumda 3. Bir aday olmadığı için yalnızca tek aday 2.oylamaya kalır. Bu adaya ilişkin oylama halk oylaması biçiminde yapılır. Yani geçerli oyların salt çoğunluğunu alırsa CB seçilir. Eğer alamadıysa o zaman CB seçimi yenilenir. Seçim takviminin ve seçim sürecinin yeniden başlaması demek.

YSK: Anayasa 79.maddede hem yerel hem genel hem de CB seçim süreçlerinden sorumlu olan kurum. YSK, 7 asıl 4 yedek üyeden oluşuyor. Asıl ve yedek üyelerin tümü Yargıtay ve Danıştay kurulları tarafından kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilen kişilerden oluşur. YSK'nın görev ve yetkileri: seçimi düzen içerisinde sürdürülmesi ve yönetimini sağlamak, buna ilişkin bütün yönetsel görev ve yetkiler YSK'nda. Seçimlere ilişkin yolsuzluklar, itirazlar, şikayetler, YSK'na yapılıyor ve YSK tarafından karara bağlanıyor. Kurulun kararı kesindir. Başka herhangi bir yargı organına veya merciye başvurmak söz konusu değildir. YSK kararlarına karşı, AYM İçtihadı çerçevesinde bireysel başvuru yoluna başvurulamıyor. AİHM'ne başvurulabilir.

CB ne zaman göreve başlıyor: CB seçildikten sonra bu seçim YSK tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazetede yayınlattır ve ilan ediyor. Bu tarihten itibaren CB TBMM genel kurulunda yemin etmesi gerekiyor. And içtiği andan itibaren CB göreve başlıyor. CB'nın göreve başlamasıyla, CB sıfatını elde etmesi 2 ayrı şeyi ifade ediyor. CB sıfatı, seçimler yapıldığı anda elde edilir. Ancak CB görevini icra edemez. Bu görevi icra edebilmesi için TBMM'nin önünde andiçmesi gerekir. Eğer TBMM seçimleri, CB seçimleriyle aynı anda yapıldıysa TBMM toplanır ve toplandıktan sonra 2. gün CB genel kurula gelir ve yasada yazılı olan 103.maddedeki and metnini okur. Böylece CB göreve başlamış olur. Hali hazırda görevde olan CB'nın görevi de son ermiş olur. CB'nın göreve başlamasının anlamı, anayasa ve diğer yasalarla tanınmış olan yetki ve görevleri kullanabilme yeteneği kazanmaktır.

CB Tarafsızlığı: 1924 anayasasında CB'nın simgesel yetkileri vardı. Yürütmenin gerçek icrai kanadı Bakanlar Kurulu. O zaman CB'nın TBMM tarafından bir kereden fazla sayısız kez seçilmesi mümkündü. CB'nın

tarafsızlığına ilişkin bir düzenleme yoktu. Örneğin 1950'ye kadar CB olan Atatürk ve İnönü'nün partileriyle olan bağı devam ediyordu. Usulden 1950'den sonra TBMM tarafından seçilen CB'nı partisi olan DP ile olan resmi bağı kaldırdı. Bu sakıncaları gidermek amacıyla 1961 anayasası CB'nın tarafsızlığına ilişkin açık bir hüküm koydu. Dedi ki "TBMM tarafından CB olarak seçilen kişiler varsa partisiyle ilişkisi kesilir." Yine "CB, yapacağı bütün işlemlerde tarafsız olmakla yükümlüdür." 1961 Döneminde hiçbir siyasal parti lideri CB makamına yeşermedi. Bu dönemde hep askeri figürler CB'na seçildi. 1982 Anayasası da 61 anayasasının bu anlayışını devam ettirdi. TBMM tarafından seçilen kişi varsa partisiyle ilişkisini kesecek, bütün eylem ve işlemlerinde tarafsız olacak. 61 ve 82 Anayasaları, TBMM seçim dönemiyle CB seçim dönemlerini birbirinden ayırdı. Amaç, CB farklı TBMM çoğunluklarıyla çalışabilsin, bir meclis çoğunluğuna ihtiyaç duymasın. 2.olarak 1961 anayasasında aynı kişinin 2 kişinin arka arkaya seçilmesi yasaktı. 82 Anayasası, aynı kişinin ancak 1 defa seçilebileceğini belirledi. Bu dönem sınırlamaları yine CB'nı tarafsızlığını sağlamaya yönelik düzenlemeler.

2017 Anayasa değişiklikleriyle hükümet sistemi tamamen değişti. Başkanlık sistemi oldu ve yürütme tek bir kişiden, CB'ndan oluşuyor. Haliyle CB'nın tarafsız olması beklenemez. 2017 anayasa değişiklikleri öncesinde yer alan CB'nın tarafsızlığına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. Buna karşılık bir tek istisnası: 103 md. alt metninde "CB tarafsızlıkla çalışacağını" söylüyor. Ama bütün yetkileri taraflı yetki. Anayasanın 104.maddesinde CB'na temsil yetki ve görevi verilmiş. Partili bir CB'nın ulusun birliğini sağlaması mümkün değil. Bu 61-82 anayasasının ilk biçiminde olan bir düzenlemeydi fakat o zaman bu yetkinin bir anlamı vardı. Çünkü CB tarafsız ve partiler üstü olduğu için ulusun birliğini sağlama yetki ve görevi içindeydi. Yine temsili bir başka yetki 104.md. Devlet organlarının düzenli ve uygun çalışmasını sağlama yetkisi 61-82 anayasalarının ilk biçiminde verilmişti. Tarafsız hakem rolü oynayacak bir devlet başkanı kuşkusuz ki devlet organları arasında bir çatışma var ise hakem rolü üstlenecek bir makam olacaktır. Oysa bir partili CB'nın bu görevleri yerine getirmesi mümkün değildir. Devlet organları yasama, yürütme, yargıdır. Yürütmeyle yargı arasındaki çatışmayı nasıl çözecek, yürütme kendisi. Bu yetki tarafsız CB'na verilmesi gereken bir yetki.

CB'na vekalet yetkisi: Anayasa 106.md.'de açıklığa kavuşturulmuş, CB makamı sürekli olarak boşalmışsa, yeni CB seçimi yapılana kadar, CB Yardımcısı makama vekalet eder ve bu yetkileri kullanır. 3.Fıkra CB'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak boşalmışsa, o zaman CB yardımcısı CB'na vekalet eder ve bütün yetkileri kullanır. Yasada CB yardımcılarının sayısı belirtilmediği için CB, dilediği sayıda CB yardımcısı atayabilir. Birden fazla CB yardımcısı atanmışsa, hangisinin CB'na vekalet edeceği konusu anayasada yer almıyor. CB kararnamesine göre, CB makamı sürekli olarak boşalmışsa, birden fazla CB yardımcısı varsa en yaşlı CB yardımcısı makama vekalet eder. CB makamı geçici olarak boşaldıysa o zaman CB mevcut yardımcılardan birisini vekil olarak atar. Her yetkiyi kullanamaz. İdareye ilişkin yetkileri kullanabilir. CB'nın çok geniş yetkileri var. Yokluğu halinde CB Yardımcısı, CB'nın bu yetkilerini kullanıyor. Buna karşılık kendisi seçimle gelmiyor. CB onu atıyor. Üstelik atama koşulları CB seçilme koşullarıyla aynı değil. Milletvekilliği seçilme yetkisine sahip yeterli ama CB'nın bütün yetkilerini kullanabiliyor. Başkanlık sistemlerinin hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Demokratik devletlerde, başkan ve yardımcısı doğrudan seçime girer. Uruguay'da başkanın yanında 2 başkan yardımcısı seçiliyor.

CB görev ve yetkileri (104.md): 2017 anayasa değişikliğine göre artık yürütme tek kişiden, CB'ndan oluşuyor. 1982 anayasasının ilk biçiminde olan görev ve yetkilerinin 2017 ile 104.mde de devam ettiğini görüyoruz. CB'nın yürütmeye ilişkin görev ve yetkilerinin ne olduğu 1982 anayasasında belirtilmiyor. Ancak yürütme organının her türlü yetkisi artık CB tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz. 2. Olarak CB'nın temsil yetkisi var ve aynı zamanda devlet organları arasında uyumu sağlama bu organlar arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözme yetkisi de CB'nına veriliyor. Bu düzenleme tarafsız CB için öngörölmüş bir düzenlemeydi. Hükümet sisteminin değişmesiyle birlikte CB'nın yetkilerine eklemeler yapıldı. Örneğin gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü mecliste açılış konuşması yapması 1924 anayasasından beri tarafsız CB'na tanınmış bir yetkidir. Zira kanunların yayınlanması, kanunların yeniden görüşölmek üzere TBMM'ne yollanması ve AYM de kanunların anayasaya aykırılığı iddiası ile iptal davası açılması yetkileri hem 82 anayasasının ilk biçiminde hem de 61 anayasasında yer alan yetkilerdi. Bunlar tarafsız CB'na verilen yetkilerdi. 1924 Anayasasında da AYM'nde iptal davası açma yetkisi dışındaki yetkiler CB verilmişti. 104.Maddedeki yetkiler içinde yeni olan ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermesi. Bu başkanlık sistemlerinde, başkana tanınan yetkidir. Başkanlık sistemindeki temel kural, yasama ve yürütme erklerinin sert bir biçimde birbirinden ayrılmasıdır. Bu çerçevede yürütmenin tek sahibi olan devlet başkanı

da örneğin parlamentoya yasa tasarısı sunma yetkisine sahip değildir. CB'nın veya yürütme makamı içinde yer alan başka bir kişinin TBMM'ne yasa tasarısı sunma yetkisi yoktur. Haliyle kendi yürütme alanı bakımından gerekli gördüğü yasal düzenlemeler konusunda parlamentonun dikkatini çekebilmek için ona birtakım mesajlar sunması gerekiyor. Belli konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Parlamento bu konuda yasal düzenlemeler yapsın biçiminde, amacı bu. CB, yardımcılarını ve bakanları atıyor. 1924-61-82 anayasalarında CB, Başbakanı ve Başbakanın önerisi üzerine bakanları atama yetkisine sahipti. Ancak bu yetki biçimsel bir yetkiydi. Parlamentar sistemde Bakanlar Kurulu, parlamentoya karşı siyaseten sorumlu. Göreve başlarken ve görevde kaldığı süre içerisinde her zaman TBMM tarafından görevden alınabilir. Gensoru önergesi verilmek yoluyla ve bu önergenin görüşülmesi sırasında güvensizlik oylaması talebi yoluyla. Ancak parlamento üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir bakanı, başbakanı ya da bakanlar kurulunun tümüne güvensizlik oyu verdiyse bakan, başbakana verdiyse bütün bakanlar kurulu görevden düşmüş olur. CB, ancak başbakanın gösterdiği kişileri bakan olarak atayabiliyordu. Başbakanda ancak parlamento çoğunluğunun güvenini alacak bir kişi ya da bir siyasal partinin liderini başbakan olarak atayabilirdi. 2017 Değişiklikleriyle birlikte artık CB'nın Bakanları atama yetkisi bağlı bir yetki değil. Çünkü yürütmenin tümü CB'na ait ve tek kişiden oluşuyor. CB'nın yardımcılarını ve bakanları atama konusunda sınırsız bir takdir yetkisi var. Bunun sınırı, atayacağı kişinin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması. 1924-61 anayasalarında bir bakanın görevine son verilmesi kuralı bulunmuyordu. 1961 anayasasında, bakanı görevden alma düzenlenmediği için Türkiye'deki siyasal istikrarsızlığa katkıda bulunmuşlardır. 1982 Anayasası bu olumsuzluğu önlemek için şu düzenlemeyi getirdi "CB, Başbakanın teklifi üzerine bakanları atar yine başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden alır. Tıpkı atama işleminde olduğu gibi görevden alma işleminde de CB yetkisine bağlı bir yetki olduğunu belirtelim. 2017 değişikliklerinden sonra ise CB'nın görevden alma yetkisinin tamamen keyfi bir yetki haline gelmiştir. Herhangi bir siyasal, hukuki ya da idari bir gerekçeyle dayanmadan atadığı bir CB yardımcısını veya bakanı görevden alma yetkisine sahiptir. Bir başka yenilik, üst kademe kamu yöneticilerini atama, görevlerine son verme, bunların atamalarına ilişkin usul ve esasları yapacağı CB kararıyla düzenlenmektedir. Yabancı temsilcilere TC temsilcilerini gönderme, TC'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etme yetki ve görevi, 1924 anayasasından beri CB'larına tanınan bir görevdi. Milletlerarası antlaşmaları onaylama ve yayınlama yetkisi de yeni değil. Ama önceki anayasalar, tarafsız ve yetkisiz bir CB'nına verilmiş bir yetkiydi. Antlaşmaları yapma yetkisi Bakanlar Kurulundaydı. TBMM'nin bir uygun bulma kanunuyla Bakanlar Kurulunun imzaladığı uluslararası antlaşmayı onaylama ve yayınlama yetkisi CB'ndaydı. Burada CB'nın bir takdir yetkisi bulunmuyordu. Arık antlaşmayı imzalayan da onaylayan da aynı kişi konumuna geldi. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunma yetkisi ilk defa 82 anayasasıyla girdi. Bu yetki 2017 değişiklikleriyle de CB'na verilmiş durumda. Milli güvenlik politikalarını belirleme ve belli önlemleri alma yetkisi 104.mad'ye 2017 de eklenen bir düzenleme. TBMM adına TSK'nin Başkomutanlığını temsil etme yetkisi. Kurtuluş savaşını meclis yaptığı için onun bünyesinde tutmaya devam ediyor. 2017 den önceki biçiminde de 1982 anayasasında bulunuyordu. TBMM adına Başkomutanlığı temsil ediyor. Başkomutanlık, TBMM'nin manevi kişiliğinden ayrılmaz. Bunu temsil etme yetkisi de CB'na verilmiştir. Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar verme yetkisi sınırlı bir yetkidir. Kendi kendine bu yetkiyi kullanamaz. TBMM'nin usulüne uygun olarak, savaş ilanı etmesi gerekiyor. Yurt dışına asker yollama kararını yine TBMM'nin vermesi gerekiyor. Bunun dışında eğer TBMM ara vermede ya da tatilde ise Türkiye ani bir yabancı gücün saldırısı ile karşı karşıya ise TBMM olağanüstü toplanıncaya kadar CB, silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verebilir. 2017 den önceki bütün anayasalarımızda bu yetki Bakanlar Kurulundaydı. Sürekli hastalık, sakatlık, kocama nedenleriyle kişilerin cezalarını hafifletmek, tarafsız bir CB'na 1924 anayasasından beri tanınan yetkilerden biridir. CB'nın kararname çıkarma yetkisi vardır. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarma yetkisi yenidir. CB, yürütmenin icracı kanadı olmadığı için 2017'den önce böyle bir düzenleyici işlem yapma yetkisi tanınmamıştı. İcra yetkisini kullanan kişi ve kurumların yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. CB, anayasa ve kanunlarda diğer yetkileri kullanır. Özellikle anayasada 104.maddenin dışında CB'na tanınan yetkiler. 1. TBMM seçimlerini yenileme yetkisi (Anayasa 116.md) Bu yetkiyi kullandığı zaman TBMM seçimleri ile birlikte CB seçimleri de yapılır. 2. MGK'nu toplantıya çağırma, kurula başkanlık etme, 1982 anayasasının ilk biçiminde de MGK, CB'nın başkanlığında toplanırdı. Bunda bir değişiklik yok. CB konumu, sistem içindeki yeni yeri, devlet içindeki konumunu da etkiledi. 3. OHAL ilan etme: 1924-61 anayasalarında olağanüstü yönetim ilan etme yetkisi bakanlar kurulundaydı. 1982 Anayasasının ilk biçimindeyse CB başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim ilan etme yetkisiyle donatılmıştı. Bu durumda OHAL kararıyla çıkarma yetkisi CB'na verildi. Bu kararnamenin CB kararnamelerinden farkı,

bunlar anayasada 119 md. de açık bir biçimde kanun hükmünde olduğunu belirtmesi. 4. Birçok seçme ve atama yetkisi verildi. Bunların tümü Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere 1982 anayasasının ilk biçiminde CB'na tanınmıştır. Sorumsuz tarafsız bir CB'na devlet organları içinde icrai görevleri üstlenen kurum ve kuruluşlara atama yetkisi yapması. Bu yetkilerin bütünüyle CB tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Sistem içindeki ağırlığını artıran en önemli yetkililerdir.

CB Yardımcıları ve bakanlar (md.106): Ölüm, görevden çekilme, Mv. Seçilme yeterliliğinin kaybı, Yüce Divanda mv. Seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme, CB'nın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi, CB'nın görevden almasıyla görevleri sona görevleri sona erer.

CB yardımcılarının görev ve yetkileri: -CB'lığına vekalet – CB'nın katılmadığı MGK toplantılarına başkanlık (md.118/5) – CB tarafından verilen görevleri yapma (1 sayılı CB kararnamesi md. 17) – CB'nın devrettiği yetkileri kullanma

CB'nın Sorumluluğu: Bunu üçe ayırıyoruz. Siyasal, cezai, hukuki sorumluluk. Bir siyasal iktidarı kullanan bir kişi ya da organın siyasal sorumluluğu demek herhangi bir nedene dayanarak veya dayanmadan o kişi ya da organın görevden alınabilmesi demek. Siyasal sorumluluğun cezai bir karşılığı olmaz. Bunun tek sonucu o kişinin ya da organın görevden alınmasıdır. Cezai sorumluluğu ise başta ceza kanunu olmak üzere diğer kanunlarda suç sayılan fiilleri işleyen bir kişi ya da kişinin karşı karşıya kalacağı sorumluluk anlamına gelir. Hukuki sorumluluk ise kişinin özel hukuk hükümleri çerçevesinde işlemiş olduğu fiillerden kanunlar çerçevesinde sorumlu olması anlamına gelir.

Siyasal Sorumluluk: Kişinin görevden alınmasıdır. Bu sorumluluk, parlamenter sistemde, yürütme erkini kullanan, icra edenin üzerindedir. Hiçbir yetkisi olmayanın sorumluluğu da olmaz. Yetkide de sorumlulukta da paralellik ilkesi. Bir kişinin ne kadar yetkisi varsa o kadar sorumluluğu olur. 2017 Öncesinde klasik parlamenter sistemde CB'ları ya da devlet başkanları simgesel niteliklerle donatılmış kişilerdi. Yürütmenin gerçek başı Başbakan ve bakanlardan oluşan bakanlar kuruldur. Haliyle siyasal sorumlulukta başbakan ve bakanlara aitti. Başbakan ve bakanların, 2 aşamada siyasal sorumluluğu vardı. Bunların, . Hükümet kurulduktan sonra TBMM de yapılan güven oylaması. Yeni kurulmuş olan bakanlar kurulunun, TBMM de güvenoyu alabilmesi için 82 anayasasına göre katılanların salt çoğunluğu yeterliydi. Eğer alamadıysa kurulmuş olan bakanlar kurulu, görevden alınmış oluyordu. Bu bir siyasal sorumluluk biçimiydi. 2. Gensoru önergesi yoluyla Başbakanın, bakanların ya da bakanlar kurulunun görevden alınması. Bakanlar kurulu görevde olduğu süre içerisinde her zaman her an TBMM'nin güvenine muhtaçtır. TBMM ne zaman isterse bakanlar kurulunu bütünüyle veya ayrı ayrı veya Başbakanı tek başına siyasal sorumluluğa tabii tutabilir. TBMM üye tam sayısının en az onda biri ile güvensizlik önergesi verilebiliyordu. Bu önergeyi kabul ettikten sonra güven oylaması yapıp Bakanlar kuruluna güvensizlik verilmesi içinde üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekiyordu. Böyle bir durumda siyasal sorumluluk yerine getirilmiş, bakanlar kurulu y da ilgili bakan görevden alınmış oluyordu. Bunun dışında hukuki, cezai başka bir sonucu yoktur. Klasik parlamenter sistemde CB'lığı simgesel yetkilerle donatıldıkları için siyasal olarak herhangi bir siyasal sorumluluğa sahip değillerdi. CB'nın tek sorumluluğu vatana ihanet olup bu siyasal sorumluluk biçimi değil, cezai sorumluluk taşımaktadır. CB'nın 7 yıllık görev süresinde siyasal bir nedenle TBMM tarafından görevden alınması mümkün değildir. 2017 değişiklikleri ile CB'nın gensoru, güven oylaması gibi bir aracı yoktur. CB'nın siyasal sorumluluğu, ancak onu seçen halka karşı olabilir. 1. Seçim yoluyla tutar. Bu sınırlı bir siyasal sorumluluktur. CB'nın 2.dönemi yeniden seçilemeyecekse o zaman seçmenin 2. Döneminde onu siyaseten sorumlu tutması mümkün değil. Klasik başkanlık sistemlerinde ABD Başkanının inpeachment yoluyla görevden alınması mümkün. Bu siyasal sorumluluğa karşılık gelir. Bunu tek yaptırımı ilgili kişinin görevden alınmasıdır. Eğer görevden alınma gerekçesi aynı zamanda bir cezai suça karşılık geliyorsa o zaman genel mahkemeler önünde başkanı yargılamak mümkün. Sonuç: 1982 anayasasına göre CB'nın siyasal sorumluluğu bulunmuyor.

Cezai Sorumluluk: Anayasanın 105.md'de düzenlenmiş. 2017'den önce 24-61-82 anayasalarında CB tek sorumluluğu vatana ihanet suçu idi. Vatana ihanet suçu göreviyle ilgili, cezai bir suçtan söz ettiğimiz zaman bunu 2'ye ayırıyoruz. Biri, kişinin kamu görevlisinin göreviyle ilgili olarak işlediği cezai bir suç var. 2. Kamu görevlisinin işlediği kişisel bir suç var. Kamu göreviyle ilgili işlediği suçlarla ilgili kanuna bakıyoruz. TCK, kamu görevlilerinin işledikleri suçlar, göreviyle ilgili suçlardır. Kişisel suçlar ise kişisel olarak işlenen ve ceza kanunlarında tanımlanan suçlar. Sonuç: 2017'den önce 1982 anayasası bakımından göreviyle ilgili cezai suçlardan vatana ihanet suçu, kişisel suçlara ilişkin ise genel mahkemelerde CB'nın yargılanması esastır. Bu durum 2017'ye kadar sürdü. Vatana ihanetten yargılanma ise, 1982 anayasasının 24 ve 61 anayasalarına göre

yüce divan sevk için nitelikli çoğunluğu artırılmıştır. 24 ve 61 anayasaları ile TBMM üye tam sayılarının 1/3'ü CB'na vatana ihanet suçlamasıyla bir önerge verebiliyordu. Bunun kabulü için TBMM üye tam sayısının 2/3'ü gerekiyordu. 82 Anayasası 3/4'e çıkardı. O zamana kadar bir tartışma konusu yaratmadı. Çünkü CB icrai bir yetkisi olmadığı için vatana ihanet gibi ağır bir suç işlediği iddiasının ortaya çıkması da hemen hemen imkansız olarak kabul ediliyordu. Vatana ihanetin siyasal bir nitelik taşıdığını ve TBMM'nin CB'nı yüce divana sevk ettiği zaman hangi fiillerin vatana ihanet niteliği taşıdığının belirtmek durumunda olduğunu ve bu fiillerin başta TCK olmak üzere diğer kanunlarda da bir suç tanımına karşılık gelmesi durumunda bu suçlardan yüce divanda yargılanacağı ileri sürülüyordu. 61 ve 82 anayasalarında AYM, yüce divan görevini yerine getiriyordu. Tıpkı bakanlar, başbakanın göreviyle ilgili suçlarda olduğu gibi. 2017 Yılında CB sorumluluğu büyük ölçüde değişti. Artık vatana ihanet diye bir suç yok. Anayasa 105.md. Göreviyle ilgili ya da kişisel bir suç olabilir. Bu çok büyük bir sorumluluk ya da sorumsuzluk kalkanı getiriyor. 148.md. AYM'nin görev ve yetkilerini düzenleyen madde. CB'nın göreviyle ilgili suçlarda, yargılama maddesi var. 105 ve 148'i bir arada düşününce buradaki sorumluluk halinin göreviyle ilgili suçlardan dolayı olduğu sonucuna varılabiliriz. 105 Kişisel suçları kapsıyor ama 148 bunu kapsamıyor. CB'nın kişisel suçlarda durum 2017 öncesi olacak bu durumda. CB'nın herhangi bir kişiden farkı yok. Genel Mahkemelerde kişisel olarak işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak CB'na karşı dava açabilecek ve yargılama yapılabilir. 105. Maddede, göreviyle ilgili meclis soruşturması düzenlemesi var. CB'nın göreviyle ilgili olarak iddia edilen bir suçtan dolayı yüce divana sevk edilebilmesi için 1. TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun bu yönde bir önerge vermesi gerekiyor. Bu önerge soruşturma komisyonunun kurulmasına ilişkin. 2. Soruşturma komisyonunun kurulup kurulmayacağına ilişkin olarak TBMM üye tam sayısının en az 3/5'inin bu yönde karar alması gerekiyor. Karar soruşturma komisyonu kurulsun ise 15 kişilik komisyon kuruluyor ve iddiaları inceliyor. Bu komisyonda TBMM'de grubu bulunan siyasal partiler üye veriyor. Meclisteki güçleri oranında temsil ediliyor. Soruşturma komisyonu 2 ay içinde her türlü araştırmayı yapıp raporunu hazırlar. Hazırlanan rapor meclis başkanlığına sunulur. Başkanlık 10 gün içinde raporu bastırır ve bütün milletvekillerine dağıtılır. TBMM üye tam sayısının en az 2/3 ile ve gizli oyla CB yüce divana sevk edilmesine karar verilir. Geniş yetkiler verilmiş olan CB'nın sorumluluğunun son derece zayıf tutulması sistemin en sakat yönlerinden biridir. Anayasa gibi önemli bir konuyu 3/5'e bağlanması, CB'nı yüce divana sevkini 2/3'e bağlanmış. Bu gerçekleşmesi hiç mümkün olmayacak bir oran. Uygulamada CB'nın göreviyle ilgili bir suçtan dolayı yargılamak, yüce divana sevk etmek mümkün değil. Yüce divana sevk edilen CB görevinde kalmaya devam ediyor. 24-61-82 Anayasalarında yüce divana sevk edilen bakanın görevi sona eriyordu. Başbakan, yüce divana sevk edilmişse, yalnızca Başbakanlığı sona eriyordu. Bakanlar kurulu da düşmüş sayılıyordu. Son derece ciddi olan bu suç isnadının yöneltmiş olması icrai görevdeki kişinin o görevde bulunmaması gerekir. Seçilmeye engel bir suçtan mahkum olursa CB'nın görevine son veriliyor. Seçilmeye engel bir suç değilse ve mahkum olursa CB görevde kalmaya devam eder. Bunun ne etik ne kamu hukuku ne idare hukukuyla bir ilgisi yoktur. CB, görev süresi bittikten sonra da bu kalkanla korunuyor. Yani görev sırasında işlediği bir suç görevi bittikten sonra ortaya çıktıysa yine aynı süreçler çerçevesinde CB'nın yüce divana sevk edilmesi ve yargılanması söz konusu olur. Yani, yürütmenin tek sahibi olan olağanüstü yetkilerle donatılmış kişinin kimseye karşı sorumlu olmamasıdır. CB, AYM kesin kararını verinceye kadar görevde kalmaya devam eder. 1982 ve 61 anayasalarında yüce divana sevk edilen CB'nın akıbetinin ne olacağı, görevde kalıp kalmayacağı konusunda bir düzenleme yok. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yüce divana sevk edilmiş olan Bakan, bakanlıktan düşüyorsa, Başbakan yüce divana sevk edilmişse Bakanlar Kurulu görevden düşmüş sayılıyorsa üye tam sayısının 2/3 ile yüce divana sevk edilmiş.

Hukuki Sorumluluk: Tıpkı cezai sorumluluk gibi 2 ayrı kanattan oluşuyor. 1. Kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı doğan hukuki sorumluluk 3. Görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk. Kişisel eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk: özel hukuk alanına girer. İçindeki yasalardan kaynaklanan sorumluluğudur CB'nın. Kişisel eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk dediğimizde mesela kredi kartı borcunu ödememişse gibi kişisel eylemlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluk. Burada CB, yerel hukuk mahkemelerinde yargılanıyor. Görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluğuna ilişkin 2 anayasa düzenleme var. Bunlardan 1. 129/5 diğeri de 125 /son fıkrası. 2 Anayasal hüküm CB göreviyle ilgili hukuki sorumluluğuna ilişkin sorunu çözüyor. 129/5 CB, göreviyle ilgili bir eylemden dolayı bir hukuki sorumluluk doğduysa bundan zarar gören CB şahsına davayı açar. Bu davayı CB tüzel kişiliğine açıyor. Eğer dava kazanılırsa, idare bunun karşılığında ödediği tazminatı CB'nından rücu etme yetkisine sahip. 125.madde CB göreviyle ilgili hukuki sorumluluğunu düzenleyen maddele. Sonuç: Kimse

böyle bir durumda CB'nına karşı dava açamıyor. Kamu tüzel kişiliğine sahip olan CB'na açılıyor. Bundan idare bir zarar gördü ise o zaman bunu CB'ndan rücu etmek yetkisine sahip.

Yürütmede CB'nın dışında bir de CB yardımcıları ve bakanlar var. CB yardımcılığı ilk defa 2017 değişiklikleri ile bizim anayasamıza girdi. 106. Madde kaç CB yardımcısı atanacağı belli değil. CB dilediği kadar yardımcı atayabilir. CB yardımcısı CB'na vekalet ediyorsa CB'nın bütün yetkilerini de kullanma yetkisine sahip. CB'nın atama işlemi resmi gazetede yayınlanıyor. Bu atamanın ertesi günü CB yardımcıları ile bakanlar TBMM önünde andiçerek göreve başlarlar. Başkanlık sistemlerinde, yasama ve yürütmenin sert ayrılığı geçerlidir. Bu sert ayrılığın bir etkisi olarak parlamento üyeleri, yürütme organının içinde görev alamazlar. Yürütme organı üyeleri de milletvekili olamazlar. Bu nedenle 1 kişi CB yardımcısı ya da Bakan olarak atanmışsa ve aynı zamanda da TBMM üyesi ise o zaman o kişinin atamayla birlikte meclis üyeliği sona eriyor. CB yardımcılığı ve bakanların görevi şu durumlarda sona eriyor; vefat ettiğinde, görevden çekildiğinde, istifa ettiğinde, herhangi bir nedenle milletvekili seçilme yeterliliğini yitirdiğinde bu yüce divan yargılaması sonucunda milletvekili seçilme yeterliliğinde engel olan bir mahkumiyet ile veya bu görevi yerine getirirken milletvekilliği seçilme yeterliliğine ilişkin bir ya da birden fazla özelliğini kaybetmesiyle olur. CB'nın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi, CB'nın görevi sona erince CB Yardımcılarının ve bakanların da görevleri sona eriyor. CB'nın görevden alması da CB yardımcısının görevini sona erdiren bir başka durum. CB Yardımcısının görev ve yetkileri: Anayasa 104.md. 1. CB'na vekalet 2. 118/5 hüküm yani MGK'na katılmak ve CB'nın katılmadığı durumlarda da onun yetkilendirmesi ve izin ile başkanlık etmek 1 No'lu CB kararnamesine göre CB'nın vereceği diğer yetkileri kullanmak.

Beta 156- CB, yardımcılara, bakanlarına yetkilerinin bir bölümünü devredebilir. Buna ilişkin düzenleme 1 No'lu CB Kararnamesinde yer alıyor. Yetkiye özel, anayasa ile belirlenmiş sınırlar var. Anayasanın CB'na tanıdığı yetkileri CB yardımcıları dahil olmak üzere bir başka makama devretmesi mümkün değil. Bu anayasaya aykırı. Münhasır yetkiler dediğimizde yasama ve yargı organlarıyla ilgili olarak CB hiçbir şekilde hiçbir makama devredemez. Örneğin bir daha görüşülmek üzere yasaların TBMM'ne gönderilmesi yetkisi. Danıştay üyelerinin 1/4 'ünü seçme ve atama yetkisi gibi yargı ya da yasama organına ilişkin olarak CB'na tanınmış olan yetkilerin verilmemesi gerekir. Bizzat kendisi kullanmak zorunda. Kuşkusuz yürütmeye ilgili yetkilerini devredecek. Bu yetkilerin de tümünü devredemez. Sınırı anayasada CB'na tanınmış olan yetkiler. Örneğin Genelkurmay Başkanının atanması yetkisi yürütmeye ilişkin bir yetki. Bu yetkiyi CB, herhangi bir kişiye devredemez. Bunun sınır, idari nitelikteki yetkilerin devri 2. Anayasa ile münhasıran özel olarak CB'na tanınmış yetkilerin 1 No'lu CB Kararnamesi ile başka bir kişiye devredebilmesi mümkün değil.

Bakanların görev ve yetkileri: 2 Genel yetkiden söz edebiliriz. Biri yönetmelik çıkarma yetkisi (124.md.) ve CB yetkilerinin ve görevlerinin bir bölümünü bakanlara devredilebilir. 2017 Öncesinde Bakanlar ve Bakanlar Kurulu yürütmenin icrai yetkilerle donatılmış kanadıydı. Yürütmenin ayrılmaz bir parçasıydı. 2017'den sonra yürütme erki tek kişiden oluştuğu için Bakanlar, icrai nitelikte karar alan yürütmenin esaslı unsuru olan bir konumda artık değiller, tek kişinin sekreteri konumundalar. 2017 Öncesinde hem bakanlar hem de bakanlar kurulu TBMM'ne karşı siyaseten sorumluydu. Herhangi bir gerekçeyle dayanmadan veya dayanarak TBMM her ana ve her zaman bir bakanı göreviyle ilgili olarak tek ya da hem de bütün olarak Bakanlar Kurulunu siyaseten sorumlu tutma yetkisine sahipti gensoru yoluyla. Yani güvensizlik önergesi vermek ya da Bakana, kurula karşı güven oylaması yapmak yoluyla.

2017 den sonra CB yardımcıları ve Bakanlar, CB'na karşı sorumludur (An. Md.106/5). Bu sorumluluk cezai, hukuki bir sorumluluk değil bir siyasal sorumluluktur. CB, herhangi bir neden göstermeden istediği kişiyi atayabilir veya her an bir gerekçe göstermeden görevden alabilir (106/4). Bunların cezai sorumluluğu açısından, görevleriyle ilgili ve kişisel suçlar bakımından. Kişisel suç, TCK ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanmış ve yaptırıma bağlanmış fiillerdir. CB Yardımcıları, bakanlar yönünden hukuki rejim farklılığı açığa çıkıyor. Bu milletvekilliği dokunulmazlığı rejimidir. And içtikleri andan itibaren milletvekillerinin sahip oldukları dokunulmazlığa sahiptirler. İşledikleri iddia edilen bir kişisel suç var ise milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kuralları, bu kişiler bakımından da geçerlidir. Görevleriyle ilgili suçlarda ise CB'nın göreviyle ilgili suçlar bahsindeki düzenleme bunlar bakımından da geçerli, 106/5 fıkrası. Bu CB için uygulanan aynı hüküm. Yüce divan ve buraya sevk koşullarını daha önce yazmıştım.

Yine CB'nında olduğu gibi Bakanlar, görevleriyle ilgili iddia edilen işlerle ilgili bir suçtan görevi sona erdirdikten sonra da bu 106/5 hükmü çerçevesinde yüce divana sevk edilebiliyordu. Neredeyse CB'nına, CB Yardımcılarına ve Bakanlara mutlak bir dokunulmazlık tanınıyor. Yüce divana sevk işi neredeyse mümkün

değil. Aynı şekilde milletvekilliğine engel bir suçtan dolayı mahkumiyet söz konusu ise bu kişiler görevlerine devam edemezler. Mahkumiyet eğer milletvekilliğine seçilmeye engel bir suç değil ise o zaman görevlerinde kalmaya devam ediyorlar. 2017 Öncesinde yüce divana sevk edilen bakanın bakanlığı, başbakan sevk edilmiş ise Bakanlar Kurulu düşmüş sayılıyordu.

Cezai sorumlulukları ikiye ayrılır; -görevleriyle ilgili suçlar (106/5 vd) – kişisel suçlar

Hukuki sorumluluk

Kişisel suçlardan cezai sorumluluk madde 106/10: CB yardımcılarının ve bakanların hukuki sorumluluğu ise kişisel eylem ve işlemlerine ilişkin olarak yerel mahkemelerde yargılanıyor. Kişiye ilişkin cezai suçlarında da yerel mahkemelerde yargılanıyor. Görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanırlar. Hukuk mahkemelerindeki yargılamalar için herhangi bir hukuki dokunulmazlıkları bulunmuyor. Görevleriyle ilgili işlemlerde de Anayasanın 129/5 fıkrası işliyor hem de 125/son fıkrası işliyor. Görevlerinden doğan işlemlerden yaptıkları işlemlerle ilgili hukuki sorumluluklarına ilişkin.

Cumhurbaşkanlığı İdare teşkilatı içindeki kurumlar: Devlet denetleme kurumu, MGK ve TSK (Genelkurmay MSB'na bağlı)

DDK (md.108), 1982 anayasası ile yaratılmış bir kuruldur. Tarafsız, partiler üstü ve devlet organları arasında uyumu sağlamak, uyuşmazlıkları giderecek makam olarak tasarlandığı için bu tasarı çerçevesinde düşünülmüş bir kuruldur. Bu kurul o zamanda CB'na bağlı olarak çalışıyordu. Kurulun başkan ve üyelerini CB'na atıyordu. Bu kurul CB'nın talimatıyla açıklayacağımız kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yapma yetkisine sahip. Bu yetkinin hukuki bir sonucu yoktur. En fazla bu raporla hukuka aykırı bir durum ortaya çıkmış ise CB, bu raporu ilgili kurum ve kuruluşlara iletir. DDK, tüm kamu kuruluşları, sermayesinin yarısından daha fazlasına bu kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı her türlü kamu kuruluşu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamu yararı dernekler, vakıflar bakımından CB bu yetkisini kullanıyor. Kuşkusuz ki inceleme ve araştırmaya konu olan kurum ve kuruluşlar bakımından (2017 yılında sa TSK, DDK'nun yetkisi içine sokuldu) son derece sakıncalı bir durum vardır, sivil toplum, toplumsal örgütlenme bakımından. Bunun demokratik devlet ilkesiyle çok ciddi bir biçimde çatıştığını söyleyebiliriz. Sivil toplum, siyasal bir idari makam tarafından denetlemeye konu oluyor. Üstelik bu denetimin siyasal bir denetim olacağını tahmin edebiliriz. 2017 Değişiklikleriyle DDK'na idari soruşturma yetkisi tanındı. Haliyle DDK'nun soruşturması, incelemesi ya da bunun sonucunda yazdığı raporlar 2 bakımdan bağlayıcı nitelik taşıyacak bir hal alıyor. Kurumun başkan ve üyeleri CB tarafından atanıyor ve belirleniyor. Sivil toplumun, yürütme erki ya da siyasal iktidar tarafından denetlenmesi ya da sesinin kısılması bakımından önemli bir işlev görme potansiyeline sahiptir.

MGK (md.118): 1924 Anayasası döneminde de MGK'na benzer bir kurum mevcut idi. Ancak bu kurumun bir anayasal dayanağı yoktu. İlk defa 1961 anayasası ile anayasal bir kurum haline geldi. 1982 Anayasası bunu artırarak devam ettirdi. Anayasa 118.madde çerçevesinde anayasada yer almaktadır. Özellikle askerin siyaset üzerinde bir vesayet aracı olarak, anayasal bir güvenceye kavuşması bakımından MGK'nun çok önemli bir rol oynadığı konusunda eleştiriye uğramıştır. Bugün CB, CB yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, MS Bakanı, ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarından oluşan bir kuruldur. Bu kurul, CB'na danışmanlık yapan bir kuruldur. Bu kurulun aldığı kararların herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Kurul şu konularda danışmanlık yapıyor; 118/1 milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanması bakımından yürütme organına tavsiye kararlarında bulunuyor. Gerekirse bu konuya ilişkin eşgüdüm sağlanması bakımından CB'na önerilerde bulunuyor. Konunun milli güvenlik kavramı son derece soyut, muğlak ve geniş bir biçimde tanımlandığını görürüz. Bunun sakıncası siyasal iktidarın takdir yetkisini kullanması o kadar genişler. Her kavramın olabildiği kadar somut olması gerekir ki muhatabın takdir yetkisi daraltılabilsin. 1982 deki kanunda da olduğu gibi eğitimden, sağlığa kadar içine her şeyi sokabileceğimiz bir kavram olarak tanımlandığını görürüz. Özellikle 1990'lı yıllarda paralel bir bakanlar kurulu olarak hareket ettiğini görürüz. 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra yine MGK da alınan kararların bu OHAL ve OHAL süresince uygulanan kararlarda bir dayanak oluşturduğunu görüyoruz.

TSK (md.117): Genelkurmay Başkanını atama yetkisi CB'na ait. 1982 Anayasasının ilk biçiminde de CB'na aitti. Ama be yetki bağlı bir yetkiydi, takdiri bir yetki değildi. Yani Bakanlar Kurulunun gösterdiği adayı atama yetkisine sahip bir CB'ydı. 1920 den itibaren TBMM bağımsızlık savaşını yöneten ve kazanan organ olduğu için ve o dönemde Başkomutanlık makamı TBMM'nin uhdesinde olduğu için sonraki anayasalarda bunu aynı

şekilde devam ettirmişlerdir. Türkiye’de siyasal ve anayasal tarihinin bir sonucu olarak Başkomutanlık yetkisi, makamı kimseye verilmemiş. 2017 den sonra da bu değişmemiştir. Anayasa 117 md. TBMM’nin manevi varlığından ayrılmaz diyor. TBMM, Başkomutanlığı bir organ olarak tek başına kullanamayacağına göre bu Başkomutanlık CB tarafından temsil olunur, kullanılmaz. 2017 Öncesinde 117/2 de Bakanlar Kurulu yazıyordu. O zaman Bakanlar Kurulunun TBMM’ne karşı sorumlu olmasının bir anlamı vardı. Bakanlar Kurulu siyaseten TBMM’ne sorumluydu. Artık CB, TBMM’ne karşı siyaseten sorumlu kılınmadığı için bu fıkranın uygulamada karşılığı yoktur. Uygulamada Başkomutanlığı, Genelkurmay Başkanı yapıyor.

Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı: Bir hukuk düzeninde farklı kapsamda farklı etkide çok sayıda hukuk kuralı vardır ve bunlar aynı nitelikte değildir. Aynı kapsamda değil ve aynı etkiyi de taşımıyor. Bu farklılıklardan oluşan hukuk kuralları arasında bir kademelenme var. Hukuk düzeninin belli bir hiyerarşi yani kademelenme biçiminde olduğunu ortaya koyan kurama Normatif hukuk kuramı denir. Her toplumda farklı farklı hukuk kuralları var. Bu hukuk kurallarının hepsi aynı etkide değil, aynı kapsamda da değil ve bu kurallar birbirine piramidi andırır gibi biçiminde birbirine dayanarak bir piramidi oluşturur. Bu piramidin önemi, alttaki normun geçerliliği ve yürürlüğü üstteki norma bağlıdır. Parlamento bu konuda yasa yaparken aslında anayasayı uyguluyor. Çünkü hiçbir norm, piramitte kendisinin üstünde olan norma aykırı olamayacağı için. Bir yerde, bir normun konması onun üstünde yer alan onun dayandığı diğer normun uygulanması anlamını taşıyor. Her norm geçerliliğini ve yürürlüğünü kendisinin bir üstünde yer alan normdan alır. Bu durumda iç hukukta piramidin en üstünde anayasa bulunuyor. İç hukukta bu piramidin en tepesinde yer alan anayasa geçerliliğini ve bağlayıcılığını mevcut hukuk düzeninin geçerliliğinden ve etkinliğinden alır. Bütün hukuk düzenlerinde, anayasanın dayandığı temel kural uluslararası hukuktur. Sonuç: Hentsen’e göre ulusal hukuk düzenleri geçerliliğini ve bağlayıcılık güçlerini normların kademeli sırasından, kendilerinden üstün olan uluslararası hukuktan alır. Bizde 24-61-82 anayasaları, anayasanın üstünlüğü ilkesini kabul etmiştir. Kanunlar, anayasaya aykırı olamaz diyorlar. 1982 Anayasasının belirlediği hukuk düzeni içindeki normlar kademelenmesine ilişkin 1982 anayasasında hüküm var. Anayasanın 11.maddesi kanunlar anayasaya aykırı olamaz” diyor. Anayasa 124, yönetmelikleri düzenliyor. Yönetmelikler, Türk Hukuk düzeninde yer alan bütün hukuki işlemler içinde, CB kararnamelerini ve kanunların altında yer alıyor, onlara aykırı olmayacağından dolayı. Anayasa 137, kanuna aykırı emir yerine getirilmez. Yönetmelik, CB kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez. Bu bize 1. CB Kararnamesi, yönetmeliğin üstünde ama kanunların altında yer alan bir işlem türü. 2. Bu sıralamada 137.maddeki normlar kademelenmesini emirlerin yerine getirilmesinin bir ölçüsü olarak düzenliyor. CB Kararnamesine ilişkin anayasanın 104/17 md. ve 119.md.’yi göz önünde bulundurmak zorundayız. OHAL kararnameleri kanun önündedir diyor. Normlar kademelenmesi bakımından olağan dönemde çıkan CB kararnamesi ile OHAL döneminde çıkarılan CB kararnamesi arasında bir fark var. OHAL kararnamesi kanun hükmündeyken, olağan CB kararnamesi kanun altında bir düzenleyici işlem türüdür. Anayasa 90/5 temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara yönelikti. Usulüne göre yürürlüğe konmuş antlaşmalar kanun hükmündedir. Maddenin devamında temel hak ve özgürlüklere ilişkin ise kanunla çatışıyorsa, aynı konuyu somut biçimde düzenleyen 2 kural çatışıyorsa, böyle bir durumda temel hak ve özgürlüğü en çok koruyan hüküm hangisi ise o hükmün uygulanması gerekir. Eğer temel hak ve özgürlüğü daha geniş bir şekilde koruyan uluslararası antlaşma hükmü ise o uygulanır. Uluslararası antlaşma hükmü değilse kanun hükmü uygulanır. Burada temel hak odaklı hakkın korunması ve tanınması odaklı bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. Eğer bir çatışma varsa, kanundan daha geniş bir şekilde temel hakkı koruyorsa o zaman o hüküm kanunun üzerindedir. Buna karşılık eğer kanun hükmü, hak ve özgürlüğü uluslararası antlaşma hükmünden daha geniş bir şekilde koruyorsa illaki uluslararası antlaşma hükmü uygulanmaz. Bu durumda kanun hükmü uygulanır. Burada kanun ile uluslararası antlaşma hükmü arasında normlar hiyerarşisinde bir üstünlük sırası söz konusu olamayıp aynı düzeydedir. Anayasa 90/5 uluslararası antlaşmaların, anayasaya aykırılığı iddiasıyla AYM’ne başvurulamayacağı öngörülüyor. Sonuç: 1.Normlar hiyerarşisinde genel kural, yukarıda sayılan anayasa maddeleri çerçevesindeki hiyerarşik kademeler. a) AYM Kararları: Anayasanın 153/6 maddesi gereğince yasama, yürütme, yargı organlarının idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesinin kararları anayasal düzeydedir. Geleneksel bir anayasa hükmü varsa, o zaman bu geleneksel anayasa hükmünde normlar hiyerarşisinde anayasayla aynı düzeyde olduğunu kabul ediyoruz. b) Danıştay ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları: Her ikisi, idareyi de, mahkemeleri de diğer yargı organlarını bağlar. Bunlar tıpkı yasa gibi etki ve sonuç doğurur. TBMM, bir içtihadı birleştirme kararını beğenmiyorsa bunu ancak çıkaracağı kanunla etkisiz hale getirebilir. c) Anayasa 90.md. mutlak bir

nitelik taşıyor yukarıda değindiğimiz istisnalar çerçevesinde. Hukuk düzenimizde bazı hukuki işlemlerin normlar kademelenmesinde yer almadığını görüyoruz. Örnek: TBMM iç tüzüğü. Meclisin, kuruluşunu, iç işleyişini çalışmasını düzenleyen bir hukuk metnidir. 3. Kişilere etki ve sonuç doğurmadığından dolayı normlar hiyerarşisinde yer almıyor. Yine CB'nın OHAL ilanı, TBMM'nin OHAL ilanını onaylaması kararları bakımından da hukuki bir rejime bağlanmamış kararlardır. Yine TBMM kararlarının da normlar hiyerarşisinin dışında kaldığı sonucuna varıyoruz. Aynı kademedeki normlar arasında bir çatışma olursa: 1. Aynı konuyu düzenleyen aynı ayrıntıdaki sonraki norm önceki normu örtülü olarak yürürlükten kaldırır. Bunun için kanunda açık bir biçimde kaldırmasına gerek yoktur. 2. Sonraki özel norm, önceki genel normu yürürlükten kaldırır. Eğer sonraki norm genel önceki norm özelse ikisi yürürlükte kalır. İçerikle, amaç bakımından bir uyumsuzluk varsa o zaman zımnen yürürlükten kalktığı istisnai amaçtır. Bunun dışında her ikisinin de yürürlükte kaldığını kabul ediyoruz.

1982 Anayasasına göre normlar hiyerarşisi dediğimizde şu anayasa hükümlerini referans verebiliriz. Anayasa 11.maddesi, Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığını düzenleyen madde. 2.Fıkra Anayasanın üstünlüğünü düzenliyor. 1924 anayasasının 104.md, 61 anayasasının 8.md'si, 82 anayasasının 11.maddesi hep kanunlar anayasaya aykırı olamaz demiş. Bu anayasanın diğer normlar karşısında üstünlüğünü gösteren bir hüküm. Buna karşılık 1961 anayasası 104.maddede de olmayan düzenlemede, anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 1982 Anayasasında 11/1, aynen bunu tekrarlamış. 1924 Anayasasından farklı olarak bu bize 61-82 anayasaları, anayasanın üstünlüğü ilkesinin yanı sıra aynı zamanda bağlayıcılığı ilkesini de getirmiş. Anayasanın bağlayıcılığı hukuk düzeninde, mahkeme baktığı davada bir kural boşluğu varsa ve o boşluğu dolduracak somut bir anayasa hükmü varsa o zaman anayasa hükmü uygulanır. Uygulayacağı bütün kuralları anayasayı göz önünde bulundurarak ele alır. Anayasaya uygun bir şekilde o normları yorumlar. Eğer anayasaya aykırı görüyorsa, o zaman o normu uygulamaması beklenir. Yargıcın, normları olabildiği kadar anayasaya uygun bir biçimde yorumlaması, anayasanın bağlayıcılığının bir gereğidir. Yine anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü aynı zamanda hiçbir devlet organının anayasayla çizilmiş sınırlar dışında herhangi bir yetkiye sahip olmaması anlamına gelir. Anayasanın 6.md.'si son cümlesi "hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" , 6.ve 11.maddeyi bir arada yorumladığımız zaman her kişinin ve organın yetkisinin sınırı anayasadır. Anayasada açıkça verilmemiş bir yetkiyi kimse kullanamaz. Yine anayasaya dayalı olarak bir kişi ya da kuruma yetki aktarılacaksa bu yetkinin mutlak bir anayasal dayanağının olması gerektiği anlamına gelir. Beta 45.sayfa Anayasa 138 ve 11.madde. yazılı ve katı anayasalarda, her zaman anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı hakkında bir düzenleme bulunur. Anayasanın üstünlüğü ilkesi 1924 103.madde, 61 anayasasının 8.md ve 1982 anayasasının 11.maddelerinde yer alan düzenlemeydi. Anayasanın üstünlüğünü ortaya koyan hüküm, kanunlar anayasaya aykırı olamaz hükmüdür. Bu, anayasanın kanunların üzerinde olduğu imajını ifade edip kanunlar, anayasaya aykırı olamayacağı anlamına gelir. 1961-82 anayasaları, 1924 anayasasından farklı olarak bir başka cümle daha eklemektedir. O cümle anayasanın bağlayıcılığı ilkesine vurgu yapan 8. ve 11. Maddelerinde " anayasa, yasama, yürütme, yargı organları, diğer kişi ve kuruluşları bağlar" diyor. Hem siyasal iktidarı kullanan kişi ve kuruluşları bağlıyor. Hem de diğer kişi ve kuruluşları bağlayan bir hukuki belge 82 anayasasının 11.md'sine göre. Ayrıca bunun yargıya ilişkin bir de izdüşümü var. 1982 Anayasasında 138/1 maddesine göre " hakimler, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar verirler." Burada normların bir sıralaması söz konusu. Burada da aslında biz 1982 anayasası düzenindeki normlar hiyerarşisini 2. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin yargısal izdüşümünü görüyoruz. Yargıç baktığı davada öncelikli ya ilgili davanın niteliğine göre kanunu uygular ya ilgili düzenleyici işlemi uygular. Yargıcın 138 maddeye göre anayasaya uygun olarak karar vermesinin anlamı: 1. Yargıç uygulamak durumunda olduğu normu her zaman anayasa kurallarını göz önünde bulundurarak yorumlamak zorundadır. Eğer o normda tam anlaşılmayan bir ifade varsa o zaman yargıç bu yorumu anayasa kurallarına uygun bir biçimde yapmak zorunda. Biz buna anayasaya uygun yorum ilkesi diyoruz. İlgili normu anayasa kuralları çerçevesinde ve ona uygun bir biçimde yorumlanması anlamına gelir. 2. Yargıç baktığı davada eğer bir hukuki boşluk varsa o zaman doğrudan anayasa hükmünü baktığı davada uygulamakla yükümlüdür. Bunun 2 koşulu vardır 1. Söz konusu konuda bir hukuki boşluğun olması gerekir. 2. O yasal boşluğa ilişkin olarak anayasanın somut bir düzenleme içermesi gerekir. Anayasanın doğrudan uygulanabilmesi için anayasada somut bir hüküm olması gerekir. 138/1 de yargıcın anayasaya uygun bir karar vermesinin 3. Bir yolu anayasa yargısında geçmişte olan bir yorumdur. AYM 2 konuda mahkeme sıfatıyla yargılama yapar; Siyasi partilerin kapatılması davaları ve Yüce Divan davalarında mahkeme sıfatını taşır. Diğerlerinde yargılama yapmadığı için mahkeme sıfatını taşımaz. AYM, bu iki işi

yerine getirirken uygulamak durumunda olduđu bir yasa kuralını iptal edemiyor ise ihmal ederek doğrudan anayasa hükmünü uygulayabilir. Anayasa 11.maddedeki kişi ve kuruluşlar ne anlama geliyor? Öncelikle anayasa hükümleri siyasal iktidarı kullananlar bakımından bağlayıcıdır. Bağlayıcılık: siyasal iktidarı kullananlar, kullandıkları yetkileri anayasadan almak zorundalar. Kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi hiç kimse kullanamaz. Bir kişi ya da kuruluşa yasa yoluyla bir yetki devrediliyor ise o yetkinin dayanağının da mutlaka anayasada bulunması gerekir. Anayasaya dayanmayan, anayasanın dışında kimsenin yetki kullanabilmesi, yetkisini genişletebilmesi mümkün değildir. 11.Maddenin bir başka izdüşümü, 6.maddede bahsettiğimiz yorumun anayasal dayanağıdır. Siyasal iktidardan başka özel kişiler bakımından sonucu anayasanın 12.maddesinde temel hak ve özgürlükler hakkında 1.fıkra kişilere doğal hak ve özgürlüklerini kullanma olanağı tanıyan bir fıkra. 2.Fıkra da ise o hak ve özgürlüklere ilişkin sınırı getiriyor. Bizler bakımından 1.yansıması 12.md, 2.yansıması biz hak ve özgürlüklerimizi devlete karşı kullanırız. Bizim hak ve özgürlüğümüzü de devlet sınırlar. Anayasa 11.madde, kişiler arasında yatay bir etki de yaratır. Bu hak ve özgürlüklerin yatay etkisidir. Yani kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde de anayasa kurallarının göz önünde bulundurulmasıdır. Kişiler arasında anayasa kuralları 1.yol anayasada tanınan hak ve özgürlükler somut olarak pek çok yasada düzenlenmiştir. Örneğin örgütlenme özgürlüğü, dernekler kanununda, sendikalar kanununda düzenlenmiştir. Örneğin miras hakkı, medeni kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunlar, kişiler arasındaki ilişkileri de düzenleyen kanunlardır. 2.yol özel hukuk işlemlerinde anayasa kurallarının göz önünde bulundurulması, tıpkı 138/1'deki yorumumuz gibi yani özel kişiler arasında yapılan işlemlerde eğer bir boşluk varsa bu boşluğu dolduracak somut bir anayasa hükmü de bulunmuyor ise o anayasa hükmü bu işlemde doğrudan uygulanmaz. İkincisi, bütün bu kanunlar kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunları ve kişiler arasındaki hukuki işlemlerin yorumlanmasında anayasa kurallarını göz önünde bulundurarak yapılması. Anayasanın 11.maddesinin, kişiler üzerindeki etkisini bu şekilde yorumlayabiliriz. Yasaların, anayasaya aykırı olamayacağına dair bir başka anlamı da anayasaya aykırı olan yasaların, hukuk düzeninden ayıklanması zorunluluğudur. Eğer hukuk düzeninde anayasaya aykırı kurallar ayıklanmıyor ise o zaman 11.md'nin 2.fıkrasında yazan ifadenin uygulamada hiçbir anlamı kalmaz. Bunu sağlayacak anayasaya aykırı yasaların hukuk düzeninden ayıklamayı sağlayacak bir düzenin olması gerekir. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi uygulamada bir anlam ifade etsin. Örneğin, 1924 anayasası böyle bir düzen öngörmedi. O nedenle siyasal alanda da hukuki alanda da yaşanan pek çok sorunun kaynağı aslında anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı kuralının hayata geçirilememiş olması olduğunu söyleyebiliriz. 1961 ve 82 Anayasaları, buna ilişkin bir kural getirdi, bu anayasa yargısı ve AYM'dir. Anayasa yargısının olmadığı bir düzende anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinden söz etmemiz mümkün değildir. Parlamentonun çıkardığı yasaların mutlaka bağımsız bir yargı organı tarafından anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutulması gerekir.

Seçim süreci: 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu md.6, seçim takvimini YSK tarafından yapılır ve ilan edilir. Seçimlerin ertelenmesi md.78, ara seçimler md.78, seçimlerin genel yönetimi ve denetimi: YSK md. 79, seçim sistemi: %10 ülke barajlı nispi temsil sistemi

Türkiye'de seçim sisteminin özellikleri: AY md.67, Temsilde adalet, yönetimde istikrar, her il bir seçim çevresi (nüfus çoksa bölünebilir), liste usulü, birleşik oy pusulası, bloke liste usulü.

OHAL rejiminin temel ilkeleri: OHAL rejimi ve alınacak önlemler yasallık ilkesine uygun olur. Önlemler OHAL ilan edilme nedeniyle sıkı bir bağ içindedir. OHAL olağan niteliğe dönüşecek biçimde uzun süreli olmamalı. Önlemler toplumda ve hukuk sisteminde özlü ve kalıcı değişikliğe neden olamaz. OHAL önlemleri yalnızca OHAL ilan edilen bölgede uygulanır.

Olağanüstü yönetim usulleri: Yetki: 2017 öncesi: Cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar kurulu, Yurdun tamamında ya da bir bölgesinde, süresi en çok 6 ay, 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Savaş halinde bu süre aranmaz.

2017 sonrası: yetki Cumhurbaşkanındadır, yurdun tamamında ya da bir bölgesinde, süresi en çok 6 ay, 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Savaş halinde bu süre aranmaz. Meclis süreyi kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü kaldırabilir. Resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15.maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlandırılacağını veya geçici olarak durdurulacağını, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. AY md. 104/17'deki

sınırlamalara tabi olmadan OHAL CBK çıkarabilir. OHAL CBK= aynı gün meclis onayına sunulur (3 ay içinde görüşülme şartı)

Olağanüstü yönetim usulleri: Neden:

2017 Öncesi: OHAL: -Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım – Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması

Sıkıyönetim: - Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması- savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi – ayaklanma olması ya da vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma – ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması

2017 Sonrası: OHAL: - Savaş, savaşı gerektirecek bir durum, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma – tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması ve son olarak ayrıca 1 uzun madde daha var.

Hükümet Sistemleri: Erkler arasındaki dikey ilişki, bize devlet biçimini veriyordu. Farklı düzeylerdeki devlet organları arasındaki ilişki bize o devletin biçimini veriyordu. Aynı düzeydeki devlet organları arasındaki ilişki ise bize o devletin hükümet sistemini, biçimini verir. Demokratik bir düzende, yatay güçler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ayrılık ya da ilişkidir. Hükümet sistemini belirleyen yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkidir. Yargı organı, bütün demokratik düzenlerde yasama ve yürütmenin dışındadır ve her iki organdan da bağımsızdır. Yargı organının, yasama ya da yürütme organına bağlı olduğu ondan etkilendiği sistem demokratik bir düzen değildir. Yasama ve yürütme organları arasındaki bu ilişki, 2 organın birbirine bağlılığına ya da bu 2 organın ayrılığına dayanabilir. Eğer yasama ve yürütme organları aynı kişide aynı organda birleşiyorsa o zaman o rejim güçler birliğine dayalı bir rejimdir. Güçler birliğine göre siyasal rejimlerden söz ettiğimiz zaman 1.durum yasama ve yürütme erkleri yürütme organında birleşebilir. 2. Durum yasama ve yürütme erkleri yasama organında birleşebilir. Eğer yasama ve yürütme bir kişide ya da bir grupta veya bir kurulda birleşiyorsa o rejim demokratik bir rejim olamaz. Bu rejimde yasama organı, yürütme organına bağımlıdır ve bağlıdır. Yasama ve yürütme yetkilerinin tümü ya da çok önemli bir bölümü yürütme erkinin elinde bulunduran bir kişide ya da grupta, bir kurumda toplanmıştır. Yürütme organı parlamentoya karşı veya yargı organına karşı ya hiç sorumlu değildir ya da son derece zayıftır. Kamu hukukunda yetki ve sorumlulukta paralellik ilkesi vardır. Bu ilke ne kadar bulunmuyorsa, bu ilkeye düzen ne kadar istisna getirdiyse o düzen o kadar az demokratiktir. Haliyle yasama ve yürütme erklerinin yürütme organında birleştiği bir düzende demokratik bir düzen olarak adlandırılmaz. Güçler birliğine dayalı 2.hükümet sistemi biçimi ise konvansiyonel hükümet sistemi. Bir başka ifadeyle yasama ve yürütme yetkilerinin yasama organında birleştiği hükümet sistemi, konvansiyonel ya da meclis hükümeti sistemi. Diğerinden farklı olarak bu sistem, demokratik bir hükümet sistemidir. Çünkü 1. Serbest genel seçimler sonucunda belirlenmiştir. 2. Ulusu temsil eder. 3. Ulusu bütün olarak temsil eder. Yani ulusun farklı unsurlarının, o parlamentoda temsil edilmesi mümkündür. Yürütmede birleşen güçler birliği sisteminde bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Tek kişiden oluşuyor. Parlamento tam tersine farklı görüşleri, toplumun farklı kesimlerini farklı çıkarları temsil yeteneğine sahip bir organ olması nedeniyle diğerlerinden ayrılır.

Hükümet Sistemleri:

1. Meclis Hükümet Sistemi: Genel seçimlerde belirlenen bir parlamento olacak ve bu parlamento hem yasama hem yürütme yetkilerini elinde bulunduracak. Meclis hükümet sisteminin /konvansiyonel sistemin) kurumsal dayanağını egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesi oluşturuyor. Boden'in anladığı anlamda egemenlik tek ve bölünmez ise o zaman onun yasama ve yürütme gibi 2 ayrı ele verilmemesi gerekir. Ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan parlamentoya verilecek. Böyle bir anlayıştır meclis hükümet sistemi. Yasama ve yürütme yetkileri parlamentoda, parlamento yasama yetkisini doğrudan kullanıyor. Yürütme yetkisini Bakanlardan oluşan bir kurul eliyle kullanıyor. Bu bakanları tek tek seçme atama ve istediği zamanda görevden alma yetkisine sahip. Bu sistemde bakanlar kurulunun bir kurul olarak parlamentoya karşı toplu sorumluluğu yok. Kollektif sorumluluk ilkesi meclis hükümet sistemi ile uyumlu değil. Yalnızca bakanların kendi görevleriyle ilgili sınırlar çerçevesinde parlamentoya karşı siyasal sorumluluğu söz konusu. Bu sistemde bakanlar kurulu birbiriyle iyi anlaşılan siyasal partiden ya da benzer siyasal partilerden gelen kişilerden oluşmak zorunda değil. Çünkü kurul olarak sorumluluk taşımıyor. Bakanlar kurulunun görevi parlamentonun direktiflerini yerine

getirmek. Parlamentonun yapmış olduğu yasaları uygulamak. Parlamento, bakanlara direktif verme yetkisine sahip. Bakanların ve kurulun yapmış olduğu işlemler parlamentonun denetiminde. Parlamento bu işlemleri değiştirebilir, kaldırabilir veya onaylayabilir. Ama son aşamada bakanların parlamentoya mutlak bir biçimde bağımlı olduğunu ve parlamentoya karşı siyaseten sorumlu olduğunu görüyoruz. Bu sistemde devlet başkanlığı ve başbakanlık makamı yoktur. 1921-23 dönemi BMM’nde de devlet başkanlığı makamı yoktu. Meclis başkanı uygulamada devlet başkanlığı makamının yerine getiriyor. Kurul üyeleri yani bakanlar parlamento içinden ve parlamento tarafında seçiliyor. Bakanların, parlamento dışından atanması kuralı, MHS ile bağdaşmıyor. Dolayısıyla bütün bakanların meclis içinden çıkması gerekiyor. Olağanüstü durumlarda bu sistemin benimsendiğini görüyoruz. Örneğin: 1791-1795 arasında Fransa da, 1920-1923 arasında ülkemizde olduğu gibi. Her iki durumda da olağanüstü koşulları atlatmak amacı vardı. Günümüzde bu sisteme en yakın uygulama İsviçre örneğidir. Bizde 1920-23 yılları arasında uygulanan bu sistemde yürütme organının parlamentoyu dağıtma yetkisine sahip değil. Parlamentonun görev süresini uzatma ya da kısaltma yetkisine sahip değil. Buna karşılık parlamento, isterse seçimleri yenileyebilir ve bakanları tek tek siyaseten sorumlu tutup görevden alma yetkisine sahip. Sonuç: MHS’nde yasama ve yürütme organı arasında, yasama organının lehine dengesiz bir ilişki var. Birbirine karşı kullanabilecekleri silah söz konusu değil. Tam tersine yürütme organının varlığı tamamen parlamentoya bağlı. Buna karşılık yürütme organının, parlamentoya karşı, onun varlığını tehdit edecek herhangi bir yetkiye sahip değil. Çünkü sistem yasama organının üstünlüğüne dayalı. Bugün de geniş anlamda konvansiyonel sistem parlamentonun yürütme organına karşı üstünlük taşıdığı bütün hükümet sistemleri için kullanılan bir ifadedir.

2. Parlamenter Sistem: Yasama ve yürütme erkleri arasında işbirliğine dayalı bir sistem. Dolayısıyla bu sisteme yumuşak güçler ayrılığına dayalı hükümet sistemi denir. 2 Temel tanımı vardır 1. Yürütme organının, yasama organından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu hükümet sistemine parlamenter hükümet sistemi denir. Yürütme organının yasama organından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu hükümet sistemi. 2. Bütün bu koşullara ek olarak yürütme organının yasama organını dağıtma yetkisine sahip olduğu hükümet sistemine verilen isim. Bütün parlamenter sistemlerde bu yürütme organının fesih yetkisi olmayabilir. Verilmeyen örnek 1924 anayasası. Verilenler ise 61-82 anayasalarıdır. Klasik parlamenter sistemin temel özellikleri 1. Yasama organı, genel seçimle belirlenir. Eğer o düzen demokratik ise bütün hükümet sistemlerinde yasama organının serbest genel seçimlerden çıkan bir parlamento olması gerekiyor. Parlamentonun tek ya da iki kanatlı olması devlet biçimini belirlemek bakımından hiçbir ayrımcı özelliği yok. Parlamentonun tek ya da 2 kanatlı olması devlet biçimini belirlemek bakımından önem taşıyabiliyor. Buna karşılık tek ya da 2 meclisli olmak hükümet sistemi bakımından hiçbir öneme sahip değil. Klasik parlamenter sistemi benimsemiş 2 meclisli parlamentoya sahip örnekler olduğu gibi tek meclisli parlamentoya sahip örnekler de var, Kanada, Almanya 2 meclisten oluşan parlamenter sistemler. Belçika da 2 meclisten oluşuyor. Buna karşılık Yunanistan, Lüksemburg, İsveç, Norveç tek meclise sahip. 2. Özellik yürütme organının 2 başlı olması. Devlet başkanı ve başbakan, bakanlar kurulundan oluşan bir 2’li yapıya sahiptir. Devlet başkanı soy esasına göre belirlenebilir. Bu durumda kendisi istemedikçe ömür boyu görevde kalır. Buna parlamenter monarşi denir. Devlet başkanı doğrudan parlamento ya da içinde parlamentonun da olduğu daha geniş bir kurul tarafından seçilecektir. Bu durumda devlet başkanının görev süresi sınırlıdır. Bu parlamenter cumhuriyettir. Her iki durumda da devlet başkanı son derece sınırlı ve simgesel yetkilerle donatılmıştır. Yürütmenin başlıca 2 önemli işlevi vardır. Bir simgesel işlevler ya da yetkiler, devleti temsil etmek, yürütmenin icrai yetkileri. Klasik parlamenter sistemde, yürütmenin simgesel yetkilerini devlet başkanı kullanır. Gerçek icrai kanadı ise bakanlar kuruluna aittir. Devlet başkanı simgesel yetkilere sahip olduğu için 1. Tarafsız olmak zorundadır. 2. Siyaseten sorumsuzdur. Bu sorumsuzluk parlamenter monarşilerde devlet başkanı bakımından mutlaklıktır. Devlet başkanı tarafsızdır. Hem cezai hem de siyasal bakımdan parlamenter monarşilerde, monarkın sorumsuz olduğunu görüyoruz. Parlamenter cumhuriyet bakımından ise devlet başkanının sorumsuzluğu genel olarak kuraldır. Siyaseten mutlak bir biçimde sorumsuzdur. Cezai olarak, anayasayı ihlal veya vatana ihanet gibi çok ağır bir suçlama ile sınırlı olmak üzere sorumlu tutulur. Devlet başkanlarının siyasal sorumsuzluğu klasik parlamenter sistemde, karşı imza ya da çift imza kuralı yoluyla saptanır. Devlet başkanının yapmış olduğu bütün işlemlerin başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması. Bunun sonucunda da o işleme yönelik siyasal ve hukuki sorumluluğun imzayı atan başbakana ve ilgili bakana ait olması anlamına gelir. Devlet başkanının kendi başına kullandığı bazı yetkileri de bulunuyor. Ulusun ve ülkenin birliğini temsil etme yetkisi, parlamentonun kabul ettiği bir yasayı yeniden görüşmek üzere parlamentoya geri gönderme yetkisi. Yine bir

yasayı anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla AYM'ne gönderme yetkisi, parlamento çoğunluğunun güvenini elde edebilecek bir parlamento üyesini başbakan olarak atama veya başbakan adayı olarak parlamentoya sunma yetkisi gibi devlet başkanının tek başına kullanabileceği yetkileri vardır. Bunlar tarafsız bir başkana verilen yetkiler olduğu için bundan kaynaklanacak bir hukuki çatışmanın da çıkmayacağı varsayılır. Bu hem monarşiler hem de cumhuriyet rejimleri bakımından geçerli bir durumdur. 1924-61 Anayasaları CB'nın bütün işlemlerinin ilgili bakan veya başbakanın imzasına bağlı olduğunu belirtmiştir. Yani karşı imza kuralı mutlak bir biçimde her iki anayasada da öngörülmüştür. 1982 Anayasası bunu biraz gevşetti. 2017 Anayasa değişikliğine kadar CB'nın hangi yetkileri tek başına kullanacağını belirtmiyor. Yürütme organının bir kanadını devlet başkanı oluşturuyor. Kural sorumsuz olması, simgesel yetkilerle donatılması ve bütün işlemlerinin karşı imza kuralına bağlanması. Diğer kanadını ise Başbakan ve bakanlardan oluşan bakanlar kurulu. Parlamente sistemde, kural bakanlar kurulu üyelerinin parlamento üyesi olmasıdır. Bu kural başbakan bakımından mutlak bir kuraldır. 1924 Anayasası bütün bakanlar kurulu üyelerinin TBMM üyesi olmasını zorunlu kılıyordu. 1961-82 anayasaları, milletvekilliği seçilme yeterliliğine sahip olmak kaydıyla dışarıdan da kişilerin bakan olarak atanabileceğini hükme bağlamıştı. Ancak bu istisnayı. Bakanlar kurulu üyelerinin çoğunluğunun dışarıdan atanması, klasik parlamente sistemin mantığına aykırıdır. Siyaseten sorumluluk, klasik parlamente sistemde hem bakanların kendi görev alanlarına giren konularda parlamentoya karşı bireysel sorumluluğu hem de hükümet sisteminden sorumlu olmak bakımından yine parlamentoya karşı toplu sorumluluğunu içerir. Bakanlar kurulunun toplu olarak sorumlu tutulması ve güvensizlik oyu ile görevden alınması durumunda bakanlar kurulu düşer. Başbakanın sorumlu tutulması ve parlamento tarafından görevden alınması durumunda bakanlar kurulu düşüyor. Bakanın tek başına sorumlu tutulması ve parlamento tarafından görevden alınması durumunda bakanlar kurulu yerinde kalıyor ancak demokratik gelenek böyle bir durumda başbakanın istifasını devlet başkanına sunmasını gerektirir. Özetle: - Genel seçimlerle belirlenen parlamento - Yürütme yetkisi parlamentoda - Parlamentonun sürekliliği ilkesi - Başbakanlık ve devlet başkanlığı makamları yok. - Bakanlar tek tek parlamento tarafından seçilir ve görevden alınır. - Bakanların toplu sorumluluğu yok. - Kurulun kararları parlamento tarafından kaldırılabilir, değiştirilebilir. Yürütme kurulu parlamentoyu tatil edemez, feshedemez.

Parlamente sistemde siyasal sorumluluk mekanizması: 1. Güven oylaması 2. Güvensizlik önergesi yoluyla. Bakanlar kurulu görevde olduğu sürece sürekli olarak parlamento çoğunluğunun güvenine sahip olmak zorunda. Parlamento dilediği zaman bakanlar kurulunu toplu olarak ya da bakanları bireysel olarak denetleme yetkisine sahip. Güven oylaması bakanlar kurulu için kuruluştaki istenebilir. Örneğin 24-61-82 anayasaları bakanlar kurulu kurulduktan sonra göreve başlar başlamaz TBMM'nin güvenoyuna ihtiyaç duyuyordu. Bunun için basit çoğunluk yeterli görülüyordu. Buna kuruluştaki güven oyu denir. Aynı zamanda kurulduktan sonra görevi süresince de başbakan, bütün bakanlar kurulu veya kendi için parlamentodan güven isteyebilir. Veya parlamento üyeleri diledikleri zaman başbakana, bir bakana ya da bakanlar kurulunun bütününe karşı güvensizlik önergesi sunabilir. Bunun sonucunda yapılacak güven oylamasında söz konusu bakanlar kurulu görevden alınabilir. Son olarak yürütmenin veto ve fesih yetkileri var. Veto yetkisi, parlamentonun kabul ettiği bir yasayı, yürütme organının yeniden görüşmek üzere parlamentoya iade etmesidir. Klasik parlamente sistemlerde geri gönderme yetkisi tarafsız devlet başkanına tanınan bir yetkidir. Bunu, bakanlar, başbakan, bakanlar kurulu kullanmaz. Fesih yetkisi ise, parlamentonun görev süresini yürütme organı eliyle kısıtılması, erken seçim kararı alınması anlamına gelir. Bunun amacı, parlamentonun hükümeti, siyaseten istediği zaman denetlemek gibi çok önemli bir silahı vardır. Bu silaha denge oluşturmak amacıyla, yürütme organına 1. geri gönderme yetkisi 2. Parlamenteroyu fesih yetkisi tanınmıştır. 1924 Anayasası, ne devlet başkanına ne bakanlar kuruluna geri gönderme yetkisi tanımadı. Ne devlet başkanı ne bakanlar kurulu herhangi bir şekilde TBMM'ni fesih yetkisi de yoktu. Aynı zamanda 1924 anayasasının meclisin üstünlüğüne dayalı bir hükümet sistemi olduğunu bize gösteriyor. 61 ve 82 Anayasaları tarafsız devlet başkanına yasaları bir daha görüşmek üzere TBMM'ne geri gönderme yetkisi tanıyordu. Fesih yetkisi ise son derece sınırlı bir biçimde verilmiş bir yetkiydi. Devlet başkanına tanınmış bir yetkiydi. Örneğin 61 anayasasında CB'nın seçimlerin yenilenmesi koşulundaki şartlar hiçbir zaman karşılanmadı ve bu nedenle hükümet istikrarsızlıkları giderilemedi. 82 Anayasası seçimlerin CB tarafından yenilenmesi koşulunu biraz kolaylaştırdı. Bir defa Haziran 2015 de anayasanın öngördüğü süre içerisinde hükümet kurulamayınca CB, TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararını aldı ve 2015 kasım ayında yeni seçim yapıldı. Bu pek çok klasik parlamente sistem örneğinde başbakana tanınan bir yetkidir. Başbakan dilediği zaman herhangi bir gerekçe öne sürmeden

parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. Birleşik Krallık'ta, başbakan avam kamarasının seçimlerini yenileyebilir.

Parlamentar sistem, yumuşak güçler ayrılığına dayalı hükümet sistemidir. Çünkü yürütme erki parlamentonun içinde çıkıyor ve ona karşı sorumlu. Haliyle yürütme ve yasama erkleri arasında yumuşak bir ilişki var ve bir işbirliği söz konusu. Bugün için yasama ve yürütme arasındaki yumuşak güçler ayrılığından çok, hükümeti kuran siyasal parti ve partilerle, parlamentonun içinde yer alan ama hükümet dışında kalan muhalefet partileri arasındaki bir ilişki biçimidir, bizim klasik parlamentar sistem dediğimiz hükümet sistemi. Eğer hükümeti tek bir siyasal parti kurmuşsa biz ona tek parti hükümeti diyoruz. Eğer hükümeti birden fazla siyasal parti kurduysa biz buna koalisyon hükümeti diyoruz. Eğer koalisyon veya tek parti hükümeti parlamentodaki üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun güvenini elde edebiliyor ise bu hükümet çoğunluk hükümetidir. Eğer bulamıyorsa biz buna azınlık hükümeti diyoruz. Düzenli, sürekli bir şekilde parlamentonun güvenini alabilmesi için hükümetin o hükümeti oluşturan siyasal partilerin parlamentodaki üye sayılarının en az üye tam sayısının salt çoğunluğu olması gerekiyor. Aynı zamanda parlamentar sistemde işgüder adı verilen bir hükümet vardır. Bir hükümet istifa, güvensizlik önergesi nedeniyle veya güven oylamasının sonucunda güven alamaması nedeniyle düşürülmesi veya Başbakan'ın yüce divana sevk edilmesi gibi durumlar sonucunda ortadan kalkmışsa, yeni hükümet kurulup göreve başlayıncaya kadar görevde kalan hükümete işgüder hükümet denir. Parlamentar sistemde de diğer herhangi bir hükümet sisteminde de bir devletin bir an bile hükümete kalmaması gerekir. Bu nedenle görevinde bulunmayan bir hükümet, yenisi kuruluncaya kadar görevde kalmaya devam eder. Amaç ülkeyi hükümete bırakmamak. İşte düşürüldükten veya istifa ettikten sonra yenisi kuruluncaya kadar görevde kalan hükümete işgüder hükümet denir. Bu hükümetin yaptığı işler sınırlıdır. Yürütmeye ilişkin, günlük işleri sürdürmeyi amaçlar. Bunun dışında gelecek hükümeti etkileyecek bir siyasal nitelikte bir kararları almaması gerekir. İşgüder hükümet, parlamentodan güven oyu almaz. Kural olabildiği kadar kısa bir süre içinde görevde kalması, yerini asıl hükümete devretmesidir. Klasik parlamentar sistemde, yasama ve yürütme ilişkileri arasında kural olarak bir denge söz konusu. Hükümet, parlamentoya karşı sürekli olarak siyaseten sorumlu. Dilediği zaman parlamento hükümeti görevden alabilir, gensoru yoluyla. Buna karşılık yasama ve yürütme ilişkisi arasında bir denge oluşturabilmek için yürütme organının eline de 2 silah verilmiştir. Biri veto yetkisidir. Parlamentonun yaptığı yasaları yürütme organının tekrar görüşmek üzere parlamentoya geri yollaması yani buna klasik parlamentar sistemde geciktirici veto yetkisi denir. Yürütmeye tanınan bu yetkinin güçleştirici bir nitelik taşıması genellikle hiç görülmez. Hep geciktirici veto niteliğindedir. Bu yetki yürütmenin sorumsuz aynı zamanda tarafsız olan devlet başkanına verilir. Kural değildir. Birleşik Krallıkta Kral, 18.yydan beri İngiliz Parlamentosunun kabul ettiği yasaları parlamentoya geri yollamıyor. 1924 Anayasasında CB'na böyle bir yetki tanınmamıştı. Buna karşılık 61-82 anayasalarının CB'na bu yetkiyi verdiğini görüyoruz. İstisna sı bütçe kanunudur. CB, bütçe kanununu geri gönderemiyordu. 2. Yetki fesih yetkisi: yürütme organının, parlamentoyu görev süresi dolmadan yasama dönemi bitmeden, parlamento seçimlerini yenileme kararı alması. Yasama ile yürütme arasındaki dengeyi sağlayan bir yetki olması nedeniyle genellikle yürütme organına verilen bir yetkidir. 1924 Anayasası yürütme organına böyle bir yetki tanımamıştı. Parlamentonun bu bakımdan yürütme karşısında önemli bir üstünlüğünün olduğunu söyleyebiliriz. 61-82 Anayasaları ise, bu yetkiyi son derece sınırlı istisnai bir nitelikte, yalnızca bir hükümet krizi çıkması durumunda. Bazı Klasik parlamentar sistemlerde ise bu yetkinin şartsız bir şekilde, hükümetin en uygun gördüğü zamanda kullanabileceği bir yetki olarak yine hükümetin icrai kanadın yani hükümete veya başbakana tanınan bir yetki olarak düzenlendiğini görüyoruz. Örnek: Birleşik Krallık, İspanya, Belçika

Pozitif Parlamentarizm: Hükümet kurulmadan hemen önce veya kurulur kurulmaz parlamentonun güvenine ihtiyaç duyuyor ise yani güven oyu almak durumunda ise biz buna pozitif parlamentarizm diyoruz. Hükümet kuruluşta güvenoyuna ihtiyaç duyması durumu. Belçika, Almanya, İtalya. 1924-61-82 anayasaları örnektir.

Negatif Parlamentarizm: Hükümetin kuruluşta güven oyuna ihtiyaç duymadığı parlamentar hükümet sistemine verilen isim. Amaç hükümetin kuruluşunu kolaylaştırmak. Kuruluşta güven oyu aranmıyor. Eğer parlamento çoğunluğu hükümetten memnun değilse gensoru önergesi vermek ve arkasından güvensizlik oylaması yapmak yoluyla o hükümeti görevden her zaman alabilir. Örnek Norveç, Danimarka, Hollanda.

Örtülü güven oylaması: Bütçe kanunu tasarısı, parlamento tarafından kabul edilmemesi durumunda Başbakanın istifa etmesi gerektiği klasik parlamentar sistemde kabul edilen bir kuraldır. Pek çok anayasa bunu yazmaz. Ama parlamentar sistemdeki teamül bütçe kanun tasarısı gibi son derece önemli bir tasarının

parlamento tarafından kabul edilmemesini, aslında örtülü bir güvensizlik olduğu biçiminde yorumlanır. Bu nedenle bütçe kanunu kabul edilmeyen bir hükümetin istifa etmesi gerekir.

Parlamente Hükümet Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları:

1. Parlamento sistemi, niteliği gereği ne yürütme organı ne de parlamentonun sabit bir süreyle görevde kalmasını gerektiren bir hükümet sistemi değil. Yani hem parlamentonun görev süresi hem de yürütme organının görev süresi esnek olabiliyor. Parlamento monarşilerde devlet başkanı ömür boyu görevdedir. Parlamento cumhuriyetlerde sabit bir süre içinde görevde ve onun görev süresinin uzatılması zaten mümkün değil. Kısaltılması ise son derece istisnai bir duruma bağlı. O durum da vatana ihanet, anayasayı ihlal gibi çok ağır bir suç. Devlet başkanının siyaseten parlamento karşısında sorumlu tutulması klasik parlamente sistemde mümkün değil. Siyaseten sorumlu olan kanat hükümettir. Bu durumda klasik parlamente sistemde hükümetin de parlamentonun da görev süresi esneklik taşıyabiliyor. Parlamento her an hükümeti düşürebilir. Görevden uzaklaştırabilir. Hükümetin, belli bir süre hiç dokunulmadan o görevde kalmak gibi bir lüksü yok. Parlamento içinde aynı şey geçerli.

Bunun için 2 yol var. 1. Yürütme organı parlamentoyu dağıtma yetkisine sahip olabilir. Parlamento kendi alacağı bir kararla kendi görev süresini erken seçim yoluyla kısaltabilir. Bu esnekliğin avantajı: Eğer parlamentoda istikrarlı bir hükümet kurulamıyorsa parlamentonun salt çoğunluğunun desteğini alan bir hükümet kurulamıyorsa o zaman seçimler yoluyla veya hükümetin başka siyasal partilerden oluşacak bir koalisyon biçiminde yeniden kurulması yoluyla bu istikrarsızlığın önü alınabilir. Parlamento sistemde, bunalımlar hiçbir zaman siyasal bunalım haline gelmez. Hükümet bunalımı olur. Bu hükümet bunalımları ya farklı siyasal partilerden oluşacak yeni hükümet alternatifleriyle aşılabılır veya parlamento seçimlerini yenilemek yoluyla aşıılır. Hükümet krizi olabilir. Ama Parlamento sistemi bu esnek niteliği nedeniyle hükümet krizlerini hiçbir zaman siyasal kriz boyutuna taşımaz.

2. Yine parlamente sistemde parlamentoda bir siyasal parti salt çoğunluğu elde edememesi durumunda birden fazla siyasal partinin oluşturacağı farklı hükümet modellerinin mümkün olabilmesi. Yani 2 siyasal parti anlaşamıyorsa bir başka siyasal parti hükümeti kurmak konusunda anlaşabilir. Haliyle birden fazla alternatif açıktır. Kuşkusuz ki hükümetin etkinliği bakımından bir siyasal partinin çoğunluğu elde edip hükümet kurduğu durumlarda o siyasal partinin kendi hükümet programını uygulamak konusunda parlamentoda bir direnç ya da muhalefet göremeyeceği kabul edilir. Çünkü parlamente sistemler kural olarak disiplinli partilere dayanırlar. Yani her siyasal partinin milletvekili kendi partisinin almış olduğu kararlara uygun hareket etmekle yükümlüdür. O nedenle siyasal partiler bakımından tek bir partinin hükümeti kurduğu durumlarda herhangi bir siyasal istikrarsızlık beklenmez.

3. Parlamento sistemde bir ya da birkaç siyasal parti hükümeti kurarken hükümet içinde yer almayan diğer siyasal partilere muhalefet görevi verilir. Eğer parlamento içinde bir siyasal parti salt çoğunluğu elde edememişse o parlamento içindeki en küçük partiden en büyük partiye kadar bütün siyasal partilerin bir gün hükümetin içinde yer alma olasılıkları vardır. Bu 1. Sağ ve sol uçtaki siyasal partilerin sorumsuz muhalefet yapmasını engeller. Bu toplumsal kutuplaşmanın yumuşamasını sağlar. 2. Parlamento sistemi, siyasal iktidarı birden çok siyasal parti arasından paylaşılmasına olanak veren hükümet sistemi olduğu için ekonomik, etnik, kültürel, dinsel bakımdan parçalanmış ya da kutuplaşmış toplumlarda bunların tümünün hükümet içinde yer almasını sağlayan bir olanak sunar. Bu olanak öncelikle kutuplaşmayı önler. Parçalanmış toplumlarda parlamente sistemin daha iyi işlediğini ve bu tür toplumlarda daha olumlu sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Demokrasi konusunda, parlamente hükümet sistemiyle yönetilen devletlerin büyük çoğunluk taşıdığını görüyoruz.

Parlamente sistemin olumsuz yönü: Her olumlu yönü aynı zamanda olumsuz yönünü de oluşturuyor.

1. Siyasal istikrarsızlığa neden olabilir. Siyasal istikrarsızlık olmasının kaynağı, eğer bir siyasal parti parlamentoda salt çoğunluğu elde edememişse koalisyon hükümeti varsa ya da azınlık hükümetleri varsa bu hükümetlerin kısa ömürlü olmasına neden olabilir. Hükümetteki siyasal parti ya da partilerin kendi programlarını istedikleri gibi uygulayamaması sonucunu doğurabilir. Bir siyasal partinin tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlaması istikrarın habercisi olmayabilir. Ayrıca tek bir siyasal parti ülkeyi yönetebilir ama toplumun genelini memnun eden bir siyaset gütmüyor olabilir. Haliyle tek parti yönetimi her zaman siyasal istikrarın kaynağıdır anlayışı geçerli değildir.

2. Etkin bir yönetim oluşturamayabilir. Etkinlik sorunu koalisyon hükümetlerinin azınlık hükümetlerinin durumlarından kaynaklanıyor. Örneğin: Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç 1945 yılından bugüne hiçbir anda

tek parti ile yönetilmedi. Ya koalisyon ya da azınlık hükümetleri ile yönetildiler. Bu örnekleri siyasal istikrarsızlıkla, az gelişmişlikle suçlamak mümkün değil.

Sonuç: Azınlık ve koalisyon hükümeti bir norm olabilir. Bunun kural olması o devletin kötü yönetildiği anlamına gelmez. Üstelik parlamenter sistemde koalisyon hükümetlerinin olması o toplumun uzlaşma kültürünü geliştiren bir olumlu unsurdur.

Parlamenter sistem, bu 2 eleştiriyi ortadan kaldırmak için bir takım hukuki araçlar öngörebilir. Hükümet sisteminin etkinliğini ve istikrarını artırmayı ve sağlamayı amaçlayan hukuki araçlara verilen isme **rasyonelleştirilmiş parlamentarizm** denir.

Parlamenter sistemde siyasal istikrarı sağlamayı amaçlayan araçlar:

1. Negatif Parlamentarizm (NP): NP veya kuruluştaki güvenoyu aranıyorsa bunun sabit çoğunlukla sağlanması, istikrarın sağlanması bakımından örnek verebileceğimiz RP araçlarından biridir. Hükümetin kuruluşunu kolaylaştıracak ve düşürülmesini zorlaştıracak bütün araçlar, istikrarı sağlamaya yönelik RP araçlarıdır. Hükümetin düşürülmesini zorlaştıran araçlardan biri, hükümetin düşürülmesindeki nitelikli bir çoğunluğun aranmasıdır. Genellikle bu üye tam sayısının salt çoğunluğu biçiminde olur. 24-61-82 Anayasaları hem kuruluştaki basit çoğunluğu yeterli bulmak hem de gensoru sonucunda yapılacak güvensizlik oylamalarının kabulü için üye tam sayısının salt çoğunluğunu aramak gibi 2 yolla hükümet istikrarını sağlamayı amaçlamıştır.

2. Yine parlamenter sistemde hükümet istikrarını sağlayan bir başka araç kurucu güvensizlik kurumudur. Bir hükümetin düşürülmesi konusunda anlaşılan uyumsuz parlamento çoğunluğu onun yerine geçecek başbakan adı konusunda da anlaşmasının şart koşulmasıdır. Böylelikle parlamento çoğunluğu hükümetin düşürülmesi konusunda anlaşmış, yeni bir hükümet konusunda anlaşamamış ise orada bir hükümet istikrarsızlığı ortaya çıkacak. Bu istikrarsızlığı önlemek amacıyla hükümetin düşürülmesi konusunda anlaşılan çoğunluğun onun yerine hükümeti kuracak başbakanın ismi konusunda da anlaşmasını öngören RP aracına **kurucu güvensizlik kurumu** denir. Örnek Almanya, İspanya, Macaristan, Belçika, İsrail. Bunlara bakınca 1. Güvensizlik önergesi veren milletvekilleri bu önergenin içine, güvensizlik önergesinin parlamentoda kabul edilmesi durumunda kimin başbakan olacağı konusunda da bir milletvekili ismini önergeye yazmak zorundadır. Almanya, Belçika ve İspanya'da güvensizlik önergesinin içine yalnızca başbakan adayının isminin yazılması yeterlidir. Buna karşılık İsrail'de hem başbakan adayının adı hem de başbakanın kuracağı hükümetteki bakanların adları, bu kurulması olası hükümetin, hükümet program taslağı mutlaka güvensizlik önergesinde yer almalıdır. Amaç bir hükümeti düşürerek yeni bir hükümette kurmayarak bu tür istikrarsızlığı ortadan kaldırmak. Kurucu güvensizlik örneklerine baktığımızda, bu ülkelerde uzun süreli hükümetlerinin oranının %83'e kadar çıktığını görüyoruz. Yani bu kurumun, uzun süreli hükümetlerin kurulup sürdürülmesi konusunda önemli bir olumlu işlev gördüğüne tanık oluyoruz.

3. Yine istikrarı korumayı amaçlayan bir başka araç fesih tehdidi ile güven oylaması. Almanya'da buna göre hükümet parlamentoda güven oyu ister ve güven oyu isterken de der ki "eğer siz bana güven oyu vermezseniz, ben parlamentoyu fesih edeceğim." Fesih ya da seçimlere gidilmesi milletvekillerinin hoşlanmadığı bir iştir. Haliyle hükümetin fesih yoluyla güven oyu istemesi de zaman zaman olumlu bir sonuç doğurabiliyor.

İstikrarı sağlamak bakımından son bir araç, parlamenter cumhuriyetlerde devlet başkanını, parlamento seçer. **4. Devlet başkanını belli bir oylama biçiminde parlamentonun seçememesi** durumunda genel seçimlere gidilmesi istikrarı sağlamaya yönelik bir RP aracıdır. 1982 Anayasamızda, ilk 2 oylamada TBMM adaylardan biri üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu aldıysa CB seçilmiş oluyor. Kimse ilk 2 oylamada bu oyu alamadıysa 3. Oylamaya geçiliyor. 3.Oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan aday CB seçilmiş oluyor. Yine kimse alamadıysa son bir oylama yapılıyor. Bir önceki turda en çok oyu alan 2 aday 4.tur yarışına katılıyor. Bu 2 adaydan, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan seçiliyor. Kimse üye tam sayısının salt çoğunluğunu alamamış ise o zaman TBMM seçimleri otomatik olarak yenileniyordu. 1961 Anayasasına göre bir kişinin CB seçilebilmesi için Meclis üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyordu. Ancak o dönemdeki TBMM kompozisyonu bir kişi üzerinde üye tam sayısının salt çoğunluğunu CB olarak bir kişinin adı üzerinde anlaşılması mümkün olmuyordu. Haliyle 1980'e gelindiğinde 10'un üzerinde TBMM oylaması yapılmıştı, CB seçimi için. TBMM seçimlerinin yenilenmesi gibi RP mekanizması da 61 anayasası öngörmediği için daha pek çok siyasal istikrarsızlığın yanına yeni bir de CB'nı seçememe gibi yeni bir sorun eklenmişti. 1982 Anayasası, bu olumsuz deneyimin bir daha yaşanmaması için 1975 Yunan anayasasına benzeyen böyle bir araç öngörmüş.

Hükümetin etkinliğini artırmayı amaçlayan RP araçları vardır. Bunlar genel olarak parlamentonun çalışmasını hızlandırıcı nitelikteki araçlardır. Örneğin 1. Parlamentonun, toplantı ve karar yeter sayısının düşürülmesi. 1924 ve 61 anayasaları bu konuda RP aracı öngörmüyordu. Tam tersine her 2 anayasa da TBMM'nin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu idi. 82 Anayasasının 96.md. uyarınca bunu üye tam sayısının 1/3'üne indirdi.

2. Özellikle yasalaşma sürecinin basitleştirilmesine yönelik önlemler. Örneğin genel kurulun bir komisyon olarak çalışması. Yani komisyon aşamasının atlanması ve genel kurulun bazı konuları görüşürken hem komisyon hem de genel kurul olarak çalışması. İkincisi komisyon aşamasında örneğin yasaların maddelerinin görüşülmesi bakımından bir süre sınırı getirilmesi. Buna giyotin usulü denir. Örneğin Birleşik Krallık'ta komisyon aşamasında uygulanan bir RP aracıdır.

Hükümete, yasa gücünde düzenleyici işlem yapma yetkisi tanınması da parlamenter hükümetin etkinliğini artırmayı amaçlayan bir araçtır. İspanya, İsrail Belçika kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hükümete tanıyor. 1973 Anayasa değişiklikleri ile KHK kurumu bizim hukuk düzenimize girmiştir. 2017 Anayasa değişikliklerine kadar yürütmenin KHK çıkarma yetkisi vardı.

İki Amerikalının ayırımında geçen **Başbakan'ın doğrudan halk tarafından seçilmesi**: Parlamenter sisteme çok benzeyen hükümet sistemidir. Bir tek İsrail'de 1991-2001 yıllarında uygulandı. Temel özelliği aslında klasik parlamenter sistem. Yürütme erki iki kanatlı, CB'nı parlamento seçiyor. CB simgesel yetkilerle donatılmış, siyaseten sorumsuz bir kişi. Yürütmenin gerçek sahibi, başbakan ve bakanlardan oluşan bakanlar kurulu. Buraya kadar parlamenter sistemdir (PS). PS'den ayrılan yönü ise, Başbakan'ın genel oyla seçilmesi. İsrail'de, parlamento ve başbakanın seçimi aynı anda yapılıyor. Amaç ülkenin kendine özgü durumu. İsrail, çok bölünmüş ve kutuplaşmış bir toplumdur. Seçim sisteminin de etkisiyle böyle bir toplum aynı şekilde parlamento ya yansıyor. Birbirleriyle uyum sağlayamayan çok sayıda siyasal parti oluyor. Bunlar birbirleriyle koalisyon kurmak istemiyor. Tek bir siyasal partinin de hükümet kuracak gücü hiç olmuyor. Başbakana, genel oydan çıkmak yoluyla bir meşruiyet gücü sağlayarak onu sistem içinde güçlendirmek. Böylelikle sistem de bir istikrar sağlamak amaçlanıyordu. Ama sistem kendisinden beklenen istikrarı getirmedi. Bu sebeple 2001'den itibaren bu sistemden vazgeçildi.

II. Dönem 22 Şubat 2023

Güçler arasında işbirliği (Yumuşak güçler ayrılığı):

Parlamenter sistem (PS) Tanım: Yürütme organının yasama organından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu sistem. Bu koşullara ek olarak yürütme organının yasama organını fesih yetkisine sahip olduğu sistem.

Yarı Başkanlık Sistemi (YBS): Yürütmenin iki başlı olduğu ama devlet başkanı kanadının doğrudan halk tarafından seçildiği bir yumuşak güçler ayrılığı sistemi. Bunun genel şemsiyesi yarı başkanlık sistemi. Yani devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçildiği, yürütme erkinin klasik PS de olduğu gibi, iki başlı olduğu yani Devlet Başkanı, Başbakan ve BK'ndan oluştuğu, yürütme erkinin iki kanadı olan Başbakan ve BK'nun parlamento ya karşı sorumlu olduğu bir hükümet sistemi yarı başkanlık sistemidir. Bu sistem kendi içinde 3'e ayrılıyor: *1. Başkanlı PS 2. Başkancı PS 3. Klasik Yarı Başkanlık Sistemi*. Bu üç hükümet sistemi Yarı Başkanlık Sistemi denilen büyük yelpazenin içinde yer alır. Bunların ortak yönü yürütmenin iki başlı olması yani Devlet Başkanı (DB) ve Bakanlar Kurulundan (BK) oluşması. BK'nun parlamento ya karşı siyaseten sorumlu olması ve DB'nın da doğrudan halk tarafından seçilmesi. Bu üç sistemi birbirinden ayıran, DB'nın sahip olduğu yetkililerdir. YBS'nde, hükümet sistemi halen parlamenter sistemde olduğu gibi iki başlı olmakla birlikte parlamenter sistemden iki bakımdan birbirinden ayrıldı.

1. Klasik parlamenter sistemde (KPS) ya soy esasına göre belirleniyordu veya içinde parlamentonun da olduğu bir kurum veya yalnızca parlamento tarafından seçiliyordu. YBS'nde, DB'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi vardır.

2. Önemli farkı, DB'nın önemli yetkilere sahip olmasıdır. KPS'de, DB'nın yetkileri simgesel ve törensel bir nitelik taşıyordu. Bu yetkilerle donatıldığı için tarafsız bir kişiliktir ve hükümet krizine müdahale etme olanağına sahipti. YBS'nde, DB seçimle geldiği için işbaşına belli vaatlerle geliyor. Bu vaatlerle DB seçilince o kişi tarafsız devlet başkanı olmuyor.

Duverger'in Yarı başkanlığın unsurları: 1. Devlet başkanı halk tarafından seçilir 2. Yürütme erki iki kanatlı olacak. (KPS'ndeki gibi) 3. Yürütmenin Başbakan ve BK kanadı, parlamento ya karşı siyaseten sorumlu olacak

(KPS’nde olduğu gibi). **4. DB**, önemli yetkilere sahip olacak. YBS’ni, KPS’den ayıran en önemli özelliklerden biri bu. YBS’nde devlet başkanının önemli yetkileri var. Yani hükümetin oluşumuna etki edebilecek, hükümetin ya da parlamentonun varlığıyla ilgili olan yetkiler. Tarihteki ilk uygulaması Fransa’da uygulanmış olan Orlenas’cı parlamenter sistem olduğunu söylüyor, Duverger. Bu sistemde, iki kanatlı olan yürütmenin Başbakan ve BK kanadının, hem parlamentoya hem de devlet başkanına yani Kral’a karşı siyaseten sorumlu olduğu hükümet sistemine verilen isimdi. 1919-1933 Yılları arasında Baymar Almanya’sını YBS’ne örnek gösterir.

İtalyan siyasetçi **Sartori’ye göre** öncelikle bir hükümet sisteminin YBS olarak tanımlanabilmesi için,

1. Öncelikle Başkanın doğrudan belli bir süre için halk tarafından seçilmesi gerekir. **2.** Gerçek anlamda “ikili iktidar” ve “ikili otorite” (diarşi) vardır. DB’nin, yürütme erkini Başbakanla ve BK ile paylaşması gerekiyor. Yürütme erkinin ve yetkilerinin, gerçek anlamda yürütmenin iki kanadı arasında paylaşılması gerekir. KPS’de böyle bir paylaşma yok. KPS’den şu yönüyle ayrılır; Yarı başkanlıkta, yürütme içinde görülen ikili iktidar gerçek ikili otorite olduğunu görüyoruz.

Bunun anlamı; **a)** DB, yasama organından bağımsız ancak yalnız başına ya da yürütmenin bütün yetkilerini kullanmaya da yetkili değildir, bağımsız hareket edemez. Anayasayla kendisine tanınan bu yetkilerini devlet başkanı çoğunlukla hükümet kanalıyla işlem görmek zorunda.

b) Başbakan ve kabinesi, parlamentodan çıkar ve onun güvenine muhtaçtır. Parlamentonun güven oyuna bağlı siyaseten parlamentoya karşı sorumlu ve her zaman onun desteğine gereksinim duyuyor.

c) Yürütmenin her iki kanadının “özerklik potansiyeli” devam eder. Başbakan ve BK da, devlet başkanından bağımsız görüntü sergiliyor. Haliyle yürütme organı içinde böyle 2’li bir otorite yapısı çıkıyor. Bu yapı içinde yürütme erkini kullanan 2 kanat, birbirine bağımlı değil. Buna karşılık, yürütme erkini kullanırken bir arada bulunmak zorunda. Bunun sonucu olarak YBS, ne tam bir KPS ne de saf bir Başkanlık Sistemi görüntüsünü taşıyor. Bir çeşit sarkaç görüntüsünde. Bir ucunda KPS bir ucunda saf BS var. YBS, bu sarkaç içinde BS’ne doğru gidebiliyor ya da PS’e doğru gidebiliyor. Eğer hükümetin 2 kanadı aynı siyasal partiden geliyorsa o zaman yürütmenin ağırlıklı kanadı DB olur. Bu hiçbir zaman BS’ne dönüşmüyor. Çünkü yürütmenin Başbakan ve BK kanadı her zaman özerklik potansiyelini koruduğu için.

d) Birlikte yaşama dönem (Cohabitation) Buna karşılık hükümetin 2 kanadı farklı siyasal akımlardan geliyor ise sistem Cohabitation yani bir arada yaşama biçimine dönüşüyor. CB’nın siyasal partisiyle, parlamento çoğunluğunun farklı siyasal partilerden gelmesi durumunda ülkeyi birlikte yönetme durumunda kalınıyor. Bu olduğu takdirde, CB uygulamada siyasal yaşamda geriye çekiliyor. Çünkü hükümet anayasa ile verilen yetkilerini kullanıyor, CB’na devretmiyor. Onun istediği biçimde kullanmıyor. Böyle olunca da sistem KPS’e yaklaşıyor. Bu sistemde, Devlet Başkanlarının, daha geniş yetkileri olduğu için bu yetkilerinin tümünü yürütmenin diğer kanadına bırakmayı istemiyorlar. Haliyle etkili bir görüntü sergileyemiyorlar.

YBS’nde yer alan üç farklı biçim:

1. Başkanlı Parlamenter Sistem: aslında klasik PS’e çok benzeyen sistem. KPS’den ayıran yönü, devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi. Yürütmenin gerçek sahibi, Başbakan ve BK. Devlet Başkanına anayasa, tıpkı KPS’de olduğu gibi simgesel ve törensel yetkiler tanınmış. Tek farkı KPS’den, devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesidir. Örnek: 1. İrlanda 2 Bulgaristan 3. Avusturya. 2008-2017 Yılları arasında Türkiye’de de bu sisteme benzer bir hükümet sistemi olduğu söylenebilir.

2. Başkancı Parlamenter Sistem: Bu sistem, Başkanlı PS’in tam tersini oluşturuyor. Yani yürütme erki 2 kanatlı, devlet başkanı ve Başbakan ve BK’ndan oluşuyor. Yine yürütmenin 2.kanadı parlamentonun içinden çıkıyor. Ona karşı siyaseten sorumlu. Yine devlet başkanını, belli bir süre için doğrudan halk tarafından seçiliyor. Buna karşılık yürütme içinde yetkiler bakımından devlet başkanının ağırlığı, başbakan ve BK’na göre çok daha büyük. Yine yasama organıyla yürütme organı arasında devlet başkanının lehine bir dengesizlik söz konusu. Devlet Başkanının çok geniş yetkileri var.

Bunlar, **1.** Yürütmenin ikinci kanadının oluşumuna ve iktidarda kalmasına hizmet edecek nitelikteki yetkiler. Yani Bakanları ataması ve onları görevden alma yetkisi.

2. Devlet Başkanının parlamentoyu dağıtma veya kararname çıkarma yetkisi de bulunuyor. Günümüzde Rusya, Ukrayna, Tayvan, Gürcistan, Orta Asya ve Kafkaslardaki Cumhuriyetlerin büyük çoğunluğunu buna örnek verebiliriz. Rusya için süper başkanlık sistem de denir. Bunun sebebi, hükümet sisteminin tek bir kişi üzerine kurulmuş olmasıdır. Bunu en iyi bilinen örneği Rusya’dır. Rusya, federal bir devlettir. Parlamento iki

kanatlı, **1. Federe devletleri temsil eden federasyon konseyi** **2. Bütün ulusu temsil eden Duma.** Hükümet, Duma'ya karşı sorumlu. Bu ülkedeki federalizm, nominal federalizmdir. Yani yetkilerin büyük ölçüde merkezde toplandığı, federe devletlerin yetkilerinin son derece sınırlı olduğu bir federal devlet biçimi.

1. Devlet Başkanı, 4 yıl için seçiliyor. Bir kişi arka arkaya iki defa seçilebiliyor. **2.** Rusya anayasasına göre devlet başkanı, vatana ihanet ve bazı ağır suçlar dışında hemen hemen hiçbir şekilde yargılanamaz. **3.** DB'nın, hem yasamaya ilişkin hem de yürütmenin ikinci kanadının oluşumuna ve varlığını sürdürmesine ilişkin çok geniş yetkileri var.

Yasamaya ilişkin: **1.** Duma'yı fesih yetkisi var. Bu sayede genel seçimlere gidebilir. **2.** Halk oylamasına gitme yetkisi. **3.** Duma'ya yasa tasarısı sunma yetkisi **4.** Parlamentonun kabul ettiği yasaları veto etme yetkisi tanınmıştır. Bu veto güçleştirici bir vetodur. Devlet Başkanının veto ettiği bir yasanın parlamentoda kabul edilebilmesi hemen hemen mümkün değildir. Başkanın bir başka yetkisi, kararname çıkarma yetkisidir. Bununla başkanın düzenleme yetkisi söz konusu. Önemli kamu görevlilerini atama yetkisi başkanın elindedir. Yürütmenin **2.** Kanadını oluşturan Başbakan ve BK, başkan karşısında son derece etkisiz. Hükümetin istifa edip etmemesi, başkanın kararına bağlı. Başbakan kendi bakanlarını atayamıyor. Hükümet kararname, anayasaya, federal yasalara ve başkanın çıkardığı kararlara aykırı olamaz. Hükümet programı, başkanın çıkaracağı kararnameye uygun olmak zorunda. Hükümetin görev süresi, başkanın görev süresiyle sınırlıdır. Bu sistemde kamu kaynaklarının harcanması ve bunların denetlenmesi meselesi de yürütmeye ait bir mesele. Parlamento, yürütme organını denetleme olanağına sahip değil ya da son derece zayıf olarak inşa edilmiş. Bu da sistemin yolsuzluklara açık hale gelmesine neden olabiliyor. Başkanın, bütün hükümet sistemine hem ekonomik düzen hem de siyasal düzen içinde tek etkili isim olması havaleci demokrasi dediğimiz bir anlayışın hakim olmasına neden olur.

Havaleci demokrasi anlayışında, devlet başkanı kendisini her şeyin üzerinde görüyor, hem yetkilerin toplandığı yürütme erkinin hem parlamentoyu hem de yargı organını kendisine yönelik denetimlerden korumaya çalıştığı görülür. Bu başkanlık sisteminin kötü uygulamalarında da sıkça görülen durumdur. Haliyle parlamento ve mahkemeler tarafından kendisine yönelik olarak yapılan sınırlamaları da ayak bağı olarak görüyor. Bu durumda kendisinin yetkilerini sınırlamaya çalışan, denetlemeye çalışan bu organları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor ve buna uygun politikaları uyguluyor.

Klasik Yarı Başkanlık Sistemi (KYBS): Fransa, Polonya, Hırvatistan'da uygulandığını görüyoruz. Fransa'daki temel özelliği; öncelikle yürütmenin her iki kanadının da önemli yetkileri vardır. Birbirlerine karşı özerklik potansiyellerini korur. Bu sistem bir sarkaç gibi işler. Yani yürütmenin 2 kanadı aynı siyasal parti ya da eğilimden geliyorsa yürütmenin devlet başkanı bölümü güçlenir. Eğer yürütmenin 2 kanadı farklı siyasal partilerden geliyorsa o zaman bir arada yaşama dönemi ortaya çıkar. Ve bu dönemde hükümetin devlet başkanının yanında ağırlığı artmaktadır. Bu dönemde sistem parlamenter sisteme doğru gider. KYBS'de, DB, parlamenter sistemden çok daha geniş yetkilerle donatılmıştır.

Fransa'da bu yetkiler; **1.** Parlamenter sistemde devlet başkanına verilen yetkiler var. **2.** KPS'de olmayan bir yerde olağan dışı yetkileri var.

KYBS'deki yetkileri: **a.** Başbakanı atama, onun önerisiyle bakanları atama ve görevden alma **b.** KPS'de olduğu gibi geciktirici veto yetkisi vardır (Bu sistemde devlet başkanlarına güçleştirici veto yetkisi tanınmaz, Rusya'da olduğu gibi). **c.** Devleti temsil etme yetkisi **d.** Parlamenteoya mesaj verme yetkisi **e.** Anayasa konseyine doğrudan 3 üye atama yetkisi vardır. Bu sistemde KPS'de olduğu gibi devlet başkanının işlemleri kural olarak karşı imza kuralına bağlıdır. Bu KPS'e özgüdür. Amaç, CB yetkisiz ve aynı zamanda tarafsız bir kişilik haliyle yürütmenin yapmış olduğu bütün işlemlerden siyaseten ve hukuken sorumlu olan kanat Başbakan ve BK olduğu için CB'nın bütün işlemleri Başbakan ve Bakanların imzasına bağlıdır. Buna karşı imza veya çift imza diyoruz. KPS'ye ait olan bu sistem KYBS ile yönetilen Fransa'da da bulunmaktadır. Bu her zaman devlet başkanının yetkilerini yürütme karşısında sınırlama işlemi görmüyor. Tam tersine Cohabitation durumlarında devlet başkanı, bu karşı imza kuralını yürütmenin diğer tarafına karşı bir pazarlık aracı olarak kullanabiliyor. Bizde 1982 Anayasasının ilk dönemlerinde CB'ları olan Turgut Özal'ın ve A. Necdet Sezer'in dönemlerinde bile bu CB'larının istemedikleri bakanlar kurulu kararnamelerini imzalamaktan kaçınmışlardı. Oysa parlamenter sistemde devlet başkanlarının böyle bir yetkisi yoktu. CB'nın diğer yetkileri – Fransa'da CB, yürütmenin, hükümetin başı. KPS'de CB yürütmenin gerçek anlamda başı değil. Çünkü yürütmenin bütün yetkileri BK'na ait ve eğer gerekli görürse Bakanlar Kurulu toplantılarına, kararlarına

katılabilir. Oysa KYBS’de BK, Elize Sarayında toplanıyor. Üstelik anayasa, CB’nin katılamayacağı BK toplantısına Başbakan’ın başkanlık etmesini sıkı koşullara bağlamıştır. Fransa anayasasına göre bu yürütmenin başının gerçek anlamda CB olduğunu gösterir. Bir de Başbakan ve Bakanlardan oluşan bir kurul vardır. Ama bu kurulun anayasal bir niteliği yoktur. Her dönemde BK, sarayda CB başkanlığında toplanır. Cohabitation dönemlerinde, anayasa öngörülmemesine rağmen Başbakan ve Bakanlar ayrıca CB’nin dışında kabine toplantısı yaparlar. CB’na karşı kendi pozisyonlarını ortaya koyup karar almayı sağlamayı amaçlarlar. CB’na anayasa ile tanınan diğer olağanüstü yetkiler yani KPS’de CB’na tanınmayan yetkiler: yasaları halk oylamasına sunma yetkisi, anayasanın 16. Maddesine göre; anayasal kurumların normal olarak işlemesi kesintiye uğramışsa o zaman CB, hükümetin ve parlamentonun yetkilerini tek başına kullanma olanağına sahip. Buna biz olağanüstü durumlarda tek kişiye tanınmış diktatörlük yetkisi deriz. Yine Fransa’da KYBS’lerin tümünde olduğu gibi CB’nin millet meclisini şarta bağlı olmadan fesih edebilme yetkisine sahip. Parlamenter sistemlerde, parlamentoyu dağıtma yetkisi yürütmenin sorumlu kanadına yani Başbakan’a verilir. Devlet başkanına böyle bir yetki verildiyse o şartlı bir yetkidir. Hükümet bunalımı varsa bu bunalımı seçim yoluyla aşmak amacıyla bu yetki tarafsız bir kişiye verilmiştir.

Özetle: KYBS’de 1.Devlet başkanı, halk tarafından seçilir. 2. Hükümet parlamentonun güvenoyuna dayalıdır. 3. Karşı imza kuralı. 4. Başkan, başbakanı ve onun önergesiyle bakanları atar. 5. Geciktirici veto yetkisi. 6. Anayasa Konseyine 3 üye atar. 7. Anayasa konseyine, yasanın anayasaya aykırılığı savıyla başvurulabilir. *Fransa’da Devlet Başkanı:* Aynı zamanda hükümetin gerçek başı. Parlamentoyu fesih yetkisi var. Yasaları halk oylamasına sunabilir. Anayasa kurumların normal işlemesi kesintiye uğrarsa hükümetin ve parlamentonun yetkilerini tek başına kullanabilir.

Avantajları: Bunun için KYBS’nin özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü başkanlı parlamenter sistem, klasik parlamenter sisteme çok yakın, başkancı parlamenter sistem ise işleyişi itibarıyla süper başkanlık sistemine çok yakın. Avantaj ve dezavantajlar için Fransa örneğinde olduğu gibi KYBS’ni esas alıyoruz.

1. Devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçildiği için demokratik meşruiyeti artar.
2. Başkanlık sisteminde, başkanla parlamento çoğunluğunun aynı siyasal partiden gelmemesi durumunda yaşanan çifte meşruiyet sorunu KYBS’nde bu çatışma rejim krizine yol açmaz. Bu krizden erken seçim yoluyla çıkmak mümkündür. Bu seçim kararını devlet başkanı verir.
3. Devlet başkanı sabit bir süre için halk tarafından seçilir ama görevden alınmaz. Ama siyaseten parlamento karşı sorumsuzdur devlet başkanı. Sorumlu olan Başbakan ve Bakanlar Kuruludur. Fransa’da anayasayı ihlal suçu dışında CB’nı görevden almak mümkün değil. CB, 5 yıl için 2 kere en çok seçilebiliyor. Bu da sistemin bir avantajı olarak yürütmenin istikrarlı kanadı olarak kabul ediliyor.
4. Yürütmenin 2 kanadının uzlaşmasına dayalı, bu uzlaşmaya zorlayan bir yönetim biçimidir.
5. Bu iki başlı yapı yürütme içinde bir kişinin mutlak üstünlüğüne izin vermiyor.
6. BK, parlamentonun çoğunluğunun güvenine her zaman muhtaç. Parlamento, dilediği zaman BK’nu veya bir bakanı görevden alma yetkisine sahip. Bu da yürütmede bir esneklik yaratıyor. Devlet başkanı ile uyumlu çalışmakta direnen bir BK yerine daha uyumlu çalışabilecek başka bir BK kuramsal olarak mümkün kılıyor.
7. Başka bir esneklik CB’na parlamentoyu dağıtma yetkisi verme bakımından da geçerli.

Dezavantajları:

1. KYBS’nde, CB ile parlamento çoğunluğu aynı siyasal partiden geliyorsa o zaman anayasada yazılmamış olsa bile fiilen CB’nin tamamen etkisi altına giriyor.
2. Bütün yetkileri tek elde toplayan başkanlık sistemine eğilimi vardır.
3. Anayasa yürütmenin iki kanadının görev ve yetki dağılımını açık bir biçimde yapmadıysa Cohabitation dönemlerinde bu muğlaklık yürütmenin iki kanadı arasında ciddi çatışmalara yol açıyor. Bu hükümet istikrarsızlığına, seçimlerin yenilenmesi gibi bir tercihi CB kullanmıyorsa bir süre sonra rejim istikrarsızlığına yol açabiliyor.

Klasik Başkanlık Sistemi: Bu sistemin en başarılı uygulandığı yer ABD’dir. 1787 Anayasası, dünyada ilk defa bu hükümet sistemini uygulayan anayasadır.

Temel özellikleri: 1. Başkanlık sistemi, sert güçler ayrılığına dayanır. Yarı başkanlık, parlamenter sistem ve türevleri yumuşak güçler ayrılığına dayanır. Sert güçler ayrılığı denince, yasama ve yürütme erklerinin kesin bir biçimde birbirinden ayrılmasıdır. Bunun sonucu ise, ne yasama erki yürütmeyi seçebilir ne yürütme erki

yasama organını seçebilir ne de ikisi birbirinin varlığına karar verebilir. İkisi birbirinden tamamen ayrılmıştır. Yürütme erki tek kişiden oluşur, o da Başkandır. Halk tarafından doğrudan seçilir. Yarı başkanlık sisteminden farklı olarak yürütme başkanlık sisteminde tek kanatlıdır. Yanında bakanlardan oluşan kurul olabilir ancak bu kurul bütünüyle siyaseten başkana karşı sorumludur. Başkan, bakanları atar dilediği zamanda görevden alır. Başkan ve bakanlar yasama organı üyesi olamazlar. Eğer yasama organından bir kişi bakan olarak atandıysa o kişinin yasama organı üyeliği sona erer. Çünkü sert güçler ayrılığında yasama ve yürütme erklerinin birbiriyle herhangi bir ilişkisinin olmaması gerekir. Bunun bir sonucu olarak başkan belli bir süre için seçilir. Bu süre içinde yasama organı tarafından görevden alınamaz. Başkanın tek siyasal sorumluluğu olup ikinci defa seçiliyorsa seçmene karşıdır. DB, yasama organı tarafından görevden alınamıyor. Çünkü ona karşı siyaseten sorumlu olmamasıdır.

Bunun tek istisnası ABD ve diğer başkanlık sistemlerinde görülen **İmpeachment kuralıdır**. Yani başkanın anayasayı ihlal etmesi, çok ciddi bir suç işlediğinin iddia edildiği durumlarda yasama organı tarafından suçlanması ve aynı şekilde görevden alınmasıdır. Başkan 2 defa 4 yıllığına seçilir. Bu kuralda, Temsilciler Meclisi, Başkanı suçluyor ve bu basit çoğunlukla arkasından senato bu suçlamanın haklı olup olmadığına 2/3 oyla karar veriyor. Bir başka sonucu, devlet başkanının da parlamentonu oluşumunun varlığını etkileyecek bir yetkiye sahip olmaması.

Yani; **1.** Devlet başkanının, parlamentoyu dağıtma yetkisi yoktur. Bu sert güçler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmaz. **2.** Klasik Başkanlık Sisteminde devlet başkanının, yasa tasarısı sunma ya da parlamentonun kabul ettiği yasaları referanduma sunma gibi yetkileri yoktur. Sadece veto yetkisi vardır. Bu yasama ile yürütme erkleri arasında denge ve denetleme ilkesinin gerçekleşmesi amacıyla başkana tanınmış bir yetkidir. Veto yetkisini başkan her iki mecliste basit çoğunlukla kabul edilen bu yasayı, veto eder ise bu yasanın aynen kabul edilebilmesi için kongrenin her iki kanadının ayrı ayrı en az 2/3 çoğunluğuyla bu yasayı kabul etmesi gerekir. Bu güçleştirici veto yetkisidir. Bunun tekrar kabul edilmesi uygulamada hiç mümkün değildir. Sert güçler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak klasik başkanlık sistemi denetleme ve dengeleme sistemine dayalıdır. Bunun işleyişi 1.yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında bir anlayış. Bunlara her bir konuya ilişkin bazı yetkiler tanınmıştır. Bu yetkiler aracılığı ile yasama ve yürütme erkleri birbirini denetliyor. Ve birbirlerine karşı aşırı güçlenmesi önlenmiş oluyor. Federal Yüksek Mahkemesi de hem parlamentoyu hem de başkan denetleyebiliyor. Bütün yüksek kamu görevlileri, başkan tarafından atanır ama bunların göreve başlayabilmesi için senato tarafından onaylanması gerekir. Bu şekilde yasama yürütmenin aşırı güçlenmesini bu yetki yoluyla engelleyebiliyor. Bu sistemin iyi işleminin nedeni siyasal partiler sistemi, seçim sistemidir. 2 Büyük siyasal parti vardır. Bu iki parti içinde her türlü eğilim mevcuttur. Bunların arasında derin bir ideoloji söz konusu değildir. ABD’de partiler disiplinli siyasal parti değildirler. Her üye bağımsız olarak karar verebilir. Bunun avantajı, örneğin başkanın partisi kongreden çoğunluğu elde edememişse, gerçekleşmesini istediği her bir gündem bakımından ayrı ayrı ittifaklar kurabilir. Kongrenin her iki kanadında başkanın partisinin çoğunlukta olması istisnai bir durumdur. Başkanlık sisteminin iyi işleyebilmesi için mutlaka parlamento ile başkan arasında bir işbirliği olması zorunluluğu vardır. Federalizmin önemi; o devlette merkezi yönetim federalizm yoluyla sınırlanıyor. Yürütmenin yetkilerinin sınırlanmasının bir nedeni gerçek anlamda güçler ayrılığının olması, yürütme organını denetleyecek bağımsız bir yargı organının olması ve bağımsız bir medyanın olmasıdır. Aynı zamanda eyaletlerin yetkilerinin olduğu ve bunların kullanılabildiği gerçek bir federal devlet mekanizmasının bulunmasıdır.

28.02.2023 **Kısaca hatırlatma:** Başkanlık sistemi sert güçler ayrılığına dayalı sistemdir. Yani yargı erki her zaman bağımsızdır. Yasama ve yürütmenin birbirlerinin oluşumuna ve devamına herhangi bir etkide bulunamaması anlamına gelir. Yani yürütme organı yasama organının içinden çıkmıyor ve ona karşı da siyaseten de sorumlu değil. Bunun gereği olarak yürütme organı yasama organını dağıtamıyor. Yasama organı da yürütme organını impeachment denen istisnai durumlar dışında görevden alamıyor. Yani parlamenter ve Yarı Başkanlık Sistemlerinde gördüğümüz güvensizlik önergesi güven oylaması gibi araçların başkanlık sistemine yabancı olduğunu görüyoruz. Başkanlık sistemi, bu iki erk arasında ayırım gördüğü için yürütme erkinin başkanın yanında yer alan diğer unsurları da (Bakanlar gibi) ne parlamentonun içinden çıkabilir ne de parlamentoya karşı sorumlu olabilir. Parlamento üyesi ise o zaman oradan istifa etmesi gerekir ki başkanlık sisteminde bakan olabilsin.

En temel 2. özelliği yürütmenin tek bir kişiden oluşması, başkandan oluşması. Başkan doğrudan halk tarafından belli bir süre için seçiliyor. Tıpkı parlamento gibi dolayısıyla ikisinin de meşruiyet zemini aynı. Başkan bir bakanlar kurulu atayabilir. Ancak bu parlamenter sistemde gördüğümüz bir bakanlar kurulu değil. Çünkü bu kurulun üyeleri doğrudan başkan tarafından atanıyor ve başkan tarafından görevden alınıyor. Yürütmenin bu unsurları sadece başkana karşı sorumlu. Bunlar da senato tarafından onaylanıyor. 3. Denet denge denen bir sistem üzerine kurulması. Yani yasama yürütme ve yargı erkleri birbirlerine karşı birbirlerini denetlemek amacıyla hazır yetkilere sahip kılınmıştır. Böylelikle bu 3 erkten hiçbirisi diğerine karşı güçlenemez. Her erk diğer erki siyaseten denetleyecek bazı yetkilere sahiptir. Başkanın yasa tasarısı sunma yetkisi yok. Buna karşılık parlamentonun kabul ettiği yasa veto etme yetkisi var. Bu başkanın parlamentonun yasama yetkisini siyaseten denetlemesini sağlayan bir yetki. Bu güçleştirici bir veto yetkisidir. İnpeachment, yetkisi var. Başkanın veto etmediği yasa federal mahkeme denetler. Bunu sonucu, Federal mahkemeye verilen yasaların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi ve anayasaya aykırı gördüğü yasaları da yürürlükten kaldırma yetkisi, yasama organına karşı yargı organına verilmiş bir yetkidir. Eğer bu denge denet sistemi iyi kurulamazsa o sistemlerde başkanlık sisteminin iyi işlemediğini görüyoruz. Bu sistemin iyi işlemesi pek çok unsura bağlıdır. 1. Seçim sisteminin nasıl olduğu 2. Siyasal partilerin nasıl bir sisteme dayandığı. Çok sayıda mı az sayıda mı. O toplumun kültürel yapısı, uzlaşmaya yatkın bir toplum mu. O toplumun siyasal düzeninde ideolojik ayrılıklar keskin mi değil mi. O toplumun genelinde ülkenin genelinde ülkenin ekonomik ve siyasal altyapısı ve düzeni konusunda bir hem fikir halinde olma durumu söz konusu mu. Başkanlık sistemlerinde başkanla parlamento çoğunluğunun işbirliği içinde çalışması gerekir. Bu işbirliğinin gerçekleşemediği bütün örneklerde sistem krize girer. Başkan ve parlamento arasında uzlaşmaya dayalı bir ilişki olmalı ki sistem iyi işlesin.

ABD’de bu işbirliğinin sağlanmasının nedenleri:

1. ABD Kongresinin iki partili bir sisteme dayanması. Parlamentonun her iki kanadının da %90’ dan fazlası bu 2 partinin üyelerinden oluşuyor.
2. Bu 2 parti arasında keskin ideolojik ayrımlar bulunmuyor.
3. Bu partilerde parti disiplini bulunmuyor. Milletvekilleri ve senatörler diledikleri biçimde oy kullanabiliyorlar. Bu da başkanın çıkarmak istediği yasa bakımından farklı çoğunlukları bulabilmesi yani ittifaklar kurabilmesini sağlıyor. Bu durumda son derece uç siyasal politikalar güdememesine neden oluyor.
4. Başkanlık seçimleri dört yılda bir yapılırken aynı zamanda temsilciler meclisinin bütünü seçiliyor ve senatonun toplamının da 1/3’ü için seçim yapılıyor. Parlamento seçileri 2 yılda bir yapılıyor. En çok 2 kez başkan olunabilir. Bütün parlamentonun başkanla bütünüyle birlikte değişmemesi ve 2 yılda bir genel seçimlerin yenilenmesi parlamentoda halkın yeni eğilimlerin yansımaya olanak sağlıyor. Bu durumda başkan bakımından her türlü taleplerini yaşama geçirebilme olanağını, otoriter bir eğilime girmesi bu şekilde sınırlanmış oluyor. Sistemin iyi işlemesini sağlayan bağımsız bir yargının yanında bağımsız medyanın da olmasıdır. Medya, başkanın hesap vermesini sağlayan en önemli araçlardan biridir.

Olumsuz Örnekleri: Latin Amerika ülkelerinin çok büyük kısmında, Afrika ülkelerinin önemli bölümünde ve Orta Asya’da Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerde uygulanan bir sistemdir. Kostarika, Uruguay ve Şili iyi işleyen başkanlık sistemi vardır. Bunların ortak özellikleri 1 Bu 3 ülke küçük ülkelerdir. 2. Etnik, toplumsal olarak daha homojen ülkelerdir.

Latin Amerika Başkanlık Sistemi:

1. Geniş yetkilerle donatılmış bir başkan 2. Zayıf bir parlamento 3. Zayıf bir yargı organı ve 4. Disiplinli, ideolojik siyasal partiler vardır. Parlamentonun 2 partili yapıda olmaması, parçalı bir parlamento yapısı olmaması. Bu durumda başkan anayasal yetkilerini de aşarak ordu gibi kurumlardan destek alarak demokratik yaşamı sonlandırmak yoluna gitti. Başkanın bunu yapamadığı durumlarda bu sefer parlamento başkanının görev süresi dolmadan görevden almaya başladı, inpeachment yoluyla. Bu da siyasal bir istikrarsızlık yarattı. Bunu aşmak için başkanın yetkilerini genişletme yolu seçildi.

Başkana; 1. Kararname çıkarma yetkisi, 2. Başkana parlamentoyu fesih yetkisi 3. Başkana olağanüstü hal yetkileri ve 4. Başkana yasaları halkoyuna sunma yetkisi verildi. Bu yetkiler klasik başkanlık sistemine yabancı olan yetkilerdir. Bu durumda başkan çok güçlü hale geldi. Aynı zamanda yasama ile yürütme arasında olması gereken denge yürütme aleyhine ortadan kalkıyor. Bu durumda da parlamentoda kendisini korumak için girişimlerde bulunuyor ve bir siyasi bunalım ortaya çıkıyor. Bu şekilde sistem iyi işlemiyor.

Bu üç ülkede başkanlık sisteminin iyi işleminin nedeni: Bu ülkelerde koalisyoncu başkanlık vardır. Yani başkanla, 2'den çok partiden oluşan parlamentonun oluşturduğu hükümet sistemi. Bu durumda başkan tıpkı parlamenter sistemde olduğu gibi kendi yasama gündemini parlamentoya kabul ettirebilmek için adeta bir başbakan gibi çalışıyor. Parlamento çoğunluğuyla koalisyon kuruyor. Devlet başkanları seçilirken, başkan yardımcılarını ya da bakanlarını başka siyasal partilerden oluşturur. İkinci olarak başkanın yetkilerini sınırlayan bazı yetkiler anayasaya yerleştirilmiştir. Bazı parlamenter sistem içindeki araçlar bunlar. Parlamentonun bakanları güvensizlik oyu ile düşürmesi durumu. Paraguay, Uruguay, Venezuela'da var. Yine parlamenter sistemlerde olan, hükümete verilen kararname çıkarma yetkisinin bu devlet başkanlarına verilmiştir.

Patronlu Başkanlık Sistemi: Devlet Başkanı, doğrudan halk tarafında seçilen ve çok geniş yetkilerle donatılmıştır. Parlamento başkan karşısında görece zayıf. Başkan devletin ekonomik kaynaklara hakimiyetini kendi kişisel hakimiyeti haline dönüştürmüş ve bu şekilde siyasal bir güç devşirme aracı haline dönüştürüyor. Bu şekilde kendisine bağlı sadık bir elit yaratıyor. İktidara meydan okuyacak bir muhalefet ortaya çıkamıyor. Hiper başkanlık sisteminde, devlet başkanının aşırılaşmış yetkileri olmalı ve başkan tüm gücü elinde bulunduran ve denetlenmeyen seçilmiş krallardır. Parlamentonun denetimi son derece sınırlandırılmış ya da araçlar koşullar son derece zorlaştırılmıştır ki imkansız hale getirilmiştir. Başkanın denetlenmesindeki 2.yol olan yargı son derece zayıftır. Ya da başkanın kendi adamlarını ataması, tehdit ya da bunlara çıkar sağlama gibi yollarla etkisizleştirir. Dolayısıyla etkisi olmayan bir yargı zayıf bir parlamento ve bunların karşısında da aşırı yetkilerle donatılmış bir başkan söz konusu. Eğer başkanın partisi üçden fazla arka arkaya hem başkanlık seçimlerini hem de parlamentonun salt çoğunluğunu elde edince oradan hiper başkanlık sistemi çıkıyor. Bu şekilde partiye de baskın parti diyoruz. Bunun hiper başkanlık sistemine etkisi, iktidar uzun süre el değiştiremediği için yasama çoğunluğunu elinde bulunduran başkanın partisi gönüllü olarak varsa yetkilerini başkana teslim ediyor. Yani hiç sorgulamadan başkanın istediği şekilde hareket ediyor.

Bu sistemin ortaya çıkmasının bir başka nedeni ise, *yanaşmacı siyasal partiler düzenidir*. Yani siyasal sadakat sonucu çıkar dağıtıcı bir yapının olmasıdır. İkincisi başkanın ekonomik kaynakları elinde bulundurması. Üçüncüsü başkanın, milletvekillerinin seçiminde etkili olmasıdır. Bütün milletvekilleri kendi belirliyorsa o zaman bu milletvekillerin siyasal sadakat sonucu başkana karşı gelmesi mümkün değildir. Son olarak anayasa başkana aşırı yetkiler vermiş ve bu yetkilerin denetlenmesi konusunda da başkanın aşırı güçlenmesini önleyecek araç öngörmemiş olmasından dolayı o düzende hiper başkanlık düzeni oluşuyor. Kısaca Hiper Başkanlık sisteminin ortaya çıkma nedenleri: 1. Başkanın partisinin en az üç kez ard arda seçimi tek başına kazanarak "baskın parti" haline gelmesi.

2. Yanaşmacı siyasal parti yapısı 3. Başkanın devletin ekonomik kaynaklarını kullanma tekeline sahip olması 4. Başkanın milletvekili adaylarının belirlenmesinde tekele ya da büyük etkiye sahip olması 5. Anayasada başkanın yetkilerini kötüye kullanmasını önleyecek denetim düzeneklerinin olmaması. Sonuç: Başkanlık sisteminde, parlamento çoğunluğu ile başkanın uyumlu, işbirliği içinde çalışabileceği bir ortamda işleyen bir hükümet sistemidir.

Avantajları: 1. Yürütme erki tek kişiden oluştuğu için çok hızlı bir şekilde hareket edilebiliyor. Olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde bu olağanüstü durumlara karşılık vermek mümkün olabiliyor. Her zaman böyle olmamaktadır.

Dezavantajları: 1. Başkanlık sistemi sıfır toplam bir oyun. Yani kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin de hiçbir şey almadığı bir oyun. Bir kişi başkan seçiliyor. Bütün yürütmenin yetkileri onda olup bu yürütmeyi paylaşmak mümkün değil eğer başkan rıza göstermiyor ise. Parlamento çoğunluğuyla başkan aynı siyasal partiden gelmiyorsa ve işbirliği kanalları da tıkalıysa bu siyasal bir istikrarsızlığa neden oluyor. Peru, başkanlık sisteminin nasıl bir siyasal istikrarsızlığa neden olduğunun en önemli örneğidir.

2. Başkanla, parlamento çoğunluğu anlaşamayınca bu sefer başkan ya anayasa dışı yetkiler kullanmaya yelteniyor. Parlamento çoğunluğu da kendine ait olan yetkileri kötüye kullanmaya çalışıyor. Sürekli olarak Onu çalıştırmak istemediği için İnpeachment silahını kullanıyor.

3. Başkanın, anayasa dışı yollarla yönetme yoluna gitmesi.

Hükümet sistemi ile demokrasi arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Bazı hükümet sistemlerinin daha demokrasiyi, demokratik değerleri korumaya yatkın olduğunu bazılarının ise hiç böyle bir yatkınlığın olmadığına tanık oluyoruz. Freedom House'un her yıl düzenli olarak bütün dünyada demokrasi ölçümü

yapıyor. Buna göre tam demokrasiye sahip 49 ülke var. Bunların yalnızca 6'sı başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bu bize başkanlık sistemi ile demokrasi arasında hatırı sayılır nitelikte ters bir ilişki vardır. Ekonomist dergisinin araştırmasına tam demokratik devlet olan sıralamaya göre ABD 35.sırada. İlk 34 devletin hemen hepsi Finlandiya dışında parlamenter sistemle yönetilen devletler. Türkiye 147. Ülke içinde 137. Sırada bulunuyor.

Türkiye’de Durum:

1876 Anayasasında, anayasanın ilk biçimi parlamentolo bir monarşi. Mutlak bir monarşi halen çünkü padişahın çok geniş yetkileri vardı. Çok kısa bir süre yürürlükte kaldı. 1909 değişikliklerinden sonra Osmanlı devletinin hükümet sistemi, parlamenter monarşiye döndü. Ancak İttihat ve Terakki’nin baskıcı yönetimi içerisinde oldu. Demokratik bir düzenden söz etmek mümkün olmadı. Yürütme erkini elinde tutan padişahın geri planda olduğunu, asıl yetkiler İttihat ve Terakki’de olduğunu biliyoruz. 1921 Anayasası, meclis hükümeti sistemiydi. 1924 Anayasası, güçler birliği ve görevler ayrılığına dayanan bir hükümet sistemi öngörüyordu. 1924 Anayasasında halen güçler birliği ilkesi ilişkisiyle o ilkeye dayalı meclis hükümeti sisteminin etkileri vardı. Artık yürütmenin 2 başlı olduğunu yani Başbakan ve BK olduğunu ve bunun yanında da Başbakan, BK ve CB’nın parlamentodan çıktığını, hükümet kanadının parlamentoya karşı sorumlu olduğunu biliyoruz. Bu anayasa güçler birliği ve görevler ayrılığına dayalı bir hükümet sistemi getirmiştir. 1961 Anayasası, tamamen tam klasik parlamenter demokrasiydi. 1982 anayasasının ilk biçiminin de parlamenter bir demokrasidir. Bu parlamenter demokraside, CB’nın yetkilerini genişletmek yönünde bir ayrıksı durum olduğunu söyleyebiliriz. 2008 Anayasa değişikliği ile CB’nın doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören bir anayasa değişikliği idi. CB’nın, hükümetin, TBMM’nin yetkilerinde ya da kuruluşunda bir değişiklik öngörülmedi. Sadece CB’nın 2 turlu bir seçimle halk tarafından seçilmesi idi. Bu hükümet sistemini başkanlı parlamenter sistem olarak kabul edebiliriz. Neden? CB’nın yetkileri Klasik parlamenter sistemdeki CB’nın yetkilerinden daha geniş yetkilere sahip olmakla birlikte Klasik yarı başkanlık sisteminde öngördüğümüz ölçüde geniş yetkilerle donatılmış bir başkan söz konusu değildi. Bu nedenle başkanlı parlamenter sistem benzeri bir hükümet sisteminin olduğunu kabul edebiliriz. 2017 Anayasa değişiklikleriyle birlikte şimdiki hükümet sistemi için.

Bizim 2017 anayasa değişiklikleri ile gerilen sistemin klasik başkanlık sisteminden ayrılan yönleri:

Klasik başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme birbirinden sert bir şekilde ayrılmıştır. Bizde CB’nın yüce divanı sevk edilebilmesi çok zor olup aynı zamanda oradaki heyeti kendisi seçiyor. Denetleme ve dengeleme sistemimiz işlemiyor. Bizde parlamento ile CB seçimleri birbirine bağlı birlikte yapılmaktadır. CB yardımcılarını atamayla geliyor, halk tarafından seçilmemesi. ABD’de yardımcılar da seçime giriyorlar. ABD’de bütçesi kabul edilmeyen başkan harcama yapamıyor. Kongrenin böyle bir önemli yetkisi vardır. Bizde 1909’dan beri bütçe çıkarma yetkisi parlamentoya verilmişti. 2017’den sonra ilk defa bu haline geldi ve klasik başkanlık sistemlerinde olması gereken yasama ve yürütme organları arasındaki dengeyi yürütme lehine değiştiren bir düzenleme. Klasik Başkanlık sisteminde başkan üst düzey yöneticileri seçiyor ve parlamento bunu onaylıyor. Üst düzey kamu yöneticilerinin, yüksek mahkeme üyelerinin doğrudan CB tarafından seçilmesi, buna karşılık parlamentonun onayına bağlı tutulmaması. Başkanlık sisteminde 2 dönem bizde CB’nın istisnai olarak 3. Dönem seçilebilmesi. Klasik Başkanlık sisteminde başkanın parlamentoyu yenileme yetkisi yok. Bizde CB’nın herhangi bir gerekçe göstermeden TBMM’ni feshedebilmesi. Bunu bir de Latin Amerika’da görüyoruz. Bu sert güçler ayrılığını alt üst eden bir durumdur. Ne yasama yürütmeye müdahale edecek ne de yürütme yasamaya müdahale edecek. Birbirlerinin varlıklarına son veremeyecekler. Oysa bizde sert güçler ayrılığı ilkesine aykırı bir durum söz konusu. CB, parlamento seçimlerini yenileme yetkisine sahip. Biz de federaliz yok ve parlamentomuz tek kanatlı. ABD’de siyasi partilerde parti disiplini bulunmuyor. Bizde siyasi partilerde parti disiplini bulunuyor. 2017 Değişikliği ile bir kararname rejimi vardır 2017 değişikliği ile. Ne tam kanun hükmünde ne değil, ikisinin ortasında bir durum. Bu saf başkanlık sisteminde bulunmamaktadır. Başkanlık sistemi hiçbir şekilde yasa gücünde düzenleme yetkisini başkana tanımıyor, sert güçler ayrılığından dolayı. Bizde meclis soruşturmasının büyük nitelikli çoğunluk aranması, bunun uygulamada imkansız hale getirmesi. Yasama ve yürütme arasında olması gereken dengeyi yürütme erki lehine bozan anayasal düzenlemelerden bir başkası. Bizde Latin Amerika ülkelerindeki uygulamalara benzer uygulamalar bulunmaktadır. Uygulama ve anayasa hükümlerine bir arada baktığımızda Hiper Başkanlık, Patronlu başkanlık sistemini görüyoruz.

Siyasal Sistemler ve Demokrasi: Demokratik devlet ilkesi 1961 anayasası ile anayasamıza girdi. 1982 anayasası da bunu yineliyor. Siyasal sistem içinde liberalizm, sosyal demokrasi, muhafazakarlık gibi ideolojiler yer alır. Anayasacılığın ortaya çıkışında ilk ortaya çıkan yaklaşım liberal yaklaşımdır.

Liberalizm: Topluma ve devleti birey ya da bireyin iradesiyle açıklayan bir yaklaşım. Liberaliz, bireyi en üstün gören anlayıştır. Siyasal liberalizm, devletin kaynağı ve amacını birey olarak gören yaklaşımdır. Devletin kuruluş amacı, birey ve bireyin doğuştan gelen doğal haklarını ve çıkarını korumaktır. Bilimsel liberalizmde, sosyolojik bakımdan birey toplumun temelidir. Birey ve devlet doğrudan iletişim içinde olmalıdır. Ekonomik liberalizm ise, devletin veya başka bir örgütün birey ekonomik faaliyetlerde bireyin faaliyetlerini sınırlamaması temel unsurudur. Bu sebepten bireyin özel mülkiyet hakkı dokunulmaz bir haktır. 1776 ABD bağımsızlık bildirgesi ve 1789 Fransız İYHB ekonomik bakımdan liberal yaklaşımı benimsemiş bildireler. Mülkiyet hakkını dokunulmaz bir hak olarak görmesi bakımından. Ticaret ve çalışma özgürlüğü de buna dahildir. Liberal düşüncenin hedefi, birey özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamak. Araçları, toplum sözleşmesi, doğal haklar, güçler ayrılığı gibi araçlarla devletin iktidarını sınırlamayı amaçlayan yaklaşıma siyasal liberaliz denir. Ekonomik liberaliz ise, ekonomik anlamda bireyin tek aktör olduğu tek söz sahibi olduğu dolayısıyla bireyin ekonomik anlamda devlet ya da başkaca bir sınırlamaya bağlı kalmadan ekonomik faaliyetlerde bulunabilme özgürlüğüdür. Bütün insanlar homoekonomikustur. Yani insan, kendi çıkarını en iyi bilen, o çıkarı doğrultusunda hareket eden bir varlıktır. Devletin müdahalesi doğru değildir. Liberalizme göre kamusal fayda herkesin kişisel kar ve çıkar doğrultusunda hareket etmeleri sonucunda meydana gelecektir. Liberalizm derki genel çıkar kişisel çıkarların toplamıdır. Devlet ekonomik yaşama, aynı zamanda da kişilerin doğuştan sahip oldukları hak ve özgürlükleri gerçekleştirmelerine ve çabalamaların karışmamaktır. Liberalizme göre, kanun önünde eşitlik ilkesi, serbest piyasa ekonomisi ile birlikte adil bir toplumsal düzen yaratacaktır. Devlet müdahale etmezse, kamunun önünde eşitlik ilkesi de benimsenmişse toplumsal bir düzen ortaya çıkacaktır. Ekonomik liberalizmin sonucu jandarma devlettir. Yalnızca devletin adalet ve güvenlikle sınırlı bir şekilde etkinlikte bulunmasına karşılık gelen devlet düzenine denir. Bu yaklaşım ekonomik liberalizmin en temel unsuru. 19. YY anayasacılığı ekonomik ve siyasal liberalizme dayanıyordu. Siyasal liberalizmin, en önemli hukuki araçlarından biri kanun önünde eşitlik ilkesini sağlamak. Liberalizme göre herkes sırf insan olmaktan kaynaklı aynı ahlaki değeri sahiptir. Bunun hukuktaki karşılığı yasa önünde eşitliktir. Yasa önünde eşitlik olan liberal eşitlik, toplumsal ya da ekonomik eşitliği içermiyor. 19.yy'da itibaren kapitalizmin, liberalizmin iddia ettiği gibi kar peşinde koşan bireylerin kişisel çıkarlarının toplamı olmadığı ve kapitalizmin, tekelleşme, oligopolleşme, kartelleşme sonucu ortaya çıktığında kapitalizmin adil bir toplumsal düzen kuramadığı ortaya çıktı. Vahşi kapitalizm, toplumdaki eşitsizlikleri derinleştirdi. Derinleşen toplumsal eşitsizlikler doğuştan sahip olduğu söylenen hak ve özgürlüklerin herkes tarafından eşit biçimde kullanılamaması sonucunu doğurdu. Varlıklı olanlar, doğal haklarını istedikleri gibi kullandılar.

Marksizm: Liberalizmin, kapitalizmin bir kökten eleştirisi olarak başladı. Liberal, siyasal ve ekonomi düzene bir alternatif getirdi, sosyalizm, kominizim biçiminde. Marksizm'e göre liberalizmin söylediğinin tersine insan doğuştan eşit ve özgür değildir. İnsanlar doğuştan eşitsiz yaratılırlar. Herkes aynı olanaklara sahip ailelerde doğmadıkları için. Bu da insanları doğuştan avantajlı, dezavantajlı duruma getirir. Doğuştan bir eşitlik söz konusu değildir. İnsan homoekonomikus değildir ama homofaberdır. Yani insanı ayrıcalıklı kılan insanın üretim gücüdür, emeğidir, insanın çalışan bir varlık olmasıdır. İnsan bu emek gücü sayesinde hem doğayı etkileme kapasitesine sahiptir hem de kendini geliştirme olanağına sahiptir. Marksizm kuramda İnsanın insana bağımlılığı yabancılaşma olarak adlandırılır. İnsan emeği ile var olabilir, doğayı etkileyebilir, temel gereksinimlerini karşılayabilir. Dolayısıyla bunları yapabilmesi için hem kendi emeğinin hem de o emeğin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin efendisi yani sahibi olması gerekir. Oysaki liberal ve kapitalist bir düzende kişinin ne kadar çalışacağına, hangi çalışma koşulları altında çalışacağına, çalışmanın süresine, çalışma sonucunda ortaya çıkardığı ürünün kime nasıl hangi fiyata satılacağına hep kapitalist karar verir. Dolayısıyla artık kişi kendi emeğinin, ürünün de efendisi değildir. O kişi kapitaliste karşı bir bağımlılık içindedir, varlığını sürdürebilmek için. Bu da beraberinde yabancılaşmayı getirir. Marksizmin buna ilişkin çözümü belli kişilerin mülk sahibi olması, belli kişilerin de çok az mülk sahibi olmasıdır. Dolayısıyla bu toplumsal eşitsizliği yaratan mülkiyettir. Haliyle mülkiyetin ortadan kaldırılması sınıfları da beraberinde yok edecektir. Böylelikle herkes eşit bir toplum içinde yaşama olanağını bulacaktır. Marksizm'e göre devlet dediğimiz aygıt sömüren sınıfın aygıtıdır ve sömüren sınıfın çıkarlarını korur. Bu sömüren sınıf burjuva sınıfıdır. Devletin temel rolü böyle bir liberal düzende emekçi sınıfın ayaklanmasını önleyecek baskı araçları oluşturmak ve bunları uygulamaktır. Eşitlik ancak mücadele ile kazanılabilir. Kapitalist düzende herkesin sahip olduğu haklardan yalnızca varlıklılar yararlandığı için gerçek eşitlik ancak ve ancak kanun önünde eşitlikle değil sosyal ve ekonomik

durumu da bireyler arasında eşitlemek yoluyla sağlanabilir. İşte bu da mülkiyetin kaldırılması, üretilen değerlerin eşit olarak paylaşılmasını gerektirir diyor Marksizm.

Marksist yaklaşım özellikle 19.yy'ın 2.yarisından itibaren bütün Avrupa'da etkili bir ideoloji oldu. Bu ideolojinin yanı sıra baskın olan liberal ideolojiydi. 19. YY'da itibaren liberalizmin genel özelliği, bir ölçüde demokrasi ile örtüşmesidir. 1776 ADB bağımsızlık bildirgesi de, 1789 Fransız bildirgesi de demokrasi olgusunu beraberinde getirir. Ama bu demokrasi aksak bir demokrasi. O dönemin demokrasisi, seçim hakkını mülkiyet hakkına bağlayan bir demokrasiydi. Sonuç olarak liberal demokrasi içinde 19.yy'da liberal demokrasinin liberal ayağının baskın olduğunu görüyoruz. 20.Yy'da liberal demokrasinin, demokrasi ayağının geliştiğini görüyoruz. Liberalizmin, vahşi kapitalizm olarak adlandırılan yönünün 19.yy boyunca çok ağırlık taşıdığını, demokrasinin yalnızca varlıklı sınıflara özgülenmiş bir yönetim biçimi haline geldiğini, ama 20.yy'da itibaren bunun geniş kitlelere yayılan bir özellik olduğunu görüyoruz. Özellikle liberalizmin dönüşmesinde ve sosyal demokrasinin ortaya çıkmasında 2 önemli unsurun ağırlık taşıdığını söyleyebiliriz. 1. Marksizmin ortaya çıkması. Rus devrimi ve arkasından Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte Marksizmin, liberalizme karşı gerçek bir alternatif haline dönüşmesi 2. Özellikle 1. Dünya Savaşı içinde ve arkasından 1929 Dünya ekonomik bunalımı ile birlikte saf liberal ekonomik uygulamaların mümkün olamayacağını, devletin ekonomik alana da müdahale etme zorunluluğunun ortaya çıkması liberalizmi de dönüştürdü. Yani sosyal demokrasiyle birlikte.

Sosyal Demokrasi: 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmaya başlayan bir olgudur. İşte 1917'li yıllarda kendini göstermiştir. Sosyal demokrasi, siyasal liberalizmin bütün araçlarını, temel ilkelerini kabul eder. Ancak devletin, kişilerin doğuştan getirdikleri eşitsizlikleri törpüleyecek müdahalelerde bulunması gerektiğini söyler. Kişiler arasındaki eşitsizlikleri azaltmayı ya da ortadan kaldırmayı sağlayacak bir ilke ve araç olmadığı ortaya çıkmıştı. Kanun önünde eşitlik ilkesini sağlayacak bir başka ölçütün olması gerekiyor. O da fırsat eşitliği ilkesi. Yani doğuştan çeşitli nedenlerle, ekonomik, toplumsal nedenlerle eşitsiz bir dünyaya doğan bireylere şans ve olanak eşitliği sağlamak yoluyla ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin bireyler üzerinde yarattığı olumsuzlukları azaltmayı amaçlar sosyal demokrasi. Sosyal demokrasinin en temel ilkesi, herkesin onurlu bir yaşam sürmesi gerektiği ve herkesin bunu hak ettiği anlayışına dayalı bir anlayıştır. Devletin hem toplumsal hem de ekonomik alanda müdahale etmesi gerektiği anlayışına dayalıdır. Sonuç itibarıyla kapitalizmin 19. Yy sonunda ve 20.yy başında tekelleşmesi, ekonomik liberalizm aracılığı ile piyasanın kendiliğinden dengeleneceği ve adil bir toplumsal düzen yaratacağı varsayımını tamamen çürütmesi. Bu çürümenin sonucudur Marksizmin bir ideoloji olarak ortaya çıkmasıdır. Bu çürümenin sonucudur sosyal demokrasinin, liberalizmi devletin ekonomik ve toplumsal yaşama müdahale etmesi gerektiği anlayışıyla yumuşatmasıdır diyebiliriz.

Siyasal Sistemler: Devletin biçimi, niteliği görevleri, ideolojisi hep o toplumdan kaynaklanır. Dolayısıyla devletin toplumla kurduğu sıkı ilişkiler ağına siyasal sistem denir. Bu sistemin içine devletten başka siyasal iş gören kurum ve kuruluş girer. Siyasal partiler, seçmenler, baskı grupları, siyasal iş gören kişi ve kuruluşlar siyasal sistemi belirleyen unsurlardır. Ana sorun yönetim aygıtı ile yönetilenler arasındaki ilişkinin niteliği, nasıl bir ilişki olduğu. Siyasal gücün tek elde toplandığı sistemler **monokrasi** olarak adlandırılır. Örneğin mutlak monarşiler buna örnektir. Ya da totaliter cumhuriyetleri de örnek verebiliriz. Buna karşılık liberal sistemler ise mutlak monarşilerle kesinlikle bağdaşmaz. Meşruti parlamenter sistemlerle ya da parlamenter cumhuriyetlerde görülen sistemdir. Liberal sistem, siyasal gücün toplum içinde olabildiğince dağılmasını getiriyor. Yani siyasal gücün tek elde toplanmamasıdır. Bunun için güçlü bir sivil toplumun kurulması gereklidir. Bunun için belli hak ve özgürlüklerin sağlanması ve güvence altına alınması gerekir. Bunlar, örgütlenme, toplantı, gösteri, ifade, basın özgürlükleri gibi. Basın özgürlüğü, liberal sistemlerde siyasal iktidarın denetlenmesini sağlayan bir rol oynar. Bunun dışında yatay güçler ayrılığında, hükümet sistemleri bakımından yasama ve yürütme erkleri arasındaki ilişki, yargı organının tam olarak bağımsız olması, dikey güçler ayrılığında merkezi yönetimin bazı yetkilerini merkezin dışında ya da altındaki kurum ve kuruluşlara bırakılması (Bu federalizm, özerk üniter devlet ya da bölgesel devlet olabilir) hep bunun ne kadar, nasıl, ne ölçüde yapıldığı o liberal sistemin yelpazenin en ucuna ne ölçüde vardığı ya da varmadığının bize gösterecektir.

Liberal sistemlerden uzak olan iki önemli yönetim biçimi var, **1. Otokrasiler**, otoriter sistemler. Bu sistemler, totaliter sistemlerden daha rengi tonu biraz daha açık olan bir yönetim türüdür. **2. Totaliter sistemler.** Bunun

bir türü olarak da faşizmi söyleyebiliriz. O yelpazenin en koyu türüdür. Bunlar liberal olmayan siyasal sistem biçimleridir.

Otoriter Sistem: 1. Sınırlı fakat sorumlu olmayan bir çoğulculuk anlayışı üzerine kurulmuş olan sistemlerdir. İşlenmiş ve yol gösterici bir ideolojiye sahip değildir. Kendilerine özgü zihniyet yapılarıyla işlerler. Bir ideolojik birlik ya da bütünlük bunları bir arada tutan unsurlardan biri değildir.

2. Gelişimlerinin bazı aşamaları dışında yoğun ve yaygın bir mobilizasyon yaratamazlar. Totaliter sistemlerde bu vardır. Çok büyük törenler yapılır ve buna katılmak zorunludur.

3. En önemli özelliği, bir kişi yani lider ya da küçük bir grubun siyasal iktidarı kullandığı rejimlerdir.

4. Bu rejimler, toplumsal alanda görece bir özgürlük alanı sağlarlar. Totaliter rejimlerde, ekonomi, aile, sanat, bilim, özel yaşam hatta ahlak tamamen tek tipleştirilir. Otoriter rejimlerde, toplumu böyle tek tipleştirecek bir güce sahip değildirler.

5. Otoriter rejimlerde ekonomik ve toplumsal kurumların bir bölümü devletin denetimi altında olmaz. Önemli bir bölümü devletin denetimi altındadır.

6. Otoriter rejimlerde yöneticiler, kendilerini bir ölümlü kişi olarak görürler. Oysa ki totaliter rejimlerde burada baştaki kişi evrene rehberlik eden bir üstün varlık olarak kabul edilir. Dolayısıyla onun kararları hiçbir zaman sorgulanmaz. O olağanüstü yetkilerle donatılmış bir güç, lider olduğu için.

Her rejim bu ikisinin hatta liberal rejimlerin farklı özelliklerini bir arada bulundurabilir. O özelliklerden hangileri ne kadar fazla ise biz o rejime monokrasilere yakın veya liberal rejimlere yakın rejim olarak tanımlarız.

Otoriter rejimde bağlayıcı bir ideolojinin olmadığını söyledik. Bu tür rejimlerin yöneticileri toplumu korku salma veya destekçilerini ödüllendirme biçiminde denetim altında tutarlar. Otoriter rejimlerin tümünde sadakat kazanır. Bu otoriter rejimler geniş bir özel alan bırakır. Bunun nedeni de resmi bir ideolojiye sahip olmadıkları için. Toplumsal örgütlenme de bir ölçüde çoğulculuğa tahammül eder. Yine toplumun tümünü mobilize etme gücüne sahip olmadıklarından görece öngörülebilir yetkilerini kullanırlar. Otoriter rejimlerde, otoriterlik ve denetim toplumdan çok siyasal iktidar ve devlet üzerine bir denetim. Totaliter rejimlerde ise toplum dahil her şey üzerinde. Bir otoriter rejim bununda ötesinde toplumun üzerinde bir denetim kurmaya çalışıyorsa, böyle bir denetimi kısmen başarıyorsa, başardığı ölçüde o rejim totaliter rejim dediğimiz rejim tipine evrilir. Bu otoriter rejimler amaçlarına ulaşmak için toplu kalabalıkları kullanırlar. Halk oylamaları, seçimler hiçbir zaman liberal rejimlerde görüldüğü gibi serbest ve adil bir nitelik taşımaz. Bunlar içinde muhalefet söz konusu olabilir ama bu muhalefet seçimler halk oylamaları, siyasal iktidarın seçimler yoluyla barışçıl yolla el değiştirmesini sağlayacak bir sonuç yaratmaz. Hak ve özgürlükler, otoriter rejimlerde düzenli olarak ihlal edilir. Özellikle negatif statü hakları ihlal edilir. Ama bu diğer hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu sonucunu da doğurmaz Bütün hak ve özgürlükler sistematik bir ihlal altındadır otoriter rejimlerde.

Totaliter Rejimler: Ortak özellikleri: Organizmacı bir devlet anlayışına dayanır. Yani devlet örgütlenmesi bir ulustur. Devlet, örgütlenmiş bir ulustur. Devleti ve ulusu bir bütün olarak gören anlayış. Böyle olunca her şey devlet içinde ve devlet içindir. Hiçbir şey devlete karşı devlete rağmen olamaz. Bu anlayış gereğince devlet dışında toplumsal örgütlenmelere izin verilmez. Devlet, toplum ve bireylerin üzerindedir. Yani totaliter anlayış bireyi ve toplumu zayıflığı, devletin birey ve toplum karşısında güçlü olduğu inancına dayanır. Liberal anlayışın tam zıttı bir anlayış olduğunu söyleyebiliriz. Devlet, toplum üzerindeki egemenliğini hakim siyasal partinin örgütleri ve kendi kurduğu ve denetimi altında tuttuğu toplumsal örgütler aracılığı ile yapar. İdeolojisini, kitlelere bu yolla benimsetir. Sosyal düzenin temelinde, toplum ve bireylerin devlet karşısında güçsüz olduklarına karşı bir ön kabul bulunur. İçindeki siyasal, ekonomik, estetik, etnik, kültürel farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlar. Totaliter rejimler, toplumun hiçbir alanında farklılıkları kabul edebilir rejimler değildir. Bu rejimlerde, bireylerin özel alanları da sınırlıdır. Kişiler buna göre yaşamak zorundadırlar. Devlet ideolojisini gerçekleştirmek amacıyla, kendi güdümü altında toplumsal örgütlenme ve siyasal katılmayı, teşvik eder.

Temel özellikleri:

1. Tek parti rejimleridir. **2.** Bu rejimlerde her zaman bir resmi ideoloji vardır. Bu ideoloji totaliter rejimin türüne göre değişebilir. Ama her totaliter rejimin kendisine özgü bir ideolojisi vardır.

3. Kitlede korku ve çekinme duygusu yaratacak bir terör siyaseti benimsenir.

4. Bütün totaliter rejimlerde devlete, ulusa karşı hayali bir tehdit vardır. Bu dış tehdit, o devletin resmi ideolojisine göre değişebilir. Bu gerçek bir tehdit değildir. Hep bu dış düşmana karşı aktif bir mücadele söz konusudur. Rejime düşmanlarına karşı kini körükleyen bir propaganda söz konusudur.
5. Aynı zamanda bu rejim diğer rejimlerde de görüldüğü gibi rejimin dayanmak istediği toplum kesimini tatmin eder.
6. Bu rejimde tek bir parti vardır ve devlet ile parti bütünleşiktir. Yani bir parti devleti ortaya çıkmıştır.
7. Gizli bir polis teşkilatı bu rejimlerin özelliklerinden birisidir. Bu güvenlik örgütlenmesi partiyi destekleyen ve parti liderleri adına onu denetleyen bir rol üstleniyor. Rejim düşmanlarını bertaraf ediyor.
8. Haberleşme araçlarının tekeli. Amaç, tek tipte düşünmeyi sağlayabilmek.
9. Sadece parti devleti yok. Aynı zamanda devletle toplumun aynı şey olduğuna ilişkin bir inancın söz konusu olduğunu görüyoruz.
10. Bu rejimlerde güçler tek bir merkezde birleşmiştir. Güçler ayrılığı ilkesi bulunmaz.
11. Ekonominin de merkezden yönetimi ve denetimi söz konusudur.
12. Hak ve özgürlüklerden söz etmek söz konusu değildir. Kişilerin bütün yaşamları devletin kontrolü altındadır. Yakın tarihte Çin’de 1949-1976 arası. İkincisi SSCB de 1927-1953 yılına kadar Stalin dönemi. Üçüncüsü Kuzey Kore’de 1948-günümüze kadar gelen dönem.

Faşizm: Totaliter rejimin tarih içinde çıkmış kendine özgü bir örneğidir. Öncelikle İtalya, Almanya ve daha sonra da İspanya’da çıktı. Avrupa’da ortaya çıkan bir düzen.

Ortak özellikleri:

1. Burjuva sınıfının yarattığı düzenlerdir. 2. Burjuvazinin, liberal demokratik düzenin ilkelerini reddeden ve zor ve baskıya dayanan düzenlerdir. Bu düzenler, burjuvazinin gerileme aşamasında ortaya çıkan düzenlerdir.
1. Ekonomik bunalımın baş gösterdiği durumlarda ortaya çıkıyor.
2. Ayrıca işçi sınıfının Marksizmi, komünizmi gerçek bir alternatif olarak ortaya çıkması ve buna ilişkin Marksizmin iktidara geleceğine ilişkin korkuyu ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkmış rejimlerdir. İşçi sınıfı karşısında kendi sınıf egemenliğini taşıyan rejimlerdir.
3. Büyük sermaye tarafından desteklenen rejimlerdir. Köylüler, küçük esnaf, küçük burjuvazi ve bazı işçiler bunu destekliyor. Çünkü ellerinde var olan sermayeyi, sosyalist bir düzenin gelmesiyle kaybetmekten çekiniyorlar. Bu sosyalist tehlikenin ortadan kaldırılması için bu faşist düzene destek veriyorlar. Bu düzenin, demokratik kurumların tam olarak yerleşmediği kökleşmedi toplumlarda daha kolay yeşerdiğini görüyoruz. Yine feodal kurumların yani kilisenin faşizmi desteklediğini görüyoruz. Bunların bir başka özelliği sosyalizm düşmanı olmaları. Aynı zamanda kapitalizm, liberalizm düşmanı. Liberal düzen düşmanlığının altında yatan neden, hem çoğulculuğa hem de farklılıkları tehlikeli görmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Faşist düzen, herkesin her şeyin bir bütün aynı olmasını, aynı inanca uymasını ister. Bu nedenle fasizim, totaliterdir. Her totaliter rejim, faşizm değildir. Faşizm, demokrasi düşmanlığıdır. Faşizm, eşitsiz bir topluma inanır. Yönetimi, üstün ve nitelikli insanlar oluşturmali, niteliksiz insanlar ulusal çıkarları savunamaz. Faşizm de üstün değer, otorite ve disipline bağlılıktır. Ona uymaktır. Bir başka özelliği güce tapınma unsurudur. Güçlü zayıfı her zaman ezer. Bu sadece bir doğa yasası değildir. Toplumda da güçsüz olan bireyler, güçlü olan bireyler tarafından yönetilmelidir. Güçlü ancak şiddet ve savaş yoluyla çıkacaktır. Güçlünün zayıfı yenmesi, zayıfın güçlüye boyun eğmesi kuralı yalnızca toplum içindeki bireyler arasında değil aynı zamanda devletler arasında da geçerli olan bir kuraldır. Faşizm der ki şiddet, savaş güçlüyü ortaya çıkarır, savaş güçlüyü daha güçlü kılar dolayısıyla yapılması gereken bir şeydir. Yine Faşist ideolojiye göre bazı mitlere dayanır. Nazizm, ari ırkın üstünlüğüne, Yahudi ırkını ari ırkı bozacağına inanılır. Gerçek değildir. Bir diğer özelliği faşizmin, tek partiye dayalıdır ve parti ile devlet iç içe geçmiştir. Tek bir kişiye bağlıdır. Bu şefe tapınma söz konusudur. Şef’in buyruğu yasa, kendisi kutsal onu sınırlayan hiçbir kural yok. Bütün kuralların kaynağı da bu şef’tir. Bütün faşist düzenler milliyetçi yani ulusçudur. Kendi uluslarını, diğer uluslara karşı üstünlüğü anlayışı benimsenmiştir. Bu rejimlerde halk oylamaları olabiliyor. Ancak bunlar genellikle bir propaganda aracı olarak kullanıldığını ve liberal demokratik düzenlerdeki gibi bir sonuç yaratmadığını söyleyebiliriz. Bu rejimler korporatif bir ekonomi siyaseti kullanır. İşçi, işveren, teknik eleman ve devlet temsilcilerinin birleştiren bir örgütlenme ve bu örgütlenmeye üyelik zorunlu. Bunların başında da o tek şef var. İtalya 1922-1943 arasında, Almanya 1933-1945 arasında İspanya 1939- 1942 arası tam faşizm, 1942-1955 arası faşizmle çok koyu otoriter bir rejim oldu ama otoriterliği hiçbir zaman ortadan kalkmamakla birlikte 1975 yılına kadar bu rejim devam

etti. Hem İtalya hem de Almanya’da yapılan serbest seçimler sonucunda ortaya çıktı. İspanya’da faşist düzen iç savaşla kuruldu.

Demokratik olmayan rejim tipleriyle bağlantılı 2 tane kavram vardır. Biri diktatörlük diğeri de despotizm’dir. **Diktatörlük** denilince, bir kişinin umulan becerisine dayanan, yasaları ve geleneği hiçe sayan toplumsal bir bunalım ya da devrim sonucunda harekete geçirilmiş geniş kitlelerce desteklenen zorlayıcı iradedir.

Despotizm ise iyice yerleşmiş toplumsal geleneklere bağlı bir hükümdarın ya da temsilcinin şiddete bağlı dayalı yönetimdir. Diktatörlük ile despotizm arasındaki fark, birinde halk desteği vardır diğerkinde ise yoktur. İkisi de aynı ölçüde demokratik değil aynı ölçü de mutlak. Aralarında bir fark yok. Batılı oryantalistlerin, batıdaki mutlak monarşileri, doğudaki mutlak monarşilerden ayırmak amacıyla yapmış oldukları tanımdı. Demokrasi, halkın yönetimi anlamına geliyor. Bir yönetim biçimi olarak ilk kez İÖ. 5.yy’da Herodot tarafından kullanılmış. Günümüzde demokrasiyi, halkın halk için halk tarafından yönetimi olarak tanımlıyor ABD Başkanı Abraham Lincoln. Özellikle 2.Dünya Savaşında demokratik güçler karşısında faşist güçlerin yenilmesi sonucunda pek çok devlet yeni anayasalar yaptılar. Bu anayasalarında demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak benimsediler. 1989’da Doğu bloğunun çökmesiyle birlikte, bağımsızlıklarını kazanan bu bloğun üyeleri demokrasiye yöneldiler. 2010’lu yıllara kadar demokrasiyle yönetilen ülkelerin sayısı yönetilmeyenlerden daha çok sayıya geldi. Bu tarihten sonra bu süreç tersine döndü. Demokrasiyle yönetilen ülkelerin otoriter yönetimlere evrildiğini görüyoruz. Bugün için en iyi yönetimin, demokrasi olduğu yanıtını veriyoruz. Gerçekten de bireyin, kişinin özgürce yaşamasını sağlayan, mevcutlar içinde en uygun demokratik rejim demokrasi olduğu için. Yalnız demokrasinin genel niteliğine dair genel bir kabul yoktur. Günümüzde demokrasi, çok boyutlu bir kavramdır. Hem bir yönetim biçimini, yaşam, karar alma sürecini, değerler kümesini ifade eden bir kavramdır. Tarihteki en önemli örnek 2500 yıl önceye dayanan Atina sitesidir. Günümüzdeki demokrasi anlayışından farklı olarak, yurttaşların doğrudan karar alma sürecine katıldığı yani seçme ve seçilme hakkına sahip olan yurttaşların bütününi sitenin meclisini oluşturuyordu, meclis kararlar alıyordu. Bu kararları uygulayacak kurul yine yurttaşlardan oluşuyordu. Bu kararlar sonucunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözecek mahkemeler yine yurttaşlardan oluşuyordu. Bu demokrasi günümüzden farklıdır. Çünkü birinci olarak Atina, coğrafi olarak, demografik olarak küçük bir siteydi. Seçme ve seçilme hakkına sahip olan yalnızca yurttaşlardı. Yurttaş olabilmek için kadın, köleler ve yabancıların seçme ve seçilme hakları yoktu. 30 Bin kişiden oluşan sitede toplam 6 bin kişi seçme ve seçilme hakkına sahip olabiliyordu. Bu da herkesin birbirini tanıdığı, yüz yüze ilişkilerin olduğu bir toplumu meydana getiriyordu. Yüz yüze ilişkiye dayalı bir toplumun özelliği ideolojik ve sınıfsal çelişkilerin bugüne göre daha az çatışmacı bir süreçte yaşanmasını sağlamaktadır. Atina toplumunun ikinci özelliği türdeş bir toplum olması. Bu toplum köken, din, dil, kültür olarak aynı kişilerden oluşuyordu. Atina’da özgür olmak demek belli bir sitenin yurttaşı olmak anlamına geliyordu. Haliyle nüfusun çoğunluğunu oluşturan kadınlar, yabancılar, köleler siyasal haklardan yoksundu. Atina ekonomisi köle ekonomisine dayanıyordu. Demokrasi de aslında kölelik kurumundan kaynaklanan bir demokrasiydi. Kölecü üretici biçimi olmasaydı yurttaşların siyasal etkinlikleri yürütmeye zamanları olmazdı. Günümüz demokrasileri Antik Atina demokrasi anlayışının hiçbir özelliğini taşıyor.

7 Mart 2023

Antik Yunan kentinde, yurttaş denilen kitle son derece küçük bir kitle dolayısıyla yüz yüze ilişkilerin olduğu bir kitle. Bu yüz yüze ilişkilerin olduğu toplumlar daha az sınıfsal çatışmaların olduğu toplumsal yapılardır. Toplum türdeş yani köken, dil, din, kültür anlamında bir türdeşliğin olduğunu görüyoruz. Bu tür toplumlarda doğrudan demokrasinin daha doğru bir şekilde işlediğini söylüyoruz. 18.YY’da demokrasi olgusu yeniden keşfedildi. 18.YY sonlarında Kuzey Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da uygulanan bir devlet yönetimi haline geldi. Antik Yunan ile o zamanki demokrasi arasında çeşitli farklar açığa çıktı. Bunu sebebi, toplumun ekonomi biçiminin değişmesinden kaynaklanan farklar. 18.YY’a geldiğimizde devletler artık ulus devlet biçiminde örgütlenmeye başladılar. Ulus devlet türdeşleştirici bir rol oynuyordu. Bu yeni bir sınıfın ortaya çıkması ve bu üretim biçiminin değişmesiyle kendini gösteren bir değişiklik. Üretim biçimi ticarete ve sanayiye dayanan bir üretim biçimi oldu. Antik demokrasi kanun önünde eşitlik ilkesine dayalı bir demokrasi değildi. Çok küçük bir yurttaşın katılımına dayalı idi. Eksik bir demokrasi olup, sitede yaşayan herkes oy kullanma ve karar alma sürecine katılan bir anlayışa dayalı bir demokrasi değildi.

Çağdaş demokrasiyi etkileyen unsurlar:

1. 18.YY’da itibaren demokrasi anlayışı temsili demokrasi anlayışına dayandı. Temsili demokrasi, yurttaşların, seçmenleri aracılığı ile belli bir dönem için kendilerini yönetecek kişileri seçtiği sistem.
2. Fransız devrimi ile başlayan ve aşama aşama gelen cumhuriyetçi gelenek anlayışı.

3. Yeni bir sınıfın talebi doğrultusunda bu yeni demokrasi anlayışı ortaya çıktığı için o sınıfın araçlarının egemen olduğu bir anlayış. O da güçler ayrılığı ilkesi.

4. Seçme ve seçilme yetkisinin ve genel oy ilkesi tarihsel olarak çok daha yeni bir döneme karşılık gelir.

5. Hem ekonomik hem de siyasal liberalizm. Bu çerçevede oluşan bir yönetim anlayışının olduğunu görüyoruz.

6. Yeni sınıfın bir başka aracı, 18.YY'da uygulanmaya başlanan çağdaş demokrasi aynı zamanda doğal hukuk doğal haklar anlayışıdır. Son olarak bu demokrasinin en önemli özelliklerinden birisi laiklik ilkesidir. Laik bir düzenin olmadığı yerde demokrasi işlemez. Çağdaş demokrasi, laik düzene dayalı bir demokrasidir. Temsili demokrasi anlayışı pasif bir yurttaşlık varsayımına dayalıdır. Pasif yurttaş, seçimlerde kendi temsilcilerine oy vermek suretiyle siyasal sürece katılır. Bunun dışında siyasal sürece katılması mümkün değildir. Karar alma yetkisi, seçimler sonucunda belirlenmiş siyasal seçkinlere aittir. Yurttaşın bunun haricinde karar alma sürecine katılması mümkün değildir.

Pasif yurttaşlık anlayışı zamanla dönüşüyor. 1. Özellikle yerel yönetimler düzeyinde doğrudan demokrasinin uygulandığı örnekler görüyoruz.

Günümüzde buna örnek, 1. İsviçre, 3 kanton var. Bu kantonlar doğrudan demokrasi yöntemiyle yönetiliyorlar.

1. Her yıl mayıs ayında kanton meclisi, o kantonun meydanında toplanıyor. Yürütme işini yapacak yürütme kantonunu seçiyor.

2. Yürütme kurulunun hazırladığı düzenleyici işlemleri ya da yasa tasarılarını onaylıyor. Antik Yunan demokrasisine benzediğini görüyoruz.

2. Örnek ABD'de bazı eyaletlerde ve aynı zamanda yerel yönetimler düzeyinde doğrudan demokrasi uygulamasının olduğunu görüyoruz. Bunları dışında artık ulusal düzeyde çağdaş günümüz demokrasilerinin doğrudan bir demokrasi örneği olmadığını söyleyebiliriz. Bu temsili demokrasi, temsili vekalet ilkesine dayanıyor. 1789 Devrimi ile bu temsili vekalet ilkesi ortaya çıkıyor. Temsilciler, kendilerini seçen seçmenlerin değil bütün ulusun temsilcisidirler. Buna göre temsilciler oy vermek yoluyla belli bir süre için kendi adlarına ülkeyi yönetme vekaletini belli bir temsilcilere bırakırlar. Seçmenin verdiği bu vekalet, o vekilin kişiliğine verilmiş bir vekalet değildir. Dolayısıyla her vekil kendisini seçen seçmenlerin değil bir bütün olarak ulusu temsil eder. Haliyle temsil yetkisi de tek tek temsilcilerden çok bu temsilcilerden oluşan parlamentoya verilmiş bir yetkidir. Temsilci, seçmene karşı tamamen bağımsızdır. Seçimler sırasında verdiği sözleri tutmak zorunda değildir. Haliyle kendisine belli bir dönem için verilmiş temsil yetkisi seçmen tarafından bu gerekçeyle bu süre içerisinde geri alamaz. Temsilci seçildiği zaman o görevde kalır. Kendisini seçenlerin de talepleriyle bağlı değildir. Çünkü onları temsil etmez kural olarak bütün ülkeyi temsil eder. Temsili vekalet ilkesinin temel özelliği budur. Buna karşılık zamanla 20. yy'dan itibaren pasif yurttaşlık anlayışına dayalı bir yönetim biçimi değil. Aynı zamanda yurttaşın karar alma süreçlerine seçimlerin dışında bazı başka araçlarla da katılabilmesini sağlayan bir yönetim biçimidir. Yurttaşın, seçimler dışında karar alma sürecine katılmasını sağlayan bu yöntem doğrudan demokrasi yöntemi diyoruz. Yurttaşın sadece seçimler yoluyla temsilcileri seçmek yoluyla karar alma sürecine katılması değil aynı zamanda ortaya konacak başka bazı araçlarla belli konularda karar vermesini sağlayan bir yönetim biçimidir.

Yarı doğrudan demokrasi aracı dediğimizde;

1. Halk oylaması: yarı doğrudan bir demokrasi aracı olarak, 19.yy'da itibaren kullanılmış araçlardır. Belli bir konuda halkın görüşünü almak amacıyla yapılan oylamalara halk oylaması denir. Bunu ilk defa ulusal düzeyde uygulayan kişi Napolyon'dur. Daha sonra en kötü uygulayıcılardan biri de Hitler'dir. Her ikisi de bu halk oylamalarını kendi rejimlerini meşrulaştırmak amacıyla kötüye kullanan 2 örnektir. Halk oylamaları konuları itibariyle 3'e ayrılır. *Kurucu halk oylaması, yasama halk oylaması ve uluslararası halk oylamasıdır.*

Kurucu halk oylaması: Anayasa değişikliğine ilişkin oylamaya verilen isimdir.

Yasama oylaması ise bir parlamento tarafında kabul edilmiş olan bir yasanın yürürlüğe girip girmemesine ilişkin yapılan oylamadır.

Uluslararası oylama ise, diplomatik bir anlaşma ya da sözleşmenin iç hukukta yürürlüğe girmesi bakımından yapılan oylamaya verilen isimdir.

Halk oylamaları, isteğe bağlı ya da zorunlu olabilir. Günümüzde bazı devletler anayasa değişikliğine ilişkin yasaların zorunlu olarak halk oylamasına sunulmasını öngörür. Bunlar içinde İrlanda'yı verebiliriz. Yine bizim anayasamızın 174.md'nde CB tarafından geri gönderilen ve TBMM tarafından üye tam sayısının 3/5 ile 2/3 arasında bir çoğunlukla aynen kabul edilen anayasa değişikliği kanununu CB halk oylamasına sunmak zorundadır. Bizde de belli koşullar altında zorunlu olarak anayasa değişikliğine ilişkin yasaların halk oyuna

sunulması söz konusu oluyor. Bazı devletlerde halk oylamaları, yürütme ya da yasama organının takdirine bırakılmıştır. En çarpıcı örneği Birleşik Krallık'tır. Orada halk oylamaları, hükümetin takdir yetkisi içinde olan oylamalardır. 2016 yılındaki halk oylamasında Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkılmamasına ilişkin oylamaydı. Bunlar zorunlu olan oylamalar değildi. Yalnızca yürütme organı istediği zaman uygun gördüğü biçimde karar verdiği oylamalardır. Yine halk oylamaları sonuçları itibarıyla ikiye ayrılırlar. Bazı halk oylamaları sonucu ne olursa olsun yürütme organının, halk oylamasının sonucuna uymak zorunda olmadığı oylamalardır. Yürütme organı belli bir konuya ilişkin olarak seçmenlerin eğilimini ya da genel olarak kararını görmek isteyebilir. 1975 ve 2016 Yıllarına ait halk oylamaları bu nitelikte olan oylamalardır. Günümüzde halk oylaması yapılmasına karar veren bir yönetimin halk oylaması sonucunu göz ardı etmesi düşünülemez. Bu o yönetim bakımından siyasal bir sorumluluk ortaya çıkaracaktır. İkinci olarak halk oylaması sonucunun yürütme organı bakımından bağlayıcı olduğu oylamalardır.

Halk oylaması ile plebisiti birbirinden ayıran birkaç unsur vardır. Bütün seçmenlerin belli bir konuda oy kullandığı oylamalar halk oylamalarıdır. Ancak bu halk oylamalarının sahip olduğu bazı nitelikler bu oylamaları, plebisit haline dönüştürüyor. Örneğin yürütme organının halk oylaması sırasında oylamanın sonucunu etkileyecek biçimde aşırı ve tek yanlı bir kampanya yürüttüğü kampanyalar plebisit olarak adlandırılır. Karşı propagandanın yasak olduğu ya da buna izin verilmekle birlikte yürütme organının kendi otoritesini yine ağırlıklı bir şekilde sonucu etkileyecek bir şekilde kabulden yana koyduğu oylamalar plebisit oylamalardır. İleride 1961-82 anayasalarının yapım sürecinde yapılan oylamaların halk oylaması mı yoksa plebisit oylaması mı olduğunu göreceğiz. Bugün yeni bir anayasanın yapılması ve anayasada değişiklik yapılması pek çok anayasada halk oylamasına sunulma şartını da içeriyor. Bugün en çok kullanılan yarı doğrudan demokrasi aracının halk oylaması olduğunu söyleyebiliriz.

Halkın kanun teklifi ya da halk girişimi demek, belli sayıda seçmenin belli bir kanunun oylamaya sunulması ya da belli bir kanunun hazırlanıp kabul edilmesi konusunda yapmış olduğu girişime verilen isimdir. Halk girişimi, tasarılı ya da tasarısız biçimde olabilir. Tasarılı halk girişimi, belli sayıda seçmenin bütün maddeleri ile somut bir şekilde bir kanun teklifi hazırlamasına verilen isimdir. Tasarısız halk girişimi ise, belli sayıdaki seçmenin belli bir konuda kanun çıkarılması yönünde yapmış olduğu girişimdir. Belli bir konuda kanun yapılması istenir. Ancak bu kanun madde madde seçmenler tarafından ortaya konmaz. Halk girişiminde 3 farklı yol benimsenebilir. 1. Seçmenlerin sunduğu tasarılı ya da tasarısız yasa teklifi parlamentoda görüşülür. Son şeklini alır. Ayrıca halk oylamasına sunulmaz. Bu halk girişiminin birinci yoludur.

İkinci Yol ise seçmenlerin hazırladığı teklif parlamentonun bir müdahalesi olmadan doğrudan halk oylamasına sunulur.

Üçüncü yolda ise halkın sunduğu tasarılı ya da tasarısız teklif parlamentoda görüşülür. Kabul edilir aynı zamanda daha sonradan halk oylamasına sunulur. Eğer halk girişimi tasarısız bir girişim ise bunun parlamentoda bir kanun halin getirilmesi yani maddelenmesi, içeriğinin belirlenmesi gerekir. Her durumda demek ki bir yasa teklifini belli sayıdaki seçmenin sunma yetkisi söz konusu oluyor.

Halk Vetosu: Parlamento tarafından kabul edilmiş bir yasanın yürürlüğe girip girmemesi konusunda yapılacak olan halk oylamasına verilen isimdir. Parlamentoda belli bir kanunun yapılmasına ilişkin seçmen müdahalesi söz konusu değildir. Bu parlamento asli yasama işlemini görür. Ancak bu kanunun yürürlüğe girip girmemesi halk vetosunda belli sayıdaki seçmenin toplayacağı imza ile halk oylamasına sunulur.

Son olarak **Geri Çağırma:** yarı doğrudan demokrasi aracı. Bunun anlamı, genel seçimler yoluyla belli bir makama seçilmiş bir kişinin görev süresi dolmadan yapılacak bir oylamayla görevden alınmasına verilen isimdir. Bu başka bir şekilde de olabilir. Atama ile belli bir göreve gelmiş olan kamu görevlisinin görev süresi dolmadan o göreve devam edip etmeyeceğine yine yapılacak bir oylama ile benimsenmesine **geri çağırma ya da emredici vekalet** denir. Bu özellikle ABD'de eyaletler üzerinde uygulanan bir yöntem. Özellikle Kaliforniya eyaleti bu konuda çarpıcı örnekler veriyor. ABD'de seçimle gelmiş kişinin yerine görevden alınması durumunda kimin bu göreve geleceğinin belirlenmesi gerekiyor.

Kollektif Azil: İsviçre'de federe devletler düzeyinde, bazı kantonlarda kollektif azil kurumunun işlediğini görüyoruz. Bu da bir geri çağırmadır. Yani kanton yasama organlarının o kantonda yapılan bir oylamayla topluca görevden uzaklaştırılmasına verilen isim. Yani yasama organına yönelik bir geri çağırma. Ulusal düzeyde ise Venezuela'da halk oylaması ile başa gelen devlet başkanının geri çağırma yönteminin anayasa ile benimsendiğini görüyoruz. Chavez dönemin de buna ilişkin girişimler oldu. Ulusal düzeyde yürütme organının görevden uzaklaştırılması bakımından emredici vekalet ilkesinin uygulandığı bir örnektir. Günümüzde, yarı

doğrudan demokrasi araçlarıyla seçmenlerin siyasal karar alma süreçlerine seçimlerin dışında da katılmasının olanakları sağlanmıştır. İtalya, İspanya gibi ülkelerin anayasalarında halk girişiminin tanındığını görüyoruz. Bu bakımdan 19. Yy demokrasi anlayışından farklılık olduğunu görüyoruz. Türkiye’de her zaman anayasalar bu yarı demokrasi araçlarına mesafeli kaldılar. 1982 Anayasası’na kadar herhangi bir yarı doğrudan demokrasi aracının yer almadığını görüyoruz. 1961 Anayasası için yapılan halk oylaması bunun istisnası ama bunun dışında olağan dönemlerde bu araçlar yoluyla halkın karar alma sürecine katılması öngörülmedi. 1982 Anayasası son derece sınırlı bir biçimde anayasa değişikliğine ilişkin olarak kanunlar sınırlı olarak ve belli şartların gerçekleşmesi durumunda halk oylamasını mümkün kılıyor. Bunun dışında halk oylamalarının ya da diğer yarı doğrudan demokrasi araçlarının yer almadığını görüyoruz. Yarı doğrudan demokrasi araçları, yurttaşın siyasal karar alma sürecine seçimler dışında da katılmasını sağlaması bakımından önemli araçlar olarak kabul ediliyor. Buna karşılık bu araçların olumsuz yönü; belirli gruplar tarafından manüple edilmesine son derece elverişli olmalarıdır. Bu manüplasyonu otoriter rejimlerde de görüyoruz. Özellikle halk oylamalarının bütün otoriter rejimlerde kullanılan en önemli meşrulaştırma aracı olduğunu belirtelim.

Saddam Hüseyin zamanında da Irak’ta halk oylamaları yapıldı. Bütün yarı doğrudan demokrasi araçlarının oylamalarında serbest ve adil oylamalar olması gerekiyor. Yani demokratik seçimler için aranan bütün koşulların bu yarı doğrudan demokrasi araçlarının uygulanmasında da olması gerekmektedir. Bu adil ve serbest seçimler, ifade, toplantı, dolaşım, örgütlenme basın özgürlüklerinin tam olarak sağlandığı düzenler. Bu düzenler yoksa o zaman bu yarı doğrudan demokrasi araçları ancak yönetimlerin kendilerini meşrulaştıracığı aslında seçmenin karar alma sürecine katılmadığı araçlardır. Seçmenler günümüzde sadece seçimler ve varsa yarı doğrudan demokrasi araçları koluyla da katılmazlar. Aynı zamanda sivil toplum yoluyla yurttaşlar karar alma süreçlerine katılabilirler. Siyasal kararların nasıl, ne şekilde alındığı demokrasinin biçimin belirler.

Çağdaş demokrasilerde ikili bir ayırım yapılır. Çoğunlukçu ve Çoğulcu demokrasi ayırımı.

Çoğunlukçu demokraside, genel seçiler parlamentoyu belirlerler. Parlamentodaki çoğunluk ulusu temsil eder. Haliyle çoğunluğun iradesi sınırlanamaz. Çünkü çoğunluğun iradesini sınırlamaya yönelik herhangi bir önlem aynı zamanda ulusun iradesini sınırlamak anlamı taşır. Ulusun iradesi de demokratik bir düzende sınırlanmaması gereken bir irade olarak kabul edilir. Yani belli bir seçimde oy kullanmış seçmenlerin belirlediği parlamentodaki çoğunluğun ulusal irade olarak kabul edilmesi haliyle ulusu temsil ettiği ileri sürülen parlamento çoğunluğunun da herhangi bir araçla sınırlanmasının söz konusu olmaması. Bu anlayışın sonucunda çoğunlukçu demokrasi anlayışında azınlık haklarına herhangi bir güvence getirmez. Bu demokrasi anlayışı çoğunluk despotizmine yönelebilecek bir anlayıştır. Çünkü belli bir dönem için parlamentoda çoğunluğu elde etmiş bir siyasal parti ya da partiler kendilerini ulus ve ulusun iradesinin tek temsilcisi olarak gördüğü için kendilerine yönelik herhangi bir sınırlamayı da ulusa yönelik bir sınırlama olarak kabul eder. Bu nedenle anayasa yargısı veya yargı organı gibi herhangi bir sınırlama çoğunlukçu demokrasi anlayışına yabancıdır.

Çoğulcu demokrasi: Bu anlayış, çoğunlukçu demokrasi anlayışının tam tersini ifade eder. Öncelikle azınlık haklarını güvence altına alır. Karar alma sürecine katılımına açıktır ve parlamento da seçimler sonucunda çoğunluğu elde etmiş siyasal parti ya da partileri ulus ya da ulusal iradeyle özdeş kabul etmez. Çünkü çoğulcu demokrasi anlayışında parlamentonun bütünü ulusu oluşturur. Çağdaş toplumlar farklı topluluklardan oluşuyor olup türdeş değildir. Bu heterojenliği parlamentolarına da yansıtır. Haliyle ulus, hem parlamento çoğunluğunu oluşturan siyasal partiler tarafından hem de azınlıkta kalan muhalefet partileri tarafından temsil edilir. Bu temsil bütündür. Çoğulcu demokrasi, içinde ikiye ayrılır.

Birincisi rekabetçi, yarışmacı ya da çoğunluk demokrasisi olarak adlandırılır. Bu çoğulcu demokrasinin bir biçimidir.

İkinci biçimi ise, ortaklaşmacı, konsensüs ya da çoğulcu demokrasi diye adlandırılan demokrasi biçimidir. Ulus devletlerin heterojen bir yapı içerisinde olduğunu görüyoruz. 20 Yy’da sınıfsal farklılıkların yanına toplumsal çeşitlilikler eklendi. Rekabetçi, yarışmacı ya da çoğunluk demokrasisi dediğimiz demokrasi biçimi siyasal karar alma süreçlerinde çoğunluk iradesine üstünlük tanıyan demokrasi modellerine verilen isim. Bu modeller genellikle sosyo-ekonomik bölünmelerin temel farklılaşma olduğu ülkelerde kendini gösteriyor. Sosyo-ekonomik bölünmelerden kast edilen sınıfsal çatışmadır. Yani toplum diğer bakımlardan görece türdeş bir görüntü sergiliyor. Temel çatışmanın sınıfsal olduğu yerlerde bu rekabetçi demokrasinin olduğunu görüyoruz. Ortaklaşmacı, konsensüs ya da çoğulcu demokrasi modelleri ise karar alma süreçlerinde

toplumu oluşturan belli başlı tüm kesimlerin o uzlaşmaya ortaya koyduğu iradeye üstünlük tanıyan demokrasi modelidir. Bu demokrasi modelinin görüldüğü toplumlar yalnızca sınıfsal çatışmaya dayanmıyor aynı zamanda etnik kültürel inançsal gibi diğer bakımlardan da farklılıklar içeriyor. Bu ikili yapı çoğulcu ve çoğunlukçu demokrasi anlayışlarıyla örtüşmüyor. Bu 2 demokrasi biçimi de çoğunlukçu demokrasi değil. Bunun her ikisi de çoğulcu demokrasi. Ama bu karar alma süreçlerine kimin nasıl katılacağına ilişkin bir farklılığa dayanıyor. Rekabetçi demokraside karar alma süreçlerinde ortaya çıkan iradeyi çoğunluk belirliyor. **Ortaklaşmacı demokrasi ya da konsensüs demokrasisinde** ise olabildiği kadar çok kişinin uzlaştığı irade belirliyor. Her ikisi de temel hak ve özgürlükleri koruyor. Her ikisi de azınlıkların hak ve özgürlüklerini koruyan bir yaklaşımı benimsiyor. Yurttaş karar alma süreçlerine yalnızca seçimler yoluyla katılmıyor. Aynı zamanda sivil toplum örgütleri aracılığıyla da katılıyor. Yani sendikalar, dernekler, meslek kuruluşları, yardım kurumları gibi toplum içinde örgütlenmiş kurum ve kuruluşları anlıyoruz. Bu bakımdan katılımcı demokrasi anlayışı yurttaşın olabildiği kadar çok ve farklı araçla siyasal karar alma sürecini etkilemesi gerektiğine dayalı bir kuram. Katılımcı kurama göre, toplumsal yaşam aşırı eşitsizlikler üzerine kuruluyor. Aşırı eşitsizliklere dayalı toplum aynı zamanda siyaseti de etkiliyor. Dolayısıyla 3-5 yılda bir sandığa gitmek genel ve eşit oy ilkelerini tanımak, törpülemek için yeterli değil. Çünkü ekonomik üstünlüğü elinde bulunduran gruplar siyasal kararları alınmasını büyük ölçüde belirliyor. Toplumsal yapının çoğulcu olması taleplerini siyasal iktidara duyurmak bakımından her zaman kolaylık, geniş imkan sağlamıyor. Mevcut çoğulculuk güçlülerin çoğulculuğu oluyor. Örgütlenmemiş kesimler, yoksul halk kesimleri bu toplumsal yapı içerisinde siyasal iktidara seslerini duyuramıyorlar. Yurttaşın, aynı zamanda sivil toplum örgütleri yoluyla katılması gerekli ancak bu yeterli değil. Bu kuramın karşısında olan demokratik seçkincilik kuramı da diyor ki siyasal katılım her zaman öyle çok istenen bir şey değildir. Siyasal katılımı öyle aşırılaştırmamak gerekir. Neden?

1. Siyasal katılımın artırılması gereksizdir. Çünkü yurttaş hem sivil toplum örgütleri hem de seçimlerde oy kullanmak yoluyla siyasal karar alma süreçlerine etki eder. 2. Yaygın katılımı demokrasinin istikrarı açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilecek olması. Doğrudan demokrasi araçlarının sık kullanılması yoluyla geniş halk kitlelerinin otoriter eğilimlere sahip olması ya da irrasyonel tahriklere açık olması nedeniyle bu tür daha yaygın katılım araçlarının benimsenmesi demokratik rejimin varlığını tehlikeye düşürebilir. 3. Sanayii ve sanayii ötesi toplumlar aşırı düzeyde katılıma dayanamazlar. Neden? Çünkü her yeni katılım biçimi karar alma sürecini yavaşlatır. Oysaki günümüz toplumları son derece hızlı karar almayı gerektiren pek çok konuyu içinde barındırıyor. Aynı zamanda ekonomi, dış politika ya da ulusal savunma gibi konular öyle yurttaşın çeşitli yollarla katılımına açık meseleler değil. Bunların belli bir ama toplumsal alanda da gerçekleştirilmesi siyasal seçkinler tarafından alınması bu kararların çoğunluğunun konuların niteliği gereğince gizli alınması dolayısıyla dar bir seçkin kadro tarafından oluşturulmasını gerekli kılar. Bu alanlar katılıma kapalı olan alanlardır diyor demokratik seçkincilik taraftarları. Katılımcı demokrasinin ileri sürdüğü görüş, katılımın yalnızca siyasal alan değil aynı zamanda toplumsal yaşamın her alanında etkili olması anlayışıdır. Bireyler kendi çıkarlarını ancak ve ancak bu yolla koruyabilirler. Yurttaş demokrasiyi nasıl içselleştirecek, demokrasi dediğimiz karar alma sürecine katılım yollarının yalnızca siyasal alanda değil ama toplumsal alanda da gerçekleştirilmesi yoluyla yani en küçük yurttaşın içine doğduğu kendi kişiliğini geliştirdiği aileden itibaren aile, okul işyeri eğer sivil toplum örgütüne üye ise o sivil toplum örgütünde herhangi bir demokrasi ya da demokratik bir yönetim karar alma süreci yaşamıyorsa o kişinin ülke düzeyinde demokratik rejimi savunması o rejimin neferi olması da beklemez diyor katılımcı demokrasiyi savunanlar. Bunun için katılımın mutlaka aileden itibaren aile, okul sendika, dinsel kuruluşlar siyasal partiler gibi bütün sivil toplum örgütlerine yerleşmiş bir yönetim anlayışı olması gerekiyor. Özellikle katılımcı anlayışın siyasal iktidara yakın olan siyasal partiler sendikalar gibi sivil toplum örgütleri bakımından olmazsa olmaz olduğunun altını çizelim. Bunun yanında siyasal iktidara uzak duran aile, okul işyerinde de mutlaka siyasal katılıma kişinin o kurumun o örgütün karar alma sürecine katılmasını sağlayacak araçların öngörülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde demokratik bir düzenin devamı o düzenin savunucusu seçmenler olacaktır diyor demokratik katılım ya da katılımcı demokrasi kuramının savunucuları.

Bir rejimi demokratik saymak için kuşkusuz ki olmazsa olmaz birtakım unsurları arıyoruz.

Bu unsurlar 1. Parlamento seçimlerinin, belli aralıklarla yapılan seçimler olması. Seçimlerin, görüntüde yapılması yeterli değil. Bu seçimlere ilişkin olarak belli koşulların sağlanmış olması gerekiyor. Biz bu koşulların bütününe serbest ve adil seçim koşulları diyoruz.

Seimleri serbest ve adil seim haline getirmenin şartları vardır; 1. Seimler herkese açık olacak, yani herkes aday olabilecek. **2.** Seimler oklu seim olacak. Tek adaylı seim kural olarak demokratik bir seim deęildir. **3.** Adaylar, kendilerini semene serbest bir ekilde anlatacak ve semeninde kendi iradesini, serbest bir ekilde oluřturmasını saęlayacak bir ifade zgürlüęü, toplantı zgürlüęü, gösteri, rgütlenme zgürlüęü ve basın zgürlüęünün olması gerekiyor.

Bunlar bir rejimi asgari olarak demokratik bir rejim biimde saymamızın olmazsa olmaz kořulları. ok partili yařamda olmazsa olmazdır. Bu siyasal partilerin uygulamada da iktidara gelme olasılıklarının olması bunun yařanması gerekiyor. Söylediğimiz hak ve zgürlükler bařta olmak üzere temel hak ve zgürlüklerin güvence altına alınması bir rejimi demokratik bir rejim olarak saymamızın kořullarından birisidir. Son olarak hukuk devleti ilkesi, demokratik rejimler hukuk devleti ilkesinin olmadığı yerde yeřerip yařayabilen rejimler deęil. Dolayısıyla hukuk devleti olmazsa olmaz kořuldur. Karar vericilerin bağımsız yargı denetimine baęlı olduęu kiřilerin kurumların hukukla baęlı olduęu devlete verilen isim. Yani hukukla sınırlı devlet. Belli bir süre için parlamentoda çoęunluęu elde etmek her istediğini yapabilmek anlamına gelmiyor. ünkü bu çoęunluk artık ulusun bütününi temsil eden bir çoęunluk varsayımına dayanmadığı için. Günümüz demokrasisi, parlamentonun bütününi bir ulus olarak görür. Dolayısıyla çoęunluk belli bir süre için semen tarafından ülkeyi temsil etme yetkisi verilmiş kiři ya da kiřilerdir. Demokratik rejimlerin karřısında da otoriter ve totaliter rejimler bulunur. 195-1960'lı yıllarda demokratik olmayan rejimler en ok görülen rejim tipleriydi. Otoriter rejim denince sınırlı fakat sorumlu olmayan bir çoęulculuęa dayalı bir rejim, işlenmiş yol gösterici bir ideolojiye sahip deęil. Böyle bir katı ideoloji totaliter rejimlere özgü bir ideoloji. Bu totaliter rejimler daha ok zihniyetlere dayalı. Genellikle duygusal tepkilerle oluřan dolayısıyla belli bir biimi olmayan ve deęişken olan düşünce biimleri. Bu rejimler gelişiminin bazı aşamaları dışında yoğun ve yaygın bir siyasal mobilizasyon saęlama yeteneğine sahip rejimler deęil. Oysa totaliter rejimlerde bunu görüyoruz (K.Kore cenaze töreni). Otoriter rejimlerde bunu göremiyoruz. Otoriter rejimler aynı zamanda bir kiřinin ya da grubun ülkeyi yönettięi rejim. Bütün siyasal iktidarı elinde bulundurduęu rejim. 1950-1960'lı yıllarda otoriter rejimlerle totaliter rejimler arasında gri bir alan vardı. Neyin nerede bařladığı belli deęildi. Günümüzde bu gri alanın, bu demokratik rejimlerle otoriter rejimler arasında oluřtuęunu görüyoruz. Günümüzde 1950-60'lı yıllarda gördüğümüz o otoriterle totaliter rejimler arasındaki bazı ara rejim tiplerinin yok olduęunu görüyoruz. Totaliter rejim tiplerinin de son derece istisnai örnekler olduęunu görüyoruz. Günümüzde demokratik, tam demokratik olmayan otoriter, otoritizmin tonu açık ya da ok koyu olan rejimler arasında bir fark olduęuna tanık oluyoruz. Yani kusurlu, tam olmayan demokrasilerden söz etmemiz mümkün. Erkek, sınırlı ya da oligarřik demokrasi genel oy ilkesinin tanınmadığı ama demokrasinin dięer unsurlarının bulunduęu demokrasiler verilen isim. Örnek apartayt rejimi döneminde Güney Afrika'yı buna örnek verebiliriz. Siyahilere genel oy ilkesinin tanınmadığı, demokrasinin dięer unsurlarının beyaz azınlık bakımından geçerli olduęu oligarřik demokrasi örneęiydi. İkinci bir eksik demokrasi biimi, tam ve eřit siyasal yarışma unsurunun eksik olduęu demokrasiler. Buna kontrollü demokrasi, fiili *tek parti demokrasisi ya da kısıtlayıcı demokrasi deniyor*.

Bütün vatandaşları, temel hak ve zgürlüklerden yararlanamadıkları rejimlere seimsel demokrasi, katı demokrasi, liberal olmayan veya illiberal demokrasi deniyor. Bütün vatandaşlar temel hak ve zgürlüklerden tam olarak yararlanamıyorlar. Liberal demokrasinin bu 3 kořulunu yerine getiren ancak seilmiş iktidarın gerek anlamda iktidarını kullanmadığı yani bazı vesayet makamlarının denetiminde olduęu bu rejimler olabilir buna vesayeti demokrasi ya da koruma altındaki demokrasi deniyor. Yani belli bir alanı ya da konunun seimle işbařına gelmiş ve semene karřı sorumlu olan siyasal sekinler tarafından belirlenmemesi, seilmemiş ve semene karřı da sorumlu olmayan birtakım kurumlara ait olması. Bunun en belirgin özellięi ordudur. Bir bařkası dini kurumlar olabilir. Örnek İran. Dini kurumun seimle işbařına gelmiş kiřilerin karar almasını engelleyici bir rolü olması bakımından verilebilecek bir örnektir. Liberal demokrasi zgürlükü demokrasi. Seimsel demokrasilerle liberal demokrasi arasında birtakım farklar vardır. Örneğin; Seimlerin yarışmacı, serbest ve adil olması konusunda aralarında hiçbir fark yok. Liberal demokraside olması gereken bazı öğelerin yani hukuk devleti, siyasal hesap verilebilirlik, bütün vatandaşların temel hak ve zgürlüklerden tam bir koruma altında yararlanması gibi unsurlarda olan eksikliktir. Seimsel demokrasilerde bu unsurlar kurumsallařmamıştır. Seimsel demokrasilerin çoęunda seilmemiş kurum ya da organların karar alma yetkisi dışında bırakılan bazı seilmemiş vesayet makamlarına terk edilen özel alanlar bulunur. Seimsel demokrasilerle, seimsel otoriter rejim adı verilen rejimler arasında da önemli bir fark vardır. Seimsel otoriter rejimler, seim sürecinin serbestlik, dürüstlük, yarışmacı olma niteliklerine ilişkin farktan kaynaklanır. Bu asgari kořullar saęlanamamaktadır. Bu seimsel otoriter rejimlerde de seimler yapılır ancak bu seimler tam

anlamıyla yarışmacı değildir. Yani birden fazla aday seçimlere girer, buna izin verilir. Muhalefetin belli sayıda milletvekili kazanması ya da belli ölçüde oy almasına da izin verilir. Ancak iktidarın seçimler yoluyla değişmesine izin verilmez. Bu seçimler serbest ve adil değildir. Seçimsel otoriter rejimlerde yönetim, yöneticiler genel oy ilkesine hukuken sınırlamak ya da fiilen ihlal etmek temel siyasal hakları kısıtlamak, para kaynaklarına ve medyaya muhalefetin erişimini sınırlamak, seçmenlerini korkutmak ya da satın almak, seçim hileleri yapmak. Seçim kurallarını kendi siyasal lehine olacak şekilde ayarlamak gibi pek çok yöntemle bu seçimlerin serbest ve adil seçim olmasını engeller. Seçimsel otoriter rejimlerde de yürütme organının başı Başkan, CB ve parlamento için düzenli seçimler yapılır. Bu seçimlere çok sayıda aday, parti katılır. Dolayısıyla bu yolla da çok partili seçim oyununu oynar. Ancak seçimlerin serbestliği ve dürüstlüğü konusunda liberal ilkeler sistematik ve derinden ihlal edilir. Seçimler demokrasinin bir aracı olmaktan çıkıp otoriter yönetimin bir aracı haline gelir. Bu seçimlerde genel oy kuralı uygulanır. Yine bu rejimler asgari ölçüde çoğulcu yani muhalefet partilerinin seçime katılmalarına izin verilir. Yine bu rejimler asgari ölçüde yarışmacı, bunların belli bir ölçüde oy almasına, milletvekilliği kazanmasına izin verilir. Ama hiçbir zaman iktidara gelmesine izin verilmez. Bu seçim yarışması o kadar yaygın, sistematik bir devlet manipülasyonu altındadır ki bu seçimi her hangi bir şekilde demokratik olarak nitelemek mümkün değildir. Seçimsel otoriter rejimler günümüzde demokratik olmayan rejimlerin en yaygın tipi haline geldi. SSCB'nin dağılmasından sonra, batılı, pekişmiş demokrasiler bu otoriter rejimlerin demokratikleşmesine aktif destek vermesi, bu ülkelerinde demokrasinin araçlarını benimsemek yoluyla uluslararası saygınlık isteği duyması, aynı zamanda bu eski otoriter rejimlerdeki, sınıfsal çatışmaların belli bir ölçüde demokrasinin araçlarıyla karşılanabileceğine ilişkin inanç eski tip otoriter rejimlerin sürdürülmesini zorlaştırdı. Bunların bir bölümü tam demokratik rejim haline geldi. Bir kısmı ise tam otoriter rejimden bu seçimsel otoriter rejime bir evrim yaşadı. Örnek Orta Asya, Kafkas ve Rusya'da ve Avrupa'da bazı devletlerde görüyoruz. Kapalı otoriter rejim denilince; yürütme organı için çok partili seçimin yapılmadığı, ifade, örgütlenme, serbest ve adil seçim unsurlarının bulunmadığı rejimdir. Bugün dünya nüfusunun %72'si demokratik olmayan ya da seçimsel otoriter bir rejim altında yaşıyor.

2.Dünya savaşından sonra liberal demokrasi kavramının anayasacılık ile ilişkilendirilmiştir. Liberal demokrasinin, demokrasi ayağının güçlendirilmiş olmasının bile sınırlı iktidar fikri bakımından yeterli olmuyor. Bir rejimi demokratik olarak tanımlayabilmek için parlamentonun belli aralıklarla düzenli olarak yapılacak seçimler sonucunda seçmenin oyu ile belirlenmesi olarak tanımlıyoruz. 2. Dünya savaşında yaşananlardan sonra demokratik rejimin yalnızca bu biçimde tanımlanmasının hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması bakımında yeterli olmadığını gösterdi.

Çoğunluğun azınlık karşısında despotizmini ortaya çıkardı. Bunu önlemenin bir yolu olarak **anayasal demokrasi** kavramı ortaya çıktı. Bunun anlamı, demokrasi ilkesiyle anayasacılığın aslında birbiriyle bağdaştırılması anlamına geliyor. Demokrasi ilkesine dayalı olarak kurulmuş olan bir rejimin anayasacılığın temel ilkeleri ile sınırlandırılması anlamına geliyor. Anayasacılık dediğimiz, çeşitli araçlarla siyasal iktidarın sınırlandırılmasıdır. Bunun içine çoğunluğun sınırlandırılması da evliliyetle girer. Siyasal iktidar kullanan demokratik rejimlerde bu serbest seçimlerle belirlenmiş çoğunluğu temsil eden siyasal parti ya da partilerdir. Dolayısıyla bunların sınırlanması da girer. Çünkü siyasal özgürlüğü güvence altına alabilmek için bit takım araçlarla bu çoğunluğun mutlak ve sınırsız yönetimini sınırlamak gerekir.

Bu araçlar **1. Yazılı ve katı bir anayasanın olması** **2. Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi**. Hak ve özgürlüklerin korunması da anayasal devletin korunmasının amacıdır. Sınırsız iktidar anayasal devlet anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmaz. Çünkü anayasal devlet çoğunluk bile olsa siyasal iktidarın araçlar yoluyla sınırlanması anlamına gelir. Anayasal demokrasi aynı zamanda demokrasinin hukuk devleti yoluyla da sınırlanmasıdır. Günümüzde anayasal devlet denilince yalnızca demokratik devleti değil demokratik hukuk devletini anlıyoruz. Hukuk devleti: siyasal iktidarı kullanan organların yapmış olduğu eylem ve işlemlerin bağımsız yargı denetimine bağlı olmasıdır. Hukuk devleti ilkesi, yalnızca yürütmenin değil aynı zamanda yasama organının yaptığı işlemlerin yani yasaların da bağımsız yargı denetimine dahil olmasını gerektirir. Bu nedenle demokratik hukuk devleti anlayışında anayasa yargısının yani yasaların anayasaya uygun olup olmadığının bağımsız bir yargı organı tarafından denetlenmesinin özel bir yeri vardır. Hukuk devletinin güvencesi, anayasa yargısıdır. Anayasacılık demokrasinin artık günümüzde vazgeçilmez unsurudur. 19.yy-20.yy'ın başındaki demokrasi anlayışı, yasama organının yapılacak adil seçimlerle halk tarafından belirlenmesiydi. Parlamento çoğunluğu ulusu temsil ettiği için bu parlamento çoğunluğunun yapmış olduğu her işlem aslında ulusal iradenin eylemi ve işlemi olarak kabul ediliyordu. Böyle bir ön kabulde yasama çoğunluğunun herhangi bir siyasal ya da yargısal bir denetime bağlı tutulmaması gerektiği sonucuna

ulaştırıyordu. Ancak 2. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan anayasal demokrasi anlayışı artık biraz önce söylenen demokrasi anlayışının ortadan kalkması sonucunu doğurdu. Anayasacılığın araçlarıyla sınırlanmamış siyasal bir iktidar günümüzde demokratik bir devlet olarak tanınmıyor. Anayasal demokrasi mutlak çoğunlukçuluğa yani çoğunluğun her şeye karar verme yetkisine ve tekeline sahip olduğu anlayışına ve mutlak eşitliğe sınırlar getiren bir anlayıştır. Bizde de anayasal demokrasi ilk önce 1961 anayasası ile belirlenmiştir. 1961 Anayasasının 2.maddesi TC Devletinin niteliklerini sayar ve bu nitelikler içinde devletin demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtir. 1982 Anayasasının 2.maddesinde bu tamlamayı aynen yineler “TC devleti, demokratik sosyal bir hukuk devletidir” der. Bu 2 anayasanın benimsediği demokrasi anlayışı hem hukuk devletine hem de sosyal devlete dayalı bir anlayıştır. 1982 Anayasasına göre demokrasinin iki tane ön şartı vardır. O da bu demokratik rejimin hem bir sosyal devlet olması hem de bir hukuk devleti olması şartıdır. Anayasa koyucunun demokratik devleti bu iki sıfatla birlikte anladığını ve bu 2 sıfatla birlikte demokratik devletin oluştuğunu düşünülmesi gerektiğini belirtmesi bakımından önemlidir.

1982 Anayasasına göre demokratik devlet ilkesinin temel düzenlemeleri:

1. Demokratik devlet ilkesi 1923 yılından itibaren bütün anayasalarımızın 1.maddesinde yer alan **Cumhuriyetçilik ilkesiyle** yakından ilişkili. Bu ilişkiyi daha önce Cumhuriyetin dar ve geniş anlamına tekrar bak. Ancak 1.madde ile demokrasi arasında yakın bir ilişki olduğunu söylüyoruz. Bizim kamu hukuku geleneğinin temel özelliklerinden biridir.

2. Ulusal egemenlik ilkesi. Bu ilke 1921 Anayasasından beri bütün anayasalarımızda yer alan bir ilke. Ulusal egemenlik ilkesi ve anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkelerinin birbiriyle olan ilişkisi 1982 anayasasında bu 2 ilkenin birbiriyle nasıl bağdaştırıldığı 1. Dönem görmüştük.

3. Temsil ilkesi: Günümüz demokrasileri esas olarak temsili demokrasi ilkesine dayanıyor. İlk defa parlamentonun kurulduğu 1876 kanuni Esasi’den bu yana bütün anayasalar temsili demokrasi ilkesini benimsedi. 80. Madde “ TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi ya da kendilerini seçenleri değil bütün ülkeyi temsil eder” Bütün anayasalarda 82 de dahil olmak üzere önceki bütün anayasalarda benimsenmediğini gösteren bir düzenleme. Ulus, Ulusal egemenlik ve halk egemenliği arasındaki ayrımı, bu ayrıma neden olan temel ilke ve özellikleri anımsamamız gerekiyor. Demokratik devlet ilkesinin 82 anayasasına göre bir başka özelliği, çoğunluğun yönetim hakkı. Bütün demokrasilerin en temel ilkelerinden birisidir. Demokrasiye dayalı bir devlette farklı grupların kendi çıkarları söz konusudur. Günümüzde ulus devletler etnik kültürel dilsel, inançsal olarak türdeş bir görüntü sergilemez. Demokrasiye dayalı bir devlet toplumdaki bu farklı çıkarlara dayalı çatışmaların varlığını kabul eden devlettir. Bunların barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak düzenekler ve araçlar içeren bir devlettir. Demokratik devlet bu farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlamaz tam tersine bu farklılıkların bir arada yaşamasını sağlayacak barışçıl bir ortamı yaratmayı kendisine ödev bilir. Çoğunluğun yönetim hakkı düzenli aralıklarla yapılan seçimler sonucunda o seçimlerde oy kullanan seçmen çoğunluğunu tercihine dayanan çoğunluğun belli bir süre için ülkeyi yönetme hakkıdır. Çoğunluğun yönetim hakkı, azınlığın ortadan kaldırmaya varacak bir biçimde her istediğini yapma hakkını vermez. Çoğunluğun yönetimi aynı zamanda bir azınlığında bulunması anlamına gelir. Bu azınlık muhalefettir. Demokratik bir rejimde nasıl ki çoğunluğun belli bir dönem için ülkeyi yönetme hakkı var ise azınlığında ülkeyi yönetenlerin eleştirme, kendi seçeneklerini açıkça savunma hakkı vardır. Çoğunluğun yönetim hakkının içine azınlığın kendini seçmene anlatabilme, seçmenin tercihini kendi lehine değiştirebilme ve günün birinde de iktidar olup ülkeyi yönetme hakkını da içerir. Eğer bir rejimde muhalefetin, hukuki olarak ya da fiilen bu yolu tıkanmışsa kendini seçmene serbestçe anlatma seçeneklerini seçmene sunma siyasal iktidarı serbestçe eleştirme ve günün birinde o siyasal iktidara talip olma ve iktidarı kullanma olanağı hukuken ya da fiilen engellenmişse orada seçimler düzenli aralıklarla yapılıyor olsa bile biz demokratik bir rejimden söz edemeyiz. Çoğunluğun yönetim hakkının içine bu azınlık hakları, muhalefet hakları da giriyor.

4. Serbest seçim: Özellikle parlamento seçimlerinin istisnasız hükümet sistemine bağlı olarak aynı zamanda yürütmenin başında olacak kişinin seçimini de belli aralıklarla yapılacak seçimler sonucunda belirlenmesini anlıyoruz. Bir seçimin serbest olarak tanımlanabilmesi için başka bazı koşullara ihtiyaç var.

Bunlar; **1.** Herkesin seçimle gelinecek görevlere aday olunabilmesi yani seçilme hakkın yönelik sınırlamaların makul olması. **2.** Adayların hukuken eşit koşullarda yarışabilmesi. Eğer adaylar eşit koşullarda yarışamıyorsa orada serbest seçimlerden söz etmek mümkün değildir. **3.** Seçme hakkının çağdaş demokratik ilkelere uygun olarak düzenlenmiş olması. Seçme hakkının çağdaş, demokratik ilkelere uygun olarak düzenlenmiş olması demek 1982 anayasasının md.67’de 2.fikrasinde seçimlere ilişkin birtakım ilkeler getirmiştir. – Tek dereceli seçim – Genel oy – Eşit oy – Serbest oy – Gizli oy – Kamuya açık sayım döküm – Seçimlerin yargı organının

gözetim ve denetiminde yapılması. Seçimlerin tek dereceli olması daha önce açıklandı. Serbest seçimlere ilişkin diğer kurallar; seçimlerin eşit oy esasına bağlı olması demek herkesin bir tek oy verebilmesidir. Birleşik Krallıkta 1948 yılına kadar eşit oy ilkesi bazı gruplar bakımından tanınmıyordu. Üniversite öğretim üyeleri ve belli bir iş yeri olan kişilerin parlamento seçimlerinde 2 oy kullana hakkı vardır. Bu kişiler, ikametgah adreslerinde hem de çalıştıkları yerde oy kullanabiliyorlardı. Bugün artık eşit oy ilkesinin demokratik devletin ve serbest seçimlerin en temel ilkesi olarak kabul edildiğini görüyoruz. İstisna olarak 2012 Macaristan anayasasıdır. Genel oy ilkesi demek; bütün yurttaşların servet, eğitim, cinsiyet gibi sınırlamalar söz konusu olmaksızın oy verme hakkına sahip olmasıdır. Genel oy ilkesinin de çok geç bir tarihte bütün demokratik devletlerde benimsendiğini anımsayalım. 1789 Devriminden sonra ortaya çıkan millet ulus egemenliğine dayalı demokrasi anlayışı genel oy ilkesini benimseyen bir demokrasi anlayışı değildi. 1876 Anayasası, 2 dereceli bir seçimi öngörüyordu. 1. Seçmen olmak için emlak sahibi olmak koşulu arıyordu. Daha sonra 1908 yılında yasal bir değişiklik yapıldı. Seçmen olabilmek için az çok vergi verme koşulu getirildi. Bizde de genel oy ilkesi kabul edilmemişti. İtalya’da 1912 ye kadar okur yazar olmayanların seçme hakkı yoktu. Genel oy ilkesine getirilen en önemli koşullardan birisi cinsiyettir. İrk ve etnik köken bakımından genel oy ilkesine getirilen istisnalar; ABD’de 1870’e kadar siyah yurttaşların oy kullanma hakkı tanınmamıştı. Yine Güney Afrika’da apartayt rejimi yıkılana kadar siyah yurttaşların seçme ve seçilme hakkı yoktu. 1935 Yılında Nazi Almanya’sı Yahudi ve çingene Alman yurttaşlarını seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmasını öngörüyordu. Kadınlar seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakılmasının hem pekişmiş demokrasilerde hem de diğer ülke örneklerinde sıkça görülmektedir. ABD’de 1870’den itibaren en azından siyah erkeklerin oy verme hakkı varken 1919’a kadar hiçbir kadın yurttaşın seçme ve seçilme hakkı yoktu. İlk defa ulusal düzeyde 1893 Yılında Yeni Zelanda’da kadınlara seçme hakkı tanındı. Bizim 1924 Anayasasında 1934’de yapılan değişiklikle birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Biz genel oy ilkesine öncülük eden konumda olduk. Yaş unsuru, makul bir yaş sınırı olmak kaydıyla bütün demokrasilerde bulunan bir unsurdur. Bunu genel oy ilkesine bir istisna olarak kabul etmiyoruz. Seçmen olabilmek için getirilen yaş sınırı seçmeni yurttaştan ayıran bir ölçüttür. Her seçmen kural olarak bir yurttaşdır ama her yurttaş bir seçmen değildir. Doğumla birlikte yurttaşlık kazanılır ama doğumla birlikte seçme ve seçilme hakkına sahip olmaz. 1982 Anayasasının 67.maddesinin ilk biçiminde seçme yaşı 21 olarak öngörülmüştü. Daha sonra bu hüküm 1987 yılında değiştirildi ve seçme yaşı 21’den 20’ye indirildi. 1995 Yılında bir değişiklik daha yapıldı ve 18’e indirildi. 1924 Anayasasının ilk biçiminde her 18 yaşını doldurmuş her erkek Türk vatandaşının seçme hakkına sahip olacağı belirtiliyordu. 1934 Yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınınca seçme yaşı 18’den 22’ye çıkarıldı. 1961 Anayasası seçme yaşı konusunda herhangi bir düzenleme içermedi. Bu işi kanun koyucuya bıraktı. 1961 Anayasası döneminde çıkarılan yasa seçmen olabilmek için 21 yaşı öngördü. Dünyadaki genel eğilim, bütün demokratik ülkelerde 18 yaş benimsenen bir yaştır. 18 Yaşın 16 yaşa doğru inmesi eğiliminin başladığını söyleyebiliriz. Bizde de 1995 yılında Anayasa değişikliğinde 67.maddede yapılan değişiklikle seçme yaşı 18 olarak belirlenmiştir.

298 Sayılı kanunla, seçimlere ilişkin temel kuralları belirler. Bu kanuna göre sandık seçmen listesinde kayıtlı olmak gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye’de de oturmak gerekiyor. Bu koşullar serbest seçim hakkına getirilmiş sınırlama değildir. Bu 2 koşula anayasa ile getirilmiş bir istisna vardır. 67.maddenin 2.fıkrasına 1995 anayasa değişikliği ile getirilen “yurt dışında bulunan kişilerin oy kullanması “anayasal güvenceye kavuşturuluyor. 1987 Yılından yapılan bir değişiklikle bu 298 sayılı kanuna eklenmişti. 1995 Yılında 67.madde 2. Fıkrasına eklenen bu cümle ile yasayla getirilmiş bir olanağa anayasal güvence sağladı. Yurt dışında ikamet etmek gerekiyor. Bu da o ülkede yasal olarak yaşaması yani oraya kayıtlı olması gerekiyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler, yalnızca milletvekilliği genel seçimleri, halk oylamalarında değil aynı zamanda CB genel seçimlerinde de oy kullanmasına ilişkin kanunda 2008 yılında değişiklik yapıldı. Aynı yıl anayasada da değişiklik yapılmıştı. Çünkü artık CB doğrudan halk tarafından seçilecekti. Elektronik ve mektupla oy kullanmak yasa ya da anayasa ile tanınmış bir değişiklik değildi. İlk kez 2008 yılında yapılan anayasa değişiklinde yer aldı. Aynı yıl AYM, mektupla oy kullanma hakkını iptal etti (E. 20008/33 K. 2008/113). Gerekçede; mektupla oy kullana benimsenirse o zaman seçmen aile üyelerinden ve sosyal çevreden her türlü etkiye açık olacak bu sebeple serbest iradesini de yansıtamayacaktır. Mektupla oy verme yöntemi hem serbest oy ilkesine hem de seçmenin oyunu görebileceği için gizli oy ilkesine aykırı olacaktır gerekçesiyle iptal edildi. Elektronik oylamayla bugüne kadar bir seçim yapılmadı. 67.Maddenin 5.fıkrasında yer alan düzenleme 1961 anayasasında da bulunuyordu. 1982 Anayasası bu yasağı daha geniş kılacak bir düzenleme içeriyordu. 1982 Anayasasının ilk biçimine göre yalnızca hükümlüler değil aynı zamanda tutuklularında seçme

hakkından yoksun bırakılacağı öngörülmüştü. 1995 Yılında yapılan anayasa değişikliği ile tutukluların seçme hakkından yararlanması sağlandı. Bugün taksirli suçlar hariç ceza ve tutukevinde bulunan hükümlülerin seçme hakkından yararlanamayacağı hükmü getirildi. 2001 Yılına kadar bütün hükümlüler bakımından bu yasak vardı. 2001 Anayasa değişikliği ile taksirli suçtan mahkum olanlar bu yasağın dışına alındı. 67. Maddenin 5. Fıkranın amacı; erler, erbaşlar, askeri öğrenciler için burada bir emir komuta söz konusu, haliyle katı hiyerarşi disiplinin serbest oy ilkesine zarar vereceği düşünülmüş. Mahkumlar bakımından da, mahkum olmanın bir ceza niteliği taşıması aynı zamanda tutukevlerinde mahkumların oylarını serbest şekilde oy kullanabilme imkanının sınırlı olmasına ilişkin bir ön kabul olduğu söylenebilir. Seçme hakkına getirilen bu yasaklar, AİHM'nin içtihatlarında özellikle hükümlü olmanın seçme hakkına getirilen bir istisna olmasının sözleşmeye aykırı olduğunu belirtiyor.

2013 tarihli Söyler, Türkiye kararı vardır. Kararında “oy hakkında mahkum bırakılma ile mahkumiyete yol açan suçun niteliği arasında orantı aranmalıdır” der. AİHM. Kanunun bu maddesinin, AİHM İçtihatları çerçevesinde gözden geçirilmesi gerekir. Temel hak ve özgürlükler için her zaman göz önünde bulundurmanız gereken ilke, hak ve özgürlüğün esas sınırlamanın ise istisna olması gerekir. 67.nin son fıkrasındaki düzenleme 2001 yılında getirildi. 31 Mart 2022 yılında seçim kanununda bazı değişiklikler yapıldı. 31 Mart tarihinden sonra yapılacak seçimlerde bu yeni düzenlemenin uygulanacağını söyleyebiliriz. Bu düzenlemenin amacı, TBMM çoğunluğunu oluşturan parti ya da partilerin kendi çıkarlarına olacak biçimde seçim kanunlarında sürekli olarak değişiklik yapmasını engellemek buna sınırlama getirmektir. Seçim sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyecek düzenlemeler bakımından geçerli olduğunu belirtmekte yarar vardır. Serbest oy ilkesi: seçmenlerin, oylarını herhangi bir baskıya uğramadan kullanabilmesi anlamına geliyor. Hem 1961 ve hem de 1982 anayasasının 114.maddesinde yer alan bir hüküm serbest seçim ilkesini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir hükümdür. Bu düzenleme ile siyasal iktidarı kullanan siyasal partilerin devlet olanaklarını kendi lehlerine kullanarak seçmen üzerinde herhangi bir baskı oluşturmalarını engellemekti 2017 Yılında, böyle bir istisna serbest oy ilkesi bakımından söz konusu değil. Serbest oy ilkesiyle bağlantılı olan bir başka unsur ise oy verme hakkının isteğe bağlı olması ya da zorunlu kılınması konusu. 67. Madde seçme hakkını bir ödev olarak değil bir hak olarak düzenlemiş olduğunu görüyoruz. 1.Dönem bu konu hakkında konuşmuştuk. Oy vermenin seçimlerde zorunlu kılınması demokrasilerde istisnai ya da olmaması gereken bir düzenleme de değildir. Amaç, seçmeni sandık başına gitmeye zorunlu kılmak yoluyla seçimlerden sonra ortaya çıkacak sonucu meşru olmasını sağlamaktır. 175.maddenin 1987 yılında eklenen hükmünde halkın seçimlere katılımını artırmak için oy kullanılmaması durumunda para cezası verilebileceğini düzenlemiştir. Gizli oy ilkesi: Seçmenin kime oy verdiğinin öğrenilmemesidir. Bu ilke ilk kez 1950 seçimlerinde uygulanmaya başlandı. 1876 Kanuni Esasi de gizli oy ilkesini tanımıştı. Ondan sonraki anayasalar bu ilkeye yer vermediler. İlk defa 1961 anayasasında gizli oy ilkesinin anayasal güvenceye kavuşturulduğunu görüyoruz. Zarfın da saydam olmamalıdır. 1982 Halk oylaması gizli oylama ilkesini ihlal eden bir oylamaydı. 67.Maddenin 2. Fıkrasında yer alan düzenleme, bu alenilik ilkesi ve seçimlerin dürüst biçimde yapılmasını sağlamak bakımından son derece önemlidir. 1950 Yılı seçimleri ilk defa bu ilkeye dayalı olarak yapılan seçimler olması bakımından önemlidir.

Seçimlerin yargı organının gözetimi ve denetimi altında yapılması: İlk defa 1961 anayasasıyla düzenlendi. 1982 Anayasası da 61 anayasasını tekrarlıyor. 82 Anayasasının 79.maddesi bu yetkiyi YSK'ya veriyor. YSK, bu yetkisini 1950 yılından itibaren bütün genel seçimler bakımından kullanmıştır. Seçim sürecinin başladığı andan itibaren olması gerekiyor. Yani seçimlerin ilan edildiği tarih. 31 Marttan sonra yapılmış olan ilanlar anayasanın 67.madde son fıkrasına uygun olur geçen yıl seçim kanunlarında yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girmesi bakımından.

14 Mart 2023

Seçimler: Yürütme organının doğrudan seçimler yoluyla belirlenmesi bir düzenin demokratik olup olmaması konusunda belirleyici değil. Asıl olan parlamentonun yapılacak serbest, adil seçimler sonucunda belirlenmesi. Seçim sistemini ikiye ayırıyoruz.

Geniş anlamda seçim sistemi, seçme, seçilme yeterliliği, adaylık, oy verme yöntemi, seçimlerin yönetimi gibi seçime ilişkin çok sayıda konuyu içinde barındıracak şekilde yapılan bir tanım.

Dar anlamda seçim sistemi ise seçmenlerin verecekleri oyların parlamentodaki sandalye dağılımında nasıl rol oynayacağı ya da parlamentodaki sandalyeye dönüştürülmesindeki kurallar biçiminde tanımlanıyor.

Seçim çevresi (bölgesi): Bir ülkede milletvekillerinin seçileceği ve seçmenlerin milletvekilleri için oy kullanacağı bölgeye verilen isim. Seçim bölgesi 3 biçimde olabilir. *Dar, geniş ve ulusal çevre biçimi.*

Dar çevre, ülkenin milletvekili sayısı kadar seçim çevresine ayrılmasına verilen isimdir. Birleşik Krallıkta dar seçim çevresi uygulanır.

Geniş çevre, 2 ya da daha fazla milletvekili çıkaracak biçimde seçim çevrelerinin oluşturulması anlamına gelir.

Ulusal çevre ise, ülkenin tek bir seçim çevresi olmasıdır. Örneğin İsrail ve Hollanda da tek bir seçim çevresi vardır ve bütün ülkeyi kapsar. Küçük devletlerde bu sistemin tercih edildiğini söyleyebiliriz. 1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra yapılan seçimlerde Türkiye bakımından geniş çevre uygulanmıştır. 1983'e kadar her il bir seçim çevresinden oluşuyordu. 1983'de yürürlüğe giren milletvekili kanunundan sonra da bu ilke değişmedi. Öncelikle bütün illere bir milletvekili tahsis ediliyor. Bunu yaptıktan sonra geriye kalan milletvekillikleri, iller arasında o illerin nüfusuna göre paylaştırılıyor. Bu yöntemi özellikle az nüfuslu illerin çıkarına olan bir yöntemdir. Büyük kentlerde milletvekili başına düşen seçmen sayısının küçük kentlere göre daha büyük daha geniş olduğunu görüyoruz. Büyük illerde mesela 150 bin kişiye 1 milletvekili düşerken, küçük illerde 30 bin kişiye bir milletvekili düşüyor olup burada bir temsilde bir orantısızlık ve hatta adaletsizlik yarattığını belirtelim. YSK belirliyor. Yapılacak genel seçimler öncesinde her ilin kaç milletvekili ile temsil edileceğini belirliyor. Yine 1995 de yapılan milletvekili seçim kanununda yapılan değişiklikten bu yana 19'a kadar milletvekili çıkaran iller 1 seçim çevresi, dolayısıyla il ve seçim çevresi burada örtüşüyor. 19-35 arasında milletvekili çıkaran iller 2 seçim çevresi 35'den daha fazla çıkaran iller ise 3 seçim çevresine ayrılıyor. 3 Büyükşehir 3 seçim çevresinden oluşuyor. 1987'de seçim çevreleri 6 milletvekilinden oluşacak biçimde değiştirildi. Bu seçim çevrelerinin nasıl belirleneceğine dair özel olan yöntem, **Gerrymandering yöntemi** denir. Seçim çevrelerinin bir siyasal partinin yararına olacak biçimde düzenlenmesi demektir. Bu kişinin 2 yöntemi var.

1 Paketleme yöntemi: seçim çevresinin mümkün olduğunca çok yandaş seçmeni aynı seçim bölgesine toplayacak biçimde belirlenmesidir. Buna göre de seçim çevresi belirleniyor.

2. Ayırma yöntemi: muhalif seçmeni olabildiği kadar başka seçim çevrelerine dağıtılmasıdır. Genellikle bu 2 yöntem birlikte kullanılmıştır. Amaç bir siyasal partinin yararına o seçim çevresinin düzenlenmesidir. Hem temsili adalet ilkesine hem de demokrasinin temel ilkesine de aykırıdır. 1954 Yılında bizde de uygulanmıştır.

Seçim sistemlerinin sınıflandırılması: 1. Seçim çevresinin büyüklüğüne göre seçim sistemlerinin sınıflandığını görüyoruz. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Dar (tek isimli) bölge yöntemi ve liste (çok isimli) yöntem.

Dar bölge yöntemi: her seçim çevresinden 1 milletvekilinin çıkarmasıdır. Yeni Zelanda ve Birleşik Krallıkta Avam kamarası seçimlerinde uygulanan yöntemdir.

Liste yönteminde ise, bir seçim çevresinden 2 ya da daha fazla milletvekilinin çıkmasını anlıyoruz. Bu liste karma, bloke ya da tercihli oy sistemi olabilir.

1. Bloke liste: liste yönteminin belirlendiği bir seçim sisteminde o seçim çevresinden ne kadar milletvekili çıkacak ise o seçim çevresinde yarışan bütün siyasal partiler oradan çıkacak milletvekili sayısı kadar aday gösterirler. O aday listesi bloke olabilir. Yani seçmen bir siyasal partiye oy verecek, o siyasal partinin aday listesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak.

2. Tercihli oy sistemi: Bütün siyasal partiler, o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar aday gösterdiği bir liste hazırlarlar. Ancak, seçmen isterse o liste içerisinde oynama, değişiklik yapabilir. Örneğin, o listenin alt sıralarında yer almış bir kişinin en üstte yer almasını isteyebilir.

3. Karma liste ise seçmenin yalnızca oy vereceği siyasal parti listesi içinde bir değişiklik yapması anlamına gelmez, tam tersine o seçim çevresinde farklı siyasal partilerin listeleri içinden bir liste yapması anlamına gelir. Örneğin Seçmen oy vermek için oy kabinine girdiğinde, A partisinin 2.sırasındaki adayı, B partisinin 5.sırasındaki adayı tercih ederek kendine bir liste oluşturabilir.

İkinci bir sınıflama oyların değerlendirilişinde kullanılan yöneteme göre belirlenen seçim sistemi: Bunda da iki büyük sınıflama vardır. **1. Çoğunluk sistemi** **2. Nisbi temsil sistemi.**

1. Çoğunluk sistemi: O seçim çevresinde en çok oyu almış olan siyasal partinin seçim çevresindeki bütün milletvekilliklerini kazanması anlamına geliyor. Kendi içinde 2'ye ayrılıyor.

a. Tek isimli çoğunluk sistemi: o seçim çevresinden 1 milletvekili çıkıyor. O bir milletvekilini de o seçim çevresinde en çok oy almış siyasal parti alıyor.

b. Listeli çoğunluk sistemi: O seçim çevresinden birden fazla milletvekili çıkıyor. Siyasal partiler bir liste halinde adaylarını belirliyorlar. O seçim çevresinde hangi siyasal parti en çok oyu almışsa, oradan çıkacak bütün milletvekilliklerini de elde etmiş oluyor. O seçim çevresindeki milletvekillikleri, orada yarışmış olan

siyasal partilerin kazandıkları oy oranına göre dağıtılmıyor. Bizde de 1954-1960'a kadar yapılmış olan seçimler bu esasa göre yapıldı. Tek isimli çoğunluk sisteminde, 2 yöntemden birisi belirleniyor.

1. Basit (tek turlu) çoğunluk sistemi: İlk oylamada kimin milletvekillikleri kazanacağı belli oluyor. Oylama sonucunda en çok oyu almış siyasal parti ister tek isimli ister listeli olsun oradan çıkacak milletvekilliklerini elde ediyor.

2. Mutlak (iki turlu) çoğunluk sistemi: O seçim çevresinde geçerli olan oyların salt çoğunluğunu almış olan siyasal partinin, o seçim çevresinden çıkacak milletvekilliklerin tümünü alması. Eğer hiçbir siyasal parti, geçerli oyların salt çoğunluğunu elde edememişse 2. bir oylama 1 hafta veya 15 gün sonra gerçekleştiriliyor. 2. Oylamaya ilk oylamada en çok oy almış siyasal partiler katılıyor. Ya da ilk oylamada geçerli oyların veya kayıtlı seçmenlerin belli bir miktarının oyunu almış siyasal partiler katılıyor. 2. Oylamada yarışan siyasal partilerden hangisi en çok oyu almışsa o seçim çevresindeki milletvekilliklerin tümünü o siyasal parti elde etmiş oluyor. Örneğin Fransa'da mutlak çoğunluk sistemi uygulanıyor. Amaç seçmenin salt çoğunluğunun oyunu almış olan bir adayın seçilmesi ve seçimde adalet ilkesinin gerçekleştirilmesidir. Tek turlu basit çoğunluk sistemi, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'da da uygulanıyor. Birleşik Krallık 650 seçim çevresine ayrılmıştır.

3. Listeli çoğunluk sistemi tıpkı tek isimli çoğunluk sistemi gibi tek turlu listeli çoğunluk veya iki turlu listeli çoğunluk sistemlerinden biri uygulanabilir. Tek isimli çoğunluk sisteminde, seçim çevresinden bir milletvekili seçiliyor. Listeli çoğunluk sisteminde o seçim çevresinden 2 ya da daha çok sayıda milletvekili seçiliyor. Ama çoğunluk sistemi olduğu zaman önemli olan ister tek ister 2 veya daha çok milletvekili seçilsin o seçim bölgesinden seçilecek milletvekilleri en çok oyu alan siyasal partiye gidiyor. Bu paylaşılma listeli çoğunluk sisteminde ilk oylamada olabilir. Hangi siyasal parti en çok oyu aldıysa bütün milletvekilleri o çıkarır. Bizde 1954-57 arasında bu sistem uygulandı.

İki turlu olduğu zaman belli bir şart aranıyor. Bu çoğunluk sisteminin getirdiği en önemli avantaj büyük partilere avantaj sağlaması. Bu daima büyük partiler lehine çalışan bir yöntemdir. Nisbi temsil sistemi ise daha küçük partilerin aldıkları oy çerçevesinde parlamentoya milletvekili sokabilmesini sağlıyor. Bunun sonucunda, parlamentoda bir siyasal partinin tek başına ülkeyi yönetmesini kolaylaştırıcı rol oynuyor. Bunu istisnası vardır. Birleşik Krallıkta 2,5 siyasal parti vardır. 1974-2014 yıllarında koalisyon hükümetleri ile yönetildi. Tek turlu basit çoğunluk sistemi parlamentoda tek bir siyasal partinin salt çoğunluğu elde etmesine yeterli olmadı.

Nisbi temsil sistemi: Bunun için seçim çevrelerinin geniş olması gerekir. En az 2 veya daha fazla milletvekilliğinin seçileceği biçimde seçim çevrelerinin oluşturulması gerekir. Bir seçim çevresi ne kadar dar ne kadar az milletvekilliği çıkaracaksa o seçim çevresi o kadar çok büyük partilerin avantajına olur. Seçim çevresi ne kadar genişlerse o kadar diğer partilerde parlamentoya milletvekili sokabilirler. Seçim çevrelerinin daraltılması ya da genişletilmesi, seçim çevresinin sayısı, temsilde adaletin sağlanması bakımından son derece önemlidir. Herhangi bir ülkedeki seçim sistemini ve bunun sonuçlarını incelemek istediğimiz zaman mutlaka seçim bölgelerine bakacağız. Kaç milletvekilini nasıl çıkarıyor, bunu göz önünde bulunduracağız. Nisbi temsil sistemi, o seçim bölgesinde çıkacak milletvekilliklerinin o seçim bölgesinde yarışan siyasal partiler arasında bu siyasal partilerin aldıkları oy oranına göre dağıtılması anlamına gelir. Temsilde adalet ilkesine yakın olan bir seçim sistemidir. Her nisbi temsil sisteminde bir seçim sayısı ya da **seçim kotası** olur. O seçim çevresinden, kullanılmış olan geçerli oylar toplamının o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısına bölünmesi ile oluşan sayıdır. O seçim çevresinde yarışa girmiş olan her siyasal partinin geçerli oy toplamı içinde bu seçim sayısı aranır. Bir siyasal partini toplam oyları içinde bu seçim sayısından kaç tane varsa o siyasal parti o seçim çevresinde o kadar milletvekilliği elde etmiş olur. Buna karşılık nisbi temsil sistemi bu şekilde düzenlenmişse, çoğu zaman dağıtılamayan milletvekillikleri her siyasal parti bakımından kullanılamayan artık oylar ortaya çıkar. Bir artık milletvekillikleri ikincisi artık oylar ortaya çıkar. İkinci bir hesaplama bu artık oyların artık milletvekilliklerin nasıl kullanılacağı ya da nasıl dağıtılacağına ilişkindir.

1. Ulusal artık ya da milli bakiye yöntemi: yurt çapındaki bütün artık oylar ve artık milletvekillikleri bir merkezde toplanıyor demek. Yurt içinde değerlendirilemeyen tüm artık oy toplamı ve yine bütün seçim çevrelerinde dağıtılamayan milletvekilliklerinin toplam sayısına bölünmesiyle ulusal seçim kotası bulunur. Bu sayı ulusal artık ya da milli bakiye sayıdır. Her partinin artık oyuyla bu ulusal seçim sayısı kaç tane varsa o siyasal parti o artık milletvekilliğini o kadar elde eder.

2. En büyük artık yöntemidir. Artık milletvekillerinin artık oyların büyüklük sırasına göre dağıtılmasıdır. Bir seçim çevresinin ya da her bir seçim çevresinde ortaya çıkan artık milletvekillikleri o seçim çevresinde değerlendirilememiş artık oyların sırasına göre dağıtılır.

3. En güçlü ortalama yöntemi: partilerin aldıkları oyların ilk dağıtımın sonucunda kazandıkları sayının bir fazlasına bölünmesi. İlk önce bir dağıtım yapılıyor, o dağıtımda siyasal partiler belli sayıda milletvekilliği kazanıyorlar veya hiç kazanamıyorlar, partilerin aldıkları oylar ikinci dağıtımda ilk dağıtımda elde ettikleri milletvekilliği sayısının bir fazlasıyla toplanıp bölünüyor. Nisbi temsil sistemi dediğimizde bir de D'Hondt sistemi var. Bu sistem, Nisbi temsil sistemi yöntemleri içinde milletvekillerinin artık bırakmayacak biçimde dağıtılmasını sağlayan bir yöntem olmasıdır. Bir seçim bölgesinde, yarışan her bir siyasal partinin aldığı oy o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısına teker teker bölünüyor. Örneğin bir seçim çevresinde 4 milletvekili çıkacaksa her siyasal partinin aldığı oy önce 1 sonra 2 sonra 3 ve 4'e bölünüyor. Her siyasal parti için 4 ayrı sayı çıkıyor. Bu sayılar en büyüktен en küçüğe doğru sıralanıyor ve her bir sayı hangi siyasal partiye aitse oradan çıkacak milletvekilliği de o siyasal partiye verilmiş oluyor. İlk 4 sayının karşısında hangi siyasal parti varsa oradan çıkacak 4 milletvekilliği o siyasal partilere bölünmüş oluyor. O seçim çevresinde 100 bin oy var. 4 milletvekili çıkacak ve 4 siyasal parti de o seçim çevresinde yarışmış. A 40 bin B 30 bin C 20 bin D ise 10 bin oy almış. O seçim çevresinin seçim sayısını yani kotasını bulacağız. Geçerli oy sayısı oradan çıkacak milletvekilliğine bölünecek. Seçim sayısı 25 bin. Nisbi temsil sistemi, çevre barajı uyguluyor ise yani o seçim çevresinde her siyasal partinin en az seçim sayısı kadar oy almış olması gerekir. Böyle bir seçim barajı uygulanıyorsa o zaman orada yarışa girmiş olan siyasal partilere en az seçim sayısı kadar oy elde etmiş olması gerekiyor. O seçim çevresinde böyle bir baraj uygulanmış ise C ve D siyasal partileri o seçim çevresinde herhangi bir milletvekilliği elde edemeyecektir. 4 Milletvekilliği A ve B siyasal partileri arasında paylaşılır. Bizde 1995 yılına kadar seçim çevresi barajı uygulanıyordu. Çifte baraj sistemi vardı. Hem ülke çapında geçerli oyların en az %10'unu elde etmesini hem de her bir seçim bölgesinde elde edilecek seçim sayısı kadar oy elde etmesi şartını arıyordu. Eğer bir seçim barajı yoksa o zaman seçim sayısını her bir siyasal partinin kaç tane oy alacağı bakımından göz önünde tutuyoruz. A partisi 40 Bin oy almış, seçim sayısına bölüyoruz. 40 Bin sayısının içinde 1 tane seçim sayısı bulunduğu için 1 tane milletvekili elde ediyor. 15 Bin artık oyu var. B partisinin 1 milletvekilliği ve 5 bin artık oyu var. C'nin hiç seçim sayısı yok bütün 20 bin oy onun artık oyu. D'nde bütün oyları değerlendirilemeyen artık oy. Böyle bir nisbi temsil sisteminde 4 milletvekilliğinin 2'si paylaştırılıyor. 2 Tane de paylaştırılmayan milletvekilliği ortaya çıkıyor. En büyük artık usulünü göz önünde bulundurarak paylaştırsak, artık milletvekillikleri, artık oyların büyüklük sırasına göre paylaştırılıyor. A'nın 15 Bin, B'nin 5 bin, C'nin 20 bin ve D'nin 10 bin artık oyu var. Bu durumda en büyük olan A 1 milletvekilliğini 2. En büyük sayıya sahip olan C'de 2 milletvekilliğini kazanmış oluyor. Bu artık oyları ve milletvekilliklerin nasıl dağıtıldığını gördük ilk derste. Saf nisbi temsil sistemi uygulandığı durumda bu artık milletvekilliklerin dağıtımında **1.En büyük artık yöntemi 2. Ulusal artık ya da milli bakiye yöntemi:** artık oylar ya da milletvekillikleri her seçim çevresinde ayrı ayrı hesaplanıp dağıtılmıyor, milletvekillikleri ve artık oylar tek bir merkezde toplanıyor ve ona göre dağıtılıyor. Ulusal artık sistemi uygulandığında da tek seferde bütün milletvekillikleri dağıtılamayabilir. Yeniden bu bölme işleminin yapılması gerekir. Artık milletvekilliği daha önceki örnekten yola çıkarak bu şekilde dağıtılabiliyor. **3. Yol En kuvvetli ortalama:** partilerin aldıkları oyların onların aldıkları ilk dağıtımın sonucunda kazandıkları milletvekili sayısından 1 fazlasına bölünmesi ve artık milletvekillerinin bu ortalamaların büyüklük sırasına göre dağıtılmasıdır. Seçim çevrelerinde göz önünde bulunduruluyor. İlk dağıtımda her bir siyasal partinin artık oyun, ilk dağıtım sonucunda elde ettiği milletvekili sayısının bir fazlasıyla bölünüyordu. Örneği incele. D'Hondt sistemi artık milletvekili bırakmayacak biçimde dağıtılmasıdır. O seçim çevresinde bütün milletvekillerin siyasal partiler arasında dağıtılabilmesi. Her bir siyasal partinin o seçim çevresinde aldığı geçerli oy o seçim bölgesinden çıkacak milletvekili sayısına tek tek bölünüyordu. Her siyasal partinin geçerli oyu sırasıyla 1,2,3 ve 4'e bölünüyor. Bu sayılar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. En büyük 4 sayı hangi siyasal partiler tarafından elde edilmişse oradaki milletvekilliği o siyasal partiler arasında paylaşılmış oluyor. Karma sistem: Çoğunluk ve nisbi temsil sistemlerini birlikte uygulayan sistemlerdir. Amaç, nisbi temsil sistemini benimsemek yoluyla parlamentoda bir adil dağılım yaratmak. Aynı zamanda parlamentonun çok parçalı olmasını bir ölçüde engelleyerek istikrarlı yönetimler kurabilmeyi sağlamak. Karma sistemler örnek olarak Çift D'Hondt'lu sistem yani Alman sistemi denir. Almanya ve İtalya'daki karma sistemin özelliği; seçmen sandık başına gittiği zaman iki ayrı oy kullanır. Bu 2 oydan biri dar bölge çoğunluk sistemine biri de nisbi temsil sistemine göre kullanılan ve değerlendirilen oy. Dar bölge

çoğunluk sistemi dediğimiz tek turlu dar bölge çoğunluk sistemi uygulanıyor. Seçmen o seçim bölgesinden bir tane milletvekili seçiyor. O bir milletvekili de o seçim çevresinde en çok oyu almış siyasi partiye gidiyor. İkincisi nisbi temsil sistemi yani seçmenin oy kullandığı eyalet düzeninde seçim çevresi belirleniyor. Nisbi temsil sistemine göre çıkacak milletvekilliklerinin belirlenmesinde bir koşul var o da ya %5 barajı ülke barajını geçmiş olması gerekiyor ya da dar bölge çoğunluk sistemiyle seçilen milletvekilliklerinin ülke çapında en az 3'ünü elde etmiş olması gerekiyor. Bir siyasal parti bu koşullardan birini sağlıyorsa o zaman nisbi temsil sistemine göre dağıtılacak milletvekilliklerinin dağıtım süreçlerine katılmış oluyor. Böylece Almanya'da hem istikrarlı bir hükümetin kurulması sağlanıyor hem de temsilde adalet ilkesi gerçekleşiyor. Çoğunluk sisteminde ülke barajı uygulanmaz. İkinci karma seçim sistemlerinde biri de bizde 1987 ve 1991 yılları seçimlerinde uygulanan ülke ve çevre barajlı kontenjan sistemi. Ülke barajı %10'du. Çevre barajı geçerli oyların oradaki milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı idi. O çevrede yarışan bir siyasal parti ülke ve çevre barajını aşamamışsa seçim çevresindeki milletvekili dağılımına katılamıyordu. Bir de bunun üzerine en çok 6 milletvekili çıkaran illerde burada bir de kontenjan adaylığı vurgulanıyordu. Yani en çok 6 veya daha fazla milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde orada yarışacak siyasal partiler bir de kontenjan adayı koyuyorlardı. Bu kontenjan milletvekilliği o seçim çevresinde en çok oyu almış olan siyasal partiye gidiyordu. 1995 Yılında hem anayasada hem de milletvekilliği seçim kanununda yapılan değişiklikle bu seçim sistemi değiştirildi. Çite barajlı bu D'Hondt sistemi büyük siyasal partilerin yararına küçük siyasal partiler aleyhine son derece dezavantajlı bir seçim sistemi olduğunu belirtelim.

Türkiye'de uygulanan seçim sistemleri:

1946-1957 Yılları arasında listeli çoğunluk sistemi uygulandı ve bunun büyük parti lehine sonuç doğurmuştu. 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşturulan yeni milletvekili seçim kanununda parlamento 2 meclisli hale gelmişti. Millet meclisi, çevre barajlı D'Hondt sistemi, Cumhuriyet senatosu ise tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi ile belirleniyordu. 1964'de milletvekilliği seçim kanununda bir değişiklik yapıldı. Cumhuriyet senatosu da çevre barajlı D'Hondt sistemine göre belirlendi. Parlamentonun her iki kanadının da aynı seçim sistemi ile belirlendiğini görüyoruz. 1965'de bir başka değişiklik yapıldı. Bu sefer 2 meclis içinde nisbi temsil sisteminin en uç sistemi olan ulusal artık sistemi uygulandı. Bu sistem, seçmenin iradesini neredeyse birebir parlamentoya yansımaları sağlayan sistem. Buna karşılık siyasal yelpaze çok renkli, birbiriyle bağdaşmayan siyasal parti varsa bunların hepsi parlamentoya girdiği için istikrarlı bir hükümetin kurulması, birbirleriyle anlaşılan koalisyon hükümetinin kurulması zorlaşabiliyor. 1965 Seçimlerinde uygulanan ulusal artık sistemi çok parçalı meclis yapısı ortaya çıkardığı için bundan vazgeçildi. 1968 Yılında milletvekili seçim kanununda yapılan değişiklikle 2 meclis içinde çevre barajlı D'Hondt sistemi yani 1961 yılındaki seçim sistemine geri dönmüş olundu. İki meclis içinde seçim barajına dayalı nisbi temsil sistemi uygulamasının anayasaya aykırılığı iddiası ile bu düzenleme AYM'ye gitti. AYM 1968 yılında 19668/13 Karar verdi. AYM, seçim sistemine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. İptal gerekçesi, böyle bir çevre barajlı D'Hondt sistemi getirdiğiniz zaman bir parti çevre barajını aşarsa diğer partilerde o çevrede o barajı aşamazsa barajı aşan parti o çevredeki geçerli oyların azınlığını almış olsa bile o çevredeki bütün milletvekilliklerini kazanacak. Diğer partiler barajı aşamadığı için. O çevredeki seçmen çoğunluğu azınlığın seçtiği milletvekilleriyle temsil edilmek durumunda kalacak. Bu durum bir seçim çevresi için değil ama ülkedeki seçim çevreleri için gerçekleşebilir. AYM'ne gör böyle bir durum demokratik bir yönetim olarak adlandırılmaz. Baraj hükümleri seçim sonuçlarını yapay bir biçimde değiştiriyor. Seçim kotasının altında kalan seçmenlerin hakkını adayların da seçilme hakkını zedeleyen bir durum ortaya çıkıyor bu çevre barajı uygulaması ile. Partinin seçimde topladığı oyların gücü oranında değerlendirilmemesi hem anayasada yer alan siyasal partilerin serbest faaliyetlerini olumsuz etkiler hem de yine anayasada yer alan siyasal partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğu ilkesiyle bağdaşmaz sonucuna vararak çevre barajına ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Bunun sonucunda TBMM, seçim sistemine ilişkin başka bir düzenleme yapmadı ve 1980'e kadar barajsız D'Hondt sistemi uygulandı. İlk genel seçim 1983 yılında yapıldı. Çifte barajlı D'Hondt sistemini öngören bir seçim kanunu vardı. 1. %10 ülke barajı, 2. Bir seçim çevresinde milletvekili dağıtımında göz önünde bulundurulabilmesi için o siyasal partinin aynı zamanda seçim çevresi barajını da aşması gerekiyordu. Seçim çevresi ne kadar küçültülürse haliyle çevre barajı o kadar büyür, küçük partiler milletvekilliği dağılımında göz önünde bulundurulmaz. Seçim çevrelerinin küçültülmesi, kontenjan adaylığı, seçim çevresi barajı saptanırken bölme işleminin bir eksikliği ile yapılması yani 6 milletvekilliği çıkarılacaksa bölme işleminin 5 ile yapılması,

amaç seçim çevresi barajını yükseltmek. O seçim çevresinde küçük partilerin milletvekilliği çıkartabilmesini engellemek, az milletvekilliği çıkarmasını sağlamak.

Karma sistemin yani çifte barajlı artık kontenjanlı D'Hondt sistemi, bu sistemin anayasaya aykırılığı AYM önün getirildi. AYM, 1987/27 Karar sayısıyla, 1987/11 Esas sayılı kararı ile 1968 yılındaki yaklaşımını tamamen değiştirdi. 1987 Yılındaki kararında anayasa, tercihi yasa koyucuya bırakmış. Yani hangi seçim sisteminin parlamento seçimlerinde uygulanacağı konusunda sessiz kalmış. AYM'ye göre seçim yasaları siyasi tercihlerin somutlaşmış belgesidir. Seçim sistemlerinden kötü yargısına varmak anayasaya uygunluk denetiminin konusu dışındadır. Bölme işleminin parti ayrımı gözetilmeksizin yapıldığı görülmekte. Bu da gösteriyor ki eşitlik ilkesine aykırı bir durum yok. Bir seçim sistemi anayasaya aykırıdır ya da değildir diyemez. AYM'ne göre kontenjan adayları için öngörülen dar bölgesi sistemde küçük partilerin şansı çok azdır. Bu karma sistemi getiren kanun hükmünü anayasaya aykırı bulmuyor. Bunun sonucunda 1995 yılında hem anayasada hem de seçim kanununda önemli değişiklikler yapıldı. 1995 Yılında Anayasanın 67.maddesine yeni bir fıkra eklendi. Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Anayasa koyucu ne saf nisbi temsil ne de saf çoğunluk sistemini benimseyemeyeceğini belirtiyor. Buna karşılık milli bakiye gibi nisbi çoğunluk sisteminin saf biçimde uygulandığı seçim sistemlerinde tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Seçmenin tercihleri büyük ölçüde parlamento ya yansıtılıyor. Buna karşılık parlamento çok sayıda siyasal partinin yer aldığı bir meclis haline geldiği için tek bir siyasal partinin hükümeti kurması ya da istikrarlı yönetimlerin oluşturulması olasılığı düşüyor. 1995 Yılında 67.maddeye getirilen bu düzenleme ne saf çoğunluk ne de nisbi temsil sistemine dayalı bir seçim sisteminin belirlenemeyeceği biçimde yorumlanmalı. İkisinin arasında bir seçim sistemi olmalı ki 67.maddeye aykırılık oluşmasın. 1995 Anayasa değişikliği seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin bu değişikliklerin yürürlüğe girdikten sonraki 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmamasına ilişkin düzenlemeyi de getirmişti. Amaç parlamentoda çoğunluğu bulunduran siyasal partinin kendi lehine seçim kanununda değişiklik yapmasını engellemek amacıyla idi. Seçim kanununu, seçim takviminin başlangıcı olarak alırsak bu değişiklikler 31 Mart 2022 de yapılmıştı. Dolayısıyla seçim kanunundaki değişikliklerin bu seçime uygulanmayacağı sonucuna varırız. Seçim bir bütündür. Dolayısıyla, bu değişikliklerin de seçim takviminin başladığı anda ve 1 yıllık yasak süresinin de seçim takviminin de başladığı andan itibaren olması gerekir. 1995 Yılında hem anayasada hem de milletvekilliği seçim kanununda değişiklik yapıldı. Çifte barajlı seçim sistemi aynen korundu. 550 Milletvekilliğinin belirlenmesinde seçim çevresinin belirlenmesinde ülke seçim çevresi olarak belirlenmesi esası getirildi.

Amaç, zaten çifte barajlı D'Hondt sistemi büyük partilerin lehine çalışan bir sistem. Bunu dengelemek için 100 milletvekili bakımından seçim çevresi ulusal seçim çevresi oldu. Böylelikle 100 milletvekili için %10 ülke barajını aşan küçük siyasal partilerde milletvekili çıkarabilsin. Bu şekilde seçmenin iradesi de parlamento ya yansiyabilsin. Bu yasal düzenleme için AYM'ne başvuruldu. Karar 1995/59. AYM, bir önceki kararında seçim sistemi yasa koyucunun takdirindedir, buna karışmam" demişti. 1995 yılındaki kararında 1961 yılındaki kararına geri döndü. Seçim sisteminin aynı zamanda anayasaya uygunluk denetiminde olduğu sonucuna vardı. Bu yaklaşımda aynı yıl yapılan anayasa değişikliklerinde payının olduğunu söyleyebiliriz. AYM, ülke barajını anayasaya aykırı bulmadı. Seçim çevresi barajını anayasaya aykırı buldu. Yönetimde istikrarı sağlamak için ülke barajı öngörülmüşken ayrıca her seçim çevresinde birde seçim barajı öngörülmesi temsilde adalet ilkesi ile bağdaşmaz. Kaldı ki D'Hondt sistemi de kendi içinde bir baraj taşıyor. Seçim çevresi barajı anayasanın 67.maddesindeki seçim sistemleri temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bir arada bağdaştıracak olmalı biçimindeki düzenlemeye aykırı olur diyor ve iptal etti. İkinci olarak kamuoyunda 100 milletvekilliği olarak bilinen milletvekilliğinin seçim yöntemini anayasaya uygunluğunu inceledi. Milletvekilliği ile seçim bölgesindeki bağın siyasal partilerin yetkili kurulmasına ilişkin bir kural AYM'de bulunmamaktadır. Ayrıca milletvekili, bölgesinden aldığı oylarla seçilmek zorundadır. Bu sebeple anayasanın hem 80.maddesine hem de 75.maddesine aykırı olduğu için iptal etti. 75.Madde milletvekilliği sayısını 550 milletvekili olarak belirlemişti. Bu 2 anayasal düzenlemenin milletvekilleri sınıflandırıp değişik biçimde adlandırmaya uygun olmadığını söylüyor. Milletvekillerinin 1 ya da birkaçının başka adla seçmenin ve ayırmanın anayasaya aykırılık oluşturacağını belirterek iptal ediyor. Bunun sonucunda 550 milletvekili %10 ülke seçim barajının uygulandığı bir D'Hondt sistemine dönüşüyor. Anayasa mahkemesi, seçim çevresi barajının temsilde adalet ilkesiyle bağdaşmadığını belirtiyor ama %10 ülke barajının temsilde adalet ilkesi ile bağdaştığını iddia ediyor. Bunu neye göre tercih ettiği ve böyle bir tercih yapıp yapamayacağı tartışılacak bir durumdur. İkinci olarak ülke seçim çevresi göz önünde bulundurularak 100 milletvekillinin belirlenmesine

ilişkin anayasaya aykırılık gerekçeleri de doyurucu değil. 75. Ve 80. Maddelerden anayasaya aykırılığı çıkarmak hiç mümkün değil. Buna ilişkin AİHM'ne de başvuruldu. 2002 Yılında sandıkta oy kullanan % 46 seçmen mecliste temsil edilmedi. AİHM, seçim sisteminin denetiminde 3 unsurun olup olmadığına bakılır.

1. Seçim sistemine ilişkin kural bazı kişi ve grupları siyasal yaşamın dışına bırakıyor mu? Eğer böyle bir etki yaratıyorsa o zaman sözleşmeye aykırılıktan söz edilebilir.

2. Seçim sisteminin neden olduğu tutarsızlıklar keyfi bir nitelik taşıyor mu?

3. Seçim sisteminin bir siyasal parti ya da adayı, diğerlerinin zararına olacak biçimde bir seçim çıkarı sağlayarak destekleme eğiliminde bir eğilim mi? Diyor ki; Türkiye'deki seçim sistemi üniter devlet ilkesine dayanan bir seçim sistemi. Bu durum aslen bölgesel temele dayalı partilere, ülke genelinde aldıkları oylar hesaba katılmadan parlamentoda temsil güvencesi sağlayan bir seçim sistemini kabul etme yükümlülüğünü getirmiyor. 2. Olarak, %10 barajı hükümet istikrarını güçlendirmeye yönelik bir baraj. Dolayısıyla bir meşru amaç taşıyor. Avrupa Konseyi içinde en yüksek seçim barajı Türkiye'ye ait. Ancak bu kadar yüksek olmasına rağmen seçimlerde siyasal alternatiflerin çıkması da engel bir unsur taşıyor. Bu konuda ulusal makamlar takdir yetkisini aşmamış. AİHM, seçim sistemine ilişkin kuralı sözleşmeye aykırı olmadığına karar veriyor. AİHM, bu konuya müdahale etmek istemiyor ve Avrupa Konseyi içinde yer alan devletler arasında genel bir eğilimin ortaya çıkmadığını söylüyor. Takdir yetkisinin ilgili bu konuda taraf devletlere ait olduğunu söylüyor. Oysaki gerekçeleri tartışmaya açık. Demokrasi siyasal partilere dayalı bir düzen. Bir siyasal partinin, sırf baraj engelini aşmak için bağımsız milletvekilleriyle seçime katılması aynı sonucu vermiyor. Üstelik bağımsız milletvekilleriyle seçime katılmak bir parti olarak seçime katılmaktan çok daha zayıf bir biçimde parlamentoya girme sonucunu doğuruyor. Bu konularda AİHM'nin kararı eleştiriye açık olmuştur.

Türkiye'de seçimler nisbi temsil sistemine göre yapılıyor. Bu sistemin D'Hondt yöntemine göre belirleniyor.

İkinci olarak ülke barajının uygulandığı bir D'Hondt sistemidir. 1983 milletvekili seçim kanunu uyarınca bunun 1995 'e kadar bunun çifte baraj sistemi biçiminde uygulanmıştı. Hem %10 ülke barajı hem de her seçim çevresinde ülke barajını aşması gerekiyor ki bir siyasal partinin TBMM'de temsil edilebilmesi için. 1995 yılında AYM kararı ile seçim çevresi barajı iptal edilmişti. 2018 Yılında milletvekili seçim kanununda yapılan değişikliklere kadar %10 barajlı ülke barajlı D'Hondt sistemi uygulanıyordu. 2018 yılında seçim kanununda yapılan değişiklikle siyasal partilerin ittifaklar kürara, ittifaklar biçiminde seçimlere girebilmesi olanağı. O zamana kadar böyle bir olanak yoktu. O zamana kadar küçük partilerin parlamentoda temsil edilmesi mümkün değildi. AİHM ve Venedik Komisyonunun raporlarında %10 ülke barajının hiçbir demokratik ülkede olmayan yükseklikte olduğunu kabul etti. Nisbi temsil sistemini benimseyen demokratik devletlerde ülke barajlarının %5 ve altı olduğunu görüyoruz. Çoğunluk sistemini benimseyen ülkelerde de böyle bir baraj yok. Türkiye 87 seçim çevresine ayrılmıştır. Her il bir milletvekilliği çıkarıyor. Bunun dışındaki milletvekillikleri illerin nüfusu oranında paylaştırılıyor. Bu paylaştırmayı YSK yapıyor. 2839 sayılı Milletvekili seçim kanununa göre 18'e kadar milletvekili çıkarak iller 1 seçim çevresi, 18-35 arasında milletvekili çıkaracak iller 2 seçim çevresine, 36 ve daha üzeri milletvekili çıkaracak iller ise 3 seçim çevresine ayrılıyor. Ankara ve İstanbul 3 seçim çevresinden oluşuyor. Bursa ve İzmir ise 2 seçim çevresinden oluşuyor. Diğer kalan illerin her birinin 1 seçim çevresi vardır. Bayburt ve Tunceli 1'er milletvekili çıkarıyor. İttifak biçiminde seçimlere girmenin avantajları; ülke barajının hesaplanmasında her bir siyasal partinin aldığı oy değil, ittifak içindeyse siyasal parti o ittifakın siyasal partilerinin toplamının almış olduğu oy göz önünde bulunduruluyor. İttifak yapılabilmesi için bir ittifak protokolünün yapılması gerekiyor. Bu protokolün de seçimin başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde YSK'ya bildirilmesi gerekiyor. 2022 Yılında yapılan bazı değişiklikler yapılmıştı. 31 Mart 2022 tarihli ve 7393 sayılı kanunla yapılan değişiklikler. Seçim sistemi ve serbest ve adil seçim ilkesi bakımından göz önünde bulundurulacak değişiklikler; 1. Ülke seçim barajı %7'ye indiriliyor. 1983'den beri ilk kez 14 Mayıs'taki seçimlerde ülke seçim barajı %7 olarak uygulanacak. 2839 Sayılı kanunun 34. Maddesinde yapılan ittifaklara ilişkin değişiklik önemli bir değişiklik. 2022 Değişikliği ile ittifak artık yalnızca ülke barajının aşılp aşılmaması konusunda göz önünde bulundurulacak bir unsurla sınırlanıyor. İttifak biçimde seçime girmenin her hangi bir seçim çevresinde o ittifaktaki siyasal partiler bakımından kolaylaştırıcı bir unsur olmaktan çıkıyor. Eskiden ittifakın bütününün aldığı oy göz önünde bulunduruluyordu, o seçim çevresindeki milletvekilliklerinin dağılımında. Dolayısıyla düşük oylu siyasal partilerin ittifak içinde yer alması milletvekili çıkarmak bakımından önem taşıyordu. Artık seçim çevrelerinde milletvekilliği dağıtılırken ittifakın aldığı oy değil ittifak içinde olan her bir siyasal partinin bireysel olarak almış oldukları oy dikkate alınacağı için az oy alan siyasal partilerin milletvekilliği çıkarması gerçekten güçleştirilmiş oluyor. Küçük siyasal partilerin TBMM'de temsilini olanaksız hale getiren bir yasa değişikliğidir. 2018 Yılında yapılan değişiklikle bir siyasal partinin

seçime girebilmesi 2 koşuldan birini yerine getirmesine bağlıyordu. 1. Seçimlerden en az 6 ay önce illerin en az yarısında örgütlenmiş ve büyük kongresini yapmış olması 2. TBMM’de grubu bulunma koşulu. 2018 Yılındaki değişiklikten hemen sonra İyi parti 1. Koşulu gerçekleştiriyordu. CHP’nin milletvekilliği desteği ile 2. Koşula sağlayarak seçimlere katılabilme imkanı elde etmişti 2022 Yılında yapılan kanun değişikliği bu 2.şartı kaldırdı. Artık bugün yalnızca 6 ay önce 81 ilin yarısında örgütlenme ve büyük kongreyi yapma koşulunu taşıyan siyasal partiler genel seçimlerde yarışma imkanını elde edebilecekler. 3. Önemli değişiklik, sandık kurulu üyeliğine bir başka partinin üyesinin gösterilemeyecek olması. Adil ve serbest seçim ilkesinin gerçekleştirilmesi bakımından son derece sakıncalı bir düzenlemedir. Çünkü eskiden o seçim çevresinde örgütlenmesi yeterli olmayan küçük siyasal partiler, daha iyi örgütlenmiş daha çok üyeye sahip siyasal partilerden destek alıyorlar. Sandık kurulu o seçimlerin adil bir seçim olmasını sağlayan önemli bir kuruldur. Bu kurula bir önceki seçimlerde en çok oyu almış 5 siyasal partinin temsilcisi katılıyor ve bir de başkan bulunur. Daha önce bu 5 parti arasında bir alışveriş ilişkisi olabiliyordu sandık kurulunun oluşturulması bakımından. Bu engelleniyor. İl ve ilçe seçim kurullarında kıdem esasına göre ad çekme usulüyle kurumlarındaki yargıçların üyelerinin kıdem esasına göre kıdem esasına göre değil de ad çekme usulü ile belirlenmesinin getirilmesi. 2022 Yasa değişikliğine kadar il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak yargıçlar o il ya da ilçedeki en kıdemli yargıçlar arasından seçiliyordu. Kıdemli yargıç olabilmek için belli bir yıl boyunca bu görevi yerine getirmek gerekiyordu yani deneyimli olmak anlamına geliyordu. İkincisi belli bir aşamaya gelmiş olduğu için dışarıdan gelecek etkilere daha az kapalı olacağı düşünülüyordu. Bu düzenleme 1961 anayasası döneminden beri yürürlükte olan bir hükümdü. 2022 Yasa değişikliği bunu kaldırdı ve ad çekme usulünü getirdi. Seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek bir düzenleme. Son olarak 2022 değişiklikleri CB’nı propaganda yasakları dışında tutuyor. CB’nın propaganda yasaklarının dışında tutulması hele bir de yürütmenin tek sahibi olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda adil seçim ilkesini zedelemeye son derece uygun bir düzenlemedir. Bütün bu düzenlemeler ana muhalefet partisi tarafından anayasaya aykırılık iddiasıyla AYM’nin önüne gitti. AYM 2022 yılında verdiği kararla bu düzenlemelerin hiçbirini anayasaya aykırı bulmadı.

Nisbi Temsil Sistemi: çok partili bir siyasal yaşama olanak tanıyan bir seçim sistemidir. Siyasal partilerin sayısını arttırıcı bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Bunu söylerken, ülke barajının makul bir düzeyde olduğunu kabul ederek söylüyoruz. 1983 yılındaki seçim sistemi ile Milli Güvenlik Kurulunun kafasında 2,5 parti sistemi vardı. Bu sistemin, özellikle seçmenin yaptığı tercihlerin adil bir biçimde ya da büyük bir sadakatle parlamentoya yansıtan bir seçim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Eksik temsil ve kutuplaşma, nisbi temsil sisteminde genellikle olmaz. Bu sistemde bağımsızların seçilmesi güçtür. Bu sistemin benimsendiği ülkelerde seçmen, genellikle kişiye değil siyasal partiye göre oyunu kullanır.

Tek Turlu Çoğunluk Sistemi: Bu sistem parti sayısını azaltıcı bir rol oynar. Bunu, bu sistemin uygulandığı bütün ülkelerde görebiliyoruz. ABD, Yeni Zelanda, birleşik Krallık’ta. Burada partilerde birbirlerinden de bağımsızdırlar. Seçim öncesi herhangi bir anlaşma ve ittifakın olmadığını görüyoruz. Seçmen oyunu en yararlı biçimde kullanıyor. Yani iktidarı elde edebileceğini düşündüğü siyasal partilerden birine oyunu veriyor. Seçmenin bu davranışı çerçevesinde iki büyük partiden biride parlamentoda salt çoğunluğu elde ederek tek başına iktidar oluyor. Bu seçim sisteminin en önemli olumsuz yönü, bu iki büyük partinin hak ettiğinden çok daha büyük bir çoğunluğu parlamentoda elde etmesini sağlıyor. Türkiye’de de 1946-57 arasında tek turlu çoğunluk sistemi uygulanıyordu. 1957 Seçimlerinde DP, oyların %48’ini almasına rağmen meclisteki sandalyenin %70’ini elde etmiş. Muhalefet partileri oyların %52’sini almasına rağmen mecliste %30 milletvekilliği ile temsil edilmişti.

İki Turlu Çoğunluk Sistemi: Tıpkı nisbi temsil sisteminde olduğu gibi çok partili bir siyasal yaşama yol açıyor. İlk turda seçmen, gönlündeki siyasal partiye oy veriyor. İkinci turda ise birbirine yakın siyasal eğilimlerde olan siyasal partiler birbirleriyle anlaşıyorlar. Ya da kendisine yakın olan bir siyasal partiyi destekleyebileceklerini ilan ediyorlar. Birbirlerine yakın olan siyasal partileri birbirlerine bağımlı kılan bir seçim sistemidir. Bu sebeple 2.turda iş birliği yapma olasılığına karşı birbirlerine yakın olan siyasal partiler hiçbir zaman birbirlerine karşı kutuplaştırmacı dil kullanmıyorlar. Bu da siyasal partilerin birbirlerini ötekileştirici bir dil kullanmamalarına neden oluyor. Bu seçim sisteminin benimsendiği yerlerde küçük seçim bölgesinde adayların kişisel nitelikleri seçimleri açısından parti örgütünün faaliyetinden daha etkili oluyor. Nisbi temsil sisteminde adaydan çok partiye oy veriliyordu.

Soruya cevap: Anayasa bir istisna hükmü getirmemiş. Hali hazırdaki CB için 2 kere seçilme koşulu uygulanmaz dememiş. Anayasa açık bir şekilde bir kişi en çok 2 defa seçilebilir demiş. Üstelik seçilecek makamın adında da bir değişiklik yok. 2017 Anayasa değişikliğinden önce CB, 2017 Anayasa değişikliği ile de CB. Örneğin 2017 Anayasa değişikliği ile makamın adı Başkan olsaydı, o zaman artık bu yeni bir makam haliyle önceki seçimler burada sayılmaz denilebilirdi. Oysa ki böyle bir şey denilmedi. Benzer bir sonuca Abdullah Gül zamanında da varılmıştı. Abdullah Gül 2007 de CB seçildi. Hemen arkasından anayasa değişikliği yapıldı. Bir kişi en çok 2 defa CB seçilebilir hükmü getirildi, halk tarafından CB seçilecek. Bir kişi de en çok 2 defa seçilebilir denildi. O zaman çıkarılan bir yasayla Abdullah Gül'ün 2. defa seçilmesi mümkün kılınmadı. İlk de 7 yıl görev yapmıştı. İkinci defa seçilirse, 10 yıldan daha uzun CB olarak görev yapacaktı. Gerekçe buydu. Yeni bir sistem getirildi, daha önce CB yapmış olanlar bakımından bir sorun olmaz. Yeni bir sistem getirildi. Daha önce CB yapmış olanlar bakımından bir sorun olmaz. Bir kişinin 2 defa CB seçilmesi, bu doğrudan halk tarafından seçim usulü yeni geldiği için sıfırdan başlar. Bu daha önce CB yapmış olan kişiler bakımından da geçerlidir. Onlarda CB'liğine aday olabilir denildi. Ama bu görüş o zaman reddedildi. Burada çözüm, geçici bir hüküm getirmek olabilirdi. Söz konusu bu hüküm, halen görev yapan CB bakımından uygulanmaz ya da önceden görev yapmış CB bakımından uygulanmaz olabilirdi. Veya makamın adı değiştirilirdi. 3. Defa CB olarak halk tarafından hali hazırdaki CB'nin seçilmesi anayasaya aykırıdır. Hem CB olduğu için hem de daha önce arka arkaya 2 defa seçildiği için.

Siyasal Parti: Üyelerin düşünce ve çıkarlarını gerçekleştirmek için iktidarı kısmen veya tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan örgütlü grup. Siyasal partinin bazı özellikleri bir arada bulundurması gerekiyor. 1. Süreklilik unsuru: bu örgütlenmenin geçici değil sürekli bir nitelik taşıması gerekiyor. 2. Örgütlenme unsuru: Ülke çapında olmak zorunda değil ama belli bir alanda siyasi partinin örgütlenmesi şart. 3. Siyasal iktidarı kullanma isteği: yani kısmen ya da tamamen siyasi iktidarı belli bir süre için elde etme isteği taşıması gerekiyor. Bu önemli bir unsur olup, siyasi partiyi dernek, sendika gibi diğer örgütlenmelerden ayıran unsurdur. Diğer örgütlenmelerde, üyelerinin çıkarları çerçevesinde bu çıkarları gerçekleştirme amacıyla kurulan ve çalışan örgütlerdir. Oysa siyasi partiler, diğer dernek, sendikalardan farklı olarak siyasi iktidarı etkilemeyi değil siyasi iktidarı kısmen ya da tamamen belli bir süre için etki etmeyi amaçlayan örgütlerdir. Yine siyasi partileri, diğer örgütlenme biçimlerinden ayıran bir başka özellik de, seçim yoluyla halkın desteğini elde etme amacına yönelmiş olmalarıdır. Yani siyasi iktidarı, herhangi bir yolla değil seçim yoluyla, halkı kendilerine oy vermelerini sağlamak, bu yolla seçmeni ikna etmek yoluyla gerçekleştirmeyi amaçlaması gerekiyor. Bu siyasi partiyi diğer örgütlenme biçimlerinden ayıran en önemli unsurlardan birisi oluyor. 1983 Yılında kabul edilen siyasi partiler kanunu, çeşitli değişikliklerle günümüzde de yürürlükte de olan bir kanundur. Bu kanunun 3.maddesi siyasi partinin tanımını yapıyor “siyasi partiler, anayasa ve kanunlara uygun olarak, CB, milletvekilliği ve mahalli idare seçimleri yoluyla tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacı güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır”. Bu kanunun getirdiği unsurlar; 1. Amaç: bakımından ulusal iradenin oluşmasını sağlamayı belirtiyor. Siyasi partiler aldıkları oylar ölçüsünde ulusal iradenin TBMM'nde oluşmasına katkı sağlarlar. Seçimler yoluyla ulusal iradenin oluşmasına katkı sağlıyorlar. 2. Bu seçimler, CB, milletvekilliği ve yerel yönetimler ile oluyor. 3. Faaliyet alanı bütün ülkedir. Günümüzde çağdaş demokrasilerde siyasi partilere ülke çapında örgütlenme zorunluluğunun getirilmediğini görüyoruz. Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği Partisi, yalnızca Bavyera eyaletinde örgütlü bir partidir. Böyle bir koşulun demokratik ülkelerdeki genel eğilimi yansıtmayan yansıtmayan bir koşul olduğunu söyleyebiliriz. 4. Tüzel kişiliğe sahip olması tabii ki önemli. Diğer demokratik devletlerde de siyasi partilerin tüzel kişilikleri vardır. Bu onları bağımsız bir şekilde iş görebilmesini sağlayan bir özellik. 5. Amaç: Demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş bir medeniyet düzenine ulaşmasını sağlamak. Ülkemizde her siyasi partinin böyle bir amaç taşımadığını da görüyoruz. Bu bütün siyasi partiler tarafından elde edilmesi gereken bir amaç olmayabilir. Siyasi partileri ortaya çıkması, büyük halk yığınları yani seçmeni etkilemek, örgütlemek amacıyla gerçekleşiyor. 17.YY'da itibaren bugün anladığımız anlamda siyasi partilerin çekirdeğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Dünyada klasik parlamenter sistemin ortaya çıktığı yer Birleşik Krallıktır. Haliyle siyasi partilerin, ilk ortaya çıktığı yer burasıdır. 17. Yy'da İngiltere'de parlamentoda ortaya çıkan 2 grup vardı.

The court eroup : Kral ve kilisenin yanında olan parlamento üyelerinden oluşan gruba verilen isim. The country eroup ise burjuva sınıfının temsilcilerinden oluşan ve haliyle sınırlı bir iktidar, kralın yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini düşünen parlamentodaki milletvekillerinden oluşan grup. Bu gruplar başlangıçta bugünkü anladığımız anlamda örgütlü siyasal partiler gibi değil. Birbirine yakın görüşleri paylaşan kişilerin parlamento içinde yemeklerde bir araya geldikleri gruplar. Seçme ve seçilme hakkında yapılan iyileştirmeler sonrasında bugünkü anlamda siyasal partilere dönüşüyorlar. Daha geniş kitlelere seçme ve seçilme hakkına, 1832-1867 yıllarında yapılan yasalarla tanınıyor. Asıl önemlisi 1872 yılında kabul edilen gizli oy ilkesinin getirilmesiyle birlikte. Bu reformlar, seçme ve seçilme hakkında ve gizli oy ilkesinin getirilmesi hakkında reformlar artık avam kamarasına seçilmek isteyen adayların kişisel nüfuslarıyla seçmenlerden oy toplamalarını güçleştirdi. Dolayısıyla bu adaylar önce parlamento içinde sonra parlamento dışında örgütlenmeye başladı. Amaç, adayları seçmene tanıtmak ve seçmenden oy istemek. Artık yüz yüze bir iletişim ile her bir adaya kendisini tanıtmayı seçmen kitlesinin genişlemesiyle mümkün olmadığı için bunun bir örgütlü çaba ile yapılması gereksinimi ortaya çıktı. Siyasal partiler bu gereksinimin bir sonucudur. İngiltere’de ilk ortaya çıkan parti Muhafazakar Parti. 1834 Yılında o dönemin başbakanı adayını dünyada ilk kez seçim bildirgesi okudu. Kurumlardaki iyi olan her şeyin korunması anlayışı muhafazakar olma siyaseti anlamına geldi. 1850-60 süreç içerisinde Liberal parti kuruldu. Amacı, kralın yetkilerinin sınırlandırılması, aynı zamanda liberal ekonomi ilkelerinin benimsenmesini amaçlayan kişilerin bir araya gelmesiyle kurulan bir parti. 20. YY’ın başın kadar İngiltere’de avam kamarası bu iki partinin egemenliği altında faaliyet gösterdi. 3. Parti olan İşçi Partisi 1900 yılında ortaya çıktı. Sendikalar işçi temsilcisi komitesini kurdular. Bu komitenin amacı olabildiği kadar çok işçi temsilcisini avam kamarasına seçtirmektir. Bir 6 yıl sonra işçi partisi olarak adını değiştirdiler. 1920’lere gelindiğinde avam kamarasındaki 2 büyük partiden biri oldu Muhafazakar parti ile. Bugünkü anlamda ilk siyasal partinin ortaya çıktığı ülke ABD’dir. Devlet 1776 yılında kurulduğundan itibaren bugün anladığımız anlamda siyasal partilerin oluşmaya başladığını görüyoruz. 2 Siyasal akım var, bunlar Federalistler ve Demokrat Cumhuriyetçiler. Daha Federalistler kendilerini Cumhuriyetçi, Demokrat Cumhuriyetçiler ise kendilerini Demokrat olarak adlandırmaya başladılar. Bu iki partiyi birbirinden ayıran özellik, Cumhuriyetçiler kölelik düzenini istemiyordu. Buna karşılık Demokrat Cumhuriyetçiler, köle düzenine dayanan ekonomik ve toplumsal yaşam taraftarıydı. Neden ABD’de çağdaş siyasal partiler ortaya çıktı sorusunun cevabı, en başta gelen nedenlerinden birisi seçme ve seçilme hakkına ilişkin iyileştirmelerin, reformların ABD’de yapılmış olmasıdır. ABD’de köleliğin kaldırılması ve zencilere de anayasal düzeyde tanınması 1870 yılına denk geliyor.

Türkiye’de Siyasal Partiler:

Demokratik düzen, anayasacılık geç ortaya çıktığı için haliyle çağdaş anlamda siyasal partilerde batı demokrasilerinden geç oluştu. İlk siyasal amaçlı örgütler 19.YY’da azınlıklar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türkler tarafından kurulan siyasal amaçlı örgütler ise gizli olarak faaliyet gösteriyorlar. Açık bir şekilde ve siyasal faaliyette bulunabilen örgütler değil. İlk anayasa olan 1876 Kanuni Esasi’nin ilk biçiminde dernek kurma ve örgütlenme özgürlüğüne yer verilmiyor. 1865’de kurulan Yeni Osmanlılar örgütü vardı. 1876 Kanuni Esasi kabul edildikten sonra kabul edilen örgütler var. 1892 de Paris’de kurulan Teşebbüsi Şahsi ademi merkezîyet cemiyeti, 1906 Selanik’te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve İttihak ve Terakki Cemiyeti. Bunlar çağdaş anlamda siyasal parti özelliği taşımıyordu. 1909 Yılındaki yapılan değişiklikler ve aynı yıl çıkarılan kanunla dernek kurmada izne de bağlanmadı. 1908’den itibaren özgürleşme ile birlikte Abdülhamit rejiminin ortadan kaldırılması ile ortaya çıkmışlardır. Milli mücadele döneminde, gerçek anlamda siyasal parti bulunmamaktaydı. 1920’den itibaren birbirlerine yakın düşünen çeşitli milletvekillerinin varlığını biliyoruz. 1920 Den sonra Meclis dışında faaliyet gösteren partiler var. Örneğin amele fırkası gibi çok sayıda parti bulunmaktaydı. 1921’de 1.grup Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu kuruluyor. 1922’de buna karşı 2. Grup kuruluyor. Parlamento içinde görülmekte olan işlevleri bu iki grup yapıyor. Nitekim 1.Grup 1923 yılında Mustafa Kemal tarafından Halk Fırkası adını alıyor. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası adına dönüşüyor. 1924 Anayasası, siyasal partiye ilişkin özel bir düzenleme getirmiyor. Ama örgütlenme özgürlüğünü getiriyor. 1924 Anayasasının genel anlayışı, bütün hak ve özgürlükleri kanun çerçevesinde tanımak ve bu kanunlarda yapılacak düzenlemelere ilişkin olarak da herhangi bir kanun koyucuya yönelik sınırlama getirme. İşte bu çerçevede dernekleşme özgürlüğü tanındığı için de siyasal partilerin güdümlü olarak oluşturulduğunu görüyoruz. 1924’de Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 1930’da yine güdümlü olarak Serbest Fırka kuruldu. Bunun dışında bölgesel nitelikte partilerde kuruldu. Siyasal partiler 1961 anayasasına kadar öncelikle herhangi bir dernek gibi

kuruluyor ve dernekler kanunu hükümlerine bağlıydılar. Siyasal partiler, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bunların kapatılması ve faaliyetine ilişkin denetimin sıkı biçimde düzenlendiğini ve bu konuda Bakanlar Kuruluna çok geniş yetkiler tanındığını görüyoruz. 1938'e kadar dernek kurma yetkisi tanınıyordu ancak fiilen bu yetkinin kullanılmadığını söyleyebiliriz. 1938 Yılında dernekler kanununda bir değişiklik yapıldı ve dernek ve siyasal parti kurulabilmesi için önceden izin alma koşulu getirildi. Bu demokratik bir ilke değildi. Üstelik dernek ve siyasal partilerin denetlenmesi ve kapatılması yetkisi de Bakanlar Kuruluna verildi. 1945'den itibaren siyasal partilerin kurulmaya başlandığını görüyoruz. Siyasal yaşam 1945 de başladı. İlk parti Milli Kalkınma Partisi ve arkasından 1946'da Demokrat Parti kuruldu. İlk defa TBMM iç tüzüğünde 1947 yılında yapılan değişiklikle siyasal partiler için kurallar getirildi. 1946 yılında yapılan yasa değişikliği ile ön izin almadan siyasal partilerin kurulabilmesi sağlandı. Siyasal partilere ilişkin asıl önemli aşama 1961 anayasasıdır. Bu anayasal siyasal partilere öyle sıradan bir dernek olmaktan çıkardı. Siyasal partilere anayasal bir düzenleme getirdi. İlk defa bu anayasa siyasal partiler demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurudurlar ibaresini getirdi. Siyasal partilerin olmadığı düzeni demokratik bir düzen olarak adlandırmamız mümkün değildir. Siyasal partilerin çalışması, onlara getirilen sınırlamalar 61 anayasasında ayrıntılı biçimde yer aldı. Bunların kapatılmasını AYM'nin yargılamasına ve kararına bağladı. İlk defa getirilen bu yenilik siyasal partiler bakımından çok önemli bir güvence taşıyordu. 61 Anayasası demokratik devlet ilkesi ve bu ilkenin asli bir unsuru olan siyasal partiler bakımından bütün çağdaş demokrasilerin sahip olduğu unsurları ülkemizdeki demokratik rejime kazandırmış oldu. 1961 Anayasasının hem demokratik devlet ilkesi hem de siyasal partilerin demokratik yaşam biçimindeki yeri bakımından son derece önemli bir anayasadır.

21 Mart 2023

Siyasal Partilerin Sınıflandırılması:

1. Siyasal partilerin yapısına göre: Duverger'in sınıflamasına göre -Kadro (Komite) partileri- kitle partileri olarak tanımlanırlar.

1. Komite partileri: sürekli olarak çalışan partiler değildir. Seçimlere hazırlanma ve seçimler sırasında kampanya yürütmeye sınırlı olarak faaliyette bulunan siyasal partilerdir. Bunlar çok geniş sayıda üyeye sahip partiler de değildir. Bu partiler bakımından parti üyesi olmak niteliksel bir önem taşır. Parti üyesi olabilmek için belli ölçütlere sahip olması gerekir bir kişinin. Bu özellikler; kamuoyunda adı, prestiji olan bir kişi olacak ya da çeşitli gruplarla siyasetle ilişkisi olan kişi olacak. Aynı zamanda paralı olmalıdır. Veya bir alanda uzman olacak. Kadro partileri bakımından, partinin üye sayısı hiç önem taşımaz. Tam tersine parti üyelerinin niteliklerine bakılır, seçilerek parti üyesi yapılır. 18.-19.yy'da ortaya çıkan bu siyasal partiler kadro partileridir.

2. Kitle Partisi: Kitle partilerinin ortaya çıkma nedeni; 19.yy'ın 2.yarisından itibaren demokrasiyi benimseyen bütün demokrasilerde görülen bir eğilimle ortaya çıktı. O da daha geniş kitleler için seçme ve seçilme hakkına dönük reformların yapılmasıdır. Bunun sonucunda, kadro partisi olan siyasal partiler ya da adaylar tek tek kişisel ilişkileriyle seçmenleri etkileyemez hale geldiler. Bunun sonucunda daha örgütlü organizasyonun ortaya çıkması ihtiyacı doğdu. 2. Yine 19.yy'ın 2.yarisından itibaren işçi sınıfının parlamentoda temsilci sahibi olması yönünde çabaları kitle partisinin ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü işçi sınıfı paralı, ekonomik, siyasal alanda ilişkileri olan bir kesim değil. Bunlardan büyük paraların elde edilmesi mümkün değildi. İşçi partileri aracılığı ile farklı bir örgütlenme biçimini aldı. Olabildiği kadar çok kişiyi siyasal partiye üye yapmak, bunlardan kitle partilerinde olduğu gibi rastlantısal zaman zaman büyük miktarda bağışlar almak yerine olabildiği kadar çok üye ve her ay küçük bir oranda üyelerin partiye küçük bir aidat ödemesi biçiminde bir örgütlenme ortaya çıktı. Böylece kitle partileri seçimler dışı zamanlarda kendi örgütlerini ayakta tutmanın yolunu bulmuş oldu. 3. Kitle partilerini, kadro partilerinden ayıran bir başka yön ise, bu partilere girişinin bir takım formalitelere bağlı olması ve üyelerin aidat ödemesi gibi koşulların ortaya çıkması. Üye ile siyasal parti arasındaki ilişki, kadro partilerinde daha gevşek bir ilişkidir. İşçi partileri, kitle partileri olarak örgütlendiler 19.yy'ın sonları 20.yy'ın başlarında Kıta Avrupası'nda. Bugün kadro partilerin ABD dışında hemen hemen yok olduğunu söyleyebiliriz.

Siyasal partilerin 2.sınıflandırma; bu partilerin işlevlerine göre yapılan sınıflandırma. Buna göre 3'e ayrılırlar. *Bireysel temsil partileri, Sosyal bütünleşme partileri, Toplayıcı (veya toplayıcı) parti şeklinde.*

1. Bireysel temsil partileri: kadro partilerine benzer. Bunların faaliyetleri, seçimlerle, parlamento ve hükümetle sınırlı olan siyasal partilerdir. Bu partilerde parti disiplini bulunmuyor. Bu partiler seçimlerde aday göstermek ve o adayların seçilmelerini sağlamakla sınırlı bir örgütsel faaliyet yürütüyor. Bunun en iyi örneği günümüzde, ABD'deki partiler oluşturuyor.

2. Sosyal bütünleşme partileri: İkiye ayrılır; demokratik bütünleşme partileri ve toptan bütünleşme partileri. Demokratik bütünleşme partileri: bireysel temsil partilerinin aksine üyeleriyle sıkı ilişki içerisinde bulunan partilerdir. Siyasal parti ile o partinin üyeleri arasında, toplumun pek çok alanında sürekli bir ilişki vardır. Siyasal parti üyelerinin toplumsal ilişkileriyle yakından ilgilenen bir parti modeli. Sosyal bütünleşme partileri kendi içlerinde demokratik olup olmamalarına göre ikiye ayrılırlar. Demokratik bütünleşme ve toptan bütünleşme (totaliter) partilerinin her ikisi de kendi üyelerinin sosyal yaşamlarıyla yakın ilişki içindeler. Üyeleriyle yalnızca seçim zamanı ve seçim nedeniyle değil ama bunun dışında da düzenli ve sürekli ilişki kuran siyasal parti.

Demokratik bütünleşme partileri, kooperatif gibi, dinlenme kampları gibi, sosyal yardım kuruluşları gibi yan kuruluşlar aracılığı ile üyeleriyle düzenli ve yakın ilişki kuruyor. Kıta Avrupa'sında görüldü. Sosyalist Partilerin, Hristiyan Demokratik Partilerin kitle partiler olduğunu söyleyebiliriz.

Totaliter bütünleşme partiler olarak daha çok komünist ve faşist partiler olarak söyleyebiliriz. Bunlar ideolojik partiler olup, üyelerinin düşünce ve davranışlarının mutlak ve özdeş olmasını önemseyen partilerdir. Parti, içinde düşünsel anlamda bir çoğulculuğa izin vermiyor. Ama bunun dışında demokratik bütünleşme partileri gibi üyelerinin toplumsal yaşamına yan kuruluşlar kurmak yoluyla etki eden partilerdir.

3. Toplayıcı partiler. Alman siyaset bilimci ortaya koyuyor. 2. Dünya savaşından sonra üretim ilişkileri değişiyor. Bununla birlikte siyasal partilerin biçiminde ve yapısında da önemli değişiklikler ortaya çıkıyor. 2.Dünya Savaşından önce siyasal partilerin son derece ideolojiye dayalı keskin siyasal partilerdi. Bu savaştan sonra üretim ilişkileri değişti. Artık katı anlaşmaz topluluklardan uzlaşma toplumuna geçildi. Kitle iletişim araçlarının 2.Dünya Savaşından sonra yaygınlaşmasıyla siyasal partilerin yapısındaki dönüşümde önemli bir işlevi oldu. Kitle iletişim araçları yaygınlaştıkça aynı kişiler ve siyasal partiler bu araçlar yoluyla seçmenlere erişmesiyle iktidarın kişiselleşmesi olgusu ortaya çıktı. Artık liderler de daha söz sahibi olmaya başladılar. Liderlik denilen olgu daha önemli hale geldi. Bunun sonucunda, siyasal partiler katı ideolojik ayrımlara göre kendi programlarını belirlememeye başladı. Bunun sonucunda da siyasal partiler her türlü eğilimden kişileri kendi partilerine katmaya başladılar. Bütün eğilimlerin bir arada olduğu siyasal partiler ortaya çıkmaya başladı. Örnek 2.Dünya Savaşından sonra Alman Sosyal Demokrat Partisi, Hristiyan Demokrat Partiler bu toplayıcı partilere verilen örnektir. Türkiye'de ise Anavatan Partisi. Günümüzde bu toplayıcı partilerin ortadan kalkmadığını halen var olduğunu söyleyebiliriz.

Üçüncü bir başka sınıflama; **siyasal partilerin, disiplinli olup olmamalarına göre yapılan sınıflama.** Bu serbest parti bir başka ifade ile yumuşak ya da gevşek parti ve disiplinli parti olarak ikiye ayrılıyor. Serbest parti üyelerini, parlamentodaki milletvekillerini eğer iktidarda ise bakanlarını katı disiplinli katı disipline bağlı tutmayan partiye verilen isim. Eğer bir siyasal partide, parti disiplini yoksa siyasal partide ideolojik birlik aranmaz. Haliyle parti içinde bütün üyelerin uyması gereken kararlar alınmaz. Bu tür kararlar alınmış olsa bile üyelerin buna mutlak bir şekilde uyması beklenmez. Üyelerin, parti merkezi tarafından alınmış kararlara uymamasında herhangi bir yaptırımı olmaz. Günümüzdeki ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti, serbest partiye verilebilecek örnektir. Parti üyeleri diğer siyasal parti ile rahatlıkla uzlaşabiliyor. Fransa'da 3. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan siyasal partilerin de tarihsel olarak yumuşak partiye verilebilecek örnektir. Disiplinli parti ise tam tersine üyeler partinin tüzük ve programına sıkı biçimde bağlılar. Üyelerin tüzük ve programa aykırı biçimde davranışları parti içinde çeşitli yaptırımlara konu olabiliyor. Özellikle ideolojik partilerin sıkı parti disiplinine bağlı olduğunu belirtelim. Bütün Kıta Avrupa'sında, Birleşik Krallıkta, Latin Amerika'da ve ülkemizde siyasal partilerin disiplinli partiler olduğunu belirtelim. Ülkemizde 2820 sayılı siyasal partiler kanunu da partilerin bu disiplini katı biçimde uygulanmasına olanak veren düzenlemeler içeriyor. Parti disiplini ile parti içi demokrasi arasında bir denge kurmak gerekiyor. Partiler demokratik olup olmamalarına göre de ikiye ayrılıyorlar. Demokratik parti ve otoriter parti biçiminde.

Demokratik parti, parti yönetiminin ve organlarının o partinin üyeleri tarafından serbestçe seçildiği ve partinin politikalarının da parti kongrelerinde belirlendiği partiye verilen isim.

Otoriter parti ise, yönetici kadroların ve partinin ideolojisinin partinin ileri gelenleri tarafından belirlendiği partiye verilen isim. Parti üyelerinin, partinin programında, partinin temel politikalarında ve yönetim kadrolarının belirlenmesinde ya hiç rolü yok ya da son derece sınırlı bir rolü var. Demokratik bir devletten söz edebilmek için siyasal partilerin de kendi yapılarının demokratik olması gerekiyor. Aksi takdirde demokratik düzenin devam ettirilmesi, savunulması aynı zamanda siyasal partilerin kendi iç işleyişlerinin de demokratik olmasına bağlı. Yalnızca demokratik devlet ilkesi o devletin ayrılmaz unsurlarından biridir demek buna ilişkin

bazı düzenlemeler getirmek yetmiyor demokratik düzeni sürdüren yeniden üreten unsur olan siyasal partilerin de demokrasinin temel ilkeleri çerçevesinde yönetilmeleri gerekiyor. İşte bu nedenle disiplinli parti ile demokratik parti arasında yakın bir ilişki vardır. Yani parti disiplininin aşırılışması o parti içinde oligarşik eğilimlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Oligarşik eğilimlerin ortaya çıkması ise o partiyi artık demokratik bir parti olmaktan uzaklaştırıyor ve otoriter parti haline getiriyor. Demokratik devletin yaşayabilmesi siyasal partilerin iç düzenlerinin ve çalışmalarının da demokratik olması ile yakından ilişkilidir.

Parti içi demokrasi; partinin iç işleyişini, parti yöneticilerinin belirlenmesini, kararların alınmasında katılımcı anlayışın uygulanmasını yani parti üyelerinin kararların alınmasına katılmasını her türlü eleştiri ve önerinin serbest olmasını anlıyoruz. Bir siyasal parti, bu tanıma ne kadar uyuyorsa o parti o kadar demokratiktir. Bizde parti içi demokrasi olgusunu ilk defa getiren 1961 anayasasıdır. 1. Siyasal partiler ilk defa anayasada tanındı ve güvence altına alındı. 2. Siyasal partiler ilk defa demokrasi ve demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak tanımlandı bu anayasada. 3. Siyasal partilerin iç işleyişi ve çalışmasının demokrasi esaslarına uygun olmasına ilişkin düzenleme de ilk defa 61 anayasası ile geldi. 1982 Anayasası kural olarak bu 3 unsurda değişiklik yapmadı. Yine siyasal partiler 82 anayasasına göre bir anayasal kuruluş olarak düzenlendi. İkincisi yine siyasal partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru oldukları ifade edildi. 3. Yine siyasal partilerin iç çalışmalarının ve düzenlerinin demokrasi esaslarına uygun olması kuralı getirildi. Bu 2 anayasa arasında asıl önemli fark siyasal partilere ilişkin olarak getirilen sınırlamalarda kendisini gösteriyor. 1982 Anayasası yasakçı, otoriter, devlet odaklı bir anayasa olduğu için siyasal partileri her bakımdan düzenleyecek sınırlamalar içeriyordu 68 ve 69. Maddelerinde. Bu sınırlamaların bir bölümü 1995 ve 2001 anayasa değişiklikleriyle kaldırıldı ama 1982 anayasasının o genel ruhunu siyasal partiler bakımından bir ölçüde devam ettirmektedir.

Parti içi demokrasi: parti içi çalışmaların ve kararların demokrasi ilkesine uygun olması kuralı anayasa 69.madde 1. Fıkrasında getiriliyor. Buna karşılık anayasa bu kuralı getirmekle birlikte demokrasi ilkesinin ne olduğunu, siyasal partilerin parti içi çalışma ve kararların hangi biçimde demokrasi ilkesine aykırı olabileceğinden söz etmiyor. Yine siyasal partilerin, bu anayasal emre uymaması durumunda ne tür yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmiyor. Dolayısıyla buna uymamanın anayasal bir yaptırımının olmadığını belirtelim. 1983 Yılında yapılan 2820 sayılı siyasal partiler kanunu bu parti içi demokrasiye ilişkin birtakım düzenlemeler içeriyor. Bunlar; 1. Genel başkan, il ve ilçe başkanları 3 yıl için parti üyeleri ya da parti üyelerinin seçtiği delegeler tarafından seçiliyor. 2. TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil bütün ulusu temsil ederler kuralı parti içi demokrasi bakımından önemlidir. Bu milletvekillerinin herhangi bir emir ve talimata bağlı olmadan kendi özgür iradeleri ile ulusu temsil etmeleri gerektiğini belirten bir düzenlemedir. Bu anayasanın 80.maddesinde yer alır. Bu maddenin, milletvekilleri bakımından üyesi oldukları partinin temsilcisi olma niteliğinden çok milletin temsilcisi olma niteliğinin ağır basması gerektiğini belirtiyor. Ama uygulamada partinin temsilcisi olma niteliği milletin temsilcisi olma niteliğinden daha üstün. Yani milletvekilleri, ulusun çıkarı doğrultusunda değil üyesi olduğu siyasal partinin çıkarı, emri doğrultusunda oy kullanıyor ve hareket ediyor. Bunun 2 nedeni vardır; 1. Parti disiplini diğeri parti içi demokrasinin ülkemizde son derece sınırlı olmasıdır. Kendi partisının üyelerinin oylarıyla yani ön seçimle milletvekilliğine aday olan ve daha sonra da seçilen bir milletvekilin parti yönetimiyle ilişkisinin daha farklı olacağını, 80. Maddeye göre ulusu önceleyecek biçimde karar alabileceğini öngörmek mümkün. Siyasal partiler kanunun 23.maddesinde, parti çalışmalarının grup içi yönetmeliğine uygun olarak yapılacağını belirtiyor. Bu madde, TBMM’de grubu bulunan siyasal partiler bakımından uygulanan bir düzenlemedir. Siyasal partiler kanununa göre parti içi demokrasiyle ilgili olarak bir başka önemli düzenleme 27.maddededir. Buradaki amaç bu parti disiplini bir ölçüde kırabilmektir. Milletvekilinin kendi vicdanına göre oy kullanmasını sağlamaktır. Siyasal partiler kendi grup başkan ve vekillerini ya da yapılacak diğer oylamalarda gizli oylama biçimdedir. Fakat uygulamada bu gizli oylamanın da milletvekillerine özerklik tanıdığını söylemek mümkün değil. Yine siyasal partiler kanununun 19.maddesinin 5.fıkrası “İl ve ilçe yönetim kurulunun seçimi ve merkez tarafından hangi hallerde işten el çektilereceği parti tüzüğünde yazar” Yasa koyucu bunu partinin iç işleyişi olarak görmüş ve bu konuya hiç müdahale etmemiştir. Yargı organları da genel merkezin kararı doğrultusunda karara yaklaşmaktadır. Siyasal partilerin adaylarının parti tüzüğünde belirlenen usule göre belirlenmesi kuralı, kanunun 37.maddesinde olup bu kural parti genel merkezlerine parti içinde tek söz sahibi yapan kural, haliyle parti içi demokrasiyi en çok baltalayan kuraldır. Adayların belirlenmesi tüzüğe bırakılmıştır. Adaylar 3 şekilde belirlenir; Önseçim yoluyla, yoklama yoluyla yani il, ilçe örgütlerine soruluyor buna eğilim yoklaması denir. Yani il, ilçe örgütleri kendi içinde hangi isimlerin aday olarak gösterilmesini istiyorlarsa nasıl bir eğilim varsa

o eğilim genel merkeze bildirilir ve genel merkez o eğilim doğrultusunda adayları belirliyor. Üçüncüsü genel merkez kimseye sormuyor, adayları kendisi belirliyor.

Çevrimiçi partiler ya da internet partileri: 2010'lu yıllardan itibaren gelişmiş demokrasilerde ortaya çıktılar. Eski tip geleneksel partilere seçmenlerin güvenlerini yitirmesi ve eski tip siyasal partilerin yeni tip toplumsal, ekonomik gelişmeler karşısında seçmenin beklediği performansı gösterememesi sonucunda ortaya çıktılar.

Bunların temel özellikleri; 1. Çevrimiçi partiler, çevrimiçi bir örgütlenme yaratmaktadırlar. Öncelikle üye olmak internet üzerinden oluyor. Sadece örgütlenme bakımından değil aynı zamanda kongreleri, toplantıları çevrimiçi yapılıyor. Parti içinde alınacak kararlara internet üzerinden dahil olabiliyorlar. Belli politikaların kabul edilmesi veya edilmemesi bakımından parti üyelerinin doğrudan çevrimiçi yolla kendi görüşlerini paylaştığını ve parti politikalarının bu şekilde belirlendiğini görüyoruz.

2. Gevşek bir örgütlenmesi vardır. Oysa geleneksel olan partiler sıkı bir örgütlenmeye dayalı olan partilerdir. Gevşek örgütlenme, üye ile siyasal parti arasında daha esnek bir ilişki vardır. Üyelik aidatı yoktur. Bu aidat aynı zamanla üye ile parti arasında bağın devamlılığını sağlar. Bu partiye üye olan bir kişi bir başka siyasal partiye de üye olabilir. Buna ilişkin herhangi bir yasak getirmiyor bu partiler. Partiye olan sadakatte esnek ve şartlı olan bir sadakat. Sadakatin esnek olmasının nedeni, üye olmanın da ayrılmanın da son derece kolay olması. Aynı zamanda başka siyasal partilerde resmi ilişkiyi sürdürmenin yasak olmaması.

3. Merkezileşmiş bir parti yapısı bulunmamaktadır. **4.** Aynı zamanda doğrudan demokrasi taraftarıdır.

5. Bunların ortak özellikleri kurulu düzene karşı siyasal parti olmalarıdır.

6. Tümü popülist aynı zamanda çevreye son derece duyarlı ve buna ilişkin somut adımların atılması taraftarı. Bunların hepsi doğrudan demokrasi taraftarlarıdır. Buna ilişkin araçların da çevrimiçi ortamda kullanılmasını istiyorlar. Yönetimin, çevrimiçi oylarla halkın denetlenmesi amaçlanıyor. Bu partiler, geleneksel partilerin de dönüşümünde rol aldığını söyleyebiliriz.

7. Bu çevrimiçi partiler daha demokratik ve doğrudan siyaset öneriyorlar. Siyasal parti üyelerinin karar alma süreçlerine doğrudan katılmaları isteniyor.

8. Bunun bir başka özelliği, bir hiper başkan modeli ortaya çıkarmasıdır. Toplumda tanınan ve sevilen kişilerin bu tür partilere önderlik ettiklerini görüyoruz. İtalya'da 5 yıldız hareketi. Ukrayna'da Zelenskiy. Bu partiler belli bir süre sonra geleneksel partilerdeki gibi örgütleniyorlar. Fakat bu örgütlenme o partilerde gördüğümüz gibi katı, disiplinli partiler haline dönüşmüyor. Korsan ve internet partileri olarak ikiye ayrılırlar. Korsan partiler, 2000'li yıllardan itibaren özellikle ekonomisi ve demokрасisi gelişmiş devletlerde kurulmuşlardır. İlk örnek 2006 yılında İsveç'te kurulmuştur. Korsan partiler, fikri mülkiyet hakkına karşı olan partilerdir. Telif hakkını ihlal eden buna karşı çıkanlara verilen isimdir. Bunlar çevrimiçi partilerin genel özelliklerini taşıyorlar. Doğrudan demokrasiyi savunuyorlar ve yönetime, seçmenlerin, parti üyelerin doğrudan katılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu korsan partiler kurulu düzene itirazı olan partilerdir. Bizde de 2014 yılında internet partisi 2013 yılında da korsan parti kuruldu. Bu partiler aktif partiler değildir.

Siyasal partilerin yarışmacı olup olmadıklarına göre yapılacak sınıflama: yarışmacı partiler ikiye ayrılıyorlar. **1. Çok partili sistemler:** Yine kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlimli çok partili sistem, aşırı çok partili sistem. Çok partili sistem, siyasal düzen içinde aynı zamanda parlamentoya giren çok sayıda partinin olduğu sistem. İlimli çok partili sistemde, parlamentoda çok sayıda parti vardır. Ancak bu siyasal partiler arasındaki ideolojik ayrılıklar derin değildir. İktidarın kullanılması iki büyük eğilim içinde yer alan partiler bloğu arasında olur. Kıta Avrupası'ndaki siyasal partiler sisteminin bu ilimli çok partiler sistemidir. Örneğin İskandinav ülkeleri, Almanya. Bu ülkelerde bu partiler tek başına iktidara gelmez, kendi görüşüne yakın olan siyasal partilerin ittifakı sonucu olarak hükümeti kurar. İlimli çok partili sistemler koalisyon hükümetlerini beraberinde getirirler. Aşırı çok partili siyasal sistemlerde ise, çok sayıda parti vardır. Bu partiler parlamentoya girmiştir. Ancak, siyasal partiler arasındaki ideolojik ayrımlar derindir. Yel pazenin kenarlarında bulunan aşırı partiler, merkezdeki partilerle işbirliği yapmak istemez. Merkezdeki siyasal partiler de bunlarla işbirliği yapmak istemez. Rejim üzerindeki uzlaşma biraz zayıftır. Uçtaki siyasal partiler hiçbir zaman hükümetin veya çoğunluğu oluşturan siyasal partilerin içinde yer alamadıkları için hem sorumsuz bir muhalefet rolü üstlenirler. Özellikle 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'sı- 3. ve 4. Cumhuriyet Fransa'sının böyle aşırı çok partili bir sistemlerdir. **2. İki partili sistemler:** iki büyük partinin siyasal yaşama egemen olduğu sisteme verilen isimdir. Kendi içinde ikiye ayrılıyor. Saf iki partili sistem ve destekli iki partili sistem. İki partili sistemde, iki büyük parti bunlar genellikle merkez sağ ve solda bulunan iki büyük partiden biri her zaman hükümetin içinde yer alır. Ancak saf iki partili sistemde bu iki büyük partiden biri tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa

parlamentoda erişir. Yüzen oylar, her seçim zamanında bu iki büyük partiden birine geçebilir. İdeolojik olarak derin farklılıklara dayanan iki büyük partiden söz etmiyoruz. Anglosakson siyasal partiler buna örnektir. Destekli iki parti sistemi ise buna aynı zamanda iki buçuk parti sistemi de deniyor. Siyasal yaşama yine 2 büyük parti egemen. Ancak bu 2 büyük partiden biri hükümetin içinde yer almakla birlikte parlamentoda salt çoğunluğu elde edemediği için mutlaka bir başka partinin desteğine ihtiyaç duyuyor. En iyi bilinen örneği Federal Almanya'dır. Bu iki parti Sosyal Demokrat ve Hristiyan Demokrat Birliği hükümeti oluşturuyor. Bu iki parti hiçbir zaman tek başına hükümeti oluşturacak şekilde parlamentoda çoğunluğu elde edemiyor. Bu destek o küçük parti olan Hür Demokrat Partidir. Bugün için Sosyal Demokrat Partinin önderliğinde Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi birlikte bir koalisyonu oluşturmuşlardır. Yarışmacı sistemlerin üçüncü bir biçimi, bir partinin üstün olduğu sistemdir. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor.

Hakim parti sistemi ve hegemonyacı parti sistemi. Burada bir partinin üstün olduğu sistemlerde parlamento seçimleri yapıyor ancak bu seçimler bir siyasal parti aralıksız olarak arka arkaya o parlamentoda çoğunluğu elde ederek hükümeti kuruyor. Hakim parti sistemi, parlamento seçimlerinde bir parti diğer partilerden her zaman üstün ve daha güçlü. Aynı parti arka arkaya en çok oyu alan parti oluyor ve bu durum belli bir süreklilik gösteriyor. Diğer partiler görevlerini yapıyorlar. Seçimler adil seçim biçiminde yapıyor. Ama bir siyasal parti oyların çoğunluğunu elde ediyor. Genellikle toplumda yaygın değer yargılarının bu siyasal parti ile aynı olması böyle bir sonucu yaratabiliyor. İsveç, Danimarka, Norveç'te Sosyal Demokrat Partiler düzenli olarak hep parlamentoda en çok sandalye kazanan partiler oldular. 1929-2009 Yılları arasında Meksika'da aralıksız olarak parlamentoda en çok oyu alan parti oldu. Hindistan'da kongre partisi de buna örnektir. Hegemonyacı parti sisteminde farklılık, Genel seçimlerin sonucunda sürekli olarak parlamentoda aynı çoğunluğu bir siyasal parti elde ediyor. Ama orada seçimler dürüst, serbest ve tam yarışmacı adil bir nitelik taşıyor. 2018 Yılından itibaren AKP'yi hakim partiden çok hegemonyacı parti olarak düşünebiliriz.

Yarışmacı olmayan sistemler: Ya tek partinin genel seçimlerde yarıştığı ya da başka uydu partiler olmakla birlikte bu partilerin hükümeti ortağı olmak konusunda herhangi bir fiilen olanağın olmadığı parti sistemlerine verilen isimdir. Bunlar 3'e ayrılır; *1. Komünist partiler 2. Faşist partiler 3. Gelişmekte olan sistemlerdeki tek partili rejimler*. Eğer ülkenin yönetimi tek bir partinin tekelindeyse birden çok parti seçimlere katılamıyorsa orada tek parti sistemi var demektir. Birden çok parti yarışa katılır ama bu göstermelik bir yarıştır. Bunun mevcut düzene herhangi bir etkisi olmaz. Yöneticilerin iş başına gelmeleri ve denetlenmeleri her zaman bu tek partinin tekelinde olur bu yarışmacı olmayan sistemlerde. Doğu Bloku ülkelerindeki komünist partileri buna örnek verebiliriz. Bunun arkasında yatan gerekçe, ideolojik olarak sınıfsız bir toplumu hedefleyen ideolojilerdir bunlar. Toplumun sınıfsız olması isteniyorsa o zaman farklı partilerin gereği yoktur. O da işçi sınıfını temsil eden parti olmalıdır. Faşist partiler, özellikle iki dünya savaşı arasında hem Almanya'da hem de İtalya'da daha sonra Faşist Franco İspanya'sında görüldü. Bunun arkasında yatan, parti ve devlet iç içe geçmiş vaziyettir. Faşist anlayışta devletin tarafsız olması mümkün değil. Devlet, siyasal parti ulus birbirinin içindedir. İdealleri olan bir devlet vardır. Tek bir parti bu idealleri yerine getirir bunun dışında başka bir partiye ihtiyaç yoktur. 3. Uygulama biçimi ise gelişmekte olan ülkelerde olan uygulamadır. Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra emperyalizmin şekil değiştirmesiyle birlikte Afrika'da bağımsız devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte böyle yarışmacı olmayan parti sistemlerini de ortaya çıkardı. Bu devletlerin ortak özellikleri, etnik ve bölgesel bölünmeleri önlemek, uluslaşmayı, ekonomik gelişmeyi sağlamak, halk yığınlarını hareket geçirmek ya da siyasal kadroların sayısal olarak yetersizliğine çözüm bulmak gerekçesiyle tek partiye dayalı siyasal sistem kurdular. Türkiye'deki 1923-46 arasındaki dönemi aynen bunun içinde düşünmek mümkün. Yarışmacı olmayan gelişmekte olan sistemler içinde yer alıyor o zamanki ülkemizdeki tek parti sistemi.

Siyasal partiler ne tür kuruluşlar: Kamu yararı için kuruluşlar mı? 1961 Anayasası yürürlüğe girdiği andan itibaren tartışılan konudur bu. AYM'nin birçok kararına da konu olmuştur. Çünkü ne 1961 anayasası ne de 1982 anayasası siyasal partilerin niteliğini ne tür kuruluşlar olduğunu açıklayan bir düzenleme içermiyordu. Benzer bir durum siyasal partiler kanunlarında da bir düzenleme içermiyordu. İlk defa buna ilişkin bir kararı AYM 1969 yılında verdi 1969/14 Kararı ile siyasal partileri kamu yararına çalışan kuruluşlar olarak tanımladı. 1971 Yılında verdiği bir başka kararında bununu değiştirdi. Siyasal partiler gördükleri hizmet bakımından çok sınırlı bir biçimde de olsa kamu hizmeti sayılabilir ama bunlar kamu kurumu değildirler. 1982 anayasasında kural olarak kamu görevlilerin siyasal parti üyesi olamadığını görüyoruz. Bu da bize siyasal partilerin anayasa bakımından da kamu kurumu olarak düşünülmediğini gösteriyor. İkinci bir görüş bu siyasal partilerin, birer

anayasa organı olduğuna ilişkin. Bu görüşün zayıf yanı, anayasanın bir tüzel kişiliğinin olmaması. Oysaki siyasal partiler tüzel kişiliğe sahip. 2820 sayılı kanun siyasal partileri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak kabul etmişti. Üçüncüsü bunlar birer dernek mi? 1961 Anayasasından önce siyasal partiler anayasada düzenlenmemişti. Siyasal partiler dernekler kanunu hükümlerince çalışıyordu. 1961-1982 Anayasaları, siyasal partileri özel bir kuruluş olarak düzenledi. Hem 1961 anayasası döneminde geçerli olan siyasal partiler kanunu hem de bugün yürürlükte olan siyasal partiler kanunu 34.maddesinde dernekler kanununun kamu yararına çalışan dernek sayımı hükümlerini siyasal partiler bakımından uygulanmayacağını belirtiyor. Yine SPK, bu kanunda düzenlenmemiş olan konular bakımından siyasal partilerin dernekler kanununa bağlı olduğunu ya da tabi olduğunu belirtiyor. Sonuç: Siyasal partilerin dernekler gibi birer kişi topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Toplumda, kişilerin siyasi düşüncelerinin ve inançların oluşmasında araç olan serbest kuruluşlar olarak tanımlayabiliriz.

1982 Anayasasına göre herkesin siyasal faaliyette bulunma hakkı vardır. Anayasanın 67/1 fıkrasının anlamı, serbestçe siyasal faaliyette bulunma anlamına geliyor. Bunun önemi, çoğulcu bir demokratik düzende yurttaşlar yalnızca genel, yerel seçimlerde oy vermekle sınırlı olarak siyasal yaşama katılmazlar. Yalnızca pasif yurttaş konumunda değildirler. Aynı zamanda siyasal iktidara başka şekillerde de etkileyecek faaliyetlerde de bulunabilir, siyasal yaşama katılabilirler. 1961 Anayasasında da aynı düzenleme vardı, 82 anayasası bunu tekrarlamış oldu. Anayasanın 68/1 fıkrasında, siyasal parti kurma ve bu partilere üye olma hakkını düzenliyor. 68/3 fıkrasını da bununla ilişkili olarak oku. Siyasi parti kurmaya ilişkin düzenlemeler 2820 sayılı siyasal partiler kanununda yer alıyor. Bu kanuna baktığımızda siyasal partiye üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 2. Olarak siyasal partilere yalnızca gerçek kişilerin üye olabileceğini veya siyasal parti kurma hakkına sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Bunu hem 2820 sayılı kanun hem de 68/1 in ifadesinden çıkarıyoruz. Tüzel kişilere parti kurma ya da parti üyesi olma hakkı neden verilmemiş? Çünkü bu ikisi arasında bir fırsat eşitsizliği yaratmamak için, asıl önemlisi tüzel kişiler siyasal partilere üye olurlarsa o zaman siyasal parti bir ya da birkaç tüzel kişinin kolu haline gelir. Bu da hem siyasal parti kurumunun anlam ve amacını ortadan kaldırır hem de siyasal düzende eşitsiz bir yarışma ortamı yaratır. Siyasal parti kurmak için en az 18 yaşında olmak 2. TC vatandaşı olmak gerekiyor. Yabancıların siyasal partiye üye olması ve kurucu olmaları mümkün değildir. 3. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Siyasal partiler kanunun 11.maddesinde yazılıdır. Bu madde aynı zamanda belli suçlardan mahkum olmama, hüküm giymemek koşulunu da getirmiş. Bu suçlar; kamu hizmetinden yasaklı olmak, zimmet, irtikap, rüşvet gibi suçtan hüküm giymemiş olmak, terör eylemlerinden hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar hariç 5 yıl ağır hapis cezası veya 5 yıl veya daha fazla hapis cezasından mahkum olmamış suçlar gibi suçlar. Bu koşulları sağlayan en az 30 kişinin bir araya gelmesi gerekiyor ki bir siyasal parti kurulabilsin. Bunun yanı sıra 68/3 de siyasal partilerin önceden izin almadan kurulacağı esasını getiriyor. Bu anayasal kural, 1961 anayasası ile girmişti. 1982 anayasası da bu düzenlemeyi devam ettiriyor. 2820 Sayılı kanunda sayılan bilgi ve belgelerin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle birlikte kurulması anlamına geliyor. Bakanlık ilgili siyasal partinin gerekli bilgi ve belgelerin vermesi üzerinden herhangi bir denetim yapma yetkisi yoktur. Eğer buna ilişkin bir eksiklik varsa buna ilişkin AYM’nde bir dava açılabilir. Kanunda belirtilen bilgi ve belgeleri İçişleri Bakanlığına veren bir siyasal partiye bir alındı belgesi verilir. Bu belgenin verilmesiyle siyasal parti kurulmuş olur. Uygulamada günümüzde aykırılık oluşturan bir durum vardır. Örnek Yeşiller Partisi. Bu partinin kuruluşuna ilişkin belgenin verilmemiş olması Anayasanın 68/3 fıkrasına aykırı bir uygulamadır. Günümüz demokrasileri, siyasal partilerin dışında bir siyasal yaşamı düşünmek mümkün değil. Bu gerçeğin yansıması olarak 1982 Anayasasının 68/2 fıkrasında belirtilen hüküm. Siyasal partiler varlıklarını sürdürebilmeleri için, örgütlerini güçlü kılabilirmeleri için aynı zamanda da seçimlere katılabilirmeleri için belli bir gelire ihtiyaç duyarlar. Bu gelirler 2 kaynaktan gelir. 1. Parti üyelerinin düzenli verdikleri aidatlar. 2. Partilere gelen kişisel bağışlar. Ancak 20.yy’dan itibaren bu kaynakların yanına bir de devlet yardımı eklendi. Bu yardımlar 2 biçimde olur. 1. Aynı yardımlar biçiminde olabilir. Mesela iletişim ihtiyaçları, posta hizmetleri devlet tarafından karşılanabilir.

2. Devletler doğrudan para yardımı yapabilirler. Devletin mali yardım yapması ve aynı zamanda gelir ve giderlerini kontrol etmesi 20. Yy’ın başından beri demokratik devletlerde karşımıza çıkan bir durumdur. İki bakımdan önemlidir; 1. Siyasal partilerin kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için asgari bir mali desteğe ihtiyaç duymaları. 2. Siyasal partiler arasındaki eşitsizliğin, adaletsizliğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla partilerin gelir ve giderlerinin belli bir denetime ve belli bir sınır içerisinde olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Örnek 1907’den beri ABD’de bağış ve seçim harcamalarını denetleyen ve düzenleyen federal nitelikteki

yasaların yapıldığını görüyoruz. Günümüzde her bir aday seçimlerde ne kadar para harcadığını ve harcadığı paraların kaynağını açıklamak zorundadır. 2.Örnek Fransa, yerel, genel ve CB seçimlerde buna katılacak adaylar bakımından bir harcama üst sınırı vardır. Bu harcama sınırı 3 yılda bir gözden geçiriliyor. Buna ilişkin bir komisyon kuruldu ve bu komisyonun üyeler yüksek yargıçlardan oluşuyor. Bu komisyonun işi, seçimlerde yarışan bütün adaylar yarışma süresince elde ettikleri gelirleri ve giderleri seçimler bittikten sonra vermek zorundadır. Komisyon gelir ve giderlerin kanuna uygunluğunu denetler. Eğer kanuna aykırılık varsa bu aykırılığa neden olan adayı dosyasını anayasa konseyine yollar. Anayasa Konseyi, kanuna bir aykırılık saptar ve bu aday seçilmişse onun milletvekilliğini düşürüyor veya gelecek seçimlerde aday olmasını yasaklıyor. Nakdi yardımda 2.Dünya Savaşından sonra 1949 yılında yapılan Alman Anayasasının ilk olduğunu söyleyebiliriz. Bizde, 2820 sayılı kanuna göre tüzel ve gerçek kişilerin ancak en çok bir yıl içinde siyasal partiye 2000 TL yardım yapması söz konusu. 1961 Anayasasında ya da 648 sayılı siyasal partiler kanununda buna ilişkin herhangi bir düzenleme yer almıyor. İlk defa 1965 Yılında 648 sayılı siyasal partiler kanununda buna ilişkin bir düzenleme getirildi. Genel seçimlerde oyların %5'ini alan siyasal partiler almış oldukları oy oranına göre her yıl devlet tarafından mali yardım siyasal partilere yapılır. Bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM önüne getirildi. 1969 Yılında AYM, bu düzenlemeyi anayasaya uygunluk denetimine bağladı. Dedi ki partilere devletçe mali yardım yapılması anayasaya aykırı değildir. Buna karşılık %5'in üzerinde genel seçimlerde oy almış siyasal partilere bu yardımın yapılması bu koşulu gerçekleştirmeyen diğer partilere bu yardımın yapılamaması eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı bulunmuştur. Üstelik de bu mali yardımın nasıl harcanacağını da belli koşullara bağlanması gerekirken bu da düzenlenmemiştir. Bu nedenle de anayasaya aykırıdır dedi ve iptal etti. 1970 Yılında yeniden aynı düzenleme yapıldı ve 1971 yılında AYM bunu tekrar iptal etti. 1982 anayasasının ilk biçiminde de, 2820 siyasal partiler kanunun ilk biçiminde de siyasal partilere yardım yapılması düzenlenmemiştir. Siyasal partilere devlet yardımı yapılmasının en önemli gerekçelerinden biri, siyasal partiler asgari ihtiyaçlarını kendi olanakları ile karşılayamazlarsa o zaman daha güçlü ekonomik odakların etkisi altına girebilmek durumunda kalabilirler. Bu da siyasal partilerin bağımsızlığını ortadan kaldırabilir. İşte bunu engellemek amacıyla devlet yardımı öngörülmüştür. 1982 Anayasasında anayasa koyucu böyle bir düzenleme getirmemesini şu gerekçeye bağlıyor; devlet, siyasal partilere mali yardım yapsa bile siyasal partiler mali olarak güçlü olan kişi ya da kuruluşların etkisi ve baskısı altın yine düşebilirler. Buna karşılık 1983 yılında siyasal partilere hazineden mali yardım yapılacağına ilişkin düzenleme getirildi. %10 Ülke barajını aşan siyasal partilere hazine yardımı yapılması sağlandı. Bu düzenleme defalarca değişti. 1989 yılında siyasal partilere mali yardım yapılmasına ilişkin düzenleme AYM'ne geldi. Bu söz konusu düzenlemeyi objektif ve genel bir düzenleme olarak niteledi. 1995 Yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle anayasanın 68.maddesinin son fıkrasına bu hazine yardımına ilişkin bir düzenleme eklendi. Bu yasa uyarınca artık siyasal partilere devlet yardımı anayasal bir güvenceye kavuşmuş oldu. 2005 Yılında yapılan kanun değişikliği ile %10'dan %7'ye indirildi. 2014 Yılında yapılan değişiklik ile en son yapılan genel seçimlerde %3'den fazla oy almış siyasal partiler artık hazine yardımından yararlanıyorlar. Her siyasal parti aynı ölçüde mali yardım almıyor. Son genel seçimlerde siyasal partinin aldıkları oy oranına göre bu miktar belirleniyor. Kanuna göre bu yardım hak eden siyasal partilere her yıl veriliyor. Genel seçimlerin yapılacağı yıl 3 katı, yerel seçimlerin yapılacağı yıl 2 katı o yardımın yapıldığını görüyoruz. Yapılan bir eleştiri, bu siyasal partilerin devlet yardımına aşırı bağımlı hale gelmesi ve üyeleri ile olan ilişkilerini de zayıflatıyor bu aşırı bağımlılık. Siyasal partilerin gelir ve giderleri AYM tarafından denetleniyor. 1982 Anayasasına göre; 1. siyasal partilerin gelir ve giderleri amaçları doğrultusunda olmalı 2. Siyasal partiler anayasanın açık hükmüne göre ticari faaliyette bulunamazlar. Dolayısıyla AYM siyasal partilerin gelir ve giderlerinin anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde denetler. Bu denetimde 1961 anayasası ile gelen bir denetimdir. Bu denetimi yaparken sayıştaydan yardım alıyor. Uygulamada AYM, bir noter işlevi görüyor. Yani Sayıştay'dan gelen raporları olumlu olumsuz aynı şekilde onaylıyor. AYM'nin yapmış olduğu bu denetimin sonunda, bir siyasal partinin gelir ve giderlerinin kanun ve anayasa hükümlerine aykırı olduğunu AYM saptarsa söz konusu gelir yasalara aykırı olarak elde edilmişse hazineye gelir olarak kaydedilir. İkinci olarak siyasal partiler birtakım sınırlamalara da bağlıdır. Bu sınırlamalar hem anayasal hem de yasal sınırlamalardır. Demokratik anayasal düzeni hem toplumdan hem de devletten gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korunması amacıyla birtakım araçlar öngörülmesi **mücadeleci veya militan demokrasi** olarak adlandırılır. Bu anlayış gereği olarak siyasi partilerin amaçlarının, örgütlenmesinin, çalışmalarının belli sınırlara bağlı olması sonucunu getirir. İkincisi mücadeleci demokrasi anlayışı, yalnızca siyasal partilere yönelik sınırlamalar getirmez. Aynı zamanda çoğulcu demokratik anayasal düzenin korunması için zorunlu olan bir takım temel hak ve özgürlükleri de güvence

altına alır. Örneğin haberleşmenin gizliliği, direnme hakkı, sivil itaatsizlik, bilgi edinme hakkı, toplantı ve gösteri hakkı gibi hak ve özgürlükler devletin demokrasi ile bağdaşmayan siyasal uygulamalarına karşı koyma olanağı sağlayan, topluma ve bireylere birtakım araçlar verir. Mücadeleci demokrasi anlayışı ilk defa 2. Dünya Savaşından sonra ortaya çıktı. İlk defa 1949 tarihli Alman anayasası bu anlayışı benimsedi. Bunun nedeni, 2 dünya savaşı arasında siyasal parti ile devlet arasındaki bütünleşmenin sonucunda ortaya çıkan olumsuz ve yıkıcı deneyimleri bir daha yaşamak amacını taşıyordu. Özgürlükçü, çoğulcu demokratik düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan siyasal partilere ya da siyasal akımlara meşru siyasal faaliyet alanını yasaklayan bir düzenlemeler içeriyordu. Siyasal partilerin demokratik anayasal düzen içinde faaliyet göstermeleri için birtakım sınırlamalar getirildi. Bizde ilk defa 1961 Anayasası işte Alman anayasasından da etkilenecek mücadeleci demokrasi anlayışını benimsedi. Bu sınırlara uyup uymadığını, uyulmaması durumunda da bu partilerin kapatılması yetkisini AYM verdi. 1982 Anayasasında aynı anlayışı benimsedi. Bu çerçevede 67-68-69 maddelerde siyasal partilerin amaçları, örgütlenmesi, faaliyetlerine ilişkin önemli yasaklar getirdi. Mücadeleci demokrasi anlayışı bakımından 1961 ile 82 anayasası arasında kayda değer bir fark vardır. Bu anayasanın yaklaşımı ve demokrasi anlayışı ile bağlantılıdır. 1961 Anayasası çoğulcu bir demokrasi anlayışına dayanıyordu. Dolayısıyla mücadeleci demokrasi anlayışı bakımından da siyasal partilere daha sınırlı yasaklar getirdi. 1982 Anayasası otoriter, bireylerin değil devletin otoritesine dayanan ve bunu kendisine esas alan bir yaklaşımı esas aldığı için siyasal partilere de çok sayıda yasak getirilmişti. Bu yasakların bir bölümü 1995 ve 2001 anayasa değişiklikleri ile kaldırıldı. Bir ölçüde daha serbest, özgürlükçü siyasal partiler düzeyi getirildi. Ancak halen 1982 anayasasında hem de 2820 sayılı siyasal partiler yasasında siyasal partilere ilişkin çok geniş sınırlamalar vardır.

Siyasi partilere getirilen yasaklar: Bu yasaklar siyasal partilerin amaçlarına, örgütlenmesine ve çalışmasına ilişkin yasaklardır. 1982 Anayasasının 68-69. maddeleri siyasal partilere ilişkin bu tür yasaklar öngörüyor.

Amaçlara yönelik sınırlama: Bu sınırlama anayasanın 68.maddesinin 4.fıkrasında yer alan siyasal partilerin amaçlarına yönelik bir sınırlamadır. Bütün siyasal partiler demokratik bir düzen içinde var olmak, faaliyette bulunmak çalışmak mecburiyetinde. Haliyle bunun dışında 68/4 de belirtilen amaçlara yönelik faaliyetler gütteği zaman bu siyasal partiler meşru anayasal alanın dışına çıkmış olacak. Anayasa siyasi partilerin örgütlenmesine ve çalışmasına ilişkin de bazı yasaklar getirmiştir.

Örgütlenmesine ilişkin yasaklar: Bazı kişilerin siyasi partilere üye olmasını yasaklıyor. 68/5 fıkrasına göre kimlerin üye olamayacağı yazılıdır. Buradaki yasaklar 1995 yılına kadar daha geniş yasaktı. Yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim elemanları ve yüksek öğrenim öğrencileri de bu yasak kapsamındaydı. YÖK'undaki öğretim elemanları da siyasal partinin merkez organlarında görev almakla sınırlı olmakla siyasal parti üyesi olabiliyorlar 68/6 fıkrasına göre, Yüksek öğrenimdeki öğrenciler de artık siyasal partilere üye olabiliyorlar. 69/1 Fıkrasına göre bu siyasal partilerin çalışma ve örgütlenmesine ilişkin bir düzenlemedir. Ancak bu çerçevede faaliyette bulunabileceklerdir. 69/2 fıkrası siyasi partilerin ticari faaliyette bulunamayacağını belirtiyor. Siyasal partilerin amaçları, örgütlerini kurmak ve aynı zamanda seçimlere katılıp aynı zamanda siyasal iktidarı kısmen veya tamamen ele geçirmek amacıyla gelir ve giderlerini kullanmalılardır. 69/9 Fıkrasının getirdiği bir başka yasak 69/8 dedir. Yalnızca anayasanın 68-69.maddelerinde değil aynı zamanda siyasi partiler kanunun başka maddelerinde de siyasal partilere yönelik sınırlamalar ve yasaklamalar vardır. Siyasal partiler kanununu oku. Bunlardan birisi 96.madde. Burada anayasada olmayan ama yasayla getirilmiş bir yasaktır.

Bu yasakların yaptırımları: Siyasal partilerin kapatılması ya da siyasal partilere yönelik bir takım mali yaptırımlar mücadeleci bir demokraside, demokratik düzenin dışına taşan siyasal partilere yönelik çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. Bunlar siyasal partinin geçici ya da sürekli olarak kapatılması, siyasal partinin belli bir dönem seçimlere girmesinin yasaklanması, siyasal parti devletten yardım alıyorsa bu yardımın tamamen veya kısmen o yardımdan mahrum bırakılması gibi çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilir. En çok bilineni siyasal partilerin kapatılmasına ilişkin. Mücadeleci demokrasi anlayışını belirleyen 1961 anayasası siyasal partilere yönelik yaptırım olarak bir tek siyasal partilerin kapatılmasını düzenlemişti. 1982 anayasasının ilk biçimi de siyasal partilerin kapatılmasını bir yaptırım olarak düzenlemişti. Daha sonra 2001 anayasa değişikliğiyle siyasal partilerin kapatılmasının yanına devletten aldıkları mali yardımda kısmen veya tamamen mahrum bırakmada bir başka yaptırım türü olarak düzenlendi. Üçüncü bir yaptırım türü de AYM'nin anayasada ve siyasal partiler kanununda öngörülen sınırlama ve yasaklara uymaması durumunda da ihtar yaptırımını uygulamasını diyebiliriz. Ama bunun dışında bizim anayasal düzenimiz siyasal partiler bakımında başka bir yaptırım türü öngörmüyor. 1995 Yılı anayasa değişikliğinden sonra siyasal partinin kapatılması 3

nedenden birine bağı tutuldu. Bugün artık anayasanın 69.maddesi hangi gerekçeler ile bir siyasal partinin kapatılabileceğini belirtiyor. Bu gerekçeler yalnızca 3 durumla sınırlı. **Anayasanın 69/5, 69/6 ve 69/10.fıkraları bir siyasal partinin hangi durumlarda kapatılabileceğini belirtiyor.** Bunun dışında anayasada ya da yasalarda belirtilen siyasal partilere yönelik diğer sınırlamalar ve yasaklar bakımından siyasal partinin kapatılması yaptırımı uygulanamaz. Bu 3 durumla sınırlıdır parti kapatmaları. 69/5, bir siyasal partinin tüzük veya programının anayasanın 68/4 fıkrasına aykırı hükümler içermesi durumunda 69/6 madde, bir siyasal partinin anayasanın 68.maddesinin 4.fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerin işlendiği bir odak olması durumunda, 69/10 fıkrası ise bir siyasal partinin yabancı bir devletten, uluslararası bir kuruluştan, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alması durumunda kapatılabileceğini belirtiyor. Anayasa ve siyasal partiler kanununda yer alan başka bir gerekçe ya da başka bir sınırlamaya dayanarak bir siyasal partinin kapatılması bu 3 madde dışında mümkün değildir. Kapatmanın dışında anayasanın 69/5-6 fıkraları çerçevesinde bir siyasal partiye kapatmanın dışında hazine yardımının kısmen veya tamamen mahrum bırakma yaptırımı da uygulanabilir veya o siyasi parti kapatılabilir. AYM söz konusu ihlalin ağırlığını göz önünde bulundurarak bu 2 yaptırımdan birine karar verebilir. Buna karşılık anayasanın 69/10 çerçevesinde bir siyasal parti bu fıkraya aykırı davranmışsa o zaman bir tek yaptırım vardır. O da o siyasal partinin kapatılmasıdır. 69/5 ve 6. Fıkralarına aykırılık durumunda uygulanabilecek bir yaptırım türü olan hazine yardımından kısmen veya tamamen mahrum bırakma yaptırımını ancak öyle yardım alan siyasi parti bakımından geçerli olduğunu söyleyelim. Eğer o siyasal parti bir önceki seçime girmemişse, girdiği halde geçerli oyların %3'den daha az bir oranını almışsa o zaman devlet yardımından yararlanamıyor demektir. Yararlanamıyorsa, böyle bir yaptırımında o siyasal parti bakımından bir geçerliliği yoktur. Siyasal partinin tüzük ve programının anayasanın 68/4 deki aykırı olması durumudur. 69/6 fıkrası ise bir siyasi partinin 68/4 eylemleri ile bir odak haline gelmesidir. 69.Madde bir siyasal partinin eylemleriyle 68/4 de aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi durumunu tanımlamış. Bu 2001 anayasa değişiklikleri ile anayasaya girdi.

Amaç; odak tanımını anayasada yaparak siyasal partilerin kapatılmasını zorlaştırmaktır. Kural demokrasinin siyasal partiler ve onlar üzerinden yürümesidir. İstisna, demokratik düzene aykırı davranan bunu ortadan kaldırmaya çalışan siyasal partilere meşru siyasal alanı kapatmak. Ama siyasal partilerin yasaklanmasının aynı zamanda kötüye kullanılmaması da gerekir. Bunlar demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurudurlar. 69/6 fıkradan çıkan sonuç: partinin üyeleri 68/4 ait eylemleri kararlılık içinde işleyecek. Bunun anlamı, bir veya birkaç üyenin bunu işlemesi veya 68/4'e aykırı eylemlerin belli bir süreklilik taşımaması odak olma durumunu gerçekleşmemesi anlamına gelir. Üyeler yoğun bir biçimde çok sayıda ve düzenli ve kararlı bir şekilde 68/4'e aykırı eylemleri işleyecek. İkinci olarak ya da bu partinin üst düzey organları tarafından hem meclis grubu hem meclis grup yönetimi hem de üst düzey karar organları tarafından bu şekilde işlenecek. Veya merkez karar organları, yönetim organları partinin bunu doğrudan işlemiyor ise üyelerin sürekli ve düzenli biçimde yapmış olduğu bu ihlallere açık veya örtülü biçimde kabul etmiş olacak. Partinin organlarını temsilen bir kişinin, üyenin buna ilişkin bir ifadesi tek başına o siyasal partiyi kapatmak için yeterli değil. Yani bunun kararlı ve süreklilik gösterecek ölçüde yoğun bir nitelikte taşıması gerekir. Bu olmazsa 69/6 kapatma gerekçesi olamayacak. Burada belirtilmemiş olsa bile anayasa 69/8'de "*temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulmaz*" hükmü ile temelli kapatılan bir partinin yeniden kurulamayacağını hükme bağlıyor. Bu kapatma sebebi olarak görülmemiş ama bunun da bir kapatma sebebi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Aksi takdirde bu anayasaya karşı hile olacaktır. Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulmuş olması hangi durumlarda söz konusu olabilir. Örneğin yeni partinin, kapatılmış olan partinin yönetici ve üye bakımından devamlılığı, tüzük ve program bakımından benzerliği o partiyi kapatılan partinin devamı niteliğini taşıtır mı sorusunu akla geliyor. Burada, sınırlama ve yasak ilkesini göz önünde bulunduracağız. Bir partinin kapatılan bir partinin devamı olarak kabul edilebilmesi için o partinin tüzük ve program benzerliği, üye ve yönetici sürekliliğinin ötesinde kapatılan partinin kapatılma nedeninin yeni kurulan partide de devam ediyor olması gerekir. Bunun dışındaki anayasa ve yasayla getirilen parti yasakları bulunduğu, ne hazine yardımından yoksun bırakma ne de kapatma yaptırımı uygulanamaz. Onun yerine siyasal partiler kanunun 104.maddesinde öngörülüyor. Bu durumda AYM o siyasal partiye ihtar verebilir. Bu ihtara uymamasının kanuni veya anayasal yaptırımı yoktur. AYM'nin, bir kere siyasal partileri kapatma yetkisi 1961 ve 82 anayasasında da bulunmaktadır. 1961 Anayasası döneminde 6, 82 anayasası bunu katladı 19 tane siyasal parti kapatıldı. 1961 Anayasasından günümüze kadar, bu partilerin anayasanın 68/4 fıkrasına aykırılıktan kapatıldığını görüyoruz. Bunların çok büyük bölümünün devlet in ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi veya laiklik ilkesine

veya ikisine birden aykırılık iddiasıyla kapatıldığına tanık oluyoruz. AKP'ye ilişkin kapatma davasında ise, laiklik ilkesine aykırılık buldu ancak partiyi kapatmak yerine partinin hazine yardımından kısmen yoksun bırakılması kararını verdi.

Siyasal Partinin Kapatılması Süreci: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (YCB) AYM'nde bu konuda dava açması gerekir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ya bu kapatma kararını resen açıyor veya CB talebi üzerine Adalet Bakanının bu yönde bir siyasal partinin kapatılması yönünde YCB'ndan talepte bulunması veya TBMM'nde grubu bulunan herhangi bir siyasal partiden gelmesi durumunda açıyor. Adalet Bakanı veya TBMM'de grubu bulunan bir siyasal partiden gelmiş ise YCB bu talebi mecburi olarak yerine getirmek zorunda değil. Eğer önüne gelen bu dosyalarda yeterli bir kanıt olmadığı kanısına vardı ise o zaman YCB böyle bir davayı AYM'nde açmıyor. Dava AYM'nde açıldı. AYM'nin genel kurulunda görülüyor. AYM, ceza yargılama hükümlerini bu davada uyguluyor ve dosya üzerinde inceleme yaparak karar veriyor. Gerekli görürse savunmalarını alıyor. AYM, katılanların 2/3 oyu ile bir siyasal partinin kapatılmasına ya da kapatma koşulları varsa, siyasal partinin hazine yardımından kısmen veya tamamen mahrum bırakılmasına karar veriyor. 2010 Anayasa değişikliği ile 2/3 oranı getirildi. Ondan önce 3/5 idi. Son derece yüksek bir karar sayısı gerekiyor. Amaç parti kapatmanın kötüye kullanmasını engellemek, özgürlüğü esas, sınırlamayı istisna tutmaya çalışmak. Eğer AYM, partiyi kapatırsa bu kapatma kararı YCB tarafından uygulanıyor.

Kapatmanın sonuçları; 1. Kapatmayla birlikte siyasal partinin tüzel kişiliği ortadan kalkıyor. 2. Varsa partinin mal varlığı hazineye devrediliyor. Bu sonuçlar, AYM'nin o siyasal partiyi kapatmasına ilişkin genel kurulda vermiş olduğu kararla o andan itibaren bu kapatma kararı yürürlüğe giriyor. 3. AYM kararları kesin. Bir başka merciye, bu kararlar için başvurmak mümkün değil. 4. Bu karar herkesi bağlıyor. 2010'a kadar AYM'nin kapatma kararına eylem ve sözleriyle neden olduğu AYM kararında belirtilen milletvekillerin TBMM üyelikleri kendiliğinden düşüyordu. 2010 Anayasa değişikliği ile bu kaldırıldı. Çünkü AİHM'nin Türkiye ile ilgili kararlarında da sıkça bu düzenleme eleştiriliyordu. Buna karşılık kapatmaya ilişkin olarak bir başka düzenleme anayasanın 69.maddesinde durmaya devam ediyor. Burada parti üyeliğine ve içinde siyasal faaliyette bulunmaya ilişkin bir düzenleme. Bu parti dışında siyasal faaliyette bulunmasını yasaklayan bir durum değildir. Bu kapatma kararları ne ölçüde AİHM kararlarına uyuyor. Bunun için AİHM'nin içtihatlarına bakacağız. 1. Bu içtihadını Türkiye'den gelen kararlarla oluşturdu. 2. Venedik komisyonunun, konuya ilişkin raporları. Venedik komisyonu, Avrupa konseyi içinde yer alan ve anayasal konularda konseye danışmanlık yapan bir kurum. Bu kurum herhangi bir karar almıyor ama anayasa hukukuna ilişkin çeşitli konularda raporlar hazırlıyor. Bu raporlar önemli. AİHM, kararlarında Venedik Komisyonunun raporlarını ölçü norm olarak kullanıyor. Bu bakımdan da AİHM içtihatları ve Venedik Komisyonunun ölçütleri bizim bakımdan önem taşıyor. Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu üyesi, 1954'de AİH Sözleşmesini onayladı, 1987 de bireysel başvuru yolunu tanıdı. 1989 Yılında AİHM'nin bağlayıcı yargı yetkisini de tanıdı. Üstelik 2004 Anayasa değişikliği ile 90/5'e eklenen cümle ile Uluslararası İnsan Hakları Anlaşmalarının ulusal hukukta bir önceliği de vardır. Üstelik Anayasa 148.maddesi bireysel başvuru yolunu AİHM sözleşmesi ile anayasanın birlikte güvence altına alınan özgürlüklerle sınırladı. Yani AİHM'nin kararları, bütün devlet organlarını bağlar. AİHM, siyasal partilerin kapatılmasını sözleşmeye aykırı bulmuyor. Alman AYM'si 1952 yılında Sosyalist Rayh Partisini, nazi partisinin devamı olduğu gerekçesiyle kapadı. 1956 Yılında da Alman Komünist Partisini kapadı. AİH Sözleşmesi, siyasal parti özgürlüğünü açık bir şekilde tanımamış. AİHM, örgütlenme özgürlüğü içinde siyasal parti özgürlüğünün olduğunu verdiği kararlarda yorum yoluyla kabul etti.

AİHM içtihatlarına ve Venedik Komisyonuna göre siyasal parti kapatma ölçütleri:

1. AİHM'ne göre siyasal partiler demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru. Bu nedenle siyasal partilerin kapatılması ancak ayırksı bir önlem olarak son çare olarak düşünülmeli. Eğer siyasal partinin demokrasiye aykırı birtakım faaliyetleri var ise kapatmadan önce başka araçların uygulanması gerekiyor. Mesela siyasal partinin faaliyetlerini geçici olarak askıya almak, siyasal partinin bir sonraki seçimlere katılmasını yasaklamak veya siyasal partinin devlet yardımından mahrum bırakılması gibi daha hafif araçların önce denenmesi gerektiğini. Venedik komisyonu ile AİHM içtihatları birbiriyle örtüşmektedir.

2. AİHM'in getirdiği 2.ölçüt bir siyasal partinin hukuka uygun yöntemlerle barışçıl bir biçimde anayasal düzenin değiştirilmesinin savunulması düşünce özgürlüğü içinde yer alıyor. - Eğer o siyasal parti şiddetli bir araç olarak savunuyor ya da kullanıyorsa o zaman o partinin kapatılması hukuka uygun olacaktır.

3. AİHM'ne göre partinin kapatılması için partinin tüzük ve programının anayasaya aykırı olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda aykırılığın partinin eylemleriyle de desteklenmesi ve bu aykırılığın esaslı bir

aykırılık olması gerekir. Demokratik düzeni gerçekten ortadan kaldıracak, ona zarar verecek nitelikte bir ihlal olması gerekir.

4. Son olarak partinin yasalarda ve devletin hukuki ve anayasal yapısında bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa bu değişikliğin 2 koşulu taşıması gerekir; **1.** Partinin anayasal, düzeni değiştirmek için kullanacağı araçların her bakımdan hukuki ve demokratik olması gerekir. Şiddet içermemesi, şiddeti doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmaması ya da teşvik etmemesi gerekir. **2.** Önerilen değişikliğin kendisi de demokratik değerlerle bağdaşmalıdır. 1. Önerilen düzenin kendisinin de demokratik olmalıdır. Bir siyasal parti AİHM içtihatları çerçevesinde teokratik ya da totaliter, faşist bir düzeni savunamaz. 2. Önerdiği anayasal, hukuki düzenin değiştirilmesi durumunda ne getirmek istediği önerilerin kendisinin de demokratik anlayışla uygun olması gerekir. Aksi takdirde söz konusu parti demokratik düzeni ortadan kaldırmayı düşündüğü için kapatılacak olup bu Avrupa standartlarına uygun bir karar olacak.

28 Mart 2023

Hukuk Devleti: Vatandaşların hukuk güvenliği içinde olduğu devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı tutulduğu devlete verilen isim. Birincisi devletin hukuk devleti olabilmesi için devletin işlemlerinin belli bir hukuk kurallarına bağlı olması gerekir ve vatandaşlarında hukuki güvenlik içinde bulunması gerekir. Bunlar keyfi yönetimin karşıtını oluşturur. Yani keyfi olmayan yönetimden söz ediyoruz. Önceden öngörülebilir olan bir yönetimdir. Hukuk devleti ile diğer yönetim biçimlerinden birbirini ayıranda birtakım unsurlar vardır. Hukuk devleti polis devletinin tam karşıtıdır. Polis devleti; 1. kamunun refahını selametini önemseyen bunu her şeyin önünde tutan ve kamunun refahı ve selameti için ya da bu amaçla her türlü önlemi alabilen 2. Bunu gerçekleştirmek için kişilerin hak ve özgürlüklerine sınırlayan hak ve özgürlük alanına müdahale edebilen devlete polis devleti denir. 3. Polis devleti kendisini hukukla bağlı saymayan devlettir. Polis devleti ile hukuk devleti birbirinin zıttı 2 yönetim anlayışıdır. Maddi hukuk devleti, biçimsel (usuli) hukuk devleti ve pozitivist hukuk devleti olmak üzere 3 biçimde tanım yapılabilir.

Biçimsel veya usuli hukuk devleti: hukuk kurallarının biçimsel birtakım özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan hukuk devleti tanımı. Yani öngörülebilirlik ve hukuki eşitlik ilkelerine dayalı bir tanımdır. Hukukun öngörülebilirliği, devlet işlemlerinin önceden nasıl olacağını, o işlemlere ilişkin sonuçların neler olabileceğine ilişkin bir tahminde bulunmak olup keyfi yönetimin karşıtı anlamında kullanılır. Hukuk kurallarının öngörülebilirliği, bu kuralların birtakım ilkeleri içinde barındırmasını gerektirir

1. Genelliği: Hukuk kuralının genel bir kural olmasıdır. Kişiyne, olaya özgü bir nitelik taşınamaması aynı ya da benzer nitelikte olan herkese uygulanabilir nitelikte bir işlem ya da kural olması anlamına gelir.

2. Belirliliği ve açıklığı : O kuralın, o işlemin açık, anlaşılabilir olması anlamına gelir. Açıklık ve belirlilik birbirini tamamalar. Yani kuralın ve işlemin anlaşılabilir yani bir muğlaklık taşınamamasını haliyle olabildiği kadar sınırlı bir biçimde yürütme erkine takdir alanı tanınması anlamına gelir.

3. Tutarlılığı: aynı zamanda o işlem tutarlı olmalıdır. Yani kendi içinde çelişkiler taşınamalıdır.

4. Geçmişe yürümezliği: Konan kurallar yürürlüğe girdikten itibaren ortaya çıkan olaylar ve durumlar için kullanılır ve hiçbir zaman geriye yürümez. Bu ilke biçimsel hukuk devleti ilkesinin en temel kurallarından biridir. Biçimsel hukuk devleti yalnızca öngörülebilirlik ilkesine dayanmaz aynı zamanda eşitlik ilkesine de dayanır. Her ikisinin bir arada olması gerekir.

Eşitlik ilkesi: Kanun önünde eşitlik ilkesinin ya da biçimsel eşitlik ilkesini anlıyoruz. Yani hukuk kuralının aynı durumda bulunan herkese aynı biçimde uygulanması olarak anlıyoruz. Keyfi bir şekilde ayrımcılık yapılmamasını anlıyoruz. Yöneticilerin belli kişilere avantajlı ya da dezavantajlı biçimde davranmasının önüne geçer bu ilke.

Maddi hukuk devleti: bu anlayışta hukukun belli bir maddi içeriğinin olması gerektiği anlaşılır. Hukuk kuralının açık, öngörülebilir, eşitlik ilkesine uygun, tutarlı, genel kural koyması yetmez aynı zamanda o hukuk kuralının nasıl bir düzenleme yaptığına da bakılır. Maddi hukuk devletinde bu içerik hak ve özgürlükleri güvenceye alan düzenlemeler olması gerekir. Yani bir hukuk kuralı biçimsel hukuk devletinin gerektirdiği bütün özellikleri taşıyabilir ancak hak ve özgürlükleri aşırı sınırlayabilir ya da belli bir hak ve özgürlüğü düzenlemeyebilir, korumaya ve güvence altına almayabilir. Böyle bir anlayışın olduğu yerde maddi hukuk devletinden söz edilemez.

Pozitivist hukuk devleti: Hukuka belli usuli ya da belli bir maddi içerik yüklemek anlamsızdır yaklaşımı vardır. Hukuku yetkili organlar, usulüne uygun biçimde yaratıyorsa, kurallar kanunda öngörülmüş usullere uygun olarak yapılyorsa o zaman burada pozitivist bir hukuk devleti var demektir. Yani kanun devleti demek

olup, yürürlükteki yasalara uygun olarak hareket eden devlet kanun devleti olup aynı zamanda pozitivist hukuk devleti olarak da tanımlanır. Pozitivist hukuk devleti, maddi ya da usuli hukuk devleti değildir. Çünkü gerçekten bir yönetim yürürlükteki kurallara uygun olarak davranabilir ama yürürlükteki hukuk kurallarının kendisi eşitsiz, adaletsiz ya da baskıcı olabilir. Eğer hukuk kuralları bu tarzda düzenlemeler getiriyorsa bu kurallara uygun davranan bir devleti hukuk devleti olarak adlandırmak mümkün değildir. Bütün otoriter rejimlerde, geçmişte monarşiyle yönetilen Kralın gerçek yetkilere sahip olduğu devletlere baktığımızda bu devletlerde kendi yaptıkları yasalara uygun olarak kendilerini yönetiyor olabilirler. Ama bu o devleti hukuk devleti yapmaz. Olsa olsa kendi yaptıkları kanuna uygun davrandıkları için o devletler birer kanun devleti olabilir. Mesela Afganistan'daki Taliban rejimi kendi koyduğu kurallara uygun davranan bir devlet olabilir. Bu o Taliban rejimini ancak kanun devleti yapabilir, hukuk devleti yapmaz. Hukuk devleti için biçimsel ya da maddi hukuk devletinin veya ikisi birden özelliklerini taşıyan bir devlet olması gerekir. Eğer bir devlete kendi yaptığı kurallara da uymuyorsa artık orada keyfi bir yönetimden hatta polis devletinin de tanımı içerisine girebilecek bir yönetimden söz etmek mümkündür. AYM'nin yaptığı yorumlama biçimi bize 1982 anayasasını yorumlama konusunda yol gösteriyor. 1961 AYM, pek çok kararında hukuk devletini tanımlıyor. 2014/68 Karar sayısında 2019/3 karar sayısında da yinelemiştir, anayasada belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun insan haklarına saygılı bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu gerçekleştiren anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, tüm devlet organlarına egemen kılan hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir. 2014/68 Karar sayısında; kanunların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel objektif adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle kanun koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde, adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçülerini göz önünde tutması gerekir. 2014/98 Karar sayısında, hukuk devleti ilkesi kişiler lehine getirilen hak ve imkanların aynı zamanda erişilebilir olmasını gerektirmektedir. Bu haklardan yararlanılmasını imkansız kılan veya aşırı derecede zorlaştıran usul hakkın varlığını anlamsız kılacağından hukuk devleti ilkesine aykırı olur. Buradan usuli bir hukuk devleti anlayışına yakın bir hukuk devleti anlayışı vardır. İnsan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup, güçlendiren devlet hukuk devleti olduğunu belirtip aynı zamanda maddi hukuk devleti anlayışı da göz ardı etmemektedir. Hukuk devletinin özellikleri, gerekleri: Bu devletin vatandaşları, devlete boyun eğen uyruklar olarak değil, hak ve özgürlükleri olan, bu hak ve özgürlüklerini yargı aracılığı ile koruyan, bunları talep eden bir yurttaşlar bütünü olarak görülüyor. Bu da kuşkusuz ki hukuk devleti ilkesiyle demokrasi ilkesi arasında yakın bir ilişki olduğunu bize gösteriyor. Hukuk devleti siyasal yönü olan bir ideali ifade ediyor. Bu gerekler; 1. Sınırlı bir devlet olması gerekiyor bir devleti hukuk devleti olarak tanımlayabilmek için. Devletin sınırlı olması aynı zamanda kişilere tanınan hak ve özgürlüklerin tanınmasını gerektiriyor. Devlet; güçler ayrılığı ilkesi, belli devlet görevlerine gelenlerin bu görevleri belli süreler için yerine getirilmesi. Yine o devlet görevine gelen kişinin belli sayıda dönemle sınırlı olarak o makamda bulunabilmesi. Hep bu nitelikte kuralların temel amacı, devlet gücünün tek elde toplanmasını önlemek. Devlet gücünün tek elde toplanmasını önleyen bir başka araç, devlet içindeki bazı kurum ve kuruluşlara özerklik tanınmasıdır. Mesela TRT, Merkez Bankası gibi kuruluşlara özerklik tanınarak, bütün siyasal gücün tek bir elde, merkezde toplanmasını önlemeyi amaçlıyor. Bunun dışında yerel yönetimlere birtakım yetkiler verilmesi ya da devletin biçimi modeli de o siyasal iktidarın merkezde tek elde toplanmasını sınırlamayı amaçlayan birtakım araçlar. Bu araçlar hukuk devleti ilkesini gerçekleştiren önemli bir rol üstleniyor. Sadece bununla sınırlı değildir. Anayasacılık hareketi de hukuk devleti amacıyla çıkıyor. Yazılı, katı bir anlayışı da hukuk devleti ilkesini gerçekleştirme konusunda önemli bir rol üstleniyor. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında, anayasa yalnızca siyasal iktidarın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler değil ama temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelerin de anayasa da yer alması kuşkusuz ki hukuk devleti ilkesini güçlendiren ilkeye bir hukuki dayanak sağlayan bir düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin tanınması ve güvence altına alınmasıyla devleti ve siyasal iktidarın sınırlayan bir işlev görür. İkincisi, Hukuk devleti gerektiren işlemlerin yargı organlarının denetimine bağlı olması. Tarihsel olarak gördüğümüz temel hak ve özgürlüklere yönelik bütün ihlallerin birinci olarak yürütme erkinden geldiği görüldü. Yani Mutlak Monarşiler döneminde zaten bütün gücü elinde bulunduran mutlak krallar keyfi en iyi ihtimalle de bir kanun devleti biçiminde iş görüyordu. Haliyle temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin tümü de yürütme organına karşı geldi. Yürütme organının sınırlandırılması, yürütme organına karşı güvence altına alınması çabaları öncelikle bu organın yapmış olduğu işlemlerin yargı denetimine bağlı tutulması sürecini başlattı. Yürütme işlemlerinin yargısal denetimin 2 farklı biçimde olabildiğini görüyoruz. 1.

Yargı birliği sistemi yani Anglosakson sistemi de denir. ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Hindistan gibi Anglosakson hukuk düzenini benimseyen ülkelerde olduğunu görüyoruz. Burada yürütme işlemlerine yargı organları bakıyor. Başka deyişle adli yargı, idari yargı ayrımı bulunmuyor. Bu nedenle buna yargı birliği sistemi denir. 2. Kıta Avrupası sistemi olup burada adli yargı idari yargı ayrımı vardır. Yürütmenin işlemlerine adli yargı değil bu işe bakmakla görevlendirilmiş özel mahkemeler yani idare mahkemeleridir. Hukuk devletinin gerçekleştirilmesi bakımından hiçbir önem taşıyor. Önemli olan yürütmenin işlemlerinin yargı organının denetiminde olmasıdır. Bunun özel ya da normal mahkemelerinin yapıp yapmamasının önemi yok. Önemli olan yürütmenin işlemleri yargı denetiminde mi değil mi sorusunun yanıtıdır. Bizim hukuk düzenimiz Kıta Avrupası ya da Fransız hukuk düzeni olarak adlandırılan hukuk düzenine bağlı. Yürütmenin işlemleri bu işle görevlendirilmiş idari yargı tarafından yerine getiriliyor. Bunun anayasal dayanağı da 1982'nin 155.madde Danıştay'ı düzenliyor ve idare mahkemelerini düzenliyor. Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi bakımından bunu hangi mahkemesin yaptığı önemli değildir. Önemli olan yürütmenin bütün işlemlerinin yargı denetiminde bulunması. Özellikle 2 durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Bazı işlemlerinin anayasa ya da yasalar eliyle yargı denetiminin dışında tutulması durumu. Buna yasama kısıntısı adı veriliyor. Yürütmenin işlemlerinin anayasa ya da yasa tarafından yargı denetimi dışında tutulmasına yasama kısıntısı deniyor. Kuşkusuz bu hukuk devleti ilkesine aykırı bir durumdur. İkinci durum ise mahkemenin kendisinin siyasal nedenlerle yürütmenin belli bir işleminin yargı denetiminin dışında tutulması yani bu işlemi denetlemekten kaçınması. O işlemi denetlemek konusunda yetkili görmemesi durumudur. Buna da **hükümet tasarrufu** adı veriliyor. Yürütme işleminin denetlenmesi konusunda ne kadar gerekirse yani yürütme işlemlerini geniş ölçüde hükümet tasarrufu olarak niteleyip onu yargı denetimine bağlı tutmaz ise orada o kadar sınırlı hukuk devletinden söz etmemiz mümkün. Örneğin, OHAL ilan kararı geleneksel olarak idari yargı tarafından hükümet tasarrufu olarak kabul edilmiştir. 1924 Anayasası döneminde Danıştay, çok daha başka konularda da yürütme işlemlerini siyasal tasarruf olarak gördü. Bunlarda doğan uyuşmazlıklara bakmaktan kaçındı. Yine 1924 anayasası döneminde 1950-60 yıllarında çıkarılan bazı yasalara, yasama kısıntısı getirdiler. Yani yasa kendisi bazı idari işlemleri yargı denetimi dışında tuttu. Bunun en bilinen örneklerinden biri Emekli Sandığı kanununun 39.maddesidir. Bu dönemde idarenin memurun rızası olmadan o memuru emekliye sevk işlemini idari yargı denetimi dışında tuttu. Bu hukuk devleti ilkesini derinden zedeleyen ve hukuk devleti ilkesini tamamen ortadan kaldıran düzenlemeler. İşte 1960 döneminden önceki u olumsuz uygulamaların bir daha yaşanmaması amacıyla 1961 anayasası bu konuda açık bir düzenleme getirdi. 1961 anayasasının 114.maddesi idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında tutulamaz diyor. 114.madde 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile "idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır" haline geldi. Bu düzenleme maddenin ilk biçimine göre az vurgulu bir görüntü sergilese de iki ifade arasında herhangi bir fark yoktur. Bunlardan çıkan sonuç, idarenin işlemlerinin yargı denetimine bağlı tutulmak zorundadır. 1982 Anayasası da 1961 anayasasının getirdiği bu hükmü 125.madde de yineliyor. Yalnız 191 anayasasından çok önemi farkı vardır 1982 anayasasının, anayasanın kendisinin bizzat yasama kısıntısı getirmesi. Yani bazı idari işlemleri yargı denetimi dışında bırakması. 125. Maddenin İlk biçiminde 2.fıkra 2 tane önemli istisna vardı. Biri CB'nın tek başına yaptığı işlemler İkincisi ise Yüksek Askeri Şura kararları. Her ikisi de pür yürütme işlemi. 1961 Yılından farklı olarak açık bir şekilde 1982 anayasasının 125.maddesinin 2.fıkrasında istisna hükmü olarak ele almış. 1982 Anayasasının ilk biçimi parlamenter sistem idi. CB'nın işlemleri çift imza kuralına bağlı. Bu işlemler yargı denetimine açık. Yargı denetimine kapalı olan CB'nın tek başına yaptığı işlemler. Bu işlemler, CB'nın bir devlet başkanı olarak yaptığı işlemler. Bu işlemleri yargı denetimi dışında tutulması, hukuk devleti ilkesini zedeleyici bir durum değil. Buna karşılık Yüksek askeri Şura kararları, niteliği itibariyle tam bir idari işlem, bunun yargı denetimi dışında tutulması açıkça hukuk devleti ilkesine aykırılık oluştuyordu. CB'nın tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında tutulacağı düzenleme 2010 anayasa değişiklikleriyle kaldırıldı. Çünkü Hükümet sistemi değişti ve bunun sonucu olarak da CB'nın eylem ve işlemleri bakımından böyle bir yasak ortadan kalktı.

Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin olarak da 2010 yılında sınırlı bir biçimde yargı denetimine bağlı tutuldu. İkinci fıkrada ilişik kesme kararlarına karşı halen yargı yolu açıktır. Bu söylenen 2 ilişik kesme kararlarının dışındaki yargı yolu açıldı ama Yüksek askeri şura kararlarının yargı denetimi dışında tutulması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığının altını çizelim. Hukuk devleti ilkesini zedeleyen anayasanın getirdiği

İkinci bir istisna anayasasının 159/10 da bulunuyor. 1982 Anayasasının ilk biçiminde o zamanki adıyla hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarının da yargı denetiminin dışında tutulmuştu. Oysaki bu kurulun

kararlarının tümü idari bir işlem. İdari işlemler de bir hukuk devletinde yargı denetimi içinde tutulması gerektiği için bizzat anayasa ile getirilmiş çok önemli ayrıksı bir düzenlemedir. 2010 Anayasa değişikliği ile Hakimler ve savcılar Kurulunun bazı kararları yarı denetimi içine alındı. Meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanla dışındaki kararlar, yargı yoluna başvurulamaz diye değiştirildi 159/10 maddesi. Böylelikle meslekten kesin olarak çıkarma cezasına ilişkin olanlar bakımından yargı yolu açıldı. Ancak diğer kararlara ilişkin olarak yargı yolu halen kapalı olup hukuk devleti ilkesi bakımından son derece sakıncalı bir istisna olmaya devam ediyor. 129. Maddesini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. İlk biçimi uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin kararları yargı denetimi dışındaydı. Şimdi bütün disiplin kararları yargı denetimi içinde tutulmuştur 2010 anayasa değişikliği ile. 125.Maddenin 4.fıkrası yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 3. Fıkradan itibaren getirilen düzenlemelerin en temel ilkelerle düzenlemeler olduğunu görüyoruz. 3. Fıkranın hukuk devleti ilkesi ile ilişkisi var. 4. Fıkra, hiçbir şekilde yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz ifadesi 2010 anayasa değişikliği ile birlikte eklendi. Burada önemli olan, yerindelik denetimi olamaz diyor. Neyin yerindelik denetimi neyin hukukilik denetimi olduğunu ayırmak her zaman mümkün değil. Bu idari yargının doğasından kaynaklanan durum. Bu düzenlemenin uygulama da çok anlamı da yoktur. 5. Fıkranın idari yargıda çokça kullanılan yürütmeyi durdurma kararını tanımlamıştır. Son fıkra ise bu yürütmeye getirilecek bir sınırlamaya ilişkin bir kısım. Yani OHAL’de, seferberlik ve savaş hallerinde yargının vereceği yürütmeyi durdurma kararlarının kanunla sınırlanabileceğini belirtiyor. Kanun, yürütmeyi durdurma kararlarını bu olağanüstü durumlarda bile ortadan kaldıramaz. Ancak olağan dönemlerden biraz daha sınırlayabilir. Sonuç: 125. Maddenin son üç fıkrasının idare hukukunun temel ilkelerini açıklayan düzenlemeler olduğunu anayasa bakımından herhangi bir güvence getirmediğini söyleyebiliriz. İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Yasama organının, yargı tarafından denetlenmesi tarihsel olarak yürütmenin denetlenmesinden sonra gelir ABD deki Anayasa yargısının ilk çıkışı Mytysan örneği ve siyasi denetim şeklinde.

Çoğunlukçu demokrasi anlayışının çok uzun süre 2. Dünya savaşının sonuna kadar egemen olmasının da yasama işlemlerinin yargı denetimine bağlı tutulmasını söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir demokrasi yaklaşımı benimsendiği zaman parlamentonun çoğunluğu ulusal iradeyi temsil ediyor. Ulusun kararlarının başka bir organ tarafından denetlenemeyeceği söz konusu olamayacağına göre ulus siyasi düzen içerisinde en üstün irade olarak kabul edildiğine göre onun adına işlem yapan parlamentonun yasalarının da işlemlerinin yargı denetimi konusu olması mümkün olamaz. Tıpkı idarenin işlemleri gibi parlamentonun işlemleri de anayasaya, hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturabilir. Burada yürütme işlemlerinin yargısal denetiminde olduğu gibi yasal işlemlerinin yargısal denetiminde de 2 büyük anlayış vardır.

1. Siyasi denetim: bu denetimin parlamento içinde ya da dışında kurulacak yargıç olmayan bir kurul veya komisyon aracılığı ile yapılması, örneğin Fransız 3.-4. Cumhuriyetlerinde 1924 Anayasası döneminde ülkemizde yasaların anayasaya uygunluğu denetiminin siyasi bir denetim olarak yapıldığını görüyoruz. Bu denetimi yapanlar yargıç olmadığı için siyasi figürler olduğu bunların verdiği kararlar da siyasi saiklerle verilen kararlar ve bunlar hep hukuki değerlendirmenin önüne geçmiş kararlardır. Bu yüzden de siyasi denetimin, hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek bakımından herhangi bir olumlu sonucu olmamıştır.

2. Durum ise yasaların anayasaya uygunluğunu yargı organları tarafından denetlenmesi tıpkı yürütme işlemlerinde olduğu gibi. Burada da ikili bir ayırım yapmak mümkün. 1. Yasaların, anayasaya uygunluğu denetimini yetkisinin bütün mahkemelerde olduğu sistem. Biz buna merkezsizleşmiş anayasa yargısı deriz. Yani Anglosakson hukuk düzenini benimsemiş olan devletlerde yasaların anayasaya uygunluğu denetimini bütün mahkemelerin yaptığını görüyoruz. ABD, Avustralya, Kanada, Meksika, Arjantin gibi bu merkezsizleşmiş anayasa yargısını benimsemişlerdir. Merkezleşmiş anayasa yargısı ise, yasaların anayasaya uygunluğu denetimini bu işle görevlendirilmiş özel bir mahkemeye bırakılan sistem. Yani anayasa mahkemelerinin olduğu sistem. 2. Dünya savaşından sonra özellikle pek çok ülkede ortaya çıkan düzen. Başta Almanya, İtalya, Avusturya olmak üzere bizde de 1961 Anayasası ile merkezleşmiş anayasa yargısı sisteminin kabul edildiğini görüyoruz. Tıpkı yürütme işlemlerinde olduğu yasama işlemlerinin yargısal denetiminde, bu denetimin merkezleşmiş mi yoksa merkezsizleşmiş mi bir yargı düzeninde yapılması önemli değildir. Önemli olan yargı organının, yasaların anayasaya uygunluğu denetimini yapması. Bu konuda da istisna bulunmaması, her türlü yasanın bu denetim içinde bulunmasıdır. 1982 Anayasası 1961 anayasasını izleyerek merkezleşmiş bir anayasa yargısı modelini sürdürüyor. 1961 Anayasasından farklı olarak bazı normların anayasa denetimi dışında tutulmasını öngörmüştür. Bunlardan biri, 1961 anayasasında olan düzenlemeydi. Anayasanın 174.

Maddesi oku. Amaç, toplumu çağdaşlaştıran ve laik bir toplum ve devlet düzeni kurmayı amaçlayan kanunlar. Bu kanunların, anayasanın bazı hükümlerine aykırı görülmesi mümkün. Bunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu kanunlarda değişiklik yapılması, bunların yürürlükten kaldırılması mümkün. Önemli değiştirilmemiş olan kanun hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasının anayasa mahkemesine taşınamayacağına dair düzenleme. Hukuk devleti ilkesini derinden yaralayan asıl önemli istisna anayasanın 148. Maddesi. 82 Anayasasının ilk biçiminde de vardı. 2017 Değişiklikleri sonrasında da devam etti. OHAL kararnamelerinin, anayasa denetiminin dışında tutuluyor. Bu hukuk devleti ilkesi bakımından kabul edilemeyecek bir istisna hükmü anayasa ile getirilmiştir. Hukuk devletinin bir başka gereği, yargı kuruluşlarının güvenilirliğinin sağlanması. Bir hukuk düzeni içinde yaşayan kişiler, o yargı organının vermiş olduğu kararlara saygı duymalıdır. Bu kararların adil olduğu konusunda kamuoyunun ya da toplumun bir görüşü olması gerekir. Eğer mahkemelerin vermiş olduğu kararların adil, hukuki olmadığına ilişkin kamuoyunda genel bir kanı var ise orada hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Yargı kuruluşlarına toplumun genelinin güven duyması bu bakımdan son derece önemlidir.

Bu güveni sağlamak için gerekli ilke ve kurallar: 1. Bu yargı kuruluşlarının özellikle yürütme ve aynı zamanda yasama organından bağımsız kılınmasını sağlayacak bir düzenlemeler. Bunun bağımsızlığı birincisi kurumsal olarak yani mahkemelerin yürütme ve yargı organlarından etkilenmeden onlardan bağımsız bir kurum olarak çalışmasını sağlayacak düzenlemeler.

2. Kişisel bağımsızlık yani yargıçlara sağlanacak bir takım kişisel güvencelerle yargıçları, yürütme, yasama aynı zamanda toplumdan gelecek baskılara karşı direnir tarafsız bir şekilde önlerindeki davayı çözmesini sağlamak. 3. Doğal yargıç ilkesinin kabul edilmesi. Anayasanın 9.maddesi yargı yetkisini düzenliyor. Tarafsız ifadesi 2017 anayasa değişikliği ile eklendi. Bu yargının tarafsızlığına ek bir güvence getiren bir düzenleme değildir. Mahkemelerin bağımsızlığı Cambyes tablosu Bruges belediye binasında asılı. Bu ilkenin gereği olarak doğal yargıç ya da kanuni yargıç ilkesi düzenlenmiştir. Hukuk devleti ilkesi ilk defa 1961'in 2.maddesinde düzenlenen bir ilkedir. "T.C, insan haklarına dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir." Bu maddi anlamda tanımlı bir hukuk devletini içeren bir tanımdır. Herhangi bir hukuk devleti değil, insan haklarına dayanan demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti. 1982 Anayasası da 2.maddesinde bu yaklaşımı devam ettiriyor. Bir fark insan haklarına saygılı ifadesi. Maddi anlamda tanımlı bir hukuk devleti. 1924 Anayasası hukuk devletine ilişkin bir düzenleme getirmemişti. Ama hukuk devletinin bazı unsurlarının diğer maddelerde yer aldığını söylemek mümkün. 61 ve 82 Anayasaları hem bu ilkeyi açık olarak devletin niteliklerinden birisi olarak sayıyor. 82 Anayasası bakımından bu ilkenin değiştirilmesi yasaklanıyor. Hem de anayasanın çeşitli düzenlemelerinde bu ilke somutlaştırılıyor. Bunlardan birisi yargı kuruluşlarının güvencesi olan doğal yargıç ilkesi: 1924-61-82 anayasalarında yer alan bir ilkedir. En kısa düzenleme 1924 anayasasında olan bir düzenlemedir. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve sevk edilemez. Burada kanunen tabi olunan mahkeme ifadesinin olduğunu görüyoruz. 61 Anayasasının ilk biçimi ise bunu tabi yargı yolu yani doğal yargı yolu biçimine dönüştürüyor. "Hiç kimse tabi hakiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi tabi hakiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz." İster buna kanunen tabi olunan mahkeme deyin ister tabi yargı yolu deyin. Bir olay olmadan, uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce o uyuşmazlığı kimin karara bağlayacağını o uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kanunla belli olması anlamına gelir, kanuni hakim güvencesi. Yargılayacak organın ve suçun, o suç gerçekleştirilmeden önce kanunla belli olması anlamına gelir. 1971 Yılında anayasanın 32.maddesini değiştirildi. Tabi yargı yolu yerine kanuni yargı yolu ifadesi kullanıldı. Yine kanunen tabi olunan mahkeme ifadesi kullanıldı. 1982 Anayasası da, 61 ve 71 de yapılan değişikliği izliyor. 37.maddesi kanuni hakim güvencesidir. 82 Anayasasının 142.maddesi de yine aslında doğal yargıç ilkesi ile ilgili bir düzenleme. 1961 Anayasasında da vardı. Amaç, bir olay bir uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce bu uyuşmazlığı hangi mahkemenin çözeceğinin belli olması ve böylelikle de olağanüstü nitelikte mahkemeler kurulmaması. Özellikle istiklal mahkemeleri bakımından ve 60 darbesinden sonra kurulan yassı ada yüksek adalet divanı bakımından bu doğal yargı yolunun işletilmediğini söyleyebiliriz. Kanuni hakim ilkesinin getirilmesindeki amaç, hakim ve savcıların olaya ve o olay sonucunda yargılanacak kişilere ilişkin nesnel olmasını sağlamak. Belli bir olaya, kişiye yönelik karar vermesini engellemek aynı zamanda yargıçlara karşı kamuoyundan gelecek etkilere karşı korumak. Olaya ve kişiye göre mahkeme kurulmasını engellemek suretiyle adil bir yargılama yapılmasını sağlamak. Öğretide kabul edilen, doğal yargı yolu, doğal yargıç güvencesiyle kanuni hakim güvencesi aynı anlama gelmektedir. Amaç olağanüstü mahkemelerin kurulmasının engellenmesi. Böyle bir nitelik taşıyan mahkeme anayasanın 37.maddesine aykırı olacaktır. Anayasa

mahkemesi de bu şekilde düşünüyor. “ Kanunen tabi olunan mahkeme, kuruluşu, görev ve yetkileri kanunla önceden belirlenmiş genel olarak ve herkes için yetkili olan mahkemedir.” AYM kararlarında, doğal hakim ilkesi: yargılama makamlarının uyuşmazlığın meydana gelmesinden sonra kurulmasını veya davanın taraflarına göre hakim atanmasını engellemek kararı 2013/93 K.

Mahkemelerin güvenilirliğini sağlamanın 2. Önemli ilkesi, mahkemelerin bağımsızlığına yönelik güvencelerin getirilmesi. Mahkemelerin bağımsızlığını 2 biçimde düşünüyoruz.

1. Kurumsal bağımsızlık: genel olarak mahkemelere yönelik olarak dışarıdan gelecek mahkemelerin, yargıçların dışarıdan gelecek her türlü etkiye karşı korunmasını ifade eder.

2. Kişisel bağımsızlık (güvenceler): Yargıçlara getirilmiş bazı kişisel güvenceleri içinde barındırır. Yargıçlar bu kişisel güvencelerle yine dışarıdan gelecek etkileri göz ardı ederek kanuna, hukuka ve anayasaya ve vicdanlarına göre karar verirler. Anayasanın 9.maddesi yargı yetkisinin bağımsız olduğuna ilişkin düzenleme. Asıl önemlisi 138.maddesi. Buradan çıkan sonuç, Türk anayasa hukukunda mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlerin bağımsızlığı aynı anlamda kullanılıyor. 1.Fıkra; yargıçların neye göre karar vereceğini düzenleyen bir fıkradır. Fıkroda yazanların dışında başka bir etmen yargıcın önündeki davayı sonuçlandırırken göz önünde bulunduracağı etmenler. Mahkemelerin bağımsızlığı ilk olarak 1876 anayasasında düzenlenmişti. 1924 anayasasında buna ilişkin düzenleme olmakla birlikte ciddi sonuç doğurucu hukuk devleti ilkesini gerçekleştirecek düzenlemeler olmadığını söyleyebiliriz. Mahkemelerin bağımsızlığını sağlamaya dönük Hakimler savcılar kurulu gibi pek çok araçla mahkemelerin bağımsızlığını sağlayan ilk anayasa 1961 anayasasıdır. 1982 Anayasası, önceki anayasanın getirdiği bu genel sistematığı korudu. 1982 Anayasasının ruhundan dolayı 61 anayasasından daha geri düzenlemeler içeren olduğunu belirtelim. 138.Madde mahkemeleri, dışarıdan gelecek her türlü etkiden korumayı amaçlayan bir düzenleme. Dışarıdan gelecek etki; yargı organı ve yargıçlar, öncelikle yürütme erkine karşı bağımsız kılınmalıdır. Arkasından yargı erkine karşı da bağımsız olmalıdır. Nitekim 138/3 yasama erkine karşı mahkemeleri koruyor. Amaç, parlamentonun, yargıçların karar verirken etkilemesini engellemek. 2. Olarak yürütme erkinin etkilerine karşı mahkemeleri ve yargıçları korumayı 2.fıkroda düzenlemiştir. Maddi anlamda yargı etkisine ilişkin bir yasa. Yani yargıçlar hep yargı yetkisini kullanıyor. Bu bakımdan 138/2 deki idareye ve yürütmeye ilişkin yasaklar geçerli. Ama bunun yanında her yargıç kalem işlerinin yürütülmesinden ve personel yönetiminden de sorumlu kişiler. Kalem işlerinin yürütülmesi ve personel yönetimine ilişkin işlerde hakimlerin adalet bakanlığı adına bu işleri yaptığını söyleyebiliriz. Bu işleri yaparken yargıçlar, idari bir makam olarak bu görevi yerine getiriyorlar. Bu işleri görürken, adalet bakanlığından talimat, tavsiye alması ya da emir alması mümkün. Ama anayasasın 138/2 de belirtilen yasaklar bakımından idare ve yürütme organından emir ve talimat almama ilkesi hakimlerin yargılama yetki ve görevlerini kullanırken geçerli olan bir yasaktır. 144.Madde de bunu destekliyor. Kuşkusuz ki mahkeme ve yargıçlar yalnızca yasama ve yürütme organlarına karşı değil, diğer mahkemelere karşı da bağımsızlıklarını korumalıdır. Alt mahkemeler bakımından, verdiği kararın üst dereceli mahkemeye gitmesi, temyiz edilmesi, alt dereceli mahkeme ile üst dereceli mahkeme arasındaki ilişki, bunun yanı sıra mahkemenin kararına itiraz gibi yargılama usullerine ilişkin araçlar, bir mahkemenin diğer mahkemeye emir ve talimat vermesi anlamına gelmez. Emir ve talimat vermek demek üst derece veya bir başka mahkemenin genel olarak bir mahkemenin bir davayı görmesi sırasında daha mahkeme o davayı sonuçlandırmadan ona ilişkin olarak onun sonucunu etkileyecek biçimde herhangi bir talimat iletmesi anlamına gelir. Bunun dışında AYM’nin bireysel başvuru yoluyla belli bir mahkemenin verdiği kararı anayasaya aykırı bulması, bir temel hak ve özgürlüğün o karar yoluyla ihlal edildiğinin tespit etmesi o mahkemeye yönelik bir müdahale değildir. Burada bir mahkemenin bir başka mahkemeye müdahale etmesi onun bağımsız karar vermesi, etkilemesi anlamını taşımayacak. Mahkemeler yalnızca yasama, yürütme organları diğer mahkemelere karşı değil aynı zamanda 3.kişiler, basına karşı da koruma altındadır. 147/5 deki amaç, hakimleri etkilenmesi olası her türlü çevreden uzak tutmaktır. Yani maddi bir çıkar gözeterek hakimın karar vermesini engellemek. Basında yargıyı etkileyebilir. Nitekim anayasanın 26/2 düşünce ve ifade özgürlüğü de hem de 28/5 basın özgürlüğünü düzenleyen madde bu konuda bir sınırlama getirdi. Günümüzde mahkeme siyasal nitelik taşıdığını düşündüğü davalarda hemen yayın yasağı getiriyor. Yargılamanın basın yoluyla etkilemekle toplumun ya da kamuoyunun haber alma özgürlüğünün ortadan kaldırmamak arasında bir denge kurması gerekir. 138/son fıkrası da yargıçların bağımsızlığını sağlayabilmek aynı zamanda onların verdiği kararların uygulanması ile mümkün. AYM kararları ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.153 /son fıkrası AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirtir. 138 ve 153/ son fıkralarını birlikte değerlendirdiğimiz zaman AYM kararları da dahil olmak üzere bütün mahkeme kararlarının eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekir. AYM’nin Bireysel başvurulara ilişkin verdiği

kararların ilk derece mahkemeler tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu kararların hem 138. hem de 153. maddeler çerçevesinde anayasaya aykırı olduğunun altını çizelim.

29 Mart 2023

Yasama kararlarına bizzat uymak zorundadır. Yasama organı bakımında 2 istisnanın bizzat anayasa ile getirildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi, af kanunları anayasanın 87.maddesinde TBMM'nin üye tam sayısının 3/5 oyu ile af kanunu çıkarabiliyor. Af kanunu çıkınca affedilen suçtan mahkum olanlar ve dolayısıyla buna ilişkin mahkeme kararları uygulanabilir olmaktan çıkıyor. Yine anayasa ile getirilen bir başka istisna anayasanın 104/16 maddesinde CB'na tanınan yetki. O da sürekli hastalı sakatlık, kocama gibi nedenlerle ona verilen cezanın hafifletilmesi, kaldırılması yetkisi. CB bunu kullandığı zaman söz konusu mahkeme kararı uygulanabilir olmaktan çıkıyor. Her iki istisna da anayasa ile getirilmiştir. Mahkemelerin bağımsızlığı, güvenilirliğinden söz edebilmek için 1. Mahkemelerin bir kurum olarak bağımsızlığını sağlayacak düzenlemelerin olması gereklidir. Bunun yolu da diğer erklerden, dış çevre unsurlarından bu mahkemeyi yargılama sürecini bu etkilerden uzak tutmak. 2. Yargıçlara bir takım kişisel güvenceler getirmek. Bu kişisel güvenceler yargıçlara birtakım ayrıcalıklar getiren güvenceler değil bunları dış unsurların etkilerinden uzak tutmayı amaçlayan dolayısıyla bir kamu çıkarı amacıyla yargıçlara verilen güvenceler. Bunun adı yargıçlık güvencesidir. 1961 Anayasası ile ilk defa güvenceye alındı yargıçların kişisel birtakım ayrıcalıkları. 1924 Anayasasında bunun kanunla düzenleneceği belirtiliyordu. Yargıçlık güvencesi ilk defa 1961 anayasası ile bu anayasanın 133.maddesi ile getirildi. 1982 Anayasası 139. Madde de bunu düzenledi. 61'den farklı olarak bu güvenceyi savcılar bakımından da genişletti. Hakimlik ya da yargıçlık güvenceleri nedir: 1. 139.madde de yazılan güvence. 2. 65 Yaşından önce kendileri istemedikçe emekli edilememeleri Anayasanın 140/4 de yer alan bir güvence. Çünkü 1924 anayasası döneminde idarenin ve yürütmenin beğenmediği kararları alan yargıçların Adalet Bakanlığı tarafından yaş haddine ulaşmadan reysen emekli edildikleri görülüyordu. Bu olumsuzlukları bir daha yaşamamak için hem 61 hem de 82 anayasası 140. Madde de yargıçlara buna ilişkin bir güvence getirdi. Bunun istisnası vardır. Anayasa da belirtilmiştir. 1. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymişse bir yargıç. 2. Görevini sağlık nedeniyle yapamayacağı kesin olarak belli olmuşsa 3. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekte kalması uygun bulunmamışsa bu yargıcın görevine 65 yaşına ulaşmadan son verilebiliyor. 1982 Anayasasının getirdiği bir başka güvence, mahkemenin ya da bir kadronun ortadan kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yargıçların yoksun bırakılamayacağı. Yargıç, yürütme erkinin hoşuna gitmeyen bir karar vermişse onu cezalandırma ya da yürütmenin istediği doğrultuda kararlar alma sağlamak amacıyla yürütmenin bu nitelikte mahkemenin kaldırılması, o yargıcın kadrosunu kaldırması gibi önlemler almak yoluyla yargıcın istediği biçimde karar vermesini engellemek. Yürütmenin yargıç üzerindeki etkisini engellemek. Kanunda açıkça belirtilmedikçe yargıçların ek bir görev üstlenmeyeceklerine ilişkin düzenleme. Bu da yargıcın birincisi yargılama işlemine asli işini hakkıyla yerine getirebilmesini sağlamak. İkincisi başka ekonomik çıkarları göz önünde bulundurarak kararları vermesini engellemek. Anayasanın 140/3 maddesinde hakim ve savcılık mesleğine ilişkin olarak bazı konuların kanunla düzenlenmesini öngörüyor. Burada sayılan alanlarda çıkarılacak yasaları iki ölçütü içinde barındırmasını öngörüyor. Bunlardan bir tanesi mahkemelerin bağımsızlığı diğeri yargıçlık güvencesi. Bu iki ilkenin esaslarına uygun olmak kaydı ile yargıç ve savcılarının nitelikleri atanmaları hakları ve ödevleri, meslekte ilerlemeleri, görev ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve bunların yargılanmasına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suç ve yetersizlik halleri meslek içi eğitimleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Bu kanunlar sıradan değildir. Günümüzde demokratik ülkelerin tümünde bu işi yapmakla görevlendirilmiş özel kurullar oluşturuluyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu gibi özerk kurullar oluşturuluyor. Bu kurulların amacı; bu denli önemli konularda yürütme organının etkisi dışında bağımsız kurullar tarafından yerine getirilmesi. Bu kurulların yapısı görev ve yetkileri konusunda yukarıda saydığımız konuları yapmak üzere donatılmıştır. Bu kurulların yargı bağımsızlığını ve hukuk devleti ilkesini gerçekleştirebilmesi ve buna uygun olabilmesi için asgari birtakım koşullara da sahip olması gerekir. Venedik komisyonu bu konuda da raporlar hazırladı ve birtakım minimum standartlar belirledi. Bu kurullar nasıl oluşturulmalı ki hukuk devleti ilkesi ve yargı bağımsızlığı gerçekleştirilsin. 1. Bu kurulun üyelerinin çoğunluğu yargıçlardan oluşmalı. 2. Kurul üyelerinin tümünün yargıçlardan oluşması ve aynı zamanda onları yargıçların seçmesi bir çeşit kast zihniyetine sahip yargı teknokrasisine yol açabilir. O nedenle bu tür kurullarda kurul içinde azınlıkta kalmak kaydı ile yargı mensuplarının dışında üyeler bulunabilir. Bu yargının hesap verebilirliğini sağlar. Eğer bu tür kurullar kapalı

bir devre usulü ile yapılıyorsa ve yalnızca yargıçlardan oluşan ve onların seçtiği kurullar tarafından yukarıda sayılan işler yapılıyorsa o zaman orada yargının hesap verebilirliğinden söz edemeyiz. Bunun gerçekleştirmek için yargıç üyelerinin dışında başka kişilerin de bu kurullarda olması gerekir. Bu aynı zamanda toplumdaki değişiklikleri, değişen eğilimleri gözlemesi, adapte olmasını sağlayacak değişikliktir. Bu kurul üyelerini 1. sadece yargıçların seçtiği örnekler olabiliyor. Böyle olunca az önce saydığımız sakıncalar olabiliyor. Genellikle şu yol izleniyor. Bu kurulun üyelerinin bir kısmı yürütme bir kısmı yasama bir kısmı da yargı organı tarafından seçiliyor. Ama seçilen üyelerin büyük bölümünün de yargıç olması genellikle olması gereken bir durum.

Bu kurul Türkiye’de nasıl oluşturuluyor. 1982 Anayasasının 159.maddesinde HSYK mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatlarına göre kurulur ve görev yapar. Bu kurul ilk defa 1961 anayasası ile oluşturuldu. Hakimlik güvencesi ve mahkemelerin bağımsızlığı tamamen adalet bakanlığının elinde olan bir konu idi. Yargıçlık güvencesine ilişkin şunu da ekleyelim.

1. Coğrafi güvence esası: geçici ya da sürekli olarak yargıçların çalışacakları yerin değiştirilmemesidir. Pek çok demokratik ülkede bir coğrafi güvence getirilmiştir. Yani kendi onayları olmadan çalıştıkları yeri sürekli veya geçici olarak değiştirilememesine ilişkin bir güvence. Böyle bir güvence yoksa o zaman yargıçları sindirmek ya da cezalandırmak amacıyla yargıçları geçici ya da sürekli olarak yer değiştirmesi mümkün olabiliyor. Türkiye’de ne 61 ne de 82 anayasası böyle bir güvence getirmedir. 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra yapılan hakimler kanununda coğrafi güvence vardı. Ancak 1972 de yapılan yasa değişikliği ile bu güvence kaldırıldı. Tamamen bu iş yürütme organına bırakıldı. Günümüzde yargıçların görev icabı başka bir yerde görevlendirilmesi mümkün olabiliyor. Bunun çok büyük oranda kötüye kullanıldığını görüyoruz. Zaman zamanda bu bir ayrımcılık olarak ortaya çıkabiliyor. Torpilini bulan uzak bir yerden geçici olarak daha büyük bir kente getirilebiliyor.

2. Hakimlerin, savcı olarak görevlendirilmemesine ilişkin bir durum: Türkiye de bunun da güvencesi yok. Hakimlerin kendi istekleri olmadan savcı olarak görevlendirilmeyeceğine dair bir güvence yoktur. 1982 Anayasasında getirilmemiştir. 1989 Yılında AYM verdiği bir kararda idare mahkemelerinde görev alan yargıçların adli yargı da, adli yargı da görev alan yargıçların da idare mahkemelerinde görevlendirilmesine ilişkin yasanın anayasaya aykırı olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık hakimlerin savcılık sınıfına kendi istekleri dışında geçirilmesine ilişkin bir kararı yoktur. Bu da kötüye kullanmaya son derece uygun bir durum.

HSYK görevleri: Anayasanın 159.maddesinde düzenleniyor. Görev ve yetkileri son derece önemli yargıçların bağımsızlığını ve yargıçlık güvencesini sağlamak bakımından. Geçici görevlendirmek, adli ve idari hakimleri ve savcılarını mesleğe kabul etmek, atamak, nakletmek, yükseltmek ve 1.sınıfa ayırmak, kadro atamak, meslekte kalmaya uygun olmayanları meslekten çıkarmak, disiplin cezaları vermek, görevden uzaklaştırmak vb. Bunların dışında da HSYK, hem yargıtaya hem Danıştaya hem de Uyuşmazlık Mahkemesine de üye seçmekle yetkilidir. Son derece geniş yetkilerle donatılmış kurumdur. İlk defa kurulduğu 61 anayasasında 2 ayrı kurul vardı. Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek savcılar Kurulu şeklinde. 1982 Anayasası bunu tek bir kurul haline getirip adını da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yaptı. Bu baştan itibaren eleştirilen bir durumdu. Çünkü nitelikleri itibariyle yargıçlık ve savcılık 2 ayrı meslek kurumu. Bunların nitelikleri de birbirinden ayrıdır. Dolayısıyla bunların özlük işlerinin de 2 ayrı kurul tarafından yerine getirilmesi gerekir. Ancak hem 2010 hem de 2017 yılında bu kurulun yapısında çok önemli değişiklikler yapıldı. Ancak ikisinde de bu kurulun yapısı değiştirilmedi. 2017 Anayasa değişiklikleri ile bugün adı Hakimler ve Savcılar Kurulu haline geldi. Bu kurul nasıl oluşuyor. 1961Anayasasının ilk biçiminde yüksek hakimler kurulu 18 asıl 5 yedek üyeden oluşuyordu. Bunların altısını yargıtay genel kurulu altısını 1.sınıfa ayrılmış hakimler üçünü millet meclisi üçünü de Cumhuriyet Senatosu seçiyordu. Millet meclisi ve CS yüksek mahkeme üyesi olmuş ya da olmaya hak kazanmış yargıçlar arasından bu seçimi yapıyordu. Hem yüksek mahkemeler hem diğer mahkemeler hem de yasama organı bu kurula üye seçiyor. Ve üyelerin tümü de yargıçlardan oluşuyor.

1971 Anayasa değişiklikleri bu yüksek hakimler yapısını ve seçimini esaslı bir biçimde değiştirdi. 1. Üye sayısını azaltıyor. Artık 11 asıl 3 yedek üyeden oluşuyor. Kurulun bütün üyelerinin yargıtay genel kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilmesi esasını getiriyor. Burada bir cohabitasyon sisteminin olduğunu görüyoruz. Bu kurul bütün yargıçların özlük işlerine bakıyor ama yargıtayın üyelerinden oluşuyor ama kurul yargıtay tarafından seçiliyor. Haliyle çoğulcu bir yapıdan tekilci bir yapıya gidiş olduğunu görüyoruz. 1982 Anayasasının ilk biçimi ile daha da küçültülüyor Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. 3 Asıl 3 yedek üyeli

yargıtay genel kurulu 2 asıl 2 yedek üyeli Danıştay Genel Kurulu, kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri 3 kat aday arasından CB seçiyor. Anayasanın genel özellikleri çerçevesinde bu kurulun oluşturulması 1. Yalnızca yüksek yargı üyelerinin inisiyatifine bırakılmış 2. Seçme yetkisi de yürütme organına ve onun içinden de CB'na bırakılmış bir yetki.

1982 Anayasasına göre üyeler 4 yıl için seçiliyordu ve yeniden aynı üyenin seçilmesi mümkündü. Üyelerin görev süreleri ve yeniden seçilmelerine ilişkin kural günümüzde de geçerli. 2010 Yılında HSYK yapısında ve seçim biçiminde yine esaslı bir değişikliğe gidildi. 1982 Anayasasının ilk biçiminde de HSYK'nun bu 5 üyesi gösterilen adaylar arasından CB seçiyordu. Adalet Bakanı kurulun asıl başkanı ve Adalet Bakanı müsteşarı da kurulun asıl üyesi. Sonuçta 7 kişilik kurulun 5 kişisi yargıçlardan 2 kişisi ise yürütme kurulundan oluşuyor. Bu kurulun başkanının Adalet Bakanı olması müsteşarının da doğal üyesi olması en çok eleştiriye konu olan durumlardan biri. Bu yürütme organının, yasama organı etkisinden uzak tutulması gerekir, Hukuk devleti ilkesi gerçekleşsin diye. Tam tersine 2 tane yürütme organının başında olan 2 kişi alınıyor. 2010 Anayasa değişiklikleri ile üye sayısı 7 den 22'ye çıkarılıyor. Bunların 4'ünün CB tarafından öngörülüyor. Bunlar hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçecek. Beşi yüksek mahkemeler tarafından seçiliyor. Üçü yargıtay ikisi Danıştay tarafından onu alt dereceli mahkemeler tarafından doğrudan seçiliyor. Bu on kişinin yedisi adli yargı üçü idari yargı arasından seçilecek. Birisi de Türkiye Adalet Akademisi tarafından üye seçilmesi öngörülüyor. Halen kurulun başkanı Adalet Bakanı ve bakan müsteşarı da kurulun doğal üyesi konumunda bulunuyor. Bu kurulun seçim yöntemi kurulun bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak bir nitelik taşıması gerekir. Uygulamada ise bunun tam tersi bir durum söz konusuydu. Burada yargının siyasallaşması durumunu oluşturdu. 2010 anayasa değişiklikleri HSYK eliyle yargıyı siyasallaştırdı.

2017 Anayasa değişiklikleri yine birtakım değişiklikler getirdi. Kurulun üye sayısı azaltıldı. 13 Üyeden oluşuyor. Bunların dördü CB tarafından seçiliyor. Üçü yargıtay biri Danıştay, üçü de serbest olarak TBMM tarafından seçiliyor. Seçecek olan organlar ikiye indirilmiş. CB ve TBMM. CB serbest seçim yapıyor. TBMM seçeceklerinin üçünü yargıtayın gösterdiği yargıtay üyeleri arasından birini Danıştay üyeleri arasından, üçünü de serbest avukatlar ve hukukçu öğretim üyeleri arasından seçiyor. Kurulun başkanı değişmiyor. Adalet Bakanı ve kurulun doğal üyesi de Adalet bakanı müsteşarı yani bakan yardımcısı.

Sonuç: 2017 anayasa değişikliklerinden sonra da yürütme organının kurul üzerindeki ağırlığı aynen devam ediyor. Dört üyeyi CB atıyor. CB karşı sorumlu olan adalet bakanı ve üçüncüsü CB karşı sorumlu olan adalet bakan yardımcısı. Yani burada seçim yönteminin kuruluşun yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak bir nitelik taşımamaktadır günümüzde. Kurulun 3 üyesi 1.sınıfa olup 1.sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri getirmemiş adli yargı hakim ve savcılarında atanıyor. Burada artık mahkemeler kendi aralarından bir aday gösteremiyorlar. Artık kendileri adına karar verecek olan önemli kurula kendileri ne doğrudan üye seçebiliyorlar ne aday gösterebiliyorlar. İkincisi bu kurulun ve yargının siyasallaşması 2017 anayasa değişiklikleri ile aynen devam ediyor. TBMM önüne bu kurula üye seçilmek istenen yargıçların, savcılarının, üniversiteye öğretim üyelerinin TBMM'ni aşındırdığını görüyoruz. Oysa ki bağımsız bir yargının olduğu bir yerde ne yargıçların ne savcılarının yasama organıyla yürütme organıyla seçilebilmek için bir ilişki içine girmemeleri gerekiyor. Şimdiki seçim biçimi yargının saygınlığını, tarafsızlığını olumsuz hale getiren sonuç doğuruyor. TBMM'nin üye seçimi 159.madde de yazılı. Bu adaylar TBMM'ne başvuruyor. Seçim propagandası yapıyorlar. Bu CV'ler karma komisyona gidiyor (anayasa ve adalet komisyonu). Komisyon her bir üyelik için 3 adayı üye tam sayısının 2/3 çoğunluk ile belirliyor. Eğer 2/3 çoğunluğa ulaşamazsa 3/5 çoğunluk arıyor. Burada da belirleyemezse en çok oy alan iki aday arasından ad çekme yoluyla belirliyor. Komisyonun görevi, asıl seçme yetkisine sahip olan genel kurula bir sürü başvuru arasından sınırlı sayıda adayı belirlemek. TBMM komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından yine aynı yöntem ile ayrı yarı gizli oyla üye seçimi yapıyor. 1.Oylamada 2/3 oyu alan seçiliyor. Bunu alamadıysa üye tam sayısının 3/5 oyunu alan varsa seçiliyor. Kimse seçilemediyse 2.oylamada en çok oyu alan iki aday arasından ad çekme usulü uygulanıyor. Bunun sonucunda toplam 13 üye belirlenmiş oluyor. Bu üyeler 4 yıl için görev yapıyor yeniden seçilmeleri mümkün. Haliyle bu üyelerin yeniden seçilebilmek için meclis çoğunluğu ve CB ile arasını iyi tutmak istemesi sonucunu doğuruyor. Kendilerini seçenlere borçlu kalmak gibi bir sonuç olabilir. Bu da yargı bağımsızlığını ve yargı tarafsızlığını hem de hukuk devleti ilkesini derinden yaralıyor. Bunlar iki komisyon halinde çalışıyor. Bu kurumun başkanı Adalet bakanı ve bakan yardımcısı halen kurulun doğal üyesi. Yürütmenin ve yasamanın etkisi çok büyük. Bunlar yargıç ve savcılar bakımından özlük ve disiplin işlerine bakan kişiler. 2010 Yılına Hakimler ve savcılar kurulunun özerk bir bütçesi, binası, sekreteryası yoktu. 2010

Yılında 159. maddeye getirilen yeni bir düzenleme ile yeni bir sekreterlik oluşturuldu. Bu genel sekreter 1. Sınıf hakim ve savcılar arasından kurulun göstereceği 3 aday arasından kurul başkanı olan Adalet Bakanı tarafından seçiliyor. Genel sekreterin kurulun gösterdiği adaylar arasından olsa bile Adalet Bakanı tarafından seçilmesi yürütmenin kurul üzerindeki etkisi bakımından olumsuzdur. 2010 Yılında genel sekreterliğe mali ya da idari özerklik tanınmıyor. Aynı zamanda kurulun saydamlığına ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmiyor. Kurulu 159/6 maddesine göre Adalet Bakanı ve bakan yardımcısı dışındaki üyeleri görevlerinin devamı süresince kanunda belirtilenler dışında başka bir görev alamıyor ve kurul tarafından bir göreve atanamıyorlar ya da seçilemiyorlar. 1999 Yılına kadar HSYK görev yapan üyeler asıl görevleri olan yargıtay ve daniştay üyeliklerine devam ediyorlardı. HSYK üyeliği bunlar bakımından ek görev niteliğinde idi. Böyle olunca HSYK'ndaki dosyalara hakim olmaları mümkün değildi. Adalet Bakanlığı personeli gerekli dosyaları hazırlıyordu ve HSYK üyeleri de hazırlanan bilgiler doğrultusunda oluşan raporları onaylıyordu. 1999 da yasayla getirilen düzenlemeyle şimdi anayasada bulunan hüküm getirilerek HSYK üyeliği asli bir görev haline getirildi. Hem bu kurulun iş yükü çok büyük olduğu için hem de bu kurulun yargı bağımsızlığını sağlamak bakımından önemli bir işlev gördüğü için buradaki üyelerin asli işi olması lazım kurul üyeliği. 2010 Anayasa değişikliği ile getirildi 159/6 fıkrası. 1999'dan beri yasayla getirilmiş olan bu düzenlemeye anayasal bir güvencedir. Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerinde yürütmenin etkisi: 1. Kurulun başkanı, Adalet Bakanı ve bakan yardımcısı kurulun doğal üyesi. Kurulun yönetimi ve temsili adalet bakanına ait. Genel sekreter kurulun gösterdiği 3 aday arasından bile olsa yine adalet bakanı tarafından atanıyor. Adalet bakanlığının merkez ve bağlı kuruluşlarında geçici ya da sürekli olarak çalıştırılacak hakim veya savcılarla adalet müfettişleri hakim ya da savcı mesleğinden olan iç denetçiler onların onayı alınmak koşuluyla adalet bakanı tarafından atanıyor. 1982 Anayasasının ilk biçiminde bile olan Adalet bakanına tanınmış olan yetki büyük yetki idi. Bu bağlı ilgili kuruluş adalet müfettişleri iç denetçileri eklemeleriyle adalet bakanının bu yetki alanı daha da genişledi. Büyük yetki çünkü bu ayrımcılık biçiminde kullanıldığı için. Adalet bakanı istediği kişileri bu merkeze bağlı kuruluşlara alıyor. Bunun sonucunda hayatında kürsü yüzü görmemiş ama 1. Sınıf hakim konumuna gelmiş çok sayıda kişi ortaya çıkarıyor. Bu ayrımcılık oluşturması bakımından eleştiriye açık anayasal düzenleme. Yürütmenin başka etkileri, 159/9 maddesi hakim ve savcıların görevlerini kanun ve mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarına bir suç işleyip işlemediklerine ilişkin haklarında inceleme ya da soruşturma açılmasında karar veren kişi adalet bakanı. Anayasanın 144 maddesinde adalet bakanının bir etkisi vardır bu alanın onun lehine genişletilmesi onun tarafından kötüye kullanılmaya uygun bir düzenleme olarak çoğu anayasa hukukçusu tarafından eleştiriliyor. Suç ve cezalara ilişkin böyle bir düzenleme ilk defa 1961 anayasasında vardı. 1982 Anayasası da aynı listeyi benimsedi 38.maddesinde bu listeye yer verdi. Bu liste zamanla genişledi. 2001 ve 2004 anayasa değişiklikleriyle buna yeni ilkeler getirildi. 1982 anayasasının ilk biçiminde ceza yasalarının geriye yürümezliği ilkesi, masumiyet ilkesi ve hiç kimsenin kendisi ya da yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ya da bu yolla kanıt göstermeye zorlanamaması ilkeleri ve cezanın kişiselliği yer alıyordu.

2001 Yılında buna 2 ilke daha eklendi. 1.Kanuna aykırı elde edilmiş olan bulguların kanıt sayılmayacağı 2. Hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle özgürlüğünden alı konulamayacağı. Her ikisinin de AİH Sözleşmesinde yer alan ilkelerdir. 2001 Yılı Türkiye'nin Avrupa Birliğine girme süreci hız kazanmıştı. Son olarak 2004 ölüm ve genel müsadere cezası verilemeyeceğine ilişkin hüküm getirildi. Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere suç işlemesi nedeniyle yabancı bir ülkeye verilemez. Hak arama özgürlüğünün tanınmadığı bir düzen hukuk devleti olarak kabul edilemez. 1982 anayasasının 36.maddesi bunu düzenliyor.

İkinci önemli unsur adil yargılanma hakkı 36/2 de var. Aynı zamanda AİH Sözleşmesinde yer alan haklar demeti. Hem yargılama öncesi hem yargılama sırası hem de yargılama sonrasında olması gereken hak ve güvenceleri barındırdığı için. Yargılama öncesi için kast edilen; keyfi yakalama ve tutuklama yasağı, kişinin tutuklanmasını bilme hakkı, avukata danışma ve onun onunla iletişim kurma hakkı, haveas korpus hakkı. Yargılama sırasına ilişkin olarak; yargılamanın yasayla kurulmuş bağımsız mahkeme tarafından yapılması, iddia ve savunma arasında silahların eşitliğinin sağlanması, duruşmanın açık yapılması, yargılamanın makul surede yapılması ve sanığa parasız çevirmen sağlanması gerekir. Masumiyet karinesi, kendi aleyhine tanıklık yapma yasağı, ceza yasalarının geriye yürümezliği, işlediği suçtan dolayı kişinin birden fazla defa cezalandırılmaması. Yargılama sonrasında ise; kararın temyizinin olması ve adli bir hata yapılması durumunda kişiye tazminat ödenmesi sayılabilir. Hukuk devletine ilişkin olarak etkili başvuru hakkı, hak arama özgürlüğünün ayrılmaz parçasıdır. Bunun aynı zamanda etkili olması gerekir. Etkili başvuru, sonuç

doğurabilir, işe yarar ve elverişli bir başvuru olanağı anlıyoruz. Etkili başvuru olanağının ayrılmaz bir bileşeni titiz ve etkili bir soruşturma yükümlülüğüdür devletin kamu güçlerinin. Savunma hakkı 36.madde, herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olabileceğine ilişkin bir düzenleme. Bu madde, etkili başvuru hakkı, savunma hakkı, hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkını içeriyor. Hukuk devleti ile ilgili 1982 anayasasında yer alan diğer ilkeler: 141/1 duruşmaların herkese açık olması ilkesi. 1876 Anayasasından beri var olan kural. Bu kural 82 anayasasında da devam ediyor.

Hukuk devleti ilkesinin en temel haklarından biri olan **dilekçe hakkı**: Anayasanın 74.maddesi bu dilekçe ve bilgi alma hakkını düzenleyen bir madde. Hukuk devletiyle ilgili olan eşitlik ilkesi: şekli hukuk devleti (biçimsel) anlayışı eşitlik ilkesine dayalı bir anlayış. Hukuk devleti ilkesi ancak eşitlik ilkesinin gerçekleştiği yerde söz konusu olabilir. Bunu hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 10.madde de yer alıyor.

Genel olarak **eşitlik ilkesi** denince, bu ilkenin 2 yönü vardır. **1.** Bu ilkedan yararlananlar açısından ayırım gözetilmemesini isteme yani eşit işlem görmeyi isteme hakkı. Bu bir tarafı olup diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşları tarafından devlete bir ödev yükleyen bir ilke. Devlet organları ve idare makamları yapmış oldukları bütün işlemlerde eşitlik ilkesini gözetmek zorundadır. Yani devlete yön veren bir egemen ilke. 10.maddenin son fıkrası işte bu eşitlik ilkesinin bu devlet organlarına ödev yükleyen yönünü düzenliyor. Bu eşitlik ilkesinin **2. Yönü**: Bu ilkenin birinci yönü olan eşit işlem görme ve ayırım gözetilmeme hakkı 10.maddenin 1.fıkrası özgün ayırım yasakları getiren bir düzenleme. Burada belli unsurların belirtilmiş olması son derece önemli. Çünkü devletin bu konularda ayırım yapmasını yasaklama nedeniyle. Böyle özgün ayırım yasaklarına dayalı eşitlik ilkesi anlayışı ilk defa 1961 anayasası ile getirildi. 61 Anayasası 82 anayasasının 10/1 fıkrasının aynıydı. Bir tek benzeri sebepler ibaresi yoktu. 1924 anayasası ise 1789 Fransız İYHB'nin eşitlik anlayışını esas almıştı. Yani böyle bir özgün ayırım yasağına yer vermeden herkes kanun önünde eşittir demişti. 61 ve 82 anayasalarında yazan bu formülasyonun daha güvenceli olduğunu görüyoruz. 61 Anayasasından farklı olarak 82 anayasasının 10.maddesi 2.fıkrası "ve benzeri sebeplerle" ifadesine de yer veriyor. Bu önemli, AYM'nin bu 10.maddenin 1.fıkrasında yer alan özgün ayırım yasaklarına olanak tanıyacak bir düzenleme. Bu zamana kadar mahkeme bunu hiç kullanmadı. Eşitlik ilkesi dediğimizde biçimsel hukuki eşitlik ve maddi hukuki eşitlik olarak ikiye ayırıyoruz. Ancak 10/1 özgün ayırım yasakları getirmekle birlikte aynı zamanda 4.fıkrası somut olarak ayrımcılık yasağı getiriyor. Bu fıkra biçimsel hukuki eşitlik ilkesinin bir unsurudur. Bu bizi biçimsel hukuki eşitliğe götürüyor. Şekli hukuki eşitlik ilkesi, yasanın genel ve soyut olması ve kapsadığı herkese de eşit bir biçimde uygulanması anlamına gelir. Bunun bir parçası ayrımcılık ve ayrımcılık yasağıdır. Maddi hukuki eşitlik: aynı durumda bulunanlar için haklarda ve ödevlerde yararlar ve yükümlülüklerde yetkilerde ve sorumluluklarda fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davranma zorunluluğudur. Bu yasanın içeriğine bakacağız. Aynı durumda bulunanlara aynı kuralların getirilmesidir. Bir normun içeriğine bakacağız. Eğer o norm toplum içindeki yeri ekonomik gücü toplumsal durumu, etnik kökeni ya da inancı gibi nedenlere dayalı olarak aynı biçimde uygulanmıyorsa orada maddi hukuki eşitlikten söz etmemiz mümkün değil. Benzer ya da aynı durumda olan herkese aynı biçimde yasanın uygulanması anlamına gelir.

Maddi eşitlik bakımından mutlak eşitlikten söz edemiyoruz. Aynı ya da benzer durumda bulunanlara aynı hükümlerin uygulanmasıdır maddi hukuki eşitlik. AYM de eskiden beri geliştirdiği içtihatlarında, maddi hukuki eşitliği tanımlıyor. Bir yasanın herkese aynı biçimde uygulanmasının eşitlik ilkesi anlamına gelmediğini, tersten söylersek aykırı uygulamaların da eşitlik ilkesine aykırı düşmeyeceğini söylüyor. Örneğin 1988/27 karar sayısında eşitlerin eşitliğinden söz ediyor. Yani her yönüyle aynı hukuki durumda bulunanlar demek. Bunun karşısında bulunanlar eşit olmayanların eşitsizliği. Böyle bir ikilem AYM göre anayasaya aykırılık oluşturmayacaktır. Ancak AYM maddi hukuki eşitliği araştırırken haklı neden ölçütünü esas alıyor. Bazı yurttaşların başka kurallara bağlı tutulması haklı bir nedene dayanıyor mu dayanmıyor mu. Eğer haklı bir nedene dayanıyorsa bir yasa belli bir kitleye farklı bir uygulamayı öngörüyorsa ve bu haklı bir nedene dayanıyorsa AYM göre bu eşitlik ilkesine aykırı olmaz.

Bu haklı nedeni araştırırken nelere bakıyor. **1.** Yasa koyucunun getirdiği bu ayırımın anlaşılabilir olması, **2.** öngördüğü amaçla ilgili olması, **3.** aynı zamanda makul olması ve adil olmasına bakıyor. Bu ayırım gerekli, zorunlu, işin özelliklerine uygun dengeli makul bir ayırım mı, adil mi, eşit mi bunlara bakıyor. Buna göre farklı uygulamaları eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığına karar veriyor. Bu madde haricinde anayasanın başka maddelerinde de eşit, eşitlik ve ayırım gözetmeme kavramına yer veriyor. Mesela 29.madde, 41.madde,

67.madde, 70.maddelerde eşitlik ve ayırım gözetilmemesi konularında düzenlemeler vardır. AYM, eşit, eşitlik ayırım gözetmemek gibi eşitlik ilkesiyle ilgili başka düzenlemeleri de biraz önceki açıklanan yorum çerçevesinde ele alıyor ve anayasaya uygunluğunu denetliyor.

İşte o hususlar: Farklı uygulamanın haklı nedene dayanması lazım. Bu haklı neden zorunlu bir uygulama olacak. Gerekli bir durum olacak, işin özelliklerine ve gereklerine uygun olacak, dengeli ve makul görülebilecek birtakım ölçüler içinde olacak, adil ve eşit olacak diyor AYM. 2018/119 Karar sayısında diyor ki kanun önünde eşitlik ilkesi hukuksal durumda aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilke ile aynı durumda bulunan kişilere ayrı kurallar uygulanarak kanun karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Kanun önünde eşitlik herkesin her yönden aynı kurallarına bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler kimi kişi ya da topluluklar için değişik uygulamaları gerektirebilir.

Pozitif ayrımcılık ilkesi: tarihsel süreç içerisinde eşitsiz ya da güçsüz konuma düşmüş olan toplumsal grupların bu fiili eşitsizliğini ortadan kaldırmayı gidermeyi, amaçlayan düzenlemelerin yapılması. Bu tür düzenlemelere baktığımız zaman pozitif ayrımcılık ilkesini göz ardı edersek burada bir ayrımcılık olduğu sonucuna varırız. Bu da eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleriz. Buna karşılık buradaki amaç tarihsel olarak ve fiilen belli toplumsal grupları ve bazı diğer toplumsal gruplarla eşit olarak erişememesi ya da bazı kamu hizmetlerini kendisinin görememesidir. İşte pozitif ayrımcılıkta, bu fiili eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla yapılan bir takım hukuki önlemlerdir. Bu uygulamalar örneğin yerliler, kadınlar, yaşlılar, gençler, cinsel yönelim esasına dayalı olarak translar, eşcinseller gibi. Veya sınıfsal olarak da yapılabilir. Yoksullar gibi belli toplumsal grupların toplumda birtakım haklarını fiilen etkin bir şekilde kullanabilme amacı güdüyor. En çok aklımıza gelen seçilme hakkının kullanılması bakımından. Anayasamızda genel eşitlik ilkesine göre herkesin seçilme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık uygulamaya baktığımızda, kadınların, gençlerin engellilerin seçilme hakkı bakımından fiilen diğer toplumsal kesimler gibi yararlanamadığını görüyoruz. İşte bunların bu haklardan yararlanabilmeleri için seçimlerde kotalar konması. Belli sayıda kadının, gencin, engellilerin seçilebilecek yerlere konması. Sadece seçimde ya da ekonomim, iş, eğitim alanında getirilen kotalar pozitif ayrımcılık ilkesine verebileceğimiz örneklerdir. Anayasamızın 10/2 fıkrası cinsiyet yönünden, kadınlar yönünden bir pozitif ayrımcılık ilkesidir. Buna uygun yapılacak düzenlemeler anayasaya aykırı olmayacaktır. 2.Fıkra 2004 Yılında yapılan anayasa değişikliği ile getirildi. 2010 Anayasa değişikliği ile de 3.fıkra eklendi. Bu gruplara yönelik pozitif ayrımcılık niteliği taşıyacak düzenlemelerin yapılabileceğini ve buna yönelik bir anayasal dayanak getiriyor. Bu düzenleme olmasaydı bile pozitif ayrımcılık taşıyacak nitelikteki yasal düzenlemelerin anayasaya aykırı olmayacağı sonucuna varabiliriz. Anayasanın 5. ve 2.maddelerinden. 5. Madde devletin görevlerini düzenleyen bir madde. Devletin görevleri arasında sosyal eşitliğin sağlanması olduğu da belirtiliyor. Anayasanın 2.maddesinde yer alan ve değiştirilmesi de yasak olan sosyal devlet ilkesi ile birlikte 5.maddeyi de düşündüğümüzde 10/3 fıkrayı düşündüğümüzde 2.fıkra da yer alan gruplar bakımından getirilecek pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel düzenlemelerin anayasaya aykırı olmayacağı sonucuna varıyoruz.

4 Nisan 2023

İnsan Hakları Hukuku: Öncelikle hak ve özgürlük arasındaki ilişkiye bakmamız gerekiyor. Özgürlük dediğimizde, 1982 anayasasında hak ve özgürlüklere ilişkin 2.kısımın içinde bazı hak ve özgürlüklerin özgürlük, bazı hak ve özgürlüklerin hak olarak düzenlendiğini görüyoruz. Özgürlük dediğimiz zaman bir şeyi yapma ya da yapmama, belli bir biçimde davranma ya da davranmama erkini anlıyoruz. Veya serbest hareket etme gücü olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda basın özgürlüğü, düşünce, seyahat, yerleşme özgürlüğü 1982 anayasasında yer bulan özgürlükler arasında. Hak ise özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve yasalar tarafından tanınmış yetkiyi anlıyoruz. Hak varsa devlet ya da 3.kişilerden onun yerine getirilmesini isteme yetkisi ortaya çıkar. Bu bakımdan hak ve özgürlük arasındaki ilişkide özgürlüğün soyut, hakkın somut olduğu sonucuna varırız. Yine hak, özgürlüğün uygulanması aşamasında ortaya çıkar. Yine hak özgürlükten farklı olarak hak mahkemeler önünde ileri sürülebilir. Özgürlük kişinin kendi edimi sonucunda gerçekleşir. Özgürlüğün gerçekleşebilmesi için devletin o alanda hiçbir şey yapmaması yeterlidir. Gösteri, yürüyüş özgürlüğü, bu özgürlüğün gerçekleşmesi devletin o alanda hiçbir şey yapmamasına bağlıdır. Hak ise diğer kişiler ve devletin, hak sahibi kişi lehine bazı edimlerde bulunmalıdır. Bir kişinin yaşam kesiti içindeki bir eylemini hak olarak tanımlayabilmemiz için o alana yönelik olarak hem 3.kişilerin hem devletin kişi lehine

bazı edimlerde bulunması zorunludur. Bu edimler, o kişinin o hakkını ortadan kaldırmama yükümlülüğü ve edimidir.

İnsan haklarına doğal hukuk yaklaşımından bakacak olursak o zaman ırk, din, dil, cinsiyet, ideolojik ya da felsefi, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin iktisadi, toplumsal siyasi statülere bakılmaksızın herkesin insan olduğu için sahip olduğu hak ve özgürlüklere verilen isim. Yine doğal hukuk yaklaşımından yola çıkacak olursak insan onurunun da bir gereği olarak ortaya çıkan haklara insan hakları diyoruz.

Doğal hukuk yaklaşımı, insanın doğuştan sahip olduğu, daha sonradan vazgeçemeyeceği, başkalarına devredemeyeceği ve devlet düzeni tarafından korunması gereken haklar olarak tanımlanıyordu. İşte bu hakların bütünü insan haklarını oluşturuyor. İnsan hakları hukuku ise, hukukun insan haklarını düzenleyen alanına verilen ad. İnsan hakları hukukuyla, insancıl hukuk aynı şeyi ifade etmiyor.

İnsan hakları hukuku, olağanüstü yönetim usulleri de dahil olmak üzere devletin savaş dışında kalan alandaki bütün anayasal, yasal ve yasa altı düzenlemelerin bütünüdür.

İnsancıl hukuk ise, savaş koşullarını ve bu savaş hukuku dediğimiz silahlı çatışmaların varlığına dayalı alanı düzenleyen hukuka denir. İnsan hakları hukuku, anayasa hukukunun alanı, insancıl hukuk ise uluslararası hukukun alanını oluşturuyor. İnsancıl hukuk özellikle 1899-1907 yılları arasındaki Lahey sözleşmeleriyle hem 1949 tarihli Cenevre sözleşmesi ve buna ek 1977 tarihli protokol, insancıl hukukun pozitif hukuk yönünü oluşturan uluslararası belgeler. İnsancıl hukukta, hakları, özgürlükleri, güvenceleri ihlal etmiş olan hem devletler hem de tek tek kişiler bu insancıl hukukun muhatapları olarak kabul ediliyor.

Temel haklar ve özgürlükler, anayasa tarafından tanınıp güvence altına alınmış hak ve özgürlüklere verilen ad. Yani insan haklarının anayasa tarafından tanınmış güvence altına alınmış bölümünü oluşturan haklara, özgürlüklere temel haklar ve özgürlükler diyoruz. Kamu özgürlükleri de anayasal haklarda aslında eş anlamlı ifadeler. Temel olmayan hak ve özgürlük, anayasa tarafından tanınıp güvence altına alınmamış, anayasa altı mevzuat tarafından tanınmış güvence alınmış hak ve özgürlüklere verilen isim. Anayasa altı mevzuat, yasalar ve yürütmenin düzenleyici işlemlerini anlarız. Bu mevzuat çerçevesinde düzenlenen tanınan hak ve özgürlükler hukuk düzeni tarafından tanınmıştır ancak anayasa tarafından tanınmamış hak ve özgürlüklerdir. Aradaki fark bir güvenceye dayanmamaktadır. Dolayısıyla anayasanın hak ve özgürlükler bakımında getirmiş olduğu genel güvence ve olanaklardan yararlanamazlar. Anayasa altı bir güvenceyle tanındığı için her zaman anayasa altı bir işlemle geri alınabilir. Anayasal bir güvenceye sahip olmadıkları için.

Temel hakların sınıflandırılması: buna ilişkin 1. O hakkın niteliği göz önünde bulundurularak yapılan 2. Temel hak ve özgürlüklerin tarihsel olarak ortaya çıkış dönemine göre yapılan sınıflama. Hak ve özgürlüğün niteliği göz önünde bulundurularak yapılan sınıflama

1. Negatif statü hakları: aynı zamanda kişi hakları olarak adlandırılıyor, yani olumsuz haklar. Negatif statü hakları, devlete karışmama ödevi yükleyen hakka verilen isim. Yani devlet bir alana yönelik olarak hiçbir müdahalede bulunmuyorsa o zaman o hakkın kişiler tarafından kullanılabilmesi mümkün olur. Devletin müdahalesine kapalı olan ve devletin müdahale etmemesi durumunda kullanılabilen haklara verilen isim. Yaşam hakkı, işkence yasağı, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, mülkiyet hakkı, eşitlik hakkı, örgütlenme özgürlüğü, çalışma özgürlüğü gibi hak ve özgürlükleri negatif statü haklarına verilecek haklardır.

2. Pozitif statü hakları veya istepne hakları olarak da adlandırılır. Bireylere devletten olumlu bir edimde bulunmayı, devletin belirli bir hizmet görmesini ya da devletten kişilere yardım isteme olanağı sağlayan, tanıyan haklara verilen isim. Olumsuz statü haklarında devletin o hakka müdahale etmemesi yani tamamen karışmaması ödevi o hakkın gerçekleştirilmesi için şart kabul edilen bir unsur. Olumlu statü haklarında, o hakkın kullanılabilmesi devletin o alana müdahale etmesine bağlı. Devletin karışmaması durumunda o hakkın gerçekleşmesi mümkün değil. Olumlu haklar, bireye, devletten yardım istemesini sağlama olanağı tanıyan haklara verilen isim. Parasız eğitim hakkı, dinlenme, sağlık, sosyal güvenlik, kültürel yaşama katılma hakkı, beslenme hakkı, su hakkı, konut, çocuğun korunması ya da engellilerin, yaşlıların korunması hakkı gibi hak ve özgürlükler hep sosyal haklar ya da pozitif statü haklara verilebilecek haklardır. Kişilerin, pozitif statü haklarından yararlanması, devletin o alana müdahale etmesi, o alanı düzenlemesi, o alana ilişkin hizmet görmesiyle mümkün olabilir. Sağlık hakkına kişilerin ulaşabilmesi için, parasız, herkesin ulaşabileceği az miktarda paralar vermek yoluyla ulaşabileceği haklara vatandaşın sahip olması gerekir. Devletin hastane açması, hastaneleri teşvik etmesi, sağlık çalışanları istihdam etmesi gerekir ki kişiler sağlık hakkını kullanabilsin. Olumlu statü haklarının gerçekleştirilmesi, devletin o alanda aktif olmasına, o alanı

düzenlemesine, o alanda gerekli olan kuruluşları, kurumları kurması ve bunları işletmesine bağlı olan haklar. Negatif statü hakları, devletin o hakka, o alana hiç müdahale etmemesini gerektiren haklar olarak tanımlanmışsa da günümüzde artık bu kuralın yeterli olmadığını görüyoruz. Negatif statü hakları bakımından da devletin bireyler karşısında pozitif yükümlülüğü söz konusu. Bunu pozitif statü hakları ile karıştırmıyoruz. Negatif statü haklarının devlet bakımından pozitif yükümlülüğü olarak tanımlıyoruz.

Yani bütün haklar bakımından olumsuz haklar veya kişi hakları bakımından devletin 3 temel görevi vardır. Bunlardan **1.** Devletin kaçınma yani devletin o hakkı ihlal etmeme yükümlülüğüdür.

2. Üçüncü kişilerin de bir kişinin hakkını ihlal etmemesi gerekir. Burada da devlete bir yükümlülük yüklenmiştir. Üçüncü kişilerin, o hakka müdahalesini önlem, o hakkın üçüncü kişilerin müdahalesinden koruma yükümlülüğü.

3. O hakkın her bir kişi tarafından tamamen gerçekleştirilmesi, etkin biçimde kişinin yararlanmasını sağlayacak özel önlemleri alacak.

Negatif statü haklarında devletin 3 görevi vardır; 1. Hakkı ihlalden kaçınma **2.** Hakkın üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesini engelleme **3.** Hakkın her bir kişi tarafından etkili bir şekilde kullanılabilmesini sağlama ve bunu sağlayacak önlemleri alma. Örnek, yaşam hakkı, işkence yasağı, kötü muamele yasağı, zorla çalıştırma yasağı, angarya yasağı, kişilerin yaşına, cinsiyetine, fiziki koşullarına uymayan işlerde çalıştırılmaması yasağı hep devletin pozitif yükümlülükleri çerçevesinde düşünülebileceğimiz haklar. Kişilerin gösteri yapma hakkı vardır. Bunu gerçekleştirmek için devlet kişilerin gösteri yapma hakkına müdahale etmeyecek. Ancak başkalarının da bu hakkın kullanılmasını engellemekle yükümlüdür.

Bunun için **1.** Gerekli siyasal düzenlemeleri yapacak. **2.** Yasal düzenlemelere herkesin uymasını sağlayacak şekilde bu alana pozitif olarak müdahale edecek. Barışçıl bir gösteri yapılırken, polis bu gösteride kalabalığı dağıtmak için orantısız bir güç kullandıysa ve müdahalenin sonucunda bir kişi yaralandıysa o zaman devlet burada kaçınma yükümlülüğünü ihlal etmiş demektir. Kişinin yaşam, maddi ve manevi bütünlüğüne bizzat kendi yaptığı eylemle müdahale ettiği için. Aynı gösteri yürüyüşünde polis, bu gösteride pasif bir şekilde bulunuyor. Fakat bir kişiye gösteriye karşı olan bir grup tarafından saldırılıyor ve kişi yaralanıyor. Böyle bir durumda negatif statü hakkını 20.yüzyılın başındaki gibi tanımlayacak olursak devletin burada herhangi bir yükümlülüğü yoktur sonucuna varırız. Bu müdahale bizzat devletten gelmediği için. Kaçınma yükümlülüğünü yerine getirdiği için. Buna karşılık 3.kişilerden o kişinin yaşam hakkına yönelik olarak bir müdahale geliyor. Devletin üçüncü kişilerden gelen müdahaleye karşı hiçbir harekette bulunmaması onu koruma yükümlülüğünü ihlal etmesi anlamına geliyor. İşte burada devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu sonucuna varıyoruz. Özellikle 1980'lerden itibaren ABD İnsan Hakları Mahkemesi hem de AİH Sözleşmesi ve bu sözleşmeyi yorumlayan AİHM bu negatif statü haklarında devletin yükümlülüğü öğretisini uygulamaya başladı. Özellikle kişilerin yaşam hakkına, diğer hak ve özgürlüklerine, aile yaşamının gizliliği hakkına 3.kişilerden gelecek müdahaleleri önleme ya da bir hakkın etkili bir şekilde kullanılmasını sağlama amacıyla devlete müdahale yükümlülüğü getiriyor. Ev içi şiddete yönelik ilk karar Türkiye'ye yönelik Opus kararıdır. Sonuç: Negatif statü haklarının, yalnızca o devletin o haklara müdahale etmemesi, o hakları ihlal etmeme yükümlülüğü altında olması biçiminde yorumlamıyoruz. Aynı zamanda devlet o hakka yönelik 3.kişilerden gelecek ihlallere karşı da o hakkı korumalı o ihlalleri etkili biçimde cezalandıracak her türlü önlemi ve düzenlemeyi almalı ve aynı zamanda her bir hakkın her bir kişi tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

3. Aktif statü hakları, yani katılma hakları biçiminde yapılan ayırım. Aktif statü hakkı ise, kişilerin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara verilen isim. Seçme, seçilme hakkı, siyasal partiye girme hakkı, kamu hizmetine girme hakkı bunlara örnektir.

Hak ve özgürlükler sınıflamasının **2.bicimi hak ve özgürlüklerin ortaya çıktığı zamana göre yapılan sınıflama:** Çıkış zamanlarına göre 1.kuşak, 2.kuşak, 3.kuşak, 4.kuşak haklar olarak sınıflanıyor.

Birinci kuşak haklar (klasik haklar): tarihte ilk defa ortaya çıkan haklardır. Özellikle burjuvazi ile feodal sınıflar arasındaki mücadelenin sonucunda 17-18.yy'da doğan haklar. Haliyle 1.kuşak hakların arkasındaki öğreti, doğal hukuk, doğal haklar ve bireycilik, kişiye dayalı bir hukuk anlayışı. 1.Kuşak haklara klasik haklarda deniyor. Özellikle bunların 18.yy'ın sonlarında ve 19.yy da ortaya çıkan haklardır. 19.YY'da yine ortaya çıkan anayasacılık akımı yoluyla ticaret ve sanayi burjuvazilerinin elde ettikleri toplumsal, iktisadi ve siyasal kazançları hukukileştirmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu hukukileşmiş belgelerin en önemlileri kuşkusuz ki Fransız ve Amerikan Devrimleri. Yeni binyıl sınıflandırmasından yola çıkacak olursak;

birinci kuşak haklar, negatif statü ve aktif statü hakları içinde barındıran haklar. Yani bu hakların içinde, işkence yasağı, yaşam hakkı, örgütlenme, basın özgürlüğü, toplantı, gösteri, mülkiyet hakkı, eşitlik, seçme ve seçilme hakkı, siyasal parti kurma hakkı, tarafsız bir hakim önünde adil yargılanma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı gibi haklar ve özgürlükler yer alıyordu.

İkinci kuşak haklar (sosyal haklar): Özellikle 19.yy'da itibaren ortaya çıkan haklar bunlar sosyal haklar olarak adlandırılıyorlar. İşçi sınıfının tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. İşçi sınıfı, 19.yy'ın 2.yarisından itibaren yoğunlaşan bir mücadele içinde. Bu mücadelenin içinde başta, zengin kesimlere tanınan siyasal hakları edinme mücadelesi var. 2.Olarakta toplumda hiçbir hakka sahip olmayan, çok kötü koşullarda bulunan kişilerin haklarını sağlama ya da bunlara daha iyi yaşam olanakları elde etme mücadelesi. Bunun sonucunda seçme ve seçilme hakkının genişletilmesi, iktisadi örgütlenme özgürlüğü yani sendika kurma hakkı, sendikaya üye olma hakkı kısaca iktisaden güçsüz olan geniş kesimleri siyasal ve toplumsal eşitsizliklere karşı tepkisi sonucunda ortaya çıkan hak ve özgürlükler. Bu dönemin ya da 2.kuşak hakların genel olarak benimsediği akımlar; sosyal düşünce akımları, hukuki bakımdan da pozitivist hukuk öğretisi. Yani hak ve özgürlükler anayasa ve anayasa altı mevzuatla tanındığı ölçüde mevcuttur. Bir hakkın doğal hak olarak tanımlanması bir şeyi ifade etmez. Bunun pozitif hukukta tanınıp güvence altına alınması gereklidir, pozitivist hukuk anlayışı. Çalışma özgürlüğü 1.kuşak haktır. Çalışma hakkı 2.kuşak haktır. Sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme yapma hakkı, işyeri yönetimine katılma hakkı, dinlenme, sosyal güvenlik, sağlık, parasız eğitim, beslenme, konut gibi haklar 2.kuşak haklara verebileceğimiz haklar. Yani kısaca pozitif statü haklarının 2.kuşak haklar olduğunu söyleyebiliriz. Buna seçme ve seçilme hakkının daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasını da eklememiz gerekir. 2.Kuşak döneminde, seçme ve seçilme hakkı yalnızca zengin olan kesimlere değil daha geniş olan kesimlere de yaygınlaştırıldı.

Üçüncü kuşak haklar: 2.Dünya savaşıdan sonra ortaya çıkan haklar. Devletler arasında uluslararası ilişkilerin gelişmesi, uluslararası örgütlerin kurulması sonucunda dayanışma hakları dediğimiz bu hakların ortaya çıktığını görüyoruz. Dayanışma hakları, birtakım hakların kullanılabilmesi hem devletleri hem toplumların hem kurumların birbirleriyle işbirliği yapmasına bağlı. O nedenle 3.kuşak haklar aynı zamanda dayanışma hakları olarak adlandırılıyor. Bunu ilk tanımlayan Karel Varsak'ın tanımlamasıyla 3.kuşak haklardan söz ediyoruz. Bu 3.kuşak haklar aynı zamanda şunu da beraberinde getiriyor. 2.Kuşak haklar yeni ortaya çıkan işçi sınıfı ile burjuva arasındaki mücadelenin sonucuydu. 3.Kuşak haklar ise zengin devletler ile yoksul devlet arasındaki mücadelenin sonucu. Çünkü dünya ölçeğinde de aslında bu düzen zengin devletlerin yoksul devletleri sömürmesine dayanan bir düzen. 3.Kuşak haklar bu sömürüyü de reddeden, haliyle yoksul devletlerin dünyanın zenginliğinden daha eşit ve adil pay almasını hedefleyen hak ve özgürlükleri de içeriyor. Örneğin, bütün devlet ve toplumların sahip olması, pay alması gereken zenginlikler. Antartika'daki zenginliklerin bütün dünya devletlerine dağıtılması. Veya uzaydaki maden ve zenginliklerin hakça yeryüzündeki bütün devletler arasında paylaşılmasını da içeren birtakım haklar. Çevre hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, gelişme hakkı, barış hakkı, insanın temiz suya ve yiyeceğe erişmesi hakkı, insani yardım alma hakkı gibi hak ve özgürlüklerin 3.kuşak hak ve özgürlükler arasında yer aldığını görüyoruz. Bu 3.kuşak haklar birincisi devletler arasındaki eşitsiz ilişkiye bir tepki olarak ortaya çıkıyor. İkincisi bütün dünyada denetimsiz sanayiye dayalı büyümenin aynı zamanda ülke içinde görülen terörün devletlerin devletlere yaptığı soykırımın işgalin, bir sonucu olarak bunları önlemek amacıyla hem devletlere hem kişilere hem topluluklara tanınan haklar. Bu hakların gerçekleştirilmesi ancak devletle arasında, kurum ve kuruluşlar arasında uluslar, halklar, toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma ile mümkün olabilir.

Dördüncü kuşak haklar: Bu haklar günümüzün hakları. 20.yy'ın 2.yarisından itibaren ortaya çıkıp 21.yy'da somutlaşan haklar. Bu haklar teknolojik gelişmeler nedeniyle, toplumsal bilimsel açıdan çok hızlı bir şekilde toplumun dönüşmesi nedeniyle ortaya çıkan hak ihlallerine bir tepki olarak tanımlanan haklar. Özellikle teknolojik gelişmelerin kötüye kullanılması, kötüye kullanılması olasılığına karşı da insanın temel özelliğini oluşturan insan onurunun korunmasını amaçlayan yeni tip haklar. Bunlar genellikle yasaklar biçiminde ortaya çıkıyor. Teknoloji ile birlikte genetik şifre ile genlerin yapısı ile oynanması mümkün oluyor. Bunların bir kısmı insanlığa hizmet eden teknoloji. Bir yandan bilimin bu yöne gelişmesinin insan onurunu zedeleyen hatta ortadan kaldıran sonuçlarının da olabildiğini görüyoruz. İnsanların klonlanmasının yasaklanması, insanların bedeninin, organlarının bir maddi kazanç haline getirilmesinin yasaklanması. Bunlar 4.kuşak haklara verebileceğimiz örnekler. Avrupa Konseyi bünyesindeki biyoetik sözleşmesi, Avrupa temel şartı içindeki

örneğin genetik kopyalanmasının yasaklanmasına ilişkin düzenleme 4.kuşak haklara verebileceğimiz örnekler. Sınırlı olmayan ucu açık, ortaya çıktıkları zamana göre hak ve özgürlüklerin sınıflanması.

1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlükler: Bazı hak ve özgürlüklerin tanınması 1876 Kanuni Esasi ‘den beri bizim anayasalarımızda yer alıyor. 1921 Teşkilatı Esasi’yi dışarıda bırakıyoruz. Ancak temel hak ve özgürlüklerin ayrıntılı bir şekilde yer alması, her hak ve özgürlüğün ayrı bir madde de düzenlenmesi, bu madde içinde sınırlama maddelerinin belirlenmesi, hakkın tanımlanması yani çağdaş bir şekilde ya da günümüzdeki biçimde hak ve özgürlüklerin anayasada düzenlenmesi ilk kez 1961 anayasası ile birlikte oldu. 1982 Anayasası da sistematik bakımdan 61 anayasasını devam ettirdi. Ancak 1982 anayasasının temel özelliklerinden biri devlet otoritesini önlemesi güçlü bir devlet yaratmak amacıyla çeşitli önlemler alması, bunu yaratmanın en önemli yolu olarak temel hak ve özgürlükleri sınırlaması olduğunu belirtmiştik. 2001 Anayasa değişiklikleriyle 1982 anayasasının otorite ya da devlet odaklı yaklaşımını, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınması bakımından önemli değişikliklere uğradığını biliyoruz. Başlangıç dahil olmak üzere 32 madde de ve 1 geçici madde de değişiklik yaptı. Büyük ölçüde bu haline geldi. Buna rağmen anayasanın o otoriter ruhu başka maddelerde de yer almaktadır. Bu anayasa 2.madde de Cumhuriyetin nitelikleri arasında insan haklarına saygılı devlet ilkesini sıralamış. İlk defa bu 1961 anayasasının 2.maddesinde yer alıyordu. Bu madde de “insan haklarına dayanan devlet” olarak belirtilmişti.

İnsan haklarına saygılı devlet demek; insan haklarının değerini, üstünlüğünü, kutsallığını, kabul etmiş olan ve bu nedenle insan hakları karşısında dikkatli, özenli, ölçülü olan devlete verilen ad. Kuşkusuz ki 1961 anayasasında yer alan insan haklarına dayanan devletle, 1982 anayasasının 2.maddesinin benimsediği “insan haklarına saygılı devlet” arasında birebir aynılık olmadığını söylemek mümkün.

İnsan haklarına dayanan devlet, kuşkusuz ki insan haklarıyla arasına mesafe koymayan devlet. İnsan haklarına saygılı devlet ise tam tersine insan haklarıyla arasına bir mesafe koyan devlet olarak tanımlanabilir. Ancak 2001 anayasa değişikliklerinden sonra anayasanın 2.maddesindeki “insan haklarına saygılı devleti” insan haklarına dayanan devlet biçiminde yorumlamamız artık mümkün. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını yasaklayan, kötüye kullanılamamasını düzenleyen anayasanın 14.maddesinin 1.fıkrasının şimdiki biçimi temel hak ve özgürlüklerin hiçbirinin insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirtiyor. Biz anayasayı bir bütün halinde yorumluyoruz. Bu 14/1 fıkrası çerçevesinde insan haklarına dayanan bir devlet olduğu sonucuna varabiliriz. Yine 1982 Anayasasının insan hakları bakımından en önemli yansımalarından biri anayasanın 11.maddesi. Çok önemli bu madde. 11/1 Fıkrasına göre yasama, yürütme, yargı organlarını idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan hukuk kurallarıdır diyor. Ve yasaların anayasaya aykırı olamayacağını da 2.fıkra belirtiyor. Anayasanın 2.kısım temel hak ve özgürlüklere ayrıldığı için aynı zamanda 2.maddesi de değiştirilemeyecek anayasa hükümleri arasında da yer aldığı için artık temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve güvence altına alınmasına ilişkin bütün düzenlemelerin de herkesi bağladığını biliyoruz. Bu aynı zamanda temel hakların yatay etkisi olarak da adlandırılıyor. Anayasa hükümlerinin yalnızca devlet ve kişiler arasında olan ilişkilerde değil aynı zamanda özel hukuk kişileri arasında olan ilişkilerde de uygulanması gerektiği belirtmiştik. Buna yatay etki demiştik. Temel haklar bakımından da bu yatay etkinin geçerli anayasa hükmü olduğu için. Bunun bir gereği anayasa hükümleri arasında bir hiyerarşi olmamasının da sonucu. Bütün anayasa hükümleri etki ve sonuç, uygulanabilirlik ve aynı zamanda da bağlayıcılık bakımında aynı etki ve değerde. 11.Madde bütün anayasa hükümleri bakımından aynı biçimde geçerli. Bu hak ve özgürlükleri düzenleyen düzenlemeler içinde söz konusu. 1982 anayasasında hak ve özgürlükler anayasanın 2.kısımında düzenleniyor. 2.Kısım genel hükümler, kişinin hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler başlıklarını taşıyor. Temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlandıracağı, kötüye kullanılması yasağına ilişkin düzenleme, yabancılar, temel hak ve özgürlüklerin niteliği yer alıyor. 3 Başlık altında hak ve özgürlükler sıralanıyor. Hak ve özgürlüklerin düzenlendiği büyük başlıkların genellikle yeni eğin sınıflamasının göz önünde bulundurulması biçiminde olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek burada göz önünde bulundurulması gereken konu, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında yer alan bazı hak ve özgürlükler nitelikleri gereği pozitif statü hakları değil negatif statü hakları biçiminde örneğin çalışma özgürlüğü, sözleşme özgürlüğü, bütün sendikal haklar, grev ve lokavt hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı yine kişinin yaşına, cinsiyetine gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılması yasağı, mülkiyet hakkı gibi hak ve özgürlükler negatif statü hakları niteliğinde, buna karşılık sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiş. Burada başlıkla içerik arasında bir uyumsuzluk olduğunu görebiliriz. Anayasada

düzenlenmeyen hak ve özgürlükler kural olarak anayasal güvenceye sahip değil. Kanunla tanınmış ama anayasada yer almayan hak ve özgürlük bulunabilir. Bu hak ve özgürlük son olarak anayasal güvenceye sahip değil. Anayasal güvence denince 13-14-15.maddelerinde yer alan güvenceleri anlıyoruz. Alman anayasa hukuku doktrininde ortaya çıkan, bizimde 1982 Anayasasında da benimseyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu.

Kapsayan hak, kapsayan özgürlük yaklaşımı. Yani anayasada açıkça yer almamakla birlikte bir hak ve özgürlüğü anayasanın 17.maddesinin 1.fıkrası kapsamında değerlendirip o hakka anayasal bir güvence tanımak mümkündür. 17/1 Fıkrası “herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip “olduğunu belirtiyor. Anayasada açıkça belirtilmemiş kanunla düzenlenmiş, hiç düzenlenmemiş bir hakkı anayasa mahkemesinin yapacağı yorumla 17/1 ile ilişkilendirmek böylelikle o insan eylemine bir anayasal güvence tanımak mümkün olabilir. Böyle bir yorum kuşkusuz ki hak ve özgürlük alanını genişletmek bakımından son derece elverişli bir yorum. Demokratik bir düzende hak ve özgürlük esas, sınırlama istisnadır. Bu çerçevede de 17/1 fıkrasını kullanmak yoluyla yani yorum yoluyla anayasada açıkça hak ve özgürlük olarak tanımlanmamış kişi fiillerinin bir anayasal güvenceye kavuşturulması mümkün olabilir. Örneğin AİH Sözleşmesi yalnızca dernek kurma özgürlüğünü düzenliyor ama AİHM getirdiği içtihatla sendika hakkını ve siyasal parti özgürlüğünü hep bu dernek kurma hakkının içinde yorumladı. Böylelikle bu maddeyi yorum yoluyla genişletti. Bu hak ve özgürlükleri tek tek anayasada yazılmış hak ve özgürlüklerle düşünmememiz gerekiyor. Bunu yorum yoluyla genişletmek mümkündür.

Hak ve özgürlüklerin niteliği: Anayasanın 12.maddesinin kenar başlığı buna ilişkindir. 1.Fıkra bize bunu söylüyor. Bu 1961 anayasasının 10.maddesinde de yer alan bir düzenlemeydi. 1982 anayasası bunu aynen 12/1 fıkrasında yineledi. Başlangıç kısmının fıkrası.... 1982 anayasasına göre herkesi bağlıyor. 6.Fıkra ne diyor bak. Bu anayasanın 12/1 fıkrasını destekliyor. Yani herkesin onurlu bir yaşam sürdürme, maddi ve manevi varlığını geliştirme yetkisine doğuştan sahip olduğunu. 17/1 ve 12/1 fıkrasını içeren bir ifade olduğunu görüyoruz. Yine anayasanın 5.maddesi devletin görevlerini belirten bir düzenleme. 5.Madde bakımından gösterdiği 1. Temel hak ve özgürlüklerin bir bütün olduğunu bize gösteriyor. Hak ve özgürlüklerden yararlanabilmek ancak kişinin siyasal, ekonomik, sosyal engellerini devlet eliyle kaldırılmasıyla mümkün olabilir. Ancak kişi, maddi ve manevi varlığını bu engeller ortadan kaldırarak geliştirebilir. Bu kuşkusuz hak odaklı bir yaklaşım. Hak ve özgürlükleri aynı zamanda kişiyi önceleyen hak odaklı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Devletin ödevleri içinde kişinin maddi manevi varlığını geliştirmenin dışında kalan zaman zaman onunla da çalışacak biçimde başka ödevlerde yüklendiğini görüyoruz. Yine başlangıcın 6.fıkrasında kişinin onurlu bir yaşam sürdürebilmesi maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesinin ancak bu anayasadaki temel hak ve özgürlükler içerisinde söz konusu olabildiğinin altını çiziyor. Yani insan hakları olarak genel olarak ele almamış bu anayasadaki temel hak ve özgürlükler diyerek aslında doğal hukuk anlayışının dışında pozitivist bir hak anlayışına yaslandığını bu ifadeden ortaya çıkarabiliriz.

Sonuç: 1982 anayasası bir yandan doğal hak anlayışını benimsemiş gözüküyor, 12.madde, başlangıç 6.fıkrasının son ifadesi, 5.madde de yansıtılan bölüm ama bir yandan da 5.maddenin diğer ifadeleri hem başlangıcın 6.fıkrasındaki temel hak ve özgürlüklerden bu anayasanın sınırlayıcı anlayışı çerçevesinde yararlanabileceğini belirtmek pozitivist anlayışına da yaslandığını gösteriyor. Kısaca 1982 anayasası ilk biçiminde bu ifadelerle yer verse de geneline göz önünde bulundurduğumuzda hak odaklı anayasa olmak yerine ödev odaklı bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de otorite, devlet odaklı anayasa anlayışının anayasanın geneline nüfuz eden anlayış olduğunu söyleyebiliriz. 2001 Anayasa anlayışı bunu bir ölçüde değiştirdi. Ama hala anlayışın izleri anayasada yer alıyor. Hak ve ödev ilişkisi anayasanın 12.maddesi doğal hak anlayışını düzenleyen bir madde. 2.Fıkroda ise 1982 anayasasının hak ve ödevleri de içerdiğini ifade ediyor. Yani ödevlerle sınırlı bir hak anlayışına dayanıyor 1982 anayasası. Veya ancak bazı ödevlerin yapılması durumunda kişilerin haklarından yararlanabileceğini bu hakları kullanabileceğine ilişkin bir yaklaşımın benimsendiğini söyleyebiliriz.

1982 Anayasasında, temel hak ve özgürlüklerden kimler yararlanabiliyorlar: Hak ve özgürlüğün öznesi gerçek veya tüzel kişi olabilir yani kişidir. 3. Kuşak hakların yaygınlaşmasıyla birlikte bu öznenin doğa gibi başka unsurları da içinde barındıracak biçimde genişletildiğine ilişkin bir eğilimin olduğunu belirtelim. Özellikle Latin Amerika anayasalarının önemli bir bölümü doğayı, çevrenin korunmasında ya da çevre hakkı anlamında bir hak öznesi olarak düzenlemekte. Bizde 1982 anayasasında ise doğanın bir hak öznesi olarak düzenlenmediğini özellikle çevrenin korunması bakımından düzenlenmediğini belirtmekte yarar var. Bazı hak

ve özgürlükleri düzenleyen anayasa maddeleri bunu açık bir şekilde belirtmiş. Anayasanın 17/1. maddesi ve 17/3 fıkrası. Bazı hak ve özgürlüklerin formülasyonunda herkes, hiç kimse diye ifade gördüğümüzde vatandaş, yabancı ayrımı gözetilmeksizin herkese tanınan haklar olarak anlıyoruz. 17/1-3 ve 18.madde “hiç kimse zorla çalıştırılmaz diyen düzenleme” bize hep bunu gösteriyor. 17-18-19-20-21 maddelerde de o hakkın öznesinin kim olduğuna yanıt bulabiliriz. İkinci olarak bazı hak ve özgürlükler vatandaşlara tanınmıştır. Bunlar, seçme, seçilme, siyasal parti kurma ya da siyasal partilere üye olma hakları. Yine kamu hizmetine girme hakkı, vatan hizmeti Türk vatandaşlarına tanınmış haklar arasında yer alıyor. Eğer anayasa hakkın öznesi olarak vatandaş, Türk vatandaşı ya da Türk gibi bir ifade kullandıysa o zaman biz bu hakları vatandaşlar bakımından güvence altına alındığı sonucuna varıyoruz. Yine bazı hak ve özgürlükler, bir takım kişi gruplarına özel olarak tanınmış olabilir. Örneğin 41.Madde 3.fıkra ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkı çocuğa tanınmış haktır. 51.Madde sendika kurma hakkı, çalışanlara ve işverenlere tanınmış bir haktır. 53.madde toplu iş sözleşmesini düzenliyor ve bu hak işçi ve işverenlere tanınmış bir haktır. Toplu sözleşme hakkı kamu çalışanlarına tanınmış bir haktır. Grev hakkı işçilere, lokavt hakkı ise işverene tanınmış bir haktır. Yabancıların hakları, anayasanın 16.maddesinde düzenlenmiştir. Yabancılar yönelik sınırlamalara konu olabilecek hak ve özgürlükler örneğin belli alanlarda yabancıların çalışma hakkı, yasaklanması söz konusu olan belli alanlar olması veya belli bölgelerde veya belli kişilere özgü olarak bu hakkın yabancılar sınırlanması mümkün olabiliyor. Belli kategoriler bakımından yabancılar o kategorilere giriyorlarsa o zaman onların da o haklardan yararlanmaları mümkün. Mesela çocuğa tanınan 41.maddedeki haklar. Ya da işverene tanınan lokavt gibi. Çalışana tanınan sendika, grev hakkı, toplu sözleşme hakkı gibi yabancıların o gruplara dahil olması durumunda yararlanabileceği haklardır. Vatandaşlar bakımından da, vatandaş yazan haklar bakımından bu hakları anayasal olarak yalnızca vatandaşlar için güvence altına alındığını söylüyoruz. Buna karşılık anayasada açık bir yasak yok ise vatandaşlara özgülenmiş hak ve özgürlükleri kanun koyucunun taktiri yoluyla yabancılar bakımından da genişletilmesi söz konusu olabilir. Örneğin kamu hizmetine girme hakkı Türk vatandaşları bakımından yasaklanamaz ya da sınırlanamaz. Buna karşılık kamu hizmetine girme hakkını yabancılar içinde tanıyabilir. Bu durumda yabancılar içinde kamu hizmetine girme hakkı bir anayasal hak değildir. Kanun koyucunun taktiri geniştir. Kanun koyucu dilediği zaman yabancılar verdiği bu hakkı geri alma olanağına da sahiptir. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkı bakımından da geçerlidir. Bu hak anayasa ile Türk vatandaşlarına tanınan ve güvencelenen bir haktır. Kanun koyucu bu hakkı Türk vatandaşlarına verdiği hakkı anayasanın öngördüğü düzenlemelerin dışında sınırlayamaz ya da ortadan kaldıramaz. Buna karşılık taktir yetkisini kullanmak yoluyla kanun koyucu dilerse belli bir süredir ikamet eden yabancıların oy kullanmasını bir kanunla tanıyabilir. Burada önemli olan yabancılar yönelik açık bir yasağın bulunmamasıdır. Açık bir yasak yok ise kanun koyucu taktir yetkisini kullanmak yoluyla böyle bir kanuni hakkı yabancıya tanıyabilir. Burada kanunla tanınmış hakla, anayasa ile tanınmış hakla güvence bakımından önemli bir farkın olmasıdır.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması:

Sınırlama, bir hak ve özgürlüğe dışarıdan yapılacak müdahale ile o hak ve özgürlüğün kullanım alanının sınırlanması. Kanun ya da yürütmenin düzenleyici bir işlemi ile böyle bir müdahalenin yapılmasıdır. Dışarıdan yapılacak müdahalenin, ilgili hakkın norm alanına yönelik müdahale olması gerekiyor. Belli bir hakkın norm alanı dediğimiz zaman, o hakkın ilgili bulunduğu yaşam kesiti içinde güvenceye altına aldığı insan davranışlarını anlıyoruz. Sınırlama ile düzenleme arasında bir ilişki var. Öncelikle her sınırlama bir hukuki düzenlemedir. Buna karşılık her düzenleme bir sınırlama olmayabilir. Yani bazı hak ve özgürlükler bakımından yapılan bütün düzenlemeler o hakkın kullanım alanını daraltır yani sınırlayabilir. Özellikle negatif statü hakları bakımından hakkın düzenlenmesiyle sınırlanması nerdeyse özdeş bir haldedir. Negatif statü niteliğindeki hakta dışarıdan yapılacak her türlü müdahale o hakkın kullanım alanını aynı zamanda daraltılması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle negatif statü hakları veya kişi hakları dediğimiz haklar nitelikleri gereği her düzenleme sonucunda o hakkın sınırlanması sonucunu doğuracaktır. Buna karşılık sosyal ve ekonomik haklar bakımından her düzenleme aynı zamanda o hakkın sınırlandırılması sonucunu doğurmayabilir. Bazı düzenlemeler o hakkın kullanımını sağlayan veya o hakkın kullanımını kolaylaştıran nitelikte olabilir. Bazı hak ve özgürlüklerin CBK yoluyla düzenlenememesinin nedeni o düzenlemenin aynı zamanda sınırlama içerecek olması ve demokratik bir düzende o hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamaların yasa yoluyla yapılması gereğine dayanıyor. Buna karşılık ekonomik ve sosyal haklar kategorisinde yer alan 1982 anayasasının ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenen hak ve özgürlüklerin CBK ile düzenlenmesi mümkün. 1982 Anayasasının ilk biçiminde de KHK ile bu olanağı sağlıyordu. Bunun nedeni, pozitif haklar

(sosyal haklar) niteliğinde olan haklar nitelikleri gereği her düzenlenen haklar bakımından bunun sınırlanması sonucunu doğurmayabilir. Bazı pozitif haklar bakımından o hakka yönelik yapılacak düzenleme o hakkın kullanım olanağını sağlayabilir. 1982 Anayasasında ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler başlığı altında yer alan düzenlenen her hak ve özgürlüğün bir pozitif statü hakkı niteliğinde olması. Bazı haklar negatif statü hakları niteliğindedir. Örnek, herkesin yaşına ve medeni özelliklerine uygun işte çalıştırılması, sendikal haklar, sözleşme ve çalışma özgürlüğü hep niteliği gereği negatif statü hakkıdır. Ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiş olsa bile negatif statü hakkı niteliğindeki biraz önce örnek verdiğimiz bu hak ve özgürlükler bakımından her düzenleme aynı zamanda bir sınırlamanı niteliği taşıyacak. Bir hak ve özgürlüğün nasıl sınırlanacağı anayasa 13.maddesinde düzenleniyor. Ancak burada hakkın 13.madde çerçevesinde kanun yoluyla sınırlanmasıyla o hakka yönelik diğer sınırlamaları birbirinden ayırmamız gerekir. Pek çok hak belli bir sınırlılık içinde doğar. Bir hakkın sınırlanmasıyla bir hakkın sınırlılığı aynı şeyi ifade etmez. Hakkın, sınırlılığı dediğimiz zaman o hakkın bizzat kendisinden kaynaklanan sınırlılığını anlarız. O sınırlar içinde bir hak doğarken belli bir sınır içinde doğar. Her hak ve özgürlüğün sınırlılığı o hak ve özgürlüğün kapsadığı, düzenlediği yaşam alanının özgün yönleriyle bağlantılı olarak değişir. Biz hakkın kendinden kaynaklanan bu sınırlılığa aynı zamanda o hakkın nesnel sınırı diyoruz. Örneğin dilekçe hakkı, hiçbir zaman tehdit içeremez. Ya da belli kişileri suç işlemeye teşvik edemez. Böyle bir sınırlama kanunda belirtilmemiş olsa bile bu dilekçe hakkının nesnel sınırıdır. Anayasanın 36.maddesi hak arama özgürlüğünü düzenler. Herkes hak arama özgürlüğüne sahiptir. Ama bu hak arama özgürlüğünün nesnel sınırı; meşru yollarla ve meşru araçları kullanarak bu hakkın kullanılması gerekir. Anayasa böyle bir sınır getirmemiş olsa bile hak arama özgürlüğünün nesnel sınırı bu özgürlüğün ancak meşru araçlarla, meşru yollarla kullanılmasına ilişkindir. Sonuç: Her hak ve özgürlük kendisine özgü yaşam alanı içinde kendine özgü bir sınır içinde ortaya çıkar. Bu sınırın anayasada ya da herhangi bir yasada öngörülmemiş olması hakkın, mutlak bir şekilde sınırsız olduğu anlamına gelmez. Sınırlama ise bu nesnel sınırın dışında kalan kişinin kullanabileceği alanın dışarıdan yapılabilecek bir müdahale ile daraltılması. Her hak ve özgürlük aynı zamanda kanun ile sınırlamanın yanı sıra anayasa ile sınırlanabilir. Aynı zamanda yürütmenin bir işlemi ile de sınırlanabilir. Veya yargı kararıyla sınırlanabilir. Anayasal sınır dediğimizde bizzat anayasada belirtilen sınırdır. Yine sınırlama anayasada öngörülen sınırların dışında kalan alana ilişkindir. Anayasal sınırlara baktığımız zamanda, bunların bir bölümünün soyut sınırlamalar olduğunu görüyoruz. Bir bölümünün ise somut yani doğrudan uygulanabilir nitelikte olan sınırlamalar ya da yasaklar olduğunu görüyoruz. Soyut sınırlamalar; başlangıç maddesinin 5. Fıkrası. Ama bunların yasayla somutlaştırılması gerekir. Yani hangi faaliyetler Türk ulusal çıkarlarına aykırı kabul edilecek. Yasa koyucunun bunu somutlaştırması gerekir. Buna göre kişilerin faaliyetleri sınırlanacak. Bir başka örnek; Anayasanın 27/2 fıkrası. Hukuk devleti ilkesi, hangi bakımlardan bilim ve sanat özgürlüğü ilkesine aykırı kabul edilecek. Anayasa 24.Madde din ve vicdan özgürlüğü. Buna ilişkin birtakım yasaklar getiriliyor. Anayasa 28/5 fıkrası. Bu kuşkusuz hem ifade hem de basın özgürlüğüne yönelik anayasal bir sınırlama. Ancak burada devletin iç ve dış bütünlüğü ve güvenliğinin yasayla tanımlanması gerekiyor. Yine 52/2 fıkrası grev ve lokavt haklarının toplum zararına kullanılamayacağı belirtiliyor. Hangi eylemlerin toplum zararına olacağını yasayla somutlaştırılması gerekiyor. Anayasada belirtilen bu soyut yasaklar temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması bakımından son derece sakıncalı yasaklar. Çünkü siz bir yasayı anayasa ne kadar soyut bir şekilde düzenlerse o kadar geniş yasama organına taktir yetkisi bırakıyor demektir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında ve bunların sınırlanmasında taktir yetkisinin tarafından olabildiği kadar somut ve dar bir biçimde tanımlanması gerekir ki hak ve özgürlükler korunabilsin. Çünkü demokratik bir düzende kural özgürlük hak asıl, bunların sınırlanması istisna. Bu kurala uyabilmek için anayasa ile getirilmiş yasakların olabildiği kadar somut olması gerekir ki bu alanda yasa koyucuya geniş sınırsız bir taktir yetkisi tanınmasın. 1982 Anayasası, aynı zamanda bir takım somut yasaklarda öngörmüş. Bu yasaklar örneğin; 69/2.fıkrası siyasal partilerin ticari faaliyette bulunamayacağını belirtiyor. Yine 68/5.fıkrası; bazı kişilerin siyasal partilere üye olamayacağını belirtiyor. Keza 42.madde; Türkçe dışında başka bir dilin okullarda anadil olarak okutulamayacağını belirtiyor. Bu yasakta, anayasa ile getirilmiş bir yasağa somut bir örnektir. Aynı zamanda dolaylı bir biçimde de temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması sonucunu doğuran düzenlemeler var. Bu düzenlemelerin en önemlisi Yüksek Askeri Şura ve Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarının bazılarının yargı denetiminin dışında tutulması. Bu yargı denetimi dışında tutulması, hak arama özgürlüğünün bizzat anayasa ile sınırlanması anlamına geliyor. Yine anayasanın 148.maddesinde düzenlenen Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerin anayasaya uygunluk denetimi dışında tutulması da başka bir yolla, bizzat anayasa ile hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalara verebileceğimiz bir örnek.

Yine 12/2 fıkrası da bütün hak ve özgürlükler bakımından bir içkin anayasal sınır olarak tanınabileceğini ileri sürebiliriz. Bu madde temel hak ve özgürlüklerin kişinin, başkaları, toplum, aileye karşı sorumluluklarını da içerdiğine ilişkin düzenlemeydi. Birincisi temel hak ve özgürlükler, yasayla düzenlenmeden önce temel hak ve özgürlükler bizzat anayasa ile sınırlıdır. İkinci olarak yürütme organının bir işlemi ile de sınırlanabilir. Yürütmenin bir anayasa ya da bir yasa eliyle bir temel hak ve özgürlüğün kullanılmanı sınırlandırmak amacıyla yetkilendirilmesi söz konusu. Bizzat anayasa ile idareye getirilen birtakım yetkiler var. Örneğin anayasanın 19.maddesi, 26/1 fıkrası, 27/son fıkrası, 34.maddesine ilişkin idareye birtakım yetkiler vermiştir. Anayasaya baktığımız zaman temel hak ve özgürlüklerin yürütme eliyle sınırlanmasına ilişkin olarak gecikmesinde sakınca bulunan hemen bütün durumlarda hak ve özgürlüklere yürütmenin müdahale etmesini mümkün kılıyor. Örneğin 20.madde, kişilerin üstünü ve eşyalarını arama yetkisi idarenin yetki ve görevi içinde. 21.Madde, 22.madde gecikme hallerinde yürütmeye yetki vermektedir. Sonuç: Olağanüstü hallerin, yargı bağımsızlıklarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman anayasa bir yandan temel hak ve özgürlükleri ancak yasayla düzenlenebileceğini belirtiyor (anayasa 13.maddesi) ama öte yandan yürütme organına tanıdığı bu zengin müdahale olanağı aynı zamanda denetimsiz alan yoluyla bunun tersini mümkün kılıyor. Üçüncü olarak bizzat yargıç kararıyla da temel hak ve özgürlüklere müdahale edilmesi bir kere yargıç kararıyla somut ve tekil durumlarda sınırlanması her zaman yargıç kararıyla olur. Ama bunun dışında anayasanın kendisi de bazı hak ve özgürlüklerin sınırlanması olanağını ya da yetkisini yargı organına tanımış. Örneğin anayasanın 33.maddesi, dernekleri faaliyetten alıkoyma yetkisi ancak yargı kararıyla olabilir. 32.Madde, düzeltme ve cevap hakkı, 69.madde de siyasi parti kapatma hakkının hep yargı kararıyla olabileceği belirtilmiştir. Sonuç, anayasanın 13.maddesine gelene kadar bizzat anayasa tarafından temel hak ve özgürlüklerin sınırlandığı görüyoruz. Bunun dışında kalan alanda sınırlama hangi esaslara göre yapılır. İşte anayasanın 13.maddesi temel hak ve özgürlüklere yönelik bizzat anayasa ile getirilen sınırların dışında kalan ve her bir hakkın nesnel sınırlarının dışında kalan alanın hangi ölçütler ve standartlar çerçevesinde sınırlanabileceğini belirtiyor. Adımız kadar iyi bilmeliyiz bu maddeyi. Temel hak ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın, yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Demek ki sınırlamada yasa koyucunun göz önünde bulundurulup bulundurulmaması gereken ölçütler; 1. Nedene bağlı sınırlama 2. Yasayla sınırlama 3. Sınırlamanın hakkın özüne dokunmaması kuralı 4. Sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması 5. Sınırlamanın, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun bir sınırlama olması 6. Laik cumhuriyetin gereklerine aykırı sınırlama yapılamaması 7. Sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olmaması

1. Nedene bağlı sınırlama: İlgili anayasada ilgili hak ve özgürlüğün düzenlendiği maddede belirtilen sınırlama sebeplerinden birine ya da varsa birkaçına dayanmalı. Bunun dışında herhangi bir sınırlama sebebine dayanmamalı demek istiyor 13.madde. Bu sınırlama, yasama organının taktir yetkisini sınırlaması bakımından önemlidir. 1982 anayasasının ilk biçimi temel hak ve özgürlüklerin hangi nedenlerle sınırlanabileceği konusunda çifte sınırlama sistemi getirmişti. Yani anayasanın 13.maddesi ilk biçiminde 9 tane sınırlama sebebi sayıyordu. Bunlar; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık gibi 9 neden. Bunların yanı sıra her hak ve özgürlük anayasada kendi düzenlendiği ilgili maddede, ayrıca başka sınırlama sebeplerine de konu olabiliyor. Bu nedenle sınırlama sistemi, 1982 anayasasının ilk biçiminde çifte sınırlama sebebi olarak adlandırılıyor. Her bir anayasal hak ve özgürlük, hem 13. Maddedeki genel sınırlama sebeplerinden birine ya da birkaçına hem de ilgili hakkın düzenlendiği maddede belirtilen başka sınırlama sebeplerinden birine ya da birkaçına dayalı olarak sınırlama getiriyor. Böyle bir sistem temel hak ve özgürlükleri cendere altına alan sistem. AİH Sözleşmesine de uygun olmayan bir sistem. AİHM pek çok kararında belirtiyor. Diyor ki” her bir hak ve özgürlük için anayasa da ayrı bir madde de o hak ve özgürlüğü düzenlemeli her hak ve özgürlüğe özgü bir anayasa maddesi olmalı 2.Her bir hak ve özgürlük, kendi özel unsurları göz önünde bulundurarak ilgili maddede belirtilen sınırlama nedenlerine dayalı olarak sınırlanmalı. 13.Maddenin ilk biçimiyle getirdiği en önemli sorun, mesela düşünce özgürlüğünü bu genel sınırlama nedenlerinden birine dayanarak sınırlayabiliyorsunuz. Mesela genel sağlık nedeniyle düşünce özgürlüğünü sınırlamak mümkün. Böyle olunca bu düşünce özgürlüğünün kendi alanına aykırı bir sınırlama nedeni. Ama anayasa böyle bir çifte sınırlama modeli öngördüğü için kanun koyucuda rahatlıkla bunu kötüye kullanacak düzenlemelerde bulunabiliyordu. 2001 Yılında köklü anayasa değişiklikleri sırasında 13.maddedeki genel sınırlama nedenleri kaldırıldı. Onun yerine her bir hak ve özgürlüğün düzenlendiği maddeye sınırlama nedenleri getirildi. Bu durumda bazı hak ve

özgürlüklere yeni sınırlama sebepleri kondu. Böylelikle bugünkü hale geldi. Örneğin 33.madde dernek kurma özgürlüğünü düzenleyen madde. Bunlar içinde başkalarının hürriyetlerinin korunması 2001 anayasa değişiklikleriyle 33.maddeye eklendi. Bu durumda genel olarak örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılmasında bu sayılan nedenlerin dışında bir nedene yasa koyucunun dayanması mümkün değil. Madde 35; mülkiyet hakkını düzenliyor. Bunu kamu yararının dışında başka bir nedene dayanarak sınırlamak mümkün değildir. Buna karşılık anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlüklere baktığımızda bu hak ve özgürlüklerin bazılarında hiçbir sınırlama nedeninin olmadığını görüyoruz. Bunlar anayasada; din ve inanç, düşünce, hak arama, vatandaşlık, çalışma ve sözleşme, kanuni hakim güvencesi. Bu konularda hiçbir sınırlama nedeni yoktur. Bu hak ve özgürlüklerin bir kısmı bakımından bunları korudukları alanın niteliği gereği sınırlamaya uygun olmadığı sonucuna varıyoruz. İnanç özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü bu biçimde. Yani bunu sınırladığımız zaman hakkın özüne de dokunmuş oluyoruz. Haliyle bu iki özgürlük bakımından özgürlüklerin sınırlandırılması bu özgürlüklerin niteliği gereği mümkün değil. Benzer bir durum bilim ve sanat özgürlüğü bakımından da geçerli. Buna yönelik her türlü sınırlama bu özgürlüklerin özüne dokunacak nitelik taşıyor. Öte yandan böyle bir sınırlama nedeninin yer almamış olması bu özgürlüklerin kendi nesnel sınırları içinde kullanılması gerektiği sonucunu ortadan kaldırmıyor. Buradaki asıl sorun; çalışma ve sözleşme özgürlüğüne herhangi bir sınırlama nedeni getirilmemiş. Sözleşme özgürlüğü kamu düzeni, genel ahlak ve zayıfın korunması gibi geleneksel sınırlama nedenine bağlı. Anayasanın bu konuda sessiz kalması bir sistem eksikliği niteliğinde gözüküyor. Bu durumda hiçbir sınırlama nedeni yer almayan hak ve özgürlükler bakımından başkalarının temel haklarının korunması bir sınırlama nedeni olarak kabul edilebilir. Çünkü doğal hukuk anlayışında herkesin hak ve özgürlüğünün bittiği yer başkasının özgürlüğünün başladığı yerdir. Kimse başkasının özgürlüğünü ihlal ederek kendi hakkını kullanamaz. Nedene bağlı sınırlamada bir başka sorun; bazı hak ve özgürlükler bakımından bir takım sınırlama nedenleri sayılmış ama yer alması gereken sınırlama nedenlerinden bazılarının yer verilmemiş. Örneğin; seyahat özgürlüğü. Hangi nedenlerle bunun sınırlandırabileceği yazılmış buna karşılık genel sağlık bir sınırlama sebebi olarak sayılmamış. Nedene bağlı sınırlama söz konusuysa o zaman karantina gibi uygulamalar anayasaya aykırı hale geliyor. Bunu Covid-19 uygulamalarında da gördük. Anayasaya aykırı bir şekilde yürütüme organı bizim dolaşım özgürlüğümüzü sınırlayan önlemler genel sağlık önlemleri nedeniyle aldı. Anayasada birden fazla hak ve özgürlük birbiriyle çatışabilir. Bir hak ve özgürlüğün sınırsız bir şekilde kullanımı başka bir hak ve özgürlüğün kullanımını aşırı ölçüde sınırlayabilir. Haliyle bu dengenin göz önünde bulundurulması gerekir bir hakkı sınırlarken. Burada önemli olan haklar arasında bir çatışma olduğunda her iki hakkın ya da özgürlüğünde en üst düzeyde kullanılmasını sağlayacak bir yöntemin uygulanması gerekiyor. Anayasa hukukunda biz bu yorum yöntemine **pratik uyum ilkesi** diyoruz. Birbiriyle çatışan iki hakkın en üst düzeyde gerçekleştirilmesi, korunmasını sağlamayı amaçlayan yorum yöntemidir. AYM, 2001 yılındaki bu anayasa değişikliklerinden sonraki kararlarında bu nedene bağlı sınırlama ilkesini katı bir şekilde uyguladı. 2016/142 E. 2008/148 K. Bu karara konu olan kanuni düzenleme, milli güvenlik nedeniyle belli ailelerin ya da kişilerin zorunlu iskana bağlı tutulmasına bağlı kanuni düzenleme. Anayasanın 23.maddesi yerleşme özgürlüğünü düzenliyor. Bu yerleşme özgürlüğüne ilişkin olarak bu özgürlüğün sınırlandırılması 23.madde uyarınca ancak suç işlenmesinin önlenmesi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarından birine dayanabilir. Yerleşme özgürlüğüne ilişkin olarak yapılacak sınırlamalar içinde milli güvenlik nedeni yer almıyor. Bu nedenle anayasanın 23.maddesine ve aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin ilgili madde de belirtilen nedenlerden birine bağlı olarak sınırlandırabileceğini düzenleyen anayasanın 13.maddesine aykırıdır diyor. Söz konusu düzenlemeyi iptal ediyor. Ancak son yıllarda verdiği kararlarda AYM'nin bu görüşünü değiştirdiğini görüyoruz. Diyor ki AYM, bir kere her maddede özel sınırlama maddelerine yer verilmeyebiliyor. Ama bu özel sınırlama nedenlerine yer verilmeyen hak ve özgürlükler diğer anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin korunması ya da anayasanın diğer maddelerinde devlete bir görev olarak yüklenen ödevler nedeniyle sınırlandırılabilir. İki gerekçe getiriyor AYM. 1. Anayasada düzenlenen diğer temel hak ve özgürlüklerin korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması biçiminde okuyabiliriz. Bu nedenle anayasada sınırlama öngörülmemiş bir hak ve özgürlük sınırlandırılabilir diyor. 2. Anayasanın devlete bir görev olarak yüklediği ödevler nedeniyle bir hak ve özgürlük sınırlandırılabilir diyor. Burada 2.olarak kast ettiği, anayasanın temel görevlerini düzenleyen 5.maddesi. AYM, bu 5.maddeye göre kişilerin, toplumun refahı huzuru, mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevlerindendir. Devletin hak ve özgürlükleri koruma ödevinin yanında bu kamu sağlığını, güvenliğini koruma ödevi de vardır. Hak ve özgürlükler bu nedenle de sınırlandırılabilir. Bu son derece eleştiriye açık bir gerekçedir. AYM'nin, anayasanın 5.maddesine dayanarak anayasada yer alan

herhangi bir hak ve özgürlüğü sınırlayabileceğini savunmak aslında 2001 anayasa değişikliğinden önce mevcut olan genel sınırlama sebeplerini yorum yöntemiyle yeniden getirdi anlamına geliyor. Hak odaklı olmayan sınırlamaya yönelik bir yorum. 2020/62 E. 2020/69 Karar. Burada anayasanın 20.maddesi ile ilgili bir karar veriliyor. Özel hayatın gizliliğini düzenleyen bir madde. 2.Fıkrası özel hayatın gizliliğini mutlak bir biçimde güvenceye alıyor. Buradaki sınırlama nedenleri özel hayatın gizliliğine ilişkin değil arama ve el koyma tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin bir sınırlama. Haliyle AYM, anayasa koyucunun amacı olmayan mutlak olarak koruduğu ve düzenlediği bir hakka sınırlama nedeni icat ediyor. Bunu anayasanın 5.maddesi yoluyla icat ediyor. 2021/9 E. 2022/4 Karar sayısı ikinci örnek. Sonuç: AYM'nin bu yorumu gerçekten temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından sakıncalı ve tartışmalı bir yorum Anayasanın 5.maddesini genel bir sınırlama sebebi haline getirilmiş olması nedeniyle.

2. Yasayla sınırlama: Temel hak ve özgürlükler ancak yasayla sınırlanabilir. Temel hak ve özgürlükler, CBK, yönetmelik ya da diğer adsız düzenleyici işlemle sınırlanamaz demek. İşte sınırlama ile düzenleme arasındaki ilişki burada önem taşıyor. Kişi hakları bakımından, negatif statü hakları bakımından her düzenleme aynı zamanda bir sınırlama olduğu için bu haklara ilişkin yapılacak her türlü müdahalenin kanunla yapılması gerekiyor. Öte yandan pozitif statü niteliğinde olan haklar bakımından düzenlemelerin kanun dışında CBK ile yapılması mümkün anayasaya aykırı değil. Buna karşılık bunlara ilişkin getirilecek sınırlamaların da kanunla yapılması şart diyoruz.

3. Sınırlamanın hakkın özüne dokunmaması kuralı: Sınırlamanın anayasanın sözüne ve özüne uygun olması gerekiyor sınırlamaların. Anayasanın sözüne uygun sınırlama; hak ve özgürlüklere yönelik olarak bizzat anayasayla, anayasa metninde getirilen güvencelere uygun olarak bu sınırlamaların yapılması demek. Anayasa ile getirilen güvenceler örneğin, işkencenin eziyetin yasaklanması, angaryanın yasaklanması, basının ön denetime bağlı tutulmaması, her ne sebeple olursa olsun kimsenin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması (15/2) ya da herkesin önceden izin almadan dernek kurması, siyasal partilerin önceden izin alınmadan kurulması gibi anayasa ile getirilen ek güvencelere uygun olarak bunlara aykırı olmayan sınırlamalar yapılması anayasanın sözüne uygun sınırlama. Anayasanın ruhuna uygun sınırlama; sınırlama yaparken anayasanın bir ya da birkaç maddesi değil bütününe göz önünde bulundurmak. Anayasanın bütününden çıkacak anlama uygun olarak sınırlamayı yapmak anlamını taşıyor. Örneğin 2001 anayasa değişikliklerinden sonra 1982 anayasasının özgürlükleri esas sınırlamayı istisna kabul eden ilkeye dayalı bir anayasa olduğunu kabul edecek olursak sınırlamaların da anayasanın bütününe göz önünde bulundurarak vardığımız ilke ve sonuçlara uygun sınırlamalar olması gerekiyor.

4. Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması: bunun ölçütü 1982 anayasasının ilk biçiminde de bulunan ölçüttü. 1961 Anayasası demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütüne yer vermemişti. Onun yerine hakkın özüne dokunma yasağı getirmişti. 1982 Anayasasını yapanlar bu hakkın özü ölçütünü kaldırdı onun yerine demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun sınırlama ölçütünü getirdi. Bu ölçüt, aslında BM'in medeni ve siyasal haklar sözleşmesinde yer alıyor hem de AİH Sözleşmesinde yer alıyor. Demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünü, hakkın özüne dokunma yasağına bir alternatif olup olmadığı hep tartışıla geldi. Pek çok anayasa hukukçusu demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünü öz kavramına göre daha belirgin ve uygulanması daha kolay bir ölçüt olduğunu iddia etti. Buradaki önemli konulardan biri, demokratik toplum düzeninin gereklerinin hangi demokratik toplum olduğu. Çünkü gördük ki demokrasi bahsinde tıpkı hukuk devletinde olduğu gibi demokrasi bahsinde de tek bir demokratik düzen yok. Çok sayıda farklı demokratik düzenlerin olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz ki bir düzeni demokratik olarak adlandırabilmek için asgari olarak ilkelerin, kuralların olması gerekiyor. Demokratik düzenin tanımını anayasa yapmamış. AYM 1986 yılında verdiği 1986/23 Karar sayısında, demokratik toplum düzenini, burada anayasanın öngördüğü demokratik toplum düzeni kuşkusuz anayasada öngörülen özgürlükçü demokrasi ve onun gerekleriyle belirlenmiş olan hukuk düzeni. 1982 anayasasının bütününden nasıl bir demokratik düzen çıkaracaksak anayasa sınırları içindeki demokratik düzeni anlayacağız. 1982 Anayasası ilk biçiminde öyle evrensel demokratik ilkelerle bağdaşan ilkeler içeren anayasa değildir. Sonuçta 1986 tarihli kararıyla AYM, demokratik toplum düzenini anayasanın öngördüğü kurallarla sınırlı haliyle otoriter düzen olarak yorumladı. Buna karşılık aynı yıl bir başka kararla, 1986/27 Karar sayısında demokratik toplum ve demokrasi kavramından ne anladığını, değiştirdi. Diyor ki; klasik demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en geniş biçimde güvence altına alındığı rejimlerdir. Buna göre anayasanın 2.maddesinde ifadesini bulan demokrasi ilkesi özgürlüklerin ancak

istisnai olarak ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlanması anlamına gelir.

Buradan çıkan sonuç: 1. Demokrasinin temel ilkesi olan özgürlük esas sınırlama istisnadır ilkesi kuralını kabul ediyor AYM. **2.** Bununla bağlantılı olarak ancak zorunlu olduğu zaman bir hakkın ya da özgürlüğün sınırlanması gerektiğini belirtiyor.

AYM'nin bu kararına göre, klasik demokratik rejimin temel özellikleri neler: **1.** Temel hak ve özgürlükler en geniş ölçüde güvence altına alınır. **2.** Rejim, düzen özgürlükçü olur. Yani özgürlük asıl sınırlama istisnadır ilkesine uygun olur. **3.** Düzen hukuk devleti olur. **4.** Kişiyi ön planda tutan bir düzen olur. Doğal hukuk anlayışına atıf yapan bir ilke. **5.** Özgürlükleri ancak istisnai olarak ve demokratik toplum düzeninin zorunlu olduğu ölçüde sınırlamak. **6.** Özgürlükleri belli özgürlüğün kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeyde sınırlamamak. Sınırlamaya da bir sınırlama getiriyor AYM. Bunu klasik demokrasi anlayışının bir unsuru olarak sayıyor ve kabul ediyor.

5.Hakkın özüne dokunma yasağı: Hakkın özü kavramının sınırlamada bir ölçüt olarak kabul edilmesi ilk defa 1961 anayasası ile oldu. Bu anayasa temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamaların o hakkın özüne dokunamayacağını açık bir biçimde belirtiyor. 1982 anayasasının ilk biçimi, demokratik toplum düzeninin gereklerine bir sınırlama ölçütü olarak getirirken hakkın özüne dokunmak yasağını yer vermedi. Buna karşılık 2001 anayasa değişiklikleri ile birlikte 13.madde yeniden yazılırken hakkın özüne dokunma yasağı yeni bir sınırlamada göz önünde bulundurulması gereken bir ölçüt olarak yeniden bir anayasanın içine eklendi. Hakkın özü kavramı ne demek; öz dediğimiz zaman özgürlüğün vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu zaman o özgürlüğü anlamsız kılacak asli çekirdeğini anlıyoruz. AYM, hakkın özünü 1961 yılından itibaren çok geniş bir şekilde tanımladı. AYM'ne göre bir hak ve özgürlüğün kullanılmasına, açıkça yasaklayan veya örtülü bir şekilde kullanılamaz hale getiren veya ciddi ölçüde güçleştiren amacına ulaşmasını önleyen ve etkisini ortadan kaldıran sınırlamalar öze dokunma sayılır. Her ne kadar 2001 anayasa değişikliği ile hakkın özüne dokunma yasağı anayasanın 13.maddesine yeniden getirilmişse de AYM bundan öncede demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünü kullanırken hakkın özüne de destek norm olarak yer veriyordu. Örneğin 1988/8 karar sayılı kararı. Önemli bir karar çünkü bu karara konu olan kanun ile suçüstü yakalama durumunda yalnızca suçüstü biçiminde yakalanan sanığın 3 günle sınırlı bir savunma süresinin olduğunu belirtiyor kanun. AYM, bunun anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Dedi ki; bu düzenleme hem savunma hakkını özünü zedeleyiyor yani hakkın özüne dokunuyor ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı bir sınırlamadır. Burada hakkın özünü zedeleyen düzenleme aynı zamanda da demokratik toplum düzeninin gereklerine de aykırı olacaktır sonucuna varmış. Ancak bunun tersini söylemek her zaman mümkün olmayabilir. Yani demokratik toplum düzenine aykırı olan ya da hakkın özüne aykırı olan her sınırlama her zaman demokratik toplum düzenine de aykırı görülmebilir. Bir kişinin haberleşmesinin izlenmesi, haberleşmenin gizliliği hakkını ortadan kaldırır. Buna karşılık demokratik düzenlerde bazı durumlarda suç işlenmesinin önlenmesi gibi çok ciddi kuşkunun ortaya çıkması durumunda suç işlenmesi gibi ulusal güvenlik gibi bazı nedenlere dayalı olarak kişilerin haberleşmelerinin izlendiği görülüyor. Belli sınırlar altında demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı kabul edilmiyor. Buna karşılık örnek verdiğimiz hak bakımından hakkın özüne dokunmuyor. Hakkın özü ile demokratik toplum düzeninin gerekleri her zaman birbirinin yerine geçen ve birbirini ikame eden ölçütler değil. 13.maddenin iki ölçüte aynı anda yer vermesi bu bakımdan son derece önemli. 1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra anayasa mahkemesi hakkın özü kavramını 1961 anayasası dönemindeki kararlarına göre çok daha diri, daha dar daha güvencesiz biçimde yorumluyor. Günümüzde AYM hakkın özü kavramına hiç girmemeye özen gösteriyor. Anayasaya uygunluk denetimini demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunlukla.... Hakkın özüne girdiği zamanda bu kavramın hakkın tümüyle kullanılamaz hale getirildiği veya tamamen ortadan kaldırıldığı sınırlamalarla sınırlıyor. 1961 Anayasası döneminde hakkın örtülü bir biçimde kullanılamaz hale getirilmesi ciddi ölçüde güçleştirilmesi, amacına ulaşmasının güçleştirilmesi, etkisini ortadan kaldırması gibi durumları da hakkın özüne dokunma olarak kabul etmiştir. Şimdi çok daha dar yorum yaptığını görüyoruz. Son yıllarda da hakkın özü kavramını kararlarında kullanmamayı tercih ediyor.

6.Laik cumhuriyetin gereklerine uygun sınırlama: Bu 2001 anayasa değişikliği ile 13.maddeye getirilen bir ölçüt. 1982 anayasasının ilk biçiminde de 1961 anayasasında da yer almıyordu bu ölçüt. Bunu genel olarak anayasa koyucunun laik cumhuriyete olan duyarlılığı biçiminde değerlendirebiliriz. Bu sınırlamadan anladığımız; anayasanın çeşitli maddelerinde bununla ilgili olabilecek düzenlemeler var. Başlangıç bölümünün

5.fikrasında da laik cumhuriyetin gereklerine uygun sınırlama var. 24.madde hem din ve vicdan hem de ibadet özgürlüğü. Bu madde de ki bütün düzenlemeler laik cumhuriyetin gereklerine uygun olmaya ilişkin sınırlamalar getirilen düzenlemelere verebileceğimiz örnek. Bu sınırlamayı demokratik toplum düzeniyle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Demokratik toplum düzeninin gereklerini de içinde barındıran ona aykırı olmaması gereken bir sınırlama olmalı.

7. Ölçülülük ilkesi: Bu ilke sınırlamanın da sınırını getiren bir ilke. Bu ilke; bir hakkın ya da özgürlüğün sınırlanması için kullanılacak araçla sınırlamayla elde edinilmek istenen amaç arasında makul ve adil bir dengenin kurulması anlamına geliyor. Ölçülülük ilkesi, AİH Sözleşmesinde de var. Orada orantılılık biçiminde yer alıyor. En temel ilkelerden olan özgürlüğün kural, sınırlamanın istisna olması ilkesinin de ayrılmaz bir parçası, ayrılamaz bir ölçütü ölçülülük ilkesi. 1961 Anayasası döneminde yer almıyordu. Ama 1961 döneminde de AYM, bu ölçülülük ilkesine uyan bir takım anayasaya uygunluk denetimleri yaptı. 1982 anayasası döneminde de zaman zaman buna kararlarında yer verdi. Ölçülülük ilkesinin 3 alt ilkesi vardır. Bunlar: elverişlilik, gereklilik ve oranlılık ilkeleri. Bu ilke 2001 anayasa değişiklikleriyle 13.maddeye eklendi. Bundan önce açık biçimde yer almıyordu. Ancak 13. Maddenin ilk biçiminde sınırlama hakkın öngörüldüğü amaç dışında kullanılamaz ifadesi yer alıyordu. Genellikle bu ifadenin ölçülülük ilkesine referans yaptığı kabul ediliyordu. Bir de 15.madde olağanüstü hallerde bile sınırlamanın hak ve özgürlüklere yönelik müdahalenin durumun gerektirdiği ölçüde yapılabileceğini belirtiyordu. Haliyle yapılan yorum şuydu “olağanüstü hallerde bile temel hak ve özgürlükler ancak durumun gerektirdiği ölçüde sınırlanabileceğine göre bu ölçülülük ilkesinin olağan dönemlerde öncelikle göz önünde bulundurulması gerekir. Haliyle 1982 anayasasının ilk biçiminde de dolaylı olarak bulunduğunu kabul ediyor idik. Ama 2001 anayasa değişikliğinden sonra bu ilke açık bir biçimde anayasada yer alan bir ilke haline geldi. Alt unsurlar nedir?

Elverişlilik: sınırlama aracının, sınırlama ile elde edilmesi istenen amaçlanan amacı gerçekleştirmek için uygun bir amaç olması gerekiyor. Aynı zamanda ulaşılması gereken sonuca katkı sağlaması gerekiyor. Örneğin sigara içilmesini kapalı alanlarda yasaklanması kamu sağlığını korumak ve aynı zamanda başkalarının korumak amacını taşıyor. Dolayısıyla burada kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasının kamu sağlığının ve başkalarının sağlığını koruma amacına ulaşmak için uygun bir sınırlama aracı olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık söz konusu yasak yalnızca kapalı alanlarda değil ama bütün açık alanları içine alacak bir yasak ise o zaman bu yasağın amaca ulaşmak için elverişli bir sınırlama olmadığı sonucuna varabiliriz.

Gereklilik: Temel hakkın sınırlanması için kullanılan aracı bu sınırlama ile elde edinilmek istenen amacı gerçekleştirmek için zorunlu bir araç olması. Eğer, amacı gerçekleştirmek için birden fazla araç var ise, o zaman bu araçlar içinde o hakkı en az sınırlayan aracın kullanılması gerekir, gereklilik ilkesinin sağlanması bakımından. 1982 Döneminde AYM’nin bir kararından somut örnek 2021/117 E. 2022/10 karar. Bu karara konu olan kanun hükmü şu; özel okullarda çalışan öğretmenler veya bir özel okula öğretmen olarak girecek kişilerin belli suçlar bakımından kovuşturmaya uğramamış olması gerekir. Eğer bir öğretmen dolandırıcılık ve sahtecilikle ilgili bir kovuşturmaya uğradıysa ya da uğramaktaysa o zaman öğretmenin görevine son verilir. Böyle bir kovuşturma geçiren kişinin özel okulların öğretmen olarak istihdam edemeyeceğini belirtiyor. Anayasa mahkemesi bu kanunu anayasaya ve elverişlilik ilkesine aykırı buluyor. Öğretmenlik mesleği önemli bir meslek. Haliyle dolandırıcılık, sahtecilik gibi suça bulaşmamış kişilerin bunu yapması gerekir. Buna karşılık kovuşturma aşaması henüz ilgili kişinin bu suçu işleyip işlemediğini kesin aşama değil. Masumiyet karinesi var. Buna rağmen böyle bir kişinin öğretmenliğine son veriliyor. Değilse böyle bir kişinin istihdam edilmesi kanun tarafından yasaklanıyor. Oysaki kanun koyucunun ulaşmak istediği amaca hakkı daha az sınırlayan bir araçla ulaşması mümkündü. Buradaki hak çalışma ve sözleşme özgürlüğü. Kamu yararının sağlanması amacına daha hafif bir sınırlama ile ulaşılması mümkünken kişiler hakkında dolandırıcılık, sahtecilik suçlarından kovuşturma bulunmaması şeklindeki sınırlamayı gereklilik ölçütüne aykırı buldu.

Oranlılık İlkesi: Sınırlama ile elde edilecek amaçla bu amaca ulaşmayı sağlayacak araç arasında adil bir dengenin bulunmasını sağlamak. Yani aşırı ölçüde hakkın sınırlanmasını engellemek. AİHM’nin Gerger Türkiye kararı. Başvurucu Deniz Gezmiş için düzenlenen bir anma töreninde mesaj göndermiş. Terörle mücadele kanunu ilgili maddeleri uyarınca hem hapis hem de para cezası almış. AİHM demiş ki “ Bir kere burada başvuruyu cezalandırmanın amacı, ulusal güvenliği , devlerin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesini korumak. Araç, hapis ve para cezası vermek mesajı nedeniyle.” AİHM diyor ki “Burada bazı şeyleri

göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1. Törene katılan çok az insan var. Dolayısıyla ulusal, kamu güvenliği üzerinde mesajın etkisi çok az. Katılan insan sayısı çok az. 2. Söz konusu mesaj, şiddete, silaha başvuru isyana teşvik etmiyor. Barışçıl bir mesaj. Haliyle bunları göz önünde bulundurduğumuzda araçla amaç arasında bir denge yok. Ceza yani araç elde edilmek istenen amaca göre çok daha ağır bir araç. Haliyle burada oranlılık ilkesine aykırılık söz konusu” demiş. Ölçülülük ilkesi genel olarak bu 3 ilkeyi taşıyor. AYM ve AİHM’de yasaların anayasaya uygunluğunda da bireysel başvurularda da ölçülülük ilkesinin anayasaya uygunluk ve temel hak ve özgürlüğün ihlal edilmediği unsurları bakımından bütün kararlarında öncelikle göz önünde bulunduruyor.

12 Nisan 2023

Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye kullanılmaması: Madde 14 de bulunuyor. 1961 Anayasasında böyle bir madde yer almıyordu. 1971 Yılında yapılan anayasa değişikliği ile 1961 anayasasının 11.maddesine 2 fıkra eklendi. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmayacağına ilişkin düzenleme getirildi. 1982 Anayasası bunu ayrı bir madde olarak düzenledi.

Bunun önemi ; I. Dönem görmüştük dokunulmazlığın kaldırılmasında 14.maddeye atıf yapılmıştı. **2.** Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen anayasanın 24.maddesinde 14.maddeye atıf var. 14.Madde 2001 anayasa değişiklikleri ile yeniden yazıldı. Ondan önce son derece daraltıcı muğlak ifadeler taşıyan bir madde niteliğindeydi. 2001 Anayasa değişikliklerinden sonra bir ölçüde iyileştirildi ama 14.maddeye yönelik eleştirilerimiz hala devam ediyor. Kötüye kullanma sayılabilecek eylemlerin açık ve somut bir biçimde ifade edilmesi gerekir. Aksi takdirde böyle bir muğlak düzenlemeler hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında yasama organına çok geniş bir takdir yetkisi bırakmaktadır. Hak ve özgürlüklerin korunması bakımından yasama organının ve idarenin takdir yetkisinin anayasanın olabildiği kadar sınırlandırılması gerekir. Aksi takdirde hem yasama hem de idarenin bunu kötüye kullanması mümkün olacaktır. Burada özellikle 2001 anayasa değişikliğinden sonra en önemli dikkat çekici konu hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının yalnızca kişiler tarafından yapılabilecek bir eylem olmaması aynı zamanda bu yasağın devlete yönelik olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bunu 2. Fıkroda açıkça görüyoruz. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal rejim, anayasa ile her hak ve özgürlük bakımından getirilen güvenceler, bu güvenceleri ortadan kaldıracak, bu güvenceleri sınırlayacak bunları anayasa ile getirilen sınırların ötesinde daraltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı haklı kılmıyor 14.madde.

Genel olarak 14.maddeye ilişkin olarak; 1. Böyle bir madde olmasaydı bile hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmayacağı zaten hak ve özgürlüğe içkin bir durum. Kimse hak ve özgürlüğü kötülüğe kullanamaz. Böyle bir düzenlemenin anayasada yer alması ya da yer almaması hak ve özgürlüğün kötüye kullanılabileceği sonucunu doğurmayacak. Bunun mevcut olmasını, yine özgürlük odaklı bir yaklaşımı göz önünde bulunduracak olursak, her zaman hak ve özgürlüklere devletin ya da siyasal iktidarın sınırlandırılmasına hep hak odaklı ve özgürlükçü bir pencereden bakıyoruz. Anayasanın 13. maddesi devletin özgürlükleri yok etme ya da anayasada belirtilenden daha geniş bir şekilde sınırlayamama kuralını zaten düzenliyor. 13. Madde, temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel bir koruma sağlıyor. 14.Madde ise devletin özgürlükleri yok etme ya da anayasada öngörülenden daha geniş bir şekilde sınırlamasını yasakladığı için bir sigorta niteliği taşıyor. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin 2.bir güvence olarak düşünebiliriz anayasanın 14.maddesini. Bu şekilde hak odaklı yorumlamak gerekiyor.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılmasının Durdurulması: 15.maddede düzenleniyor. Bunu OHAL yönetim usullerini ele aldığımızda bunu ayrıntılı olarak görmüştük. Söylenilecek 3 şey; **1.** Temel hak ve özgürlükler, olağanüstü dönemlere göre daha geniş bir şekilde sınırlandırılabilmesi için ya da bu hak ve özgürlüklerin kullanımını geçici olarak askıya alınabilmesi için usulüne uygun olarak bir olağanüstü hal, seferberlik ya da savaş ilan edilmesi gerekir. **2.** Söz konusu sınırlamaların anayasanın 15.maddesi çerçevesinde hak ve özgürlüklere yönelik olarak yapılacak sınırlamaların uluslararası hukuktan doğan yükümlülöklere aykırı olmaması gerekir.

Bundan anladığımız; **1.** Uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun bir sınırlama (ahde vefa, mücbir sebep, sebepsiz zenginleşme gibi) uluslararası hukukun genel ilkelerini göz önünde bulunduruyoruz. Bunlara aykırı bir biçimde anayasanın 15.maddesine dayanılarak temel hak ve özgürlüklere müdahale dilemez.

2. Uluslararası yükümlölükler bize; Türkiye'nin taraf olduđu uluslararası antlaşmalar ve bu antlaşmalardan kaynaklanan yükümlölüklere uygun olarak hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sonucunu getiriyor. Bunlar Türkiye'nin taraf olduđu, BM bünyesinde ya da Avrupa Konseyi bünyesinde yapılmış insan haklarını düzenleyen anlaşmaları anlıyoruz. Örnek; 1948 Tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1966 imzalanan BM'nin ikiz sözleşmeleri, 1954 yılında Türkiye'nin katıldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, işkenceye karşı BM sözleşmesi yine BM bünyesinde yapılan ırk ayrımcılığın önlenmesine ilişkin sözleşme, 1975 tarihli Helsinki Sonuç Belgesi, 1990 Paris Şartı gibi uluslararası sözleşmelerde yazan düzenlemelere aykırı sonuç doğuracak biçimde anayasanın 15.maddesi çerçevesinde hak ve özgürlüklere müdahale edilemez. AİHM'nin içtihatlarına aykırı olarak da hak ve özgürlüklere müdahale edilemeyeceği sonucunu çıkarıyoruz anayasanın 15.maddesinin 1.fikrasında. 3.bir sonuç anayasanın 15.amaddesi çerçevesinde 2.fıkarda belirtilen bu dokunulmaz hak ve özgürlüklere hiçbir şekilde müdahale edilememesi yani bu hak ve özgürlüklere olağanüstü durumlarda bile dokunulamaması diyebiliriz. OHAL bakımından anayasanın 119.maddesini de göz önünde bulundurarak son derece tatmin edici güvenceler. Buna karşılık bu güvencelerin uygulamaya geçirilmesi anayasanın 148.maddesinde OHAL Kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimi dışında bırakılmasıyla tamamen anlamsız bir hale geliyor.

Temel Hak ve Özgürlükler Nasıl Korunabilir: İki düzeyde hak ve özgürlükleri korumak mümkün. **1.** Ulusal düzeyde korumak **2.** Ulusal Üstü düzeyde korumak. Ulusal düzeyde koruma denilince, **1.** Öncelikle siyasal erki elinde bulunduran organlara karşı koruyoruz. **2.** Tabi ki 3.kişilere karşı da koruyoruz. Bu devletin sorumluluđu ve yükümlölüğü altındadır. Devlet bu görevini yerine getirmiyorsa yine sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir. Hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin aykırılıkların çok önemli bir bölümü devletten kaynaklandığı için. Temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlalleri ortadan kaldırmanın temel hak ve özgürlükleri korumanın en önemli yolu hukuk devletidir. Hukuk devletinin olduđu bir hukuk düzeninde temel hak ve özgürlükler en etkili bir şekilde korunur. Anayasanın 40. Maddesi bize anayasal korumanın dayanağını veriyor. Bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin ortadan kaldırılması için 1.yargının dışında bir takım koruma düzenekleri olabilir. 1982 anayasası da bu yargı dışı koruma düzeneklerini düzenliyor. Bunun bir kaynağı 40.madde. 2 olarak anayasanın 74.maddesi. Devlet kadar eski bir haktır dilekçe hakkı. Devletin biçiminin nasıl olduđu önem taşımaksızın ister yurttaşlık esasına ister uyrukluğa esasına dayanmış olsun herkesin yöneticilerden, şikayetlerini yöneticilere iletme ya da dileklerini yöneticilerle paylaşma hakkı vardır. Dilekçe hakkı 1214 Magna Carta'da beri yazılı olan yazılı olmasa bile yurttaşların, buyrukların sahip olduđu bir hak. Anayasanın 74.maddesi bu hakkı tanıyor. Temel hak ve özgürlüklerin yargı dışı yollarla korunması 2 kaynaktan olabilir. **1.** Yasama organı yani parlamento **2.** İdare yani yürütme organı eliyle olabilir. Yasama organı yoluyla temel hak ve özgürlükler şu şekilde korunur; TBMM'ne dilekçe vermek yoluyla. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin iddialar içeren bu dilekçe, TBMM'de bulunan İnsan Hakları Komisyonuna verilir. 1990 Yılında kuruldu. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin şikayetlere bakan bir komisyon. 2. Eğer kadın erkek eşitliğine ilişkin bir durum söz konusu ise o zaman kadın erkek eşitliği komisyonuna da verilebilir. TBMM çatısı altında bu komisyon 2009 yılında kuruldu.

Öte yandan bu komisyonlar aracılığı ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz 2 nedenle. **1.** Bu komisyonlar siyasal partilerin güçleri oranında o komisyonlara verdikleri temsilcilerden oluşuyorlar. **2.** Bu komisyonların hazırladıkları raporların irade bakımından herhangi bir bağlayıcılığı yok. Şimdiki hükümet sistemini de göz önünde bulundurunca yürütme erkiyle yasama organının çoğunluğu hangi siyasal partilerden geliyor ise o zaman bu komisyonların yürütmeden kaynaklanan bu ihlalleri kamuoyu ile paylaşan raporlar hazırlama olasılığı da çok düşüktür. 1990 Yılında İnsan Hakları Komisyonu ilk kurulduğunda gerçekten çok etkili çalışmalarda bulundu. Örneğin karakollara gidip işkence iddialarıyla ilişkili raporlar yazdı ama o dönemde ülkede bir koalisyon hükümeti olduđu için bunun yarattığı "olumlu bir sonuçtu". Parlamento ve yürütme erki aynı elde toplandığı zaman bu komisyonların temel hak ve özgürlüklerin korunması yönünde hiçbir etkisi yok. Yürütme ve parlamento çoğunluğunun farklı siyasal partilerde olması durumunda bile bu komisyonların hak ve özgürlüklerin korunmasındaki rolü son derece sınırlı. En fazla devletten kaynaklanan sistematik hak ve özgürlük ihlallerini tespit edip bunu kamuoyu ile paylaşmak. Bu vesileyle kamuoyunu harekete geçirmek gibi bir rol üstlenebiliyordu. Bu komisyonların dışında bir başka yargı dışı koruma mekanizması olarak tartışılabilir bir kurum kamu denetçiliği kurumu. 2010 Anayasa değişikliği ile bizim hukuk düzenimize girdi. Demokratik ülkelerin tümünde kamu denetçiliği, parlamento komiserliği, ombudsmanlık, halkın avukatı gibi adlar altında bu kamu denetçiliği kurumunun olduğunu görüyoruz. Bu

kurum bir kere demokratik ülkelerde parlamentoya bağlı olarak çalışan ama parlamento ve idareden de bağımsız olan bir kurum. Bu kurum parlamento yıllık raporlar veriyor. Bir yol boyunca idare, idari kurum ve kuruluşlar temel hak ve özgürlüklere ilişkin sistematik ihlaller yapmışlar mı, hangi alanlarda daha çok şikayet var. Hangi hak ve özgürlüklerin kullanılması konusunda idareden kaynaklanan olumsuz uygulamalar var gibi konuları ele alan yıllık raporları hazırlayıp bunları da parlamento ile paylaşır. Bu kurumun hazırlamış olduğu raporların, yapmış olduğu araştırma ve incelemelerin hukuki bir sonucu yoktur. En fazla kamuda açık bir hak ihlali var ise o zaman yargı organını harekete geçirebilir. Bu ihlalleri kamuoyu ile paylaşabilir. Kamuoyunu harekete geçirebilir. Bunun dışında başka bir yaptırım yetkisi yoktur. 2010 Anayasa değişikliği ile kurulmuş olan kamu denetçiliği kurumu da aslında bu amaçla kurulmuş gözüküyor. Anayasanın 74.maddesinde düzenleniyor. Bu kurumun hakkıyla bu görevi yerine getirebilmesi için idari, mali olarak hem parlamentodan hem de yürütme organından özerk olması gerekir. Yürütme organından özerk olması son derece önemli. Çünkü onun eylem ve işlemlerinin, hak ve özgürlükleri ihlal edip etmediğine ilişkin şikayetleri inceliyor. 74/3 Fıkrası Kamu denetçisi, TBMM tarafından 4 yıl için gizli oyla seçilir. Bir kişinin TBMM tarafından seçilmesi mümkün. İlk 2 oylamada 2/3 oran aranıyor. Kimse o oya ulaşamazsa üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Yine kimse üye tam sayısının salt çoğunluğunu elde edemezse 4.oylamaya son oylamada en çok oy almış 2 aday katılıyor. Bu adaylardan hangisi en çok oyu alırsa kamu denetçisi seçiliyor. Parlamento içinde siyasal partiler arasında uzlaşmaya dayalı bir seçim yöntemi uygulanmamış. Bunun sonucu olarak kendine yakın birisini seçiyor. Kendine yakın olan kişinin tekrar seçilmesi mümkün olunca bir kişi kurumun asli işlemini yerine getirmesi mümkün değil. Günümüzde uygulamada yargı organını bu yürütmenin hak ve özgürlük ihlallerine karşı harekete geçirmesi bakımından bir rolü bulunmamaktadır. Adı olup da kendisi olmayan bir kurumdur. Yürütme içinde temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik birtakım düzenekler oluşturulabilir mi?

Örneğin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2012 yılında Başbakanlık bünyesinde kurulmuş bir kurum. Bu kurum 11 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin tümünü CB atıyor. Haliyle CB'na bağlı olan yürütmeden kaynaklanacak hak ihlallerinde de herhangi bir tespitte bulunmak, bunu kamuoyu ile paylaşmak, kamuoyunu bu konuda harekete geçirmek gibi işlevleri üstlenmeyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi bu tür kurumların temel hak ve özgürlüklerin korunmasında küçük bile olsa bir rol üstlenebilmesi için birtakım unsurları içinde barındırması gerekiyor. Bu unsurların ne olduğu 1992 tarihli genel kurulda kabul edilen BM Paris İlkelerinde yer alıyor. Bu ilkelere uygun olması gerekiyor ki bu tür kurumlar kuruluş işlemlerini yerine getirebilsin. Bu tür kurumların şu özelliklere sahip olması gerekiyor; 1. Bu kurum ve kuruluşlar, hangi konuya ilişkin olarak kuruldu ise konu ile ilgili olarak çalışan sivil toplum temsilcilerine yer vermeli. Sivil toplum temsilcileri dediğimiz zaman yürütme organının ya da parlamento çoğunluğunun makbul bulduğu sivil toplum örgütü temsilcileri değil farklı bakımdan aynı hak ve özgürlüğe yaklaşan farklı sivil toplum örgütü temsilcilerinin bu tür kuruluşlarda yer alması gerekiyor. Yine konuya bağlı olarak değişecek olan hukukçular, doktorlar bilim insanları, sendikacılar, gazeteciler gibi üniversite temsilcileri, meslek kuruluşları gibi sivil toplumun farklı alanlarının bu kurumlarda temsil edilmesi gerekiyor. 2. Bunların mali açıdan yeterli kaynağa sahip olması ve hem mali hem de idari özerkliğe sahip olması gerekiyor ki temel hak ve özgürlüklerin korunmasında asgari de olsa bir işleve sahip olabilsin. Ulusal düzeydeki temel hak ve özgürlüklerin ulusal düzeyde korunmasının ikinci bir yolu yargısal koruma. Kuşkusuz devlet kuruluşlarından gelecek hak ve özgürlük ihlallerinde en geçerli, en etkili koruma yargıdan gelecek korumadır. Bu yargısal korumanın anayasal dayanağı, anayasanın 36.maddesi olan hak arama hürriyetidir. Yargısal korumanın en temel unsuru hukuk devletidir.

Bunun da en temel unsuru ; devletin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlı olması, aynı zamanda da yargılamayı yapacak yargı organının, bağımsız bir yargı organının gereklerini yerine getirmesidir. Yargısal koruma dediğimizde 2010 anayasa değişiklikleriyle bizim hukuk sistemimize giren mekanizma da bireysel başvuru adı altında anayasanın 148/3 fıkrasında düzenlenmiş olan anayasa şikayeti kurumudur. Kişilerin somut olarak belirli bir temel hak ve özgürlüğün ihlali iddiasıyla doğrudan AYM'ye başvurma olanağını tanıması nedeniyle önemli.

Ulusal üstü kurumlar aracılığı ile temel hak ve özgürlüklerin korunması mümkün olabilir. 2.Dünya Savaşından sonra artık temel hak ve özgürlükler, devletlerin kendi egemenlik meselesi olmaktan çıktı. Artık temel hak ve özgürlükler ulusal üstü bir mesele. Bunun içinde ulusal koruma mekanizmalarının dışında ulus üstü koruma mekanizmalarının da oluşması sonucunu doğurdu. Bu bağlamda hem BM düzeyinde hem de bölgesel ölçekte

insan hakları ile ilgili uluslararası belgelerin yapıldığını görüyoruz. BM nezdinde yapılan belgeler; bunların tümü ve 1985 tarihli CEDAW denen kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine de Türkiye taraf. Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden birisidir. Konsey bünyesinde üretilen çok sayıda insan haklarına ilişkin sözleşmenin de tarafı. Bunlar; AİH Sözleşmesine 1954 yılında taraf oldu ülkemiz, 1961 yılında Avrupa Sosyal şartına taraf oldu. Hem BM düzeyinde hem de bölgesel ölçekte kabul edilmiş bir takım insan haklarına ilişkin sözleşmeler aynı zamanda yarı yargısal ya da yargısal bir takım koruma mekanizmaları da oluşturdular. Örneğin BM bünyesinde 1966 yılında yapılan BM Siyasal Haklar Sözleşmesi İnsan Hakları Komitesini kurdu. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar sözleşmesi aynı adla komite kuruldu. Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme aynı adla bir komite kurdu. Çocuk hakları sözleşmesi yine çocuk hakları komitesini kurdu. Türkiye'nin geçen yıl vazgeçtiği İstanbul Sözleşmesi de yine buna ilişkin bir komite kurdu. Bu komite tam yargısal nitelik taşımayan yarı yargısal niteliktedir. Çünkü buralara da bireysel olarak başvurmak mümkün, devletler ve ülkemiz de buralara bireysel başvuru yolunu tanıyorlar. Buna karşılık bireysel başvurular sonucunda bu komitelerin bu komitelerin hazırladığı raporlar, devletler bakımından bağlayıcı nitelik taşıyor. Devletlerin bu raporlara kararlara uymamasının bir sonucu yok. Ama AİHM kararı bakımından, o karara devletlerin ısrarla uymamasının yaptırımı olduğunu biliyoruz. Yarı yargısal koruma mekanizması denilince gerçek anlamda yargısal koruma mekanizması kuran sözleşmeler, AİH Sözleşmesi, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika İnsan ve Toplum Hakları Sözleşmesi sayılabilir. Uluslararası ceza divanı bakımından Cenevre sözleşmeleri sayılabilir. AİH Sözleşmesi, AİHM'ni yargısal koruma olarak düzenliyor. Aynı şey diğer 3 mahkeme için de geçerli. Bunlar içinde en iyi işleyen, en etkili ulusal üstü yargısal koruma mekanizması AİH Sözleşmesi ve bu sözleşmenin kurduğu AİHM'dir. İkinci sırada ise Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunun kurduğu mahkemedir. Mahkemeler, kararlara uymayan taraf devletlere yaptırım öngörmek bakımından etkili ve aynı zamanda AİH Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından da taraf devletlerin iç hukukunda yer alıyor. Hem anayasamızın 90.maddesinin 5.fıkrası Türkiye'nin taraf olduğu bütün insan hakları sözleşmeleri bakımından anayasa altı bir güvence veriyor bu sözleşmelere hem de anayasanın 148/3 bakımından bireysel başvuru yolu sadece anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin idare tarafından ihlal edilmesi bakımından değil aynı zamanda söz konusu ihlalin AİH Sözleşmesinde yer alan bir hak ve özgürlüğü de ihlal etmiş olması gereğine dayandığı için. Böyle olunca bu sözleşmeyi yorumlama tekeline sahip olan AİHM'nin kararları, içtihatları da bizim hukuk düzenimizin ayrılmaz bir parçası, hukuk düzeni içerisinde hem yargı organı hem yasama organı bu içtihatlara uygun davranmakla anayasal bir yükümlülüktür.

Laiklik: Laicus, din adamları sınıfına ait olmayan demektir. **Seküler :** Dinden bağımsız; dini ya da ruhani olmayan; dünyacılık yanlısı. **Sekülerizm:** Toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden çok dünyevi yaşama odaklanılması yönündeki siyasal düşünce. **Laiklik:** dinsel kişi ve kurumların devletin işleyişine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi; devletin de din işlerine karışmaması anlamına gelir.

Tüm dinsel ve felsefi inançlara eşit mesafede duran, bunlardan hiçbirine öncelik ya da ayrıcalık tanımayan devlete **laik devlet** denir. Bir devletin laik olabilmesi için bütün inançlara aynı mesafede durabilmesi gerekiyor. Bunlardan hiçbirine kamusal alanda öncelik ya da ayrıcalık tanınamaması gerekir. Laiklik günümüzde demokratik bir devletin ayrılmaz bir parçası. Bugün demokratik olup laik olmayan bir devlet yok. Bunun tersi olabilir. Bir devlet laik olabilir ama demokratik olmayabilir. Buna karşılık bir devlet laik ise demokratik olmak zorundadır. Laiklik demokratik düzenin temel, ayrılmaz bir parçasıdır. Demokratik devletin en temel özelliklerinden birisi eşitlik ilkesi idi. Hukuk devletinin en temel özelliklerinden birisi de eşitlik ilkesidir. Eşitlik ilkesi hem demokrasinin hem de hukuk devletinin olmazsa olmaz bir unsuru ise laiklikte bütün inançlara eşit mesafede olmayı gerektiriyor ise hukuk devletine dayalı demokratik bir devletin de laik bir devlet olması şarttır. Bizde 1928'den buyana devlet laik bir devlettir. 1928 Yılına kadar bütün anayasalarımızda devletin dayandığı bir dini vardı. Devletin dini islam dinidir hükmü 1928 yılında anayasadan kaldırıldı ve bununla birlikte, devlet anayasal düzlemde laik bir devlet haline geldi. 1937 Yılında laiklik ilkesi anayasaya bir ilke olarak eklendi. 1937 Yılından buyana bütün anayasalarımızda da Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan bir ilke olmuştur. Haliyle anayasal kimliğimizin bir parçasıdır. Aynı zamanda bu ilkenin kaldırılması da bizzat anayasa ile yasaklandığı için bizim anayasal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Laik bir devletin temel özellikleri: tıpkı demokratik tıpkı hukuk devleti gibi her düzende her devlet demokrasiyi ya da hukuk devletini farklı anlayabiliyorsa bazı farklılıklar devletten devlete olabiliyorsa laik devlet bakımından da aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yine nasıl ki demokratik devlet hukuk devleti

dediğimizde bu ilkelerin asgari bir takım özellikleri var. Bu özelliklerin bulunmaması durumunda biz o devlete demokratik veya hukuk devleti diyemiyorsak aynı durum laik devlet bakımından da geçerlidir. Laik devletin 2 temel özelliği vardır. Bu 2 temel özellik laik devleti aynı zamanda demokrasi ile de kendisini sıkı sıkıya bağlıyor. **1. Din ve vicdan özgürlüğü.** Laik devlet, din ve vicdan özgürlüğüne dayalı bir devlet olmak zorundadır. O yüzden sadece kanun önünde eşitlik ilkesi değil din ve vicdan özgürlüğünün tam bir güvenceye alınması da, her iki unsur da demokratik devletin en temel özelliği olduğu gibi laik devletin de en temel özelliği. O yüzden demokratik bir düzen laiklik olmadan kurulamaz.

İkinci olarak laikliğin 2. Temel özelliği, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Kuşkusuz ki dini kurumların devlet içinde yer almaması birinci gerektir. İkinci gerek yasaların ya da temel kuralların dinin gerekleri göz önünde bulundurularak değil akli, toplumsal gereksinimler göz önünde bulundurularak yapılmasıdır.

Üçüncüsü, devletin bir dininin olmamasıdır. Dördüncüsü, eşitlik ilkesidir. Devletin bütün inanç sahiplerine eşit mesafede durmasıdır. Aynı şekilde davranmasıdır. Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi yine laik devletin temel öğeleri arasında yer alır. Laik yönetimine akıl egemendir. Yasalar, toplumsal ihtiyaçlar ve rasyonalite göz önünde bulundurularak yapılır. Toplumsal ihtiyaç, rasyonalite akıl neyi gerektiriyorsa kurallar ona göre konur. Dinin gerekleri göz önünde bulundurularak konmaz. Siyasal alanın dini bir inanca dayanmaması da devletin resmi bir dininin olmamasını beraberinde getirir. Bir toplumda laikliğin nasıl olduğu aslında tarihsel arka planı ve toplumsal yapısıyla yakından ilişkilidir. O nedenle ABD'deki laiklik ilke Fransa'daki laiklik aynı şeyi ifade etmez. Din adamları sınıfı ve kilise kralın, eski düzenin yanında olmuştur. Din adamları sınıfının cumhuriyet rejiminin tam karşısında olmasından kaynaklanır. Fransa'daki laikliğin tarihsel temeli budur. ABD, böyle bir karşıtlık ortaya çıkmadığı için laiklik farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Birbirinden ayıran özellikler: 1. Dışlayıcı ya da pozitif laiklik : Dini kamusal alandan bütünüyle çıkarmak ve onu özel alanla sınırlamak için devletin “dışlayıcı” bir tutum izlemesi gerektiğini savunan anlayış. Bu şekilde devleti, bütün inançlara karşı eşit mesafede tutmayı amaçlıyor. Fransa en önemli örnek. İnanç, pozitif laiklik anlayışına göre tamamen kişisel bir meseledir. Din ve vicdan özgürlüğü ile sınırlıdır. Bunun tam bir şekilde sağlanması ile inanç sahiplerine yeterli bir alan sağlanmış olur der pozitif laiklik anlayışı.

2. Pasif ya da negatif laiklik: devletin, dinin kamusal görünürlüğüne göz yumarak daha “pasif” bir pozisyon almasını savunan anlayış. Bu nedenle pasif ya da negatif laiklik tanımı kullanılır. Amerika, Hollanda, İspanya bunlara örnek verilebilir. Burada dinsel simgelerin kamusal alanda görülmesine izin verilir. Buna karşılık laikliğin bütün temel özellikleri hem pozitif hem de negatif laiklikte yer alır. Yalnızca bu laikliğin kamusal alanda inançların simgelerinin görünür olup olmaması gereğiyle ilgili bir ayrımdır. 1982 Anayasası laiklik ilkesiyle ilgili şu düzenlemeleri getirmiştir; 1. Cumhuriyet ilkesi laiklikle ilişkili bir düzenleme. 2.Madde de Cumhuriyetin nitelikleri arasında zaten açık bir şekilde yer almaktadır. Anayasanın 1. ve 2. Maddelerinin değiştirilmesini yasaklayan 4.madde de kuşkusuz ki dolaylı olarak laiklik ilgili bir düzenlemedir. Anayasanın 6.maddesi yani egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğunu düzenleyen madde de yine laiklik ilkesiyle ilgili. Yani egemenliğin kaynağını ulusta görüyor. İlahi bir kaynak olarak görmüyor. Anayasanın 10.maddenin 1.fıkrası kanun önünde eşitlik ilkesi, kuşkusuz ki laikliğin ayrılmaz bir parçası. Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24.madde. Siyasal partilerin faaliyetleri, çalışmalarının laiklik ilkesi çerçevesinde olması gerektiğini söyleyen ve buna uymayanlara çeşitli yaptırımlar getiren düzenlemeler laiklik ilkesi içinde. Anayasanın 13.maddesi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında laik cumhuriyetin gerekleri bir sınırlama ölçütü olarak düzenleniyor. Açıkça laiklik ilkesiyle bağlantılı. İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetleri Anayasanın 14.maddesi çerçevesinde görüyor. 15.Maddenin 2.fıkrası olağanüstü hallerde bile dokunulması yasaklanan çekirdek bir hak ve özgürlük alanı olarak düzenliyor. Burada kimsenin din, vicdan, kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı ve bundan dolayı da suçlanamayacağı belirtiliyor. Anayasanın 136.maddesi Diyanet İşleri Başkanlığını düzenleyen madde. Burada Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik ilkesi çerçevesinde faaliyette bulunacağını belirtiyor. Laiklik ilkesi anayasanın pek çok maddesine ulaşmış bir ilkedir. Anayasal düzenin ayrılmaz bir ilkesi olarak düzenlenmiştir. Laiklik ilkesinin temel özellikleri anayasada nasıl düzenlenmiştir. Laiklik ilkesinin en temel unsurlarından birisi; din, vicdan ve ibadet özgürlüğüdür. Bunun tam olarak sağlanması hem demokratik bir devletin hem de laik bir devletin gereğidir. Anayasanın 24/1. ve 3. Fıkraları din ve vicdan özgürlüğünü düzenler. 2.Fıkrası ise ibadet özgürlüğünü düzenler. Din ve vicdan özgürlüğü mutlak bir şekilde sağlanmıştır, herhangi bir sınırlama sebebi öngörülmemiştir. Çünkü, din ve vicdan özgürlüğünün norm alanı onun özüyle aynıdır. Din ve vicdan

özgürlüğünü sınırladığınız anda Yönü var. Olumlu boyutu; din ve vicdan özgürlüğünün, belli bir dine ya da inanca sahip kişilerin kendi inançlarını başkalarıyla paylaşmak, başkalarına açıklama ve anlatma özgürlüğü. Bu din ve inanç özgürlüğünün olumlu boyutunu oluşturuyor. Olumsuz boyutu ise, inanç sahiplerinin isterlerse buna ilişkin herhangi bir açıklama yapmak zorunda olmamalarıdır. İnançlarını, başkalarıyla paylaşma zorunda olmamalarıdır. İsterlerse buna ilişkin hiçbir şekilde konuşmak durumunda olmamalıdır. Bu negatif yönüdür, 24/3 maddesinde belirtilir. İnanç özgürlüğünün negatif boyutu 24/3 de güvence altına alınır. Kimsenin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ve bundan dolayı da kınanamayacağı da din ve inanç özgürlüğünün negatif boyutunu oluşturur. Pozitif boyutu ise; Kişilerin inançlarını isterlerse herkesle paylaşabilmesi, anlatabilmesidir. Haliyle misyonerlik faaliyeti dediğimiz faaliyetler inanç özgürlüğü kapsamı içinde yer alır. İnanç özgürlüğü bir dine inanmayı değil aynı zamanda hiç inanç sahibi olmamayı bir dine, bir dinin belli bir mezhebini dilediği gibi yorumlamayı da beraberinde getirir. İnanç ve vicdan özgürlüğünün korunması bakımından mutlak bir özgürlük alanı vardır. AİHM kararları da bunu sıklıkla dile getiriyor.

1993 Tarihli AİHM'nin kokinakis kararında; bir inancın dinsel bir inanç olarak kabul edilip edilmemesine ya da bir inancın meşru olarak değerlendirilip değerlendirilmemesine devletin karar veremeyeceğini belirtir. Din ve vicdan özgürlüğü bakımından biz de en çok tartışılan konulardan biri, vicdani retçilerdir. Vicdani ret dediğimizde, kişinin dinsel inancı ya da felsefi görüşü nedeniyle silah tutmayı reddetmesidir. Bazı inançlarda silah açık bir şekilde yasaklanmıştır. AİHM önüne bu konuda giden çok sayıda karar var. İlk karar 2006 tarihli Ülke Türkiye kararı. Felsefi bakımdan bu askerlik hizmetine karşı çıkıyor. Mahkeme başvuruların tümünde Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye'nin, vicdani retçi olan başvurularda alternatif bir olanak sunması gerekiyor. Din ve vicdan özgürlüğü bakımından, 24.madde vicdani ret hakkını yasaklayan bir düzenleme içermiyor. 24/1 Fıkrası, vicdani retçileri de içine alan bir güvence sağlıyor. Vatan hizmetine ilişkin düzenleme olan anayasanın 72.maddesinin de vicdani retçilerin durumuna uygun bir şekilde vatan hizmetini düzenlemeyi yasaklayan bir hüküm içermiyor. Avrupa Konseyine üye ülkeler içinde Türkiye ve Azerbaycan dışında vicdani reddi tanımayan bir ülke kalmamıştır. Vicdani reddi, bir kısım ülke anayasal bir güvenceye kavuşturdu. Bir kısım kanuni düzenlemelerle vicdani reddi tanıdı. Burada yapılması gereken, vicdani reddi olan ya da inancı gereği ile silah altına girmek istemeyen kişilere alternatif bir kamu hizmeti sunmaktır. Bunu bir kanun ile düzenlemek mümkündür. Din ve vicdan özgürlüğünün bir başka boyutu, ibadet özgürlüğüdür. Bu bütün inanç sahipleri bakımından geçerli olan bir şeydir. İnancın tam olarak yerine getirilmesi o inancın pratiklerinin yapılmasıyla mümkün. 24/2 Fıkra da belirtildiği üzere bunun da negatif ve pozitif yönü vardır. Bunun pozitif yönü kişilerin tabi oldukları inancın gereklerini yerine getirebilmelerini sağlamak, **bu pozitif yönü.**

Negatif yönü ise, istemeyenin ise bu inancın gereklerini yerine getirmeye zorlanmaması. Haliyle anayasanın her ikisini de açık bir şekilde düzenlediğini görüyoruz. Ama inanç özgürlüğünden yani 1.fıkradan farklı olarak 2.fıkranın ibadete ilişkin olarak bir sınırlama nedeni getirdiğini görüyoruz. O da 14.maddenin hükümlerine aykırı olmamak. 14.Madde genel bir sınırlama sebebi olmamalıdır. Böyle bir sınırlama sebebi olarak kullanılmamalıdır. Bunun uygun bir sınırlama sebebi olmadığını belirtiyoruz. Burada başka ne getirilebilir?

Başkalarının hak ve özgürlükleri sağlık, kamu düzeni gibi birtakım sınırlama nedenleri getirilebilir, ibadet özgürlüğünün niteliğine uygun sınırlama nedenleri. Nitekim sağlık, bir sınırlama nedeni olarak 24.maddenin 2.fıkrasındadüzenlenmediği için örneğin Covid salgını döneminde ibadethanelerin kapatılması anayasaya aykırıydı. Yine 14.madde bağlamında yalnızca laik cumhuriyeti düzenlemiyor, aynı zamanda devletin ülkesi, milletiyle bölünmez bütünlüğü gibi başka unsurlarda içeriyor. Haliyle bu unsurların tümünün ibadet özgürlüğü ile ilişkili olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu 14.maddedeki düzenlemenin 24.madde ile bağlantılı olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekir. İkincisi yine inanç özgürlüğü ile yakından ilgili olan mesele din eğitimi. Çünkü inanç özgürlüğü aynı zamanda kişinin kendi inancını, çocuğuna aktarabilmesi ve kendi inancını başkalarına anlatabilmesi, açıklayabilmesini ve öğretebilmesini de gerektiriyor. Aynı zamanda laik devlet, belli bir dinin öğretimini üstlenmemeli. Ya bütün dinlerin eğitimi üstlenmeli, isteyen inanca ilişkin dersi alabilmeli veya devlet bu konuda tamamen tarafsız olmalıdır. Bizde sorun anayasanın 24.maddeden kaynaklanan sorun. Anayasanın 24/4 fıkrası ne diyor; din kültürü ve ahlak öğretimi dersinin ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu ders olarak okutulacağını belirtiyor. 1961 Anayasası böyle bir düzenleme içermiyordu. Orta öğretim kurumlarında okutulacak din dersine ilişkin şöyle bir ifade yer alıyordu “Böyle bir din dersi almak isteyen kişi ya da küçükse o kişinin velisi, vasisi okula başvurmak yoluyla din dersini almasını sağlayacaktı. Yani bu isteğe bağlı bir dersti. Üstelikte bu dersi almak isteyen okullara başvurması öngörülmüyordu. Çünkü, istemeyenin ben bu dersi almak istemiyorum diye bir dilekçeyle başvurması aslında

inanç özgürlüğünün negatif boyutuna aykırılık oluşturacağı için. Yani kendisi istemeden kendi inancını, dinini açıklamak zorunda kalacağı için bu dersi almak isteyenlere başvuru yükümlüğü getirilmişti. 1982 Anayasası tamamen bu anlayışı ortadan kaldırdı ve din kültürü ve ahlak öğretimi dersini ilk ve orta öğretim okullarında zorunlu tuttu. Başlı başına böyle bir dersin zorunlu tutulması laiklik ilkesine aykırı olmayabilir. AİHM Sözleşmesine de aykırı olmayabilir. Fakat Türkiye’deki mesele bu dersin içeriğine ve uygulanmasına ilişkin bir konu. Yani bu ders bütün inançlara ilişkin genel bir kültür dersi niteliğinde olsa, nesnel, eleştirel bir nitelik taşısa o zaman bu dersin zorunlu bir ders olması laiklik ilkesine aykırı olmaz. Ya da bu ders zorunlu bir ders olmayıp, isteyen aldığını istemeyenin almayacağı bir ders olsa ama inancı belli bir inancı, belli bir mezhebi öğreten ders olsa bu da yine laiklik ilkesine aykırılık oluşturabilecek. Mesele içerikle o dersin zorunlu olması arasındaki uyumsuzluk.

18 Nisan 2023

Laiklik ilkesi anayasanın 2.maddesinde yer alan bir ilke. 24. Maddenin ilk 3 fıkrasında din ve vicdan özgürlüğü yer alıyor. 1. ve 3. fıkralar inanç özgürlüğünü, 2. Fıkra ise ibadet özgürlüğünü düzenliyor. İnanç özgürlüğü, sınırlama sebebi gözetilmeyen niteliği gereği de aslında sınırlanamayacak olan bir özgürlüğe karşılık geliyor. İnanç özgürlüğünün olumlu yönü, bu özgürlüğün kişinin dinini, inancını, açığa vurma herkesle paylaşma, açıklama, öğretme ve belli bir inancı öğrenme özgürlüğünü içerir. Bu olumlu boyutunun içine kişinin inancının gereklerini yerine getirme yani ibadet özgürlüğünü de katmamız mümkün. Din ve vicdan özgürlüğünün olumsuz boyutu ise, kişinin kendi inancını isteği dışında açıklama zorunda bırakmaması ve ibadet özgürlüğü kapsamında dilerse inancının gereğini yerine getirmesi, dilerse bu ritüelleri yerine getirmemektir. Bu bakımdan da belli bir ibadeti yapmaya zorlanamaması, belli bir inancını açıklamaya, bunun gereklerini yerine getirmeye zorlanamaması anlamına geliyor. 24. Madde, inanç özgürlüğünün hem negatif hem de pozitif boyutunu güvence altına almakta. Buna karşılık, uygulamada din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 24.maddeye aykırı olarak ülkemizde belli olumsuz yönlerin olduğundan da söz ettik. Bunlardan birisi vicdani red meselesi idi. 72. Ve 24. Maddeyi birlikte ele aldığımızda bu konu anayasamıza aykırı bir durum yaratmayacak.

Vicdani red, inanç özgürlüğünün bir parçası olarak tanınabilir. İnanç ve ibadet özgürlüğünün geçmişten günümüze kadar çoğunluk olmayan mezhep ve inançlara karşı sistematik bir biçimde ihlal edildiğini görüyoruz. Bu sistematik ihlallerde AİHM’nin önüne gidiyor. 2016 Tarihli AİHM’nin bir kararı. Bu davanın gerekçesi şu; 1988’den beri devlet bu Yehova şahitlerine bir ibadethane göstermiş. 2000 Yılında bu ibadethaneyi kapamış. Ondan sonra da başka bir ibadet yeri de göstermemiş. Bu inancın sahipleri Türkiye’de ibadet edebilecekleri bir yer bulamıyorlar. Bütün idari, yargısal süreçleri tamamlıyorlar. Bu sorunu çözemiyorlar. AİHM bu kararda Türkiye’yi, sözleşmenin 9.maddesine aykırı davrandığı sonucuna varıyor. 9. Madde, inanç ve düşünce özgürlüğünü düzenleyen madde. Bu kararında, dini bir topluluğun ibadetini gerçekleştirmek için, bir yere sahip olmaması durumunda dinini açıklama durumunun tamamen elinde alınması durumunu ortaya çıkarıyor. Bu da inanç özgürlüğüne aykırılık oluşturuyor. Anayasanın 24. Maddesine de aykırı bir durum. Hem 2.maddesi açık bir şekilde ibadet özgürlüğünü düzenlediği için. Bu yalnızca İslam dışında kalan dinlere yönelik olumsuz bir uygulama değil. Aynı zamanda Alevi inancı bakımından da, ibadet özgürlüğüne yönelik sistematik olarak anayasaya aykırı uygulamalar dizisi olduğunu söyleyelim. Tabi ki bu da AİHM’nin çok sayıda kararına konu oldu. Örnek; 2014 tarihli Yenibosna Cem Evi Türkiye kararı. 2016 Tarihli İzzettin Doğan ve diğerleri Türkiye kararı, 2015 tarihli Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Türkiye kararı ve son olarak 2019 tarihli Cem Vakfı Türkiye kararı. Bu konuların tümü benzer taleplere yönelik ve tümünde de Türkiye’nin sözleşmenin 9.maddesini ihlal ettiği sonucuna vardı AİHM. Bunun nedeni, Diyanet İşleri Başkanlığının, Aleviliği İslam dini içinde bir kol olarak görmesi. Haliyle Alevilerin, devletin diğer inançlara sağladığı kamusal hizmetleri sağlamaması. Örneğin, ibadethanelerin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması. Örneğin İzzettin Doğan ve diğerlerinin başvurusunda başvuru bu şekilde oluyorlar. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gelirinin herkesin verdiği vergilerle toplanan paralarla elde edilen bir gelir. Buna karşılık Diyanet’in içinde Aleviler temsil edilmiyorlar. Üstelik Cem evleri bir ibadethane olarak kabul edilmiyor. Aynı bir inanç olarak kabul edilmediği için Aleviler, vakıf ya da dernek çatısı altında örgütleniyorlar. Böyle bir örgütlenme biçimin yarattığı başka sakıncalar ortaya çıkıyor. Örneğin bağış toplamakta sorun yaşıyorlar. Diğer inanç gruplarının sahip oldukları hukuki güvencelere sahip değiller. Bu nedenle din ve vicdan özgürlüğü ile ibadet özgürlüklerini tam olarak

yaşayamıyorlar. AİHM, bu başvurularını haklı buluyor. Alevi toplumunun din ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğu sonucuna varıyor.

Türkiye, AİHM kararlarında bu konu hakkında çok sayıda ihlal kararıyla karşılaşmasına rağmen, bu konuda henüz hiçbirini yerine getirmedir. Laik devlet, tarafsız devlettir. Tarafsız devlet, kendi egemenliği altında yaşayan kişilerin ya da grupların dini inanç aidiyetlerini incelemek, bilmek durumunda değildir. Bir inanç grubunun gerçekten bir din olup olmadığını saptama yetkisi de devlete veya devletin kurumların verilmesi gereken bir yetki değildir. Yine Yunanistan'ın, Müslüman azınlığa yaptığı ayrımcı uygulamaları var. Bunların da 9.maddeyi ihlal ettikleri yönünde kararlar aldı. Geçmişte halledilmeyen inanç özgürlüğünün olumsuz ve olumlu yönleriyle ilgili olarak. TC vatandaşlarının sahip oldukları kimliklerde yer alan dini inanç bölümü. Birkaç yıl öncesine kadar TC kimliklerinde bir din hanesi bulunuyordu. Bu başlangıçta doldurulması zorunlu bir haneydi. 2006 Yılında yapılan değişiklikle, bu hanenin dolu olabileceği ya da dilerse boş bırakılabileceği yönünde bir düzenleme getirdi. Bu haliyle ve eski haliyle anayasanın 24.maddesine aykırı bir düzenleme. Hem 24/3 hem de anayasanın 2.maddesine aykırı. 2.Maddesine aykırı olmasının nedeni, laik bir devlette kişilerin inançlarının dine ya da bu inançlarını ortaya çıkarma gibi bir zorunluluğunun olmaması. 24/3 fıkrasına aykırılığı ise kişilerin kendi istekleri dışında inançlarını açığa çıkarmak zorunda bırakılmaları. O hanenin boş bırakılması da ilgili kişinin kendi inancını açığa çıkarması anlamına gelecektir. Böyle bir durumda da anayasanın 24/3 fıkrasına aykırı bir durum oluşturacaktır. Bu iş AYM'nin önüne gitti. AYM, 1995/16 Karar sayısı olup karar tarihi 21.06.1995. AYM, bunu anayasaya aykırı bulmadı. Eşitlik ilkesine de aykırı bulmadı. Dedi ki burada yasa önünde eşitlik ilkesine uygun bir durum söz konusu. Çünkü ayrımcılığa maruz kalma bakımından burada herkes aynı riskin altında. Ayrımcılığa maruz kalma durumu, azınlığa sahip kişiler bakımından ortaya çıkan bir tehdit ve tehlike. Ayrıca dedi ki nüfusa kaydolurken kişinin anayasanın öngördüğü anlamda dini inanç ve kanaatlerini değil sadece kişinin özgün durumu yönünden kamu yararı, kamu düzeni ve sosyal gereksinimlerle ilgili olarak göz önünde bulundurulmak üzere o kişinin dinin ne olduğunun açıklanması söz konusu olmakta. Bu kural zorlayıcı niteliği ve bağlayıcılığı söz konusu değildir. Bunun üzerine AİHM'ne bu konu ile ilgili başvurular yapıldı. En önemlisi Sinan Işık Türkiye başvurusu. 2007 Tarihli bu başvurunun en önemli özelliği şudur; kimlik kartında başvuru İslam yerine Alevi yazılmasını istiyor. Nüfus idaresi bu başvuruyu reddediyor. Nüfus idaresinin bu kararını İdare Mahkemesine götürüyor. Mahkeme, bunu reddediyor. AİHM, burada Türkiye'nin din ve vicdan özgürlüğüne aykırı davrandığı sonucuna varıyor. Burada devlet, bir kişinin sahip olduğunu söylediği inancın gerçek bir inanç olup olmadığı konusunda karar vermek konumunda değil. Çünkü devlet laik bir devlet. Üstelik AİHM diyor ki, Alevilik binlerce yıldır Anadolu topraklarında var olan bir inanç. Haliyle yeni ve uydurma bir inanç da değil. Kişi bu şekilde kendisini ifade etmek istiyor. Devlet makamları, bu inancın İslam'ın bir kolu olduğu ve ayrı bir din olarak da nüfus hanesine de yazılamayacağını söyleme ve böyle bir karar alma yetkisi de yok. Burada kişinin inanç özgürlüğüne aykırılık söz konusudur diyor. Sinan Işık kararı, AİHM'nin verdiği ilk karardır. Bu konuya ilişkin olarak Türkiye'den giden başka kararların olduğunu da söyleyelim.

Bu kararın sonucunda bunun gereğini yerine getirmek amacıyla şuandaki kimliklerde kişinin dini inancına ilişkin bir bilgi yer almıyor. Buna karşılık nüfus işleri kanununa baktığımız zaman burada kimlikte yer alan cıp içinde başka bilgilerde yer almaktadır. Bu bilgiler arasında kişinin inancına ait bilgilerde yer alıyor. Nüfus işleri kanununa baktığımız zaman kanun diyor ki *"kanunda görülen hallerde yetkili makamlar bu cıpte yer alan bilgileri kişilerin açık rızası olmadan işleme yetkisine sahip"* Buradaki anayasaya aykırılık sorunu; 1. Bu bilgiye erişim yetkisine sahip olan kişi ve kurumlar, belirsiz. Haliyle idarenin bunu takdirenen genişletmesi, herkesin erişebileceği ya da erişebilecek kişi ve kurumların sayısını artırması her zaman mümkün. 2. Bu bilginin hangi durumlarda kişinin rızası dışında kullanılacağı da belirsiz. Bu düzenlemenin kişiler bakımından ayrımcı uygulamalara yol açacak biçimde kötüye kullanılması her zaman mümkündür. Sonuç: Kişinin inancına ilişkin bilgilerin kendi isteği dışında açığa vurulması bakımından anayasaya aykırılık oluşturan kimliklerde din hanesinin yer almasına ilişkin olarak düzenlemenin tam olarak bu anayasaya aykırılığı ortadan kaldıracak biçimde düzenlenmediğinin altını çizelim. Uygulamada buna ilişkin başka olumsuz düzenlemelerin de olduğunu görüyoruz. AYM'nin önüne giden bireysel başvuru örnekleri vardır. 2017 Tarihli Suat Özcan başvurusu. Başvurucu devlet okulunda çalışan bir öğretmen. Hakkında disiplin soruşturması açılıyor. Disiplin soruşturması sırasında başvurucuya mezhebi soruluyor. Başvurucu, böyle bir durumun disiplin soruşturması içinde yer almasını anayasanın 2. Ve 24.maddelerine aykırı olduğunu ileri sürüyor. İdare ve idare yargı bunu göz önünde bulundurmuyor ve başvurunun aleyhine karar veriyor. AYM'ye başvurmak durumunda kalıyor

başvurucu. Ama AYM, başvuruçunun burada mağdur sıfatını taşımadığını belirtiyor. Üstelik söz konusu olayı da anayasanın ilgili maddesi bakımından incelemek yerine özel hayatın gizliliği düzenlemesi kapsamında ele alıyor.

24.Madde içinde göz önünde bulundurulması gereken mesele din eğitimi meselesidir. Kişilerin kendi çocuklarına kendi inançlarını ve felsefi, dini inançlarını öğretme hakkı din ve vicdan özgürlüğünün içinde yer alan bir hak. Aynı zamanda AİHM sözleşmesinin 1 no'lu ek protokolünün 2.maddesinde güvence altına alınmış bir hak. Bu madde “Ebeveynlerin çocuklarını kendi inanç ve felsefi görüşleri doğrultusunda yetiştirme hakkı olduğunu belirtiyor. Bunula ilgili olarak anayasanın 24/4 fıkrasında “din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu ilk defa anayasalara eklenmiş olan bir düzenleme. Ne 1924 anayasasında ne de 1961 anayasasında yer almadığını görüyoruz. 1961 Anayasası din dersini ebeveynlerin talebi üzerine öğrenci tarafından alınabileceğine dair bir düzenleme içeriyordu. Bu inanç özgürlüğüne uygun bir düzenleme idi. Çünkü her zaman kişiler diledikleri takdirde inançlarını açığa çıkarma bunu başkalarıyla paylaşma özgürlüğüne sahiptirler. Dilemedikleri takdirde de başkalarıyla paylaşmama özgürlüğüne de sahiptirler. Çocuğun eğitim almasını istemeyen birinden böyle bir dilekçe istemek din ve vicdan özgürlüğünün olumsuz boyutunu zedeleyecek bir uygulama olacaktır. 1982 Anayasasının 24.maddesi din ve ahlak eğitim ve öğretiminin hem devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağını belirtiyor. Bu 1961 yılında da var olan bir düzenlemeydi. Hem de din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve orta öğretim okullarında zorunlu bir ders olarak okutulacağını belirtiyor. 82 Anayasasının yürürlüğe girdiğinden beri bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Buna ilişkin olarak AİHM’ne giden çok sayıda başvuru var. Türkiye bu başvurularda hep haksız bulundu. Bu uygulamanın, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğu sonucu çıktı. Buna ilişkin AYM’nin de aslında din ve vicdan özgürlüğü odaklı bir yaklaşım olmadığını belirtelim. Bu konuyla ilgili çok çarpıcı kararı var. Bu karar aynı zamanda mahkemenin laiklik ilkesine yaklaşımını bakımından da önemli. Esas 2012/65, karar 2012/128 AYM karara konu olan olay; bir kanun çıkarılıyor. Bu kanunda 2 dersi ilk ve orta öğretim kurumlarında seçmeli zorunlu ders olarak okutulmasına karar veriliyor. Bu derslerden birinin adı Kuranı Kerim, ikincisinin adı Hz. Muhammed’in hayatı. Bu dersler zorunlu seçmeli ders. Çünkü seçmeli dersler listesinde mutlaka olması gereken ders olarak kanun bunu düzenliyor. Bunun dışında hangi derslerin seçmeli olacağı konusunda ise MEB’liğine takdir yetkisi veriliyor. Bu düzenlemenin anayasanın 2 ve 24.maddelerine aynı zamanda 10.maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğunu iddia ediyor, iptal davası açanlar. AYM, “devlet, dinler karşısında tam olarak tarafsız kalamaz. Toplumun çoğunluğunun dini duygularını gözetmek zorundadır, devlet.” İslam dini eğitiminin eğitimi devletin temel görevidir. 1982 Anayasası çoğunluğun dini olan İslam dininin öğretilmesi konusunda devlete pozitif bir yükümlülük getirmiştir 24.madde. Yine AYM bu kararında “devletin laikleştirme görevi yoktur. Devletin böyle bir görev üstlenmesi baskıcı bir laikliktir. Çoğunluğun dini olan Sünni İslam inancının gereklerini yerine getirmek devletin pozitif yükümlülüğüdür.” AYM’nin benimsediği bu yeni laiklik anlayışını esnek ya da özgürlükçü laiklik olarak tanımlıyor. AYM’nin benimsediği bu anlayış, aslında devlete dini konularda çok takdir yetkisi veren bir anlayış olarak ortaya çıkıyor.

Bunun eleştiriye açık olmasının nedeni: 1. Laik bir devlette, toplumun çoğunluğunun inancı ya da azınlığın inancı diye bir ayrım bulunmaz. Laik bir devlet, bütün inançlara eşit mesafede durmak hainde olduğu için. Devlet, inançlara eşit mesafededir. **2.** AYM’nin ileri sürdüğü gibi 24.maddede devlete, çoğunluğun dinini öğretmek bakımından pozitif bir yükümlülük verildiğine ilişkin bir düzenleme bulmak mümkün değil. En fazla devletin din eğitiminde gözetim ve denetimi olduğuna ilişkin düzenleme olduğu görülebilir. Ama buradan devlete bir pozitif yükümlülük çıkarmak mümkün değil. Bir başka yönü AYM, bu kanun hükmünü anayasaya uygunluğunu yorumlarken hiçbir şekilde anayasanın 24/1 ve 3.fıkralarını göz önünde bulundurmamış.

1. Bunun bir inanç özgürlüğü boyutu var, azınlıkta kalanlar bakımından. Azınlıkta kalmasalar bile her çoğunluk inancına sahip olanlar aynı biçimde o dini yorumlamak zorunda değil. **2.** Olarak inanç özgürlüğünün ifade özgürlüğü boyutu var. Bütün inanç özgürlüğü aynı zamanda ifade özgürlüğü ile de ilgili olduğu için. AYM, bunu da hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyor kararında. Sonuç ne oluyor? AYM, 2012 den önceki kararlarında laiklik ilkesini çoğunluğun inancını azınlık karşısında baskı unsuru olmasını engelleyecek bir araç olarak yorumluyordu. Yani çoğunluğun dinsel baskının, azınlık üzerindeki olası dinsel baskısının sona erdirilmesi bakımından devletin dinsel alana müdahalesini meşru buluyordu. Bu kararlar aynı zamanda militan demokrasi anlayışıyla da yakından ilişki kurduğu AYM’nin kararı. Bu yaklaşımla Sünni İslam inancının, öğretiminin devletin temel yükümlülüğü olduğu anlayışına, devletin dinler arasında aslında tarafsız kalamayacağı yaklaşımına, devletin toplumun çoğunluğunun dini duygularının gözetmek zorunda olduğuna

ilişkin bir yaklaşıma evrildiğini görüyoruz. AYM'nin benimsediği yeni laiklik anlayışının gerçekten evrensel bakımdan bir laiklik anlayışı olduğunu söylememiz mümkün değil. Devlet ancak hem ibadet özgürlüğüne hem inanç özgürlüğüne demokratik toplum düzeninin gerekleri çerçevesinde müdahale etmelidir. Eğer inanç ve onun ritüelleri demokratik değerlere, demokratik toplum düzeninin gereklerine, başkalarının hak ve özgürlüklerini kullanmasına aykırı bir durum oluşturuyorsa o zaman orada devletin müdahalesini görmek meşrudur. Ama bunu dışında kişilerin inançları, o inançların gereklerini yerine getirmelerine ve onun bir sonucu olarak da kendi inancına ilişkin olarak eğitim ve öğretim görmesi bakımından müdahale etme etmedir. Bu olayın bir boyutu, ikinci boyutu 24.maddede açık bir biçimde yazan din ve ahlak dersinin anayasa ile zorunlu bir ders olması ortaöğretim kurumlarında. Böyle bir düzenleme AİHM'nin içtihatlarına göre kendi başına sözleşmeye aykırı düşmeyebilir. Yani devlet din ve ahlak öğretimi dersini belli koşullar altında zorunlu bir ders olarak düzenlemişse böyle bir düzenleme mutlaka din ve vicdan özgürlüğüne aykırılık oluşturmayabilir.

Hangi durumlarda aykırılık oluşturmayabilir? 1. Din ve ahlak eğitimi dersi seçmeli bir ders ise isteyen seçiyorsa burada vicdan özgürlüğüne bir aykırılık olmayacak. 2. Eğer bu ders isteyenler bu dersten muaf tutulabiliyorsa yine burada din ve vicdan özgürlüğüne aykırılık olmayacak. 3. Bu ders herkes için zorunlu olmakla birlikte dünyadaki belli başlı inançlar hakkında nesnel bilgi veren, aynı zamanda eleştirel bir bakış açısına sahip olan bir ders niteliğinde ise o zaman böyle bir dersin zorunlu olması din ve vicdan özgürlüğüne aykırılık oluşturmayacaktır.

Bizdeki sorun bu dersin içeriği ile ilgili bir sorun; 1.Bu dersin zorunlu tutulması 2. Bu dersin yalnızca İslam dininin dışındaki inanç sahiplerinin muaf tutulması 3. Muaf olabilmek için bundan muaf olacak kişilerin bu inanç isteğini açığa çıkarması 4. Bu konuda okul yönetimlerinin mutlak bir takdir yetkisine sahip olması. Yani Hristiyan ve Yahudi inanç sahibi çocuklar dışındaki başka inanç sahibi örneğin Aleviler bakımından dersin zorunlu tutulması. Bu dersten muaf olma durumunun kabul edilmemesi, 5. Ders zorunlu olmakla birlikte dersin içeriğinin az önce belirttiğimiz özellikleri taşıması. Yani belli bir dinin, belli bir mezhebin ritüellerini anlatması AİHM'nin deyişiyle çocukları endoktrine eden yani çocukları belli bir inanca yönelik olarak onu teşvik eden onu zorlayan yani o inancı empoze eden bir nitelik, içerik taşıyor. Bu bakımdan AİHM, örneğin ilk kararı Hasan Eylem Zengin Türkiye 2007 kararında, Türkiye'nin zorunlu din dersine ait bu koşulları taşıması nedeniyle sözleşmenin 9.maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı. 2014 Tarihli Mansur Yalçın ve diğerleri Türkiye'ye kararı aynı konuya ilişkindir. Hem Hasan Eylem Zengin hem Mansur Yalçın ve diğerlerinde başvurucular Alevi inancına sahipler. Zorunlu din dersini çocuklarının almasını istemiyorlar. Hem idare hem de arkasından idari yargı bu taleplerini ret ediyor. AİHM sözleşmenin 9.maddesine az önce söylediğim gerekçelerle sözleşmenin 9.maddesine aykırılık tespit ediyor. AYM, bu konuyla ilgili olarak 2022 yılındaki kararında, Hüseyin El ve Nazlı Şirin El kararı. AYM bu kararında AİHM'nin içtihatlarını takip ediyor. Anayasaya aykırılık tespit ediyor. Başvurucuların zorunlu din dersini almaya mecbur kılınmasını, başvuruculara istisna tanınamasının anayasaya aykırı buluyor. Hem AYM'nin hem son 2022 tarihli kararı hem de 2007 den buyana AİHM'nin konuya ilişkin olarak vermiş olduğu çok sayıda kararın gereğini Türkiye tarafından yerine getirilmediğini belirtelim. Bu da kişinin sahip olduğu inancın çocuklar üzerinde eğitim hakkına ilişkin ülkemizdeki en yakıcı sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hem AİHM'nin hem de AYM'nin bu aykırılığa ilişkin tespitleri var ama bu kararların gereği idare tarafından yerine getirilmiyor. Umarız yakında sözleşmeye ve anayasaya uygun idari düzenlemeler yapılır.

Bir devleti laik yapan başka unsurlarda var. Yalnızca din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması bir devleti laik bir devlet olarak tanımlamak için yeterli değil. İkinci bir unsur, laik bir devlet din kurallarına dayanmak zorunda değildir. Hukuk kurallarının ortaya çıkışında doğrudan ya da dolaylı olarak dinin rolü olabilir. Nitekim de olmaktadır. Önümüzdeki bayramların resmi kaynağı din. Hukuk kuralları din kurallarından da etkilenebilir. Örneğin laik Hristiyan devletlerde Pazar gününün tatil olması bunun bir göstergesi. Yine Noel'in resmi tatil olması buna verebileceğimiz örnekler. Burada laik devlet açısından hukuk kurallarının dinin buyruklarına ya da gereklerine dayanmak zorunda olmaması. Hukuk kuralları akli olmalı. Aynı zamanda toplumun gereksinimleri göz önünde bulundurularak yapılmalı. Bu çerçevede bakınca, şu an itibarıyla hukuk kurallarının dini buyrukların göz önünde bulundurularak yapılmadığını söyleyebiliriz. Anayasanın 2.maddesi uygulamada kendisini gösteriyor. Üçüncü bir özellik, devletin resmi bir dininin olmaması. Bu son derece önemli. Çünkü laik bir devlet bütün inançlara eşit mesafede olan bir devlet. Bir devletin resmi bir dininin de olmaması gerekir. Eğer bir devletin resmi bir dini var ise o zaman o resmi dine öncelik ayrıcalık tanıyan bir devlet demektir. Bu

laiklik ilkesiyle bağdaşmaz. Bizde devletin resmi bir dini yok. 1928 Anayasa değişikliğinden bu yana böyle. Devletin resmi bir dininin olmaması kuralıyla çatışan bağdaşmayan uygulama birinci derste konuşulan konu. Yani ortaöğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersini zorunlu bir ders olarak uygulanması. Burada dersin kendisinden kaynaklanan bir aykırılık yok. Dersin içeriğinden kaynaklanan laiklik ilkesine olduğunu söyleyebilir. Bütün laik devletler bakımından devlet her türlü inanca eşit mesafededir. Bu bakımdan da devletin resmi bir dininin olmaması gerekir, Anayasanın 24/4.maddesi bu gereğe uygulamada zorlayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Laiklik ilkesinin bir başka unsuru devlet kuruluşlarıyla din kuruluşlarının birbirinden ayrılması. Bu şart. Devletin içinde dini nitelikte bir kuruluş var ise bu laiklik anlayışına aykırılık oluşturur. 1961 ve 1982 Anayasası da Diyanet İşleri Başkanlığını (DİB) anayasada düzenlemiş. DİB, günümüzde anayasal bir kurum. 1924 Yılında kuruldu DİB. O zaman din işlerini devlet eliyle gören böylelikle de çeşitli cemaatlerin halkın dini duygularını kötüye kullanmasına engelleme amacı taşıyan bir kurum olarak oluşturuldu. Bu bir yerde devletin dini kontrol etmesi amacını taşıyordu. Özellikle bu kuruma özgün bir dini kurum niteliği kazandırmamak için 1924'den itibaren DİB, devletin genel idare örgütlenmesi içinde yer aldı. Amaç ona özel bir tüzel kişilik, özel bir yer tanınmadı devlet örgütlenmesi içinde. Bugünde aynı şekilde devam ediyor. Devletin genel idare teşkilatı içinde yer alıyor. Anayasanın 136. maddesi DİB hakkında. Bu 136.madde, anayasanın laiklik bakımından en sorunlu düzenlemelerinden birisi. DİB'na yüklenen bu görevden başlayarak ne kadar sorunlu olduğunu görebiliriz. İlk olarak DİB, milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek. Laiklik ilkesinin temeli devletin bütün inançlara eşit mesafede durmasıdır. Laiklik ilkesinin temeli devletin resmi bir dininin olmaması. Böyle olunca dini bir kuruluş aracılığı ile milletçe dayanışma ve bütünleşme nasıl sağlanacak. Eğer devlet toplumdaki bireylerin inancına aynı ölçüde saygılıysa, bütün inançlara eşit mesafede duruyorsa o zaman DİB bu dayanışma ve bütünleşme işini nasıl yerine getirecek. Bu laik bir devlette dinsel bir kuruluşa böyle bir görev yüklemek mümkün değil. Dinsel bir kuruluşun amacı da milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlamak olmamalı. Hele hele inanç ve düşünce farklılığı olan bir toplumda bir kurumun böyle bir işlevi yerine getirmesi mümkün değil. DİB'nın bu kanunda kendisine verilen görevleri laiklik ilkesi doğrultusunda yerine getireceği. Dini bir kuruluş laiklik ilkesi doğrultusunda bunu nasıl yerine getirebilir. Bu tam olarak oksimoron dediğimiz ifadeye verilebilecek bir örnektir. Dini bir kuruluşa laiklik ilkesi doğrultusunda görevlerini yerine getirme ödevi yüklemek. Haliyle 136.maddenin kendisi bunu düzenlemesi başlı başına sorunlu bir düzenleme. Çünkü laik bir devlette, devletin görevi dinsel bir kuruluşa dinsel bir inançta toplumu bütünleştirme görevi vermek değildir. Tam tersine laik bir devletin görevi farklı inançların yan yana birbirine zarar vermeden barış içinde yaşamasını sağlayacak ortamı sağlamak ve sürdürmektir. Herkesin din ve vicdan özgürlüğünü tam olarak yaşamasını, kullanmasını sağlayacak bir ortam sağlamaktır. Bir inancın başka bir inanca tahakküm etmesini, bir inancın başka inanç sahiplerini ötekileştirmesini, ayrımcılığa uğratmasını amaçlamak laik devletin en temel işlevidir. Bunun için laik devlet demokratik devletin ayrılmaz bir parçasıdır.

136.Maddenin tanımı ve DİB'na yüklediği ödevler bizzat kendi içinde çelişkili görevler yüklemektedir. Bunun dışında DİB'nın yapısı, uygulamada toplum ve devlet içinde edindiği yer aynı zamanda bütçesi bakımından laik devletle Anayasanın 2.maddesi ile yakından uzaktan ilişkisi olmayan bir durumdadır. 1. DİB, İslam ile ilgili konularda bir fetva makamı gibi çalışıyor. Öyle ki mahkemelerde önlerine gelen davalarda ilgili bir durum var ise DİB'nın görüşünü alıp o görüş doğrultusunda kararlarını kuruyor. Örneğin Sinan Işık Türkiye kararında, AİHM'nin sözleşmeye Türkiye'nin aykırı davrandığını tespit etmesinin nedenlerinden birisi de buydu. Sinan Işık, nüfus cüzdanında dine ilişkin haneye Alevi yazılmasını istiyor. Reddediliyor, İdare mahkemesine gidiyor. İdare Mahkemesi, DİB'dan görüş istiyor. Görüş şu "Alevilik ayrı bir inanç mı değil mi?" DİB da "Aleviliğin ayrı bir inanç olmadığını, İslam dininin bir kolu olduğunu dolayısıyla kimliklerde ayrı bir inançmış gibi yazılamayacağını, İslam yazılması gerektiğine" dair bir görüş bildiriyor. Mahkeme, bu görüşe dayanarak davacının talebini reddediyor. AİHM, bunu sözleşmeye aykırı buluyor. Diyor ki "burada dini bir kuruluşun görüşüne dayanarak bir mahkeme kararını kuramaz, böyle bir dini kuruluşun görüşüne dayandırarak veremez" diyor. Her konuda DİB, neyin dini olduğuna neyin olmadığına dair görüşlerini bildiriyor. Düzce'de işçiler sendikaya üye olmalarından dolayı işten çıkarılıyor. Düzce Müftülüğü bir hutbe okuyor. Bu hutbede "iş gereğinden fazla yavaşlatmak, iş yerine zarar vermek, karı ve karlılığı azaltıcı davranışlarda bulunmak çalışanı ağır dini sorumluluk altına sokar" diyor. Bunu laiklik ilkesi ile bağdaştırmak mümkün değil. Anayasaya aykırı zaten. Çünkü anayasanın bütün kişilere tanıdığı hak ve olanakları dini kullanmak yoluyla etkisiz kılmak gibi bir işlev görüyor. Anayasanın çalışanlara tanıdığı sendika kurma

hakkını, grev, toplu sözleşme hakkını konu alan, bunları dini kurallarla karşılaştırıp dine aykırı bulan, hatta dini sorumluluk altına sokan bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz.

DİB’liğinin bu tarzda müdahaleleri 2 bakımdan anayasaya aykırı; **1. Anayasa**, ayrımcılık yasağını açık bir şekilde tanıyıp güvence altına almış. Anayasanın 10/1. Fıkrasına aykırı. **2. Anayasanın 10. maddesi** son fıkrasına aykırı. DİB çalışanları da kamu görevlisi olduğu için onlarında anayasanın eşitlik ilkesini göz önünde bulundurarak buna aykırı olmayacak şekilde görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. AİHM’nin, nefreti yaymak, nefreti yüceltmekle ilgili ifade özgürlüğünün nefreti yayan, nefreti teşvik eden, yücelten bir nitelik taşıması durumunda buna yönelik yaptırım getirmesini hatta kimi durumlarda da gerekli bulduğunu belirtmek gerekiyor. Buradaki mesele DİB’nin eliyle hukuk devletinin, anayasanın sunduğu hakların, işlemi referanslarla kişilerin elinden alınması, bunların meşru olmadığına dair bir durum var. Bugün DİB’nin 2022-2023 bütçesine bakalım. Bu bütçenin birçok icracı bakanlıktan çok daha büyük bir bütçeye sahip olduğunu görüyoruz. Birçok sorunun kaynağı uygulama olup onun da asıl kaynağı 136.maddedir. 1982 Anayasası 1961 anayasasına göre laiklik ilkesini daha aşındıran düzenlemeler içeriyor. Laikliğin korunmasına ilişkin 2 düzenleme var. Bunlardan birisi 24.maddenin son fıkrası. Yukarıda devletle din kuruluşlarının birbirinden ayrılmasına örnek olarak verdiğimiz bilgiler ve uygulamaya yönelik getirdiğim eleştiriler aslında 24.maddenin son fıkrasıyla da ilişkili, oraya da aykırılık taşıyor. 1961 Anayasasında böyle bir düzenleme yer almıyordu. Bu 1982 anayasasının getirdiği bir düzenleme. Anayasa koyucunun dini duyguların kötüye kullanılmasına istismar edilmesine yönelik duyarlılığını göstermesi bakımından önemlidir diyebiliriz. Gerekli değildir. Hiçbir hak ve özgürlüğün kötüye kullanılamayacağını söyledik. Üstelik anayasanın 14.maddesi var. Bu madde, din duygularının kötüye kullanılamayacağını açık bir şekilde belirtiyor. Ayrıca 24.maddenin son fıkrasına gerek yok. Laikliğin korunmasına ilişkin 2.düzenleme 1961 anayasasında da bulunan bir düzenleme. Devrim kanunlarının korunmasına yönelik 174.madde. Bu maddenin laikliğin korunmasına yönelik bir rolünün olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü TBMM bu kanunları değiştirebiliyor. Mesela şapka kanunu, Kanunların bir bölümü de günümüzde uygulanmıyor. Sonuç: Türkiye anayasaya göre 1928 yılından beri laik bir devlet ama tarihsel olarak bakıldığında Türkiye laikliğinin çok genç bir laikliktir. Tarihsel kökeni güçlü olan bir laiklik değil. Cumhuriyetin yarattığı kültür devriminin bir parçası. Toplumun da sekülerleştiğini görüyoruz. Laiklik ilkesi bakımından en önemli unsur, din ve vicdan özgürlüğü olduğunu görüyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü ile eşitlik ilkeleri laikliğin de temel hak ve özgürlüklerin de, demokrasinin de olmazsa olmaz 2 unsuru. Bizdeki laiklik sorunun da bu iki hakkın hem eşit olma hakkının hem de din ve vicdan özgürlüğünün tam olarak sağlanamamasıyla ilgili bir şey. Bide çoğunluğun laiklik anlayışına yaklaşımı, aslında batılı ülkelerdeki din ve vicdan özgürlüğü yaklaşımına henüz uzak olduğu sonucunu görüyoruz. İnancın kişinin iç dünyasını düzenleme işlevi olarak görülmediğini görüyoruz ülkemizde. İnanç daha çok böyle irradiantist yani tetikçi o ölçüde de agresif bir nitelik taşıyor. Böyle bir din anlayışı mevcut olduğunu görüyoruz belli bir kesimde.

1982 Anayasasının içinde yer alan sosyal devlet ilkesi bir başka ifade ile refah devleti ilkesi. Bu çok önemli bir ilke. Bir devlet ne kadar çok sosyal devlet ise bunu ne kadar gerçekleştirebiliyorsa o devletin çatısı altında yaşayan yurttaşların anayasal haklarını gereği gibi kullanabilmeleri o kadar olanaklı hale gelir. Sosyal hakların dışındaki hak ve özgürlüklerin gereği gibi kullanılması da başlangıçta hiç bunun gibi ilgisi olmayan bir konuymuş gibi gözüксе de öyle değil. Sosyal hakların dışındaki hak ve özgürlüklerin kullanılmasında sosyal devlet ilkesinin çok önemli bir payı ve rolü var. Sosyal devlet; vatandaşlarına, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sunmayı amaçlayan, bu amaçla vatandaşların önündeki toplumsal ve ekonomik engelleri kaldıracak önlemler alan devlettir. Kapitalizmi benimseyen toplumlarda o toplum içindeki bireylerin tümü aynı ekonomik ve toplumsal koşullara sahip olmaz. Kapitalist toplumlar ekonomik olarak farklılaşmış toplumlardan oluşur. Doğuştan aynı ölçüde ekonomik ve toplumsal bakımdan başka ailelerden daha az şanslı bir aileye düşmüş olan bir bireyin bu doğuştan getirdiği eşitsizliği şans ve olanak eşitliği sağlamak yoluyla bir yerde törpülemek ya da yumuşatmak amacını taşır. Sosyal devlet, sosyalist devlet demek değildir. Sosyalist devlette, üretim araçları kamunun ya da devletin kontrolü altındadır ve sınıflar arasındaki farklılığı ortadan kaldırmayı amaçlar. Herkesin aynı ya da birbirine çok yakın ekonomik olanaklara sahip olmasını sağlar. Sosyal devlet ise, kapitalist bir düzen içerisinde bu düzeni benimsemiş devletlerde ortaya çıkan bir ilke. Haliyle sosyal devlet, kapitalist düzenin temel araçlarını benimseyen bir devlettir. Bu araçlar; Pazar ekonomisi, özel mülkiyet hakkı gibi ilkeler ve hak ve özgürlükler sosyal devletin de benimsediği hak ve özgürlüklerdir. Ancak sosyal devlet, doğuştan ekonomik ve toplumsal olarak şanssız olarak doğan kesimlere şans ve olanak sağlamak yoluyla yani fırsat

eşitliği sağlamak yoluyla bu eşitsizlikleri yumuşatmayı amaçlar. Sosyal devlette, kapitalist düzenin temel araçları benimsendiği için eşitsizlikler mutlak bir biçimde ortadan kalkmayacaktır. Zaten sosyal devlette, herkesi ekonomik anlamda eşitlemeyi amaçlayan bir devlet değildir. Yalnızca aşırı ekonomik ve toplumsal eşitsizlikleri şans ve olanak vermek yoluyla yumuşatmayı amaçlayan devlettir. Bunu da ekonomik ve toplumsal alana müdahale etmek yoluyla sağlar. O nedenle sosyal devlet, 19.yy'da gördüğümüz ekonomik bakımdan liberal devletin tam karşısı konumundadır. 19.yy veya 20. yy'ın başındaki liberal devlet, jandarma devletti. Devletin ekonomik alana müdahalesine karşı olan devletti. Sosyal devlet ise, bu ekonomik ve toplumsal eşitsizlikleri yumuşatmak amacıyla ekonomik ve toplumsal alana müdahale eden devlet anlamına geliyor. Sonuç; sosyal devletin, sosyalist ya da komünist devlet anlamına gelmediği, sosyal devletin, kapitalist düzenin temel araçlarını ve özelliklerini benimseyen bir devlet olduğu biçimdir. Sosyal devlet; sosyal adaleti ve güvenliği sağlamakla ve herkese insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyini gerçekleştirmekle yükümlü olan devlet. Bu tanımdan; 1. Sosyal adalet; sosyal adaleti ve sosyal güvenliği sağlamakla ve herkese insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyini gerçekleştirmekle yükümlü olan devlettir. Bu tarihsel olarak yeni bir olgu. Çağdaş devlet olgusu, anayasacılığın ortaya çıkmasından itibaren devlet, hep liberal bir devlet olarak tanımlanıyordu ve hep bir liberal devlet olarak çağdaş devlet ortaya çıktı. Liberal devletin temel özelliği; negatif statü ve siyasal hakların sınırlı bir kesime tanındığı devletin jandarma devlet olarak kabul edildiği bir devlet modeliydi. Ancak özellikle 20.yy'dan itibaren 2.Dünya Savaşından sonra dünyanın dört bir tarafına yayılan jandarma devlet anlayışı değişti ve sosyal devlet anlayışına evrildi. Çünkü jandarma devlet anlayışının toplumdaki farklı ekonomik ve toplumsal farklı kesimler arasında derin ayrılmalar yarattı. Bununda toplumsal barışa hizmet etmediği tam tersine toplumsal barışı baltaladığı gerçeği ortaya çıktı. Ekonomik bakımdan en liberal olduğunu düşündüğümüz devletler bile bugün öyle ya da böyle sosyal devlet ilkesinin araçlarını bir ölçüde kullanan devletler. Örneğin ABD, Avusturalya kuruluşundan itibaren liberal devleti ekonomik bakımdan da liberal devleti benimseyen devletlerdi. 20. yy'da görülen küresel çaptaki ekonomik bunalımlarla birlikte devletin ekonomik alana ve toplumsal alana müdahalesinin yolunu açmıştır. Bugün artık saf anlamda liberal devlet bulmak güç. Bütün devletler, sosyal devleti ister anayasalarına bir ilke olarak yazsınlar iste yazmasınlar az ya da çok sosyal devletin araçlarını kullanan bu araçlara sahip olan devletler. Sosyal devlet ilkesi, özellikle ekonomik sınıflar arasında derin uçurumlar olduğu yani zenginin çok zengin yoksulun çok yoksul olduğu ekonomik bakımdan devletin kaynaklarının çok sınırlı olduğu bir başka ifade ile zengin olmayan devletlerde yoksullar ve zenginler arasındaki uçurumun ve bu uçuruma neden olan gelir dağılımı eşitsizliğinin ortaya çıktığı devletlerde sosyal devlet ilkesi ayrıca büyük bir önem taşıyor. Sosyal adaleti ve güvenliği sağlayan herkese insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyini gerçekleştiren devlet, bu ödevi yüklenmiş olan devlet sosyal devlettir.

Bu tanımda iki önemli kavram vardır. **1. İnsan onuru kavramı:** Herkes, eşit ölçüde saygı görececek bir değere sahip. Yani insan, insan olduğu için eşittir. Eşit ölçüde de herkes birbirine saygı göstermek durumundadır. İnsan onuru aynı zamanda insanlık dışı muameleye bağlı tutulmaması, kişinin kendini gerçekleştirmesine ve yaşamsal gereksinimlerinin tatmin edilmesini sağlayacak gerekli koşulların yaratılmasını gerektirir. İnsan onuru kavramında 2 önemli tanım karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, kişinin yaşamsal gereksinimleri, yani insanın onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için asgari ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu barınma gereksinimidir, insan gibi yaşayacak gıdaya ulaşma gereksinimidir, temiz suya ulaşma gereksinimidir. Aynı zamanda insan olmaktan kaynaklanan asgari kültürel olanaklara da ulaşma gereksinimidir. Bunların bütünüdür, asgari yaşamsal gereksinimler. İnsanın, barınma ihtiyacının asgari ölçüde karşılanması demek herhangi bir barakada yaşaması demek değil. İkinci olarak kişinin kendi kendisini gerçekleştirmesini sağlayacak koşulların sağlanması; bunun sağlayacak olanaklarla insan onuru arasında çok yakın bir ilişki var. İnsan onurunun bir parçasını oluşturuyor. Kişinin kendini gerçekleştirmesinin anlamı; kişinin özgürleşmesi anlamına geliyor. Kişinin özgürleşmesi, önündeki ekonomik, toplumsal engellerin kaldırılması demek. Sosyal devlet, kişinin önündeki ekonomik ve toplumsal engelleri kaldırarak ki kişi kendi kendini gerçekleştirip özgürleşebilsin. Kişinin kendi kendisini gerçekleştirebilmesinin 1961 anayasasındaki bir başka ifadesi anayasanın 17.maddesi. Kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahip olması insan onuruyla ve kişinin özgürleşmesiyle ilişkili bir özgürlük. 1982 Anayasasının 17. Maddesinde ve başlangıçta insan haysiyeti olarak atıfta bulunduğu insan onuruyla yakından ilişkili bir özgürlük ve hak olduğunu belirtelim.

2. Sosyal adalet kavramı: Toplumun ekonomik bakımdan zayıf olan kesimlerini korumak ve belli bir kesimin ezilmesine izin vermemek demek. Yani bu kavram adalet kavramıyla yakından ilgilidir. Ama sosyal adalet,

toplumun ekonomik ve toplumsal bakımdan zayıf olan kesimleri korumayı amaçlayan bir ilkedir. Yine ekonomik ve toplumsal bakımdan zayıf olan belli bir kesimin güçlü olan kesim karşısında ezilmesini önleyecek önlemleri alan devlet, sosyal adaleti kendisine ilke edinmiş devlettir. Sosyal devlet ilkesi, illaki anayasalarda yer almak zorunda değil. Anayasasında, sosyal devlet ilkesine yer vermemiş olmakla birlikte gerçek anlamda sosyal devlet olan pek çok devlet olduğunu biliyoruz. Çünkü bu ilke, hem yasalar yoluyla hem de yargı kararları yoluyla gerçekleştirilebilir. Anayasasında yer almasına gerek yoktur. Örneğin; Belçika, Hollanda. Belçika'nın ilk anayasası 19.Yy'da yaptığı kuruluş anayasası, Hollanda anayasası sosyal devlet ilkesine yer vermemekle birlikte günümüzde sosyal devlet nerede var denildiğinde ilk aklımıza gelen devletler arasında yer alır. Örneğin Lüksemburg, anayasasında sosyal devlete yer vermiyor. Fakat devlet yasalar yoluyla sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmiş. Bunun anayasada yokluğu o devletin sosyal devlet olmadığı, olamayacağı sonucunu bize vermez. İlk defa bir kavram olarak 1961 anayasası sosyal devleti 2.maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayan anayasadır. Bunun daha önceki anayasalarımızda olmaması çok doğaldır. Bu 20.yy'ın ortalarında ortaya çıktı. Bu ilke ve bu ilkenin gerektirdiği haklara yer veren ilk anayasa 1917 Meksika anayasasıdır. Bu anayasadan önce hiçbir anayasa, ne sosyal devlete ne de sosyal devletin temel unsurlarını oluşturan hak ve özgürlüklere yer vermemişti. Bundan sonra 1919 Baymar Alman anayasası gelir. 1924 Anayasası, sosyal devleti içeren bir anayasa değildi. İki tane hak ve özgürlükler demeti içerisinde 2 tane sosyal devlet ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz düzenlemesi vardı 1924 anayasasında. Bunlar; 1. Çiftçilerin topraklandırılmasına ilişkin düzenleme ki 1924 anayasasının ilk biçiminde bu yoktu. 1937'de yapılan değişiklikle eklendi. 2. İlköğretimin, kız erkek bütün öğrenciler bakımından devlet okullarında parasız olacağına ilişkin düzenlemeydi. Bu 2 düzenleme dışında, sosyal devlet ile ilişkilendirebileceğimiz bir düzenleme yok. Buna karşılık 1924 anayasasının yürürlükte olduğu dönem içinde yasalar yoluyla sosyal devlet ilkesinin bazı unsurları bizim hukuk düzenimize kazandırıldı. Örneğin; 1945 yılında sosyal güvenliği sağlamak amacıyla 1945 yılında SSK kuruldu. 1949 Yılında Emekli Sandığı kuruldu. Bu düzenlemeler hep sosyal devleti sağlamaya yönelik olarak yasa yoluyla sağlanan düzenlemelerdi.

1924 Anayasası sosyal devlet ilkesine ya da sosyal haklara yer vermemiş olmakla birlikte uygulamada anayasanın yürürlüğe girdiği dönem içerisinde sosyal devlet ilkesiyle ilişkili bazı düzenlemelerin yapıldığı bazı kurum ve kuruluşların kurulduğunu söyleyebiliriz. İlk defa sosyal devlet ilkesi ve sosyal ve ekonomik haklar bütüncül olarak 1961 anayasasında düzenlendi. 1982 Anayasası da 61 anayasasının getirdiği yeniliği devam ettirdi. 1961 ve 82 Anayasalarının 2.maddesi cumhuriyetin nitelikleri arasında sosyal devlet ilkesini saydığı, bunun dışında da devlete verilen ödevler çerçevesinde sosyal devletin gereği olması gereken düzenlemeleri içerdi. 1961 Anayasasının 10.maddesi ve 1982 anayasasının 5.maddesi devletin ödevlerini ve yükümlülüklerini düzenleyen maddeler. Devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen maddeler. 61 Anayasasının 10/2.fıkrası “devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerine kişi huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddi ve mali varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar. Bu fıkra tam anlamıyla sosyal devlet ilkesini düzenleyen ve devlete bu konuda ekonomik, toplumsal alana müdahale etme ödevi yükleyen bir anlayışı karşımıza çıkarıyor. 61 Anayasasının başlangıç kısmının 5. Paragrafında “insan hak ve özgürlüklerine, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, demokratik hukuk devletine bütün hukuki ve sosyal temellerini kurmak” diyor. Burada sosyal adalet kavramı çok önemli. Hem 10.madde de hem de başlangıç kısmında yer vermiş. İkinci olarak başlangıç bölümünde demokratik hukuk devletini sosyal temelleriyle kurma ifadesi son derece önemli bir ifade. Bu bize 1961 anayasasının, öngördüğü sosyal devlet anlayışı, hem demokratik devlet hem de hukuk devleti anlayışı ile yakından ilgili. Yani demokratik hukuk devleti olabilmenin yolu, sosyal devlet olmaktan geçiyor. Bu ilkeler birbiriyle yakın ilişkili olan ilkeler. Bir ilke diğerini güçlendiriyor. Bu 3 ilkeden birinin olmaması, diğer ilkeleri önemli ölçüde sakatlıyor. Sosyal devlet ilkesi, demokratik bir siyasal yapının varlığını gerektirir. Çünkü demokratik devlet geniş kitlelere siyasal karar alma sürecine katılma ve bu süreci etkileme olanakları tanır. Bu tür olanakların tanınması toplumsal kesimler arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesini sağlayacak politikaları güvence altına almış olur. Bu politikaların oluşturulması siyasal elitler tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını güvence altına almış olur. Yine demokratik bir devlette, çalışma yaşamına ilişkin hak ve özgürlükler ancak güvence altına alınır. Aynı zamanda çalışma yaşamına ilişkin hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması da demokratik bir devlet içerisinde söz konusu olur. Bu nedenle sosyal devlet, demokratik bir devlet içinde anlam kazanır. Aksi takdirde sosyal güvenlik hakkını tanıyabilir, sağlık hakkını tanıyabilir. Ama tanıdığı bu hakları geri alması, bu hakları keyfi

olarak sınırlaması bu hakları kaldırması her zaman mümkündür. Kendi yaptığı anayasaya uymayabilir. Demokratik bir devlet, kişilerin sahip olduğu her türlü hakları güvence altına alan devleti bu hak ve özgürlüklerle sınırlayan, sınırlamanın güvencesini oluşturan bir devlettir. O yüzden demokratik devletin varlığı, sosyal devletin varlığı için olmazsa olmaz bir unsurdur. Aynı şey hukuk devleti bakımından da geçerli. Hukuk devletinin olmadığı bir yerde demokratik bir düzenden söz edemeyiz. Hukuk devletinin olmadığı bir yerde sosyal devlet de gereği gibi var olamaz. Hukuk devleti birincisi hak arama özgürlüğünü sağlar ve güvence altına alır. İkincisi siyasal iktidarın yasama ve yürütme organlarının bağımsız yargı önünde hesap vermesini ve aynı zamanda yaptığı işlemlerin hukuka uygun denetlenmesini sağlar. Bu aynı zamanda sosyal devleti sağlamanın da bir gereğidir. Hukuk devleti, demokratik devlet ve sosyal devlet iç içe geçmiş, birinden vazgeçilmesi mümkün olmayan üçlemedir. 1982 anayasasını 61 ile karşılaştırdığımız zaman, devletin genel amaçları başlığında 5.madde var” devletin temel amaç ve görevleri kişilerin ve toplumun refah, huzur, mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak ölçüde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Benzemeyen yönleri var; 1. Sosyal adalet demekten kaçınmış, adalet demiş. 2. 1961 anayasasının 10.maddesi devlete daha kesin bir yükümlülük veriyor “*insanın maddi ve manevi gelişmesi gerekli şartları hazırlar, bütün engelleri kaldırır*” diyor. 1982 anayasasının 5.maddesi ise bu işi muğlak bırakarak devlete kesin bir ödev yüklememiş. 1982 Anayasasının başlangıç kısmının 6.fıkrası 1961 anayasasının başlangıcına yakın bir düzenleme içeriyor “Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanması” burada sosyal adalete yer verilmiştir. Anayasayı, bütüncül bir biçimde yorumlamamız her zaman gerekir. Hak ve özgürlük odaklı yorumlamamız gerekir. 1982 Anayasası başlangıç bölümü ve kenar başlıkları anayasadan sayıyor. Haliyle anayasanın diğer maddeleri gibi bağlayıcı olduğuna göre biz anayasanın 5.maddesinde yer alan adalet kelimesini sosyal adalet olarak yorumlayabiliriz. Başlangıcın 6.fıkrasını 1961 anayasasının başlangıcı ile karşılaştıracak olursak birincisi sosyal adalet kavramının Türk vatandaşlarına verilmiş ya da bu hakkın Türk vatandaşlarına özgülenmiş bir hak olarak formüle edildiğini görüyoruz. 1961 Anayasası evrensel bir hak olarak görmüş “İnsan hak ve özgürlükleri” diyor. Burada vatandaşlığı değil insan olmayı kendine özne olarak almış.

İkinci olarak bu anayasadaki temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal adaletten gerektiğince yararlanmak diyor. Burada temel bir insan hakları anlayışını benimsemediği sonucunu çıkarabiliriz. Bu anayasa ile sınırları çizilmiş hak ve özgürlükler demek istiyor. Bu da 1982 anayasa kurucusunun genel olarak sınırlayıcı, özgürlük yaklaşımını bir başka ifadesi olarak tanımlanabilir. AYM, anayasanın yorumunu tekeli elinde bulunduran yargı organı. AYM’nin yapmış olduğu yorumlar, aldığı kararlar son derece önemli. AYM’nin sosyal devlet tanımı; 1988/33 Karar sayılı kararında hukuk devletini, “sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerektirir. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir.” AYM’nin yapmış olduğu bu tanım evrensel sosyal devlet anlayışına uygun bir tanım. İkinci maddedeki tanımı da içeriyor. Hem 1961 anayasasının 2.maddesi hem 1982 anayasasının 2.maddesi sosyal devleti bir hukuk devleti olarak tanımlamış “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.” Demek ki hukuk devleti alelade bir hukuk devleti değil sosyal bir hukuk devleti, sosyal devlete dayalı bir hukuk devleti. Sosyal devlette, alelade bir sosyal devlet değil hukuk devletine dayanan bir sosyal devlet. İki şekilde okumamız mümkün. Bu tanım, sosyal devleti hukuk devleti ile bütünleştiren ve devlete kişiyi koruma, sosyal güvenliğini sağlama, sosyal adaleti gerçekleştirme ödevi yükleyen bir tanım getirmiş. Sosyal devlet denilince planlama son derece önemli. Planlama denilince; toplumun iktisadi yani ekonomik kaynaklarının ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla bilimsel ve akılcı biçimde kullanılmasını anlıyoruz. Her devletin ekonomik kaynağı toplumsal kaynağı da sınırlı olup bu sınırlı kaynağı en verimli şekilde kullanmak gerekir. Bu da ancak bir planlama yapmak yoluyla mümkün olabilir. O yüzden planlama, sosyal devlet ilkesinin en önemli araçlarından biridir. İlk defa bizde 1961 anayasası ile anayasamıza girdi. 1924 Anayasasında bulunmuyordu. Buna ilişkin bir örgütlenme de yoktu o dönemde. 1982 Anayasası da bazı farklılıklar içermek kaydıyla aynı planlama anlayışını devam ettirdi.

1961 Anayasası, 41 ve 129.maddelerde planlamaya ilişkin düzenlemeler getirmiş. 41 Madde “ İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi

sağlanması amacına göre düzenlenir. 129.Madde bunu biraz daha somutlaştırıyor “İktisadi, sosyal, kültürel kalkınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir.” İktisadi bakımdan, kalkınma ve büyüme iki ayrı şeyi ifade eder. Kalkınma, kültürel, sosyal, iktisadi unsurları içerir. Büyüme ise matematikseldir. Ekonomik alandaki gelişmelerle ilişkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kuruluş ve görevleri planın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, değiştirilmesinde gözetilecek esaslar planının bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.” 1961 Anayasası 129.maddesinde bu planlama işinin örgütlenmesini öngörüyor ve örgüt olarak da DPT’ni belirtmiş. Yani 1961 anayasasına göre anayasal bir burumdur DPT. 1982 Anayasası ise 166.maddesinde düzenlemiş “ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak, verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir. Plan da milli tasarrufu, üretimi arttırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri bu plana göre gerçekleşir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına TBMM’nce onaylanmasına, değiştirilmesine, bütünlüğünü bozacak değişiklikleri önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir” diyor.

Birtakım farklılıklar vardır bunlar; 1961 anayasası kalkınmayı öncelerken, 1982 anayasasının 166.maddesi büyümeyi önceliyor ve ekonomik verileri ön plana çıkarıyor. Milli tasarrufu, üretimi arttırmak, fiyatlarda istikrar, dış ödemelerde denge kavramları salt ekonomik nitelikteki amaçlar. Haliyle planlamanın amacı 1982 anayasasında değişmiş, kalkınma değil artık. Ekonomik, toplumsal kalkınma yer alıyor ama planlama bakımından öncelenen salt ekonomik nitelikteki amaçlar.

İkinci farklılık; artık DPT’na bir anayasal kurum olarak 1982 anayasası yer vermiyor. Bugün artık DPT kaldırıldı. Onun görevini Kalkınma Bakanlığı yapıyor. Ama ciddi plansızlık olduğunu son 20 yılda yaşayarak görüyoruz. 166.Maddenin son fıkrası 2010 anayasa değişikliği ile eklenen bir fıkra, 2017 yılında da değişikliğe uğradı. Bu fıkra “Ekonomik ve Sosyal Konsey” kuran fıkra. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanı’na istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Bu konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir” diyor. Bu konseyin amacı, iş yaşamına ilişkin alanda yaşanan sorunları dile getirmek, buna ilişkin birtakım politikalar önermek. Pek çok demokratik devlette, Ekonomik ve Sosyal Konseyler oluşturulmuştur. Bu konsey; hem çalışanların hem işverenlerin hem işveren olarak devletin de içinde yer aldığı, temsilcilerinin bulunduğu bir konsey. Bunlar bir araya gelerek çalışma yaşamına ilişkin sorunları dile getiriyorlar. Politikaların oluşturulmasında öneriler sunuyorlar. Zaten bu bir danışma organı olup almış olduğu kararların bir bağlayıcılığı yok. Bu danışma organı CB’na danışmanlık yapıyor. 2009 Yılından beri bu Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmıyor. Bu anayasal düzenlemenin de günümüzde uygulanmadığını söyleyelim. Hem hukuk devleti hem de demokratik düzenin olması gerekir ki sosyal devlet ilkesi tam olarak gerçekleşe bilsin.

Sosyal devlet ilkesinin amacı; çeşitli kesimler arasında görülen sosyal, toplumsal, ekonomik eşitsizlikleri yumuşatarak kişinin refahını sağlamak. Kişilerin içine sosyoekonomik farklılıklardan kaynaklanan eşitsizlikleri şans ve olanak eşitliği bir başka ifade ile fırsat eşitliği sağlamak yoluyla dengelemek. Kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmeleri için asgari ön koşulları sağlamak. Farkları yok etmek amacını içermez, yalnızca yumuşatma amacını içerir.

Çalışma hakkı: Çalışmak isteyen herkese devletin iş bulmasını isteme hakkı değil. Devlet, çalışmak isteyen herkese iş bulma olanağını sağlayacak uygun politikaları geliştirme ve izleme yükümlülüğü altında. Çalışma hakkı dediğimizde herkesin çalışabilmesini sağlayacak gerekli politikaları üretme ve bu politikaları yaşam geçirme yükümlülüğü anlamına geliyor. Nitekim 49.maddenin 2.fıkrası tam da bunu düzenliyor “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Bu konularda devlete ödev yüklemiş 49.madde. Çalışma hakkı aynı zamanda bir ödev. 49.Maddenin 1.fıkrasında bunu açık bir şekilde belirtmiş. Neden ödev? Çünkü çalışma, bireyin kendisi ve ailesi için bir geçim kaynağı yaratma anlamına gelir. Çalışma ile yaratılan değer, sadece kişiyi ve ailesini değil aynı zamanda topluma da yarar sağlayan bir değerdir. O nedenle de aynı zamanda bir ödevdir. Çalışacak fiziki güçte olan herkes kendi eğitimi ve becerisi ile ilgili olan bir işte çalışma yükümlülüğü altındadır. Sosyal devlet ilkesi ile ilgili olan ikinci hak ve özgürlükler emeğin korunmasına ilişkin düzenlemelerdir.

Anayasanın çeşitli maddelerinde buna ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilmiş. Mesela anayasanın 18.maddesi. Bu ekonomik sosyal haklar ve ödevler başlığı altında yer alıyor. Ama **emeğin korunması ile ilgili bir düzenleme, zorla çalıştırma ve angarya yasağı**. Hiç kimse zorla çalıştırılmaz, angarya yasaktır diyor. 18.Madde 2.fikrasında bazı koşullar altında yapılan çalışmaların zorla çalıştırma sayılmayacağını belirtiyor. Zorla çalıştırma anayasa ile mutlak bir yasak. Anayasa bizzat aynı maddenin 2.fikrasında bu mutlak yasağa 3 istisna getirmiş. Bunlar; hükümlülük ve tutukluluk hallerinde yapılan çalışmalar, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler ve ülke ihtiyacının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği taşıyan çalışmalar bu anayasal istisnalar olarak 2.fıkra düzenlenmiş.

Emeğin korunması ile ilgili ikinci kural; çalışma şartları ve dinlenme hakkına ilişkin. Anayasanın 50.maddesinde düzenlenmiş. bu maddeyi okuyun lütfen, maddeyi yazmadım. Bu maddeler hem dinlenme hakkını hem çalışma koşullarının ele alan madde. Ücretli adaletin sağlanması kuşkusuz ki sosyal adalet bakımından son derece önemli bir düzenleme, 55.maddede yer alıyor. Bu maddeyi oku. Bu hüküm, kanun önünde eşitlik ilkesini de göz önünde bulundurduğumuzda (10.madde), eşit işe eşit ücret ve asgari ücretin anayasal dayanağını oluşturur. Bu maddenin 2. Fikrası 2001 yılında getirilen bir düzenleme. Bu maddeyi oku. Bu 2.fıkra asgari ücrete anayasal bir güvence getiren fıkra. Sosyal güvenlik hakkı, emeğin korunması bakımından son derece önemli bir hak. Sosyal güvenlik; yaşlılık, hastalık, iş göremezlik, işsizlik gibi nedenlerle çalışamayan dolayısıyla geliri sürekli ya da geçici olarak kesilen kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan maddi desteğin sağlanması anlamına geliyor. Anayasanın 60-61-62.maddeleri bu sosyal güvenliği düzenleyen maddeler. 60.Madde sosyal güvenlik hakkını herkese tanıyor. Bugün SGK, kanunda yazılı olan bu işlevi gören ve kanunla kurulmuş olan bir kurum. 61-62.Maddeler ise sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken kesimleri sıralamış. Bunları oku. Sosyal devlet ilkesi ve ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin yumuşatılmasında en önemli araçlardan biri gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına yönelik önlemler. Bunun başında da kuşkusuz vergi geliyor. Devletin egemenlik alanı içinde yaşayan herkes vergi verme yükümlülüğü altında. Anayasanın 73. maddesi bu vergi yükümlülüğünü adalet ilkesi ile birleştirmiş “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” Yani çok geliri olanların daha çok az geliri olanların daha az vergi vermesi ya da hiç vergi vermemesidir. Örneğin asgari ücretle hayatını geçindiren bir kişiden hiç gelir vergi alınmaması buna örnek verilebilir. Bu tür gelir ve servet farklılıklarını yumuşatmanın bir yolu çok az geliri olanlardan mesela asgari ücretlilerden gelir vergisi almamaktır. Gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına yönelik önlemlerin bir başka önemli yönü de devletin topladığı vergilerin yeniden dağılımını sağlamak. Bu yeniden dağılım da ekonomik olarak dezavantajlı olan grupların daha çok yararlanmasını sağlayacak önemler biçiminde.

Gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına yönelik önlemler özel mülkiyete yönelik müdahaleler: Devletin, özel mülkiyete yönelik olarak yaptığı müdahaleler anayasanın 35. maddesinde yazılıdır. Mülkiyet hakkına, kamu yararı amacı ile devletin müdahale etmesi mümkün. Anayasa koyucu hem 61 hem de 82 anayasasında bu özel mülkiyete kamu yararı amacı ile müdahalenin 2 özel biçimini özel olarak düzenlemiş. Birisi kamulaştırma, diğeri ise devletleştirme. Kamulaştırma anayasanın 46.maddesinde düzenleniyor. Kamulaştırma; kişinin onayı ve izni olmadan özel mülkiyete ait bir taşınmazın kamu malları arasına katılması. Yol genişletilecektir. Yolun yapılacağı yer kişiye ait ise o alanı devlet kamulaştırmak yoluyla orayı alıp o yolu yapabilir. 46. Maddeyi oku. Anayasa hukuku ile özel mülkiyetin istisnası olan kamulaştırma ile ilgili olduğu ölçüde, o da acele kamulaştırma kararları. Acele kamulaştırma nedir; kamulaştırma kanununun 27.maddesinde düzenleniyor bu. Olağanüstü sayılacak bir takım durum ve koşullarda yani acil bir durum söz konusu ise kamulaştırmaya ilişkin bütün usul ve prosedürün işlenmesi kamu yararı bakımından o zaman acele kamulaştırma yapılır. Acele kamulaştırmanın, acele olmayan olağan kamulaştırmadan farkı; birincisi, acele kamulaştırmada da bilirkişi kamulaştırılacak taşınmazın bedel tespitini her iki durumda da yapıyor. Ancak acele kamulaştırmada bilirkişinin o taşınmazın bedel tespitini yapması dışındaki bütün işlemler kamulaştırmadan sonraya bırakılıyor. Yani idare kamulaştıracığı taşınmaza acele kamulaştırma usulünü kullanarak önce el koyuyor. Arkasından zilyetliği alıp kullanmaya başladıktan sonra da mülkiyetini alıyor. Acele kamulaştırma milli müdafaa denilen durumlarda kanunla yapılabilir. Bunun dışında başka özel kanunlar varsa onunla yapılabilir. En vahimi Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınabiliyor. Günümüzde her türlü kamulaştırmanın acele kamulaştırma biçiminde yapıldığını görüyoruz. Mesela çevreyi mahveden HES’ler, kentsel dönüşümler, madencilik faaliyetleri bunların tümünün acele kamulaştırma biçiminde yapıldığını görüyoruz. Bu acele

kamulaştırma mülkiyet hakkına 35.maddeye açık bir aykırılık ve kamulaştırma yetkisinin idare eliyle kötüye kullanılması. Örneğin; 1978'den beri idare, acele kamulaştırma kararını alıp uyguluyor. Bu zamana kadar mesela 1700 civarında acele kamulaştırma kararı alındı ve bunların yalnızca 5 tanesi 1978 ile 2002 yılları arasında. Geri kalan acele kamulaştırmalar 2002 yılından sonrasına aittir. Bu istisnai durum olağan bir hale dönüştürülmüş durumda. Bunun mülkiyet hakkına ne kadar aykırı olduğunu tekrar söyleyelim. Özel mülkiyetin kamu aracılığı ile müdahalesinin ikinci aracı devletleştirmedir. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel girişimlerin kamu yararını zorunlu kıldığı durumlarda özel girişimlerin kamuya aktarılması işlemidir. **Birincisi**, devletleştirmek, taşınmazı da içine alınabilir. Ama sadece taşınmazdan ibaret değil. Bir özel işletme olması gerekiyor.

İkincisi her özel işletme devletleştirmenin konusu olamaz. Bunun kamu hizmeti gören bir işletme olması gerekiyor. Telefon, internet, elektrik gibi kamuya yönelik bir hizmet olması gerekiyor. Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devleştirilebilir. 1999 Yılında bir anayasa değişikliği yapıldı. Bu değişiklik ile maddenin kenar başlığı devletleştirilme olmaktan çıkarıldı, devletleştirme ve özelleştirme biçimini aldı. Bununla birlikte artık özelleştirme de bir anayasal güvenceye kavuşmuş oldu. Bu özel mülkiyete devlet eliyle ve kamu yararı amacıyla müdahaleye ilişkin olarak anayasanın öngördüğü son bir düzenleme de topraksız köylüye toprak saklamak amacıyla yapılacak toprak reformuna ilişkin. Böyle bir şey anayasal güvenceye kavuşturuldu. 1961 Anayasasında da vardı. 1924 anayasasında da vardı. 1937 Yılında yapılan değişiklikle eklenmişti. Amaç; topraksız köylüyü topraklandırmak ve bunu da kolaylaştırmak amacı ile bu nedenle yapılacak kamulaştırmalarda peşin ödeme şartını kaldırdı. Yani kamulaştırılan mülkiyetin sahibine kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebileceğini belirtmek yoluyla anayasa koyucu bu olanağı sağlıyor. Özel olarak korunması gereken kesimlerden söz ediyor anayasa. Anayasanın pek çok maddesi toplumun çeşitli kesimlerin korunmasında devlete ödev vermiş. Mesela 41.madde; ailenin, annenin, çocukların korunmasını düzenliyor. 45.Madde; tarım ve hayvancılık dallarında, 59.madde, gençliğin korunması, 59.madde; başarılı sporcuların korunması, 62.madde; yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının korunması, 64.madde de sanatçılar, 170.madde orman köylüleri, 172.madde ile tüketiciler, 173.madde ile esnaf ve sanatkarların korunması. Anayasa tarafından bu özel olarak korunması gereken toplum kesimlerine yönelik olarak birer hak olarak düzenlenmemiş yalnız devlete o toplum kesimlerinin korunması yönünde önlem alması bakımından bir ödev getirilmiş.

25 Nisan 2023

Kollektif Haklar: Sosyal haklardan birisidir. Kişilerin tek başın kullanamayacakları, bir araya gelmekle kullanılabilecek haklardır. Örneğin örgütlenme özgürlüğü, bir başka ifade ile dernek hakkı da aynı şekilde kollektif hak niteliğinde. Çünkü dernek hakkını kişi tek başına kullanamayacağı için. Aynı durum sendikal haklar bakımından da geçerli. Kişilerin, çalışanların tek başlarına kullanamayacakları bir araya gelmek yoluyla kullanılabilecek haklar. Sendikal hak denildiği zaman 3 temel hakkı anlıyoruz. Sendika kurma ya da sendika içinde örgütlenme hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı. Lokavt hakkı çalışanlara verilmiş değil işverenlere verilmiş bir olanak olduğu için. 1982 Anayasası 51-52-53-54.maddelerinde bu hakları düzenliyor. Sendikal haklar çalışanların işverene karşı kendi çıkarlarını koruyabilmeleri bakımından son derece önem taşıyan haklardır. Demokratik devlet bakımından önemli hem de sosyal devlet bakımından önemli haklardır. İlk dönemde görmüştük; işçilerin ilk talep ettikleri örgütlenme hakkıydı. Burjuvazi ise örgütlenmenin yasaklanmasını istemişti. Bugün artık demokratik devletin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor bu sendikal haklar. Bizde sendika kurma hakkı 1947 yılında kabul edilen bir yasa ile gerçekleşti. 1924 Anayasası, dernek özgürlüğünün dışında sendikal hakları tanımadı. 1947 Kanunu, ilk defa sendika kurma hakkını tanıdı. Buna karşılık 1961 anayasasına kadar hem toplu iş sözleşmesi hem de grev hakkı yasaklanmıştı. Bizde ilk defa 1961 anayasası ile tanındığını görüyoruz. Bu haklar aynı zamanda çıkarılan yasalarla da somutlaştırıldı. 1982 Anayasası da 61 anayasasında olduğu gibi bu 3 hakkı tanıdı. 1961 Anayasasından farklı olarak 1982 anayasasının, bu sendikal hakları çeşitli biçimlerde sınırladığını çok dara alana bahsettiğini görüyoruz. Pek çok yasaklama ve sınırlama nedenleri getirmiştir. Hem sendika hakkı hem toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı bakımından söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu yasakların bir ölçüde 2001 ve 2010 anayasa değişikliği ile yumuşatıldığı kaldırıldığını söyleyebiliriz. Ancak 1982 anayasasının temel ruhunu çalışan ve emekçi bir ruh odaklı olmadığı açık.

Örgütlenme özgürlüğünü genel bir biçimde herkesin kullanmasına olanak veren bir anayasa olmadığı da çok açık. Bu anayasanın çalışanlar ya da emekçilerden çok işverenleri önceleyen bir anayasa olduğunu

söyleyebiliriz. 2001 ve 2010 değişiklikleri anayasanın bu durumunu yumuşatmış olmasına rağmen bu genel ruhu devam ettiğini görüyoruz. 51. Madde Sendika kurma hakkını düzenleyen madde. Bu hak, 51. madde ile hem çalışanlara hem işverenlere tanınan bir hak. 1982 Anayasasının ilk biçiminde sendika hakkı yalnızca işçilere tanınan bir haktı. İşçi statüsü dışında çalışanların sendikalaşma hakkı yoktu. 1995 Anayasa değişikliği ile birlikte kamu görevlilerinin de aralarında sendika kurmasına kanunla izin verilebileceğine ilişkin bir düzenleme eklendi. Böylelikle işçiler ifadesi çalışanlar biçimine dönüştürülerek sendika hakkının kapsamı genişletildi. Kamu görevlilerin de sendika kurabileceği belirtiliyor. Buna ilişkin istisnalarının, sınırlamaların ve buna yönelik diğer düzenlemelerin de kamu görevlileri sendika kanununda düzenleneceği belirtiliyor. 51.Madde ile anayasa, kanunun adını da açık biçimde vermiş. Kamu görevlilerinin sendika hakkının düzenlenmesi başka kanunlarda değil ama kamu görevlileri sendika kanunun da düzenlenecek deniyor. Kamu görevlileri ile diğer çalışanların sendika haklarının kanunla farklı rejimlere bağlı tutulduğunu da belirtelim. Kamu görevlileri bakımından farklı ve geniş sınırlamalara bağlı tutulmuş. 51.Madde sendika ve üst kuruluşlarının önceden izin alınmaksızın kurulmasını öngörüyor. Bu örgütlenme özgürlüğü bakımından son derece önemlidir.

Örgütlenme bakımından iki sistem söz konusu. 1. Bildirim usulü 2. İzin usulü: Örgütlenme hakkının kullanılabilmesi için eğer izin usulü var ise, önceden idareden izin alınması gerekiyor ki bu örgütlenme hakkı yaşama geçirilebilsin ki sendika, dernek, siyasi parti kurulabilsin Bildirim usulünde ise örgütlenme hakkı kullanılıyor ancak yeni bir örgütlenmenin olduğu idareye bildiriliyor. Eğer bu yeni kurulan örgüt kanuna ya da anayasaya aykırı ise kurulduktan sonra kanunun ve anayasanın öngördüğü usuller çerçevesinde o kuruluşundaki anayasaya ya da kanuna aykırılıklara ilişkin hukuki bir yargısal süreç başlatılabilir. Kuşkusuz ki demokratik bir devlette örgütlenme özgürlüğünün bildirim usulüne bağlı olması gerekir. 1961 Anayasasına kadar Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü bakımından yani dernek, siyasal parti kurma özgürlükleri bakımından hep izin usulü öngörülüyordu. 1961 Anayasası ilk kez örgütlenme özgürlüğünün her türü bakımından bildirim usulünü benimsedi. 1982 Anayasası da bunu devam ettiriyor. Hem dernek kurma bakımından hem örgütlenme özgürlüğünün parçası olarak siyasal partiler bakımından hem de sendikalar bakımından bildirim yöntemi benimsenmiştir. Yine geçerli olan bir kural güvenceye alınmış; kimse sendikaya üye olmaya, sendika da üye kalmaya ya da sendikadan ayrılmaya zorlanamaz hükmü bunu veriyor. Bunun aynı şekilde siyasal partiler bakımından da anayasa da düzenlendiğini hatırlayalım. Aynı düzenleme dernek kurma ya da örgütlenme biçimleri bakımından da geçerli bir kural. Sendika kurma hakkı, önemli bir hak. Çünkü çalışanların kendi çıkarlarını ortak bir çatı altında savunabilmelerini sağlamak bakımından önemli. Demokratik bir devlet, örgütlü bir devlettir. Yani topluma çeşitli yollarla örgütlendiği bir devlettir. İşte sendika kurma hakkı da iş yaşamında çalışanların, emekçilerin ve işverenlerin örgütlenmesine olanak sağlayan bir hak olması nedeniyle son derece önemli. Demokratik devlet ilkesinin ayrılmaz bir parçası kabul edilen bir hak. Sendikal hakkın bir başka hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkıdır. Anayasanın 53.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin öznesine baktığımızda, sendika hakkının öznesinden farklılık taşıdığını görüyoruz. Sendika hakkının öznesi çalışanlar ve işverenler, toplu iş sözleşmesi hakkının öznesi, işçiler ve işverenler. Emekçilerin, çalışanların çalışma ve ücret koşullarının sendikaları aracılığı ile işverenle yapılacak pazarlık yöntemi ile belirlenmesine toplu iş sözleşmesi denir. 1982 Anayasası toplu iş sözleşmesi hakkını, sendika kurma hakkı olan bütün çalışanlara tanımamış, yalnızca işçilere tanımış. Toplu iş sözleşmesinin amacı ya da kapsamı; çalışma ya da ücret koşullarını, işverenle yapacakları bir pazarlıkla belirlemek. Çalışma ve ücret koşullarını, sendikaları aracılığı ile yani işveren ve işçi sendikaları arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkıyor. Bu sözleşme kapsamında işçiler ve işverenler belli çalışma koşulları ve işçilerin ücretleri bakımından bir uzlaşmaya varıyorlar.

1995 Yılında 53.Maddeye bir ek getirildi. Kamu görevlileri sendikaları bakımından bu sendika ile kamu görevlilerin işvereni olan devlet arasında toplu görüşme yapılacağı belirtildi. Toplu görüşme ile toplu iş sözleşmesi iki ayrı usulü ya da yöntemi ifade ediyor. 2010 Yılında 53.madde bir kere daha değiştirildi. Bu toplu görüşme, toplu sözleşme biçiminde değiştirildi. 2010 Anayasa değişikliği ile birlikte işçiler ve işverenle arasında yapılan sözleşme anayasaya göre toplu iş sözleşmesi iken kamu görevlileri ile devlet arasında yapılan sözleşme toplu sözleşme. Bu ikisi arasında hala usule ilişkin bir fark var. İşçilerle işveren sendikası arasında toplu iş sözleşmesi pazarlığında uzlaşma olmaması durumunda işçilerin grev hakkı söz konusu. Buna karşılık kamu görevlileri sendikası ile işveren yani devlet arasında toplu sözleşme pazarlığında uzlaşma çıkmaması durumunda kamu görevlilerinin grev hakkı bulunmuyor. Böyle bir uyumsuzluk çıkarsa uyumsuzluğu, kamu

görevlileri hakem kurulu çözüyor. Bu hakem kurulunun kararları da kesin. Buna ilişkin yargısal ya da idari bir başvuru merci bulunmuyor.

53.Maddenin kenar başlığı bu iki usulün ya da yöntemin birbirinden farklı olduğunu bize gösteriyor.

54.Maddenin kenar başlığı grev hakkı ve lokavt. Grev hakkı; çalışanların, çalışma ve ücret koşullarının kendi lehlerine değiştirmek amacıyla topluca işi bırakmalarına verilen ad. 54.Madde grev hakkını, sınırlı bir biçimde tanıyor. **1. Hakkın öznesi bakımından sınırlı.** Yalnızca işçilere tanınan bir hak. Bütün çalışanlara değil kamu çalışanları kamu görevlileri bu hakkı dışında tutulmuş.

2. Grev hakkını, 1982 anayasası yalnızca toplu sözleşme yapılması sırasında çıkacak uyuşmazlıklar bakımından tanımış. 1982 Anayasasının ilk biçiminde mesela işçilerin daha önce yapılmış toplu iş sözleşmesi ile kazandığı hakların işveren tarafından ihlal edilmesi bakımından yapacakları hak grevlerinin yine, siyasal amaçlı grevini, dayanışma amaçlı grevini, genel grevi, işyeri işgalini, işi yavaşlatma, verim düşürmeyi ya da başka tür direnişleri açık biçimde yasaklıyor. 1961 Anayasasında olmayan bir sınırlamaydı. 2010 Yılında bu yasak sınırlaması kaldırıldı. Ama buna karşılık 54.madde, yalnızca grev hakkını işçilerin toplu iş sözleşmesi sırasında çıkan uyuşmazlıklar bakımından güvence altına alıyor. Diğer biçimdeki grevleri güvence altına almıyor. Bunu tamamen kanun koruyucunun takdirine bırakıyor. 1982 Anayasasının ilk biçimine göre daha hak odaklı bir hale geldi bu düzenleme ama hala tam demokratik bir anlayışla yapılmış bir madde değildir. 2010 Yılında aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya da üye olma yasağı da kalktı. Bu yasağın kalkması, sendikaların işverene karşı güçlenmesi bakımından olumlu bir düzenleme olmadığını belirtelim. İşçi sendikaları bu yasağın kalkmasına itiraz etmişlerdi. Çünkü bütün sendikalar işverene karşı, toplu iş sözleşmesi yapmak ve grev hakkı sahip değil. O işyerinde en güçlü olan sendika bakımından bu geçerli. Haliyle işçilere birden fazla sendikaya üye olma hakkı tanınınca bu durumda sarı sendika dediğimiz işveren ya da devlet taraflı sendikaların güçlenmesi ve toplu iş sözleşmesinde taraf olarak kabul edilmesini kolaylaştıran bir sonuç yarattı. Grev hakkına ilişkin düzenlemeye baktığımızda, yürütme organına grevin yasaklanması ya da ertelenmesine ilişkin çok geniş bir yetki tanındığını görüyoruz.

Grev ve lokavtın yasaklandığı durumlarda ya da yürütme organının kararıyla ertelendiği durumlarda o zaman yüksek hakem kurulunca bu uyuşmazlığın çözüldüğü belirtiliyor. Bunu kamu görevlileri hakem kuruluyla karıştırmıyoruz. Yüksek hakem kurulu, grevin yasaklandığı, ertelendiği durumlarda işçi sendikası ile işveren arasındaki uyuşmazlığı çözen kurul. Bu kurulun kararları kesin olup başka bir yere başvurulamıyor.

54. Maddedeki bu düzenlemenin sonucu; fiilen grev hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğuruyor. Yüksek hakem kurulu, işveren, işçi ve devlet temsilcilerinden oluşan bir kurul. Devlet ve işveren temsilcileri sayısal olarak her zaman işçi temsilcilerinden daha kalabalık. Bu kurulun almış olduğu kararlar genellikle işçilerin aleyhine işverenlerin lehine bir nitelik taşıyor. Uygulama da grev erteleme ve grev yasakları yoluyla işçi sendikalarının bu hakkını kullanması hemen hemen imkansız hale geliyor. İlgili kanunun da buna ilişkin düzenlemelerinin bunda çok önemli payı vardır. 6356 Sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu bu alanı düzenliyor. Bu kanun CB'na, milli güvenlik, genel sağlık, ekonomik ve finansal istikrar sağlama nedeniyle grev ertelemesi hakkı veriyor. Ekonomik ve finansal istikrar geniş bir alan. Her alanda ve her konuda da grev erteleme olanağı CB'na tanınmıştır. Bu kadar geniş ve muğlak bir yetki vermek yoluyla 54.maddedeki grev hakkını tamamen uygulamada kullanılamaz hale getirdi. İkinci olarak bu kanun, çıkar grevleri dışındaki yani çalışanların, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin konular dışındaki tüm grevleri yasa dışı ilan ediyor. İş yavaşlatma, işçilerin dayanışması, sempati ya da genel grevin tümü bu kanuna göre yasa dışı. Anayasa böyle bir yasak öngörmediği halde kanun bunları yasa dışı kabul ediyor. Dahası kanunsuz greve katılan işçilerin de iş sözleşmelerinin de tazminatsız olarak fesih edileceğini belirtiyor. Bu da kanunun konuya işveren odaklı olarak baktığını gösteriyor. 6356 Sayılı bu kanun 60 günlük bir süre ile CB'na herhangi bir grevi erteleme yetkisini veriyor. Böyle bir erteleme kararı alındığında da işçileri temsil eden sendika greve gidemiyor. Bunun sonunda uyuşmazlık otomatik olarak yüksek hakem kuruluna gidiyor. Kurulun çoğunluğu işveren ve hükümet temsilcilerinden oluştuğu için bu erteleme uygulama grev hakkının kullandırılmaması sonucunu doğuruyor. 9 Ekim 2020 Tarihli resmi gazetede yayınlanan bir CBK ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarına ait fabrikalarda sendikanın almış olduğu grev kararını erteliyor. Erteleme gerekçesi de genel sağlık ve milli güvenlik. Milli güvenliğin Şişe Cam fabrikası ile ne ilişkisi var onu bilmiyoruz. 60 Günün sonunda da grev yapılmaksızın iş yüksek hakem kuruluna götürülüyor ve orada karara bağlanıyor.

2015 Tarihli bireysel başvuru kararı var AYM'ne. 2015/14862 Sayılı bireysel başvuru kararı. Bu kararında anayasa mahkemesi, grevin CB tarafından ertelenmesinin o zaman Bakanlar Kuruluydu, hükümet sistemi

parlamenter sistemdi. Yürütme organı tarafından ertelenmesini bir hak olarak görmüştü. Ama AYM'nin bu nitelikteki kararlarına yürütme organının uymama durumu var. 2015 Tarihli bu kararından sonra 2020 tarihli böyle bir CBK ile bunun ertelendiğini örnek olarak verdim. 54.Madde aynı zamanda lokavtı düzenliyor. Lokavt; işçilerin, çalışanların işveren tarafından topluca işten uzaklaştırılması anlamına geliyor. İşçilerin grev hakkına karşı işverene tanınmış bir olanak. 1961 Anayasasında düzenlenmemiştir lokavt. İlk defa anayasal olarak 1982 anayasası ile tanındı. Son derece eleştiriye açık. Sosyal devlet, güçsüzün yanında olan devlettir. İşverende elinde sermaye olması bakımından zaten güçlü bir durumdadır. Yani sosyal devlet ilkesini benimseyen bir anayasanın güçlüyü değil güçsüzü koruması gerekir. Dolayısıyla lokavtın anayasa içinde yer alması lokavta anayasal bir nitelik tanınması aslında sosyal devlet ilkesinin mantığı ile bağdaşmıyor.

1982 Anayasası sosyal devlet ilkesi kapsamında başka hangi haklara yer vermiş? 42.madde eğitim ve öğretim hakkından söz ediyor. İlköğretimim devlet okullarında parasız olacağı kuralının, 1924 anayasasından beri anayasal bir güvence altında olduğunu belirtelim. Bu hakkı bu şekilde düzenleyen ilk anayasa 1961 anayasasıdır. Burada eleştiriye konu olan noktalardan biri, devletin maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencileri destekleme yükümlülüğü tanınması. Oysaki sosyal devlette başarılı ya da başarısız öğrencilerden çok maddi olanakları olmayan bütün öğrencilere devletin asgari bir destek sağlaması gerekir. Başarılı öğrencileri ayrıca desteklemek tabii ki iyi bir şeydir. Sağlıklı çevrede yaşama hakkı 56.maddede düzenleniyor. 1.ve 2. Fıkraları buna ilişkin. Daha sonraki fıkralar ise sağlık kuruluşları ve sağlık hakkı ile ilgili düzenlemeler. Bunlar 3.kuşak haklar olarak adlandırdığımız bir hak. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. 57. Madde konut hakkını düzenliyor. Deprem bölgesindeki konutlarını kaybetmiş olan yurttaşlara devletin parasız o konutları sağlamasına ilişkin seçimlerde vaat var. Bu vaadi yapanlar anayasanın 57.maddesini referans veriyor. Devlet isterse bunu yapabilir ve yapması da gerekir. Buna karşılık 57. madde devlete böyle bir anayasal yükümlülük yüklememektedir. Devletin anayasal yükümlülüğü buna ilişkin önlem almaktır. Maddi bakımdan gücü sınırlı olan kesimlerin konut sahibi olmasını veya ucuz konutlarda barınabilmesini sağlayacak önlemleri politikaları alır ve yürütür. Bunun anayasal dayanağını getiriyor. Ekonomik ve sosyal alanda anayasanın devlete yüklediği ödevlerin bir sınırı var mı? Anayasanın 65.maddesi bunu düzenliyor. Bu maddiyi oku yazmadım. Burada ekonomik ve sosyal hakların sınırı; bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözütecek ve mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirecek.

Sosyal devlet ilkesi içinde anayasanın düzenlediği bütün haklar ve devlete yüklediği ödevler bakımından geçerli olan bir sınır mıdır bu? 1. Gördük ki anayasanın ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiş hak ve özgürlüklerin tümü pozitif statü hakları değil. Bunların bir kısmı negatif statü hakkı niteliğinde. Negatif statü haklarının kişiler bakımından kullanılabilmesi devlete herhangi bir mali yük yüklemeyiz. Devlet o alanda kişilerin bu haklarını kullanabilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapacak, kendisi o alana müdahale etmeyecek, kendisi o hakları ihlal etmeyecek, 3.kişilerin bu hakları ihlal etmesini önleyecek yasal önlemleri alacak. Bu nitelikteki hak ve özgürlükler bakımından sendikal haklar başta olmak üzere. Negatif statü haklar bakımından niteliğindeki sosyal haklar bakımından devletin yapacağı şey, bu hakları anayasaya aykırı bir biçimde sınırlamamak. Üçüncü kişilerin bu hakları ihlal etmesini önleyecek yasal düzenlemeleri yapmak. 65.Madde bu nitelikteki haklar ve özgürlükler bakımından geçerli değil. Negatif statü hakkı niteliğini taşımayan yani pozitif statü hakkı niteliğinde olan düzenlemeler bakımından geçerli. Bu düzen bakımından geçerli olan haklarda kişilere yargı yoluyla talep edilebilecek subjektif bir kamu hakkı vermiyor bu nitelikteki haklar. Örneğin orman köylülerin korunmasına ilişkin düzenleme. Devlet orman köylülerin korunmasına ilişkin bir müdahalede bulunmadıysa, orman köylüleri bu benim bir anayasal hakkım dolayısıyla devlet beni korusun diye yargı yoluyla bunu talep edemez. Bu nitelikteki düzenlemeler, belli toplumsal nitelikteki kesimleri korumaya yönelik düzenlemeler anayasa da bir hak olarak düzenlenmemiş. Bunların niteliği; yasama organına bir çeşit direktif veren program hükümler. Bu düzenlemeler program niteliğinde haliyle muhatabına bir dava yoluyla bir hak tanımıyor. 65.Madde bu bakımdan devlete bir sınır getiriyor. 65.Madde bu yükümlülüğü ne ölçüde yapıp yapılmayacağı konusunda devreye giriyor. Yani mali kaynakları ölçüsünde bunu yerine getirecek. Bir başka görüşe göre bu haklar bakımından hiçbir yasa çıkarılmamasının hiçbir bağlayıcılığı yok. Yani yargı yoluyla böyle bir zorlamada bulunulamaz. Ama TBMM, bir kez böyle bir düzenleme yaptıysa örneğin orman köylülerine ilişkin böyle bir düzenleme yaptıysa daha sonra anayasanın 65.maddesini gerekçe göstererek bu hak için benim mali kaynağım yok diyerek bu hakkı bu kesimin elinden alamaz. Bir kez bu hak tanındığı zaman mali kaynakların yetersizliği gerekçesiyle o haktan yoksun bırakılamaz, anayasa tarafından güvence altına alınmış olan kesim. AYM de bu ikinci görüşü benimsiyor.

Özellikle sosyal güvenlik haklarına ilişkin 1980’lerden itibaren vermiş olduğu kararların tümünde bu yaklaşımı benimsediğini görüyoruz.

Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi:

Siyasal iktidarı ikiye ayırmıştık. Asli kurucu iktidar ve türevsel kurucu iktidar olarak. Ondan öncede siyasal iktidarı ikiye ayırmıştık ilk dönem. *Kurucu iktidar ya da kurulmuş iktidar.* Anayasaların yapılması işlemine kurma ya da kuruculuk adı veriliyor. Devleti siyasal bir kurum olarak kuran iktidara da **kurucu iktidar** denir. **Kurulmuş iktidar** ise, kurulmuş iktidarı anayasa ile hukuki statülerine ve yetkilerini verdiği belirlediği, saptadığı devlet organlarına kurulu ya da kurulmuş iktidar deniyordu. Kurulmuş ya da kurulu iktidar, anayasa ile tanınan aynı zamanda hukuki statüsü ve yetkisi de anayasa ile belirlenen devlet organları yani yasama yürütme ve yargı.

Kurucu iktidar ise anayasayı yapan iktidara verilen isim. Kurucu iktidar 19.yy’dan bu yana tam olarak ikiye ayrılır. *Asli kurucu iktidar ve türev veya tali kurucu iktidar.*

Asli kurucu iktidar, anayasayı ilk defa ya da yeniden yapan iktidara verilen isim.

Tali kurucu iktidar ise, anayasayı değiştiren iktidara verilen isim. Asli kurucu iktidar dediğimiz zaman daha önce konmuş hukuk kuralı ile kendini bağlı ya da sınırlı görmeyen devleti kuran ona hukuki ve siyasal statüsünü veren anayasayı ilk kez ya da yeniden yapan iktidara asli kurucu iktidar denir. Bu tanıma göre anayasayı yapan iktidar asli kurucu iktidar. Anayasayı ilk kez yapabilir ya da yeniden anayasa yapabilir. Her iki durumda da asli kurucu iktidardan söz ediyoruz.

Bunun en temel özelliği; hiçbir hukuk kuralı ile kendisini bağlı ya da sınırlı görmemesi. Bunun içine anayasa da dahil. Eğer bir anayasa varsa ve bu kurucu iktidar yeni bir anayasayı, mevcut anayasayı değiştirme kuralları içerisinde yapıyorsa biz bu anayasaya yapan iktidar asli kurucu iktidar demiyoruz. Çünkü asli kurucu iktidar niteliği gereği hiçbir hukuk kuralı ile kendisini bağlı ve sınırlı saymayan iktidara verilen isim. Asli kurucu iktidar, yeni bir hukuk düzeni kurulurken eski hukuk düzeninin ortadan kalktığı ya da hukuki bir boşluk bulunduğu varsayımına dayalı olarak ortaya çıkan iktidar. Asli kuruculuk örneğin yeni bir devletin kuruluşu ile ortaya çıkıyor. Yeni bir devletin kuruluşu ile o anayasayı yapan iktidar asli kurucu iktidar. 1787 Amerikan anayasası, 1950 Hindistan, 1963 Cezayir, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası yani yeni bir devletin ortaya çıkması sonucunda yapılan anayasa, asli kurucu iktidarın yaptığı anayasa. İkinci bir durum; örneğin savaş sonucu geçici olarak yok olan bir devletin yeniden ortaya çıkması durumu.

Asli kuruculuk, burada da yapılan anayasa ile de ortaya çıkıyor. 1947 Japan anayasası, 1949 Alman anayasası buna verilecek örnekler. Örneğin işgalci güçlerle yürütülen kurtuluş savaşı sonucunda o güçlerin ülkeden kovularak devletin kuruluşunun yeniden kurulması sonucunda ortaya çıkabilir. Yine başka olarak anayasal bir devlet vardır. Ama o devlet bir devrim ya da darbe sonucunda ortadan kalkar ve yenisi kurulur. Örneğin 1848 Fransız anayasası, 1917 Rusya anayasası, 1961 ve 1982 Türkiye Cumhuriyeti anayasaları, devrim ya da darbe sonucunda asli kurucu iktidarın ortaya çıkmasıyla verilebilecek örnekler. Bu darbe dönemlerinde gözlemlediğimiz bir durum olabilir. Bu da hali hazırda bulunan anayasa tümünden kaldırılmamış olabilir. Böyle bir durumda yürürlükte olan anayasa kuralları herhangi bir yasa değerinde olabiliyor. Normlar hiyerarşisinde en üstte yer alan değiştirilmesi diğer yasalardan daha zor ve farklı usullere bağlı olan bir anayasa niteliğini kaybediyor. *Bu da darbeler etkisiyle anayasasızlaştırma adı veriliyor.* 1980 darbesinden sonra çıkarılan 2928 sayılı kanun “1961 anayasasında TBMM’ne ve CB’na ait yetkilerin tümünü Milli Güvenlik Konseyine devredildiğini ve bunun konsey üyesi olan devlet başkanına ait olduğunu” belirtmişti. Ayrıca bu yasa Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilecek, ilgili karar ve yasaların 1961 anayasası ile çelişen hükümlerinin anayasa değişikliği sayılacağını belirtiyordu. Yani kuramsal olarak 61 anayasası halen yürürlükte 1961 anayasasının anayasa değişikliği için öngördüğü kurallar yürürlükte değil, Milli Güvenlik Konseyi bildiri, karar veya yasalar yoluyla 61 anayasasını değiştirme yetkisine sahip. Bazı hukukçular bu asli kuruculuğu, bir hukuki temeli olduğunu söylerken bazıları bunu hukuk dışında bir iktidar olarak tanımlıyor.

Birinci görüşe bağlı olanların eski düzene bir darbeyle ortadan kalkması bir hukuki boşluk doğurmuyor. Bunlara göre darbe ya da devrim yürürlükte olan hukukun geçerliliğini yitirmesi değil hukuk yapısının dönüşüme uğraması anlamına geliyor. Bu bakımdan bu görüşü savunanlar için asli kurucu iktidar bir hukuki olgu.

Diğer görüşü savunanlar yani asli kurucu iktidarı tamamen hukuk dışı olduğu görüşünü savunanlar bakımından ise asli kuruculuk fiili bir nitelik taşıyor. Böyle olunca da asli kurucu iktidar, daha önce yürürlükte olan

herhangi bir kurala varsa anayasaya, herhangi bir pozitif hukuk normuna bağlı değildir. O nedenle de hukuki bir niteliğe sahip değildir. Bu iddianın bir sonucu olarak asli kurucu iktidar, aslında ortaya çıktığı toplumdaki güç dengesine göre oluşan siyasal bir niteliğe sahip. Bu önemli dedi. Asli kurucu iktidarın, hiçbir hukuk kuralına bağlı olmaması nedeniyle hukuk dışı bir olgu olduğunu iddia eden görüş diyor ki asli kurucu iktidar toplumdaki güç dengesine göre oluşan siyasal bir niteliğe sahip. Aslında asli kurucu iktidar ne tümüyle hukuki bir iktidar ne de tümüyle hukukun dışında bir iktidar. Bütün asli kurucu iktidarlar, yürürlükteki anayasaya bağlı olmak zorunda olmayan iktidardır. Asli kurucu iktidarı, asli kurucu iktidar yapan yürürlükteki önceki anayasaya ya da başka hukuk kuralına kendini bağlı görmeyen iktidar. Buna karşılık asli kurucu iktidarın hukuki olmaması, bütünüyle her türlü hukuk kuralının dışında hareket etmesi anlamına mı gelir? Hayır, çünkü evrensel anlamda hukukun varlığı anasadan bağımsızdır. Demokratik kurucu iktidar bakımından hukukun genel ilkelerinden, evrensel insan hakları hukukundan asli kurucu iktidar kendini bağımsız tutamaz. Kuramsal olarak yürürlükteki hiçbir kuralla bağlı değildir. Ama asli kurucu iktidar bu iktidarını kullanırken yine de anayasa dışında bir takım evrensel ilke ve kurallarıyla kendini bağlı sayabilir. Yani önündeki dış etmenleri tamamen göz ardı ederek anayasa yapamaz asli kurucu iktidar. Her demokratik olmayan yönetimlerde bile anayasayı yapanlar hep toplumsal dinamiklerden hem de başka dış etkilerden az çok etkilenir. Örneğin toplumdaki yerleşik siyasal inanç ve tutumlar, toplumsal güç dengeleri her zaman asli kurucu iktidarın yetkisini bir ölçüde sınırlar. Bu hukuki değil fiili bir sınırlama. Uygulamada demokratik olmayan asli kurucu iktidarı bile sınırlayan birtakım etmenler vardır. O toplumun yerleşik siyasal inançları, toplum içindeki güç dengeleri, o devletin uluslararası ilişkileri, uluslararası ortam bunların hepsi asli kurucu iktidarı sınırlayan etmenler.

Asli kurucu iktidar örneğin uluslararası toplumun bir parçası olmak niyetinde ise o zaman uluslararası örgütlerin demokrasi yönündeki yaklaşımı asli kurucu iktidarı fiilen sınırlayacaktır. 1924-61-82 anayasaların baktığımız zaman bu anayasaları belli bir takım ortak özellikleri koruduğunu görüyoruz. Bu ortak özelliklerde bize Türkiye’de yerleşik inanç ve tutumların yerleşikliğini gösteriyor. Bu sürekliliğin her üç anayasaya da yansıdığını gösteriyor. Asli kurucu iktidarlar teorik olarak önceki hukuk kuralı ile kendilerini bağlı görmüyorlarsa da yine toplumsal güç dengeleri bu anayasal düzenlemelerini etkiledi. 1982 Anayasası biz hep hak ve özgürlükleri öncelemeyen otorite ve devlet odaklı bir anayasa olarak görüyoruz. Üstelik 1982 anayasasını yapan asli kurucu iktidar öyle demokratik bir asli kurucu iktidar olarak adlandırılmayacak nitelik taşıyor. Buna karşılık bu asli kurucu iktidar bile 1982 anayasasını yaparken uluslararası ortamdan etkilenecek bunu yapmış. Örnek; anayasanın 15.maddesi, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasını düzenliyordu. Bu maddenin birebir AİH Sözleşmesinin 15.maddesi olduğunu görüyoruz. Uygulamada hiçbir anayasa için dış ortamlardan bağımsız mutlak bir şekilde bu yetkisini kullanan bir iktidar olarak tanımlamamız mümkün değil. Burada ortaya çıkan bir sorun 2010’lu yıllarda Türkiye’de çok tartışılmış olan mesele TBMM’nin asli kurucu iktidar olarak yeni bir anayasa yapıp yapamayacağı sorunu. Bazı hukukçular TBMM’nin kurucu bir iktidar işlevini göremeyeceğini söyler. Çünkü 1982 anayasası, anayasanın nasıl değiştirileceğini belirtmiştir ve TBMM’nin kuruluşu zaten 82 anayasasında yer alır. TBMM, ancak 1982 anayasasında, anayasanın değiştirilme usullerine ilişkin düzenlemeleri göz önünde bulundurarak, yine anayasanın 4.maddesini göz önünde bulundurarak anayasayı değiştirebilir. 82 Anayasasının ilk 3 maddesi dışındaki bütün maddelerini TBMM değiştirse bile bu yeni bir anayasa olmaz. TBMM bunu yaparken, asli kurucu iktidar işlevine sahip değildir. Olsa olsa ilk 3 maddesi dışındaki bütün maddeleri değiştirmiş bir 1982 anayasasından söz edilebilir. Bunu yaparken de TBMM bir türevsel kurucu iktidar işlevini görür. Bu görüşün karşısında olanlar der ki; TBMM, kurucu bir meclis sıfatı ile seçilmemiş olsa bile, asli kurucu ortam işlevi görebilir. Bu yetkiyi kullanabilir. Yani asli kurucu iktidar olabilir. Çünkü zaten biz asli kurucu iktidarı o toplumdaki siyasal güç dengeleri olarak tanımlamıştık. Böyle bir denge varsa TBMM’nde o meclisi oluşturan siyasal partiler yeni bir anayasa yapılması konusunda uzlaşmışsa o zaman asli kurucu iktidar olarak TBMM pekala yapabilir. Aksini düşünmek o zaman yeni bir anayasa yapılmasını sadece bir devrim, bir darbe bir savaş bir işgal koşulunun gerçekleşmesine bağlamak olur. Nitekim 2011-2013 sürecinde TBMM, kendi içinde siyasal parti grubu bulunan temsilcilerinden oluşan bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşturmuş. Süreç 2013 yılından sonra işlemedi AKP masadan çekildi. En azından o dönemde TBMM’nin içinde yer alan siyasal parti grupları meclisin asli bir kurucu iktidar işlevi ile bu gücü üzerine alarak yeni bir anayasa yapabileceği konusunda anlaşmıştı. Asli kurucu iktidarı sadece olağanüstü koşullarda ortaya çıkar diye tanımlamak doğru değildir.

Örnek Finlandiya anayasası. Barışçıl yollarla yeni anayasaların yapılabilmesinin önü açılması gerekir. Eğer bunu kabul edersek asli ve tali kurucu iktidar ayrımı da ortadan kalkıyor. Çünkü 2011-2013 süreci bakımından

konusacak olursak eğer yeni anayasanın maddelerinin yapımı konusunda taraflar uzlaşmış olsaydı 1982 anayasasının anayasayı değiştirme çerçevesinde yeni anayasa TBMM’nde görüşülüp kabul edilecekti.

Asli kurucu iktidarı ikiye ayırıyoruz. 1. Monokratik asli kurucu iktidar: Kaynağını tek kişinin iradesinden alan iktidara denir. Bu iktidar anayasayı ya ferman ya da misak yani sözleşme biçiminde yapıyor. Ferman asli kurucu iktidar; anayasayı yapan iktidar sadece hükümdar, monark. Hükümdarın, tek yanlı iradesinin ürünü olan anayasa ferman anayasa. Örnek: 1848 İtalya, 1889 Japonya, 1876 Kanuni Esasi Anayasaları. Ferman anayasalar, mutlak monarşilerden sınırlı monarşilere geçişinde ortaya çıkan anayasalar. Ferman anayasaların özelliği, tek bir kişinin elinde olunca bu anayasaları kaldırma ve değiştirme yetkisi de yani tali kurucu iktidar yetkisi de yine tek kişi de oluyor. Misak biçimdeki monokratik kurucu iktidar ise; hükümdarın iradesinin yanında ona kendini kabul ettirmiş ve hükümdarla birlikte onun iradesine eklemlenmiş temsili bir organ ya da meclisin birlikte yaptığı anayasa. Artık burada monark söz konusu değil. Monarkla birlikte halkın temsil eden bir meclis de bulunuyor ve bir arada yapılıyor. Buna karşılık, bunlar iki taraflı sözleşmelerdir. Monarkla birlikte temsili nitelik taşıyan organ arasındaki sözleşme. Burada önemli olan bu sözleşmede ya da demokratik asli kurucu iktidar olarak monokratik misak kurucu iktidarın demokratik bir kurucu iktidar olarak tanımlanmamasının nedeni iki tarafında yani hem hükümdarın hem de meclis güçlerinin hemen hemen aynı olması ve bazı konulardaki üstünlüğün hala hükümdarda olması. Bu nedenle bu biçimde yapılan anayasalar ya da bu biçimdeki anayasayı yapan iktidar monokratik kurucu iktidar olarak tanımlanıyor. Bu nitelikteki anayasaya da misak anayasa deniyor. Misak anayasalar, tarihsel olarak monarşilerin zayıfladığı, ulusal egemenlik ya da halk egemenliğinin gücünün arttığı dönemlerde görülüyor. Örneğin 19.yy’da yapılan anayasaların önemli bir bölümünün misak anayasa olduğunu görüyoruz. Özellikle monarklar, hem devleti modernleştirmek aynı zamanda da güçlenen burjuvaziye karşı kendi iktidarını sağlamlaştırmak amacıyla yeni bir anayasa yaparken temsili nitelik taşıyan meclislerle de işbirliği yapma yoluna gidiyorlar. Örnek; 1830 Fransız anayasası, 1850 Prusya anayasası.

2. Demokratik asli kurucu iktidar: Bunun her türü ya da biçimi bizim bugün anladığımız biçimde gerçek anlamda demokratik değil. Ancak özellikle, asli kurucu iktidarın kaynağını halktan ya da ulustan alması nedeniyle tam olarak demokratik olmayan kurucu iktidarlarda bu kategori içinde tanımlanıyor.

Asli kurucu iktidar anayasayı yapan iktidardır. Türev ya da türevsel iktidar dediğimizde, anayasayı değiştiren iktidarı anlıyoruz. Asli kurucu iktidar, anayasayı yapmak bakımından monokratik asli kurucu iktidar ve demokratik asli kurucu iktidar olarak ikiye ayrılıyor demiştik. Günümüzde geçerli olan asli kurucu iktidar tipi demokratik asli kurucu iktidar. Monokratik asli kurucu iktidarların özellikle yazılı anayasaların ilk defa ortaya çıktığı süreçlerde 18-19.yy’larda karşımıza çıktığını görüyoruz. Monokratik asli kurucu iktidarda iki tür anayasa yapım biçimi vardı. Ferman ve misak anayasa olmak üzere. Hükümdarın, monarkın tek taraflı iradesiyle kendi başına yaptığı anayasaya verilen isimdi. Monarkla birlikte temsil yeteneğine sahip olan bir parlamentonun, meclisin anayasa yapım biçimine verdiğimiz isimdi. Bunun en önemli unsurlarından birisi monark tek başına anayasayı yapmıyor, onunla birlikte bu anayasayı yapımına yani asli kurucu iktidara ortak olan temsili bir yetkiye yani halktan aldığı bir temsile dayanan bir organ ya da parlamento var. Ama halen parlamento bugün anladığımız parlamenter monarşilerde gördüğümüz biçimde mutlak olarak yasama ve yürütme yetkisine egemen değil. Parlamento ile monarkın yetkileri az çok birbirine yakın yetkiler. Misak anayasalarda, bu anayasanın yapımında monarkın gücünü öyle simgesel bir güç olmadığını bize gösteriyor. Demokratik asli kurucu iktidar, monokratik asli kurucu iktidarın tam karşısı olarak kaynağını bir kişinin iradesinden değil ama ulustan ya da halktan alan iktidara verilen isim. Demokratik asli kuruculuğun sahibi halk ya da ulus oluyor. Monokratik asli kurucu iktidarda ise monokratik asli kuruculuğun sahibi monark ya da iktidar. Misak anayasa biçiminde olduğu zamanda bu monarkın yanına temsili nitelikte bir parlamentonun eklenmesi söz konusu. Bütünüyle ulus değil. Demokratik asli kurucu iktidar, anayasaların bir toplum sözleşmesi olduğu anlayışına dayalı olan iktidardır. Bu nedenle anayasaların, ulusu, halkı temsil eden bir anlayışla yapılması gerektiğini söyler. Demokratik asli kuruculuk tek bir biçimde ortaya çıkmaz. Yani bu iktidarın sahibi olan ulus, anayasayı tek bir biçimde yapmaz. Demokratik asli kuruculuğu ya da demokratik asli kuruculuğa dayalı anayasa yapımını birden fazla biçimi olabilir. Birincisi halkın belli aralıklarla seçtiği yasama ve yürütmeyi denetlemek yetisiyle donatılmış olağan parlamentoların anayasayı yapması biçiminde ortaya çıkabilir.

Örneğin 1924 TC anayasası, 2012 Macaristan anayasası olağan parlamentonun yani anayasayı yapmak amacıyla yani bu amaçla sınırlı olarak oluşturulmamış bir parlamentonun yapmış olduğu anayasalara örnek

olarak verilebilir. İkinci bir asli iktidar kullanım biçimi halkın ya da ulusun anayasayı yapma amacıyla seçtiği anayasayı hazırlayan ve kabul eden veya bu yetkiye sahip olan yalnızca bu amaçla kurulmuş bir kurucu meclis yoluyla anayasayı yapmasıdır. Burada da ikili bir ayırım yapmak mümkün. Yani kurucu meclis yoluyla, demokratik asli meclis yoluyla kuruculuğun kullanılması yani anayasanın yapılması biçiminde olabilir. 1. Konvansiyon sistemi ya da başka deyişle Amerikan sistemi 2 Kurucu meclis sistemi ya da Fransız sistemidir. Bunların ortak özellikleri; her iki sistemde de meclis yalnızca anayasa yapmak amacıyla oluşturulur. Bu iki sistemi birbirinden ayıran yön; Amerikan sisteminde yani konvansiyon sisteminde, bu meclisin yalnızca anayasayı hazırlamak ve kabul etmek yetkisiyle sınırlı bir yetkiye sahip olması. Fransız sisteminde ise bu yetkiye ek olarak kurucu meclisin, olağan meclislerin sahip olduğu yasama ve hükümetin denetleme yetkilerine de sahip olmasıdır. Biri yalnızca anayasayı hazırlama ve kabul etme yetkisine sahip diğeri bu yetkinin yanında olağan meclislerin sahip olduğu yasa yapma ve hükümeti denetleme yetkilerine de sahip. İlk defa kurucu meclis yoluyla anayasaların yapılması yöntemi ABD’de ortaya çıktı. Hatta ABD ortaya çıkmadan önce 13 sömürge bağımsızlıklarını kazandıktan sonra her biri ayrı ayrı kendi anayasalarını yaptılar. Bu anayasaları konvansiyon sistemi ile yaptılar. 1787 ABD anayasası da yine konvansiyon sistemi ile yani kurucu meclis yoluyla yapılmış bir anayasadır. Fransız yöntemi ile oluşturulan kurucu meclis ise Fransız Devriminden sonra yapılmış kurucu meclis ile karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede 1791-1848-1875 anayasaları kurucu meclis usulü ile yapılan anayasalardır. Bu kurucu meclislerin bir başka önemli özelliği bunların özel bir konu için anayasayı yapmak için seçilmiş ve bu görevleri de bittikten sonra kendiliğinden dağılan meclisler olmasıdır.

20 ve 21.yy’da yapılan anayasaların çok önemli bir bölümünü kurucu meclis yöntemi ile yapıldığını görüyoruz. 1988 Brezilya, 1991 Kolombiya, 2005-2010 Kenya, 1193 Kamboçya, 2003 Ruanda, 1997 Tayland anayasaları da kurucu meclis yöntemine göre yapılan anayasalara verilecek örneklerdir. Bunlar tüketici biçimde sayılmış örnekler değil çok sayıda başka anayasa da kurucu meclis usulüne göre bu anayasalarını yaptılar. Günümüzde çok yaygın olarak görülen bir yöntemdir. Anayasanın bu iş için seçilmiş olan özel bir meclis tarafından hazırlanması ve kabul edilip yürürlüğe girmesi yöntemi. Üçüncü bir yöntem; Yalnızca kurucu meclisin anayasayı hazırlayıp kabul edip yürürlüğe sokması değil, kurucu meclisin anayasayı hazırlayıp kabul ettikten sonra bunun halk oylamasına sunulması yoludur. En demokratik yol budur. Çünkü halk anayasanın yapımına yalnızca kurucu meclis üyelerini seçmek yoluyla değil aynı zamanda bu meclisin hazırladığı anayasayı birde halk oylaması ile kabul etmek yoluyla iki aşamada dahil olur. Kurucu meclisin hazırlayıp kabul ettiği anayasanın sunulduğu halk oylamasına da **kurucu halk oylaması ya da kurucu referandum** deniliyor. 1793 ve 1946 Fransız anayasaları aynı zamanda 1978 İspanyol anayasası bu yöntemle göre kabul edilip yürürlüğe giren anayasalara vereceğimiz örnekler.

Halk oylamasına gerek görülmesinin nedeni: Kurucu meclis yönteminin demokratikliğinin özellikle 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren kuşkuyla yer vermesi bunun eleştirilmeye başlanması. Çünkü deniliyor ki; doğrudan halkın oyuna başvurma olanağı varken, sadece halkın temsilcilerinin oyu ile anayasanın yapımında yetinmek, gerekli değildir ve anlamlı da değildir. Günümüzde de çok demokratik olmayan mesela Macaristan 2012 anayasası çok demokratik olmayan anayasa yapım süreçlerinin dışında 20.yy’ın sonları ve 21.yy’dan itibaren yapılan anayasaların hemen hemen tümünde hem kurucu hem halk oylamasının bir arada olduğunu görüyoruz. Kurucu meclisin olmadığı anayasa yapım süreçlerinde bile halk oylamasının mutlaka yer aldığına tanık oluyoruz. Kurucu halk oylaması denilen yöntem, günümüzde en çok karşılaştığımız demokratik asli kuruculuk yöntemlerinden biri.

Dördüncü olarak: Bu da aslında **asli kuruculuk yöntemi**, ama **içeriği bakımından daha az demokratik bir asli kuruculuk yöntemi**. İktidarı, belli bir dönemde elinde bulunduranların hazırladıkları anayasa taslağını halk oylamasına sunulmasıdır. Burada temsili bir parlamentonun yapmış olduğu bir anayasadan söz etmiyoruz. Yürütmenin, hazırladığı bir anayasayı halk oylamasına sunmak yoluyla yürürlüğe konmasından söz ediyoruz. Bu halk oylaması belli bir tartışma ortamı gerekmeden gerçekleştirildiyse yani demokratik halk oylamasının gereklerini tam olarak yerine getirmiyorsa biz buna plebisit kuruculuk diyoruz. Anayasanın halk oylamasına sunulması yoluyla kullanılması kuruculuktur. Bu nitelikteki anayasa yapımına biz **plebisit kuruculuk** diyoruz. İktidarı belli bir dönem elinde bulunduranların hele bir de demokratik bir tartışma ortamı yaratmadan hazırladıkları anayasa taslağını halk oylamasına sundukları asli kurucu iktidar biçimine biz plebisit kuruculuk diyoruz. 1799 Napolyon Bonapart ve 1852 ve 2.Napolyon anayasaları aynen bu şekilde yapılan anayasalardır. Fransa’daki bu her iki Napolyon’un yapmış olduğu anayasalarda plebisit halk oylamaları yoluyla yürürlüğe

giren anayasalar olduğu için ve Napolyonların yapmış oldukları anayasalar oldukları için bu anayasaya ve bu biçimdeki anayasacılığa **Bonapartist Anayasacılık** denir.

Bonapart 1799 anayasası için bir komisyon kuruyor. Komisyon üyelerini de kendisi atıyor ve bu komisyon Bonapart bağlı olarak çalışıyor. Anayasa metni hazırlanıp halk oylamasına sunuluyor. Bu anayasa metni üzerinde özgür bir tartışma ortamı yaratmıyor ve bu metnin serbest bir şekilde değerlendirilmesine izin verilmiyor. Bu şekilde yapılan halk oylaması ile 1799 anayasası yürürlüğe girmiş oluyor. Daha yakın tarihte Bonapartist anayasacılığın izlerini taşıdığını söylenen bir başka anayasa ilse 1958 Fransız anayasasıdır. 1958 Yılında Fransa da Cezayir savaşı nedeni ile bir darbe oluyor. Asli kuruculuk yetkisi Charles Degol'un eline veriliyor. Bu anayasayı yaparken birtakım ilkeleri de göz önünde bulundurması öngörüyor, bir takım sınır çiziyor. Bu ilkeler; 1.yasamanın ve yürütmenin genel oyla çıkması, 2. yargı bağımsızlığına dayalı olarak yargının kurulması 3. Güçler ayrılığının öngörülmesi, hükümetin parlamento önünde sorumlu tutulması başka ifadeyle salt başkanlık sistemine dayalı bir anayasa yapılmaması gibi ilkeler öngörülüyor. Charles Degol, buna göre anayasayı hazırlıyor. Plebisitten farklı olarak bu hazırlanan anayasa serbest bir kamuoyu tarafından tartışılıyor. Halk oylamasında da %80 oyla kabul ediliyor. İktidarı belli bir dönemde elinde bulunduranların yapmış olduğu ve arkasından da halk oylamasına sunulan bir anayasa olması nedeniyle de bir örnek olarak verdim. Asli kurucu iktidar bakımından en demokratik anayasa yapım biçimi **1**. Bu anayasayı bir kurucu meclisin yapması **2**. Bu anayasayı kurucu meclis hazırladıktan sonra bunu halk oyuna sunulması. Buna karşılık bu anayasanın nasıl yapılacağı konusunda ne tür unsurların olması ve halkın anayasa yapımına hangi yollarla katılması konusunda 20. yy'ın sonundan itibaren çok daha geniş araçlar dizisi ortaya çıktı. Anayasa yapımına ilişkin olarak özellikle Venedik Komisyonu'nun bir raporu son derece önemli. Birincisi 2005 tarihli ve ikincisi 2011 tarihli Venedik Komisyonu raporları. Her ikisi de anayasa yapımına ilişkin temel ilkeleri ortaya koyan raporlar. Venedik Komisyonu, bu iki raporda da belirli bir anayasa yapım yöntemi önermiyor. Anayasa illa şu şekilde yapılacak diye bir yöntem önermiyor. Ancak anayasanın, meşru bir anayasa olabilmesi için anayasa yapım sürecinin bazı unsurları bünyesinde taşıması gerektiğini belirtiyor. Kurucu meclis oluşturulacak dedik. Ama bu kurucu meclisin de birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Çünkü anayasanın meşru olabilmesi ve meşruluğunun güçlü olabilmesi ve kurucu iktidarın demokratik bir nitelik taşıyabilmesi için o toplumdaki bütün siyasal güçler ve sivil toplum arasında gerçek bir uzlaşmaya dayalı olarak o anayasanın yapılması gerekir. Yine bu anayasanın içerik bakımından da dengeli olması, kendi içinde de bir iç uyumunun olması mutlaka gerekir Bu yapımın saydam bir nitelik taşıması gerekir. Saydamlık, demokratik bir düzende son derece önemli. Demokratik bir düzende yürütme organı, idare, yasama, yargı organı saydam olmak zorunda Bu aynı zamanda hesap verebilirliğin de gereği. Demokratik devletin en temel ilkelerinden biri olan bu saydamlık ilkesi, demokratik asli kurucu iktidar bakımından da aranır. Anayasa yapım sürecinin mutlaka saydam olması, iyi niyete dayanması mutlaka toplumun belli bir kesimini ötelemeyi, anayasa yapım süreci dışında bırakmayı, onların haklarını ya da özgürlüklerini sınırlamayı amaçlamaması gerekiyor. Aynı zamanda bilgi ve uzmanlığa da dayalı olarak yapılması gerekiyor. Halkın katılımı da bu konuyla ilgili olan uzmanların da anayasa yapımına dahil olmasını gerektiriyor.

Demokratik bir anayasa yapım sürecinin başarıya ulaşabilmesi için aslında 3 temel unsur vardır.

1. Anayasanın yapım sürecine halkın dahil edilmesi. Halkın kurucu meclis üyelerini seçmek, halk oylamasında oy vermek ve başka yollarla da katılabiliyor.
2. İfade özgürlüğünün tam olarak sağlanması; anayasanın hangi konuları nasıl düzenleyeceği konusunda yurttaşların görüşlerini serbestçe ifade edebilmelerinin sağlanması. Böyle bir anayasanın içeriği konusunda, anayasanın yapım süreci konusunda yurttaşlar eğer ifade ettikleri görüşlerin sonucunda yurttaşlar eğer suçlamaya maruz kalacaklarsa, böyle bir ihtimal varsa, soruşturmaya uğrayacaklarsa, bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklarsa, burada anayasa yapım sürecine serbest bir şekilde katılmasından söz etmemiz mümkün değil. O nedenle anayasa yapım sürecinde yurttaşların normal koşullarda ceza kanununun bir unsuru olabilecek düşünce açıklamalarını da serbestçe ifade etmelerini sağlayacak bir ortamın olması gerekir. Bir yerde parlamento üyelerine sağlanan yasama sorumsuzluğunun anayasa süreci ve anayasa ile sınırlı olmak üzere bütün yurttaşlar bakımından sağlanması gerekir ki yurttaşlar bu sürece aktif bir biçimde katılabilirler.
3. O ülkede anayasa yapım aşamasında genel bir güvenlik ortamının bulunması. Yurttaş tam bir ifade özgürlüğü ile anayasaya ilişkin düşüncelerini açıklayabilmeli de bundan dolayı da bir can ve mal güvenliğinden endişe etmemelidir.

2011-2013 Yılları arasında TBMM çatısı altında yeni bir anayasa yapım sürecinden bahsetmiştim. Bu süreç içerisinde TBMM bu anayasaya ilişkin bir web sitesi kurdu. Bütün yurttaşlar, anayasaya ilişkin görüşlerini

paylaşımlar. Bu web sitesi için TC kimlik numarası girilmesi istenmişti. Yurttaşın görüşü yüzünden hakkında dava açılmayacağı ve suçlanmayacağı bundan dolayı cezai yaptırımla karşılaşmayacağı hiçbir güvencesi yok. Milletvekillerine tanınan yasama sorumsuzluğu yurttaşlara tanınmadı. Haliyle o süreçte bu düzen bir aldatmaca oldu. Olması gereken ifade özgürlüğü bu süreçte sağlanamamış olması. Halkın anayasaya desteği ne kadar yüksekse o anayasa o kadar meşru kabul edilir. Halkın desteğinin anayasanın meşruiyet derecesini artırmasının yanı sıra o anayasayı sürekli, daha sağlam, güçlü bir demokrasi haline de getirir. O nedenle anayasanın halk desteğine sahip olması son derece önemlidir. Anayasa üzerindeki halk desteğinin büyük ya da geniş olmasının gereği ise anayasanın hem yapım sürecine hem anayasanın içeriğine olabildiği kadar dahil olmasıyla mümkün olur. 1970'lere kadar anayasa yapımı, işin uzmanlarının bir meselesi olarak gözükiyordu. Bu siyasal partiler ve uzmanlar arasındaki eş güdüm içinde ortaya çıkıyordu. Ancak 20.yy'ın sonlarından itibaren halkın anayasa yapım sürecine yalnızca kurucu meclisler, halk oylaması yoluyla değil hem daha doğrudan hem de anayasanın yazımından önce yazılma aşamasında ve yazımından sonra farklı biçimlerde dahil olmasını sağlayacak araçlar ortaya çıktı. Halk bu anayasanın yapımına farklı biçimlerde ve değişik süreçler içinde katılırsa halkın o anayasaya desteği artar, halk desteği artması anayasanın meşruluk derecesini artırır. Anayasanın meşruluk derecesinin artması o anayasanın dayanıklılığını artırır. Bu da kuşkusuz ki daha sağlam bir demokrasi için bir temel oluşturur. Halkın anayasa yapılmasına karar verildikten sonra anayasanın yapımı konusunda eğitilmesi bir araç olarak ortaya çıktı.

Bu örneğin, Güney Afrika'da, Eritre'de uygulandı. Halk anayasanın yazılmasından önce ve yazılması sırasında, anayasanın ne olduğu, yapım sürecinin ne olacağı ve yine anayasanın üstünlüğü ve demokrasinin genel olarak nasıl işlediği ya da işleyeceği üzerine bir eğitime tabi tutuldu. 1997 Eritre'de, okuma yazma oranı düşük olmasına rağmen halkın bu yeni anayasanın yapım sürecinde farkındalığının artması, yeni anayasanın içinde temel ilkelerin ne olabileceği bakımından aydınlatılması bakımından son derece önemli bir rol oynadı. Bu 20. yy'ın sonlarından itibaren bir katılım biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa yapım sürecine halkın doğrudan katılımını sağlayacak.

İkinci bir araç ise **sosyal medyadır**. 2011 Yılında İzlanda'da yeni bir anayasanın yapım süreci başladı ama sonuçlanmadı. Anayasayı yazacak olan kurul bir internet sitesi kurdu. Sosyal medya, anayasa yapım sürecinde halkın bu süreçte bilgilendirilmesi bakımından önemli. İkincisi kendi görüşlerini doğrudan paylaşabilmesi bakımından son derece önemlidir. Ancak sosyal medyanın, halkın katılımını ve anayasa yapımı konusundaki farkındalığını arttırmak konusunda güçlü bir araç olması için bir takım ön gereklerin olması gerekiyor. Bunlar; halkın çok büyük bölümünün internete ulaşımının sağlanması gerekir. Yine halkın çok önemli bir bölümünün belli başlı sosyal paylaşım sitelerine dahil olması gerekir. Bu türlü altyapının yeterli olmadığı ülkelerde kuşkusuz sosyal medyanın halkın anayasanın yapım sürecine katılımını rolünün son derece düşük olacağını söyleyebiliriz. Ülkelerin gelişmişlik düzeyin son derece önemli olduğunu görüyoruz.

Halkın anayasanın yapımına katılımını doğrudan sağlayan bir başka araç, **halk girişimidir**. Bunu doğrudan ya da yarı doğrudan demokrasi araçlarında ele almıştık. 20.yy'ın sonlarından itibaren yapılan anayasalara yurttaşlara anayasa metninde görmek istedikleri maddeler ya da düzenlemelere ilişkin teklif verme olanağı tanınıyordu. Bunun ilk örneği Papua Yeni Gine anayasasıdır. Ama en iyi uygulama; 1988 Brezilya anayasasına halk 64 bin adet dilekçe ile katkı vermiş. 1997 Güney Afrika anayasası yapılırken de halk 2 milyon dilekçe vermiş. 1998 Arnavutluk anayasasında hem 2005-2010 Kenya anayasalarında da bu imkanını tanındığını görüyoruz. Bu halk girişimi, yatay ve dikey güçler ayrılığı konusunda yine eğer o ülke içinde önemli ise azınlık gibi konularda anayasanın hangi yönde düzenleme yapması gerektiğine ilişkin somut öneriler sunuyorlar. Bu halkın psikolojik olarak kendisini bu sürece dahil etmesi bakımından önemli bir araç. Ancak bu yöntemin aynı zamanda bu önerilerin dikkatlice analiz edilerek anayasa yaparken de kullanılması gerekir. Genel olarak bu yöntemi kullananları bu teklifleri anayasasının yazılımında çok büyük ölçüde göz ardı ettiklerini söyleyebiliriz.

2011-2013 Türkiye'deki anayasa yapım sürecinde de bu halkın kanun teklifi vardı. Uzlaşma komisyonu, üçer milletvekili bulunmak şartıyla tüm siyasal partilerden oluşturuldu. Web sitesi yoluyla gelen teklifler dikkate alınmadı. Türkiye'de bu halk girişimi kopyala yapıştır biçiminde, aynı önerilerin farklı hesaplardan binlerce kere web sitesine gönderilmek yoluyla kötüye de kullanıldı. Bu girişim sürecin manipülasyonuna son derece olanak veren bir girişimdir. En demokratik olan anayasanın bir kurucu meclis tarafından yapılmasıdır. Nitelik Venedik komisyonu da hem 2005 hem de 2011 tarihli raporlarında, kurucu meclisin demokratik bir anayasa yapımı için en demokratik yöntem olduğunu belirliyor. Kurucu meclisin olağan meclise tercih edilmesinin nedeni; olağan meclisin yapısıyla kurucu meclisin yapısı birbirinden farklı. Olağan meclislere ilişkin seçim

sistemlerinde örneğin ülke ya da bölge barajını görürüz. Bunun amacı yürütmeye bir istikrarın sağlanması. Bir siyasal partinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesini kolaylaştırmak. Ya da parlamentonun çok sayıda siyasal partiden oluşmasını sınırlamak. Kurucu meclisin amacı, anayasayı hazırlamaktır. Bunun dışında başka bir işi amacı yok. Böyle olunca da kurucu meclisi oluşturacak seçimlerde kuşkusuz ki bir ülke ya da bölge barajına ihtiyaç yok. Kurucu meclis olabildiği kadar toplumun bütün kesimlerini temsil edebilecek bir temsil taşımak. Bu meclisin hazırlayacağı anayasa toplumun her kesiminin katkı verdiği, içinde bulunduğu bir anayasa olsun. O zaman bu anayasanın meşruluğu artar. O kadar anayasanın dayanaklılığı artar. Toplumun farklı kesimlerinin uzlaşması sonucunda yazıldığı ve ortaya çıktığı için. Olağan parlamentolar için yapılan seçimler, toplumun tam olarak parlamentoya yansıtıldığı seçimler olmaz. Kadınlar, bazı etnik dinsel kesimler ya da ha az ya da hiç temsil edilmez. Ama kurucu meclislerin toplumun bütününe yansıtan bir izdüşüm olması için olağan parlamentolarda temsil edilemeyen azınlıkların bu kurucu meclislerde temsil edilmesi gerekir. Bu sebeple olağan meclisle parlamento aynı şeyi ifade etmez. Bunların yapıları da birbirinden farklı olur. Bu sebeple kurucu meclisler, olağan meclislerden daha olması gerektir. Olağan parlamento ile kurucu meclis arasındaki bir başka fark, olağan parlamentolar genellikle çok sayıda üyeden oluşur. Kurucu meclislerin, toplumun her kesimini temsil etmeli ama aynı zamanda anayasa yapım işlevini hakkıyla yerine getirebilmek için çok kalabalık olmamalı. Ne az sayıda olmalı ne de çok kalabalık olmamalı. Çünkü ne kadar kalabalık olursa o meclis içinde uzlaşmak o kadar zor olur. Meclis ne kadar kalabalık olursa o anayasa metninin içinde iç uyumu sağlayacak uzlaşma o kadar güç olur. O yüzden yeni bir anayasanın böyle sınırlı sayıda üyeden oluşan bir kurucu meclis tarafından yapılması uygundur. Genellikle anayasa yapım süreci başladığında buna ilişkin bir süre sınırı konmaz. Anayasa yapım süreci bir acele sürece denk getirilmemeli. Halk anayasanın ne olduğunu anlayabilmeli. Halk, yeni anayasanın içinde olması istenen temel ilkeler konusunda halk eğitilmelidir. Siyasal aktörler bilgilendirilmeli, yine halkın somut öneriler getirilmesine, özellikle bölünmüş toplumlar bakımından toplumun bir uzlaşmaya olanak verecek ölçüde uzun bir süre olması gerekir. Anayasanın başlangıçtan yapımına kadar geçen süre içerisinde halkın konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesini, farkındalığın artırılmasını, siyasal aktörlerin işin içine girmesini, bilgilendirilmesini, halkın anayasaya yönelik somut öneriler getirmesini, bu önerilerin hakkıyla değerlendirilmesini, toplumun uzlaşmadığı konularda oydaşma sağlayacak bir süre de yapılması gerekiyor diyor Venedik komisyonu. 2008 Tarihli Myanmar anayasası buna örnektir. Bu anayasa 17 yılda yapıldı. Bu süre çok uzun bir süre. Bunun aşırı süre alması halkın konuya ilgisini ortadan kaldırır. Daha sonra bu anayasa darbe ile ortadan kalktı. 1938 Romanya anayasası bunun tam tersidir. Anayasa Komisyonunun ilan edilmesinden 9 gün sonra anayasa metni tamamlanır. Bu taslağın hazırlanmasından 3 gün sonra metin halk oylamasına sunuluyor. Haliyle 12 gün içinde yeni bir anayasanın hazırlanmasıyla bunun yürürlüğe girmesi arasında 12 günlük bir süre vardır. Anayasa hukukçuları istatistiki bir çalışma yapmışlar. Bunlardan birisi 1789 ile 2005 yılları hazırlanmış olan hazırlanmış anayasalara bakmışlar. Bu süre içerisinde 148 tane yeni anayasa yapılmış. Bu anayasaların yapılış süreçlerinin ortalaması 16 ay. Önemli olan anayasa yapımının gereğinden kısa gereğinden uzun bir süre almaması diyebiliriz. 2012 Tarihli Macaristan anayasası kötü anayasa yapım sürecine bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. İyi anayasa yapım sürecine örnek olarak 1988 Brezilya anayasası ve ikincisi en temel örnek olarak 1997 tarihli Güney Afrika anayasasına örnek olarak verebiliriz.

02 Mayıs 2023

Monokratik kurucu iktidar özellikle 19.yy'da yapılmış ya da yapılan anayasalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir anayasa yapım yöntemi. Demokratik asli kurucu iktidar ise farklı biçimlerde ortaya çıkabiliyordu. Asli kurucu iktidarın demokratik olabilmesi için halkın o anayasa yapım sürecine çeşitli biçimlerde o anayasa yapımının çeşitli aşamalarında dahil olması gerekiyordu. Halkın anayasa yapımına katılacağı iki önemli araç var. 1. Halk, parlamento yoluyla yani kendi seçtiği temsilcileri yoluyla ki bu dolaylı bir katılım yöntemi, anayasa yapımına katılabilir. 1787 ABD anayasasından beri karşımıza çıkan bir yöntem. Bu yöntem de kendi içinde ikiye ayrılabilir. 1. Halk, bir anayasayı yapma göreviyle bir meclis seçebilir. Buna **kurucu meclis** denir. Ya da halk yasama görevini yerine getirmek üzere bir meclis seçmiştir. Bu meclis aynı zamanda anayasayı yapar. Her iki durumda da halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir organın anayasayı yaptığını görüyoruz. 2. En çok karşımıza çıkan durum ise **halk oylamalarıdır**. Eğer hem parlamento hem de halk oylamasının bir arada bulunduğu süreçte anayasa yapıldıysa kuşkusuz ki bu anayasanın demokratik meşruiyetini artırıcı bir durumdur. Çünkü halk iki farklı aşamada da birinde temsilcileri aracılığı ile diğerinde doğrudan o anayasaya olumlu ya da olumsuz oy vermek yoluyla o anayasanın yapımına katılmış oluyor. Halk oylamaları en çok kullanılan yöntem

olmasına rağmen en fazla da mesafeli durmamız gereken yöntemlerden birisidir. Halk oylamaları hem anayasanın yapımında hem de başka kararların alınmasında demokratik olmayan yönetimlerinde sıkça kullandığı bir araçtır. Halk oylamalarının manipüle edilmesi son derece kolaydır. Yalnızca halk oylamaları bakımından değil, diğer yarı demokrasi araçlarının da manipüle edilmeye yatkın çok kolay araçlar olduğunu söylüyoruz. Bu 2 yöntemin dışında özellikle 20.yy'ın sonlarından itibaren demokratik asli kurucu iktidarı başka araçlarla birlikte halkın anayasa yapımına katıldığını görüyoruz.

Bunlar; 1. Yeni bir anayasa yapılmasına karar verildikten sonra ama bu anayasa yazımı başlamadan önce buna ilişkin olarak halkın bilgilendirilmesi bu halkın katılımını anayasa yapım sürecine ilgi duymasını ve bilinçlenmesini sağlayan bir yoldur. Halk çeşitli yollarla anayasa yapım sürecine dahil ediliyor. Geçen hafta açıkladığımız kırsal kesimde halkın katılımını sağlayan toplantılar yoluyla ya da okullarda anayasa yapımına ilişkin kompozisyon ödevleri vermek ya da yarışmalar sağlamak yoluyla farklı halk kesimlerinin bu sürece katılımı sağlanabilir.

2. Anayasa yapım sürecinde metnin yazımı aşamasında kanun teklifi yoluyla, halk girişimi yoluyla halkın anayasada görmek isteyeceği somut düzenlemeleri toplamak biçiminde olabiliyordu. Ama gerçekten halkın katılımını sağlayacak bir yol olabilmesi için halk girişimi ile gelmiş olan önerileri toplayacak bunları analiz edecek ve anayasa metninin içine de ekleyecek bir sürecin olması gerekiyor. Aksi halde bu halkın kendi fikirlerini söylediği ama bu fikirlerin hiç dikkate alınmadığı bir sonuç yaratacaktır. Demokratik asli kurucu iktidarın gerçek amacının bu olmadığını söyleyebiliriz. Günümüzde anayasa yapım sürecinin farklı aşamalarında ve çeşitli araçlarla halkın anayasa yapımına katılımının sağlandığı görülüyor. Bir anayasa yapımı ne kadar demokratik olursa o anayasa metni de o kadar demokratik olur mu? Bir anayasa yapımı ne kadar otoriter ise o anayasa metni de o kadar otoriter olur mu? Bütün anayasa süreçlerine bakıp ve bu anayasanın metnine bakıp şöyle bir genelleme yapabiliriz. Anayasa yapım süreci ne kadar otoriterse metnin içeriğinin de bu yapım sürecine paralel bir nitelik taşıdığını genel olarak söyleyebiliriz. Kuşkusuz ki bunun istisnaları var. Ama bir anayasa ne kadar yürütme odaklı yapıldıysa anayasanın kendisinin de genellikle güçlü yürütme yönünde bir anayasa olduğunu görüyoruz. Anayasa yapımının yine ne kadar çok aşamasında halkın katılımı sağlandıysa o anayasanın o kadar demokratik nitelik taşıdığını söylemek mümkün.

Demokratiklik: 1. Temel hak ve özgürlükler listesinin geniş ve ayrıntılı olmasının 2. Siyasal iktidarı sınırlayacak araçların, kurumların çeşitlenmesinden anlıyoruz. 3. Yine bu süreç ne kadar benimsenmişse o anayasanın içinde yer alan özgürlükler listesinin o kadar geniş olduğunu ve bu hak ve özgürlükleri koruyacak mekanizmaların o kadar çeşitli ve ayrıntılı olduğuna tanık oluyoruz. Demokratik olmayan bir anayasanın olumsuz yönü; metnin kendisinin de demokratik olmaması. Metnin kendisinin de devlet, otorite odaklı olması. Buna karşılık katılımcı bir anayasa tasarımı metnin iç tutarlılığını baltalayabilir. Yani anayasa yapımına ne kadar çok aktör dahil olursa bu kuşkusuz ki o toplumun iç dinamikleriyle de ilgili bir konu. Bir toplum ne kadar bölünmüşse bu unsurların hepsinin anayasa yapımına katılması demek o anayasa metninin iç tutarlılığında bir sorun ortaya çıkması sorununu yaratabilir. Çünkü anayasa yapımına katılan bütün aktörler birincisi kendilerini anayasa metninde görmek isterler. İkincisi kendi özgürlüklerini ya da haklarını güvence altına almak isterler. Böyle bölünmüş toplumlarda toplumun hiçbir kesimi diğerine tam olarak güvenmez. Kendisini anayasa metninde görmek ister. Olabildiği kadar ayrıntılı bir düzenleme yapmak biçiminde görür. O düzenleme ne kadar ayrıntılı olursa o toplum kesimi bakımından o kadar büyük bir güvence ortaya çıkar. Böylelikle anayasa yapımının demokratik olması toplumun farklı kesimlerinin anayasa metninin güvence altına alması o anayasanın ayrıntılı olması yani kazuistik olması sonucunu doğurur. Yine kamuoyunda katılım olanaklarının episodik olduğu yani düzenli olmadığına ilişkin yaygın bir kanı varsa o zaman normalde anayasa dışı siyasetin konusu olacak kurumlarda anayasa metninin içine eklenebilir. Amaç farklı kesimlerin kendini güvende hissedeceği kurumların düzenlemeleri anayasa metnine eklemek. Daha türdeş olan toplumlarda, anayasaların kısa olması mümkün olabilir. Ama toplum ne kadar karmaşıkla ne kadar bölünmüşse ve anayasa yapım süreci ne kadar demokratik ise her toplum kesimi o anayasada kendini görmek ister ve güvence altına almak ister. Birincisi hak ve özgürlüklerin tanınması, ikincisi onları güvence altına alacak düzeneklerin anayasada yer alması üçüncüsü siyasal iktidarı sınırlayacak yine araçların anayasada yer alması yoluyla. Bunlar anayasada yer aldıkça anayasa maddelerinin ve sözcüklerinin sayısı artar. Haliyle kazuistik bir hale gelir. 18.YY'ın Amerikan toplumu türdeş bir toplumdur. Bugünkü Amerikan toplumu bölünmüş bir toplumdur. ABD'de bugün bir anayasa yapılacak olsa 1787 anayasası gibi kısa öz bir anayasa olmayacaktır. Hala bu anayasanın sürdürülmesinin nedeni; anayasadaki bu eksiklikleri boşlukları federal yüksek mahkemenin vermiş

olduğu kararlarla doldurmuş olmasıdır. 21.YY'da yapılan anayasaların uzun ve ayrıntılı olmasının en önemli nedeni budur. 1988 Brezilya anayasası 246 maddeden oluşur. Yine 243 maddeden oluşan Güney Afrika anayasası. Her ikisi de demokratik asli kurucu iktidar tarafından yapılan anayasa olmasıdır. Demokratik asli kuruculuk ne kadar genişse onun yaptığı anayasaların sözcük ve madde sayısının artacak olma ihtimali içindedir. Katılımcı ve kapsayıcı süreçlerle anayasayı yapanlar bütün yetkileri yasama organına devretmek yerine özerk kurum ve organlar yaratmaya yönelirler. Örneğin bir anayasa yapımı ne kadar katılımcı ve kapsayıcı ise o toplum ne kadar bölünmüş toplumsa örneğin çift meclis gibi, örneğin anayasa yargısı gibi federalizm gibi, siyasal iktidarı sınırlayan kurum ve araçların anayasada bulunma olasılığı o kadar fazladır. Bunların dışında da siyasal iktidarın mutlak olarak her şeye karar vermesini sınırlayacak siyasal iktidarı frenleyecek özerk kurum ve organlar da yaratılır.

Örneğin Ombudsmanlık kurumu gibi anayasada ayrıntılı olarak düzenlenmesi, merkez bankası özerkliğinin anayasada güvence altına alınması. Veya yürütme, idare içinde bağımsız ya da özerk kurumların oluşturulmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yine anayasada yer alması buna örnek verilebilir. Buna ilişkin yapılan araştırmadan çıkan sonuç; daha temsili daha kapsayıcı süreçlerden çıkan anayasaların serbest seçimler daha büyük bir siyasal eşitlik, sosyal adalet, temel hakların korunması ve siyasal iktidarın daha güçlü bir şekilde hesap vermesine ilişkin mekanizmaları içerdiği görülmüş. Demokratik anayasa yapım süreci aslında anayasanın içeriğini olumlu anlamda belirliyor. Anayasa daha ayrıntılı düzenlemeler içermesine rağmen anayasanın içeriğinin daha demokratik olması olasılığı sonucunu doğuruyor. Anayasanın demokratik bir kurucu iktidar tarafından yapılmasıyla bu anayasanın sürekliliği, dayanıklılığı arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Eğer bir anayasayı halk yaptıysa bunu sahiplenecektir. Asli kurucu iktidar ne kadar demokratikse onun ürünü olan anayasayı halkın ve gelecek kuşakların sahiplenmesi de o kadar mümkün olacaktır. Bunun örneği 1988 Brezilya anayasasında değişiklikler var ama halen yürürlükte. Yine demokratik anayasa yapımının en iyi örneklerinden birisi 1997 Güney Afrika anayasası benzer bir şekilde örnek verilebilir. Halen yürürlükte bu anayasa. Nabıbya anayasası da demokratik bir anayasa yapım süreci sonucunda yapıldı. Ama bu anayasalarının dayanıklılığı kısa sürdü. Tayland'ın 1997 anayasası yapılırken Tayland halkı bu anayasanın yapımına iki araçla katıldı. 1. Kurucu meclis üyelerini seçmek yoluyla 2. Halk oylaması yoluyla katıldı. Bu anayasasının aslında Tay ulusunu temsil eden anayasa olduğunu söylememiz mümkün olabilir. Buna karşılık bu anayasanın demokratik bir kurucu iktidar tarafından yapılması halkın bu anayasayı denetlemesinde bir araç işlemi görmedi. 2006 Yılında halk darbe yaptı ve anayasasını ortadan kaldırdı. Halk bu darbe sırasında anayasasını savunmadı.

Sonuç: Demokratik kurucu iktidar, anayasanın dayanıklılığını artırmakta mutlaka bir rol üstlenecektir. Kuşkusuz ki anayasa yapımına katılmış bir halk o anayasanın sürekliliği için mücadele edebilir. Ama bu mutlak bir sonuç değildir. Tersinden bakalım; 1947 Japon ve 1949 Alman anayasalarına bakalım. Her iki anayasada 2. Dünya Savaşından sonrada yapıldı. Her iki anayasanın yapımında 2.Dünya Savaşının kazanan dış güçlerin ve her iki devletin siyasal seçkinlerinin payı olduğu, ikisi tarafından hazırlandığı örneğin Japon anayasasında dış güçlerin ağırlığı çok güçlüdür. Japon anayasasının 1787Amerikan anayasası ile çok büyük benzerlikler taşıdığını görürsünüz. Bu Alman anayasasında da vardır. Haliyle demokratik asli kuruculuk ya hiç yoktur ya da son derece sınırlıdır bu iki anayasa bakımından. Ama anayasal düzen gayet sağlıklı yürümektedir. Demokratik bir düzen her ikisi bakımından da söz konusudur. İki toplumun demokratikliği birbirinden farklıdır. Her ikisi de demokratik devletin asgari koşullarını karşılamaktadır. Sonuç: Demokratik asli kuruculuk olmasa ya da çok sınırlı olsa bile o anayasaların sağladığı düzenin demokratik olarak devam etmesinin mümkün olduğunu bize gösteriyor. Bu anayasalar demokratik kurucu iktidar tarafından yapılmamış anayasalar ama anayasaların kendisi demokratik düzenlemeler içeren anayasalar. Buradan çıkarılabilecek bir başka sonuç şudur; anayasa, siyaset sahnesinin çerçevesini çizer. Buna ilişkin düzenlemeler getirir. Siyaset oyunun da temel kurallarını belirler anayasalar. Bu anayasaların içeriği kadar nasıl uygulanacağını da önemli olduğunu söylemeliyiz. Çok demokratik bir anayasa olabilir ama o anayasayı uygulayanlar anayasa hükümlerini göz ardı edebilir. Ya da bir anayasa otoriter ya da hak ve özgürlük odaklı olmak yerine otorite, devlet odaklı olabilir. Anayasayı uygulayanlar bunun içine yargı organı da dahil. O anayasayı olabildiği kadar hak odaklı yorumlayabilir. Olabildiği kadar özgürlük odaklı yorumlayabilirler. O otoriter ruhu da sınırlanmış olabilir. Bir anayasa son derece hak, özgürlük odaklıdır. Buna karşılık siyasal iktidar, yargı organları anayasanın bu genel rolünü genel havasını göz ardı ederler. Anayasayı otoriter bir çizgide belirlerler.

1982 Anayasası otorite odaklı, hak odaklı olmayan bir anayasa. 2001 Değişiklikleri ile o ruhun o genel havasının bir ölçüde değiştiğini iddia edebiliriz. Bu anayasayı yorumlama yetkisine sahip olanlar bu organı tam tersi bir eğilim gösteriyorlar. Haliyle her şey anayasa metni değildir. O anayasanın nasıl uygulandığı nasıl yorumlandığı da anayasa metni kadar önemli. Asli kurucu iktidar sürekli mi yoksa geçici bir iktidar mıdır? Yani anayasayı yapma işlevini yerine getirmekle birlikte ortadan kalkan bir iktidar mıdır? Bu konuda Türkiye de görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre; asli kurucu iktidar sürekli bir iktidardır. Yani anayasayı yapan gücün iktidarı asli kuruculuktur. Anayasada öngörülen usullere, yöntemlere bağlı olmamasıdır. Millet'in kurucu iktidarı bütün hukuki kurallardan, bütün hukuki sınırlamalardan bağıstır. Anayasanın kendisi kurulu iktidarlara bağlar. Ama kendisinin anayasayı yapan ulusu bağlamaz. Asli kurucu iktidar, demokratik düzende halka aittir. Anayasa metninin kendisi de eğer anayasayı değiştirme usulü varsa bu da ancak kurulu iktidarı bağlar, asli kurucu iktidarı bağlamaz. Bu görüşü günümüzde savunanlara göre asli kurucu iktidar, yalnızca bir hukuki boşluk doğması durumunda ortaya çıkamaz. Hukuki boşluk ne zaman ortaya çıkıyordu? Savaş, darbe, devrim olunca hukuki düzende bir kesinti ortaya çıkar. Bu kesintide durumunda kendisini gösterir. Ama bu görüşü savunanlara göre; asli kurucu iktidar sürekli bir iktidardır. Yalnızca savaş, darbe ya da devrim gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkmaz. Gerektiği durumlarda her zaman ortaya çıkar. Çünkü bu kuruculuk, ulusa ait bir kuruculuktur. Öyle bir kere yapılmakla ortadan kalkmaz. Bunun sonucunda, asli kuruculuğun hukuk dışı olması, onun hukuk çerçevesinin dışında ortaya çıkması. Onun hukukla açıklanmasının mümkün olmamasını anlamına gelir. Bu iktidarın sınırsızlığı, önceden konmuş bir hukuki norma bağlı olmaması sonucunu doğurur. Olağan bir durumda da asli kuruculuk işlevi yerine getirilebilir. Barış zamanlarında da yeniden bir anayasa yapabilir. Bunun karşında olanlar; asli kurucu iktidar, sürekli bir iktidar değildir. Eğer bir anayasa, kendi kurduğu anayasal düzende anayasayı değiştirme usulü öngörmüşse ve bu kurulu iktidarlardan birine de anayasayı değiştirme yetkisi vermişse, artık burada asli kurucu iktidar yeni bir anayasa yapamaz. Haliyle de yeni bir anayasanın yapılması, kabul edilmesi, yürürlüğe girmesiyle birlikte ortadan kalkmıştır. Asli kuruculuk ne zaman ortaya çıkmıştır? Asli kuruculuk olağan dönemlerde uykudadır. Ancak devrim, darbe, savaş gibi olağanüstü bir durumda ortaya çıkar. Bunun dışında olağan durumlarda asli kuruculuğun uykusundan uyandırmak mümkün değildir. Olağan durumlarda eğer anayasa, anayasayı değiştirme yükümlülüğünü düzenlediyse ve anayasayı değiştirme yetkisini de kurulu iktidar yetkisini kullanan organlardan birine verdiyse artık burada asli kuruculuk yetkisi kurulamaz. Yapılan her anayasal düzenleme, bir anayasa değişikliğidir. Yeni bir anayasa değildir. Bir anayasanın bütün maddeleri değiştirilmiş olsa bile bu değişiklik anayasanın öngördüğü anayasayı değiştirme usullerine göre ona bağlı olarak ve kurulu iktidar tarafından yani parlamento tarafından yapıldığı veya yapılacağı için bu anayasa yine yeni bir anayasa olmayacaktır. Mevcut anayasanın değiştirilmesi anlamına gelecektir. Bir anayasada değişmez maddeler varsa kurulu iktidar yine anayasada öngörülen kurallara uygun olarak değişiklik yapabilecektir. Bu değişmez maddelere dokunamayacaktır. Bunun dışındaki bütün maddeleri değiştirmiş olsa bile bu değişikliği tali, türev kurucu iktidar yapmış olacaktır. Yani bu asli kurucu iktidarın yaptığı bir anayasa olmayacak olup bir anayasa değişikliği olacaktır. Ergun Özbudun, asli kuruculuğun sürekli bir iktidar olduğunu, Kemal Gözler ise asli kuruculuğun anayasanın yapılması ile birlikte ortadan kalkan ancak olağanüstü bir durumun ortaya çıkması durumunda yeniden belirecek olan bir iktidar olduğunu ileri sürer. Hocamıza göre kuşkusuz ki demokratik asli kuruculuk, olağan dönemlerde de ulusun kendi anayasasını değiştirebilmesini gerektirir. Aksi takdirde bir darbe gibi bir olayı beklemek gerekir. Bu demokrasi ve demokratiklik anlayışı ile bağdaşan bir durum değildir. Eğer kurucu güç ulusta ise kurucu güç bu gücünü dilediği zaman kullanabilmelidir. Gerçek anlamda ulustan gelen bir istek varsa yeni bir anayasanın yapılabilmesi gerekir.

Bizde, monokratik bir asli kurucu iktidar tarafından (1876) da demokratik bir asli kurucu iktidar tarafından da yapılmıştır (1921-1924). 1876 Kanuni Esasi'den başlayalım. Bunu Abdülhamit yapmıştı. Cemiyeti Mahsusa adı altında özel bir kurul kurdu. Bu kurulun görevi, bir anayasa taslağı hazırlamaktı. Bu kurulun bütün üyelerini de kendisi seçti ve atadı. Bu kurul 2 asker, 16 sivil bürokrat ve 10 tane de ulemadan oluşuyordu. 28 üyelik bir kuruldu. Bu komisyon 1876 Kanuni Esasi'nin taslağını hazırladı. Hazırlarken de o dönemde yürürlükte olan yabancı ülke anayasalarına da baktı. Belçika, Polonya, Prusya anayasaları bu kurulun dikkate aldığı yabancı ülke anayasalarına örnektir. Tasarı hazırlandıktan sonra Heyeti Bukelanın onayından geçti. Padişaha geldi. Padişah kabul etti ve 23 Aralık 1876'da da ilan etti. Bu anayasa, tek kişinin iradesine dayalı, tek taraflı anayasa ve ferman bir anayasaya örnek bir anayasadır. 1921 Teşkilatı Esasiye kanunu; BMM yaptı. BMM, yeni bir anayasa yapmak amacıyla oluşturulmamıştı. Buna karşılık 1920 yılında BMM oluşturulurken, olağanüstü

yetkilere sahip bir meclis Ankara'da toplanacak denmişti. Anayasa yapımı da olağanüstü yetkileri de beraberinde gerektirir. Bu bağlamda 1921 tarihli anayasayı yapan BMM'nin bir kurucu meclis olduğunu ileri sürebiliriz. Haliyle bir kurucu meclis tarafından yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde yürürlükte bulunan 1876 Kanuni Esasi'nin, anayasayı değiştirme hükümlerine bağlı kalınarak yapılmadı. Asli kuruculuğu, BMM'nin kullandığını gösteren bir kurul bu. Haliyle 1921 Teşkilatı Esasi'nin demokratik bir kurucu iktidar tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü BMM, 23 Nisan 1920'de ilk açıldığı andan itibaren ulusu temsil eden bir parlamento olduğu için. 1924 anayasası, 2. TBMM tarafından yapılan ve kabul edilen bir anayasa. 1924'de yapılan TBMM seçimleri, olağan bir seçimde. Parlatentonun yenilenmesi biçiminde bir seçimdi. 1924 Anayasasını yapan 2. TBMM, bir kurucu meclis değildi. Olağan bir meclis tarafından yapılmış bir anayasadır. Ulusun temsilcilerinden oluşan demokratik bir anayasa yapımı olup ama kurucu iktidar tarafından yapılmamış bir anayasadır bu bakımdan. Halk oyuna sunulması ya da ulusun başka araçlarla 1924 anayasasının yapılmasına katılması söz konusu değildi. Bu anayasanın yapıldığı dönemde de halk oylaması ve parlatentonun anayasanın yapılması dışında da başka araçlarla halkın anayasa yapımına katılması söz konusu değildi. Bunlar 20.yy'ın son çeyreğinden sonra ortaya çıkan araçlar idi. Anayasa konusunda ilk girişim kanuni esasi encümeninden geldi. Yani TBMM'deki anayasa komisyonundan geldi. TBMM, bu anayasa taslağını hazırladı. Bunu hazırlarken de yine o dönemin yürürlükte olan batı anayasalarını göz önünde bulundurdu.

Örneğin 1875 Fransız anayasası ve 1921 Polonya anayasası. 9 Mart 1924'de bu taslağı anayasa taslağı hazırladı. Bunu TBMM genel kuruluna sundu. 20 Nisan 1924'de genel kurulda kabul edildi. Aynı yılın 23 Nisan'ında da yürürlüğe girdi. Demokratik bir kurucu iktidar tarafından yapılmış bir anayasa. Ancak kurucu meclis eliyle değil olağan bir yasama meclis eliyle yapılmış bir anayasadır. 1961 Anayasası, 1960 darbesinin ürünüdür. 27 Mayıs 1960'da Silahlı Kuvvetler, bir hükümet darbesi yaptılar. Bu darbe, düşük rütbeli genç subayların yaptığı bir darbedir. Mevcut iktidarın antidemokratik uygulamalarından rahatsızlık duyan ve demokratik bir düzen isteyen, seçimler yoluyla Demokrat Parti'nin iktidarı devretmeyeceğini düşünen bir grup subay tarafından yapılmış olan bir darbedir. Dönemin İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Ankara'ya getiriliyor. Bunlar bir rapor sunuyorlar. 1924 anayasasının bazı hükümlerini yürürlükten kaldıran bir sayılı kanunun çıkarıyor Milli Birlik Komitesi. Bu kanun Milli Birlik Komitesini Kuruyorlar. Bu komite TBMM'nin yetkilerini üzerine alıyor. Bu komitenin başkanı da devlet başkanı sıfatı aldığını belirtiyor. Burada anayasasızlaştırma vardır. 157 Sayılı kanun ile eski TBMM'nin yetkileri de yeni oluşturulacak olan kurucu meclise devrediliyor. Anayasayı yapma ve anayasayı hazırlama yetkisi bu kurucu meclisin görevi içerisinde yer alıyor. Bu kanuna göre bir süre sınır getiriyor anayasanın hazırlanmasına ilişkin olarak. 157 sayılı kanun anayasanın hazırlanacağı süreyi belirliyor ve anayasanın halk oylamasına karşı reddedilmesi durumunda yeni bir kurucu meclisi seçileceğini, bu meclisin yeni bir anayasa hazırlanacağını, bunun halk oylamasına sunulmayacağını, hemen yürürlüğe gireceğini ve bir an önce genel seçimlerin yapılacağını ve bu seçimler sonucunda oluşacak TBMM'nin en geç 29 Ekim 1961'e kadar sivil iktidarın oluşturulacağını belirtiyor. Bu kanun anayasanın yapımında belirli bir süre sınırı öngörüyor. Öngörülen süre içerisinde anayasanın yapılamaması, yapıldığı halde halk oylamasında reddedilmesi durumunda seçim yoluyla bir kurucu meclisin oluşturulacağını belirtiyor. Bu kurucuların adına da temsilciler meclisi denilmiş.

Üçüncü olarak da bu yeni oluşacak temsilciler meclisinin 29 Ekim 1961'de genel seçimler sonucunda oluşacak TBMM'ne bütün iktidarı belirtiyor. 61 Anayasasını yapan bu meclisin adı kurucu meclis, iki daldan oluşuyor; **1. Temsilciler meclisi** **2. Milli Birlik Komitesi**. Temsilciler meclis, çok dereceli bir seçimle belirlenen 256 üyeye sahip. Ayrıca Bakanlar bu temsilciler meclisinin içinde. Bu 256 üye toplumun çeşitli kesimlerinin kendi içlerinden gösterdiği temsilcilerden oluşuyor. Bunların içinden iller, siyasal partiler, Baro, Basın, yargı organı, üniversiteler, sanayi temsilcileri, gençlik kuruluşları, sendikalar, tarım kuruluşları gibi toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerini çok dereceli bir seçimle seçilip, temsilciler meclisinde yer aldığını görüyoruz. Bu kurucu meclis kurulduğu zaman bu milli birlik komitesinin sayısı, 37'den 23'e düşmüştü. Temsilciler meclisi 2'şer kişiden oluşan 2 komisyon kurdu. Birisi anayasa komisyonu diğeri de seçim yasası komisyonu. Çünkü kurucu meclisin görevi **1. Yeni bir anayasa yapmak** **2. Yeni bir seçim kanunu yapmaktır**. Bu amaçla temsilciler meclisinde 2 tane ayrı komisyonun kurulduğunu görüyoruz. Anayasa komisyonu, 1961 anayasa taslağını hazırlayan komisyon. Temsilciler meclisi kurulurken meclis dışında iki tane taslağın oluşturulduğunu görüyoruz. Bir tanesi İ.Ü. Hukuk Fakültesi tarafından oluşturulan taslak. Diğeri ise A.Ü. Siyasal Bilgiler fakültesi tarafından oluşturulan taslak. 61 Anayasasından çıkan sonuç SBF'nin metninden etkilenmiş olduğu.

Batı anayasalarından, 61 anayasa koyucu etkilenmiştir. Hazırlanan her bir anayasa maddesi öncelikle anayasa komisyonunda görüşülüp kabul edildikten sonra temsilciler meclisinde görüşülüp kabul ediliyor. Daha sonra Milli Birlik Komitesine gidiyor. Her ikisi de aynı maddede, aynı metinde anlaşırsa madde ve içeriği kesinleşmiş oluyor. Milli Birlik Komitesi, temsilciler meclisinden gelen metni beğenmemişse o zaman her iki kanadın eşit sayıda üyesinden oluşan bir karma komisyon kuruyor. Bu karma komisyon o maddenin metninde uzlaşıyor. Son metin, karma komisyonun çalışması bittikten sonra her iki kanadın bütün temsilcilerinden oluşan birleşik toplantıda toplam üyelerin 2/3 oyu ile kesinleşiyor.

Sonuç: Kurucu meclisin üyelerinin sivil üyelerinin sayısı asker olan üyelerden çok fazla. Milli Birlik Komitesi 23 kişiden oluşuyor. Temsilciler meclisi üyeleri 253 kişi ve bakanlardan oluşuyor. Çok büyük bir rakam sivillerden oluşuyordu. 1961 anayasasının yapımında sivil kanada üstünlük verildiğini bu bakımdan söyleyebiliriz. 27 Mayıs 1961’de kurucu meclis anayasayı kabul ediyor. 9 Temmuz 1961’de halk oylamasına sunuluyor. Halk oylamasında tam bir demokratik ortamda anayasanın tartışıldığını iddia edemeyiz. Buna karşılık bu anayasaya hayır verilmesi gereken taraflar için kendilerini ifade eden bir ortam olduğunu belirtebiliriz. Halk oylaması, gizli oy açık sayım esasına göre gerçekleştiriliyor. 1961 Anayasası geçerli oyların %61.5’ünü alarak yürürlüğe giriyor.

1982 Anayasası da bir darbenin ürünüdür. Anayasanın yapım sürecinde asli kuruculuğun kullanılması bakımından da bu iki anayasanın birbirinden farklıdır. Bu darbeyi yapanlar kendilerini Milli Güvenlik Konseyi olarak adlandırdılar. Bu konsey 5 kişiden oluşuyordu. Ordunun en üst kademe komutanlarından oluşan bir konseydi. Darbenin yapıldığı gün hemen 1 sayılı bir bildiri yayınladılar ve TBMM’nin etkinliğini durdurdular. Hükümetin faaliyetini durdurdu. Parlamenter bağışıklıkları yani TBMM üyelerinin yasama sorumsuzluğunu ve yasama dokunulmazlığını kaldırdı. Bütün yurttaki sıkıyönetim ilan etti. Yurt dışına çıkışları yasakladı ve yine ülkenin her yerinde sokağa çıkma yasaklarına girişti. Bunun dışında bu askeri darbenin getirdiği başka bir sonuç; siyasal partilerin, sendikaların, THK, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu dışındaki bütün derneklerin faaliyetlerinin durdurulması oldu. Sivil topluma ait bu alanın darbeler tarafından bütünüyle dondurulması söz konusu. Milli Güvenlik Konseyi hemen yetkili bir hükümet atadı. Yeni anayasanın yapımına ilişkin bir adımı yaklaşık 8 ay atmadı Haziran 1981’e kadar. 1961 darbesini yapanlar bakımından öngörülebilirlik söz konusuydu. Ne olacağı, nasıl olacağı, hangi durumda neler yapılacağı belli idi. Yeni anayasanın yapılması için Haziran 1981’e kadar hiçbir adım atılmadığı gibi bu anayasanın halk oylamasında reddedilmesi durumunda ne olacağı, nasıl bir sürecin olacağı, kimin başka bir anayasa hazırlayıp hazırlamayacağı hiçbir şey belli değildi. Milli Güvenlik Konseyinin kabul ettiği “*Anayasa düzeni hakkında temel yasa*” bu yasa ile Milli Güvenlik Konseyi ve bu konseyin başkanının yetkilerini yeniliyor. Bu konseyin kabul edeceği bildiri, karar ve yasaların anayasa olarak yürürlüğe gireceğini belirtiyordu. Darbelerin etkisiyle anayasasızlaştırma sürecine karşılık gelen bir yasa. Yürürlükte bulunan 1961 anayasasının hükümleri ile yayınladıkları bu bildiri çatışır ise bu bildirideki kanunların anayasa olarak öngörülüyordu. Devleti yöneten siyasal iktidarı elinde bulunduran asıl organ bu konseydi. Bu konseyin başkanı da devlet başkanı sıfatını aldı. Aynı durum 1961 darbesi döneminde de olmuştu. Bir yasa çıkarılarak kurucu meclisin kuruluşuna ilişkin bir yasa çıkarılıyor.

Bu kurucu meclisin başlıca üç görevi var; **1.** Yeni bir anayasa hazırlamak **2.** Yeni bir seçim yasası hazırlamak **3.** Yeni bir siyasal partiler yasası hazırlamak. 1960’da kurulan kurucu meclis, yeni bir anayasa ve yeni bir seçim yasası yapmakla görevliydi. 1980 darbesinden sonra kurulan kurucu mecliste bunlara ek olarak siyasal partiler yasası hazırlama görevi de getirildi. Yine 1960 darbesi sonrasında kurucu meclis, hem seçim yasasını yeni anayasayı bir arada hazırladı. Bunun için özel iki ayrı komisyon kuruldu. 1980 Darbesiyle kurulan kurucu mecliste ise kurucu meclisin öncelikle yeni anayasayı hazırladığını, yeni anayasanın halk oylamasına sunulup kabul edildikten sonra diğer yasaları görüşüp kabul ettiğini görüyoruz. Uygulamada bir fark söz konusu. Bu farkın kurucu meclisin yapısı ve anayasayı yapma süreci bakımından da geçerli olduğunu görüyoruz. Çıkarılan yasa kurucu meclisin iki kanattan oluşacağını belirtiyor. 1960 Darbesinden sonra kurulan kurucu meclise benzerlik taşıdığını görüyoruz. Burada da kurucu meclisin bir kanadını Milli Güvenlik konseyi oluşturuyor. Diğer kanadını ise danışma meclisi oluşturuyor. Danışma meclisi 160 kişiden oluşuyor. Bunun 120 üyesini her ilin valisi her bir üyelik için göstereceği 3 aday arasından Milli Güvenlik Konseyi belirliyor. 40 Üyeyi ise, doğrudan seçip atıyor. Sonuç olarak danışma meclisinin üyelerinin tümünü doğrudan ya da gösterilen adaylar arasından Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçildiğini görüyoruz. 1960 Darbesi sonucunda oluşturulan temsilciler meclisinde bakanların dışında diğer üyelerin tümünü çok dereceli bir seçim yoluyla toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerinden oluşturduğunu görüyoruz. 1980 Darbesinden sonra kurulan Danışma Meclisi’nde

ise üye olmanın en önemli koşulu 11 Eylül 1980 itibarıyla siyasal parti üyesi olmamaktır. 1980 Darbecileri, toplumu siyasalsızlaştırmak ilkesi üzerine kurdular.

Danışma Meclisi çalışmaya başlamadan kısa süre önce bütün siyasal partileri fesih etti. Darbe ile birlikte siyasal partilerin faaliyetleri durdurulmuştu. Ama Danışma Meclisinin faaliyete geçmesinden çok kısa bir süre de hukuken dağıtıldılar. 23 Kasım 1981 de bu kurucu meclis çalışmaya başladı. Kendi içinden 15 üye seçerek bir anayasa komisyonu kurdu. Bunun başına da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Profesörü olan Orhan Aldıkaçtı'yı koydu. Bu anayasa komisyonu, anayasa taslağını 17 Temmuz 1982 tarihinde tamamladı. Bu anayasa metni, Danışma Meclisinin Genel Kurulunda görüşüldü ve kabul edildi ve bu anayasa Milli Güvenlik Konseyine gitti. 1961 Döneminde temsilciler meclisinin kabul ettiği bir anayasa maddesi Milli Birlik Komitesi kabul etmediyse, anlaşamadılarsa bu durumda iki taraftan oluşan eşit sayıda bir komisyon kuruluyordu. Bu komisyon bir madde metni üzerinde anlaşıyordu ve karma komisyonun anlaştığı bu metinde kurucu meclisin iki kanadının üyelerinde oluşan birleşik toplantıda üye tam sayısının en az 2/3 üye sayısı ile kabul ediliyordu. Her iki kanadın toplamı içerisinde sivil üyelerin sayısı asker üyelerden çok daha fazla. Bu tür anlaşmazlıklarda çoğunluk kurucu meclis içerisindeki sivil üyelerdeydi. 1982 Anayasası yapılırken ise Danışma Meclis anayasa taslağını hazırladı. Bu anayasayı Danışma Meclisi kabul etti. İş Milli Güvenlik Konseyine geldi Bu konsey, Danışma Meclisinin kabul ettiği maddeler üzerinde ister kabul ister değiştirerek kabul isterse reddetme yetkisi vardı. İsterse de Danışma Meclisinin öngörmediği yeni maddeler koyma veya kabul edilen maddelerin bir kısmını çıkarma yetkisine sahipti. Milli Güvenlik Konseyinin bu anayasa metni üzerinde mutlak ve tam bir söz sahibi olması söz konusudur. Bu nedenle kurucu meclisin Danışma Meclis tarafıyla Milli Güvenlik Konseyi arasında bir astlık üstlük ilişkisi vardı. Danışma Meclisi gerçekten de Milli Güvenlik Konseyine danışmanlık yapan, asıl yetkinin Milli Güvenlik Konseyinde olduğu bir meclis biçimindeydi. Danışma Meclisi tarafından hazırlanan 193 madde Milli Güvenlik Konseyi tarafından 170 maddeye düşürmüştü. 11 Geçici maddeyi de 16 geçici madde haline getirmiş. Daha sonra resmi gazetede yayınlanarak halk oylaması süreci başladı. Milli Güvenlik Konseyi, anayasanın halk oylamasına sunulması konusunda bir yasa çıkardı. Anayasanın halk oylamasına sunulma süreci bu yasanın hükümleri çerçevesinde gerçekleşti. Bu yasanın içinde çok sayıda yasak vardı. 11 Eylül 1980 Tarihi itibarıyla siyasi parti üyesi olan bir kişinin anayasa hakkında herhangi bir beyanatta bulunması yasaklanmıştı. Anayasaya ilişkin halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birleştirilmişti. 1982 Anayasasının ilk biçimi klasik bir parlamenter sistemi öngörüyordu. Haliyle CB'nın TBMM tarafından seçilmesi biçiminde bir düzenleme vardı.

Milli Güvenlik Konseyinin koyduğu geçici 1. Maddesine göre halk oylamasıyla anayasanın kabul edilmesi durumunda devlet başkanlığı yapan kişinin 7 yıl için CB olarak seçilmiş sayılacağı öngörülmüyordu. Aynı zamanda bu Milli Güvenlik Konseyinin diğer üyeleri de 7 yıl CB'na danışmanlık yapacaklardı. Bu kişilerin milletvekillerin sahip olduğu yasama dokunulmazlığına da sahip olması öngörülmüyordu. Neden halkın önüne 2 sandık konulmuyor diye eleştiri getirildi. İkinci olarak bir seçimden söz ediliyorsa CB'lığının seçimine ilişkin birden fazla adayın olması gerekirdi. 1961 anayasasına göre ilk CB'nını anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra öngörüldüğü üzere kendisi seçiyor. Burada darbecilerin siyasal yaşama metazorik bir biçimde dahil olması sağlayacak bir zorlama vardır. İkinci olarak anayasanın halk oylamasına sunulması aşamasında tek taraflı bir propaganda sürecinden söz edebiliriz. Anayasanın kamuoyuna tanıtılmasından sorumlu olan tek kişi Orgeneral Kenan Evren olarak öngörüldü. Alınan aynı kararda anayasanın geçici maddeleri ile Kenan Evren'in anayasa hakkındaki konuşmalarının hiçbir şekilde eleştirilemeyeceğini belirtmişti. Kenan Evren hem anayasa için hem de kendi CB'lığı için kampanyayı kendi başına yaptı. Bu anayasanın demokratik bir anayasa olmadığına ilişkin bir eleştiri ve itirazı da açık bir şekilde yasakladı Milli Güvenlik Konseyi. Üstelik dolaylı olarak bu anayasa itiraz eden bu anayasayı eleştirenler de anarşist gibi yaftalarla ötekileştirildi. Bu dönemde yasak olduğu için ancak dolaylı olarak hayır kampanyası yapıldı. Ama bunlar bile bastırıldı. Tek taraflı bir propaganda ile bu kampanya yürütüldü. Anayasanın halk oylamasına sunulması konusundaki yasa gizli oy ilkesini sağlamak amacıyla oy pusulasının içine konulacak zarftan belli olmayacak biçimde düzenleme getirildi. Ancak zarflar beyaz olacaktı. Hayır oyu anlamına gelen mavi oy pusulası, beyaz zarfın dışından görüleceğine ve gizli oy ilkesine aykırı olacak şekilde bir endişe oluştu. Zarf çok ince olduğu için zarfın içindeki oy pusulası dışarıdan görülebiliyordu. Bu halk oylaması da gizli oy ilkesini de gerçekleştirilmemiş bir oylama oldu. Halk oylamasına katılmak zorunlu tutuldu. Anayasaya konulan geçici bir madde ile bu anayasa halk oylamasına katılmayan gelecek 5 yılda yapılacak halk oylaması, yerel ve genel seçimlerde oy kullanamayacaklarına ilişkin bir düzenleme de getirildi anayasaya. Bu şekilde oylamaya

katılmasını sağlamak ve “halk oylaması ile anayasanın meşruiyetini sağlamak” amacıyla bu yapıldı ve bundan da sonuç alındı. %91 Katılım oranı ve %91 kabul oyu ile anayasa kabul edildi. 1961 anayasanın yapılışı ve süreçleriyle karşılaştıracak olursak, plebisit anayasacılığın, Bonapartist anayasacılığın bütün özelliklerini taşıyan bir anayasa 1982 anayasası. Anayasanın yapım ve kabul süreci yöntemi aslında anayasanın içeriğini de belirler. Bir anayasa ne kadar demokratik olarak yapılırsa bu anayasanın içeriğinin de buna uygun olarak demokratik olduğunu görüyoruz. 1876 Anayasasını dışarıda bırakacak olursak TC içindeki hem içerik hem de yapım süreci olarak demokratik olmayan en otoriter anayasa 1982 anayasasıdır.

Türev (Tali) Kurucu İktidar: Bir anayasayı, o anayasada öngörülmüş yöntemlere bağlı olarak değiştiren iktidara, biz tali kurucu iktidar diyoruz. Bir anayasayı değiştirme yetkisi yürürlükteki anayasadan kaynaklandığı, yürürlükteki anayasadan türediği için aynı zamanda bu kurucu iktidara türev veya türevsel kurucu iktidar da deniyor. Çünkü türevsel kurucu iktidar anayasayı yine o anayasada öngörülen yöntemlere bağlı olarak değiştirildiği için. Sonuç olarak asli kurucu iktidar, hukuken sınırsız olan iktidardır. Mevcut olan hiçbir hukuk kuralına kendini en azından kuramsal olarak bağlı saymayan iktidardır. Türevsel kurucu iktidar ise bir kere hukuki bir iktidardır. Asli kurucu iktidar hukukla açıklanamayan bir iktidardır. Dolayısıyla herhangi bir hukuk kuralıyla da yürürlükteki hali hazırdaki anayasa olmak üzere herhangi bir hukuk kuralı olmak üzere kendini bağlı saymayan iktidardır. Türevsel kurucu iktidar, hukuki bir iktidardır. Bu iktidarı kuran ve sınırlarını belirleyen bir anayasa var ve buna göre kurulmuştur. İkincisi sınırlı bir iktidardır. Çünkü anayasada öngörülen kendisi için öngörülmüş olan sınırlama ve yasaklara uymak zorunda olan bir iktidar. Hem hukuki hem de sınırlı bir iktidar. Türevsel kurucu iktidar, anayasayı değişikliği yapma yetkisine sahip olan bir iktidardır. Anayasa, türevsel kurucu iktidara hem anayasayı kısmen değiştirme hem de anayasayı tamamen değiştirme yetkisini de verebilir. Bazı anayasalar açık bir biçimde türevsel kurucu iktidara anayasayı tümüyle değiştirmeye hem de kısmi olarak yetkisini tanır. Bu yetkiyi tanıırken de 2 yetkiyi de birbirinden ayırır. Türevsel kurucu iktidar bu 2 yetkiden birini diğerine göre farklı biçimde kullanmak zorundadır. Bu ayrımı yapan anayasalara örnek olarak 1978 İspanyol, 1992 Paraguay, 1999 İsviçre anayasasını örnek olarak verebiliriz. 1978 İspanyol anayasası türev kurucu iktidara hem anayasayı toptan değiştirme hem de kısmi değiştirme yetkisini vermiş. Anayasaya göre anayasanın kısmi olarak değiştirilebilmesi için parlamentonun 2 meclisinin ayrı ayrı üye tam sayısının 3/5’i ile bu anayasa değişikliğini kabul etmesi gerekiyor. Eğer kısmi anayasa değişikliğinde parlamentonun 2 kanadı anlaşamamışsa hemen bir karma komisyon kurulur. 2 Meclis eşit sayıda üye verir bu karma komisyona.

Karma komisyon ortak bir anayasa değişikliği metnini hazırlar. Bu metin yeniden meclisin her iki kanadının oyuna sunulur. Yine üye tam sayısının 3/5 sayısı aranır. Eğer bu sayı bulunamazsa o zaman millet meclisi kanadının üye tam sayısının en 2/3 ile kabul etmesi ve senatonun da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul etmesi durumunda parlamentodan geçmiş olur ve halk oylamasına sunulur. Halk oylamasında da geçerli oyların çoğunluğunu alması durumunda da bu kısmi anayasa değişikliği yürürlüğe girmiş olur. Anayasanın bütünüyle yürürlüğe girmesi için ise parlamentonun iki kanadının ayrı ayrı bu değişikliği üye tam sayısının 2/3’ü ile kabul etmesi gerekir. Eğer bu gerçekleşirse parlamento hemen dağılır. Genel seçimler gidilir ve genel seçimler sonucunda oluşan her iki meclis genel seçimden önceki parlamentonun kabul ettiği metni yine ayrı ayrı üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul eder. Daha sonra bu anayasa metni halk oylamasına sunulur. Anayasanın bazı maddelerinin kısmi olarak değiştirilmesi ile anayasanın bütünüyle değiştirilmesi yöntemini birbirinden ayırıyor. Bütün olarak anayasanın değiştirilmesi yöntemi çok daha zor usullere bağlanmış. Anayasanın kendisi bizzat anayasanın toptan değiştirilmesine ilişkin bir yöntem öngördüğü için anayasa bütünüyle değiştirilip yeni bir anayasa yapılıyor olsa bile bu anayasayı asli kurucu iktidar değil türev kurucu iktidar yapar. Çünkü anayasanın kendisi buna ilişkin bir düzenleme getirdiği için. Bazı anayasalar ise türev kurucu iktidar tarafından anayasanın toptan değiştirilmesine ilişkin özel bir düzenleme getirmez. Sadece anayasa değişikliğine ilişkin bir düzenleme öngörür. Toptan ya da kısmi bir ayrıma gitmez. 1974 İtalyan, 1949 Alman, 1988 Brezilya anayasaları buna örnektir. Bizde de 1924-1961-1982 anayasaları da anayasaların değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler öngörmüştür ama anayasanın toptan veya kısmi değiştirilmesi diye bir ayrıma gitmemiştir. Anayasayı, anayasada öngörülmüş yöntemlere bağlı olarak değiştiren iktidara türev kurucu iktidar denir. Anayasalar, bu türev kurucu iktidara yönelik birtakım sınırlamalar getirebilir. Örneğin, yapılacak anayasa değişikliğinin içeriğine ilişkin olabilir. Biz buna türev kurucu iktidara yönelik maddi sınır diyoruz. Ya da anayasa türev kurucu iktidara ilişkin bir takım süre sınırlamaları öngörülüyor. Buna da türev kurucu iktidara yönelik zamansal sınırlamalar diyoruz. Üçüncü olarak da anayasa, türev kurucu iktidara

yönelik o anayasa değişikliklerinin hangi yöntemle yapılacağına ilişkin birtakım sınırlamalar getirebilir. Buna türevsel kurucu iktidara yönelik biçimsel sınırlamalar denir. Maddi sınırlamalar: değiştirilmesi anayasa tarafından yasaklanan anayasa hükümlerine denir. Bunlar türev kurucu iktidarın maddi sınırlarını oluşturur. Aynı zamanda biz buna anayasanın maddi katılığı da denir. Her anayasa maddi katılığa sahip olmayabilir. 1924 Anayasasında bizim herhangi bir maddi sınır yoktu. Yani türev kurucu iktidarın değiştiremeyeceği bir hüküm yer almıyordu. Ama 1961-1982 anayasaları böyle bir maddi katılık öngördü. Yani değiştirilmesi yasaklanan maddeler öngördü. Bir anayasa değiştirilmesi yasaklanan hükümlerin sayısı ve içeriği ne kadar fazla ise o anayasanın maddi katılığı o kadar çoktur. Bir anayasada anayasanın değiştirilmesi yasaklanan madde ve hükümleri ne kadar az ya da sınırlı ise o anayasanın maddi katılığının o kadar düşük olduğunu söyleriz. Günümüzde çağdaş anayasaların pek çoğunda anayasaların belli bir maddi katılığa sahip olduğunu görüyoruz. Peki o zaman bu değiştirilmesi zor ya da değiştirilemez maddeler koymanın amacı nedir? Bunun amacı, anayasa koyucunun önem verdiği ve değişmesini istemediği bazı ilkelerin, kuralların, hak ve özgürlüklere ilişkin bazı düzenlemelerin sürekliliğini sağlamak. Bu ilkeyi güvence altına almak için özel bir korumadır. Örneğin çağdaş anayasalarda en çok görülen değiştirme yasakları devlet biçiminde ilişkin. Fransa, İtalya, Portekiz, Rusya gibi çok sayıda anayasada devlet şeklinin cumhuriyet olduğuna ilişkin değiştirilmez maddeye ilişkindir. Yine devlet biçimine ilişkin olarak devletin federal ya da üniter olma özelliğinin değiştirilmesini yasaklayan anayasalar var. 1988 Brezilya, 1949 Alman anayasası devletin federal niteliğinin değiştirilmesini yasaklıyor. Tam tersi olarak devletin üniter niteliğini öngören anayasa hükmünün değiştirilmesini yasaklıyor Romanya anayasası. Bizde devlet üniter bir devlet olarak açık bir şekilde tanımlanmamıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi var. Devlet biçimini tanımlamamıza yardımcı olacak bir ilke bu. 1982 Anayasasının 3.maddesinde yer alıyor. Bu bizde değiştirilmesi yasak olan ilkeler arasında bulunuyor. 1961 ve 1982 Anayasaları, türev kurucu iktidara maddi sınırlar getirmiştir. Katılık bakımından 1982 anayasasının 1961 anayasasına göre daha katı bir anayasa olduğunu söyleyelim. 1961 Anayasası yalnızca anayasanın 1.maddesinin değiştirilemeyeceğini belirtirken, 1982 anayasası değişmez maddelerin ve hükümlerin sayısını arttırdı. 1982 Anayasası 1-2-3.maddelerinin değiştirilmesi ya da böyle bir değişikliğin teklif edilmesi yasaktır. Bunun dışında demokrasinin temel ilkelerine ilişkin, temel hak ve özgürlüklere ilişkin değişmez maddelerinde olduğunu görüyoruz. 1999 İsviçre anayasası türev kurucu iktidara anayasa değişiklikleri uluslararası hukukun uygulanması zorunlu kurallarının ihlal edemez kuralını koymuş. Çek Cumhuriyeti de demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı anayasa değişikliği yapılamayacağını belirtmiştir. 1949 Alman anayasasına göre, anayasanın 1-20. Maddelerinde yer alan hak ve özgürlükler değişmezlik kapsamı içindedir. Bunlara örnek; insan onurunu dokunulmazlığı, demokratik sosyal federal devlet ilkesi, iktidarın halktan kaynaklanması, direnme hakkı. Son olarak bazı anayasalar, devletin dayandığı ideolojinin de değiştirilmesini yasaklar mesela 1979 İran anayasası. Bu anayasaya göre devletin İslami niteliklerinin değiştirilmesi yasak. Bu maddi sınırların bağlayıcılığı nedir? Anayasanın öngördüğü bu maddi sınırlara uymakla yükümlüdürler. Anayasalar, türev kurucu iktidarın maddi sınırlara uyup uymadığı konusunda açık bir şekilde anayasa mahkemelerini yetkili kılabilirler. Böyle bir yetkiye sahipse AYM, o zaman anayasa değişikliklerinin anayasanın değiştirilmez maddelerine aykırı olup olmadığını denetleme yetkisine AYM’nde olacaktır.

Bazı anayasalar ise bu konuda tamamen sessiz kalmıştır. Anayasa Mahkemeleri zaman zaman yorum yoluyla bu yetkiyi kendi üzerine alıyor. Anayasa açıkça anayasa değişikliklerini anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisini yasaklamamış. Yasaklamadığına göre o zaman bu yetki bendedir. Ben bir anayasa değişikliğini anayasada öngörülen maddi sınırlara uygun olup olmadığını denetleme yetkisine sahibim. Böyle yorum yoluyla türev kurucu iktidara maddi sınırlara uyup uymadığını denetleme yetkisini üstüne almış. Bazı anayasa mahkemeleri ise anayasanın sesiz kalmasına karşın, anayasa ya da kanun anayasa mahkemesine açık bir biçimde yasaların anayasaya uygun bir biçimde denetimini yapma yetkisini tanımamış. Öyle olunca ben böyle bir yetkiyi kendi kendime üstüme alıp anayasaya uygunluk denetimi yaparım. Bu AYM’lerinin kendi kendilerini sınırlama siyaseti gütmesi anlamına gelir. Örnek Fransız Anayasa Konseyi. Bizde 1924 Anayasası döneminde AYM yoktu. Anayasa değişikliklerinde maddi sınırdan öngörmemişti. 1961 Anayasasının ilk biçiminde kanunların anayasaya uygunluğunun şekil ve esas bakımından denetleme yetkisi anayasa mahkemesine verilmişti. Ama özel olarak anayasa değişikliği kanunlarından söz edilmemişti. Anayasa değişiklikleri de bir yasa ile yapıldığına göre bütün anayasaların uygunluk denetimi de AYM’nin yetkisi içinde olduğuna göre AYM’de türev kurucu iktidarın anayasanın öngördüğü maddi sınırları aşıp aşmadığını yetkisini

kendisinde gördü. 1982 Anayasası, biraz daha farklı bir düzenleme getirdi. AYM'nin anayasa değişikliklerinin yalnızca şekil açısından denetleyebileceğini belirtti.

Üstelik şekil bakımından denetimi de sınırlı bir biçimde **üç unsurun** olup olmadığı ile sınırlı bir biçimde saydı. Böyle olunca AYM'nin anayasa tarafından eli kolu bağlandı. 2008 Yılına kadar AYM, bir anayasa değişikliğinin anayasanın öngördüğü maddi sınırları aşıp aşmadığı denetleme yetkisini kendisinde gördü. 2008-2010 Yıllarında 1961 anayasası dönemindeki içtihadına döndü. Türev kurucu iktidarın, anayasanın öngördüğü maddi sınırları aşıp aşmadığı denetleme yetkisini kendisinde buldu. 2010 Yılından beri hiçbir anayasa değişikliği AYM önüne gitmedi. AYM'nin başka kararlarında benimsediği kararlarını göz önünde bulunduracak olursak, böyle bir anayasa değişikliğine ilişkin bir yasa geldiğinde mahkemenin 2008 öncesindeki yaklaşımına geri döneceğini varsayabiliriz.

İkinci bir sınır; zamansal sınır. Anayasanın değiştirilmesini belli bir süre için anayasa ile yasaklanması. Böyle bir zamansal yasak anayasanın tümüne ilişkin olabileceği gibi bazı maddelerine ilişkin de olabilir. Zamansal yasak belli bir süre için olabileceği gibi bazı ortam ve koşulların olduğu her durumda da söz konusu olabilir. Anayasaların asli kurucu iktidarın türev kurucu iktidara yönelik bu tür zamansal sınırlar öngörmesinin amacı; yeni bir anayasal bir düzen yerleşiyor. Bu anayasal düzenin yerleşmesine zaman tanıma, kısa sürede anayasa değişikliklerinden kaynaklanabilecek siyasal istikrarsızlıkları önlemek. Bu yeni anayasanın yerleşmesi bakımından. Bu zamansal sınırlar geçici nitelik taşır. 1787 ABD anayasası. Bu anayasa 1808'e kadar zenci köle ticaretine ilişkin anayasada düzenleme yapılamaz. 1975 Yunanistan ve 1976 Portekiz anayasaları diyor ki "son anayasa değişikliğinin üzerinden 5 yıl geçmedikçe yeni bir anayasa değişikliği yapılamaz." Sık anayasa değişikliklerinden kaynaklanabilecek bir siyasal istikrarsızlık ortamını engellemek. 1992 Paraguay anayasasında 10 yıl geçmedikçe toptan, 5 yıl geçmedikçe kısmi değişiklik yapılamaz. Bu geçici bir nitelikteki bir zamansal sınırdır. Bu düzenlemenin amacı; anayasanın getirdiği yeniliklere bir süre tanımak ve hemen anayasa değişikliği yapılmasını önlemek.

Bir başka önemli zamansal sınır, belli ortam ve koşulların gerçekleşmesi durumunda, belli koşullar ve ortam altında anayasa değişikliği yapılmasını yasaklamak. Bunlar genellikle; OHAL, sıkıyönetim, savaş, ülkenin işgali, devletin karşı karşıya olduğu olağanüstü dönemlere ilişkindir. Pek çok çağdaş anayasalarda böyle zamansal sınır olduğunu görüyoruz. Bu koşullar sürdüğü sürece anayasa değişikliği yapılması yasaklanmıştır. 1958 Fransa, 1978 İspanya, 1991 Romanya türev kurucu iktidara bu nitelikte sınırlar koymuştur. Amaç olağanüstü durumda oldu bittiye getirerek anayasa değişikliği yapılmasını engellemek, siyasal istikrarı sağlamak, anayasal düzenin korunmasını sağlamak. Bu tür olağanüstü durumlar her türlü hak ve özgürlüğün olağan dönemlerden çok daha geniş biçimde sınırlandığı, yürütme erkine de olağan dönemden çok daha geniş takdir yetkisinin verildiği dönem. Yürütmenin bu elindeki geniş olanağı anayasa değişikliği yoluyla kötüye kullanılmasını engellemek. Bunun ne kadar önemli olduğunu 2017 anayasa değişiklikleri sırasında gördük. 2017 Anayasa değişiklikleri bütün ülkede olağanüstü halin yürürlükte olduğu dönemde kabul edildi ve halk oylamasına sunuldu. O önemde temel hak ve özgürlükler sınırlandı, demokratik bir tartışma ortamı sınırlıydı. Bizde böyle bir zamansal sınır, demokratik bir düzeni korumak bakımından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Getirilen bu köklü anayasa değişiklikleri kamuoyunda enine boyuna tartışılmadan olağanüstü hal koşulları altında kabul edilip halk oylamasına sunuldu.

9 Mayıs 2023

Anayasa, nasıl değiştirileceğine ilişkin düzenlemeler içeriyordu ki biz buna katı anayasa diyorduk. Hiçbir hüküm içermiyorsa yumuşak esnek anayasa demektir. Katı anayasalarda türevsel kurucu iktidara yönelik olarak çeşitli sınırlar söz konusu olabilir. Bunlardan bir tanesi; maddi sınırlardı. İkincisi zamansal sınırlardı. Yine karşılaştırmalı hukuktan örnekler verdik. Üçüncüsü biçimsel sınırlardı. Bu biçimsel sınırları, bugün ele alacağız. Biçimsel sınır dediğimiz zaman anayasanın, hangi yöntemlere göre değiştirileceğini o anayasa metninde o anayasanın kendisinde belirtilmesi türev kurucu iktidara yönelik biçimsel sınırları oluşturur. Her anayasa türev kurucu iktidara yönelik biçimsel sınırları farklı biçimde belirleyebilir. Türev kurucu iktidara yönelik birden fazla biçimsel sınır aynı anayasada öngörülmüş olabilir. İlk biçimsel sınır türü; olağan ya da diğer yasalardan daha büyük nitelikli çoğunlukların anayasa değişiklikleri için aranması olabilir. Bir anayasa değişikliğinde nitelikli çoğunluk, genel olarak 2/3 veya 3/5 çoğunlukların aranmasını anlarız. Olağan yasalardan farklı daha nitelikli bir kabul çoğunluğunun aranması türev kurucu iktidara yönelik bir biçimsel sınır oluşturur. Örneğin 1946 Alman, 1991 Romanya, 1990 Hırvat, 1996 Güney Afrika anayasaları, anayasa

değişikliği için parlamento üye tam sayısının en az 2/3'ünü arıyor. 1993 Çek, 1980 Şili, 1992 Estonya anayasaları ise anayasa değişikliği için parlamentonun üye tam sayısının en az 3/5 çoğunluğu şartını koyuyor. Nitelikli çoğunluk aranması, türev kurucu iktidara yönelik biçimsel sınırlara verebileceğimiz bir örnek. Örneğin olağan yasalar bir kez ya da 2 kez görüşmekle kabul ediliyorsa parlamentoda olağan yasalar için öngörülen görüşme sayısından daha çok daha büyük bir görüşme sayısı aranıyorsa anayasa değişikliklerinde bu da türev kurucu iktidara yönelik bir biçimsel sınıra örnek verilebilir. Örneğin Venezuela anayasası, anayasa değişikliğini parlamentoda 3 kez görüşülmesini şart koyuyor. İtalyan anayasası iki kez görüşülmesini şart koyuyor. Bu da bir biçimsel sınır örneği. Başka biçimsel sınır örneği, anayasaların bir bölümü, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için söz konusu bu değişikliği kabul eden parlamentonun dağılmasını, hemen genel seçimlere gidilmesini bu seçimler sonucunda oluşacak parlamentonun, önceki parlamentonun kabul ettiği anayasa değişikliğini aynen kabul etmesini şart koşar. Araya genel seçileri sokmak yoluyla 2 ayrı parlamentonun aynı anayasa değişikliği metninin kabul etmesi şartı aranıyor. Böyle bir biçimsel şartın konmasının amacı, araya genel seçimler koymak yoluyla genel seçimler aracılığı ile dolaylı da olsa halkın bu anayasa değişikliğine onaylaması amaçlanıyor. Örneğin 1953 Danimarka, 1983 Hollanda, 1994 Belçika anayasaları böyle bir biçimsel katılık öngören anayasalara verebileceğimiz örnekler. Bazı anayasalar parlamentonun kabul ettiği anayasa değişikliklerini mutlak bir şekilde halk oylaması yoluyla halkın onayına da sunarlar. Burada isteğe bağlı bir halk oylaması değil anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için zorunlu bir halk oylaması aşaması öngörülür. Örneğin 1946 Japon, 1991 Romen anayasası. Federal devletlerin önemli bir bölümünde yalnızca merkezi parlamentonun kabul ettiği anayasanın değil aynı zamanda federe devletlerinde bu anayasa değişikliğini onaylaması öngörüyor. 1787 Amerikan, 1900 Avustralya, 1917 Meksika anayasaları, anayasa değişikliklerinin federal parlamentoda kabul edilmesinden sonra federe devletler tarafından onaylanmasını şart koyuyor. Yine biçimsel sınırlara verilebilecek bir başka örnek, bazı anayasaların bu biçimsel katılığı kademeli bir biçimsel katılık olarak düzenlemesi yani anayasa anayasada düzenlenen bazı maddelerin ya da bazı konuların değiştirilmesini anayasadaki diğer madde ve konulara göre daha farklı ve genellikle de daha zor koşullara bağlaması. Yani anayasa değişikliklerinde konu, hüküm ya da madde itibarıyla birden fazla farklı anayasa yapım yöntemi ya da usulü öngörülmesi. 1978 İspanyol anayasası. Bu anayasada yapılacak değişiklikler toptan anayasa değişikliği hükümlerine bağlıydı. Nedir toptan anayasa değişikliği hükümleri? Bu maddelerde ya da anayasanın bu bölümlerinde yapılacak anayasa değişiklikleri ancak parlamentonun 2 kanadının 2/3'ünün kabulü ile mümkün. Ondan sonra parlamento dağılıyor. Seçimlerden sonra oluşacak yeni parlamentoda aynı anayasa değişikliğini kabul eder ise o zaman metin halk oyuna sunuluyor. Halk oyunda da kabul edilirse yürürlüğe giriyor. İspanyol kurucu iktidarı, türev iktidara yönelik olarak bu kadar karşılanması zor bir kademeli biçimsel katılık öngörmüş. Buradaki önemli unsur 1978 anayasası herhangi bir maddenin değiştirilmesini yasaklamıyor. Herhangi bir maddeye yönelik bir değişmezlik düzenlemesi getirmiyor. Buna karşılık biçimsel bir kademeli katılık söz konusu. Yani bazı maddelerin değiştirilmesini diğerlerine göre çok zor koşullara bağlı.

Aynı biçimde değil yine kademeli bir biçimsel katılık öngören ama gerçekleştirilmesi daha kolay olan bir başka örnek Rusya anayasasıdır. Bu anayasaya göre anayasadaki genel esaslar, temel hak ve özgürlükler, anayasanın değiştirilmesine ilişkin anayasadaki maddeler ancak bir kurucu meclisin oluşturulması yoluyla değiştirilebilir. Diğer maddeler bakımında olağan parlamento anayasa değişikliği yapabilir. Ama bu anayasa hükümleri bakımından kurucu meclisin oluşturulması gerekir. Bunun gibi kademeli biçimsel katılığı öngören çok sayıda anayasa vardır. Örneğin Şili, Bulgaristan, Paraguay, Bolivya anayasalarında da böyle bir kademeli katılık görüyoruz. Kademeli biçimsel katılığı öngören anayasalarda maddi sınırların olmadığını belirtelim. Tali, türevsel kurucu iktidara yönelik tali sınırlar yoktur. Yani maddi sınırlar yerine böyle bir kademeli biçimsel katılık öngörmüş asli kurucu iktidar. Hangisi türev kurucu iktidarı sınırlamak bakımından etkilidir diye soracak olsak; eğer maddi sınırların aşılp aşılmadığını, türev kurucu iktidarın anayasanın öngördüğü maddi sınırların aşılp aşılmadığına ilişkin bir yargısal denetim öngörmediyse ya da böyle bir olası yargısal denetimi anayasa açıkça yasakladıysa bu maddi sınırları uygulamada türev kurucu iktidara yönelik gerçek bir sınır olma yetkisi yoktur. Diğer taraftan hiçbir maddi sınır öngörmeyip az önce İspanyol örneğinde olduğu gibi kademeli bir biçimsel katılık düzenlediyse bir asli kurucu iktidar anayasasında bunun daha etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tür biçimsel sınırların aşılp aşılmadığı konusunda anayasa mahkemeleri genellikle denetim yaptıkları için. Kendi üzerine almayan ya da 1982 anayasasında olduğu gibi bunu yasaklayan açıkça maddi sınırların aşılp aşılmadığının denetleme yetkisini yasaklayan anayasalarda bulunuyor. Bu bakımdan

karşılaştırma yaptığımızda biçimsel maddi sınırların türevsel kurucu iktidarın bu sınırları aşıp aşmadığını denetleme bakımından daha etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Osmanlı- Türk anayasalarında türevsel kurucu iktidar yönelik ne tür sınırlamalar vardı: 1876 Kanuni Esasi'de; 166. Maddesinde anayasa değişikliği düzenleniyor. Buna göre, anayasa değişikliği teklifi Meclisi Bükela, Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayan tarafından verilebilir. Birinci olarak yürütmenin de anayasa değişikliği verme yetkisi vardır. İkinci olarak Meclisi Umumi vekilleri tek tek ya da bir arada anayasa değişikliği teklifi veremiyorlar. Ancak anayasa değişikliğine ilişkin bir talepte bulunabiliyorlar. Eğer böyle bir talep varsa o vekil hangi meclisin vekili ise o meclis bu talebi görüşüyor. Basit çoğunlukla kabul ediyor. Eğer basit çoğunlukla kabul ederse artık o anayasa değişikliği teklifi oluyor. Ama bu teklif bir vekilin bir üyenin teklifi değil üyenin içinde yer aldığı meclisin teklifi oluyor. TBMM üyeleri belli bir sayıya ulaşmak kaydı ile anayasa değişikliğine ilişkin önerge verme yetkisine sahip. 1876'da ancak anayasa değişikliği önergesi verilmesini talep etme yetkisine sahip. Bu talebi kabul edip etmemek meclisin basit çoğunluk ile alacağı bir karara bağlı. Bundan sonra meclislerden birisi anayasa değişikliği teklifinde bulundu. Kim bulunmuş olursa olsun bu anayasa değişikliği teklifi öncelikle meclisi mebusanda arkasından da Meclisi Ayan'da görüşülüyordu. Her iki meclisin de aynı metni üye tam sayısının en az 2/3 ile kabul etmesi gerekir. Kabul ettikten sonra bu anayasa değişikliği padişaha gider. 1909'a kadar bütün kanunlar bakımından padişahın **mutlak bir veto yetkisi** vardı. Anaya değişikliği kanunları içinde aynı şey geçerli. Padişah bunu reddederse artık anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi mümkün değildi. 1909 Anayasa değişiklikleri ile birlikte artık padişahın yetkisi anayasa değişiklikleri bakımından **geciktirici bir veto yetkisine** dönüştü. Olağan yasalar Meclisi Umumi tarafından basit çoğunluk ile kabul edilebiliyordu. Padişah, Meclisi Umumi tarafından kabul edilmiş olan bu kanunu Meclisi Umumi'ye yeniden görüşmek üzere geri gönderirse Meclisi Umumi'yenin bu kanunun aynen en az 2/3 çoğunlukla kabul etmesi gerekir ki padişahın vetosunu aşabilsin. Ama anayasa değişikliği kanunlarında 1876 Kanuni Esasi'ye göre zaten en az üye tam sayısının 2/3 gerektiği için padişah bu anayasa değişikliği kanununu Meclisi Umumi'ye geri gönderdiği zaman da daha büyük bir çoğunluk aranmıyor. Parlamentonun iki kanadının da ayrı ayrı 2/3 çoğunluk ile aynen kabul etmesi durumunda padişahın vetosunu aşmış oluyordu. O nedenle **olağan kanunlar bakımından padişahın vetosu güçleştirici, anayasa değişiklikleri bakımından geciktirici bir veto niteliği taşıyordu**. 1921 Teşkilatı Esasiye kanunu ise, yumuşak bir anayasa idi. 1921 Teşkilatı Esasiye kanunu, anayasanın değiştirilmesine ilişkin herhangi bir hüküm içermiyor. Uygulamada da diğer yasalar gibi anayasa değişiklikleri yapıldı. **Cumhuriyet ilan edilince buna uygun yapılan anayasa değişiklikleri hep olağan kanunlar gibi basit çoğunlukla ve kanunlar için öngörülen usul ve yöntemlere bağlı kalınarak yapıldı**.

1921 Anayasası bakımından türev kurucu iktidara yönelik maddi, zamansal ya da biçimsel bir sınırın öngörülmediğini görüyoruz. 1924 Anayasası 102.maddesinde anayasanın nasıl değiştirileceğini hükme bağlamış. Buna göre TBMM üye tam sayısının en az 1/3 tutarındaki milletvekili bir araya gelerek yazılı ve gerekçeli olarak anayasa değişikliği teklifi sunabilir. Burada 1. Teklif bakından olağan kanunlardan farklı olarak anayasa değişikliği teklifi yalnızca milletvekillerine verilmiş. Yani yürütme organının, Bakanlar Kurulu'nun böyle bir yetkisi yok. 2. Olağan kanunlar bakımından tek milletvekili yasa teklifi sunabilirken anayasa değişiklikleri bakımından en az üye tam sayısının 1/3 milletvekilinin bir araya gelip ortak bir anayasa değişikliği kanun teklifi sunması gerekiyor. Anayasa değişiklikleri bir kanun biçiminde parlamentolarda kabul edilir. Bu şekilde anayasa değişikliği kanun teklifi sunulduktan sonra bu kanunun kabul edilebilmesi için üye tam sayısının en az 2/3'ünün oyu gerekir. Burada da nitelikli bir çoğunluk aranıyor. Tıpkı 1876 da olduğu gibi. 1924 Anayasası bir onay aşaması öngörmüyor. Yani CB, TBMM'nin kabul ettiği bir anayasa değişikliği teklifini yeniden görüşmek üzere TBMM'ne geri gönderme yetkisi bulunmuyordu. TBMM'nin 2/3 çoğunluk ile kabul ettiği anayasa değişikliğinin resmi gazete de yayınlayarak yürürlüğe sokmak zorunda.

1924 Anayasası türev kurucu iktidara yönelik biçimsel sınırlar öngörmüş. Zamansal bir sınır öngörmemiş. Buna karşılık bir maddi sınırı var. 102.Maddede yer alan "anayasanın 1.maddesindeki devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna ilişkin hükmün değiştirilmesi yasak". Buna ilişkin değişiklik teklif edilmesi de yasak. 1961 Anayasası aslında büyük ölçüde türev kurucu iktidar bakımından 1924 anayasasının öngördüğü düzenlemeleri benimsemiş. 1961 Anayasasının 155. Maddesinde düzenleniyor, anayasanın nasıl değiştirileceği. Buna göre TBMM'nin yine üye tam sayısının en az 1/3 anayasa değişikliği teklifi vermek zorunda. Bu değişiklik teklifi yazılı ve gerekçeli olmalı. Teklifin kabul edilebilmesi için TBMM her iki kanadının ayrı ayrı bu değişikliği en az üye tam sayısının 2/3 ile kabul etmesi gerekir. Bu tekliflerin,

görü  lmesi ve kabul   bu sınırlar dı ında di er yasaların g  r  lmesi ve kabul   hakkındaki h  k  mlere ba lı tutulmu . Tıpkı 1924 anayasasında oldu u gibi 1961 anayasası da anayasa de i ikliklerinin y  r  rl  e girmesi bakımından bir onay a aması   ng  rmemi . Yani CB, 1961 anayasası d  neminde de TBMM'nin kabul etti i bir anayasa de i ikli i teklifini yeniden g  r  mek   zere TBMM'ne geri g  nderme yetkisine sahip de il. Maddi sınır bakımından da 1924 anayasasının   ng  rd    maddi sınırı s  rd  r  yor. Yani anayasanın 1.maddesi "Devlet   klinin Cumhuriyet oldu una" ili kin maddenin de i tirilmesinin teklif edilmesini yasaklı or. 1982 Anayasasını ise 2 b  l  mde incelememiz lazım. Biri 1987 anayasa de i ikli ine kadarki d  nem di eri ise 1987 anayasa de i ikli i ile birlikte ortaya  ıkan yeni d  nem. Anayasanın ilk bi imine g  re (1987 de i iklik   ncesine g  re) bazı bakımlardan   nceki Cumhuriyet anayasalarından   nemli farkların oldu unu g  r  yoruz. 1. 1924 Anayasasından bu yana var olan anayasa de i ikli i teklifine ili kin kuralın aynen korundu unu g  r  yoruz. 1982 Anayasasına g  re TBMM   ye tam sayısının en az 1/3'inin yazılı ve gerek eli teklifi ile anayasa de i ikli i s  recinin ba latılabilece ini s  yl  yor. **Anayasa de i iklik teklifleri tıpkı 1924, 1961 anayasalarında oldu u gibi 1982 anayasasında da TBMM   ye tam sayısının en az 1/3'inin yazılı ve gerek eli teklifi ile olabilir.** 2. Yine 1924 ve 1961 anayasalarında oldu u gibi anayasa de i ikli i TBMM   ye tam sayısının en az 2/3 oyu ile kabul ediliyor. 1982 Anayasasının ilk bi imi 24 ve 61 anayasaları ile aynı. **1982 Anayasası   nceki anayasalarda olmayan bir onay a aması getiriyor.** TBMM'nde kabul edilmi  olan bir anayasa de i ikli i kanunu CB'na gidiyor. CB, bu anayasa de i ikli i kanununu ya yeniden g  r  mek   zere TBMM'ne yolluyor.

Bu durumda; 1. TBMM, bu anayasa de i ikli i kanununu yine   ye tam sayısının en az 2/3 ile aynen kabul etmesi gerekir ki CB'nın itirazını a abilsin. 2. CB, ya da bu anayasa de i ikli i kanununu halk oylamasına sunabiliyor. 3. Bu ikisini yapmazsa CB, anayasa de i ikli i kanununu resmi gazetede yayınlattır ve b  ylelikle y  r  rl  e giriyor.

Buradaki de i iklik hi  olmayan CB'na tanınan iki   nemi yetki; 1. CB'nın anayasa de i ikliklerini TBMM'ne yeniden g  r  mek   zere geri g  ndermek yetkisi 2. Yine bu anayasa de i ikliklerini CB'nın halk oylamasına sunma yetkisi. 1961 anayasası, yalnızca 61 anayasası yapıldı ı zaman bu anayasanın b  t  n olarak y  r  rl  e girip girmemesine ili kin olarak halk oylaması yapmı . T  rev kurucu iktidara y  nelik herhangi bir halk oylaması   ng  rm  yor. **1982 Anayasası ise hem plebisit y  ntemi ile anayasanın y  r  rl  e girmesi i in bir halk oylaması yaptı. Hem de t  rev kurucu iktidara y  nelik olarak yalnızca CB'nına ait olan bir halk oylamasına sunma a aması   ng  rd  .** CB'nın, TBMM'nin kabul etti i anayasa de i ikli ini halk oylamasına sunma yetkisi takdiri bir yetki olup zorunlu bir yetki de ildir. Canı isterse bunu resmi gazetede yayınlattır y  r  rl  e koyar. **Bi imsel sınıra y  nelik olarak en   nemli de i iklik budur.** Anayasa de i ikli inin bir onay a aması i ermesi ve bu de i ikli i s  recine parlamento ile birlikte CB'nın eklenmesi.

  kinci   nemli de i iklik, 1982 anayasasında t  revsel kurucu iktidara y  nelik, maddi sınırların geni letilmesi. 1924 ve 61 Anayasaları yalnızca anayasanın 1.maddesinin de i tirilmesini yasaklamı tı. 1982 Anayasası 1.maddenin yanına 2. ve 3. Maddeleri de ekledi. 4.Madde "anayasanın 1-2-3. Maddelerin de i tirilemez ve teklif dahi edilemez" der. Hem anayasa de i ikli inde onay a amasına CB'nın eklenmesine ili kin h  k  m hem de t  revsel kurucu iktidara y  nelik maddi sınırların i letilmesi danı ma meclisinde kabul edilen metinde yer almıyor. Bu de i iklikler, anayasa metninin kabul edip Milli G  venlik Konseyine sunduktan sonra Milli G  venlik Konseyi tarafından yapılmı  olan tek taraflı de i ikliklerle anayasaya eklendi.

G  n  m  zdeki durum: Anayasanın 175. Maddesi anayasanın nasıl de i tirilece ini belirtiyor. Yani t  revsel kurucu iktidarı d  zenliyor. Bu 175.madde 1987 yılında yapılan anayasa de i ikli ini de i tiriyor. Daha   nceki 175.maddenin ilk bi iminden bazı bakımlardan farklı bir yolun oldu unu g  r  yoruz. Anayasa de i ikli inde 4 a ama vardır. Anayasa de i ikli ine ili kin teklif a aması, bu teklifin g  r   lme a aması, bunun kabul a aması ve onay a aması olmak   zere 4 a amadan olu uyor, t  revsel kurucu iktidarın bu yetkiyi kullanması. Teklif a amasına baktı ımız zaman; 1924 anayasasından beri var olan teklife ili kin ko ulun aynı   ekilde devam etti ini g  r  yoruz. Yani anayasa de i ikli i teklifi, TBMM   ye tam sayısının en az 1/3'  n  n yazılı ve gerek eli bir   nergisiyle yapılabilir. Burada aynı anayasa de i ikli i i in imza koyan milletvekilleri, bu teklife farklı gerek elerle katılabilir. Aynı gerek eye sahip olması gerekmez. Ama aynı de i iklik teklifine imza atmaları gerekir. De i iklik teklif metni aynı olacak ama bu metne milletvekilleri farklı gerek elerle imza atmı  olabilirler. En az 1/3 tutarındaki sayı olan 200 milletvekilinin kar ılanması i in aynı teklife imza atmı  olması i in yeterlidir. Teklifin konusu denilince anayasadaki maddi sınırlar burada kar ıımıza  ıkıyor. Teklifin

konusu anayasanın değiştirilmesini yasaklayan maddelerini içerecek bir konu olmamalı. Yani anayasanın ilk 3 maddesinde herhangi bir değişiklik içermemeli. Bu maddeleri oku. Bu maddeler hakkında değişiklik teklifi verilemez ve bu maddeler de herhangi bir şekilde de değiştirilemez.

1982 Anayasasının türev kurucu iktidara yönelik olarak öngördüğü maddi katılığı oluşturuyor. Bu yasağa karşı anayasanın ilk 3 maddesinde değişiklik öneren teklifin durumu ne olacak? Anayasada açıkça farklı bir düzenleme yok ise olağan yasalar için öngörülen kurallara bağlı. Anayasa değişikliğine ilişkin teklif Meclis Başkanlığı'na veriliyor. Bu değişiklik teklifi ilk 3 madde de değişiklik öngörüyorsa o zaman Meclis Başkanının bunu işleme koymaması gerekir. Bu değişiklik teklifini teklif sahiplerine geri vermesi gerekir. Eğer Meclis Başkanlığı bu değişiklik teklifini iade etmemişse o zaman TBMM genel kurulunun bu teklifi reddetmesi gerekir. Genel Kurulda bunu kabul etmiş ise o zaman CB'nın ilk 3 madde de değişiklik yapması nedeniyle, anayasanın 4.maddesine aykırı bir anayasa değişikliği olması nedeniyle söz konusu anayasa değişikliğini onaylamaması gerekir. Eğer CB da onaylamışsa artık bu anayasa değişikliği teklifinin 1982 anayasasına göre hukuken etkisiz hale getirmemiz mümkün değil. 1982 Anayasası buna ilişkin herhangi bir yaptırım öngörmemiştir. Böyle bir yaptırım 24 ve 61 anayasalarında da yoktu. Ama 1961 anayasası döneminde AYM, bu türev kurucu iktidarın anayasanın kendisine koyduğu maddi sınırları aşıp aşmadığını denetliyordu. 1982 Anayasası ise böyle bir denetimi öngörmediği gibi tam tersine AYM'nin anayasa değişikliklerini yalnızca biçim yönünden denetleyebileceğini bu denetimin de sınırlı bir denetim olacağını 148.maddesinde öngörüyor. Bir görüş, bu tür maddi sınıra ilişkin yasaklar yalnızca siyasal bir temenni niteliğindedir. Ergun Özbudun ise parlamentonun bu yasaklara parlamentonun uyması gerekir ama uymazsa da parlamentoya yönelik herhangi bir hukuki yaptırım yoktur. Bu nedenle de geleceğin kurucu iktidarı bakımından da hukuki bağlayıcılığı yoktur. Gerekçesi ise "Tarihin belli bir anında yapılmış olan bir anayasa yani asli kurucu iktidar geleceğin kurucu iktidarını hukuki bakımdan bağlamamalıdır. Bu parlamentoya yönelik ahlaki bir düzenlemedir. Bunun ötesinde hukuki bir değeri yoktur. Çünkü hukuken parlamentoyu bağlamaz. Bu görüşü savunanlar; türevsel kurucu iktidara yönelik maddi katılık, maddi sınırların bir bölümü devletin, hükümetin şekline ilişkin değişmez hükümler içeriyor. Bir bölümü ise temel hak ve özgürlüklere ilişkin yasaklar içeriyor. Bir toplum gereksinimlere göre devlet, hükümet şeklini değiştirebilir. Örneğin, devletin federal niteliğinin değiştirilmesini yasakladıysa bir anayasa zamanla üniter devlete dönebilir. Buna karşılık temel hak ve özgürlüklere ilişkin kazanımların geriletilmesi ya da ortadan kaldırılması benzer bir sonuç doğurmaz.

Anayasanın öngördüğü maddi sınırların içeriğine bakmak lazım. Eğer bu maddi sınırların içeriği devletin, hükümetin biçimine ilişkin ise bu yasağı mutlak bir yasak olarak okumamak lazım. Ama temel hak ve özgürlüklere ilişkin ise o zaman bu temel hak ve özgürlükleri geriletecek veya ortadan kaldıracak anayasa değişikliklerinin yapılmaması gerekir diyor. Karşı görüşte olan Kemal Gözler "anayasada bir değişmez madde var ise bu kural mutlaklıktır. Bazı değişmez hükümler değiştirilebilir, bazıları değiştirilmez diye bir yorum yapmamak gerekir. Anayasanın 4.maddesi değiştirilmediği sürece anayasanın ilk 3 maddesinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Gözler'e göre 1982 anayasasının 4.maddesinin değiştirilmesini yasaklamadığı için bu madde değiştirilebilir. O zaman ilk 3 madde de değiştirilebilir. 1982 anayasasında yer alan ilk 3 maddedeki değişmezlik yasağını aslında sözel olarak değil içeriği ile ilgili bir yasak olarak değerlendirmek gerekir. Yasakları özgürlük, hak odaklı olarak tutmalıyız. Yasakları olabildiği kadar dar olarak yorumlamalıyız. Bu ilk üç maddedeki ilkeleri ortadan kaldırmak mümkün değil. Buna karşılık ilk 3 madde içinde içeriği somutlaştıran bu maddelerde yer alan nitelikleri ortadan kaldırmayan zayıflatmayan değişikliklerin yapılabileceğini kabul etmemiz gerekir. Örneğin 2.maddede yer alan demokratik devletin yerine çoğulcu ya da özgürlükçü koymak. Ama bu 2.maddenin içeriğini değiştirmez. İlk 3 maddedeki ilkeleri zayıflatmayan, anlamsızlaştırmayan değişikliklerin ilk 3 maddeye ilişkin olarak ileri sürüyor hocamız.

Ya da 3.maddeyi devletin resmi dili Türkçe'dir şeklinde değiştirmek. Kişilerin dili devletin resmi dili olur. İkinci maddede yer alan devletin niteliklerine yeni nitelik eklenebilir. Devletin var olan niteliklerini zayıflatmıyorsa anlamsızlaştırmıyorsa yeni koşullara göre eklenebilir. Örneğin çevreye saygılı ya ada çevreci devlet gibi devlete yeni bir nitelik yüklemenin bunu da anayasanın 4.maddesindeki değişmezlik yasağı kapsamına almanın bence anayasaya aykırılığı olmayacaktır. Buradaki yorumumuz pozitivist bir yorum değil burada amaçlı bir yorum yani mevcut ilkeleri düzenlemeleri ortadan kaldırmayacak, zayıflatmayacak güçlendirecek somutlaştıracak değişikliklerin yapılabilmesidir. 2.Madde de belirtilen cümleye göre başlangıcında değişmezlik kapsamı içinde olması gerekir. Buna karşılık anayasanın başlangıç bölümü hem 1995 hem de 2001 de yapılan anayasa değişiklikleriyle 2 kere değiştirildi. Temel hak ve özgürlükler yönünde

değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler olumlu anlamda hak ve özgürlük odaklı değişiklik oldu. İkinci olarak aklımıza şu soru gelebilir; değişmez maddelere ilişkin olarak ilk 3 madde de hiç değişiklik yapılmaz. Ama anayasanın başka maddelerinde bu 3 maddedeki ilkelerin etkisini zayıflatan ya da ortadan kaldıran bir değişiklik yapıp yapılamayacağı. Yani 4.maddedeki değişmezlik kuralı yalnızca ilk 3 maddeye mi ilişkin yoksa bu ilk 3 maddeyi açıklayan anayasanın diğer hükümlerine ilişkin bir yasak mı? AYM bu konuda bu alanı daraltıcı bir yorum yapıyor. 2 Kararı var 2008/16 E. 2008/116 K. Ve 2010/49 E. 2010/87 K. Birincisi diyor ki; anayasanın 4.maddesinde ilk 3 maddedeki değişmezlik yasağını güvence altına alması bakımından değişmezlik kuralı altındadır. Yani TBMM anayasanın 4.maddesini değiştiremez diyor. İkinci olarak bu iki kararında AYM diyor ki; ilk 3 madde de değişiklik öngören ya da diğer maddelerde yapılan değişikliklerle doğrudan ya da dolaylı olarak aynı sonucu doğuran yasama tasarrufu teklif koşulu sayısal yönden anayasaya uygun olsa bile geçersiz olur. Eğer yapılan anayasa değişikliği ilk 3 maddenin dışında anayasa maddesinde yapılan bir anayasa değişikliği ilk 3 maddede güvence altına alınan değiştirilmesi yasaklanan bir ilkeyi anlamsız hale getiriyorsa ya da dolaylı olarak ortadan kaldırıyorsa o zaman onu anayasaya uygunluğunu denetlemeli.

Anayasa değişikliği tekliflerinin TBMM’de nasıl görüşülüyor: Anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağı 1982 anayasasının 175.maddesinde düzenlendi. 175/2 ye göre ayrıkçı durumlar ve sınırlamalar dışında anayasa değişikliği yasaları diğer yasaların görüşülmesi ve kabulüne ilişkin kurallara bağlıdır. Diğer yasalardan farklı olarak; **1. Teklif çoğunluğu farklı.** Yasa teklifleri bir milletvekili tarafından bile verilebilir. Ama anayasa değişikliğine ilişkin yasa teklifleri ancak TBMM üye tam sayısının 1/3’ünün vereceği yazılı önergesiyle verilebiliyor.

2. Anayasa 2 defa görüşme kuralı getiriyor, 175.madde.

3. Kabul çoğunluğuna ilişkin. İstisnalar dışında kural olarak yani herhangi bir yasa TBMM’inde basit çoğunlukla kabul edilebilir. Bu basit çoğunluk anayasada öngörülen TBMM görüşmeleri bakımından asgari toplantı ve karar yeter sayısının sağlanmış olma koşulu. İstisnalar dışında yani anayasa, af kanunlarını üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul edilmesini öngörüyor. Kural basit çoğunlukla yasaların genel kurulda kabul edilmesi biçiminde. Kabul çoğunluğu bakımından da 175.madde anayasa değişikliği kanunları için ayrıkçı bir durum getiriyor. En az üye tam sayısının **3/5 çoğunluğu** ile kabul edilme koşulunu getirdiği için. **İki kez görüşme** usulü öngörülmüş. Bu 175.madde de açık olarak yazılıdır. İç tüzüğün 93.maddesi de anayasa değişikliği yasalarının TBMM’inde nasıl görüşüleceğini belirtiyor. Anayasa değişiklik teklifleri diğer kanun tekliflerinin görüşülmesindeki usule bağlıdır. Bu teklif Meclis Başkanlığına veriliyor. Teklif sayısı karşılandıktan sonra meclis başkanlığı ilgili komisyona havale ediyor. Anayasa değişiklik tekliflerinin görüşüleceği komisyon anayasa komisyonudur. Bu komisyon havale ediliyor. Tıpkı diğer yaslarda olduğu gibi burada bu teklif görüşülüyor. Bütün görüşmeler anayasa komisyonunda bittikten sonra teklife ilişkin raporunu hazırlıyor komisyon. Eğer komisyon aşamasında bir değişiklik oldu ise o değişiklikleri de rapora ekliyor. Bu teklife ilişkin komisyonda itirazlar var ise o itirazlara ilişkin karşı oylarda bu anayasa komisyonunun hazırladığı metne işleniyor. Bu metin diğer kanunlarda olduğu gibi meclis başkanlığına gidiyor. Meclis Başkanlığı iç tüzüğün 52.maddesine göre kabul edilmiş bir yasa teklifinin TBMM’nin genel kuruluna gündemine alınabilmesi için bu anayasa komisyonunun hazırladığı raporun bastırılıp TBMM üyelerinin tümüne dağıtımından itibaren 48 saat sonra herhangi bir gün genel kurul gündemine alınıyor. Kural 48 saat geçmedikçe bu teklifin genel kurul gündemine alınmaması. Diğer yasalarda olduğu gibi söz konusu bu süre dolmadan teklifin genel kurul gündemine alınması ve diğer işlerden önce görüşülmesi de mümkün. Aynı olanak anayasa değişikliği teklifleri için de geçerli. Genel kurulda basit çoğunlukla alınacak bir kararla 48 saat sürenin beklenilmemesi mümkündür. Neden 48 saat? Genel kurulda bulunacak olan bütün üyeler, önlerine gelen anayasa değişiklik teklifini inceleyebilsinler, buna ilişkin bilgilenebilsinler bu konuda belli bir kanaat oluşturabilsinler. Bu süre sonunda teklif genel kurula geliyor ve görüşmeler başlıyor. İki defa genel kurulda görüşülmesi gerekiyor. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifi dışındaki diğer kanunlar, genel kurulda bir kez görüşülmekle kabul veya reddediliyor. Ama anayasa değişikliği teklifleri için 2 kere görüşme koşulunu arıyor anayasanın 175.maddesi.

Bu kural 1961 anayasasında da geçerliydi. Bunun amacı, anayasa değişikliklerini aceleyle getirmemek, milletvekillerine hem de kamuoyuna bu konu hakkında görüşlerini olgunlaştıracak zaman tanımak. Birinci görüşmede herkes görüşlerini dile getirecek ondan sonra 48 saat süre geçecek (bu 48 saati kısaltmak mümkün

değil) daha sonra ikinci görüşmeler yapılacak bu arada 1. ve 2. görüşme arasında hem milletvekillerinin konuya ilişkin kanaatlerini olgunlaştırması, değiştirmesi ya da değiştirmemesi ve kamuoyunun bu konu hakkındaki görüşlerini pekiştirebilmesi için zaman tanıma. Çünkü anayasa değişikliği çok önemli bir iş. Dolayısıyla da aceleye getirilmemesi gerekir. Birinci görüşmede önce teklifin tümü üzerinde bir görüşme açılıyor. Tıpkı diğer yasalarda olduğu gibi. Bu görüşmelerde, siyasal parti grupları adına bir milletvekili, anayasa komisyonu adına bir kişi, bunun dışında da 2 milletvekili kendi görüşlerini kanunun tümü için bildiriyor ve oylamaya geçiliyor. Oylamadan sonra maddelerin görüşülmesine geçiliyor. Her bir madde için ayrı ayrı görüşme açılıyor. Siyasal parti grupları adına 1 milletvekili, komisyondan bir sözcü ve yine 2 milletvekili her bir madde için ayrı ayrı görüşünü bildiriyor. Birinci görüşmeler sırasında her bir madde için hangi madde görüşülüyor ise o maddeye ilişkin değişiklik önermeleri de birinci görüşmede verilir. Birinci görüşme bittikten sonra herhangi bir madde için değişiklik önermesi verilemez. Bu değişiklik önermeleri ilgili madde 1.görüşme aşamasında görüşülüyor iken verilmeli. Daha sonra her bir madde için görüşmeler yapıp her görüşmeden sonra her bir madde için oylama ayrı ayrı yapıldıktan sonra birinci görüşme aşaması bitiyor. Araya bir 48 saat giriyor. 48 Saatten önce 2.görüşe yapılamıyor. Bu en az 48 saat, bu 48 saati aşabilir içtüzüğün 93.madde hem de 175.maddesi uyarınca bu bir kural. Daha sonra 2.görüşme başlıyor. İkinci görüşmede, birinci görüşmede görüşülmüş olan maddeler yeniden görüşülüyor. Yalnızca birinci görüşmede değişiklik önermesi verilmiş ise bir maddede, bu değişiklik önermeleri görüşülüyor. İkinci görüşme, yeniden her bir maddenin oylanması arkasından da teklifin bütünü oylanmasının ardından sona eriyor. İki görüşme yapılması demek aynı maddelerin 2 kez görüşülmesi anlamına gelmiyor. İkinci görüşme ilk görüşmede değişiklik teklifi verilmiş olan maddelerde yalnızca değişiklik tekliflerinin görüşülmesi anlamına geliyor. Anayasa değişiklik teklifi, diğer yasalardan farklı olarak anayasanın 175.maddesi uyarınca değişiklik teklifleri gizli oyla yapılıyor. Bunun amacı milletvekillerinin anayasa değişikliği gibi önemli bir konuda hem kendi partilerinden hem dışarıdan gelecek baskılara milletvekillerini bu tür baskılardan koruyarak vicdanları doğrultusunda oy vermelerini sağlamak.

Gizli oy, her milletvekilinin eline farklı renkte 3 tane oy pusulası veriliyordu. Milletvekili, ne yönde oy kullanacaksa o oy pusulasını atıyordu. Beyaz, kırmızı, yeşil renkte. Dışarıdan içerisi gözükmeyecek şekilde oluşturulan o kapalı oy verme yerlerine konan oy pusulasının içine bu istediği rengi atıyordu. Anayasa değişiklik teklifleri 1924-61 anayasalarında TBMM üye tam sayısının 2/3'ünün kabulü ile yasallaşıyordu. 1982 Anayasasının ilk biçimi içinde aynı şey geçerliydi. Ama 1987'den buyana güncel 175.maddenin son hali uyarınca en az üye tam sayısının 3/5 oyu ile bir anayasa değişikliği teklifi kabul ediliyor. Anayasa değişikliği teklifi sırasında 4 defa o anayasa değişikliğine ilişkin genel kurulda oylama yapılıyor. İlk 2 oylama birinci görüşmede son 2 oylama ikinci görüşmede yapılıyor. Birinci oylama birinci görüşmede teklifin bütünü üzerinde görüşmeler bittikten sonra teklifin tümünden maddelerin tümüne geçilmesine ilişkin oylama, ikinci oylama birinci görüşmede her bir maddenin görüşülmesinden sonra her bir madde için ayrı ayrı oylama. Üçüncü oylama, ikinci görüşmede her bir madde için ayrı ayrı yapılan oylama ve dördüncü oylamada yine ikinci görüşmede maddeler için yapılmış olan oylamadan sonra değişiklik teklif metninin bütünü için yapılan oylama. Anayasanın 175.maddesini okuyunca ya da 94.maddenin 1.fikrasını okuyunca kabul için 3/5 çoğunluk gerektiğini söylüyor. Dört oylama yapıldıysa o zaman her bir oylama için ayrı ayrı bu nitelikli çoğunluğun aranması gerekir. Ama uygulama bu yönde değil. Bunun böyle olmamasının nedeni iç tüzük hükmü. Diğer bir nedeni de AYM'nin bu içtüzük hükmünü yorumlaması. Birinci oylama, AYM'nin 2007'de anayasaya aykırı bulmadığı karara göre birinci oylama basit çoğunlukla yapılıyor, nitelikli bir çoğunluk aranmıyor. 3/5 oy çokluğu aranmıyor. Basit çoğunlukla yetiniyor. 94.Maddenin 2.fikrasına göre "birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde, ikinci görüşmede de gerekli kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur" diyor içtüzüğün 94/2 fıkrası. İchtüzüğün bu düzenlemesi AYM'nin önüne gidiyor, anayasaya aykırılık iddiasıyla. Künye 2007/72 E. ve 2007/68 K. Mahkeme "Anayasa'da değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin herhangi bir sınırlama ya da kayıt yoktur." Anayasanın tümünden maddelere geçiş için yapılan birinci oylamanın basit çoğunlukla yapılması ve basit çoğunluk ile maddelerine geçilmesine kabul oyu verilmesi tıpkı diğer kanunlarda olduğu gibi. AYM diyor ki "böyle bir uygulama anayasaya aykırı değil çünkü anayasanın kendisi metnin tümünden maddelerine geçiş için oylamada özellikle herhangi bir özel çoğunluk aramamış. Dolayısıyla bunun basit çoğunluk ile yapılması anayasaya aykırı değildir" diyor. Getirdiği bir başka gerekçe de "anayasanın 175/1.fikrasında iki defa görüşme kuralı getirilmiş anayasa değişiklikleri için. İki defa görüşme kuralı demek 2 defa oylama kuralı demek. 175.madde de böyle iki defa görüşme ve iki defa oylama kuralı getirmiş. Eğer birinci oylama da yani metnin tümünden maddelerine geçiş sırasında yapılan oylamada

da nitelikli çoğunluk aranırsa o zaman anayasanın öngördüğü iki defa görüşme iki defa oylama kuralı etkisiz kalabilir. İkinci gerekçe olarak da teklife birinci görüşmede gerekli desteği vermeyen milletvekillerinin görüşmeler sırasındaki tartışma sürecinde görüşü değişebilir. İlk başta bu değişiklik teklifine olumsuz bakan bu milletvekilleri görüşme sırasında bu değişiklik teklifini olumlu görebilir. Bu da sonuçta basit çoğunlukla maddelere geçilmesi milletvekillerinin bu konu hakkındaki görüşlerini değiştirmelerini sağlayacak bir olanak tanır” diyor. AYM’nin bu gerekçesi aynı şekilde birinci görüşmede yapılan ikinci oylamada da geçerli. İkinci oylama, birinci görüşmede her bir madde için ayrı ayrı yapılan oylama idi. AYM, bu ikinci oylamada da anayasa değişiklik teklifinin kabulü için öngörülen nitelikli çoğunluğu aramıyor. Burada da basit çoğunluğu anayasa değişikliği teklifi bakımından yeterli buluyor. İçtüzüğün 94/2 fıkrasında “ilk oylamada da yeterli çoğunluğu alamayan bir anayasa değişiklik teklifi ikinci görüşmede de yeterli çoğunluğu alamamışsa o zaman kabul edilmemiş sayılır” diyor. Bu çerçevede ilk görüşmede yapılan iki oylama bakımından da AYM kararı uyarınca, nitelikli çoğunluk aranmaz. Aslında bu AYM’nin 2007’deki görüşü yeni bir görüş değil. 1961 Anayasası döneminde 1970’de verdiği bir karar vardı. Bu kararda, genel kurulda anayasa değişikliği teklifi için yapılan bütün oylamalarda 61 anayasasındaki en az 2/3 çoğunluğun aranması gerektiğini belirtmişti. Ama 5 yıl sonra bu görüşünü değiştirdi. 1975 Tarihinde verdiği bir kararda AYM dedi ki “ilk iki oylamada nitelikli çoğunluğa gerek yok. Sonuç alıcı olan oylama ikinci görüşmede yapılan son iki oylama. Dolayısıyla nitelikli çoğunluk da bu oylamada aranır” dedi. 2007 Kararı, 1975 yılında vermiş olduğu kararın bir devamı niteliğinde. Oylamanın tümünün anayasa değişiklik sürecinin bütününe oluşturduğunu göz önünde bulunduracak olursak eğer kabul aşamasını birinci ve ikinci görüşmelerde yapılan 4 ayrı oylamanın bir bütünü olduğu sonucu olduğunu bulunduracak olursak AYM’nin bu yaklaşımının tartışmalı olduğu sonucuna varabiliriz. Çünkü anayasa değişikliği teklifinin kabulü bir bütün oluşturuyor. Bunu birbirinden parçalamak mümkün değil. Anayasa kabul için nitelikli bir çoğunluk arıyor. Haliyle bu nitelikli çoğunluğun anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında yapılan bütün oylamalar bakımından aranması gerekir. Bunu eleştirmemin sebebi; nitelikli çoğunluk yani en az 3/5 çoğunluk katı bir anayasanın gereği. Katı anayasa dediğimizde kabul ve görüşme usulleri diğer yasalardan farklı ve daha zor kurallara bağlanmış bir anayasa değişikliği arıyordu. Hal böyle olunca bunu kolaylaştırmak değil ama katı bir anayasanın bir gereği olarak yapılan bütün oylamalarda anayasanın öngördüğü karar çoğunluğunu aramak gerekir. Olan yalnızca ikinci görüşmede yapılan oylamalarda nitelikli çoğunluğun aranması. AYM bu yorumu ile, anayasa değişikliklerinin kabul sürecinin bölünebilir olduğu sonucun varıyor dolaylı olarak. 2. Olağan kanunlarda olmayan bir işlev yüklüyor sürece. Olağan kanunlarda, kanunun ikinci kez görüşülmesi söz konusu değil. Olağan kanun tekliflerinde milletvekillerine kanuna ilişkin olumlu ya da olumsuz düşüncelerini değiştirmelerini sağlayacak ikinci bir olanak tanınmıyor. Anayasa değişikliğinde ise AYM’nin bu yorumu ile böyle bir olanak tanınmıyor. Bu da katı anayasa anlayışına aykırı bir yorum. Olağan yasalarda bile olmayan bir olanağı anayasa değişikliği gibi çok daha önemli bir konuda milletvekillerine tanınması gibi bir sonuç çıkarıyor. Anayasanın 175.maddesine göre, TBMM anayasa değişikliğine ilişkin yasa teklifini kabul ederken aynı zamanda bu yasanın halk oylamasına sunulması durumunda hangi hükümlerin birlikte hangi hükümlerin ayrı ayrı halk oylamasına sunulacağını da karar verir. Bu zamana kadar halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği tekliflerinin tümü bakımından TBMM hem iş bu kanun halk oylamasına sunulduğu taktirde kanun bütün olarak oylanacaktır biçiminde hüküm koydu. Kanun metninin içini hiç bölmedi. Ama anayasanın TBMM’ne böyle bir yetki vermesinin nedeni aslında birbiriyle ilişkili olan maddelerin CB tarafından ya da başka bir biçimde birbirinden ayrılarak oylanmasını engellemek, böylelikle anayasa değişikliğinin bütünlüğünü sağlamak. Yani birbiriyle ilgili olan maddeler ayrı ayrı oylanırsa ve bu oylamanın sonucunda bir madde ret alırsa ya da kabul oyu alamazsa diğer madde kabul oyu alırsa bu sefer anayasa metni içinde bütünlük zarar görebilir. Bunu engellemek amacıyla 175/7 fıkrasına böyle bir düzenleme kondu. Bu zamana kadar hiçbir zaman ayrı ayrı oylansın demedi. Kabul aşamasından sonraki aşama onay aşaması. Onay aşaması, bu zamana kadar ki bütün Osmanlı- Türk anayasaları içinde 1982 anayasası ile getirilmiş bir aşama.

Onay aşaması CB ile halk arasında paylaştırılmış. Bu hem 1982 anayasasının ilk biçiminde böyleydi. Hem de 1987 ile getirilen anayasa değişikliğinden sonra yeniden yazılan 175.madde bakımından da geçerli. 175. Madde kabul bakımından 2 tane nitelikli çoğunluk arandığını görüyoruz. Biri üye tam sayısının 3/5’i diğeri üye tam sayısının 2/3’ü. Bu iki farklı nitelikli çoğunluk aslında onay aşamasının nasıl yapılacağına ilişkin bize yol gösteriyor. Öncelikle birinci senaryo da eğer TBM anayasa değişikliği yasası üye tam sayısının en az 3/5’i ile kabul etmişse ama kabul çoğunluğu 2/3’e varmamışsa CB’nın önünde 2 seçenek vardır. Ya bu yasayı

yeniden görüşmek üzere TBMM'ye geri gönderir. Ya halk oylamasına sunar. Eğer TBMM anayasa değişikliği yasası, en az üye tam sayısının 2/3'si ile veya daha büyük bir çoğunluk ile kabul etmişse o **zaman CB'nin önünde üç seçenek var; 1.** Söz konusu yasayı yeniden görüşmek üzere TBMM'ne yollar. **2.** Söz konusu yasayı onaylayarak resmi gazetede yayınlattır. Değişiklik yürürlüğe girer. **3.** Söz konusu yasayı halk oylamasına sunar.

Diyelim ki CB, söz konusu yasayı TBMM'ne geri gönderdi. TBMM bu yasayı aynen en az 3/5 çoğunluk ile kabul ederse ancak kabul çoğunluğu 2/3'yi bulamamışsa o zaman CB, bu yasayı halk oylamasına sunmak zorundadır. Burada taktir yetkisi yoktur CB'nin. Eğer TBMM tarafından yeniden görüşülen ve aynen kabul edilen yasa, üye tam sayısının en az 2/3'si tarafından kabul edilmişse CB'nin önünde iki seçenek var. Söz konusu anayasa değişikliği kanunun resmi gazetede yayınlattırarak yürürlüğe sokmak. İkincisi söz konusu anayasa değişikliği kanununu halk oylamasına sunmak. Gördüğünüz gibi 2/3 ya da daha büyük bir çoğunlukla kabul edilen anayasa değişikliklerinde, CB'nin bu değişikliği halk oylamasına sunma yetkisi taktiri bir yetki. Buna karşılık 2/3 den daha düşük bir oranla ama 3/5 den az olmamak kaydıyla kabul edilen bir anayasa değişikliği teklifinde CB'nin söz konusu yasayı halk oylamasına sunmaktan başka bir yolu yok. Burada halk oylamasına yasanın sunulması CB'nin taktirinde olacak bir durum değil. TBMM hangi yeter sayı ile anayasa değişiklik yasasını kabul ettiğini hangi aşamada yapılan oylamaya bağlı olduğu. Dört oylama var dedik. İlk 2 oylama sayılmıyor. Ondan sonra ikinci görüşmede her bir madde için ayrı ayrı oylama yapılıyor. Ondan sonra da metnin bütünü için oylama yapılıyor. Uygulama da metnin bütünü için yapılan oylama söz konusu kanunun halk oylamasına zorunlu ya da CB'nin taktirine bağlı olarak sunulup sunulmayacağını belirliyor. Diyelim ki 1.madde üye tam sayısının 2/3'sinin oyunu almış. Ama teklifin tümü üye tam sayısının 3/5'nün oyunu almış bu durumda bütün maddeler ister 2/3 alsın ister TBMM üyelerinin tümü o madde için olumlu oy kullanmış olsun zorunlu olarak halk oylamasına gidiyor. Buna karşılık metnin tümü için en az 2/3 kabul oyu çıktı ise diyelim ki 1.madde üye tam sayısının 3/5 ile kabul edilmiş bile olsa o kanunun tümü CB'nin taktirine bağlı olarak halk oylamasına gidiyor.

Sonuç; *kabul aşamasındaki son oylama, anayasa değişikliği yasasının nasıl onaylanacağını bize gösteriyor.* Bu eleştiriye açık bir konu. Çünkü 3. Ve 4. Oylama çoğunlukları farklı olurlarsa 3.oylamanın da göz önünde bulundurulması gerekir. Aksi taktirde bu oylamalar niye yapılıyor sorusu aklımıza geliyor. Üstelik 3 ve 4. Oylamaların arasında fark olması milletvekillerin metnin bütünü ile her bir madde bakımından farklı farklı düşündüğünü bize gösteriyor. Haliyle milletvekillerinin iradesinin bölünmesine olanak tanıyor. Oysaki son oylamayı biz kendimize esas alırsak o zaman diğer 3. Oylamanın hiçbir anlamı kalmıyor. Bir milletvekilinin 1.maddeyi beğenip 2.maddeyi beğenmemesinin de yine hiçbir anlamı kalmıyor.

Son aşama halk oylaması aşaması: Bazı durumlarda zorunlu bazı durumlarda CB'nin taktirine bağlı bir halk oylaması süreci vardır. *Halk oylamasının anlamı, TBMM'nde kabul edilmekle birlikte yasalaşmış anayasa değişikliğinin yürürlüğe girip girmeyeceğine ilişkin olarak yapılan bir oylamadır.* Bir yasa teklifi TBMM genel kurulunda kabul edilmekle birlikte yasalaşır. Halk oylaması, TBMM'de kabul edilmiş olan anayasa değişikliği hakkındaki yasanın yürürlüğe girip girmemesine ilişkin bir oylamadır. Anayasaya göre bir anayasa değişikliği yasasının yürürlüğe girmesi için geçerli oyların çoğunluğunun kabul olması yeterlidir. Bazı anayasalar bu anayasa değişikliklerinin meşruluğunu güvenceye almak için kayıtlı seçmenlerin belli bir oranının mutlaka sandık başına gitmesini yine kayıtlı seçmenlerin belli bir yüzdesinin bu değişikliğe kabul oyu vermesini şart koşturmak. Bizde böyle bir şey yok. Bunun nedenini şuna bağlamak mümkün, 1946 seçimlerinden buyana seçimlere katılım oranı genellikle yüksektir. Bu deneyime güvenerek böyle bir alt sınır koyma ihtiyacı duymamış. Halk oylamaları, genel ve yerel seçimlerde olduğu gibi halk oylamaları da 76.maddeye göre YSK'nun gözetimi ve denetiminde yapılıyor. Tek yetkili merci YSK'dur. Halk oylamalarına ilişkin usul ve kuralları 1987'de kabul edilen bu anayasa değişikliği ile birlikte kabul edilen 3376 sayılı anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulması hakkındaki kanunla, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun. Bu 2 kanunun hükümleri uyarınca bu halk oylamaları yapılıyor. Bu halk oylamasının yapılmasına ilişkin kanuna göre eğer CB anayasa değişikliği yasasını halk oyuna sunacaksa isteğine bağlı veya zorunlu olarak ilgili kanunun halk oylamasına sunulmasına ilişkin kararını resmi gazetede yayınlattırıyor. Anayasa değişikliğinin halk oylamasına ilişkin kararın resmi gazetede yayımlandıktan sonra bunu izleyen 60.günden sonraki ilk Pazar gününde söz konusu yasaya ilişkin halk oylaması yapılır. Eğer geçerli oyların çoğunluğunu alırsa yasa o zaman yürürlüğe girmiş oluyor ilgili anayasa değişikliği. Reddedilirse anayasa değişikliği yürürlüğe girmiyor. Bugüne kadar 5 defa anayasa değişikliği yasalarının halk oylamasına

sunulduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 1987’de. 12 Eylül 1980 den önce siyasal partilerde aktif olarak görev alan o dönemki siyasal parti yönetiminde yer alan siyasilere 5 yıllık ve 10 yıllık yasaklar getiren bu 4.maddenin kaldırılmasına ilişkin bir halk oylamasıydı. Bu yasa %50.1 ile kabul edildi. İkincisi 1 yıl sonra yapıldı. Genel ve yerel seçimler anayasanın ilk biçimine göre 5 yılda bir yapıyordu. O dönem Turgut Özal, yerel seçimleri 5 yıldan bir yıl önceye almak istedi. Böyle bir anayasa değişikliği yaptı ama bu anayasa değişikliği %65 ile reddedildi. 2007 Yılında CB’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi ve birkaç anayasa maddesinde yapılan değişiklikler. %67.5 ile kabul edildi. 2010 Anayasa değişiklikleri, anayasanın çeşitli maddelerinde değişiklik yapıyordu ama bu anayasa değişikliklerine damga vuran yargıya ilişkin değişiklikler. AYM’nin yapısını kökten değiştirdi. O zaman ki adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı kökten değişti. %69 gibi oyla kabul edildi. 2017 Anayasa değişiklikleri, hükümet sisteminde yapılan köklü değişikliklerdi. Bu değişikliklerde %51 oran ile kabul edildi.

1982 Anayasasından önce onay aşaması yoktu. CB’nın görevi sadece resmi gazetede yayınlamaktır. Klasik parlamenter sistemde CB’nın simgesel, törensel yetkileri vardı. 1982 Anayasasının ilk biçiminde CB’nına klasik parlamenter sistemin ötesinde geniş yetkiler tanındığı için Kenan Evren’den sonra gelen, TBMM tarafından seçilen CB’ları eski büyük parti liderleri olduğu için garip bir durum başladı. Sadece resmi gazetede yayınlamamak değil ama beğenmedikleri Bakanlar Kurulu Kararnamelerini imzalamamak gibi CB’nın davranışı başladı. CB’nın söz konusu işlemi hukuken tamamlamaktan ibaret bir yetki olmalıydı. Ama CB’ları bu yetkilerini kötüye kullandılar.

TEKLİF: AYM Kararı E. 2008/16, K. 2008/116; E. 2010/49, K. 2010/87

“İlk üç maddede değişiklik öngören ya da diğer maddelerde yapılan değişikliklerle doğrudan ya da dolaylı olarak aynı sonucu doğuran bir yasama tasarrufu, teklif koşulu sayısal yönden Anayasaya uygun olsa bile geçersiz olur”

GÖRÜŞME: İçtüzük Madde 93: Anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülür. İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırksekiz saat geçmeden başlanamaz. İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önermeleri görüşülür, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemez.”

KABUL: Anayasa değişiklik tekliflerinin kabulü İçtüzük madde 94: Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür. Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur. Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama usulü suretiyle tekrarlanır.”

Madde 175/7: TBMM, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar”.

ONAY: Madde 175/3-4,5 ve 6

Hazırlayan: Cengiz YILDIRIM

